



República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

Magistrado ponente

SL2600-2025

Radicación n.º 11001-31-05-003-2019-00231-01

ACTA 44

Bogotá D. C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por **CLAUDIO MAURICIO PEÑA HOYOS**, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el cinco (5) de marzo de dos mil veinte (2020), en el proceso ordinario laboral que promovió contra la sociedad **PROCESOS Y CANJE SA.**

I. ANTECEDENTES

El hoy recurrente demandó a la sociedad Procesos y Canje S. A., con el propósito de que se declarara que se encontraba amparado por el fuero de prepensionado al momento de su despido y, en consecuencia, la demandada fuera condenada a reintegrarlo al cargo que venía desempeñando, así como a pagarle los salarios dejados de

percibir desde la fecha de su despido hasta cuando se hiciera efectivo el reintegro, más las costas del proceso.

En sustento de sus pretensiones adujo que ingresó a laborar a la empresa demandada el 2 de mayo de 2006; que el contrato de trabajo que lo vinculó con aquella fue a término indefinido; que fue despedido el 30 de junio de 2017 sin justa causa; que fue afiliado a Colpensiones para el riesgo de vejez; que para la fecha del despido tenía 59 años y medio, por lo que le faltaban menos de tres años para cumplir la edad pensional; que es beneficiario del fuero de prepensionado; que contrajo nupcias el 1 de diciembre de 1995; que para el 30 de junio de 2017 su esposa padecía *litiasis renal* en el riñón izquierdo; y que su cónyuge, debido a la enfermedad que padece, depende económicamente de él.

Sostuvo, además, que su salario en calidad de empleado era el único sustento económico que percibía para satisfacer sus necesidades personales y familiares; que, debido a su desempeño laboral y al fuero de prepensionado, tenía la legítima confianza de poder continuar trabajando al servicio de la demandada hasta cumplir la edad para obtener su pensión de vejez; que desde su despido se ha visto imposibilitado para pagar las cotizaciones al sistema de seguridad social en salud; que el despido fue ilegal, pues se le violó la estabilidad laboral reforzada que le otorga el mentado fuero; que su último salario mensual ascendió a la suma de \$5.683.110; y que ha reclamado su reintegro sin éxito alguno.

La sociedad demandada se opuso a las pretensiones del actor y, en cuanto a los hechos, admitió los relativos a la data en que aquél ingresó a laborar a su servicio, el despido sin justa causa, la afiliación a Colpensiones para el riesgo de vejez, la edad para la fecha del despido (59 años y medio), la enfermedad padecida por la esposa de su extrabajador y el valor del último salario devengado por éste. Los demás los negó o dijo que no le constaban.

En su defensa, propuso las excepciones que denominó inexistencia de estabilidad laboral reforzada, buena fe y lealtad, continuidad de la afiliación y aportes al sistema de seguridad social en salud para el demandante y su cónyuge, auxilio de cesantía y pago de desempleo de la caja de compensación familiar, y la innominada.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá, al cual correspondió el trámite de la primera instancia, por sentencia del 6 de febrero de 2020, resolvió:

PRIMERO: Declarar probada la excepción de inexistencia de la estabilidad laboral reforzada (fuero de prepensionado) del demandante, propuesta por la parte demandada Procesos y Canje S.A., conforme la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia, absolver a la sociedad demandada Procesos y Canje S.A. de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra por el demandante [...], conforme la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Condenar en costas, incluidas las agencias en derecho al demandante [...].

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Al resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante sentencia del 5 de marzo de 2020, confirmó la de primer grado y gravó con costas al demandante.

Centró el problema jurídico en dilucidar si al momento de la desvinculación del actor, éste se encontraba resguardado por la estabilidad laboral reforzada (fuero de prepensionado); y si, con ocasión de ello, procedía su reintegro.

Dijo que de los medios de prueba allegados al plenario podía colegirse que, bajo el marco de un vínculo contractual laboral a término fijo de tres meses, el actor había trabajado al servicio de la sociedad demandada, desempeñando como último cargo el de *‘jefe de PCA’*, desde el 2 de mayo de 2006 hasta el 30 de junio de 2017 (folios 18 a 20), momento en el que feneció por decisión sin justa causa de la convocada a juicio, según la carta de folio 21.

A continuación, precisó lo siguiente:

[...] el fuero reclamado por Peña Hoyos, contrario de aquellos derivados de la Ley 361 del 97 y de la lectura que sobre el particular ha gestado la Corte Constitucional, no haya su sustento en el ámbito normativo reglamentario, sino que su desarrollo ha sido generado y amplificado por la Corporación de cierre de la jurisdicción constitucional al desplegar un parangón con aquella institución del retén social que cobija a los servidores públicos. Es esa la razón a lo antepuesto, que los postulados que demarcan la estabilidad laboral u ocupacional reforzada, no

resultan ajenas a aquellos afiliados próximos a merecer la prestación para el riesgo de vejez por ser la materialización de una interpretación humanizada del derecho del trabajo y los derechos fundamentales, que con éste se conjugan como el mínimo vital y la seguridad social, que en suma, conducen a la guarda del trabajador afectado y con ello a la prohibición asignada a los empleadores de fenecer el vínculo laboral, de suerte que, tal garantía constitucional ha sido avalada por aquellos prestadores de servicios que se encuentran ubicados dentro de la ejecución de su contrato de trabajo y de faltar tres o menos años para reunir los estipendios normativos para la causación de la pensión de jubilación o vejez, a saber, la edad y el tiempo de servicio o semanas de cotización, adjudicándose de esta manera el título de prepensionado.

Lineamientos que, como se enunció de manera antepuesta, encontraron su origen en las prerrogativas concedidas a los servidores públicos que resultaban desplazados con una reestructuración, como se vislumbra en la sentencia T-089 de 2009 y C-975 de 2009, pero que a tono con el derecho de igualdad se ha ampliado al sector privado, enseñando en sentencia T-326 de 2014 que “dicha protección es de origen supralegal, la cual se desprende no solamente de lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución --que establece la obligación estatal de velar por la igualdad real y efectiva de los grupos tradicionalmente discriminados y de proteger a las personas en circunstancias de debilidad manifiesta--, sino de los artículos 42, 43, 44 y 48 superiores; se trata en consecuencia de una aplicación concreta de las aludidas garantías constitucionales [...]”.

Es bajo tal marco de acción, que quien persiga de la jurisdicción abrogarse los beneficios afirmando el título de prepensionado, deberá demostrar como presupuestos ineludibles el ser huérfano del requisito de edad y semanas para el estadio temporal de cese de labores, de manera coetánea, y que ello se presente cuando le faltare menos de tres años para su acceso. Circunstancia que contrario a lo referenciado por el profesional de derecho de la parte accionante, ha sido el estandarte para su procedibilidad aún antes de la fecha de despido sin justa causa, consumado el 30 de junio de 2017 (folio 21).

Denótese como en la sentencia T-357 del 6 de julio de 2016, la Corte Constitucional concluyó que: “La Sala entiende que la condición de prepensionado de un trabajador y la protección que de ésta se deriva no se circunscribe a las relaciones laborales afectadas por los planes de renovación de la administración pública, sino que cobija a todos los trabajadores próximos a pensionarse, definidos como aquellos a quienes les falten 3 o menos años para reunir los requisitos de edad y tiempo de servicio o semanas cotizadas para obtener el disfrute de la pensión de jubilación o vejez”.

Reiterado en la sentencia SU-003 de 2018, que en su labor de unificación, la Corte Constitucional concretó símiles presupuestos y resaltando que “dado que se acredita el cumplimiento del número mínimo de semanas de cotización, no hay lugar a considerar que la persona sea beneficiaria del fuero de estabilidad laboral reforzada de prepensionado, dado que el requisito faltante de edad, puede ser cumplido de manera posterior, con o sin vinculación laboral vigente. En estos casos, considera la Corte que no se frustra el acceso a la pensión de vejez”.

Fluyendo innegable, que al acreditarse que para el momento de extinción del vínculo contractual con Procesos y Canje S.A. el accionante era carente -únicamente- del requisito de edad de que trata la Ley 797 de 2003 por contar para el 30 de junio de 2017 con 59 años, pero acreditar 2043 semanas al 30 de julio de esa anualidad, conforme lo referenciado por el juez constitucional (folio 57), y según la confesión del reclamante jurisdiccional al rendir interrogatorio de parte, en tanto informó que para tal estadio temporal contaba con 1300 semanas (folio 189), es que emana indiscutible la falta de presupuestos para ordenar el reintegro al cargo que desempeñaba el actor.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Solicita el recurrente que la Corte case la sentencia del Tribunal, para que, en sede de instancia, revoque la proferida por el *a quo* y, en su lugar, acceda a las pretensiones de la demanda inicial.

Con tal propósito formula dos cargos por la causal primera de casación laboral, los cuales fueron replicados y serán estudiados conjuntamente, como quiera que se

enderezaron por la misma vía de violación de la ley, denuncian similar normativa y persiguen idéntico fin.

VI. CARGO PRIMERO

Por la vía directa acusa la interpretación errónea de los artículos *«12 de la Ley 790 de 2002 y 1º y 12 del Decreto 190 de 2003, infracción legal que produjo la aplicación indebida de los artículos 19 del C.S.T., 6º y 1746 del Código Civil, 13, 25, 46, 48 y 53 de la Constitución Política y 1º del Acto Legislativo número 1 de 2005, en relación con los artículos 33 de la Ley 100 de 1993, 9º de la Ley 797 de 2003 y 27 del C.C.»*.

En la sustentación del cargo arguye que no discute los supuestos fácticos que el Tribunal encontró probados, sino el hecho de haberle negado el fuero de prepensionado, bajo el argumento de que *«aunque tenía las semanas de cotización suficientes para adquirir la pensión y le faltaban menos de tres años para que se causara la prestación, dicho fuero no lo cobijaba puesto que "el requisito faltante de la edad puede ser cumplido de manera posterior, con o sin vinculación laboral vigente" en cuyo caso»* no se frustra el acceso a la pensión de vejez.

Manifiesta que el artículo 12 de la Ley 790 de 2002 instauró el fuero de prepensionado de conformidad con la reglamentación que estableciera el Gobierno Nacional, para aquellos trabajadores que cumplieran los requisitos de edad y tiempo de servicios necesarios para disfrutar de su pensión de jubilación en el término de tres años; y que dicha

reglamentación, en el artículo 1 del Decreto 190 de 2003, definió como servidor o trabajador próximo a pensionarse a *«aquél al cual le falten tres o menos años contados a partir de la promulgación de la Ley 790 de 2002 para reunir los requisitos de edad y tiempo de servicios o semanas de cotización para obtener el disfrute de la pensión de jubilación o de vejez»*.

A su vez, esgrime que el artículo 12 del mismo decreto dispuso que no podían ser despedidos los trabajadores que en el término de los últimos tres años cumplieran la totalidad de los requisitos de edad y tiempo de servicios para disfrutar de su pensión de jubilación, según la definición establecida en el artículo 1 de dicha normativa.

Aduce que ni la Ley 790 ni su Decreto Reglamentario establecieron diferencia, condición o restricción alguna en lo relativo al cumplimiento de los dos requisitos para la causación de la pensión de jubilación, por manera que, si en los términos del Acto Legislativo 01 de 2005 *«se entiende que la pensión se causa cuando se cumplen los requisitos para acceder a ella»*, para el fuero de prepensionado tal requisito es el de cumplir la edad, como el de tener el tiempo de servicios mínimo o semanas de cotización.

Advierte que el *ad quem*, al efectuar tal distinción, interpretó equivocadamente los artículos 12 de la Ley 790 de 2002 y 1 y 12 del Decreto Reglamentario 190 de 2003, pues fraccionó la *hipótesis normativa general* contenida en los citados preceptos, para comprender dentro de su preceptiva

solo a los trabajadores a quienes les faltara el requisito de semanas de cotización —y no a los que les faltara la edad para acceder a la prestación—.

Enseguida asevera textualmente que:

El argumento del Tribunal según el cual el fuero de pre-pensionado no cobija a quienes vayan a cumplir la edad para acceder a la pensión dentro de los tres años posteriores al despido, puesto que ese requisito puede ser cumplido con posterioridad sin que "se frustre el acceso a la pensión de vejez", es simplemente sofista pues valdría igualmente argumentar que también dentro de esos tres años el trabajador puede seguir cotizando hasta cumplir el mínimo de semanas requeridas aún sin estar sujeto a una relación laboral, con lo cual tampoco se frustraría el acceso a la pensión.

Olvidó el Tribunal Superior que el trabajador adulto mayor y su familia tienen que seguir viviendo y atendiendo a sus necesidades básicas durante el tiempo que le falte para cumplir la edad que le dará acceso a la pensión de vejez y olvidó también la casi insalvable dificultad a la que se enfrenta un trabajador después de los 59 años de edad para conseguir un empleo remunerado que le permita atender las necesidades vitales crecientes de quien llega a la tercera edad y que, al menos en teoría, debiera quedar bajo la especial protección ofrecida por el artículo 46 de la Carta Fundamental.

Para los efectos previstos de manera general en la Constitución y específicamente en el fuero de pre-pensionados, es exactamente lo mismo que al trabajador le falten menos de tres años para cumplir la edad o que le falte ese mismo tiempo de cotizaciones para acceder a la prestación. Lo que el Legislador se propuso al crear el fuero de pre-pensionados fue simplemente impedir en la práctica los despidos de aquellos trabajadores que estuvieran muy próximos a jubilarse teniendo en cuenta que durante el breve lapso que les faltara para ello, tanto el Estado como los empleadores particulares pueden mantenerles sin dificultad, e incluso con provecho, la estabilidad laboral ordenada en el artículo 53 de la Carta Política, naturalmente si no incurrían en justos motivos para la pérdida del empleo.

No entendió bien el Tribunal la teleología o finalidad del fuero de pre-pensionados al considerar que es distinta la situación a la que se enfrenta un adulto mayor despedido injustamente, cuando para acceder a la pensión que quizá le garantice una supervivencia digna por el resto de sus días, le hacen falta

semanas de cotización a cuando le hace falta tiempo para cumplir la edad. Ni el artículo 12 de la Ley 790 ni los artículos 1 y 12 de su Decreto Reglamentario permiten hacer esa distinción que comporta una discriminación ilegal e injusta entre trabajadores de edad avanzada enfrentados a las mismas dificultades vitales.

Tampoco una interpretación gramatical (art. 27 C.C.) del precepto contenido en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002 autoriza la conclusión a la que arribó el Tribunal. En efecto, para la operancia del amparo o fuero del pre-pensionado, las palabras utilizadas en esta norma disponen, inequívoca y contundentemente, que "la totalidad de los requisitos" para disfrutar de la pensión, deben cumplirse dentro de los tres años allí previstos, de manera que, si el texto legal exige el cumplimiento de los requisitos en su totalidad, el intérprete mal podría entender que esa totalidad equivale solamente a uno de los requisitos. Además, la norma precisa que esos requisitos son tanto la edad como el tiempo de servicios, impidiendo que los operadores judiciales puedan separarlos o dividirlos para condicionar la aplicación del amparo al cumplimiento de solo uno de ellos, pues se correría el riesgo de que mientras algunos de dichos operadores prefirieran exigir el cumplimiento del primer requisito, otros operadores optaran por el segundo.

Sin embargo, el Tribunal entendió el artículo 12 de la Ley 790 como si la norma hubiera impuesto como único requisito para la efectividad del amparo del trabajador próximo a pensionarse el de no haber completado el tiempo de servicios o de cotizaciones, pues el de la edad no era necesario, efectuando una inaceptable mutilación de la cobertura y excluyendo así posiblemente a la mitad del componente humano hipotético amparado por el precepto legal.

Al agregarle motu proprio al artículo 12 de la Ley 790 de 2002 la excepción según la cual la estabilidad laboral allí consagrada dejaba de operar si el trabajador tenía cumplido el tiempo de servicios o de cotizaciones, aunque le faltara la edad para causar su derecho a la pensión, incurrió en una evidente interpretación errónea de la norma.

VII. CARGO SEGUNDO

Acusa la sentencia de violar por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida, la misma normativa denunciada en el cargo anterior.

Sostiene que el Tribunal, al limitar la cobertura de los artículos 12 de la Ley 790 de 2002 y 1 y 12 del Decreto 190 de 2003 a los prepensionados que no hubieran cumplido el tiempo de servicios o las semanas de cotización, y dejar inoperante el fuero para quienes les faltara tiempo para cumplir la edad, dividió el campo de aplicación de tales preceptos, fraccionamiento no establecido por el legislador, con lo cual incurrió en una aplicación indebida de esas normas.

Por lo demás, repite los argumentos esbozados en el primer cargo.

VIII. RÉPLICA

La opositora señala que la Ley 790 de 2002 y el Decreto 190 de 2003 le son aplicables, única y exclusivamente, a los servidores públicos, conforme el espíritu de las normas y para los casos de reestructuración de entidades del Estado, por lo que no procede su aplicación a trabajadores particulares.

Afirma que el recurrente no se pronunció respecto a la jurisprudencia constitucional que fue el fundamento principal de la decisión atacada, y se limitó a manifestar la presunta aplicabilidad de las normas públicas, que no fueron objeto del contenido ni de la argumentación del Tribunal.

También destaca que, para el 30 de junio de 2017, el actor tenía cotizadas 2043 semanas, entonces cumplía con

uno de los dos requisitos que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado (sentencia CC SU-003-2018). Por lo tanto, *«el recurrente no se considera una persona con fuero de estabilidad laboral reforzada “prepensionable” al cumplir con el requisito de las semanas cotizadas, el requisito faltante, relativo a la edad, puede ser cumplido de manera posterior, con o sin vinculación laboral vigente»*.

IX. CONSIDERACIONES

Dada la vía de ataque seleccionada por la censura, no son objeto de debate en esta sede extraordinaria los siguientes supuestos fácticos que dio por acreditados el Tribunal: (i) la existencia de un contrato de trabajo entre las partes, desde el 2 de mayo de 2006 hasta el 30 de junio de 2017 (folios 18 a 20 del cuaderno de primera instancia); (ii) el actor fue despedido sin justa causa por la aquí demandada (folio 21); y (iii) Peña Hoyos, al momento de la terminación del vínculo laboral, ya tenía cumplido el requisito de semanas de cotización, más no el de la edad, pues para dicha data tan solo contaba con 59 años (folio 24).

Así pues, corresponde a la Sala determinar si se equivocó el Tribunal al sostener que el demandante no estaba amparado por la estabilidad laboral reforzada (fuero de prepensionado) al faltarle únicamente el requisito de la edad (estar a menos de tres años para causar el derecho a la pensión) para el momento en que fue despedido por su empleador.

Resolver el anterior cuestionamiento impone a la Corte memorar que en el marco de los programas de renovación y modernización de la administración pública, en los cuales se adoptan medidas de reestructuración de la planta de personal de las entidades estatales, fusión o disolución de éstas, el legislador previó un valioso mecanismo de estabilidad laboral reforzada en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002 para tres grupos de trabajadores que no pueden ser retirados del servicio, a saber: (i) madres cabeza de familia o padres con esa condición sin alternativa económica (CC C-1039-2003); (ii) personas con limitación física, mental, visual o auditiva; y (iii) servidores públicos próximos a pensionarse, es decir, a quienes les faltaren tres años o menos para cumplir los requisitos de acceso a la pensión de vejez (CSJ SL1496-2014, SL5528-2018 y SL059-2021).

Ello obedece a que, en tales circunstancias, al presentarse la terminación unilateral del vínculo laboral por la mera voluntad del empleador, lo obvio es que se produzca la afectación de derechos de rango superior para esas personas, por cuanto se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad frente al resto de la población.

De consiguiente, la figura del *retén social* derivada del artículo 12 de la Ley 790 de 2002 posibilita la continuidad del vínculo laboral de los mentados segmentos poblacionales situándolos en una especie de posición *preferente*, al brindarles una garantía especial en función de la discriminación que pueden padecer para su ingreso al mercado laboral y/o para la conservación del empleo, por lo

menos, hasta la liquidación definitiva de la entidad, en los eventos en que ésta se haya ordenado, pues, a partir de allí, se tornaría imposible la conservación de las relaciones laborales de los trabajadores (CSJ SL1496-2014).

En el caso puntual de los servidores públicos que se encuentren próximos a pensionarse, la estabilidad laboral reforzada se encuentra afincada en mandatos constitucionales, tales como la irrenunciabilidad del derecho a la seguridad social (art. 48), la dignidad humana (art. 1) y los principios mínimos fundamentales del trabajo (art. 53), así como en el reconocimiento de que estas personas pueden tener mayores barreras de acceso al empleo y marcadas dificultades para conservarlo.

Por lo tanto, el Estado y la sociedad no pueden ser indiferentes ante esta realidad y, en tal sentido, deben adoptarse los mecanismos necesarios que les permitan a dichos trabajadores arribar al cumplimiento de los requisitos legales, a fin de que puedan acceder a la pensión de vejez.

Lo que sigue es establecer si tal garantía puede quedar reducida o limitada a los eventos de renovación de la administración pública, en los estrictos términos del artículo 12 de la Ley 790 de 2002, pues ello implicaría dejar por fuera a otros, quienes reuniendo las mismas condiciones como trabajadores, esto es, faltándoles tres años o menos para el cumplimiento de los requisitos pensionales, también se encuentran protegidos constitucionalmente ante la eventual terminación del vínculo laboral, *que impida la configuración*

definitiva de la prestación, como sería el caso de aquellos trabajadores en similar circunstancia, pero del sector particular o privado.

Puestas así las cosas, importa a la Corte recordar que el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo, que fue ratificado por Colombia mediante la Ley 22 de 1967, y que hace parte del grupo de convenios de derechos fundamentales en el trabajo según la Declaración de la OIT de 1998, consagra que *no puede haber distinciones, exclusiones o preferencias que alteren o anulen la igualdad de oportunidades o trato en el empleo*, por manera que, frente a este aparte de la disposición —igualdad de oportunidades o trato en el empleo— la estabilidad laboral del prepensionado no podría aplicarse solamente a un grupo de trabajadores, los del sector público, en los citados eventos de renovación de la administración, pues, evidentemente, se trataría de un derecho cuyos contornos resultan mucho más amplios, considerándose que debe protegerse a toda persona que ostente dicha calidad o condición, sin importar que se trate de un servidor público o de uno particular, lo cual, como se advirtió en precedencia, encontraría asidero en los principios constitucionales antes referidos.

La condición de prepensionado requeriría, entonces, activar el principio de igualdad a tan particular situación laboral, para advertirse que esta forma de estabilidad debe cobijar a las personas que trabajan tanto en el sector público como en el particular o privado, por encontrarse próximas a cumplir los requisitos de edad y tiempo de servicios previstos

en el RPMPD o en el RAIS para acceder a la pensión de vejez, esto es, porque les faltan tres años o menos para alcanzarlos.

En puridad, la garantía de permanecer en el empleo por razón de la proximidad a adquirir la pensión no puede generar discriminaciones indebidas e injustificadas, por ser claro que el principio de igualdad contemplado en el artículo 13 de la Carta Política prevé que, ante la misma situación de vulnerabilidad, *como es el caso de quienes están próximos a pensionarse*, debe darse el mismo tratamiento de amparo.

De esa forma es que la protección del retén social para servidores públicos conduce a plantearse el interrogante de si esa tan importante protección resulta aplicable también a la situación de todos los demás prepensionados, sin distinción alguna, dado que, en términos fácticos, hay una clara e inequívoca similitud.

Ahora, como lo asentara esta Corporación en la sentencia CSJ STL13403-2018, *«aun cuando se han reconocido derechos de estabilidad laboral reforzada para ciertos grupos poblacionales —madres cabeza de familia, personas con limitaciones físicas y próximas a pensionarse—, se tiene que tal protección no es automática, sino que deben acreditarse condiciones específicas para su aplicación, en virtud de las cuales primarían tales garantías»*.

En tal sentido, para que llegare a operar la aludida estabilidad laboral del prepensionado, emerge necesario que el juez de la causa verifique que el despido ubica al

trabajador en una situación de vulnerabilidad, como consecuencia necesaria de la ruptura del vínculo jurídico laboral, lo que no solo ocurre cuando se frustra el cumplimiento del requisito de densidad de semanas de cara a la consolidación definitiva del derecho a la pensión, como lo ha venido sosteniendo la Corte Constitucional desde la sentencia de unificación SU-003-2018, sino también, y esta la razón de este análisis, en los casos en los que se afecta injustificadamente --es decir, por el mero arbitrio patronal-- cuando se está próximo al arribo de la edad, pues no puede perderse de vista que nuestro ordenamiento jurídico, en el artículo 53 constitucional, consagra como principio mínimo fundamental la *estabilidad en el empleo*.

A este respecto, el régimen laboral colombiano, tanto para el sector privado como en el público, en términos generales, opta por un sistema de estabilidad laboral impropia o relativa, por cuanto el empleador privado u oficial puede dar por terminado el contrato de trabajo aduciendo una justa causa o, en ausencia de esta, de forma unilateral y por su mera liberalidad, pagando a cambio una indemnización al trabajador, salvo en los aludidos casos hasta ahora previstos de estabilidad *reforzada*. Cláusula normativa que ha dado en llamarse como condición resolutoria del contrato de trabajo, que facilita la su terminación unilateral por parte del empleador, a condición, sencillamente, de que pague una indemnización tarifada en el ordenamiento jurídico nacional (artículo 64 CST).

Desde luego, la estabilidad no se puede entender como una permanencia absoluta o irrestricta en el trabajo, sino en la aplicación de medidas normativas para otorgar la protección debida al trabajador a fin de que su despido o desvinculación se realice bajo causas justificadas, postulado que conlleva a que el empleador acredite las razones suficientes, con las debidas garantías y, a su turno, que las causales imputadas no sean arbitrarias o contrarias a derecho.

En esa dirección, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han construido un enfoque de derechos fundamentales centrado en la ratificación de la Declaración de los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, cuyas categorías incluyen la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.

Y en el ámbito de la jurisprudencia interamericana, aunque la Corte Constitucional ha dicho que, salvo los casos en que el Estado colombiano sea parte, ésta no es vinculante, sobre el tema aquí estudiado resulta muy diciente lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en casos como el de *Lagos del Campo vs. Perú* (sentencia hito del 31 de agosto de 2017), en el cual, en punto de la mentada y especial estabilidad laboral reforzada —relevante para la interpretación de los derechos y deberes laborales en Colombia y, en general, para los Estados americanos—, reflexionó:

149. Como correlato de lo anterior, se desprende que las obligaciones del Estado en cuanto a la protección del derecho a la estabilidad laboral, en el ámbito privado, se traduce en principio en los siguientes deberes: a) adoptar las medidas adecuadas para la debida regulación y fiscalización de dicho derecho; b) proteger al trabajador y trabajadora, a través de sus órganos competentes, contra el despido injustificado; c) en caso de despido injustificado, remediar la situación (ya sea, a través de la reinstalación o, en su caso, mediante la indemnización y otras prestaciones previstas en la legislación nacional). Por ende, d) el Estado debe disponer de mecanismos efectivos de reclamo frente a una situación de despido injustificado, a fin de garantizar el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva de tales derechos (infra, párrs. 174, 176 y 180).

150. Cabe precisar que la estabilidad laboral no consiste en una permanencia irrestricta en el puesto de trabajo, sino de respetar este derecho, entre otras medidas, otorgando debidas garantías de protección al trabajador a fin de que, en caso de despido se realice éste bajo causas justificadas, lo cual implica que el empleador acredite las razones suficientes para imponer dicha sanción con las debidas garantías, y frente a ello el trabajador pueda recurrir tal decisión ante las autoridades internas, quienes verifiquen que las causales imputadas no sean arbitrarias o contrarias a derecho.

[...]

152. Con motivo de ello, el señor Lagos del Campo perdió su empleo, la posibilidad de acceder a una pensión por jubilación, así como ejercer sus derechos como representante de los trabajadores. Tal incidente tuvo como consecuencia ciertas repercusiones en su vida profesional, personal y familiar (supra, párr. 72). Al respecto, Lagos del Campo declaró en la audiencia pública ante la Corte que entre las consecuencias de su despido fueron las siguientes:

[No pudo acceder a una jubilación porque faltaban cinco años según las leyes para poder acceder a una jubilación digna para poder sobrevivir, pero todo eso estuvo conculcado porque no contaba en ese entonces con el requisito que era o exigía la ley de presidente. [...] Durante la dictadura de ese gobierno [...], lamentablemente todo ciudadano o trabajador después de los cincuenta ya no tenía acceso a ninguna empresa ni a un puesto rentable. [...] [Además que] después de tantos largos años de sufrimiento, de pedir justicia nacional, en este caso internacional, [...] sufrió] [en el 2015] [afectaciones a su salud] [...].

153. En vista de lo anterior, la Corte concluye que, con motivo del despido arbitrario del señor Lagos del Campo, se le privó de su empleo y demás beneficios derivados de la seguridad social,

ante lo cual el Estado peruano no tuteló el derecho a la estabilidad laboral, en interpretación del artículo 26 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1, 13, 8 y 16 de la misma, en perjuicio del señor Lagos del Campo.

154. Finalmente, cabe señalar que la Corte ha establecido previamente su competencia para conocer y resolver controversias relativas al artículo 26 de la Convención Americana, como parte integrante de los derechos enumerados en la misma, respecto de los cuales el artículo 1.1 confiere obligaciones generales de respeto y garantía a los Estados (supra párr. 142). Asimismo, la Corte ha dispuesto importantes desarrollos jurisprudenciales en la materia, a la luz de diversos artículos convencionales. En atención a estos precedentes, con esta Sentencia se desarrolla y concreta una condena específica por la violación del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dispuesto en el Capítulo III, titulado Derechos Económicos, Sociales y Culturales de este tratado.

Es evidente, entonces, que la potestad del empleador de dar por terminado el contrato de trabajo sin justa causa tiene excepciones fundadas, como se verá enseguida, pues mediando el principio de estabilidad en el empleo es que se ha considerado, precisamente, la protección de personas en condiciones especiales, como ocurre, entre otros, con las mujeres en estado de embarazo, trabajadores en situación de discapacidad, VIH o fuero sindical, frente a quienes se mantiene la garantía del vínculo como una manifestación del principio aludido, limitándose o restringiéndose válidamente la posibilidad de dar por terminado el contrato sin que exista una justa causa para ello.

En ese orden, la protección *reforzada* de los llamados prepensionados debe ser entendida como otra excepción al diseño de estabilidad laboral relativa imperante en nuestro orden jurídico interno, por razones constitucionales

arraigadas en las particulares condiciones de este grupo etario que demanda una especial protección.

Al efecto, se parte del supuesto de que lo que allí se protege es la estabilidad laboral como un concepto integralmente concebido, no solamente por estarse *ad portas* de la estructuración del supuesto de cotización del derecho a la pensión, como lo ha señalado de manera reiterada la Corte Constitucional, sino también, porque las condiciones de este segmento poblacional resultan altamente vulnerables, por esa mera posibilidad de pérdida del empleo y desvinculación del sistema de seguridad social, lo que impone concebir en su justa dimensión el concepto de estabilidad laboral reforzada, mismo que en su sentido natural y obvio se traduce en la continuidad del vínculo --no solo de aportes al sistema de seguridad social--.

De ahí que resulta legítimo sostener que la norma cuestionada --artículo 12 de la Ley 790 de 2002-- protege a la persona, independientemente de que le falte el tiempo mínimo de servicios para constituir la base económica de su pensión o la edad pensional prevista en la norma que regula la prestación.

Por otro lado, bien vale la pena mencionar que la condición resolutoria que va atada a todo contrato de trabajo, que es el que rige las relaciones laborales de los trabajadores del sector particular o del sector público en lo que respecta a los trabajadores oficiales, no puede tenerse por absoluta, como ya se ha visto en determinados casos, menos,

tratándose de una situación como la aquí estudiada que pone al trabajador en un escenario requirente de especial amparo.

De consiguiente, el rompimiento arbitrario de la relación laboral en esta etapa inmediatamente previa a la pensión (trienio anterior al arribo de la edad), no se corresponde con el principio tuitivo del trabajo, por lo que la denominada condición resolutoria debe limitarse o relativizarse para hacer efectiva la permanencia en el puesto de trabajo hasta que el trabajador pueda acceder realmente a la prestación, esto es, cuando se conjuguen y cumplan los requisitos de edad y semanas de cotización al sistema de seguridad social; así, la simple invocación de la libertad empresarial no puede ser un soporte válido para sostener la plenitud de la validez de la condición resolutoria de los artículos 64 del Código Sustantivo del Trabajo y 51 del Decreto 2127 de 1945, dado que el bien común es límite de dicha libertad, dentro del cual lógicamente está el de los trabajadores.

Nótese que la empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones (art. 333 CP), entre ellas, entiende la Sala, la generación de empleo y su permanencia (art. 1.º de la Ley 590 de 2000), la conservación del trabajo y la solidaridad como valores fundantes del Estado Social de Derecho (preámbulo y artículo 1.º de la Constitución Política), en pro del mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes (art. 334 CP), que implica, indefectiblemente, facilitar el acceso a la seguridad social e ingreso mínimo vital del trabajador y su grupo familiar hasta

cuando se consolida el derecho pensional si se está *ad portas* de adquirirlo, se repite.

Ahora bien, con esta nueva visión tampoco se trata de avalar la petrificación del vínculo laboral con relación a los prepensionados, como ya se anunció líneas atrás, pues, precisamente, el legislador estableció la transición del derecho al trabajo al derecho de la seguridad social pensional, al consagrar en el parágrafo 3.º del artículo 9 de la Ley 797 de 2003, como justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo o la relación legal o reglamentaria, *cuando el trabajador del sector privado o público cumpla con los requisitos para tener derecho a la pensión* y, además, autorizó al empleador para finiquitar la relación laboral cuando sea reconocida o notificada la prestación pensional. También lo facultó para solicitar su reconocimiento en nombre del empleado, cuando éste no la pide después de transcurridos treinta (30) días de haber cumplido los requisitos para acceder al derecho ya consolidado.

Cabe destacar que el mencionado parágrafo 3.º omitió reglamentar el supuesto de hecho respecto del intervalo de tiempo que transcurre entre la notificación del reconocimiento de la pensión y el disfrute efectivo de la misma. Para la Corte Constitucional, dicha circunstancia vulnera los principios superiores que protegen al trabajador que se pensiona, cuando el vínculo laboral termina, aún de haberse notificado el reconocimiento pensional, pero sin que el beneficiario se encuentre recibiendo efectivamente su mesada, es decir, sin contar con los ingresos necesarios para

llevar una vida digna durante dicho interregno.

La omisión anterior exigió del Alto Tribunal, como única medida para que el precepto deviniese constitucional, proferir una sentencia aditiva con el fin de disponer que el vínculo laboral solo se puede terminar cuando se garantice al trabajador el pago efectivo de la mesada pensional con la inclusión en la nómina de pensionados. Sobre el particular, la sentencia CC C-1037-2003 señaló lo siguiente:

11.- La Corte considera que el mandato constitucional previsto en el artículo 2º de la Constitución, según el cual el Estado debe garantizar la “*efectividad de los derechos*”, en este caso del empleado, público o privado, retirado del servicio asegurándole la “*remuneración vital*” que garantice su subsistencia, su dignidad humana y los derechos de los trabajadores impone el deber de dictar una sentencia aditiva, esto es que agregue un supuesto de hecho o requisito a los señalados por el legislador con el fin de hacer compatible la norma con la Constitución Política. En este caso es necesario adicionar a la notificación de la pensión la notificación de su inclusión en la nómina de pensionados correspondiente.

La desmejora en los ingresos del trabajador al cambiar su status (sic) de trabajador activo al de pensionado, dado que en el mejor de los casos recibirá lo equivalente al 75% de su salario, no puede traducirse tampoco en que no reciba la mesada pensional durante ese intervalo de tiempo, puesto que dicha situación cercenaría, también, la primacía que la Carta reconoce a los derechos inalienables de la persona, en este evento del trabajador.

Esta circunstancia permite a la Corte concluir que no puede existir solución de continuidad entre la terminación de la relación laboral y la iniciación del pago efectivo de la mesada pensional, precisamente para asegurar al trabajador y a su familia los ingresos mínimos vitales, así como la efectividad y primacía de sus derechos (C.P., arts. 2º y 5º). Por tanto, la única posibilidad de que el precepto acusado devenga constitucional es mediante una sentencia aditiva para que el trabajador particular o servidor público sea retirado sólo cuando se le garantice el pago de su mesada pensional, con la inclusión en la correspondiente nómina, una vez se haya reconocido su pensión.

Conforme a lo hasta ahora expuesto, resulta indiscutible que no solamente el reconocimiento pensional goza de especial protección constitucional, sino también, el de su tránsito hacia ese estado, es decir, el de quien está en vía de adquirir el derecho por faltarle apenas tres años para su disfrute, por encontrarse el trabajador en condiciones especiales de vulnerabilidad, entiéndase, cuando se le da por terminado *prematura y arbitrariamente* el vínculo contractual laboral.

Esto obedece a que el fin último de la normativa es evitarle al sujeto un período de marginación económica anterior a su inclusión a la nómina de pensionados, de manera tal que consagra una dimensión no solo jurídica-laboral, sino también económica de protección para el prepensionado.

En estos eventos, el acercarse a la pensión hace que el trabajador se ubique en una situación de vulnerabilidad funcionalmente semejante a la reconocida en la jurisprudencia de prepensionados, lo que impone al empleador un deber intensificado de preservación del vínculo laboral cuando le faltan única y exclusivamente tres años o menos de edad para arribar a la edad pensional.

Y ello es así porque al llegar a la edad de la pensión el trabajador debe abandonar el mundo laboral para pasar a depender de la mesada pensional; tránsito que también es concebido como un derecho humano de especial protección, a tal punto que la ya mencionada Convención Interamericana

sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en el artículo 14, expresamente señala:

Los Estados Parte promoverán programas y medidas que faciliten una transición gradual a la jubilación, para lo cual podrán contar con la participación de las organizaciones representativas de empleadores y trabajadores y de otros organismos interesados.

Precisamente por ello, al realizarse el examen de constitucionalidad de la ley aprobatoria de la Convención, la disposición fue declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-395-2021, por considerar que *«la Sala Plena entiende que la garantía del derecho al trabajo que realiza la Convención sub examine se articula con los preceptos y finalidades constitucionales, ya que resalta la protección especial que debe brindarse a los adultos mayores en materia laboral, lo cual constituye un elemento cardinal para la promoción de su integración a la vida activa social, y que, por demás, exalta la posibilidad de materializar sus derechos al mínimo vital, y a vivir una vida autónoma e independiente»*.

Por si fuera poco, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el artículo denominado *«Eliminemos el Edadismo y la discriminación por edad, afirma experto de las Naciones Unidas»*, señaló que la discriminación por razones de edad marca la realidad que viven las personas mayores *ad portas* de una pensión, que hoy se perciben como *«insignificantes, descartables y una carga para la sociedad»*.

Por tanto, para esta Sala de Casación, la estabilidad laboral reforzada no se activa únicamente si con la terminación del vínculo se frustra la posibilidad de adquirir el derecho --por no acreditarse el número de semanas--, sino también, como garantía para que el derecho pensional se alcance en condiciones dignas-- lo que sucede cuando se tienen las semanas pero no la edad--, con el propósito de garantizar la subsistencia del trabajador y su núcleo familiar, cuando este se encuentra, se insiste, a menos de tres años para causar el derecho.

En suma, tratándose de cuestiones de carácter general prevalece, sin discusión alguna, la condición resolutoria --regla universal--, misma que se encuentra consagrada en la ley, pero cuando se está cercano a una pensión de vejez, como en este caso, esa condición resolutoria --por vía de excepción-- no puede tener esa amplitud subjetiva que podría concebirse en una época distinta de la vida (recuérdese el desgaste físico, emocional e intelectual que conlleva la situación del prepensionado). En ese escenario, debe primar el derecho del trabajador de permanecer en el empleo, otorgándosele a la aludida cláusula una dimensión *relativa*, con miras a proteger los derechos fundamentales en tensión. También resulta claro que los eventuales subsidios de desempleo, cesantías e indemnización por despido sin justa causa que llegare a recibir el trabajador afectado, no derruyen, en manera alguna, la prevalencia de los principios superiores a que se ha aludido y el hecho cierto de que la persona quedaría desprotegida, en un momento tan crucial de su vida, en materia de seguridad social.

Así las cosas, la sola circunstancia de que al trabajador le falte el requisito de la edad para acceder al derecho pensional (AL 01/05), por haber alcanzado ya el número mínimo de cotizaciones previstas en el sistema de seguridad social, bajo el mero argumento de que esta exigencia se puede acreditar con o sin vínculo laboral vigente, no puede servir de sostén para desactivar la garantía de estabilidad en el empleo y negar así el derecho a permanecer en el mismo.

Recapitulando, para la Corte, la estabilidad laboral reforzada de los prepensionados es una garantía constitucional de las personas vinculadas al sector público o particular, que consiste en no ser desvinculados de sus cargos cuando se encuentren *ad portas* de cumplir con los requisitos para acceder a la pensión de vejez, garantía fundamentada no solo en el derecho a la igualdad, el trabajo y la seguridad social, sino también en el principio de estabilidad en el empleo, por lo que, en términos generales, sus beneficiarios no se pueden distinguir por el sector al que obedezca su vinculación laboral.

Tampoco puede olvidarse que la Constitución Política de 1991 consagró el derecho a la seguridad social como un servicio público de carácter obligatorio a cargo del Estado, siendo la Ley 100 de 1993 el instrumento dispuesto por el legislador para conseguir ese fin constitucional. Allí se consagró el mecanismo de protección de las contingencias económicas, a través de los regímenes de pensiones, salud, riesgos laborales y servicios sociales complementarios, con el objetivo de garantizar los derechos irrenunciables de la

persona y la comunidad en general, en aras de obtener una calidad de vida acorde con la dignidad humana.

La citada normativa concibe a la seguridad social como un sistema *integral*, creado para brindar protección a la población contra las necesidades sociales que afectan la disminución del nivel de vida del trabajador, a causa del acaecimiento de las contingencias cubiertas con criterio delimitador por los subsistemas de pensiones, salud y riesgos laborales. En el caso de los trabajadores, el sistema está diseñado para prestar una atención a los afiliados y beneficiarios cuando afrontan un estado de debilidad económica derivado de la contingencia.

De este modo se establece una relación jurídica entre las instituciones, los trabajadores y sus empleadores, cuyo objeto es determinar los derechos y obligaciones de cada uno de los sujetos que participan en su operación, a través de los instrumentos que la integran: afiliación, cotización y protección. De ahí la importancia del empleo para garantizar el sostenimiento de la protección en los períodos de inactividad laboral.

Dicho contexto impone a la Corte recabar sobre la importancia de proteger a quienes les falten tres años o menos para cumplir los requisitos que les permitan acceder a la pensión de vejez. Hasta ahora, la respuesta había sido que *«la pre-pensión protege la expectativa del trabajador de obtener su pensión de vejez, ante su posible frustración como consecuencia de una pérdida intempestiva del empleo»*, es

decir, la figura del prepensionado había sido concebida para posibilitar la acreditación de las semanas de cotización exigidas para la pensión, más no para garantizar el empleo a quienes se encuentran próximos a pensionarse, dado que *«el requisito faltante de edad puede ser cumplido de manera posterior, con o sin vinculación laboral vigente»* (CC SU-003-2018).

Ese criterio delimitador de la situación protegida por el fuero de estabilidad laboral tenía un origen meramente circunstancial en relación con el número de semanas que el trabajador hubiera podido reunir en toda su vida laboral, independientemente del estado de debilidad económica que de hecho genera la pérdida del empleo en proximidades a la obtención del derecho pensional, ya que el lapso de tres años o menos para alcanzar la prestación no se veía relevante, en el entendido de que, cuando el trabajador de forma prematura lograba cotizar el número de semanas exigido, la edad podía ser cumplida, con o sin vinculación laboral.

No puede olvidarse que, aun cuando la estabilidad se establezca en beneficio exclusivo del trabajador, la mayor prolongación de la permanencia de éste en la empresa, redundaría también en beneficio del empleador; sobre todo por la mayor experiencia y conocimientos que se adquieren con el paso de los años y que, en definitiva, benefician a los empleadores, a lo que se suma la ventaja que le representa no estar experimentando y enseñando a nuevos trabajadores, con la cadena inevitable de errores, fracasos, perjuicios y pérdidas de tiempo.

El anterior razonamiento, a juicio de la Corte, origina un trato discriminatorio, porque la pérdida del empleo, cuando el trabajador se encuentra a tres años o menos para acceder al derecho pensional, le ocasiona una situación de vulnerabilidad que le impide su participación en la vida cultural, económica y social, condiciones inherentes a la dignidad humana.

Por ende, el concepto de prepensionado debe ser entendido en función de la proximidad con el acaecimiento de la contingencia de vejez, como una extensión del riesgo social amparado por el sistema de seguridad social, cuya justificación, desde épocas pretéritas, obedece a que la vejez hace imposible el mantenimiento del trabajo en una vida activa. En verdad, el lapso que corre entre la inactividad laboral y la consolidación definitiva del derecho a la pensión, definido ya como de tres años o menos para adquirir el derecho pensional, debe ser objeto de protección por el fuero de estabilidad laboral reforzada de los prepensionados, pues de lo que se trata es de garantizarle a éste —y a su núcleo familiar— las fuentes normales de existencia durante el período que hace falta para el aseguramiento de la pensión y, de esta manera, evitar que el sujeto de especial protección caiga en un estado de necesidad, producto de la pérdida del empleo.

Además, no puede pasarse por alto que, si la seguridad social busca hacer efectiva la solidaridad entre los afiliados al sistema general de pensiones para garantizar el pago oportuno de las prestaciones y la sostenibilidad financiera

del sistema, no tendría sentido, entonces, excluir de la estabilidad laboral reforzada a los prepensionados quienes, precisamente, durante largos períodos de tiempo han sufragado sus aportes cumplidamente, como se espera de todos los afiliados y que, durante un ciclo laboral de más de cinco lustros han contribuido al sistema pensional, lo que incide en el hecho de que la persona permanezca vinculada para protegerlo de los riesgos comunes que ampara la seguridad social, sobre todo, en caso de infortunios laborales.

Por otra parte, en nuestro país, el sistema de seguridad social integral (Ley 100 de 1993) contempla la obligación de las entidades públicas de carácter nacional, como las del sector privado, de incluir dentro de los programas regulares de bienestar social el componente de preparación para la jubilación. De igual manera, el Decreto 36 de 1998 delegó en el Ministerio del Trabajo, o quien haga sus veces, la responsabilidad de asesorar a las empresas en la adopción de proyectos de preparación para el retiro que propicien el mejoramiento de condiciones y estilos de vida.

Por ello la necesidad de definir acciones o implementar iniciativas que repercutan positivamente sobre los colaboradores que terminan su ciclo laboral o que están próximos a jubilarse, a fin de reducir los prejuicios asociados a la vejez y paradigmas relacionados con el cese de actividades. Tales programas suelen incluir componentes educativos, psicológicos y legales, que permiten a los interesados durante esta última fase del ciclo de vida laboral

planificar su existencia post-jubilación con una visión integral, abriendo oportunidades para nuevas ocupaciones, proyectos de vida y gestión de su patrimonio.

En definitiva, un retiro laboral abrupto en vía de la adquisición del derecho pensional puede desatar una crisis profunda que afecta la calidad de vida del sujeto próximo a pensionarse y de su familia, pues trunca la posibilidad de una jubilación *armónica y gradual*, como proceso inevitable en la vida laboral de una persona, a quien se le impide, en últimas, adaptarse a esta nueva etapa de la vida con el menor impacto posible, siendo esto lo deseable.

Para esta Corporación es menester buscar facilitar la transición hacia el retiro laboral como una nueva etapa del ciclo vital, en la que no puede desconocerse el impacto que la falta de empleo ocasionaría al sujeto *prepensionado* en las particulares condiciones ya descritas.

Bajo los anteriores derroteros, que se adoptan como un criterio auxiliar para resolver el cuestionamiento propuesto en este asunto, la Sala en esta oportunidad se aparta para avanzar de los lineamientos trazados por la Corte Constitucional en la sentencia CC SU-003-2018, entre otras razones, por las que se explican a continuación.

Importa recordar que el derecho a la estabilidad laboral reforzada de las personas próximas a pensionarse no se fundamenta en un mandato legal, sino en disposiciones especiales de protección contenidos en la Constitución

Política que se estructuran como instrumento normativo dirigido a la satisfacción de los derechos fundamentales de aquellos colectivos que se verían gravemente interferidos por el retiro del empleo cuando se encuentren *ad portas* de cumplir con los requisitos para acceder a la pensión de vejez.

De esa suerte, no puede predicarse la exclusividad de la carencia de semanas de cotización como único factor habilitante de protección. En últimas, la prioridad tuitiva se enfoca en la continuidad monetaria previa a la obtención de la prestación pensional, la cual se vería menoscabada por el acto de despido. Por lo tanto, no resulta válido acudir al argumento según el cual la edad puede ser cumplida con posterioridad, aun sin una vinculación laboral patente, en tanto que, precisamente, la situación del trabajador en esos casos configura una situación de vulnerabilidad estructural, al producir un impacto desproporcionado y negativo en su proyecto de vida y en su mínimo vital.

Además, la antigüedad representa un valor y una utilidad para la propia empresa, pues constituye un modo indirecto de estimular la permanencia del trabajador en la empresa y garantizar que, en un marco sistémico de relaciones de trabajo, permita una transición progresiva entre la vida profesional y un régimen de actividad libre, el paso de un trabajador a la situación de retiro, como lo sugiere la Recomendación 162 de la OIT.

Por último, la aplicación sistemática entre la normativa colombiana, los instrumentos de la OIT y del Sistema

Interamericano lleva a reconocer que la edad es un factor relevante de protección sin que se blinden todos los vínculos laborales, pues los estándares internacionales recomiendan favorecer su continuidad, evitar el despido por edad y garantizar condiciones de trabajo no discriminatorias.

Por ello, el Tribunal erró al sostener que, como el actor ya contaba con las semanas mínimas de cotización, con fundamento en un criterio restrictivo de interpretación de los derechos fundamentales de la persona y los propios del trabajador, por cuanto, para el momento del despido tenía cotizadas más de las 1300 exigidas por el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 9 de la Ley 797 de 2003, pero le faltaban (única y exclusivamente) menos de tres años para arribar a la edad pensional, aquél no resultaba beneficiario de la garantía constitucional de permanecer en el empleo.

En consecuencia, los cargos prosperan y se casará la sentencia impugnada.

Sin costas en el recurso extraordinario de casación.

Previo a emitir sentencia de instancia, y para mejor proveer, se ordenará que por Secretaría se oficie a Colpensiones para que, en el término de diez (10) días contados a partir del recibo de la respectiva comunicación, certifique si a la fecha el demandante se encuentra pensionado y, en caso afirmativo, indique a partir de qué fecha.

Asimismo, se oficiará a la empresa Procesos y Canje S. A. para que, en igual lapso, allegue la liquidación final de prestaciones del demandante e indique el último salario devengado por él.

Una vez se obtenga la documental requerida, la Secretaría de la Sala la pondrá a disposición de las partes por el término de tres (3) días. Vencido dicho plazo, el expediente regresará al Despacho para proferir la decisión que en derecho corresponda.

X. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **CASA** la sentencia dictada el cinco (5) de marzo de dos mil veinte (2020), por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por **CLAUDIO MAURICIO PEÑA HOYOS** contra la sociedad **PROCESOS Y CANJE SA.**

Sin costas en casación.

Previo a emitir sentencia de instancia, y para mejor proveer, se ordenará que por Secretaría se oficie a Colpensiones, para que en el término de diez (10) días contados a partir del recibo de la respectiva comunicación, certifique si a la fecha el demandante se encuentra

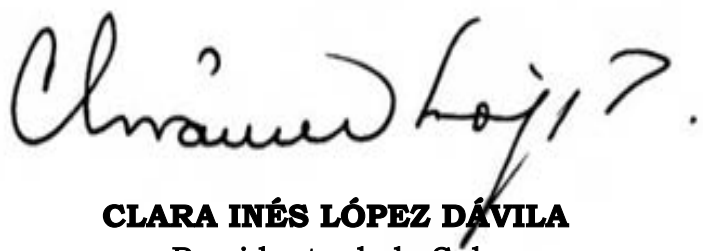
pensionado y, en caso afirmativo, indique a partir de qué fecha.

Asimismo, se oficiará a la empresa Procesos y Canje S. A. para que, en igual lapso, allegue la liquidación final de prestaciones del demandante e indique el último salario devengado por él.

Una vez se obtenga la documental requerida, la Secretaría de la Sala la pondrá a disposición de las partes por el término de tres (3) días. Vencido dicho plazo, el expediente regresará al Despacho para proferir la decisión que en derecho corresponda.

Notifíquese y cúmplase.

Firmado electrónicamente por:



CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA

Presidenta de la Sala
Salvamento de voto

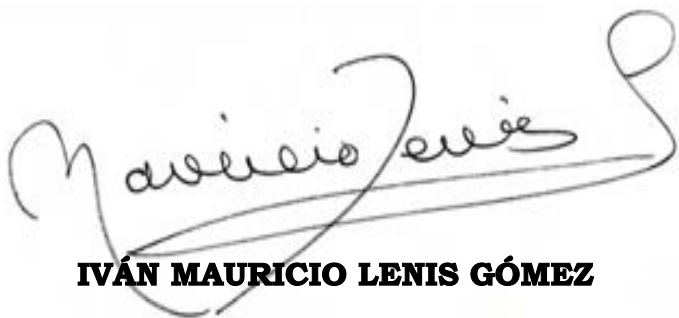


JUAN CARLOS ESPELETA SÁNCHEZ



LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

Aclaración de voto

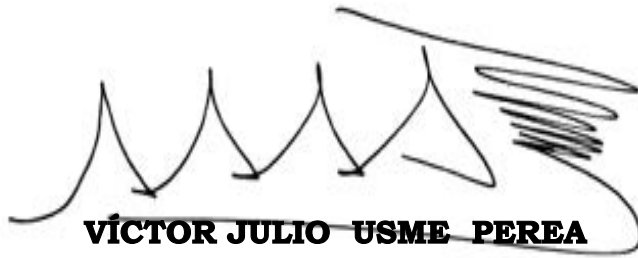


IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ



OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

Salvamento de voto



VÍCTOR JULIO USME PEREA



MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

Código de verificación: 8C5075EAD1276F499D491BC02FBE18E80443482371F1419A321DF7A720432018

Documento generado en 2025-12-19

**PREPENSIONADOS QUE OCUPAN CARGOS DE CARRERA EN
PROVISIONALIDAD EN EL MARCO DE UN CONCURSO DE
MERITOS-Mecanismos de protección**

(...) la estabilidad laboral reforzada del prepensionado genera la obligación de trato preferencial que debe cumplir la entidad nominadora “en la medida de las posibilidades”. Esa obligación se concreta en: (i) tomar medidas para que esos servidores sean los últimos en ser desvinculados de sus cargos; y, (ii) si existen cargos en vacancia definitiva similares o equivalentes a los que venían ocupando, nombrarlos en esos cargos mientras se proveen a través del concurso de méritos y hasta que logren cumplir los requisitos para obtener su pensión de vejez.

**ACCION DE TUTELA PARA RECLAMAR ESTABILIDAD
LABORAL REFORZADA DE PREPENSIONADO-Procedencia
excepcional**

**DESVINCULACION DE SERVIDORES PUBLICOS PROVISIONALES
CON ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA CON OCASION DE
CONCURSO DE MERITOS-Reiteración de jurisprudencia**

**ESTABILIDAD LABORAL DE PERSONAS PROXIMAS A
PENSIONARSE-Protección legal**

**DERECHO AL MINIMO VITAL Y ESTABILIDAD LABORAL
REFORZADA-Orden de reintegrar a empleado**

**ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PREPENSIONADO-Solo
aplica en los casos en que sea necesario mantener el vínculo laboral del
trabajador, para que éste pueda completar las semanas de cotización
requeridas**

REPÚBLICA DE COLOMBIA



**CORTE CONSTITUCIONAL
-Sala Sexta de Revisión-**

SENTENCIA T-253 de 2023

Referencia: Expediente T-9.041.640

Asunto: Revisión de las sentencias de tutela proferidas dentro del proceso promovido por Blanca Enaida Rojas Pérez contra el Municipio de Tibasosa (Boyacá)

Magistrado sustanciador:
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Bogotá D.C., once (11) de julio de dos mil veintitrés (2023)

La Sala Sexta de Revisión, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente sentencia al revisar la proferida el 31 de agosto de 2022 por el Juzgado Primero Civil del Circuito Oral de Duitama, mediante la cual revocó la emitida el 26 de mayo de 2022 por el Juzgado Promiscuo Municipal de Tibasosa.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos relevantes

1. La señora Blanca Enaida Rojas Pérez se desempeñaba como servidora pública, nombrada en provisionalidad, en el cargo de “auxiliar administrativo”, código 407, grado 09, en el Municipio de Tibasosa (Boyacá), desde el 12 de marzo de 2002¹.
2. La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), a través del Acuerdo Nro. 20191000004696 de 14 de mayo de 2019, convocó y estableció las reglas del proceso de selección para proveer -de manera definitiva- cargos de carrera administrativa de la planta de personal en el Municipio de Tibasosa (Boyacá) dentro de la Convocatoria 1241 de 2019. La Convocatoria tenía por objetivo proveer once vacantes, de las cuales dos eran para el cargo “auxiliar administrativo”, código 407, grado 9, que correspondían a la Oferta Pública de Empleo de Carrera -OPEC 67261.
3. La señora Rojas Pérez se inscribió para ocupar el cargo que venía desempeñando en provisionalidad.
4. Cumplidas las etapas de la convocatoria, la CNSC publicó la lista de elegibles para las dos vacantes de la OPEC 67261, mediante Resolución 2785 de 1º de marzo de 2022. En la lista de elegibles, que cobró firmeza el 11 de marzo de 2022², la señora Rojas Pérez se ubicó en la tercera posición:

“(…) Artículo Primero. Conformar y adoptar la Lista de Elegibles para proveer dos (2) vacante(s) definitiva(s) del empleo denominado AUXILIAR ADMINISTRATIVO, Código 407, Grado 9, identificado con el Código OPEC No. 67261. ALCALDÍA DE TIBASOSA – BOYACÁ-, del Sistema General de Carrera Administrativa, así:

<i>Posición</i>	<i>Documento</i>	<i>Nombres</i>	<i>Apellidos</i>	<i>Puntaje</i>
<i>1</i>	<i>46452297</i>	<i>Grace Elena</i>	<i>Angarita Royero</i>	<i>79.78</i>
<i>2</i>	<i>1055314764</i>	<i>Diana María</i>	<i>Sierra Ortiz</i>	<i>76.01</i>
<i>3</i>	<i>24166772</i>	<i>Blanca Enaida</i>	<i>Rojas Pérez</i>	<i>74.25</i>

*(…) ”*³.

¹ Expediente T-9.041.640. “9041640_2022-10-24_BLANCA ENAIDA ROJAS PEREZ_9_REV”. Solicitud de selección de tutela, p. 4.
² Expediente T-9.041.640. “3_15806408900120220012400-(2022-09-26 14-19-13)-1664219953-3”. Contestación CNSC, p. 7.
³ Expediente T-9.041.640. “1_15806408900120220012400-(2022-09-26 14-18-50)-1664219930-1”. Resolución 2785 del 1 de marzo de 2022 de la CNSC, p. 14.

5. El 30 de marzo de 2022, la señora Rojas Pérez recibió, vía correo electrónico, la Resolución 132 de 22 de marzo de 2022⁴, expedida por la alcaldesa del Municipio de Tibasosa (Boyacá), por medio de la cual: (i) se nombró en período de prueba, en el cargo de “auxiliar administrativo”, código 407, grado 09, a la señora Diana María Sierra Ortiz, quien ocupó el segundo puesto de la lista de elegibles para la OPEC 67261; y, (ii) como consecuencia del nombramiento en período de prueba de la señora Sierra Ortiz, se terminó la vinculación de la señora Rojas Pérez, quien ocupaba en provisionalidad dicho cargo.

6. El 31 de marzo de 2022, la Jefe de Talento Humano del Municipio de Tibasosa (Boyacá) le notificó a la señora Rojas Pérez la terminación de su nombramiento provisional. Adjuntó copia de la Resolución 132 de 22 de marzo de 2022 y copia de la aceptación de la señora Sierra Ortiz para ocupar el cargo de “auxiliar administrativo” ofrecido en la OPEC 67261.

7. El 6 de abril de 2022⁵, la señora Rojas Pérez presentó recurso de reposición contra la Resolución 132 de 22 de marzo de 2022. Solicitó la revocatoria de la terminación de su nombramiento en provisionalidad y su consecuente nombramiento “sin solución de continuidad laboral” en período de prueba, en un cargo de igual o superior jerarquía. Argumentó que: (i) goza de estabilidad laboral reforzada porque tiene la calidad de prepensionada debido a que le faltan menos de tres años para reunir los requisitos para obtener la pensión de vejez; (ii) es madre cabeza de familia; y, (iii) ocupó el tercer lugar en la lista de elegibles de la OPEC 67261 y, después del nombramiento en período de prueba de las dos personas que lograron acceder a los dos cargos ofrecidos en esa OPEC, quedó en “primer lugar”⁶ para ser nombrada en una de las vacantes definitivas del cargo “auxiliar administrativo” que habrían surgido con posterioridad a la Convocatoria 1241 de 2019 en el Municipio de Tibasosa (Boyacá). Esa posibilidad de ser nombrada en un cargo que no había sido ofrecido estaría sustentada en el numeral 4 del artículo 6 de la Ley 1960 de 2019⁷, el cual establece que la lista de elegibles de una convocatoria, que tiene vigencia de dos años, se puede usar para proveer cargos equivalentes que no fueron ofrecidos para concurso de méritos y que surjan con posterioridad a la convocatoria respectiva.

8. El 2 de mayo de 2022, la alcaldesa de Tibasosa (Boyacá) resolvió de manera negativa el recurso reposición presentado por la accionante⁸. Señaló que: (i) según criterio unificado de la CNSC de 16 de enero de 2020⁹ y concepto 217781 de 5 de junio de 2020 emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP)¹⁰, el numeral 4 del artículo 6 de la Ley 1960 de 2019 sólo entró en vigencia el 27 de junio de 2019 cuando se publicó la ley, por lo que no puede ser aplicado al caso concreto debido a que la Convocatoria 1241 de 2019 se hizo el 14 de mayo de

⁴ Ibidem., Resolución 132 de 2022 de la alcaldía del municipio de Tibasosa (Boyacá), pp. 10-11.

⁵ Ibidem., Recurso de reposición. Pp. 22-27.

⁶ Expediente T-9.041.640. “1_15806408900120220012400-(2022-09-26 14-18-50)-1664219930-1”. Respuesta recurso de reposición, p. 7.

⁷ “Artículo 6. El numeral 4 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, quedará así: ‘Artículo 31. El proceso de selección comprende: (...) 4. Con los resultados de las pruebas la Comisión Nacional del Servicio Civil o la entidad contratada, por delegación de aquella, elaborará en estricto orden de mérito la lista de elegibles que tendrá una vigencia de dos (2) años. Con esta y en estricto orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso y las vacantes definitivas de cargos equivalentes no ofrecidos, que surjan con posterioridad a la convocatoria del concurso en la misma Entidad.’”

⁸ Expediente T-9.041.640. “1_15806408900120220012400-(2022-09-26 14-18-50)-1664219930-1”. Respuesta recurso de reposición, pp. 28-38.

⁹ CNSC, Criterio Unificado “Uso de listas elegibles en el contexto de la Ley 1960 del 27 de junio de 2019”. Disponible en: <https://www.cnsc.gov.co/sites/default/files/2021-06/CRITERIOUNIFICADOUSODELISTASDEELEGIBLESENELCONTEXTOLELLEY1960DE2019.PDF>

¹⁰ DAFP, Concepto 20206000- 21778. Proceso de Selección y/o concurso de méritos. 14 de mayo de 2020. Disponible: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=136355>

2019; y, (ii) al momento de iniciar el proceso de selección de la Convocatoria 1241 de 2019, la señora Rojas Pérez no tenía calidad de prepensionada, y su cargo lo ocupaba en provisionalidad, razón por la cual tenía una estabilidad laboral relativa que debe ceder a la provisión del cargo que se realiza en virtud de un concurso de méritos. En este caso, su desvinculación obedeció a una razón objetiva que fue descrita de manera detallada en la motivación de la Resolución 132 de 22 de marzo de 2022 para garantizar el derecho de contradicción.

9. Según certificación de 14 de febrero de 2023¹¹ suscrita por la Jefe de Talento Humano de la alcaldía de Tibasosa (Boyacá), en marzo de 2022, cuando fue emitida la Resolución 132 de 22 de marzo de 2022 por medio de la cual se desvinculó a la señora Rojas Pérez de su cargo, no había cargos en vacancia definitiva dentro de la planta de personal del municipio. De igual forma, conforme a la certificación emitida por la misma dependencia, con corte a 31 de mayo de 2022¹², dos meses después de la desvinculación de la accionante, los cargos de “auxiliar administrativo”, código 407, grado 09, se encontraban ocupados por personas cobijadas con la protección por estabilidad laboral reforzada, ya por ser madres cabeza de familia, ya por ser prepensionadas, además de otra que era cuidadora de una persona en situación discapacidad.

2. Solicitud de protección constitucional

10. El 12 de mayo de 2022, la señora Rojas Pérez, en nombre propio, solicitó la tutela de sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y al acceso a cargos públicos de carrera, que habrían sido vulnerados por la desvinculación del cargo que desempeñaba. Afirmó que dicha desvinculación desconoció la garantía a la estabilidad laboral reforzada en su calidad de prepensionada y madre cabeza de familia, ocasionando perjuicios irremediables que afectaron el mínimo vital de ella y de su hija menor de edad.

11. Señaló que la Alcaldía desconoció (i) su estabilidad laboral reforzada por su calidad de prepensionada, y (ii) el artículo 6 de la Ley 1960 de 2019 que establece que la lista de elegibles conformada luego de un proceso de selección puede ser usada para proveer vacancias definitivas¹³ de cargos equivalentes que no hicieron parte del proceso pero que surgen después de la convocatoria pública realizada.

12. Afirmó que, después de provistos los dos empleos de la OPEC 67261, ella quedó en el “primer puesto” de la lista y debe ser ubicada en uno de los cargos que habría quedado vacante después de iniciado el proceso de selección a través del concurso de méritos. Aseguró que si bien no tenía la calidad de prepensionada cuando inició el proceso de selección de la Convocatoria 1241 de 2019, ella obtuvo esa calidad con el paso del tiempo gracias al servicio público que prestó en el Municipio de Tibasosa (Boyacá) y que al momento de presentar la solicitud de tutela solo le faltaba un año y seis meses para cumplir los requisitos para acceder a la pensión de vejez.

13. Por lo anterior, solicitó ordenar a esa Alcaldía que revoque solamente el artículo tercero de la Resolución 132 de 22 de marzo de 2022, por medio del cual se terminó su vinculación al cargo de “auxiliar administrativo”, en provisionalidad,

¹¹ Expediente T-9.041.640. “Consolidado salida 0309”. Certificación del 14 de febrero, pp. 17-20

¹² Expediente T-9.041.640. “Pruebas enviadas honorable corte constitucional”, p. 25.

¹³ La vacancia definitiva en los términos del artículo el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, hace referencia a los cargos que pueden estar siendo desempeñados de manera temporal por un funcionario nombrado en encargo o de forma provisional.

y que la restablezca en dicho cargo, “sin solución de continuidad”; o en su defecto, como pretensión subsidiaria¹⁴, que se le nombre en período de prueba, en un cargo vacante de “auxiliar administrativo”, código 407, grado 09, de la planta del Municipio de Tibasosa (Boyacá) porque actualmente se encuentra en el “primer lugar”¹⁵ de la lista de elegibles para ser nombrada. Con respecto a esa última pretensión, la accionante sostiene que hay varios cargos de igual nivel en vacancia definitiva¹⁶, lo que significaría, en virtud del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, que pueden estar siendo desempeñados de manera temporal a través de funcionarios en encargo o con nombramiento provisional.

14. Para una mejor comprensión de la solicitud de amparo, es importante precisar que en la solicitud no se cuestiona, de ninguna forma, el proceso de selección desarrollado con ocasión de la Convocatoria 1241 de 2019, ni la legalidad de la Resolución 132 de 22 de marzo de 2022 en cuanto al nombramiento de la señora Diana María Sierra.

3. Trámite procesal de instancia

15. La solicitud de tutela le correspondió al Juzgado Promiscuo Municipal de Tibasosa que, en Auto de 12 de mayo de 2022, la admitió y vinculó a la CNSC, a la señora Diana María Sierra Ortiz -quien fue la persona nombrada en período de prueba para ocupar el cargo que desempeñaba la accionante-, y a las demás personas que participaron en la Convocatoria 1241 de 2019 para proveer los dos cargos de la OPEC 67261 y con las cuales se conformó la lista de elegibles. También, ordenó notificar la admisión de la tutela a la Personería del municipio de Tibasosa (Boyacá) para que, en su condición de agente del Ministerio Público, rindiera concepto en caso de considerarlo necesario.

4. Oposición en instancia

16. En escrito radicado el 16 de mayo de 2022, a través de apoderada, la alcaldesa de Tibasosa (Boyacá) rindió informe sobre la acción de tutela presentada en el que solicitó negar las pretensiones de la accionante ya que no se demostró un perjuicio irremediable en su contra y cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para solicitar la “revocatoria”¹⁷ de la Resolución 132 de 22 de marzo de 2022.

17. Explicó que: (i) la Convocatoria 1241 de 2019 inició el proceso de selección el 14 de mayo de 2019 mientras que la Ley 1960 de 2019 entró en vigencia el 27 de junio de 2019. El numeral 4 del artículo 6 de dicha Ley establece que con la lista de elegibles se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso y las vacantes definitivas de cargos equivalentes no ofrecidos que surjan con posterioridad a la convocatoria del concurso en la misma entidad, en estricto orden de mérito. Sin embargo, no prevé su aplicación retroactiva, a procesos ya iniciados,

¹⁴ Si bien la accionante no la cataloga como una pretensión subsidiaria, al ser contradictoria con la primera pretensión se presenta bajo esa categoría. Expediente T-9.041.640. “1_15806408900120220012400-(2022-09-26 14-18-50)-1664219930-1”. Respuesta recurso de reposición, p. 7.

¹⁵ Ibidem.

¹⁶ “Artículo 2.2.5.3.1 Provisión de las vacancias definitivas. (...) Las vacantes definitivas en empleos de carrera se proveerán en periodo de prueba o en ascenso, con las personas que hayan sido seleccionadas mediante el sistema de mérito, de conformidad con lo establecido en la Ley 909 de 2004 o en las disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera, según corresponda. Mientras se surte el proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto Ley 760 de 2005 o en las disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera. (...)” (énfasis añadido)

¹⁷ Expediente T-9.041.640. “4_15806408900120220012400-(2022-09-26 14-19-27)-1664219967-4”. Contestación acción de tutela, pp. 4-15.

de acuerdo con el criterio unificado de la CNSC de 16 de enero de 2020, y el concepto 217781 de 2020 del DAFP. Además, (ii) la prohibición de ofrecer para concurso de méritos los cargos ocupados por funcionarios en provisionalidad que tuvieran la calidad de prepensionados fue introducida por la Ley 1955 de 2019, también con posterioridad al inicio del proceso de selección de la Convocatoria 1241 de 2019. Advirtió, en todo caso, que la accionante no ostentaba la calidad de prepensionada al momento de ofrecerse su cargo para el concurso de méritos de la Convocatoria 1241 de 2019.

18. Agregó que: (iii) varios conceptos del DAFP¹⁸ indican, entre otros asuntos, que los servidores públicos que ocupan un cargo en provisionalidad gozan de una estabilidad laboral relativa, lo que implica que pueden ser removidos del cargo por causales legales y objetivas que deben ser expresadas de manera clara en la decisión de desvinculación. Así, el funcionario que ocupa el cargo en provisionalidad debe cederlo a la persona que ocupe el primer lugar en la lista de elegibles ya que el mérito es el factor que determina el ingreso y la permanencia en el sector público; (iv) la acción de tutela es improcedente porque en la sentencia SU-498 de 2016 se estableció que la nulidad y el restablecimiento del derecho es el medio de control judicial de los actos de carácter particular que profiere la administración pública; a su turno, (v) la sentencia T-464 de 2019 indicó que los funcionarios en provisionalidad que son sujetos de especial protección constitucional gozan de una estabilidad laboral reforzada pero pueden ser desvinculados con el propósito de proveer el cargo que ocupan con una persona que haya ganado un concurso de méritos, pues el derecho del funcionario en provisionalidad cede frente al derecho de quien obtuvo un resultado positivo en el concurso; y, (vi) con base en la sentencia T-554 de 2019 no se configura perjuicio irremediable en el presente caso porque la accionante no es una persona de avanzada edad, ni ella ni su familia tienen deterioro de salud, y no acreditó ser madre cabeza de familia.

5. Intervención de las entidades y las personas vinculadas al proceso de tutela

19. La CNSC¹⁹, en calidad de vinculada, señaló que: (i) no se demostró la inminencia, urgencia, gravedad, ni el carácter impostergable de la acción de tutela, motivo por el cual no se configuró un perjuicio irremediable; (ii) la accionante ocupó el tercer puesto de la lista de elegibles de la OPEC 67261, y no sería posible nombrarla en el cargo ofrecido porque se vulnerarían los derechos al debido proceso, a la igualdad, al libre acceso a cargos públicos, al mérito, a la libre concurrencia, y a la transparencia e imparcialidad de quienes ocuparon la posición de elegibles en la OPEC 67261; (iii) quienes resultaron elegidos adquirieron un derecho que no se puede desconocer; (iv) los artículos 2.2.12.1.2.1 y 2.2.12.1.2.2. del Decreto 1082 de 2015, que establecen una estabilidad laboral reforzada a favor de madres cabeza de familia y prepensionados, tienen efectos para los servidores públicos activos que requieren protección especial, pero no se extiende para los aspirantes inscritos en el proceso de selección de la Convocatoria; (v) la provisión de los empleos públicos, con excepción de quienes son funcionarios de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los trabajadores oficiales y los demás que determine la Ley, se debe fundamentar única y exclusivamente en el mérito según el artículo 125 de la Constitución y los artículos 27 y 28 de la Ley 909 de 2004; (vi) según las sentencias SU-446 de 2011 y T-595 de 2016 de la Corte Constitucional, y el Concepto Marco 9 de 2019 del DAFP, los empleados en

¹⁸ DAFP. Conceptos 145521 de 2020, 161571 de 2020, 59401 de 2021 y 228281 de 2021.

¹⁹ Expediente T-9.041.640. “3_15806408900120220012400-(2022-09-26 14-19-13)-1664219953-3”. Informe de la CNSC frente a la acción de tutela, pp. 3-13

provisionalidad que se encuentran en situaciones de especial protección constitucional no tienen un derecho a permanecer de manera indefinida en el cargo; y (vii) no toda circunstancia que afecte un derecho configura un perjuicio irremediable, pues se exige un grado de certeza suficiente sobre la inminencia, urgencia, gravedad y el carácter impostergable del amparo que reclama la accionante.

20. La señora Grace Elena Angarita Royero²⁰, quien ocupó el primer puesto de la lista de elegibles de la Convocatoria 1241 de 2019 y fue vinculada al proceso para que se pronunciara sobre los hechos de la tutela, aseguró que fue notificada para tomar posesión de su cargo en período de prueba por seis meses, y que se posesionó el 1º de abril de 2022.

21. La señora Diana María Sierra Ortiz²¹, quien ocupó el segundo puesto de la lista de elegibles de la Convocatoria 1241 de 2019 y fue vinculada al proceso para obtener su pronunciamiento sobre la tutela, señaló que el 28 de marzo de 2022 aceptó su nombramiento, y que el 1º de abril siguiente se posesionó en el cargo para un período de prueba de seis meses. También, precisó que su nombramiento, contrario a lo que señaló el juez en el auto de admisión, no es en provisionalidad sino con derechos de carrera administrativa.

22. El señor Marco Isidro Rojas Rojas²², quien participó en la Convocatoria 1241 de 2019 ocupando el puesto sexto en la lista de elegibles y fue vinculado al proceso para pronunciarse sobre los hechos de la tutela, afirmó que no conoce la situación personal de la accionante, ni el estado y vinculación laboral que tiene con la administración municipal.

23. La Personería del Municipio de Tibasosa (Boyacá) no intervino.

6. Decisiones judiciales objeto de revisión

6.1. Decisión de primera instancia

24. El Juzgado Promiscuo Municipal de Tibasosa, mediante sentencia de 26 de mayo de 2022²³, concedió el amparo constitucional invocado por la señora Rojas Pérez. Sin embargo, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Duitama decretó *“la nulidad de todo lo actuado por el Juzgado Promiscuo Municipal de Tibasosa (Boyacá), a partir del emitido el 26 de mayo de 2022, inclusive, conservando valor las pruebas recaudadas”*, y devolvió el expediente para que se subsanara la indebida integración del contradictorio por considerar que debía vincularse a la Universidad Nacional de Colombia por ser la entidad que hizo las pruebas de aptitud en la Convocatoria 1241 de 2019. En consecuencia, mediante Auto de 9 de junio de 2022²⁴, el Juzgado Promiscuo Municipal de Tibasosa vinculó a la Universidad Nacional de Colombia y le dio traslado de la acción de tutela, sin obtener respuesta.

²⁰ Expediente T-9.041.640. “8_15806408900120220012400-(2022-09-26 14-20-24)-1664220024-8”. Pronunciamiento sobre la tutela, de Grace Angarita Royero, pp. 2-3.

²¹ Expediente T-9.041.640. “5_15806408900120220012400-(2022-09-26 14-19-41)-1664219981-5”. Pronunciamiento sobre la tutela, de Diana María Sierra, pp. 2-5.

²² Expediente T-9.041.640. “6_15806408900120220012400-(2022-09-26 14-19-51)-1664219991-6”. Pronunciamiento sobre la tutela, de Marco Isidro Rojas, pp. 2-3.

²³ Expediente T-9.041.640. “9_15806408900120220012400-(2022-09-26 14-20-38)-1664220038-9”. Sentencia del 26 de mayo de 2022, pp. 1-16.

²⁴ Expediente T-9.041.640. “7_15806408900120220012400-(2022-09-26 14-20-05)-1664220005-7”, Auto del 9 de junio de 2022, pp. 1-2.

25. Mediante sentencia de 14 de junio de 2022, el Juzgado Promiscuo Municipal de Tibasosa amparó los derechos de la señora Rojas Pérez, y ordenó al Municipio de Tibasosa (i) su reincorporación a un cargo vacante con funciones similares o equivalentes a las que desempeñaba; y (ii) el pago de los salarios y aportes dejados de pagar hasta que cumpla los requisitos para obtener la pensión de vejez.

26. Por un lado, sostuvo que el amparo era procedente para evitar un perjuicio irremediable mientras se surte el proceso en la jurisdicción contencioso-administrativa, espera durante la cual se vería en riesgo el mínimo vital de la accionante y su familia.

27. Por otro lado, concluyó que si bien cuando inició el proceso de selección de la Convocatoria 1241 de 2019 la accionante estaba a más de tres años de cumplir los requisitos para obtener su pensión, esa situación cambió cuando se conformó la lista de elegibles de la Convocatoria en marzo de 2022, momento en el cual ya tenía la calidad de prepensionada y la expectativa de gozar de su derecho pensional. Por tanto, previo a su desvinculación, la alcaldía de Tibasosa debió adoptar medidas para garantizar sus derechos tales como nombrar a los elegibles en cargos diferentes al ocupado por la accionante, teniendo en cuenta su condición de madre cabeza de familia y que su sustento dependía de su vinculación laboral.

28. Finalmente, argumentó que los derechos fundamentales de la accionante también se vieron afectados cuando, después de proveer los cargos ofrecidos, no se adoptaron medidas para evitar la desvinculación de la accionante a pesar de existir cargos vacantes. Explicó que, si bien no se obtuvo una certificación de la existencia de esas vacantes disponibles, la alcaldía de Tibasosa no desvirtuó en el proceso la afirmación que hizo la accionante, en su solicitud de amparo, sobre la disponibilidad de esos cargos:

“Empero, si bien no se allegó una certificación sobre la existencia de otras vacantes en cargos similares al que ocupaba la accionante, en los hechos de la acción la misma afirmó que con posterioridad a haberse abierto la convocatoria respectiva por la Comisión Nacional del Servicio Civil, se produjo la vacancia de algunos otros cargos ante el reconocimiento pensional de las personas que los ocupaban, afirmación que no fue desvirtuada por la administración, pues lo único que hizo la Alcaldía fue indicar que como quiera que los nuevos cargos no habían sido ofertados en esta convocatoria, no resultaba procedente su provisión mediante la lista de elegibles de la convocatoria en mención.

Para el Despacho, si bien, los cargos respecto de los cuales se produjo la vacancia con posterioridad a la expedición de la Convocatoria N° 1241 de 2019, no fueron ofertados en la misma, pues la convocatoria se abrió para proveer dos cargos que ya fueron provistos con las dos primeras personas de la lista de elegibles, ello no constituye razón suficiente para negar a la accionante el derecho a desempeñarse en alguno de ellos, en primer lugar por cuanto la administración no adoptó medidas para evitar la desvinculación de la accionante pese a su condición de pre pensionada, y, en segundo lugar, por cuanto se tiene certeza que la accionante también superó el concurso de méritos para ese tipo de cargos, encontrándose en el tercer lugar de la lista de elegibles y por consiguiente, es la persona que sigue en turno para ocupar cualquier vacante que se pueda producir en la administración municipal para dicho cargo”²⁵ (énfasis añadido).

²⁵ Ibidem., p. 15.

6.2. Impugnación

29. El 17 de junio de 2022²⁶, la alcaldía de Tibasosa solicitó revocar la decisión y, en su lugar, declarar improcedente la acción por las siguientes razones: (i) el Juzgado dio por probado, sin estar acreditado en el proceso, que la señora Rojas Pérez es madre cabeza de familia, que el salario que recibía era el único ingreso económico que tenía, y que su desvinculación podría causar un perjuicio irremediable; (ii) cuando inició la Convocatoria 1241 de 2019, para proveer dos cargos de “auxiliar administrativa” según la OPEC 67261, la señora Rojas Pérez no tenía la calidad de prepensionada y, por lo tanto, no gozaba de estabilidad laboral reforzada; (iii) la Alcaldía reportó a la CNSC que el cargo que ocupaba la señora Rojas Pérez sería ofrecido en el concurso de méritos de la Convocatoria 1241 de 2019 porque en ese momento no tenía la calidad de prepensionada; (iv) la accionante ocupó el tercer puesto en la lista de elegibles para la OPEC 67261, razón por la cual no ganó el derecho a ocupar alguno de los dos empleos ofrecidos para el cargo “auxiliar administrativo” en la Convocatoria 1241 de 2019; (v) la desvinculación de la señora Rojas Pérez obedeció a una razón objetiva; y (vi) se anexó certificación de la Jefe de Talento Humano de la entidad, fechada el 31 de mayo de 2022, donde aparece que tres funcionarias que ocupaban a esa fecha los cargos de “auxiliar administrativo”, código 407, grado 09, eran madres cabezas de familia, una de ellas prepensionada, y la restante era cuidadora de una persona en situación de discapacidad.

30. Explicó que (vi) la Ley 1960 de 2019 no se puede aplicar a la Convocatoria 1241 de 2019 porque entró en vigencia con posterioridad al inicio del proceso de selección y dicha ley no previó su aplicación retroactiva; (vii) la acción de tutela se presentó un “mes y veinte días”²⁷ después de notificada la Resolución 132 del 22 de marzo de 2022, razón por la cual no cumpliría el requisito de inmediatez; (viii) la tutela no cumplió el requisito de subsidiariedad porque la accionante debió acudir al medio de control la nulidad y el restablecimiento del derecho y tampoco probó la configuración de un perjuicio irremediable; y (ix) a la fecha de presentación de la impugnación, la accionante no había presentado el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución 132 de 22 de marzo de 2022, ni había solicitado la suspensión de los efectos del acto administrativo como medida cautelar.

6.3. Decisión de segunda instancia

31. En sentencia de 31 de agosto de 2022, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Duitama revocó la decisión de primera instancia y “negó por improcedente” la acción presentada por la señora Rojas Pérez. Sostuvo que: (i) la accionante contaba con los medios de control de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir el acto administrativo que reprochaba; (ii) el retiro de la accionante de su cargo obedeció al nombramiento en el cargo que desempeñaba la señora Diana María Sierra Ortiz, quien superó el concurso de méritos, razón objetiva y legítima para la desvinculación de la accionada; (iii) correspondía a la accionante informar a su nominador sobre las condiciones que la hacían sujeto de especial protección, no obstante lo cual no allegó prueba alguna que acredite su calidad de madre cabeza de familia. Subrayó que, en todo caso, la Corte

²⁶ Expediente T-9.041.640. “33_15806408900120220012400-(2022-11-02 14-10-37)-1667416237-33”. Impugnación de sentencia del 14 de junio de 2022, pp. 2-23.

²⁷ Expediente T-9.041.640. “33_15806408900120220012400-(2022-11-02 14-10-37)-1667416237-33”. Impugnación de sentencia del 14 de junio de 2022, p. 10.

Constitucional en la sentencia T-003 de 2018 señaló que no existe un derecho fundamental a permanecer en el cargo, pues los funcionarios pueden ser separados del servicio cuando se convoca un concurso para proveer la plaza de manera definitiva. Finalmente, sostuvo que (iv) no corresponde al Juez de tutela decidir sobre reintegros a cargos públicos.

7. Actuaciones en sede de revisión

7.1. Selección y reparto del expediente

32. En Auto de 29 de noviembre de 2022 la Sala de Selección de Tutelas Nro. 11 de la Corte Constitucional resolvió seleccionar el expediente de la referencia para su revisión y lo repartió a la Sala Cuarta de Revisión para su decisión, la cual se encontraba presidida por el magistrado sustanciador. Posteriormente, mediante el Acuerdo 1º de 7 de diciembre de 2022, la Sala Plena de la Corte Constitucional determinó una nueva conformación de las Salas de Revisión a partir del 11 de enero de 2023, correspondiéndole al magistrado sustanciador presidir la Sala Sexta de Revisión.

7.2. Pruebas practicadas en sede de revisión de la tutela

33. En Auto de 7 de febrero de 2023, la Sala ordenó la práctica de pruebas e informó a las partes que, una vez recibidas, se pondrían a su disposición. El 2 de marzo de 2023, la Secretaría General de la Corte Constitucional allegó al despacho del magistrado sustanciador el informe de ejecución del Auto mencionado²⁸.

7.3. Información aportada por el Municipio de Tibasosa (Boyacá)

34. La apoderada de la alcaldía de Tibasosa (Boyacá) allegó comunicación el 15 de febrero de 2023²⁹ en la que manifestó que: (i) a la fecha de inicio del proceso de selección de la Convocatoria 1241 el 14 de mayo de 2019, la accionante no ostentaba la calidad de prepensionada; (ii) se nombraron en el cargo de “auxiliar administrativa” a las dos personas que ocuparon los dos primeros puestos de la lista de elegibles; la accionante ocupó el tercer lugar por lo que no fue nombrada en ninguno de los empleos ofertados; (iii) en cumplimiento de la sentencia de tutela de primera instancia, la alcaldía de Tibasosa inició gestiones para reincorporar a la señora Rojas Pérez a un cargo con funciones similares o equivalentes al que desempeñaba. Verificada la planta de personal se constató la ausencia de cargos vacantes. Por consiguiente, el 29 de agosto de 2022 se emitió el Decreto municipal 72, mediante el cual se creó un cargo de “auxiliar administrativo”, código 407, grado 9, con el fin de dar cumplimiento a la sentencia de tutela de primera instancia y posesionar así a la accionante en ese cargo temporal. Ese mismo día también se emitió el Decreto municipal 73, por medio del cual se nombró a la señora Rojas Pérez en el cargo temporal que fue creado. Pero, (iv) revocada la sentencia de primera instancia, la alcaldía del municipio de Tibasosa revocó los Decretos municipales 72 y 73 de 29 de agosto de 2022.

35. Finalmente anexó (v) certificación de la Jefe de Talento Humano de la alcaldía de Tibasosa³⁰, de 15 de febrero de 2023, para acreditar que una vez verificada la hoja de vida de la señora Rojas Pérez no se encontró comunicación en

²⁸ Expediente T-9.041.640. “Informe de pruebas auto 7-2-23”.

²⁹ Expediente T-9.041.640. “Consolidado salida 0309”. Informe de la alcaldía de Tibasosa (Boyacá), pp. 1-15.

³⁰ Expediente T-9.041.640. “Consolidado salida 0309”. Certificación del 15 de febrero, p. 16.

la que manifieste sobre la calidad de prepensionada, ni de madre cabeza de familia; (vi) certificación de la Jefe de Talento Humano del Municipio de Tibasosa³¹, de 14 de febrero de 2023, según la cual hay siete (7) cargos de “auxiliar administrativo”, código 407, grado 9, en la entidad y están ocupados por tres funcionarios con derechos de carrera administrativa, y por cuatro funcionarios nombrados en provisionalidad, de los cuales una funcionaria tiene la calidad de prepensionada. También, la certificación señala que, en marzo de 2022, cuando se realizó la desvinculación de la accionante, a través de Resolución 132 de 22 de marzo de 2022, no había ningún cargo en vacancia definitiva dentro de la planta de personal de la alcaldía del municipio.

7.4. Información aportada por la accionante

36. Mediante correo electrónico de 15 de febrero de 2023, la accionante informó que no cuenta con servicio de salud para ella ni para su hija menor de edad. Además, allegó: (i) copia de los Decretos municipales 72 y 73 de 2022 mediante los cuales se creó un cargo temporal de “auxiliar administrativa”, código 407, grado 9, y se le nombró en ese cargo; y copia de los Decretos municipales 77 y 78 del 2022, mediante los cuales se revocó la creación del cargo y su nombramiento; (ii) planilla de autoliquidación de aportes al sistema general de seguridad social correspondiente a la cotización de octubre de 2022, en la que aparece la novedad de “retiro”; y, (iii) copia del registro civil de nacimiento de su hija Daniela Faura Rojas.

7.5. Respuesta del Municipio de Tibasosa (Boyacá) al traslado de pruebas

37. El 23 de febrero de 2022³², la apoderada de la alcaldía de Tibasosa (Boyacá) aseguró que: (i) la señora Rojas Pérez no presentó prueba de su calidad de madre cabeza de familia; (ii) el registro civil de la hija de la accionante no demuestra que sea madre cabeza de familia, o que es la única persona que tiene a cargo el cuidado, manutención o sostenimiento de la niña; (iii) la accionante debió solicitar su reubicación al nominador y no directamente al juez constitucional, pues, en todo caso, el competente es el juez contencioso-administrativo; (iv) la desvinculación de la accionante, y de su hija menor de edad del sistema general de seguridad social ocurrió en febrero de 2023 según la base de datos de la Administradora de los Recursos del Sistema General de la Seguridad Social en Salud (ADRES). Lo anterior demuestra que ella continuó haciendo sus aportes al sistema de seguridad social en salud después de su desvinculación; y, (v) las pruebas aportadas por la accionante el 15 de febrero de 2023, al no haber sido decretadas en el Auto de pruebas, se presentaron con violación al debido proceso y son nulas de conformidad con los artículos 164 y 168 de la Ley 1564 de 2012.

7.6. Respuesta de la accionante al traslado de pruebas

38. El 22 de febrero de 2023, la accionante aseguró que: (i) presentó recurso de reposición en contra de la Resolución 132 de 22 de marzo de 2022 por medio de la cual fue desvinculada de su cargo, al cual anexó copia de su cédula de ciudadanía, reporte de semanas cotizadas a Colpensiones y registro civil de su hija menor de edad; (ii) el Decreto municipal 43 de 4 de junio de 2019 que define la planta de personal de la alcaldía del municipio de Tibasosa indica que hay seis cargos de “auxiliar administrativo”, código 407, grado 9. Para 4 de junio de 2019, cuatro de

³¹ Expediente T-9.041.640. “Consolidado salida 0309”. Certificación del 14 de febrero, pp. 17-20.

³² Expediente T-9.041.640. “Pronunciamiento de pruebas”, pp. 1-29.

esos cargos estaban provistos por funcionarios con derechos de carrera administrativa y dos estaban en provisionalidad, uno de ellos ocupado por la accionante. Para el 30 de marzo de 2022, solo había una funcionaria con derechos de carrera administrativa y cinco en provisionalidad pues tres funcionarias con derechos de carrera administrativa habían obtenido su pensión de vejez; (iii) tiene derecho a obtener uno de los cargos que están en vacancia definitiva y que se encuentran ocupados temporalmente con funcionarios en provisionalidad³³, pues ella sigue en el orden de la lista de elegibles; (iv) la Jefe de Talento Humano de la alcaldía de Tibasosa, certificó que el 31 de mayo de 2022 había una vacancia definitiva ocupada por una funcionaria en provisionalidad. Adjuntó certificación de 31 de mayo de 2022³⁴ donde aparece que cuatro funcionarias que ocupan el cargo de “auxiliar administrativo”, código 407, grado 9, están nombradas en provisionalidad. El documento también certifica que tres de ellas son madres cabeza de familia y la restante es una persona en situación de discapacidad; (v) que la alcaldesa y la Jefe de Talento Humano del Municipio de Tibasosa no buscaron mecanismos para reubicarla aun existiendo cargos en vacancia definitiva ocupados con funcionarios en provisionalidad y que podían ser provistos con la lista de elegibles de la Convocatoria 1241 de 2019, según el numeral 4 del artículo 6 de la Ley 1960 de 2019; (vi) en 2019 no contaba con la edad para ser prepensionada porque le faltaban más de cuatro años de tiempo de servicios para obtener esa calidad; y, (vi) presentó acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable como el que está soportando junto a su hija en la actualidad, sin salario, servicio médico ni seguridad social.

7.7. Respuesta de la señora Diana María Sierra al traslado de pruebas

39. El 24 de febrero de 2023³⁵, la señora Diana María Sierra aseguró que el 28 de marzo de 2022 aceptó su nombramiento en el cargo “auxiliar administrativo”, código 407, grado 9, que hizo la alcaldía de Tibasosa luego de realizada la Convocatoria 1241 de 2019, y que el 1º de abril de 2022 se posesionó en el cargo para un período de prueba de seis meses. Informó, igualmente, que luego de los seis meses del período de prueba obtuvo una calificación definitiva “sobresaliente”³⁶, razón por la cual fue nombrada de manera definitiva mediante el Decreto municipal 90 de 20 de octubre de 2022 en el cargo mencionado, en el cual se posesionó obteniendo sus derechos de carrera administrativa según acta 29 de 20 de octubre de 2022.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

40. La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, con fundamento en los artículos 86, inciso segundo, y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, y 31 a 36 del Decreto Ley 2591 de 1991, es competente para revisar las decisiones judiciales proferidas dentro del proceso de tutela de la referencia.

³³ Los cargos en vacancia definitiva se pueden proveer temporalmente con funcionarios nombrados en provisionalidad: “Artículo 2.2.5.3.1 Provisión de las vacancias definitivas. (...) *Las vacantes definitivas en empleos de carrera se proveerán en periodo de prueba o en ascenso, con las personas que hayan sido seleccionadas mediante el sistema de mérito, de conformidad con lo establecido en la Ley 909 de 2004 o en las disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera, según corresponda. Mientras se surte el proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto Ley 760 de 2005 o en las disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera. (...)*” (énfasis añadido)

³⁴ Expediente T-9.041.640. “Pruebas enviadas honorable corte constitucional”, p. 25.

³⁵ Expediente T-9.041.640. “Respuesta Oficio OPTB-041.640-2023_0001”, p. 1-2.

³⁶ Ibidem, p. 2.

2. Delimitación del problema jurídico y estructura de la decisión

41. A pesar de que la solicitud de tutela no es clara en tanto plantea pretensiones contradictorias, resulta razonable interpretar que la accionante solicita la protección de su derecho a la estabilidad laboral reforzada, la cual se habría visto afectada por la desvinculación del cargo que desempeñaba³⁷ (i) sin tener en cuenta su calidad de prepensionada, y (ii) sin dar aplicación al artículo 6 de la Ley 1960 de 2019 que le permitiría ocupar otro cargo de “auxiliar administrativo” del Municipio por ser la siguiente en la lista de elegibles, ya que ocupó el tercer puesto en la Convocatoria 1241 de 2019 realizada para proveer dos de esos cargos. El daño causado, según la solicitud de amparo, habría consistido en la disminución de su sustento económico y de su hija menor edad, ya que tiene la calidad de madre cabeza de familia.

42. En consecuencia, la señora Rojas Pérez pretende que se le ordene a la Alcaldía revocar el artículo tercero de la Resolución 132 de 22 de marzo de 2022, por medio del cual se terminó su vinculación al cargo de “auxiliar administrativo”, en provisionalidad, y que sea restablecida en dicho cargo “sin solución de continuidad”. La solicitud de protección, en todo caso, está limitada en el tiempo en tanto se encuentra condicionada al cumplimiento de la cotización mínima de semanas para acceder a la pensión de vejez. En su defecto³⁸, que se le nombre en período de prueba para lograr obtener los derechos de carrera administrativa, en un cargo vacante de “auxiliar administrativo” de la planta del Municipio de Tibasosa (Boyacá) porque actualmente se encuentra en el “primer lugar”³⁹ de la lista de elegibles para ser nombrada.

43. El Juzgado Promiscuo Municipal de Tibasosa concedió el amparo porque: (i) la accionante al momento de conformarse la lista de elegibles de la Convocatoria 1241 de 2019, en marzo de 2022, tenía la calidad de prepensionada; y, (ii) como la Alcaldía no desvirtuó en el proceso de tutela la afirmación de la accionante sobre la existencia de cargos vacantes de “auxiliar administrativo”, se debe entender que existen esos cargos y que, a pesar de no haber sido ofrecidos en la Convocatoria 1241 de 2019, pueden ser provistos con la lista de elegibles que resultó de la Convocatoria para la OPEC 67261.

44. Impugnada la decisión por la Alcaldía, el Juzgado Promiscuo Civil del Circuito de Duitama revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, “negó por improcedente” la acción de tutela. Argumentó que (i) la accionante cuenta con otros mecanismos de defensa judicial, eficaces e idóneos, para controvertir su desvinculación, en especial los medios de control de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho; (ii) la desvinculación de la accionante obedeció a una razón objetiva y legítima ya que resultó del nombramiento de la señora Sierra Ortiz quien superó el concurso de méritos de la Convocatoria 1241 de 2019; (iii) el juez de tutela no puede ordenar el reintegro de la accionante al servicio público porque esa función le compete al nominador; y, (iv) no se allegó prueba que acredite que la accionante es madre cabeza de familia.

³⁷ Expediente T-9.041.640. “1_15806408900120220012400-(2022-09-26 14-18-50)-1664219930-1” Acción de tutela, pp. 1-2. Esa violación a la estabilidad laboral reforzada tiene relación con sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, al y al acceso a cargos públicos de carrera.

³⁸ Si bien la accionante no la cataloga como una pretensión subsidiaria, al ser contradictoria con la primera pretensión se puede calificar bajo esa categoría. Expediente T-9.041.640. “1_15806408900120220012400-(2022-09-26 14-18-50)-1664219930-1”. Respuesta recurso de reposición, p. 7.

³⁹ Ibidem.

45. En consecuencia, corresponde a la Sala revisar si las sentencias de tutela proferidas el 31 de agosto de 2022 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Duitama, en segunda instancia, y el 14 de junio de 2022 por el Juzgado Promiscuo Municipal de Tibasosa, en primera instancia, se encuentran ajustadas a derecho en los términos de los artículos 31 a 36 del Decreto Ley 2591 de 1991. En caso de ser revocadas se determinará si la alcaldía del municipio de Tibasosa (Boyacá) vulneró la estabilidad laboral reforzada de la señora Rojas Pérez al ser desvinculada de su cargo de “auxiliar administrativo” y si el tercer puesto que ocupó en la lista de elegibles conformada en la Convocatoria 1241 de 2019 le otorga el derecho a ser nombrada en un cargo igual o similar al de la OPEC 67261, mientras la lista siga vigente.

46. Al efecto, la Sala (3) demostrará que se cumplen los requisitos de procedencia de la solicitud de tutela, (4) expondrá las razones por las que las sentencias revisadas no se encuentran ajustadas a derecho y deben ser revocadas, y (5) decidirá el caso concreto.

3. Análisis de los requisitos de procedencia de la acción de tutela

3.1. Legitimación en la causa de la parte activa

47. El artículo 86 superior establece que la acción de tutela es un mecanismo al que puede acudir cualquier persona para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales. Por su parte, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991 dispone que *“La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante”*.

48. En este caso se cumple el requisito porque la señora Rojas Pérez actuó en nombre propio⁴⁰ y es la persona que se considera vulnerada en su estabilidad laboral reforzada al ser desvinculada del cargo que desempeñaba sin tener en cuenta que tenía la calidad de prepensionada y al no haberse dado aplicación al artículo 6 de la Ley 1960 de 2019 que le permitiría ocupar otro cargo de “auxiliar administrativo” de la Alcaldía por ser la siguiente en la lista de elegibles.

3.2. Legitimación en la causa en la parte pasiva

49. El mismo artículo 86 superior y los artículos 1º y 5 del Decreto Ley 2591 de 1991 establecen que la acción de tutela procede contra cualquier autoridad pública e incluso contra particulares. Así, la legitimación por pasiva se entiende como la aptitud procesal que tiene la persona contra la que se dirige la acción y quien está llamada a responder por la vulneración o la amenaza del derecho fundamental cuando alguna resulte demostrada.

50. En el caso bajo análisis se cumple el requisito porque la tutela se presentó contra la alcaldía de Tibasosa (Boyacá), por ser la entidad que desvinculó de su cargo a la accionante y por no haber dado aplicación al artículo 6 de la Ley 1960 de 2019 que le permitiría ocupar otro cargo de “auxiliar administrativo”.

3.3. Inmediatez

⁴⁰ Expediente T-9.041.640. “1_15806408900120220012400-(2022-09-26 14-18-50)-1664219930-1”. Acción de tutela, p. 1.

51. La acción de tutela es un mecanismo expedito que busca garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares. Así, uno de los requisitos para evaluar su procedencia es la inmediatez. Lo anterior significa que, si bien la tutela puede formularse en cualquier tiempo, su interposición debe hacerse dentro de un plazo razonable y proporcionado a partir del evento generador de la supuesta amenaza o violación de los derechos fundamentales so pena de que se determine su improcedencia⁴¹.

52. En este caso se cumple con la exigencia de inmediatez porque la solicitud de tutela fue radicada para su trámite judicial el 12 de mayo de 2022, en contra de la decisión adoptada el 2 de mayo anterior que confirmó la desvinculación de la accionante, contenida en la Resolución 132 de 22 de marzo del mismo año, y que también negó la aplicación del artículo 6 de la Ley 1960 de 2019 para que se nombrara a la accionante en un cargo equivalente a los ofrecidos en el proceso de selección de la Convocatoria 1241 de 2019 y que habría quedado en vacancia definitiva después de surtido el proceso⁴². Contrario a lo sostenido en la impugnación del fallo de tutela por parte de la alcaldía de Tibasosa (Boyacá), el estudio del término razonable para presentar la solicitud de amparo no se debe contar, en este caso, desde la notificación de la Resolución 132 de 22 de marzo de 2022, sino desde cuando se resolvió el recurso de reposición que la accionante presentó contra dicha decisión; es decir, desde el 2 de mayo de 2022, ya que en ese momento la accionante conoció la respuesta definitiva a su solicitud de vinculación al servicio público en aplicación del artículo 6 de la Ley 1960 de 2019.

3.4. Subsidiariedad

53. De acuerdo con los artículos 86 superior y 6 del Decreto Ley 2591 de 1991, la acción de tutela está revestida de un carácter subsidiario. El principio de subsidiariedad determina que dicho mecanismo de protección es procedente siempre que: (i) no exista otro medio de defensa judicial; (ii) aunque exista ese medio, este no es idóneo y eficaz en las condiciones del caso concreto; o (iii) es necesaria la intervención del juez constitucional para conjurar o evitar la consumación de un perjuicio irremediable.

54. La accionante considera que su estabilidad laboral reforzada fue vulnerada cuando fue desvinculada del cargo que desempeñaba, en cumplimiento del artículo tercero de la Resolución 132 de 22 de marzo de 2022.

55. En casos sobre estabilidad laboral reforzada, la Corte ha sostenido que, en el análisis del requisito de subsidiariedad, se debe tener en cuenta que, generalmente, están involucrados sujetos de especial protección constitucional⁴³. En el presente caso, como la controversia que se plantea gira en torno a la desvinculación de la accionante mediante un acto administrativo, se podría considerar que, en principio, la señora Rojas Pérez debió acudir a la jurisdicción contencioso administrativa en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, según los artículos 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011 respectivamente, solicitando, como medida cautelar, la suspensión provisional de la decisión.

⁴¹ Corte Constitucional, Sentencias T-526 de 2005, T-834 de 2005, T-016 de 2006, T-692 de 2006, T-905 de 2006, T-1009 de 2006, T-1084 de 2006, T-792 de 2007, T-825 de 2007, T-243 de 2008, T-265 de 2009, T-299 de 2009, T-691 de 2009, T-883 de 2009, T-887 de 2009, T-328 de 2010, T-805 de 2012 y T-067 de 2020.

⁴² Según el numeral 2 del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011.

⁴³ Corte Constitucional, sentencia T-433 de 2022; sentencia T-041 de 2019; sentencia T-405 de 2015.

56. Sin embargo, la Corte Constitucional ha establecido que la existencia de un medio de defensa judicial no significa la improcedencia automática o absoluta de la acción de tutela; ya que, para saber si la tutela es procedente, se debe estudiar la eficacia e idoneidad de aquellos, atendiendo a las circunstancias particulares del caso⁴⁴. Este criterio ha sido aplicado, por ejemplo, en casos en los que un funcionario nombrado en provisionalidad es desvinculado del cargo, pero alega ser beneficiario de la garantía de estabilidad laboral reforzada. Así se hizo en la sentencia T-246 de 2022:

“Esta Corte ha señalado que, en principio, la tutela no es procedente para controvertir actos administrativos por medio de los cuales se retira del servicio a un empleado público nombrado en provisionalidad, dado que se trata de controversias asignadas a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ‘cuya estructura permite un amplio debate probatorio frente a las circunstancias que podrían implicar una actuación de la administración contraria al mandato de legalidad’. Específicamente, ha indicado que este tipo de asuntos debe ser controlado judicialmente acudiendo para ello al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

No obstante, ha admitido que la tutela procede cuando tal mecanismo judicial ordinario no resulta idóneo ni eficaz, a la luz de las circunstancias del accionante, para proteger los derechos que se estiman vulnerados, tal como se deriva de lo dispuesto en los artículos 6.1 y 8 del Decreto 2591 de 1991.”⁴⁵ (énfasis añadido)

57. En el caso bajo estudio, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho no es eficaz para lograr el amparo solicitado por la accionante, pues no se observa vicio de nulidad de la Resolución 132 de 22 de marzo de 2022, por medio de la cual se ordenó su desvinculación, ya que el acto administrativo tuvo como sustento la lista de elegibles conformada en el proceso de selección de la Convocatoria 1241 de 2019, es decir una causal objetiva suficiente conforme al artículo 125 constitucional. De esta manera, ese medio de control no es idóneo para la protección de la estabilidad laboral reforzada de la señora Rojas Pérez, en su calidad de prepensionada, ya que el acto administrativo en sí mismo no presenta, *prima facie*, vicio de nulidad. La solicitud de amparo, por el contrario, pretende que se respete una garantía a favor de la accionante, que es obligación de la administración pública-empleador, y que nace del hecho de que la funcionaria desvinculada está cerca de cumplir el requisito de semanas de cotización para obtener su pensión de vejez.

58. Según las causales de nulidad a las cuales se circunscriben esos medios de control, señaladas en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, el análisis que se haría en la jurisdicción contencioso-administrativa estaría delimitado por los elementos de legalidad de la Resolución 132 de 22 de marzo de 2022, sus fundamentos, motivaciones y propósitos, y no por las omisiones de la administración-empleador para garantizar la estabilidad laboral de la accionante, por fuera de esa actuación administrativa y con fundamento en los artículos 13 y 53 de la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional⁴⁶. Se subraya que el asunto planteado en la solicitud de tutela trasciende el control de legalidad de la Resolución 132 de 22

⁴⁴ Corte Constitucional, sentencia T-443 de 2022. Fundamento 31; sentencia SU-691 de 2017. Fundamento 20.

⁴⁵ Corte Constitucional, sentencia T-443 de 2022. Fundamentos 52 y 53.

⁴⁶ Corte Constitucional, sentencia T-500 de 2019. Fundamento 2.6.1. Ver también Sentencias SU-897 de 2012, T-229 de 2017 y SU003 de 2018, entre otras.

de marzo de 2022; control que, en todo caso, la accionante no pretende porque comprende que la Resolución se emitió conforme a derecho. De este modo, la señora Rojas Pérez no cuestiona la Convocatoria 1241 de 2019 ni la legalidad del nombramiento de la señora Diana María Sierra, quien obtuvo el segundo puesto de la lista de elegibles conformada en la Convocatoria 1241 de 2019. Las pretensiones de la solicitud de amparo se limitan a solicitar la protección de la estabilidad laboral reforzada que considera violentada al negar el reintegro solicitado, teniendo en cuenta su calidad de prepensionada, o la aplicación del artículo 6 de la Ley 1960 de 2019⁴⁷. En suma, esos medios ordinarios no serían eficaces porque, en este caso, la desvinculación de la accionante obedeció a una razón objetiva y suficiente, como lo es el nombramiento de una persona que accedió a un cargo en virtud del mérito. Al respecto, la Corte en la sentencia T-246 de 2022 señaló:

“El medio de control no resulta idóneo para lograr la protección de los derechos fundamentales de la tutelante, dado que el asunto planteado trasciende la órbita del examen de legalidad y restablecimiento del derecho del acto administrativo por el cual se dio por terminado su vínculo laboral. Si bien el medio de control de nulidad y restablecimiento permitiría reclamar el reintegro, el pago de salarios y prestaciones sociales dejados de percibir -desde el momento del retiro-, la vulneración de los derechos que alega la accionante no tiene como causa la ilegalidad de la actuación por medio de la cual se efectuó su desvinculación y se designó a la persona seleccionada para la prestación del servicio (...).”⁴⁸ (énfasis añadido)

59. Por otro lado, en un proceso contencioso-administrativo el juez tendría limitaciones para restablecer el derecho de la accionante ya que, como se dijo, el nombramiento de la señora Diana María Sierra tuvo sustento constitucional y legal suficiente y, por lo tanto, no cabría declarar su nulidad ni, como medida de restablecimiento de la accionante, ordenar su reintegro al cargo que venía ocupando.

60. En consecuencia, la Sala encuentra cumplido el requisito de subsidiariedad.

4. Las decisiones revisadas no se encuentran ajustadas a Derecho

Revisión de la sentencia de segunda instancia

61. El Juzgado Promiscuo Civil del Circuito de Duitama decidió revocar la decisión de primera instancia y, en su lugar, “negar por improcedente” la tutela presentada por la señora Rojas Pérez⁴⁹.

62. No obstante haber concluido la improcedencia de la tutela por no cumplir el requisito de subsidiariedad, razón que ya fue desvirtuada en el acápite anterior, la sentencia de tutela de segunda instancia estudió de fondo el asunto y expuso tres argumentos para no acceder a las pretensiones de la demanda: (i) existió una razón objetiva y legítima para la desvinculación de la accionante; (ii) la accionante no probó su calidad de madre cabeza de familia; y, (iii) el juez de tutela no tiene competencia para ordenar el reintegro de un servidor público, ya que esa función recae en el nominador del cargo. Los expuso así:

⁴⁷ Expediente T-9.041.640. “1_15806408900120220012400-(2022-09-26 14-18-50)-1664219930-1”. Acción de tutela, p. 7.

⁴⁸ Corte Constitucional, sentencia T-246 de 2022. Fundamento 55.

⁴⁹ Es importante advertir la falta de técnica jurídica cuando una solicitud se “niega por improcedente”. El juez de tutela puede (i) declarar la improcedencia de la solicitud cuando no se cumple los requisitos de procedibilidad; (ii) amparar o no amparar los derechos cuando, superados los requisitos de procedibilidad, estudia el fondo del asunto.

*“La accionante fue retirada del cargo ya mencionado, a raíz del nombramiento de la señora DIANA MARÍA SIERRA ORTÍZ (...), quien superó el concurso de méritos proceso de selección N.º 1241 Territorial Boyacá, Cesar y Magdalena y es por lo anterior que **no es posible acceder a la protección constitucional solicitada en el presente caso, pues al existir una razón objetiva y legítima para la desvinculación de la accionada, no es procedente la petición encaminada a mantener el empleo que ocupaba en provisionalidad o su reubicación laboral.***

*(...) En cuanto a lo ordenado por el a quo a la ALCALDIA MUNICIPAL DE TIBASOSA ORDENAR al MUNICIPIO DE TIBASOSA que (...) proceda a iniciar las gestiones necesarias para la reincorporación de la señora BLANCA ENAIDA ROJAS PÉREZ a un cargo vacante con funciones similares o equivalentes a las que desarrollaba la misma como Auxiliar Administrativo, código 407, grado 09 se tiene que, **una orden de tal talente, no puede ser proferida por el Juez de tutela, por dos circunstancias específicas que se pasan a exponer.***

*En primer lugar, para que ello fuera procedente, se hace indispensable que, de manera previa, la accionante solicite al respectivo nominador, la ubicación en dicho lugar, con el objeto de que exista pronunciamiento sobre el particular. En este orden de ideas, no se evidencia del estudio del expediente, que la accionante haya puesto en conocimiento de la entidad su particular condición, como tampoco fue anexada la solicitud de traslado debido a dicha condición. Y, en segundo lugar, porque **el nombramiento en el cargo referido, es un asunto que no (sic) compete al nominador, lo que implica que el Juez Constitucional no pueda atribuirse una función que no le compete;***

(...) Ahora bien, observa el despacho que la señora BLANCA ENEIDA ROJAS PÉREZ, si bien alegó la condición de sujeto de especial de protección constitucional por su calidad de ‘madre cabeza de familia’, no allegó prueba alguna que así lo demostrara y de otra parte la Corte Constitucional en sentencia T-003 de 2018 ha establecido que por esa sola condición no existe un derecho fundamental a permanecer en el cargo por lo que, en principio, no se puede amparar por tutela y que dichas personas solamente pueden ser apartadas de un empleo en provisionalidad i. por motivos disciplinarios, ii. porque se convoca a concurso para llenar la plaza de manera definitiva (sic) (...)”⁵⁰ (énfasis añadido)

63. La Sala comparte el primer argumento en tanto la Alcaldía de Tibasosa (Boyacá) sí adujo una razón objetiva y suficiente para desvincular a la accionante de su cargo, pues obedeció a la garantía del mérito que establece el artículo 125 de la Constitución. Lo anterior, empero, no impide que la accionante, como se verá más adelante, sea beneficiaria de la protección que impone la garantía de la estabilidad laboral reforzada por su calidad de prepensionada, la cual exige un trato preferencial en el trámite de su solicitud de nombramiento en un cargo igual o equivalente al que desempeñaba, siempre que haya disponibles en la planta de personal del Municipio de Tibasosa. Esa garantía constitucional tiene sus fundamentos en los artículos 13 y 53 de la Constitución.

⁵⁰ Expediente T-9.041.640. “47_15806408900120220012400-(2022-11-02 14-19-16)-1667416756-47” Sentencia del 31 de agosto de 2022, pp. 10-13.

64. Igualmente comparte la Sala el argumento con base en el cual no se puede garantizar la estabilidad laboral reforzada de la accionante en su condición de madre cabeza de familia, por no haber sido probada dentro del proceso.

65. Quienes tienen la condición de madres cabeza de familia gozan de la garantía de la estabilidad laboral reforzada en virtud del artículo 43 superior. Al respecto, la Corte en la sentencia SU-691 de 2017 afirmó:

*“En suma, para la Corte Constitucional no cabe duda de que la implementación de medidas como la **estabilidad laboral reforzada** para mujeres cabeza de familia, responde a imperativos constitucionales que se desprenden de los artículos 13, 42, 44, 53 y especialmente 43 (inciso segundo) de la Constitución Política y que constituyen en sí mismo fines esenciales en el Estado Social de Derecho. **Ello busca garantizar la primacía de los derechos inalienables de la persona, la protección de la familia y, de manera especial, la supremacía de los derechos de los niños.**”⁵¹ (énfasis añadido)*

66. Ahora bien, la estabilidad laboral reforzada en favor de las madres cabeza de familia no genera una protección absoluta que impida su desvinculación del servicio público. De existir razones objetivas de carácter constitucional o legal se puede dar su desvinculación. Así lo señaló la Corte en sentencia T-246 de 2022:

*“Es por estas razones que la estabilidad laboral reforzada en favor de las personas prepensionadas y las mujeres cabeza de familia no constituya una **protección absoluta ni automática**. El Estado-empleador puede proceder al retiro del servicio con fundamento en razones objetivas previstas en la Constitución y en la ley, entre estas, la necesidad de proveer el cargo con el ganador de un concurso de méritos (...)”⁵² (énfasis añadido)*

67. En todo caso, para que se garantice esa estabilidad a favor de las madres cabeza de familia, la jurisprudencia constitucional⁵³ ha establecido unos requisitos para que se acredite tal calidad:

“(i) que se tenga a cargo la responsabilidad de hijos menores o de otras personas incapacitadas para trabajar; (ii) que esa responsabilidad sea de carácter permanente; (iii) no sólo la ausencia permanente o abandono del hogar por parte de la pareja, sino que aquélla se sustraiga del cumplimiento de sus obligaciones como padre; (iv) o bien que la pareja no asuma la responsabilidad que le corresponde y ello obedezca a un motivo verdaderamente poderoso como la incapacidad física, sensorial, síquica o mental o, como es obvio, la muerte; (v) por último, que haya una deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros de la familia, lo cual significa la responsabilidad solitaria de la madre para sostener el hogar”⁵⁴.

68. En el caso bajo estudio, la señora Rojas Pérez no acreditó ante el Municipio de Tibasosa (Boyacá)⁵⁵, ni en el trámite del proceso de tutela, que tenga la calidad

⁵¹ Corte Constitucional, sentencia SU-691 de 2017. Fundamento 77.

⁵² Corte Constitucional, sentencia T-246 de 2022. Fundamento 114.

⁵³ Corte Constitucional, sentencia SU-388 de 2005; sentencia T-003 de 2018; sentencia SU-691 de 2017; sentencia T-246 de 2022.

⁵⁴ Corte Constitucional, sentencia SU-691 de 2017. Fundamento 80.

⁵⁵ Expediente T-9.041.640. “Consolidado salida 0309”. Certificación del 15 de febrero, p. 16.

de madre de cabeza de familia, conclusión a la que también llegó el Juzgado Promiscuo Civil del Circuito de Duitama cuando revocó la sentencia de tutela de primera instancia⁵⁶. Si bien en el expediente aparece el registro civil de nacimiento de la hija de la accionante, esa no es prueba suficiente que acredite que la señora Rojas Pérez tiene a su cargo exclusivo la responsabilidad de cuidado y el sostenimiento económico de su hija, sin el apoyo del padre de la niña o de los demás miembros de su familia. Por lo anterior, la accionante no es objeto de esta protección especial al no estar probado que goza de esa calidad.

69. Sin embargo, contrario al tercer argumento desarrollado en la decisión de segunda instancia, la Sala considera que el juez constitucional sí tiene competencia para ordenar excepcionalmente el reintegro de un funcionario público que está protegido con estabilidad laboral reforzada.

70. La estabilidad laboral reforzada es una garantía de origen constitucional que se deriva de los artículos 13 y 53 de la Constitución, y busca proteger la igualdad y la estabilidad del empleo del trabajador. Esa garantía impone al Estado-empleador, en los casos de los servidores públicos, la obligación de tomar medidas para que el funcionario protegido sea el último en ser desvinculado, cuando se proveen cargos como resultado de un concurso de méritos y, si existen cargos vacantes similares o equivalentes al que venía ocupando la persona desvinculada, nombrarlo en alguno de esos cargos para lograr así la protección de su empleo.

71. De esta manera, el juez constitucional que conoce de una acción de tutela en la que se solicita la protección de la estabilidad laboral reforzada de un servidor público, sí tiene competencia para ordenar la protección de los derechos fundamentales vulnerados de la persona afectada mediante su vinculación a un cargo similar o equivalente al que venía desempeñando siempre que sea posible. Dicha competencia está regulada en el artículo 23 del Decreto Ley 2591 de 1991, y ha sido analizada por la Corte Constitucional en varias decisiones⁵⁷.

72. En el caso bajo estudio, la señora Rojas Pérez solicitó su reintegro en el recurso de reposición que interpuso el 6 de abril de 2022 contra la Resolución 132 de 22 de marzo de 2022⁵⁸. Sin embargo, el Municipio de Tibasosa (Boyacá) resolvió su solicitud de manera negativa. En consecuencia, presentó solicitud de tutela para obtener la protección de sus derechos fundamentales por considerar vulnerada la garantía a la estabilidad laboral reforzada en su calidad de prepensionada y madre cabeza de familia. Esa protección se traduce en un trato preferencial al momento de proveer cargos vacantes mediante la vinculación a un cargo similar al que desempeñaba, y por el tiempo necesario para cumplir con la cotización mínima de semanas para acceder a su pensión de vejez. Lo anterior se explicará con detalle en el capítulo siguiente y es el fundamento para que la Sala revoque el fallo de tutela de segunda instancia.

Revisión de la sentencia de primera instancia

73. El Juzgado Promiscuo Municipal de Tibasosa amparó los derechos de la señora Rojas Pérez en decisión de primera instancia proferida el 14 de junio de 2022.

⁵⁶ Expediente T-9.041.640. “47_15806408900120220012400-(2022-11-02 14-19-16)-1667416756-47” Sentencia del 31 de agosto de 2022, pp. 10-13.

⁵⁷ Corte Constitucional; Sentencias SU-691 de 2017, T-063 de 2022, T-464 de 2019, entre otras

⁵⁸ Expediente T-9.041.640. “1_15806408900120220012400-(2022-09-26 14-18-50)-1664219930-1”. Recurso de reposición, pp. 22-27.

74. En primer lugar, consideró que la acción de tutela era procedente como mecanismo transitorio para la protección de los derechos fundamentales de la accionante con el fin evitar un perjuicio irremediable.

75. En segundo lugar, al estudiar el fondo de la solicitud, encontró que el Municipio de Tibasosa (Boyacá) vulneró los derechos fundamentales de la accionante al abstenerse de proteger su estabilidad laboral reforzada mediante la vinculación a un cargo equivalente o similar al que venía desempeñando, a pesar de la existencia de cargos vacantes. Lo explicó así:

“Empero, si bien no se allegó una certificación sobre la existencia de otras vacantes en cargos similares al que ocupaba la accionante, en los hechos de la acción la misma afirmó que con posterioridad a haberse abierto la convocatoria respectiva por la Comisión Nacional del Servicio Civil, se produjo la vacancia de algunos otros cargos ante el reconocimiento pensional de las personas que los ocupaban, afirmación que no fue desvirtuada por la administración, pues lo único que hizo la Alcaldía fue indicar que como quiera que los nuevos cargos no habían sido ofertados en esta convocatoria, no resultaba procedente su provisión mediante la lista de elegibles de la convocatoria en mención.

Para el Despacho, si bien, los cargos respecto de los cuales se produjo la vacancia con posterioridad a la expedición de la Convocatoria N° 1241 de 2019, no fueron ofertados en la misma, pues la convocatoria se abrió para proveer dos cargos que ya fueron provistos con las dos primeras personas de la lista de elegibles, ello no constituye razón suficiente para negar a la accionante el derecho a desempeñarse en alguno de ellos, en primer lugar por cuanto la administración no adoptó medidas para evitar la desvinculación de la accionante pese a su condición de pre pensionada, y, en segundo lugar, por cuanto se tiene certeza que la accionante también superó el concurso de méritos para ese tipo de cargos, encontrándose en el tercer lugar de la lista de elegibles y por consiguiente, es la persona que sigue en turno para ocupar cualquier vacante que se pueda producir en la administración municipal para dicho cargo.”⁵⁹ . (énfasis añadido)

76. La Sala se aparta de los anteriores argumentos. Por un lado, para superar el requisito de subsidiariedad, el juez debió ahondar en la falta de idoneidad y eficacia de los medios de defensa ordinarios sin acudir a la eventual configuración de un perjuicio irremediable en tanto este argumento impuso mayores cargas a la accionante pues le exigía interponer las acciones ordinarias que, como ya se explicó, resultan inidóneas e ineficaces.

77. Por otro lado, no obra prueba en el expediente de la existencia de cargos vacantes que hubieran podido haberse ofrecido a la accionante, por lo que no se puede afirmar que el Municipio de Tibasosa se hubiera abstenido de adoptar las medidas necesarias para garantizar la alegada estabilidad laboral reforzada de la accionante. De hecho, el Municipio de Tibasosa aportó certificación fechada el 14 de febrero de 2023⁶⁰, emitida por la Jefe de Talento Humano de la alcaldía de Tibasosa (Boyacá), que señala que en marzo de 2022, cuando fue emitida la Resolución 132 de 22 de marzo de 2022 por medio de la cual se desvinculó a la

⁵⁹ Ibidem., p. 15.

⁶⁰ Expediente T-9.041.640. “Consolidado salida 0309”. Certificación del 14 de febrero, pp. 17-20

señora Rojas Pérez de su cargo, no había cargos en vacancia definitiva dentro de la planta personal del municipio.

78. Por lo anterior, la sentencia proferida el 14 de junio de 2022 por Juzgado Promiscuo Municipal de Tibasosa también será revocada por carecer de fundamento.

79. Debido a que los fallos de tutela revisados deben ser revocados por las razones explicadas más arriba, procede la Sala a asumir la competencia del juez de instancia y a conocer el fondo del asunto para resolver el caso concreto. En consecuencia, se determinará si el municipio de Tibabosa (Boyacá), al desvincular a la accionante, vulneró (5.1.) el derecho a acceder a cargos públicos al abstenerse de aplicar el numeral 4 del artículo 6 de la Ley 1960 de 2019; y (5.2.) la garantía de la estabilidad laboral reforzada en su calidad de prepensionada.

5. Solución del caso concreto: La alcaldía de Tibabosa está en la obligación de nombrar a la accionante, en período de prueba, en un cargo no ofrecido en la Convocatoria y que quede en vacancia definitiva, mientras siga vigente la lista de elegibles. De no ser posible, deberá vincular a la accionante en provisionalidad a un cargo similar o equivalente al que venía desempeñando, cuando surja una nueva vacancia definitiva, y durante el tiempo necesario para cumplir el número de semanas de cotización requeridas para acceder a la pensión de vejez

80. En la solicitud de tutela, la señora Rojas Pérez afirmó que la desvinculación del cargo que desempeñaba desconoció (i) que el artículo 6 de la Ley 1960 de 2019 establece que la lista de elegibles conformada luego de un proceso de selección puede ser usada para proveer vacancias definitivas de cargos equivalentes que no hicieron parte del proceso pero que surgen después de la convocatoria pública realizada; y (ii) que al momento de su desvinculación gozaba de estabilidad laboral reforzada por su calidad de prepensionada.

5.1. Aplicación retrospectiva de la Ley 1960 de 2019

81. El artículo 6 de la Ley 1960 de 2019 establece:

“El numeral 4 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, quedará así:

‘Artículo 31. El proceso de selección comprende:

4. Con los resultados de las pruebas la Comisión Nacional del Servicio Civil o la entidad contratada por delegación de aquella elaborará en estricto orden de mérito la lista de elegibles que tendrá una vigencia de dos (2) años. Con esta y en estricto orden de méritos se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso y las vacantes definitivas de cargos equivalentes no convocados, que surjan con posterioridad a la convocatoria de concurso en la misma Entidad.’” (énfasis añadido)

82. De acuerdo con el artículo 7 de la misma normativa, esta disposición surte efectos a partir de su publicación el 27 de junio de 2019⁶¹. Sin embargo, en las

⁶¹ Diario Oficial. 50.997 del 27 de junio de 2019.

sentencias T-340 de 2020⁶² y T-081 de 2021⁶³, la Corte explicó que su aplicación es retrospectiva por cuanto se aplica a situaciones de hecho que ocurrieron con anterioridad a su entrada en vigencia. Para el caso de la modificación introducida al artículo 31 de la Ley 909 de 2004 por la Ley 1960 de 2019:

*“(…) se tiene que la situación de hecho respecto de la cual cabe hacer el análisis para determinar si hay o no una situación jurídica consolidada es la inclusión en la lista de elegibles. De esta forma, deberá diferenciarse, por un lado, la situación de quienes ocuparon los lugares equivalentes al número de vacantes convocadas y que, en virtud de ello tienen derecho a ser nombrados en los cargos convocados y, por el otro, la situación de aquellas personas que, estando en la lista de elegibles, su lugar en ellas excedía el número de plazas convocadas. (...) Así las cosas, las personas que ocuparon los lugares equivalentes al número de vacantes convocadas tienen **un derecho subjetivo** y adquirido a ser nombrados en período de prueba en el cargo para el cual concursaron, de suerte que respecto de ellos existe una situación jurídica consolidada que impide la aplicación de una nueva ley que afecte o altere dicha condición. Sin embargo, no ocurre lo mismo respecto de quienes ocuparon un lugar en la lista que excedía el número de vacantes a proveer, por cuanto estos aspirantes **únicamente tienen una expectativa de ser nombrados**, cuando quiera que, quienes los antecedan en la lista, se encuentren en alguna de las causales de retiro contenidas en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004”⁶⁴ (énfasis añadido)*

83. En el caso bajo análisis: la Convocatoria 1241 de 2019 se hizo el 14 de mayo de 2019, la Ley 1960 de 2019 fue publicada el 27 de junio de 2019 y la lista de elegibles de la convocatoria para la OPEC 67261 quedó en firme el 11 de marzo de 2022. Por consiguiente, el Municipio de Tibasosa (Boyacá) debe aplicar el numeral 4 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, en la forma como fue modificado por el artículo 6 de la Ley 1960 de 2019, y hacer uso de la lista de elegibles en la que la accionante se encuentra en el siguiente puesto, ya que las personas que ocupaban los dos primeros fueron debidamente nombradas. Lo anterior, porque su situación fáctica no se consolidó desde el punto de vista jurídico con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1960 de 2019, ya que la lista de elegibles quedó en firme con posterioridad a la entrada en vigencia de dicha Ley. Ello coincide con el complemento del Criterio Unificado de la CNSC, de 6 de agosto de 2020, sobre el "Uso de listas de elegibles en el contexto de la ley 1960 de 27 de junio de 2019"⁶⁵, según el cual las listas de elegibles conformadas por esa entidad y aquellas que sean expedidas en el marco de procesos de selección aprobados antes del 27 de junio de 2019, fecha de entrada en vigencia de la Ley 1960 de 2019, deberán ser usadas durante su vigencia para proveer las vacantes de la OPEC y para cubrir nuevas vacantes que se generen con posterioridad y que correspondan a los mismos empleos públicos. El concepto de “mismo empleo”, según ese Criterio Unificado, hace referencia a cargos con igual denominación, código, grado, asignación básica mensual, propósito, funciones, etc., a aquel de la OPEC.

⁶² Corte Constitucional, sentencia T-340 de 2020. Fundamento 3.6.3.

⁶³ Corte Constitucional, sentencia T-081 de 2021. Fundamento 86.

⁶⁴ Corte Constitucional, sentencia T-340 de 2020. Fundamento 3.6.3.

⁶⁵ El complemento fue emitido el 06 de agosto de 2020 y está disponible en: CNSC, Complementación al Criterio Unificado “Uso de listas elegibles en el contexto de la Ley 1960 del 27 de junio de 2019”. Disponible en: <https://historico.cnsc.gov.co/index.php/criterios-unificados-provision-de-empleos#>

84. Por lo anterior, el tercer lugar ocupado en la lista de elegibles de la Convocatoria 1241 de 2019, por parte de la señora Rojas Pérez, le otorgó una expectativa a ser nombrada en período de prueba en un cargo no ofrecido en la Convocatoria⁶⁶ cuando haya una vacancia definitiva mientras siga vigente la lista de elegibles, y que el cargo sea igual o equivalente al ofrecido en la OPEC en la que participó. De no existir una vacante definitiva mientras la lista de elegibles siga vigente, la estabilidad laboral reforzada de la que goza la accionante en su calidad de prepensionada debe ser garantizada tal como se explica en el capítulo siguiente.

5.2. La protección a la estabilidad laboral reforzada de la que goza la señora Rojas Pérez en su calidad de prepensionada

5.2.1. La estabilidad laboral reforzada

85. La estabilidad laboral reforzada es una garantía de origen constitucional que se fundamenta en los artículos 13 y 53 de la Constitución, los cuales consagran el principio de igualdad y la obligación que tiene el Estado de velar por una igualdad real y material a favor de las personas que se encuentran en debilidad manifiesta⁶⁷, y la estabilidad en el empleo que se le debe proteger al trabajador o funcionario público⁶⁸. Esa garantía tiene como objetivo impedir que el empleador, en el sector público o privado, abuse de sus facultades legales frente a la vinculación de una persona y, so pretexto de su ejercicio, cometa actos de discriminación que sobrepasen los límites que imponen los derechos fundamentales⁶⁹.

5.2.2. La estabilidad laboral reforzada de los prepensionados

86. De acuerdo con la sentencia SU-003 de 2018⁷⁰, son prepensionados las personas vinculadas laboralmente al sector público o privado, que están próximas (dentro de los siguientes tres años) a cumplir el número de semanas -o tiempo de servicio- requeridos en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida o el capital necesario en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad. En esa decisión, la Corte unificó su jurisprudencia para determinar que los funcionarios de libre nombramiento y remoción no gozan de estabilidad laboral reforzada, y que no

⁶⁶ Así lo sostuvo la Corte en la decisión T-340 de 2020 al analizar un caso análogo al decidido en esta ocasión: “*Como fue planteado en el capítulo anterior, la consolidación del derecho de quienes conforman una lista de elegibles ‘se encuentra indisolublemente determinado por el lugar que se ocupó dentro de la lista y el número de plazas o vacantes a proveer’ Así las cosas, las personas que ocuparon los lugares equivalentes al número de vacantes convocadas tienen un derecho subjetivo y adquirido a ser nombrados en período de prueba en el cargo para el cual concursaron, de suerte que respecto de ellos existe una situación jurídica consolidada que impide la aplicación de una nueva ley que afecte o altere dicha condición. Sin embargo, no ocurre lo mismo respecto de quienes ocuparon un lugar en la lista que excedía el número de vacantes a proveer, por cuanto estos aspirantes únicamente tienen una expectativa de ser nombrados, cuando quiera que, quienes los antecedan en la lista, se encuentren en alguna de las causales de retiro contenidas en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004. // Para la Sala, el cambio normativo surgido con ocasión de la expedición de la Ley 1960 de 2019, regula la situación jurídica no consolidada de las personas que ocupaban un lugar en una lista de elegibles vigente que excedía el número de vacantes ofertadas, por lo que las entidades u organismos que llevaron a cabo los concursos deberán hacer uso de estas, en estricto orden de méritos, para cubrir las vacantes definitivas en los términos expuestos en la referida ley. Lo anterior no implica que automáticamente se cree el derecho de quienes hacen parte de una lista de elegibles a ser nombrados, pues el ICBF y la CNSC deberán verificar, entre otras, que se den los supuestos que permiten el uso de una determinada lista de elegibles, esto es, el número de vacantes a proveer y el lugar ocupado en ella, además de que la entidad nominadora deberá adelantar los trámites administrativos, presupuestales y financieros a que haya lugar para su uso.*” (énfasis añadido). Corte Constitucional, sentencia T-340 de 2020. Fundamento 3.6.5.

⁶⁷ Como lo expresó la Corte en sentencia C-200 de 2019, el derecho a la estabilidad laboral reforzada corresponde a una noción amplia que ha sido modificada a lo largo de los años, tanto legal como jurisprudencialmente. Los pronunciamientos de esta Corte han protegido a varios grupos de trabajadores, de acuerdo con ciertas circunstancias específicas. Alguno de ellos son: (i) mujeres embarazadas; (ii) algunos empleados prepensionados; (iii) madres cabeza de familia con ciertos vínculos laborales; (iv) sujetos que gozan de fuero sindical; (v) servidores públicos; (vi) trabajadores en situación de discapacidad; (vii) algunos cónyuges o compañeros permanentes de mujeres embarazadas no trabajadoras; (viii) padres cabeza de familia con ciertos vínculos laborales y, para el caso que ocupa a esta Sala, (ix) personas en situación de debilidad manifiesta como consecuencia de afecciones de salud.

⁶⁸ La Corte Constitucional también ha reconocido esta garantía para las personas que están bajo un contrato de prestación de servicios, reconociéndoles una estabilidad ocupacional reforzada. Corte Constitucional, sentencia SU-049 de 2017.

⁶⁹ Corte Constitucional, sentencia T-246 de 2022. Fundamento 100.

⁷⁰ Corte Constitucional, sentencia SU-003 de 2018. Fundamento 61.

tiene la calidad de prepensionado el funcionario al que solamente le falta cumplir el requisito de la edad para obtener la pensión⁷¹.

87. La calidad de prepensionado protege la expectativa de obtener la pensión de vejez ante la pérdida intempestiva de su empleo. Por lo anterior, la estabilidad laboral reforzada a favor del prepensionado ampara la estabilidad en el cargo y la continuidad en la cotización efectiva al sistema general de seguridad social en pensiones para consolidar así los requisitos que le faltan para obtener la pensión de vejez, que deben corresponder a la cotización equivalente a tres años o menos (es decir a 154,44 semanas de cotización o menos, para el Régimen de Primera Media con Prestación Definida).

88. Ahora bien, esa garantía de estabilidad laboral reforzada a favor del prepensionado no otorga un fuero absoluto de protección que le impida a la entidad nominadora la desvinculación del servicio público, por razones objetivas tales como el desarrollo de un concurso de méritos. Al respecto, la Corte sostuvo en la sentencia SU-446 de 2011:

“(...) En consecuencia, la terminación de una vinculación en provisionalidad porque la plaza respectiva debe ser provista con una persona que ganó el concurso, no desconoce los derechos de esta clase de funcionarios, pues precisamente la estabilidad relativa que se le ha reconocido a quienes están vinculados bajo esta modalidad, cede frente al mejor derecho que tienen las personas que ganaron un concurso público de méritos”⁷² (énfasis añadido)

89. No obstante, la estabilidad laboral reforzada del prepensionado genera la obligación de trato preferencial que debe cumplir la entidad nominadora *“en la medida de las posibilidades”*⁷³. Esa obligación se concreta en: (i) tomar medidas para que esos servidores sean los últimos en ser desvinculados de sus cargos; y, (ii) si existen cargos en vacancia definitiva similares o equivalentes a los que venían ocupando, nombrarlos en esos cargos mientras se proveen a través del concurso de méritos y hasta que logren cumplir los requisitos para obtener su pensión de vejez⁷⁴. Al respecto, la Corte en la sentencia T-464 de 2019 sostuvo:

“No obstante, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que dentro de las personas que ocupan un cargo de carrera en provisionalidad, pueden encontrarse sujetos de especial protección constitucional, como las madres y padres cabeza de familia, quienes estén próximos a pensionarse, las personas que se encuentran en situación de discapacidad o en debilidad manifiesta por causa de una enfermedad. En estos casos, la Corte ha afirmado que antes de proceder al nombramiento de quienes superaron el concurso de méritos, los funcionarios que se encuentren en provisionalidad deberán ser los últimos en removerse y en todo caso, en la medida de las posibilidades, deben vincularse nuevamente de manera provisional en cargos vacantes de la misma jerarquía o equivalencia de los que se venían ocupando.”⁷⁵ (énfasis añadido)

⁷¹ Corte Constitucional, sentencia SU-003 de 2018. Fundamentos 43 y 59.

⁷² Corte Constitucional, sentencia SU-446 de 2011. Fundamentos 10.1 y 10.2; sentencia T-443 de 2022. Fundamento 75.

⁷³ Corte Constitucional, Sentencia T-464 de 2019.

⁷⁴ Corte Constitucional, sentencia SU-003 de 2018; Fundamento 62. *“La ‘prepensión’ protege la expectativa del trabajador de obtener su pensión de vejez, ante su posible frustración como consecuencia de una pérdida intempestiva del empleo. Por tanto, ampara la estabilidad en el cargo y la continuidad en la cotización efectiva al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, para consolidar los requisitos que le faltaren para acceder a su pensión de vejez.”* (énfasis añadido)

⁷⁵ Corte Constitucional, sentencia T-464 de 2019. Fundamento 2.

90. En estos términos, la Sala analizará el cumplimiento de la obligación de trato preferencial que se imponía a la entidad nominadora.

5.2.3. La estabilidad laboral reforzada de la señora Rojas Pérez por su calidad de prepensionada

91. *Sobre la adopción de medidas para ser la última desvinculada:* El Municipio de Tibasosa (Boyacá) informó que antes de iniciar la Convocatoria 1241 de 2019 reportó el cargo de la accionante a la CNSC para proveerlo por medio de concurso de méritos porque: (i) se encontraba en vacancia definitiva en los términos del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015⁷⁶, razón reiterada por la CNSC⁷⁷; (ii) la señora Rojas Pérez no tenía en ese momento la calidad de prepensionada porque le faltaban más de tres años para lograr el derecho de pensión⁷⁸; y, (iii) la administración municipal nunca recibió comunicación de la accionante en la que manifestara que era prepensionada. Es decir, antes de emitir la Resolución 132 de 22 de marzo de 2022, la administración municipal desconocía la calidad de prepensionada que tenía la señora Rojas Pérez y, por esa razón, no tomó en cuenta esa condición para proceder al nombramiento de la señora Diana María Sierra en su cargo.

92. En todo caso, según certificación suscrita por la Jefe de Talento Humano del Municipio de Tibasosa (Boyacá) el 14 de febrero de 2023⁷⁹, al momento de ser proferida la Resolución 132 de 22 de marzo de 2022 por medio de la cual se desvinculó a la señora Rojas Pérez de su cargo, no había cargos en vacancia definitiva dentro de la planta personal del municipio. Así mismo, a 31 de mayo de 2022⁸⁰, los cuatro cargos de “auxiliar administrativo”, código 407, grado 09, se encontraban ocupados por personas protegidas por estabilidad laboral reforzada: tres madres cabeza de familia, una de ellas prepensionada, y la funcionaria restante era cuidadora de una persona en situación discapacidad. En consecuencia, el Municipio de Tibasosa (Boyacá) tampoco habría podido tomar medidas para que la accionante fuera la última en ser desvinculada de su cargo teniendo en cuenta que no había vacancias definitivas en ese momento y que las demás personas que ocupaban cargos equivalentes gozaban de estabilidad laboral reforzada.

93. *Sobre el nombramiento en cargos vacantes similares o equivalentes a los que venían ocupando, mientras se proveen a través del concurso de méritos y hasta que logre cumplir el requisito de cotizaciones o aportes para obtener su pensión de vejez:* La Jefe de Talento Humano del Municipio de Tibasosa (Boyacá) certificó el 14 de febrero de 2023⁸¹ que en la planta de personal del Municipio no hay cargos en vacancia definitiva. Concretamente, respecto de los cargos de “auxiliar

⁷⁶ “Artículo 2.2.5.3.1 Provisión de las vacancias definitivas. (...) Las vacantes definitivas en empleos de carrera se proveerán en periodo de prueba o en ascenso, con las personas que hayan sido seleccionadas mediante el sistema de mérito, de conformidad con lo establecido en la Ley 909 de 2004 o en las disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera, según corresponda. Mientras se surte el proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto Ley 760 de 2005 o en las disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera. (...)” (énfasis añadido)

⁷⁷ Expediente T-9.041.640. “33_15806408900120220012400-(2022-11-02 14-10-37)-1667416237-33”. Impugnación de sentencia del 14 de junio de 2022, p. 5; “3_15806408900120220012400-(2022-09-26 14-19-13)-1664219953-3”. Contestación tutela CNSC, p. 9.

⁷⁸ Esta afirmación se confirma con el reporte de semanas cotizadas en pensiones, de Colpensiones, donde aparece que a marzo de 2022 la señora Rojas Pérez tendría 986.21 semanas cotizadas, es decir le faltaban más de 3 años para el número mínimo de 1.300. Expediente T-9.041.640. “1_15806408900120220012400-(2022-09-26 14-18-50)-1664219930-1”. Reporte de semanas cotizadas. p. 19.

⁷⁹ Expediente T-9.041.640. “Consolidado salida 0309”. Certificación del 14 de febrero, pp. 17-20

⁸⁰ Expediente T-9.041.640. “Pruebas enviadas honorable corte constitucional”, p. 25.

⁸¹ Expediente T-9.041.640. “Consolidado salida 039” Certificación del 13 de febrero de 2023, pp. 17-19.

administrativo”, código 407, grado 9, tres estaban ocupados por funcionarios con derechos de carrera administrativa y los demás por funcionarios en provisionalidad. Sostuvo, en consecuencia, que en el Municipio de Tibasosa (Boyacá) no existía en ese momento la posibilidad de nombrar a la accionante en uno de esos cargos porque ya se encuentran provistos de manera definitiva o temporal.

94. La Sala encuentra justificación razonable en la anterior circunstancia y la imposibilidad de realizar la vinculación solicitada ante la inexistencia de vacancias definitivas. Sin embargo, la posibilidad de que la accionante pueda ser nombrada en un cargo similar al que venía desempeñando puede surgir con el transcurso del tiempo, después de notificada esta decisión judicial, razón por la cual la Sala ordenará la protección de su estabilidad laboral reforzada para que su solicitud de vinculación en provisionalidad a un cargo similar o equivalente al que venía desempeñando siga en orden de prioridad para cuando exista una nueva vacancia definitiva, y ante la imposibilidad de ser nombrada en período de prueba en un cargo que no fue ofrecido en la Convocatoria y que esté en vacancia definitiva, mientras siga vigente la lista de elegibles. Esa vinculación, empero, deberá limitarse al tiempo necesario para lograr las semanas de cotización requeridas para obtener su pensión de vejez. En caso de que la accionante cumpla el número de semanas de cotización requerido antes de que surja una vacante para ser nombrada en provisionalidad en el Municipio de Tibasosa (Boyacá), no será necesaria la vinculación por cuanto ya se habría consolidado su derecho a la pensión de vejez.

6. Síntesis de la decisión

95. Al revisar los fallos proferidos dentro del proceso de tutela de la referencia, la Sala encuentra que carecen de fundamento y, en consecuencia, procede a revocarlos por las siguientes razones: La de segunda instancia, porque (i) sí se supera el requisito de subsidiariedad; (ii) a pesar de que la desvinculación se produjo por una razón objetiva y suficiente ello no habilita a desconocer la garantía el derecho a la estabilidad laboral reforzada de la accionante en su calidad de prepensionada; y (iii) el juez constitucional sí tiene competencia para ordenar, en casos excepcionales, la vinculación de un funcionario público a un cargo igual o similar al que desempeñaba. La de primera instancia, porque el juez debió analizar la falta de idoneidad y eficacia de los medios de defensa ordinarios sin acudir a la eventual configuración de un perjuicio irremediable en tanto este argumento impone mayores cargas a la accionante pues le exige interponer las acciones ordinarias que, como ya se explicó, resultan inidóneas e ineficaces. También, porque en el expediente no obra prueba de la existencia de cargos vacantes que hubieran podido haberse ofrecido a la accionante, por lo que no se puede afirmar que el Municipio de Tibasosa se hubiera abstenido de adoptar las medidas necesarias para garantizar la alegada estabilidad laboral reforzada de la accionante.

96. Al asumir el estudio de fondo de la solicitud de tutela, encuentra la Sala que, en virtud de la aplicación retrospectiva de la Ley 1960 de 2019, el Municipio de Tibasosa (Boyacá) deberá nombrar a la señora Rojas Pérez en el cargo de “auxiliar administrativo”, código 407, grado 09, o en cargo equivalente, tan pronto exista una vacante definitiva mientras siga vigente la lista de elegibles de la OPEC 67261 de la Convocatoria 1241 de 2019 en la que participó. De no surgir vacante definitiva durante la vigencia de la lista, la entidad deberá vincular a la accionante en un cargo similar o equivalente al que venía desempeñando cuando surja una nueva vacante definitiva, en virtud de la garantía a la estabilidad laboral reforzada en su calidad de prepensionada. De lograrse esta última vinculación, estará limitada

al tiempo necesario para cumplir con el número de semanas de cotización necesarias para obtener su pensión de vejez.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE

PRIMERO. REVOCAR las sentencias de tutela proferidas el 31 de agosto de 2022 por el Juzgado Promiscuo Civil del Circuito de Duitama, y el 14 de junio de 2022 proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Tibasosa, por las razones expuestas en esta providencia y, en su lugar, **AMPARAR** la garantía a la estabilidad laboral reforzada de la accionante en su calidad de prepensionada.

SEGUNDO. ORDENAR al Municipio de Tibasosa (Boyacá) que, en aplicación de la Ley 1960 de 2019, nombre de manera inmediata en período de prueba a Blanca Enaida Rojas Pérez en el cargo de “auxiliar administrativo”, código 407, grado 09, o en cargo similar o equivalente, mientras esté vigente la lista de elegibles de la OPEC 67261 de la Convocatoria 1241 de 2019 y exista la respectiva vacante. En caso de que al momento de la notificación de esta decisión no exista dicha vacante, la entidad queda con la obligación de comunicar de manera inmediata a la señora Rojas Pérez cuando surja la vacante. Al efecto, deberá rendir ante el Juez de primera instancia un informe trimestral sobre los movimientos en la planta de personal mientras la lista de elegibles siga vigente.

TERCERO. En el evento en que no surja vacante para nombrar a Blanca Enaida Rojas Pérez durante la vigencia de la lista de elegibles de la OPEC 67261 de la Convocatoria 1241 de 2019, **ORDENAR** al Municipio de Tibasosa (Boyacá) su nombramiento en provisionalidad cuando haya una vacante definitiva en un cargo con igual denominación, código, grado, asignación básica mensual y funciones que el de “auxiliar administrativo”, código 407, grado 9, situación que deberá ser comunicada por el Municipio a la interesada de manera inmediata. Esa vinculación podrá limitarse al tiempo necesario para que la señora Rojas Pérez cumpla las semanas mínimas de cotización requeridas para obtener su pensión de vejez (1300 semanas en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida). En caso de que la accionante cumpla con ese requisito antes de que surja una vacancia definitiva para su nombramiento en provisionalidad, el Municipio no estará obligado a realizar tal vinculación porque la garantía de estabilidad laboral reforzada a su favor no tendría efectos materiales ya que se habría consolidado su derecho a la pensión de vejez.

CUARTO. Por Secretaría General, líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA
Magistrada

CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
Con salvamento de voto

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ
Secretaria General

**SALVAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
A LA SENTENCIA T-253/23**

Referencia: Expediente T-9.041.640

Asunto: Acción de tutela instaurada por Blanca Enaida Rojas Pérez contra el Municipio de Tibasosa (Boyacá).

Magistrado Ponente:
Antonio José Lizarazo Ocampo

Con el acostumbrado respeto a las decisiones adoptadas por la Sala Sexta de Revisión presento mi salvamento de voto frente a la sentencia de la referencia.

Concretamente, estimo que en este caso sí se configuró una violación del derecho a la estabilidad laboral reforzada de la accionante, difiero de los argumentos del proyecto de sentencia y me aparto de la decisión adoptada por las razones que presento a continuación.

Considero que la sentencia no tuvo en cuenta que la protección de la estabilidad laboral reforzada de una persona surge es en el momento en que cumple los requisitos legales y jurisprudenciales para el efecto. En el caso resuelto en esta oportunidad, el análisis de esos requisitos habría llevado a la Sala a concluir que la protección de la estabilidad laboral reforzada de la accionante tenía fundamento en su calidad de prepensionada. En consecuencia, la Sala ha debido adoptar un

remedio judicial idóneo para proteger de manera efectiva la protección del derecho a la estabilidad laboral reforzada derivado de la condición de prepensionada de manera que se le asegurara a la accionante permanecer en su cargo u otro similar para poder cumplir con las semanas de cotización que le faltaban para adquirir el derecho a la pensión de vejez.

Asimismo, la Sala ha debido determinar con precisión el momento en que la accionante adquirió la condición de prepensionada y, así, verificar si el municipio nombró en provisionalidad a las señoras Andrea Yaneth Acevedo Pérez, Angélica María Ducon Acevedo, Gloria Stella Hurtado Molano y Liliana Amparo Porras, pese a que la accionante ya había cumplido con los requisitos para tener la calidad de prepensionada y, en consecuencia, la protección a la estabilidad laboral que se deriva de esta.

En estos términos dejo sentada mi posición.

Fecha *ut supra*,

CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada

DERECHO FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD SOCIAL-
Vulneración en la faceta de acceso a una historia laboral completa,
actualizada y unificada

(...) la historia laboral de la demandante presentaba algunas inconsistencias en relación con el número de semanas cotizadas a pensión... (Las entidades accionadas) afectaron las garantías ius fundamentales de la actora porque incumplieron con su deber de validar y mantener actualizada la información relacionada con sus aportes al sistema pensional.

INCONSISTENCIAS EN HISTORIA LABORAL-Administradoras de pensiones deben desplegar las actuaciones necesarias para garantizar la veracidad, claridad y precisión de las historias laborales, y no trasladar la carga de su negligencia a los afiliados

(...) la accionante no está obligada a soportar las consecuencias negativas de la inexactitud de la información que reposa en su historial laboral. Esta situación impactó en el reconocimiento de la calidad de prepensionada de la demandante, pues (la entidad empleadora) se valió de dicha circunstancia para desconocer la garantía de estabilidad laboral reforzada por la condición de prepensionada de la actora.

ACCION DE TUTELA CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARACTER PARTICULAR Y CONCRETO-Procedencia excepcional para solicitar el reintegro de servidores públicos por ser prepensionados

EMPLEADO NOMBRADO EN PROVISIONALIDAD EN CARGO DE CARRERA ADMINISTRATIVA-Goza de estabilidad relativa o intermedia

PREPENSIONADO-Concepto

ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PREPENSIONADO-Solo aplica en los casos en que sea necesario mantener el vínculo laboral del trabajador, para que éste pueda completar las semanas de cotización requeridas

DESVINCULACION DE SERVIDORES PUBLICOS PROVISIONALES CON ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA CON OCASION DE CONCURSO DE MERITOS-Reiteración de jurisprudencia

PREPENSIONADOS QUE OCUPAN CARGOS DE CARRERA EN PROVISIONALIDAD EN EL MARCO DE UN CONCURSO DE MERITOS-Mecanismos de protección

(i) motivar debidamente el acto de desvinculación; (ii) establecer los mecanismos necesarios para garantizar que dicho grupo de personas sean los últimos en ser desvinculados de sus cargos; y, (iii) mantener su permanencia en

el empleo, siempre que los criterios de razonabilidad y proporcionalidad lo permitan, es decir, cuando se cuenten con vacantes para reubicarlos.

ESTABILIDAD LABORAL DE PERSONAS PROXIMAS A PENSIONARSE-Protección legal

HISTORIA LABORAL-Contenido y finalidad/**HISTORIA LABORAL**-Relevancia constitucional

DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES-Deberes de las Administradoras de pensiones respecto de la información consignada en la historia laboral de sus afiliados

EMPLEADOR-Deber de colaboración para actualizar la historia laboral del empleado

REPÚBLICA DE COLOMBIA



CORTE CONSTITUCIONAL Sala Segunda de Revisión

SENTENCIA T-052 DE 2023

Referencia: Expediente T-8.987.455

Acción de tutela instaurada por Blanca Bellanid Galíndez Joven contra la Secretaría de Educación Departamental de Putumayo

Procedencia: Juzgado Segundo Civil Municipal de Mocoa

Asunto: Afectación de los derechos fundamentales al trabajo y a la estabilidad laboral reforzada de una persona prepensionada en el marco de concurso de méritos. Inconsistencias en la historia laboral. Deber de las administradoras de pensiones y de los empleadores de mantener actualizada la información de los afiliados.

Magistrado Sustanciador:
Juan Carlos Cortés González

Bogotá, D.C., ocho (08) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la Magistrada Diana Fajardo Rivera y los Magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y Juan Carlos Cortés González, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente

SENTENCIA

1. En el trámite de revisión del proceso por acción de tutela con fallo de segunda instancia, proferido el 23 de agosto de 2022 por el Juzgado Civil del Circuito de Mocoa, que revocó la decisión del 12 de julio de 2022 por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Mocoa y, en su lugar, declaró la improcedencia del amparo solicitado por la señora Blanca Bellanid Galíndez Joven contra la Secretaría de Educación Departamental de Putumayo.

2. El asunto llegó a la Corte en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. El 28 de octubre de 2022, la Sala de Selección de Tutelas No. 10 de esta Corporación lo escogió para su revisión¹. El 15 de noviembre de 2022, la Secretaría General de esta Corporación remitió el expediente al despacho del magistrado sustanciador encargado en ese momento², para lo de su competencia³.

I. ANTECEDENTES

3. El 28 de junio de 2022, la demandante presentó acción de tutela en contra de la Secretaría de Educación Departamental de Putumayo (en adelante SED). La accionante consideró que la entidad demandada vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, a la seguridad social, a la estabilidad laboral reforzada, al debido proceso y al mínimo vital. Lo expuesto, porque aquella finalizó su vínculo laboral sin tener en cuenta su condición de prepensionada⁴.

Hechos y pretensiones

4. *Las condiciones personales de la accionante y sus antecedentes laborales.* La petitionaria tiene 60 años⁵. Su último empleo fue con la SED en el cargo de Auxiliar de Servicios Generales en la Institución Educativa José María

1 Auto del 28 de octubre de 2022 proferido por la Sala de Selección de Tutelas Número Diez.

2 El 30 de noviembre de 2022, Juan Carlos Cortés González se posesionó como magistrado titular, con efectos a partir del 1 de diciembre siguiente, a partir de entonces le correspondió sustanciar el presente asunto.

3 Constancia del 15 de noviembre de 2022 suscrita por la Secretaría General de esta Corporación.

4 Acción de tutela. En expediente digital: “03-TutelaBlancaGalindezVsSecretariaDeEducacion.pdf”.

5 Cedula de Ciudadanía. Blanca Bellanid Galíndez Joven. Fecha de nacimiento: 10/02/1963 Tomado de expediente digital: “ANEXOS_28_6_2022, 8_54_53.pdf”. Pág. 1.

Hernández⁶, ubicada en Puerto Leguizamo (Putumayo). Ella fue nombrada en provisionalidad⁷ y ejerció sus funciones entre el 15 de mayo de 1998 y el 15 de marzo de 2022 con una asignación mensual neta de \$3.385.928, la cual después de los descuentos se estimaba en \$1,317,685. De acuerdo con lo probado en el expediente, laboró durante los siguientes periodos⁸:

Empleador	Periodos Laborados
Industrias Cato S.A.	27/07/1981 - 25/09/1981
Industrias Cato S.A.	26/04/1982 – 26/08/1982
Servicios y asesorías del Valle	01/12/1982 – 02/05/1983
Servicios y asesorías del Valle	22/08/1983 – 01/09/1984
Secretaría de Educación Departamental de Putumayo	15/05/1998 – 15/03/2022

5. *Convocatoria concurso de méritos.* Mediante Acuerdo No. CNSC-20191000005986 del 14 de mayo de 2019⁹, la Comisión Nacional del Servicio Civil (en adelante CNSC) convocó a concurso de méritos para proveer definitivamente 42 vacantes en el cargo auxiliar de servicios generales código 470¹⁰ de la Gobernación de Putumayo. Entre aquellos cargos estaba el ocupado por la accionante.

6. *La solicitud de actualización de datos a COLPENSIONES.* El 4 de noviembre de 2021, la accionante solicitó a la Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES) la actualización de las semanas cotizadas a pensión en su historia laboral. Mediante comunicación del 11 siguiente, la entidad informó a la actora que “(...) *con relación a los periodos 15-05-1998 al 30-06-2009 con el empleador SECRETARIA (sic) DE EDUCACIÓN DEL PUTUMAYO, se requirió a la entidad encargada por medio de BZ 2021_12798401 del 28 de octubre de 2021, dar inicio a las gestiones tendientes del traslado de sus aportes con el fin de normalizar su historia laboral. Por lo anterior, se sugiere validar con posterioridad(...)*”¹¹.

7. *La conformación de lista de elegibles.* El 17 de noviembre de 2021¹², la

6Anterior Colegio Nacional José María Hernández. Decreto N° 0042 del 13 de mayo de 1998. Tomado de expediente digital: “ANEXOS_28_6_2022, 8_54_53.pdf”. Pág. 2.

7Decreto N° 0042 del 13 de mayo de 1998. “Por medio del cual se hace un nombramiento provisional a un administrativo del Colegio José María Hernández del Municipio de Puerto Leguizamo, mientras se convoca concurso”. Tomado de expediente digital: “ANEXOS_28_6_2022, 8_54_53.pdf”. Pág. 2.

8Historia laboral del 26 de enero de 2023 elaborada por COLPENSIONES. Tomado de expediente digital: “HL.pdf”.

9Tomado de expediente digital: “19-RespuestaAccionDeTutelaCNSC.pdf”. Pág.1.

10Proceso de selección territorial 2019- Gobernación de Putumayo. Tomado de expediente digital: “19-RespuestaAccionDeTutelaCNSC.pdf”. Pág.1.

11Tomado de expediente digital: “Respuesta2021_11479895_2021_11_11_17_42.pdf”. Pág. 1.

CNSC conformó la lista de elegibles¹³ con los aspirantes que superaron las etapas del concurso de mérito para el cargo de auxiliar de servicios generales código 470.

8. *La primera solicitud de reconocimiento de la condición de prepensionada.* El 29 de noviembre de 2021, la accionante solicitó a la SED reconocer su calidad de prepensionada porque, a su juicio, le faltaban menos de tres años para cumplir los requisitos para acceder a la pensión de vejez, según el artículo 8° de la Ley 2040 de 2020¹⁴. Expresó que si es desvinculada, sufriría un perjuicio grave porque depende de su salario para subsistir, pues por su edad no podría conseguir un nuevo empleo. A través de comunicación del 6 de enero de 2022¹⁵, la entidad, le manifestó que garantizaría su estabilidad laboral¹⁶. Lo expuesto, porque la actora contaba con 58 años y 1196 semanas cotizadas a pensión¹⁷.

9. *La desvinculación de la accionante.* Mediante Resolución No. 1224 del 24 de febrero de 2022¹⁸, la SED desvinculó del cargo a la accionante, con efectos a partir del 15 de marzo de 2022. En su lugar, nombró a la señora Ingri Paola Cortés Ortiz, quien hacía parte de la lista de elegibles conformada por la CNSC, de acuerdo con el concurso de méritos adelantado.

10. *La segunda solicitud de reconocimiento de la condición de prepensionada.* Mediante apoderado¹⁹, el 21 de marzo de 2022, la demandante solicitó nuevamente a la SED su reintegro “sin solución de continuidad” , el pago de los

12Comisión Nacional del Servicio Civil. Resolución N° 10797 del 17 de noviembre de 2021. Tomado de expediente digital: “19-RespuestaAccionDeTutelaCNSC.pdf”. Págs. 1-4.

13“(…) [U]na vez realizadas todas las etapas del proceso de selección y publicados los resultados definitivos obtenidos por los aspirantes en cada una de las pruebas aplicadas, la CNSC elaborará en estricto orden de mérito la lista de elegibles que tendrá una vigencia de dos (2) años. Con esta y en estricto orden de méritos se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso.(…)”. Tomado de expediente digital: “19-RespuestaAccionDeTutelaCNSC.pdf”. Pág.1.

14Ley 2040 de 2020. “Artículo 8°. Protección en caso de reestructuración administrativa o provisión definitiva de cargos. Las personas a las que les falte tres años o menos para cumplir los requisitos que les permitirían acceder a la pensión de jubilación o vejez, que hagan parte de las plantas de las entidades públicas en nombramiento provisional o temporal y que, derivado de procesos de reestructuración administrativa o provisión definitiva de cargos públicos a través de concursos de mérito, deberían ser separados de sus cargos, serán sujetos de especial protección por parte del Estado y en virtud de la misma deberán ser reubicados hasta tanto adquieran los requisitos mínimos para el acceso al beneficio pensional.”.

15Tomado de expediente digital: “RTA PUT2021032137”. Págs.1-3.

16“(…) [E]ste despacho procederá a generar una solución para garantizar la continuidad laboral en la entidad, con el fin que no se vea vulnerado el status de prepensionada de la señora GALINDEZ JOVEN BLANCA BELLANI (sic)(…)”. Ibidem. Pág. 10.

17“(…) [A] la fecha tiene 58 años, (cumple con el requisito de edad pues tiene más de la edad mínima de 54 años); ahora si analizamos el tiempo de servicios, tiene 23 años. (Lo que equivale, aproximadamente 1.196 semanas cotizadas) En conclusión, Si cumple con la edad mínima, y además, con el requisito de tiempo de servicio)(…)”

18Secretaria de Educación Departamental. Resolución 1224 del 24 de febrero de 2022. Tomado de expediente digital: “ANEXOS_28_6_2022, 8_54_53.pdf”. Págs.6-8.

19Luis Alberto Ortega Revelo. Poder. Tomado de expediente digital: “ANEXOS_28_6_2022, 8_54_53.pdf”. Págs.17-19.

Derecho de petición del 21 de marzo de 2022. Tomado de expediente digital: “DEMANDA_28_6_2022, 8_55_33”. Págs. 1-7.

salarios dejados de percibir y demás acreencias laborales desde el momento en que fue desvinculada²⁰. Consideró que su condición de prepensionada le permite acceder a una especial protección constitucional, porque tiene 59 años y ha cotizado más de 1200 semanas al sistema pensional. En respuesta del 21 de abril del 2022²¹, la SED informó que “(...) la señora Blanca Bellanid Galíndez Joven cuenta con 1.016 semanas según reporte de Colpensiones, por consiguiente no cumple con el requisito de haber cotizado las 1.150 semanas exigida[s] para obtener la calidad de pre pensionad[a](sic), lo que impide acceder a sus pretensiones.(...)”.

11. *El recurso de reposición y en subsidio de apelación.* El 28 de abril de 2022, la actora presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la anterior decisión²². Indicó que goza de la calidad de prepensionada, por tanto, pidió revisar su historial laboral para corroborar el número de semanas aportadas a COLPENSIONES. A través de la Resolución 2936 del 21 de junio de 2022²³, la SED negó el recurso y reiteró que la demandante no acreditó los requisitos para adquirir la condición de prepensionada²⁴. Concluyó que: “(...) [aquella] cuenta con el reporte de 968,14 semanas cotizadas en pensiones por (sic) Colpensiones a corte 18 de febrero de 2021, (...), lo que permite presumir que, a la fecha de su desvinculación, es decir el 15 de marzo de 2022, no tendría las semanas efectivamente cotizadas, teniendo en cuenta que cada año tiene 52 semanas de cotización.(...)”²⁵.

12. *La desafiliación al sistema de seguridad social en salud de la actora.* El 15 de junio de 2022, la accionante fue desafiliada del régimen de seguridad social en salud. Lo anterior, porque el artículo 66²⁶ del Decreto 2353 de 2015 dispuso

20 “PRETENSIONES: (sic) 1. Sírvasse reintegrar a la señora BLANCA BELLANID GALINDEZ JOVEN en su cargo de Auxiliar de Servicios General o a uno superior, por ostentar una estabilidad reforzada al haber alcanzado categoría de prepensionada. 2. El lugar o sitio de reintegro no debe atentar contra la unidad familiar, ni ocasionarle gastos de transporte. 3. El reintegro debe ser sin solución de continuidad, se debe cancelar todos los salarios dejados de percibir, con sus primas y demás derechos laborales y prestaciones que gozaba mi representada.” Tomado de expediente digital: “DEMANDA_28_6_2022, 8_55_33”. Pág. 6.

21 Tomado de expediente digital: “ANEXOS_28_6_2022, 8_54_53.pdf”. Págs. 11-12.

22 “[I]nterposición de recurso de reposición y en subsidio apelación contra el acto administrativo mediante el cual da respuesta a la petición No radico PUT2022ER006587 del 23/03/2022. Oficio de salida PUT2022EE010321 del 21 de abril de 2022”. Tomado de expediente digital: “RECURSO REPOSICION.pdf”. Págs. 1-3.

23 Secretaría de Educación Departamental de Putumayo. Resolución No. 2936 del 21 de junio de 2022. Tomado de expediente digital: “RESOLUCION 2936 BLANCA BELLANDI GALINDEZ JOVEN.pdf. Págs. 1-12.

24 De igual forma, no concedió el recurso de apelación. Al respecto, afirmó que cuenta con delegación expresa de las funciones para resolver y agotar la vía gubernativa de todos los asuntos que conoce su dependencia. Tomado de expediente digital: “RESOLUCION 2936 BLANCA BELLANDI GALINDEZ JOVEN.pdf. Pág. 8

25 Secretaría de Educación Departamental de Putumayo. Resolución No. 2936 del 21 de junio de 2022. Tomado de expediente digital: “RESOLUCION 2936 BLANCA BELLANDI GALINDEZ JOVEN.pdf. Pág. 8.

26 Decreto 2353 de 2015. “Artículo 66. Período de protección laboral. Cuando el empleador reporte la novedad de terminación del vínculo laboral o cuando el trabajador independiente pierda las condiciones para continuar como cotizante y reporte la novedad, el cotizante y su núcleo familiar gozarán del período de protección laboral hasta por uno (1) o tres (3) meses

un periodo de protección laboral ante la desvinculación laboral del titular que lo beneficia por un periodo de tres meses.

13. *La acción de tutela.* Por lo anterior, el 28 de junio de 2022, mediante apoderado²⁷, la demandante presentó acción de tutela²⁸. Según su escrito, la SED afectó sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, a la seguridad social, a la estabilidad laboral reforzada, al debido proceso y al mínimo vital porque finalizó su vínculo laboral sin tener en cuenta su condición de prepensionada. Con fundamento en certificación laboral expedido por SED²⁹, afirmó que, a la fecha de su desvinculación contaba con 59 años y 1224 semanas trabajadas. En tal sentido, pidió al juez de tutela ordenar a la demandada su reintegro sin solución de continuidad en el puesto de trabajo que desempeñaba o en uno superior. Además, que le pague los aportes, las acreencias laborales y los salarios dejados de percibir³⁰.

14. *El auto de admisión.* El 28 de junio de 2022, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Mocoa admitió la acción de tutela³¹. Vinculó al trámite a la accionada, al Departamento de Putumayo, a la CNSC, a COLPENSIONES y a la señora Ingri Paola Cortés Ortiz, a quienes les concedió el término de dos días para que ejercieran sus derechos de defensa y contradicción.

15. *Las respuestas de las accionadas y/o vinculadas:*

Respuestas allegadas al trámite	
Entidad	Argumento
Secretaría Departamental de Educación ³² y Gobernación del Departamento de Putumayo ³³	En escritos separados, pidieron no tutelar los derechos invocados por la accionante. Manifestaron que la desvinculación laboral de aquella tuvo fundamento en la provisión definitiva del cargo que había ocupado en provisionalidad. Con fundamento en la Sentencia SU-917 de 2010, afirmaron que la estabilidad laboral cede frente al derecho de quienes superaron el concurso público de méritos. De otro lado, señalaron que no está acreditado el requisito de subsidiariedad, pues la acción de tutela no procede para solicitar el reintegro de empleados públicos. Además, indicaron que, en ese momento, el recurso de reposición y en subsidio apelación interpuesto no había sido desatado. Por lo tanto, solicitaron

más contados a partir del día siguiente al vencimiento del período o días por los cuales se efectuó la última cotización. Durante el periodo de protección laboral, el afiliado cotizante y su núcleo familiar tendrán derecho a la prestación de los servicios de salud del plan de beneficios por el periodo de un {1} mes cuando haya estado inscrito en la misma EPS como mínimo los doce (12) meses anteriores y de tres (3) meses cuando haya estado inscrito de manera continua durante cinco (5) años o más. (...)”.

27Luis Alberto Ortega Revelo. Poder. Tomado de expediente digital: “ANEXOS_28_6_2022, 8_54_53.pdf”. Págs.17-19.
28Acta Individual de Reparto. Tomado de expediente digital: “02-Acta312JzCivilMpal.pdf”.
29Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral – Consecutivo No.710. Secretaría de Educación Departamental de Putumayo. Tomado de expediente digital: “ANEXOS_28_6_2022, 8_54_53.pdf”. Pág. 13-16.
30Tomado de expediente digital. “03-TutelaBlancaGalindezVsSecretariaDeEducacion.pdf”. Págs. 1-15.
31Tomado de expediente digital. Carpeta: “02SegundaInstanciaJCctoM2022-00126-01”. Documento: “05-Autoadmite.pdf”. pág. 2.
32Tomado de expediente digital. Documento: “11-RespuestaAccionDeTutelaSED.pdf”.
33Tomado de expediente digital. Documento: “22-RespuestaAccionDeTutelaGobernacion.pdf”.

	declarar improcedente el amparo.
COLPENSIONES ³⁴	Sostuvo que los hechos y pretensiones que fundamentaron la interposición de la tutela no están dentro del marco de sus competencias. En consecuencia, solicitó su desvinculación.
Comisión Nacional del Servicio Civil ³⁵	Expresó que la solicitud de amparo es improcedente en relación con aquella por falta de legitimación en la causa por pasiva. De igual manera, encontró que la actora no superó la etapa de verificación de los requisitos mínimos en el concurso de méritos que adelantó. Finalmente, afirmó que los empleados provisionales cuentan con estabilidad laboral, hasta tanto un servidor público no adquiera derechos de carrera a través del mérito.
Ingri Paola Cortés Ortiz ³⁶	Informó que actualmente ocupa el cargo de Auxiliar de Servicios Generales Código 470 Grado 2 porque ganó el concurso de méritos. Sin embargo, solicitó ser reubicada en un cargo similar dentro del municipio de Mocoa. A su juicio, esta fórmula permite que la demandante continúe en el ejercicio de sus labores.

Decisiones objeto de revisión

16. *La sentencia de primera instancia*³⁷. El 12 de julio de 2022, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Mocoa (Putumayo) negó el amparo. Al respecto, consideró que: (i) el reintegro por vía de tutela procede solamente cuando se demuestra la vulneración a un derecho fundamental como el mínimo vital y la dignidad humana. Sin embargo, la accionante no presentó elementos de prueba que soporten dicha afectación, más allá de sus afirmaciones; y, (ii) la desvinculación de la actora obedeció a la provisión definitiva del empleo que ostentó en provisionalidad. En tal sentido, su retiro no fue caprichoso y no hubo afectación a sus derechos fundamentales.

17. *La impugnación*³⁸. La accionante impugnó la decisión de primera instancia. Afirmó que no cuenta con los recursos que garantizan su mínimo vital y que padece de hipertensión arterial, prediabetes y obesidad³⁹. Además, señaló que es responsable de los gastos de educación, alimentación y alojamiento de su hijo de 24 años⁴⁰. A su juicio, estos elementos permiten acudir a la acción de tutela, en lugar de ejercer los mecanismos ordinarios de defensa. En consecuencia, solicitó amparar sus derechos y ordenar el reintegro laboral.

18. *La sentencia de segunda instancia*⁴¹. El 23 de agosto de 2022, el Juzgado

34Tomado de expediente digital. Documento: “16-RespuestaAccionDeTutelaColpensiones.pdf”.

35Tomado de expediente digital. Documento: “19-RespuestaAccionDeTutelaCNSC.pdf”.

36Tomado de expediente digital. Documento: “13-RespuestaAccionDeTutelaIngriCortez.pdf”.

37Sentencia del 12 de julio de 2022 proferida por el Juzgado 2 Civil Municipal de Mocoa. Tomado de expediente digital. Documento: “24-Falloniegaderechos.pdf”. pág. 1.

38Tomado de expediente digital. Documento: “blanca impugnación tutela Corregido.pdf”.

39Tomado de expediente digital. Documento: “blanca impugnacion tutela Corregido.pdf”. Pág. 5.

40Anexo: Historia Clínica, Copia de la finalización de la atención médica a la señora Blanca Bellanid, por parte de la NUEVA EPS, copia del último comprobante de pago, copia del crédito que la señora Blanca Bellanid tiene con el banco BBVA, declaración notarial extra proceso, en la que manifestó tener una vivienda avaluada en \$30.000.000 como único patrimonio, carta dirigida a la señora Juez, constancia de estudio del señor José Luis Andrade Galíndez y registro civil del hijo de la accionante.

41Tomado de expediente digital. Documento: “04FalloSegundaInstancia20220823.pdf”.

Civil del Circuito de Mocoa revocó la decisión de primera instancia. En su lugar, declaró improcedente el amparo. Expresó que la accionante puede acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para obtener un pronunciamiento sobre la validez del acto administrativo que ordenó su desvinculación sin tener en cuenta su condición de prepensionada. De igual forma, valoró los documentos aportados con el escrito de impugnación. Sobre aquellos, señaló que la accionante: (i) no es una persona de la tercera edad; (ii) tiene algunas afectaciones en su salud, las cuales están controladas; (iii) puede afiliarse al régimen subsidiado de salud o ser beneficiaria de su cónyuge; y, (iv) cuenta con una situación económica estable, pues tiene el apoyo económico de su pareja. Por último, argumentó que no es posible determinar el número de semanas cotizadas a pensión debido a la inexactitud de la información⁴².

Actuaciones en sede de revisión

19. *El decreto oficioso de pruebas.* Mediante auto del 5 de diciembre de 2022⁴³, el magistrado sustanciador decretó pruebas de oficio. Al respecto, (i) solicitó información a la accionante sobre su estado de salud, su situación económica, entre otras; y, (iii) ofició a COLPENSIONES a la SED y a la CNSC para que allegaran documentos relacionados con la situación de la accionante y respondieran algunos interrogantes sobre los hechos expuestos en la tutela.

20. *Las respuestas de las entidades oficiadas al auto de pruebas:*

Respuestas allegadas al trámite	
Entidad	Argumento
Blanca Bellanid Galíndez Joven ⁴⁴	Afirmó que su núcleo familiar está compuesto por su esposo de 56 años, quien se desempeña como docente de la SED; y, su hijo de 24 años, quien estudia en la Normal Superior de Florencia ⁴⁵ . Indicó que su esposo sufre de dolencias abdominales y que su hijo nació con una afectación respiratoria que aún persiste. Respecto de su situación económica y laboral, señaló que actualmente no labora y que los medios económicos para la subsistencia de su familia dependen de los ingresos de su esposo que ascienden a \$3.944.525, suma que después de los descuentos legales y créditos de libranza se estima en \$1.987.154 ⁴⁶ . Mencionó que con ellos cubren el pago de servicios públicos, obligaciones bancarias, alimentación, así como la educación y manutención de su hijo. Destacó que su esposo y ella tienen algunas obligaciones crediticias de aproximadamente \$70.000.000 cada una. En

42En concreto, señaló que persiste una indeterminación en cuanto a las semanas cotizadas por la accionante. Manifestó que la información aportada por la accionante y la SED no coincide. Por tal razón, en su criterio, es necesario hacer la verificación con la entidad que tiene a su cargo la administración de los aportes a pensión. Tomado de expediente digital: “04fFalloSegundaInstancia20220823.pdf”.

43Tomado de expediente digital: “Auto_de_pruebas_T8987455.pdf”.

44Tomado de expediente digital: “2.1 RESPUESTAS CORTE CONSTITUCIONAL.pdf”.

45El cual depende económicamente de sus padres.

46El esposo de la demandante recibe (i) un salario como docente activo por un valor básico de \$2.305.574, el cual después de los descuentos se estima en \$1.242.098; (ii) además, es titular de una pensión de jubilación por valor de \$1.638.951. La cual, después de los descuentos se estima en \$745.056. En total, el esposo de la accionante recibe por concepto de ingresos \$3.944.525 , suma que después de los descuentos quedaría en \$1.987.154. Tomado de expediente digital: “7.DESPREDIBLE-OCTUBRE.pdf” y “ 9.COMPROBANTE DE NOMINA-GENTIL.pdf”.

	relación con su estado de salud, manifestó que no está afiliada a ninguna E.P.S. Por lo tanto, no ha continuado con el tratamiento de las patologías que padece ⁴⁷ . Finalmente, informó que no ha promovido ninguna actuación judicial diferente a la acción de tutela ⁴⁸ .
COLPENSIONES ⁴⁹	Remitió copia de la Certificación de Tiempos Laborados (CETIL) y el reporte de semanas cotizadas al sistema pensional. A pesar de ello, la información contenida en aquellos documentos no precisó los aportes y los tiempos laborados por la actora. El primer documento demuestra que la accionante laboró desde el mes de mayo de 1998 hasta el mes de marzo de 2022. Sin embargo, el reporte de semanas cotizadas a pensión solo certificó el periodo comprendido entre octubre de 2002 y marzo de 2022.
Secretaría Departamental de Educación ⁵⁰	Informó que en su planta existen 97 cargos similares al que tenía la accionante. Al respecto, explicó que en la Institución Educativa en la cual laboró la demandante, existen 4 cargos, de los cuales dos están en vacancia definitiva. Estos últimos deben ser provistos mediante la lista de elegibles. De otro lado, afirmó que la accionante no cumplió con el requisito de haber cotizado 1.150 semanas al sistema pensional. Por lo tanto, no fue posible reconocerla como prepensionada.

21. *El requerimiento para el cumplimiento del auto de pruebas.* El 17 de enero de 2023, el magistrado sustanciador requirió⁵¹ a la SED para que respondiera algunos interrogantes puntuales sobre la situación laboral de la demandante y, a la CNSC para que cumpliera con lo ordenado en el auto de solicitud de pruebas. Adicionalmente, solicitó a COLPENSIONES precisar la información sobre los tiempos laborados y los aportados efectivamente al sistema pensional.

22. *Las respuestas de las entidades oficiadas al auto de requerimiento:*

Respuestas allegadas al trámite	
Entidad	Argumento

47Hipertensión, pre-diabetes y obesidad.
48Como soporte a sus respuestas, la accionante aportó los siguientes documentos: (i) su historia clínica y la de su esposo; (ii) los extractos de su crédito bancario con BBVA (\$64.968.805,47); (iii) los soportes del crédito bancario con BBVA (\$68.265.188,00) y de libranza con FINSOCIAL (\$42.963.428) de los que es titular su esposo; y, (iv) los desprendibles de pago del salario a cargo de la Secretaria de Educación de Putumayo y comprobantes de nómina del FOMAG por concepto de pensión de jubilación, ambos de su esposo.
49Tomado de expediente digital: “*Respuesta2022_18548474_2022_12_20_7_33.pdf*”.
50Tomado de expediente digital: “*RESPUESTA AUTO CORTE CONSTITUCIONAL.pdf*”.
51Tomado de expediente digital: “*Requerimiento-Pruebas-T-8987455*”.

Secretaría Departamental de Educación ⁵²	La entidad afirmó que la accionante contó con una sola vinculación laboral sin interrupciones y que el registro de sus cotizaciones a la seguridad social en pensión es el contenido en el certificado de tiempos de servicios No. 3283 ⁵³ . En aquel consta que la actora laboró por 23 años y 10 meses, entre el 13 de mayo de 1998 y el 14 de marzo de 2022.																						
Comisión Nacional del Servicio Civil ⁵⁴	Aportó los documentos relacionados con el concurso de méritos para proveer cuarenta y dos (42) cargos de Auxiliar de Servicios Generales, código 470, Grado 2 ⁵⁵ dentro de la Gobernación de Putumayo. Al respecto, informó que mediante el Acuerdo No. 20191000005986 del 14 de mayo de 2019 inició la convocatoria para proveer dichas vacantes, la cual finalizó el 17 de noviembre de 2022, con la conformación de las listas de elegibles para ocupar esos cargos. De otro lado, expresó que las entidades no deben identificar la condición de prepensionado de las personas que ocupan las vacantes que serán ofertadas a través del concurso. Sin embargo, el Concepto Marco No. 9 del 2018 estableció los lineamientos para la provisión de cargos con listas de elegibles y la protección de las personas en situación de discapacidad, madres y padres cabeza de familia y prepensionados.																						
COLPENSIONES ⁵⁶	Informó sobre las gestiones que realizó ante la UGPP⁵⁷ y la SED para regularizar el historial laboral de la accionante. Al respecto, indicó que, de acuerdo con la CETIL, entre mayo de 1998 y junio de 2009, los aportes pensionales fueron cotizados a CAJANAL (hoy UGPP). A través de la Resolución RDP 001693 del 26 de enero de 2022, la UGPP autorizó el traslado de tales aportes. Sin embargo, COLPENSIONES también encontró en sus registros, aportes cotizados entre octubre de 2002 y marzo de 2022, lo que significa que la SED certificó aportes por los mismos periodos de cotización en dos administradoras de pensiones diferentes. Por tal situación, concluyó que la información reportada en la CETIL presenta inconsistencias. A partir de lo expuesto, consideró que la SED debe corregir y aclarar dicha situación para proceder a validar los soportes de las cotizaciones que traslade la UGPP para normalizar el historial laboral de la actora⁵⁸. Sin embargo, no lo ha hecho. A pesar de ello aportó la historial laboral del 26 de enero de 2022, en el que se acreditaron las siguientes cotizaciones: <table><tr><th>Empleador</th><th>Periodos laborados</th><th>Semanas</th></tr><tr><td>Industrias Cato S.A.</td><td>27/07/1981 - 25/09/1981</td><td>8,71</td></tr><tr><td>Industrias Cato S.A.</td><td>26/04/1982 – 26/08/1982</td><td>17,57</td></tr><tr><td>Servicios y asesorías del Valle</td><td>01/12/1982 – 02/05/1983</td><td>21,86</td></tr><tr><td>Servicios y asesorías del Valle</td><td>22/08/1983 – 01/09/1984</td><td>46</td></tr><tr><td>Secretaría de Educación Departamental de Putumayo</td><td>01/10/2002 – 31/03/2022</td><td>987,55</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td></td><td>1.081,71</td></tr></table>		Empleador	Periodos laborados	Semanas	Industrias Cato S.A.	27/07/1981 - 25/09/1981	8,71	Industrias Cato S.A.	26/04/1982 – 26/08/1982	17,57	Servicios y asesorías del Valle	01/12/1982 – 02/05/1983	21,86	Servicios y asesorías del Valle	22/08/1983 – 01/09/1984	46	Secretaría de Educación Departamental de Putumayo	01/10/2002 – 31/03/2022	987,55	TOTAL		1.081,71
Empleador	Periodos laborados	Semanas																					
Industrias Cato S.A.	27/07/1981 - 25/09/1981	8,71																					
Industrias Cato S.A.	26/04/1982 – 26/08/1982	17,57																					
Servicios y asesorías del Valle	01/12/1982 – 02/05/1983	21,86																					
Servicios y asesorías del Valle	22/08/1983 – 01/09/1984	46																					
Secretaría de Educación Departamental de Putumayo	01/10/2002 – 31/03/2022	987,55																					
TOTAL		1.081,71																					

52Tomado de expediente digital: “*RESPUESTA AUTO ENERO CORTE CONSTITUCIONAL.pdf*”.

53Tomado de expediente digital: “*TIEMPO DE SERVICIO GALIMDEZ J. BLANCA.pdf*”.

54Tomado de expediente digital: “*Blanca Bellanid Galíndez Joven-RESPUESTA A REQUERIMIENTO DE PRUEBAS EN SEDE DE REVISION.pdf*”.

55Tomado de expediente digital:
“*ACUERDO_20191000005986_GOBERNACION_PUTUMAYO.pdf*”, “*2021RES-400.300.24-9216 OPEC 25976.pdf*”, “*2021RES-400.300.24-9239 opec 120420.pdf*”, “*2021RES-400.300.24-9247 OPEC 25975.pdf*” y “*2021RES-400.300.24-10797 OPEC 25974.pdf*”.

56Tomado de expediente digital: “*Respuesta2023_1115175_2023_1_27_7_56.pdf*”.

57Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales.

58[N]o podemos cargar únicamente los ciclos faltantes 199805 a 200209, puesto que la Resolución de la UGPP informa más periodos y un total a pagar que los incluye. Para dar solución a tal yerro de la entidad certificadora, se realizó solicitud para corregir la certificación en la plataforma cetil 20220000212639 sin que a la fecha la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL PUTUMAYO haya corregido dicha situación.”. Tomado de expediente digital: “*Respuesta2023_1115175_2023_1_27_7_56*” Pág. 2.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

23. La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela proferidos dentro del proceso de la referencia. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241.9 de la Carta, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

Asunto objeto de análisis

24. En esta oportunidad, la Sala estudia el caso de una mujer que fue desvinculada de un cargo en provisionalidad, como Auxiliar de Servicios Generales, sin tener en cuenta su calidad de prepensionada. La SED argumentó que ello obedeció a la provisión definitiva del empleo con la persona que superó las etapas del concurso de méritos. Asimismo, afirmó que la accionante no cumplía con los requisitos necesarios para ser beneficiaria de la condición de prepensionada, porque su historia laboral no demostró que le faltaran menos de tres años para obtener su pensión de vejez. Lo expuesto, a pesar de las inconsistencias que presentaba dicho documento en relación con el número de semanas cotizadas.

25. El amparo busca la protección de los derechos fundamentales a la seguridad social, la estabilidad laboral reforzada, el mínimo vital y el debido proceso de la actora. En consecuencia, pide al juez de tutela ordenar: (i) reintegrarla sin solución de continuidad al cargo que desempeñaba o a uno equivalente; y, (ii) pagarle los salarios y demás prestaciones laborales dejadas de percibir⁵⁹.

26. A continuación, la Sala analizará la procedencia de la acción de tutela de acuerdo con los criterios legales y jurisprudenciales establecidos.

Procedencia de la acción de tutela

27. *Legitimación por activa.* El artículo 86 de la Constitución⁶⁰ establece que cualquier persona puede interponer la acción de tutela “*por sí misma o por quien actúe en su nombre*”, con el fin de reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten amenazados o vulnerados por la acción u omisión de una autoridad o por el actuar de particulares. En concreto, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991⁶¹ define que la acción de tutela puede

59Tomado de Expediente digital: “03-TutelaBlancaGalindezVsSecretariaDeEducacion”. Pág. 13.

60Constitución Política. “Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.(...)”.

61Decreto 2591 de 1991. “Artículo 10. LEGITIMIDAD E INTERES. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de

ejererse, entre otros, a nombre propio o mediante apoderado judicial. En el caso objeto de estudio, la acción de tutela fue presentada por el señor Luis Alberto Ortega Revelo, como apoderado de la señora Blanca Bellanid Galíndez Joven, con el fin de proteger sus derechos fundamentales a la seguridad social, a la estabilidad laboral reforzada y al mínimo vital. En tal sentido, es claro que quien presenta la acción de tutela es la afectada y cuenta con la debida representación para actuar dentro de este trámite⁶². Por lo tanto, la legitimación por activa está comprobada⁶³.

28. *Legitimación por pasiva*. Este presupuesto hace referencia a la capacidad legal de quien está llamado a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental⁶⁴. En este caso, la acción de tutela se dirigió inicialmente en contra de la Secretaría de Educación del Departamento de Putumayo, por ser la entidad que desvinculó del cargo a la accionante. Adicionalmente, dicha entidad tenía deberes de actualización y gestión de la información de la historia laboral de la peticionaria. La Sala observa que aquella tiene aptitud y capacidad para ser parte del proceso y, en esa medida, está legitimada por pasiva.

29. De otro lado, la autoridad de primera instancia vinculó al trámite a COLPENSIONES, a la Comisión Nacional del Servicio Civil, a la Gobernación de Putumayo y a la señora Ingri Paola Cortés Ortiz. Al respecto, la Sala encuentra acreditada la legitimación por pasiva únicamente en relación con COLPENSIONES. Lo expuesto, porque en ejercicio de sus competencias, le corresponde gestionar y actualizar el historial laboral de la accionante⁶⁵. En relación con la CNSC y la Gobernación de Putumayo la Sala advierte que carecen de legitimación por pasiva porque no administran la información laboral ni los aportes a pensión de la actora y tampoco participaron en la desvinculación del cargo de la accionante. Por esa razón, serán desvinculadas. Por otra parte, la señora Ingri Paola Cortés Ortiz no cumple con los requisitos previstos en la ley para ser accionada como particular en este caso⁶⁶. Sin embargo, aquella puede intervenir como tercero con interés por ocupar el cargo que desempeñaba la accionante. En ese sentido, se mantendrá su condición dentro del trámite, pues la

representante. Los poderes se presumirán auténticos. || También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. || También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.”

62Luis Alberto Ortega Revelo. Poder. Tomado de expediente digital: “ANEXOS_28_6_2022, 8_54_53.pdf”. Págs.17-19.

63Adicionalmente, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece que “los poderes se presumirán auténticos”.

64Ver sentencias T-1015 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-780 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-373 de 2015 y T-098 de 2016 ambas con ponencia de la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, entre otras.

65Decreto 309 de 2017. “Por el cual se modifica la estructura de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)”. “Artículo 5°. Funciones. En desarrollo de su objeto, la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), cumplirá las siguientes funciones: (...) 9. Gestionar la historia laboral y pensional, las cuentas individuales de los vinculados, los registros de novedades y la consistencia de la información. 10. Gestionar el manejo, administración, control, custodia y conservación de los expedientes pensionales, en los términos previstos en las normas vigentes”.

66En efecto, no está encargada de prestar ningún servicio público ni existe una relación de subordinación o indefensión en relación con la demandante.

definición de la situación jurídica de la demandante incide en su vinculación laboral con la SED⁶⁷.

30. *Inmediatez*. Esta Corporación ha señalado que este requisito se cumple cuando es razonable: (i) el tiempo que va desde que se produjo la vulneración o amenaza a los derechos fundamentales, hasta la presentación de la acción de tutela; y/o, (ii) el lapso en el cual se promovió la última actuación en defensa de los derechos aparentemente vulnerados y la solicitud de amparo (T-176 de 2018⁶⁸). También, procede la acción cuando la vulneración de los derechos de la víctima permanecen en el tiempo (T-413 de 2019⁶⁹).

31. La Sala estima que el presente caso satisface este presupuesto. La última actuación que la accionante promovió ante la SED en defensa de sus derechos fue resuelta desfavorablemente mediante resolución del 21 de junio de 2022⁷⁰; y, la acción de tutela fue presentada el 28 de junio del mismo año⁷¹. En ese sentido, el término de 7 días entre ambos eventos es razonable y perentorio. Asimismo, los efectos jurídicos y económicos del acto de desvinculación se han mantenido en el tiempo. Lo anterior, genera un perjuicio constante en la capacidad adquisitiva de la accionante y las expectativas de acceder a una pensión de vejez.

32. *Subsidiariedad*. De conformidad con los artículos 86⁷² de la Constitución y el 6^o⁷³ del Decreto 2591 de 1991 la acción de tutela es un recurso subsidiario que procede cuando: (i) no existan medios de defensa judicial; y, (ii) se utilice de manera transitoria para evitar un perjuicio irremediable. La Corte ha establecido que cuando se solicita el reintegro de empleados públicos el mecanismo de defensa idóneo es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (artículo 138 del CPACA⁷⁴). La naturaleza de dicho proceso permite reclamar en sede de lo contencioso administrativo, la nulidad total o parcial del

67Sentencia T-443 de 2022, M.P. Diana Fajardo Rivera.

68M.P. Alberto Rojas Ríos.

69M.P. Cristina Pardo Shlesinger.

70Secretaría de Educación Departamental de Putumayo. Resolución No. 2936 del 21 de junio de 2022. Tomado de expediente digital: “RESOLUCION 2936 BLANCA BELLANDI GALINDEZ JOVEN.pdf. Págs. 1-12.

71Acta Individual de Reparto. Tomado de expediente digital: “02-Acta312JzCivilMpal.pdf”.

72Constitución Política. “Artículo 86. (...)Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.(...)”.

73Decreto 2591 de 1991. “Artículo 6°. Causales de improcedencia de la tutela. a acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante| 2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas corpus.| 3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no obsta, para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable. 4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.| 5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto.”.

acto que presuntamente produce la vulneración de derechos y solicitar la correspondiente reparación por el daño causado (T-063 de 2022⁷⁵). Adicionalmente, dentro del trámite de dicho proceso, existe la posibilidad proponer medidas cautelares con el fin de proteger y garantizar el objeto de lo pretendido (artículo 223 del CPACA⁷⁶). Sin embargo, lo anterior no significa la improcedencia automática de la tutela. Bajo ese entendido, los jueces constitucionales están obligados a determinar la idoneidad y/o eficacia de los medios de defensa en concreto con respecto a: (i) el contenido de la pretensión y (ii) las condiciones de los sujetos involucrados (SU-691 de 2017⁷⁷).

32.1. Del mismo modo, esta Corporación ha aceptado la procedencia excepcional de la acción de tutela cuando el accionante alegue tener la calidad de prepensionado. Lo anterior, si demuestra que la desvinculación pone en riesgo su derecho al mínimo vital. Esto puede acontecer cuando una persona tiene dificultades para obtener su sustento y/o no le es posible asegurar su supervivencia autónoma por factores como la edad, el estado de salud y el tiempo que tardaría el medio de defensa judicial (T-055 de 2020⁷⁸).

32.2. Asimismo, el juez constitucional tiene la obligación de aplicar un enfoque de género. Lo anterior, con el propósito de no pasar por alto ni reforzar patrones de desigualdad que afectan especialmente a las mujeres (T- 401 de 2021⁷⁹). Esto puede suceder, por ejemplo, cuando la incapacidad de las mujeres para trabajar o recibir un salario, las sitúa en una posición de inferioridad y desigualdad social (T-878 de 2014⁸⁰). Al respecto, la Sala reitera que las mujeres son un grupo históricamente discriminado y, por esa razón, tienen un tratamiento constitucional reforzado.

32.3. Finalmente, la Corte ha avalado el estudio de acciones que recaen sobre derechos ciertos e indiscutibles, es decir, garantías que no requieren de un profundo análisis probatorio para ser reconocidas porque surgen del

74 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. “*Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.*”.

75M.P. Alberto Rojas Ríos.

76ódigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. “*Artículo 233. Procedimiento para la adopción de las medidas cautelares. La medida cautelar podrá ser solicitada desde la presentación de la demanda y en cualquier estado del proceso.(...)*”.

77 M.P. Alejandro Linares Cantillo.

78M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

79M.P. Diana Fajardo Rivera.

80M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

cumplimiento de los supuestos de hechos establecidos en la norma. Por lo tanto, no existe duda sobre su carácter real, cierto e innegable⁸¹ (T-040 de 2018⁸²).

33. En el presente caso, la accionante es una mujer, adulta mayor, de 60 años que alega tener la condición de prepensionada. La Sala encuentra que, en particular, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho no es idóneo para conocer de lo pretendido, porque la actora no cuestionó la legalidad de la resolución mediante la cual la desvincularon del cargo, y tampoco alegó alguna de las causales de nulidad establecidas en el artículo 137⁸³ del CPACA (T-373 de 2017⁸⁴). Por otro lado, dicho mecanismo no es eficaz por su prolongada duración en el tiempo⁸⁵ (T-186 de 2013⁸⁶). En ese sentido, el proceso ante lo contencioso administrativo no tiene la virtud de garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de la accionante a la seguridad social, al mínimo vital, al trabajo y la dignidad humana. Dicha intervención del juez constitucional es requerida con urgencia dada su condición de adulta mayor y sus expectativas razonables de acceder a la pensión de vejez. Adicionalmente, como

81Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencia del 08 de junio de 2011, radicado No. 3515. *“el carácter de cierto e indiscutible de un derecho laboral, que impide que sea materia de una transacción o de una conciliación, surge del cumplimiento de los supuestos de hecho o de las condiciones establecidas en la norma jurídica que lo consagra un derecho será cierto, real e innegable, cuando no haya duda sobre la existencia de los hechos que le dan origen y exista certeza de que no hay ningún elemento que impida su configuración o su exigibilidad.”*.

82M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

83Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. *“Artículo 137. Nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general. |Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular; o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió. También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro. Excepcionalmente podrá pedirse la nulidad de actos administrativos de contenido particular en los siguientes casos: |1. Cuando con la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad que se produjere no se genere el restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor del demandante o de un tercero. |2. Cuando se trate de recuperar bienes de uso público. |3. Cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en materia grave el orden público, político, económico, social o ecológico. |4. Cuando la ley lo consagre expresamente.*

84M.P. Cristina Pardo Shlesinger.

85El promedio de duración de procesos de nulidad y restablecimiento del derecho en el régimen escritural es de 844 días, mientras que en el régimen oral es de 299 días. *“Resultado del estudio de costos procesales”*. Consejo Superior de la Judicatura. 2016.Tomo II. Pág. 124. Asimismo, *“Para el caso de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho es importante mencionar que, en estos procesos la reclamación se realiza sobre un acto administrativo proferido por una entidad pública, en la que, por ejemplo, se desvinculó a un funcionario, (...) Como se evidencia gráficamente en las curvas de supervivencia de Kaplan-Meier, el valor de la media del tiempo procesal es de 2.48 años.”*. García Ramírez, V. (2022). Predictores en la duración de los procesos judiciales en Colombia. Universidad de los Andes. Pág. 15. *“Para el caso de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho es importante mencionar que, en estos procesos la reclamación se realiza sobre un acto administrativo proferido por una entidad pública, en la que, por ejemplo, se desvinculó a un funcionario, (...) Como se evidencia gráficamente en las curvas de supervivencia de Kaplan-Meier, el valor de la media del tiempo procesal es de 2.48 años.”*.

86M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

consecuencia de su desvinculación, la demandante no cuenta con los medios para garantizar su mínimo vital y subsistencia, pues no tiene un empleo, ni ha podido acceder a la pensión de vejez. En efecto, la actora demostró que no posee una fuente de ingresos y que es titular de deudas por valor aproximado de \$65.000.000⁸⁷. De igual forma, la accionante comparte con su esposo la manutención de su hijo y de su hogar. Estos compromisos se han visto intempestivamente afectados por la reducción abrupta de sus ingresos. Por lo que, resultaría desproporcionado para ella esperar el pronunciamiento del juez administrativo en perjuicio de su derecho al mínimo vital y su subsistencia (T-643 de 2015⁸⁸).

33.1. Por otro lado, la accionante se encuentra en una situación de indefensión frente al mercado laboral por su género. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)⁸⁹ la tasa de desempleo en el último trimestre para las mujeres a nivel nacional fue de 12,6%, en contraste con la de los hombres que fue de 7,8%, con una diferencia de -4,7p.p.⁹⁰. Esa brecha crece hasta llegar, en los centros poblados y rurales dispersos del país, a alcanzar -7,8 p.p. en perjuicio de las mujeres⁹¹. En cuanto a la tasa de ocupación, del 100% de las mujeres en edad de trabajar, solamente el 45,4% están efectivamente ocupadas. En contraste con el 70,6% de hombres con respecto al total de los mismos en edad de trabajar⁹². Esa situación de desigualdad evidencia una clara desventaja para acceder y permanecer en un empleo para las mujeres por el hecho de ser mujer. En el caso concreto, como consecuencia de su desvinculación del cargo de auxiliar de servicios generales, la accionante se enfrenta al panorama descrito. Escenario que se agrava por su condición de adulta mayor.

33.2. De igual forma, lo pretendido con esta acción se trata del reconocimiento de un derecho cierto e indiscutible, como lo es la estabilidad laboral por ostentar la calidad de prepensionada. Ese ejercicio, con fundamento en las pruebas que obran en el expediente, no requiere de un despliegue probatorio que desborde la acción de tutela y que deba darse en el marco de los procesos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

33.3. Por último, en relación con la pretensión relativa al pago de salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el momento de la desvinculación de la actora, la Sala advierte que la procedencia de la acción de tutela surge únicamente respecto al reintegro laboral, pues la jurisprudencia constitucional ha delimitado el estudio de estos casos en relación con el reintegro y no al pago

87Tomado de expediente digital: “Extractos de su crédito bancario con BBVA” (\$64.968.805,47).

88M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

89Gran encuesta de hogares (GEIH). Boletín técnico. Octubre- diciembre de 2022. DANE.

Tomado de: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/segun-sexo>

90P.p.: puntos porcentuales.

91Gran encuesta de hogares (GEIH). Boletín técnico. Octubre- diciembre de 2022. DANE.

Tomado de: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/segun-sexo>

92Ibidem.

de prestaciones sociales. Lo expuesto, porque en otras oportunidades, la Corte ha expresado que no puede ordenar el pago de prestaciones económicas por servicios no prestados (T-643 de 2015⁹³). En consecuencia, la demandante podrá acudir al proceso administrativo para reclamar tales emolumentos (T-063 de 2022⁹⁴).

34. La Sala concluye que la presente acción cumple con los requisitos de procedencia. Por lo tanto, fijará los problemas jurídicos y la metodología de decisión.

Problemas jurídicos y metodología de decisión

35. *Problemas jurídicos.* A partir de lo anterior, la Sala deberá resolver los siguientes problemas jurídicos:

(i) ¿COLPENSIONES y la SED vulneraron el derecho fundamental a la seguridad social al no actualizar la información contenida en la historia laboral y los aportes pensionales de la actora?

(ii) ¿La SED vulneró los derechos fundamentales, a la estabilidad laboral, al trabajo, a la seguridad social, al mínimo vital y dignidad humana de la accionante al desvincularla del cargo que ocupó en provisionalidad, para nombrar a quien superó el concurso de méritos sin considerar la condición de prepensionada que aquella alegó?

36. *Metodología de la decisión.* Para resolver los anteriores interrogantes, la Sala abordará los siguientes asuntos: (i) la estabilidad laboral reforzada de los servidores públicos nombrados en provisionalidad en condición de prepensionados; (ii) los deberes de las administradoras de pensiones y de los empleadores en relación con la información consignada en la historia laboral y la garantía del derecho a la pensión; y, (iii) resolverá el caso concreto.

37. La Sala procede, a continuación, con el estudio del fondo del caso en el orden anunciado.

La estabilidad laboral reforzada de los servidores públicos nombrados en provisionalidad que ostentan la condición de prepensionados. Reiteración de jurisprudencia

38. *De los servidores públicos nombrados en provisionalidad.* Los servidores públicos en provisionalidad gozan de una estabilidad laboral relativa. Lo anterior, implica que solo pueden ser desvinculados por causales debidamente motivadas en el acto de desvinculación. Tales como, la comisión de faltas disciplinarias o la provisión definitiva del cargo por concurso de méritos, entre otras (T-443 de 2022⁹⁵).

93M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

94M.P. Alberto Rojas Ríos.

95M.P. Diana Fajardo Rivera.

39. *De los prepensionados.* La Corte, definió que los prepensionados “(...) serán (...) aquellos a los que les falte tres años o menos para cumplir los requisitos que les permitirían acceder a la pensión de jubilación o vejez” (SU-897 de 2012⁹⁶)⁹⁷.

40. Asimismo, fijó que el fundamento del reconocimiento de la estabilidad laboral reforzada de los prepensionados tiene raigambre constitucional y que no depende de un mandato legislativo particular. En ese sentido, “(...) dicha estabilidad opera como instrumento para la satisfacción de los derechos fundamentales de estos grupos poblacionales, que se verían gravemente interferidos por el retiro del empleo(...)” (T-186 de 2013⁹⁸). Por lo tanto, su finalidad constitucional es amparar la estabilidad del trabajador que tiene una exceptiva de obtener su pensión ante la repentina pérdida del empleo (SU-003 de 2018⁹⁹).

41. Posteriormente, esta Corporación estableció que cuando el único requisito faltante para acceder a la pensión es la edad, en caso de desvinculación, no se frustra su derecho al acceso a la pensión. Lo expuesto, porque dicho requisito puede acreditarse de manera posterior, con o sin vinculación laboral (SU-003 de 2018¹⁰⁰).

42. Con fundamento en lo anterior, la Corte consolidó la regla jurisprudencial sobre la materia. En tal sentido, señaló que son beneficiarios del fuero de estabilidad laboral reforzada de prepensionable las personas vinculadas laboralmente al sector público y/o privado a los que les falten lo equivalente a tres años o menos para acreditar el requisito de semanas en el régimen de prima media o el capital necesario en el régimen de ahorro individual con solidaridad, para acceder a la pensión de vejez (SU-003 de 2018¹⁰¹).

43. *De los servidores públicos nombrados en provisionalidad que tienen la calidad de prepensionados.* La jurisprudencia indicó que con el fin de garantizar la protección especial que ofrece ser servidor público en provisionalidad y tener la calidad de prepensionado, ante la provisión definitiva de su empleo por concurso de mérito, las entidades públicas tienen los siguientes deberes: (i) motivar debidamente el acto de desvinculación; (ii) establecer los mecanismos necesarios para garantizar que dicho grupo de personas sean los últimos en ser desvinculados de sus cargos (SU-446 de 2011¹⁰²); y, (iii) mantener su permanencia en el empleo, siempre que los criterios de razonabilidad y proporcionalidad lo permitan, es decir, cuando se cuenten con vacantes para reubicarlos (T-186 de 2013¹⁰³).

96M.P. Alexei Julio Estrada.

97El artículo 34 de la Ley 100 de 1993 estableció los requisitos que deben cumplir las mujeres en el régimen de prima media para acceder a la pensión de vejez. En ese sentido, deben contar con 57 años y 1300 semanas cotizadas al sistema pensional.

98M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

99M.P. Carlos Bernal Pulido.

100M.P. Carlos Bernal Pulido.

101M.P. Carlos Bernal Pulido.

102M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

103M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

44. *Remedios constitucionales.* Ante la omisión de los anteriores deberes, la Corte, ha ordenado a las entidades públicas reubicar al prepensionado en una vacante equivalente al cargo del que fue desvinculado, que se encuentre disponible, mientras completa los requisitos para acceder a la pensión. Cuando ello no sea posible, la jurisprudencia ha dispuesto incluir al trabajador en la lista de personas con derecho a la estabilidad laboral para ser nombrado en provisionalidad en un cargo similar, hasta que obtenga su derecho pensional (T-443 de 2022¹⁰⁴).

45. *Protección legal.* Según la Ley 2040 del 2020¹⁰⁵ y el Decreto Reglamentario 1415 de 2021¹⁰⁶ los prepensionados que estén nombrados en entidades públicas en cargos provisionales y deban ser desvinculados por la provisión definitiva del mismo o por procesos de reestructuración administrativa cuentan con una protección especial. En esos casos, las entidades deben reubicar a dichos funcionarios hasta que completen los requisitos mínimos para acceder a su pensión¹⁰⁷.

Deberes de las administradoras de pensiones y de los empleadores en relación con la información consignada en la historia laboral y garantía de la pensión. Reiteración de jurisprudencia¹⁰⁸

46. La historia laboral es un documento esencial para la garantía de varios derechos fundamentales, cuya administración y conservación recae en las administradoras de pensiones, sin que los errores en su elaboración, gestión y actualización en que incurra el empleador o las administradoras de pensiones

104M.P. Diana Fajardo Rivera.

105Ley 2040 de 2020. “*Por medio de la cual se adoptan medidas para impulsar el trabajo para adultos mayores y se dictan otras disposiciones*”. “Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto impulsar el empleo de las personas adultas mayores que no gozan de pensión, promoviendo la autonomía y autosuficiencia económica del adulto mayor, garantizando así el envejecimiento activo, satisfactorio y saludable de la población colombiana”.

106Decreto 1415 de 2021. “*Por medio del cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015 en lo relacionado a la (sic) Protección en caso de reestructuración administrativa o provisión definitiva de cargos para el personal que ostente la condición de prepensionados*”. “Artículo 2°. Adicionar el artículo 2.2.12.1.2.4 al Decreto 1083 de 2015, el cual quedará así: *Provisión definitiva de cargos públicos a través de concursos de mérito. Para el caso de la provisión definitiva de cargos públicos a través de concursos de mérito de servidores públicos vinculados mediante nombramiento provisional que les falte tres (3) años o menos para causar el derecho a la pensión de jubilación o de vejez, se deberá tener en cuenta lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 263 de la Ley 1955 de 2019*”.

107 Ley 2040 de 2020. “Artículo 8°. *Protección en caso de reestructuración administrativa o provisión definitiva de cargos. Las personas a las que les falte tres años o menos para cumplir los requisitos que les permitirían acceder a la pensión de jubilación o vejez, que hagan parte de las plantas de las entidades públicas en nombramiento provisional o temporal y que, derivado de procesos de reestructuración administrativa o provisión definitiva de cargos públicos a través de concursos de mérito, deberían ser separados de sus cargos, serán sujetos de especial protección por parte del Estado y en virtud de la misma deberán ser reubicados hasta tanto adquieran los requisitos mínimos para el acceso al beneficio pensional.*”.

108T-379 de 2017 M.P. Alejandro Linares Cantillo.

puedan afectar los derechos fundamentales de los trabajadores. Al respecto, la ley y la jurisprudencia han establecido que:

46.1. La historia laboral tiene relevancia constitucional, porque permite el reconocimiento de derechos prestacionales que están sometidos a la verificación de la información en ella contenida (T-398 de 2015¹⁰⁹).

46.2. El tratamiento de los datos contenidos en ella debe observar las reglas establecidas en la Ley 1581 de 2012, en cuanto a los principios de legalidad, finalidad, libertad, veracidad, transparencia, seguridad y confidencialidad¹¹⁰. En ese sentido, la información que se suministre debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible¹¹¹.

46.3. En cuanto al principio de veracidad o calidad, la jurisprudencia exige que la información que acredita la historia laboral debe ser confiable. Es decir, debe (i) reflejar el verdadero esfuerzo económico que ha realizado el afiliado; y, (ii) ser cierta, precisa, fidedigna y estar actualizada (T-436 de 2017¹¹²).

46.4. Por ello, el Decreto 1074 de 2015¹¹³ dispuso que las administradoras de la información deben adoptar las medidas razonables para garantizar la precisión, suficiencia, actualización o rectificación de los datos que gestionan.

46.5. Por su parte, las administradoras de pensiones, como responsables del tratamiento de datos, también custodian, conservan y guardan los documentos físicos o magnéticos y las bases de datos en los que reposa la información de sus afiliados. En consecuencia, tienen la carga de la prueba sobre la veracidad y la exactitud de lo que certifican en ellas (SU-405 de 2021¹¹⁴). COLPENSIONES tiene la obligación de gestionar la historial laboral de sus afiliados y de responder por la consistencia de la información en ella contenida¹¹⁵.

109M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

110Ley 1581 de 2012. Artículo 4°. Principios para el tratamiento de datos personales.

111Ley 1581 de 2012. “Artículo 17. Deberes de los responsables del tratamiento. Los Responsables del Tratamiento deberán cumplir los siguientes deberes, sin perjuicio de las demás disposiciones previstas en la presente ley y en otras que rijan su actividad: (...) e) Garantizar que la información que se suministre al Encargado del Tratamiento sea veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible; (...)”.

112M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

113Decreto 1074 de 2015. “Artículo 2.2.2.25.4.3. Del derecho de actualización, rectificación y supresión. En desarrollo del principio de veracidad o calidad, en el tratamiento de los datos personales deberán adoptarse las medidas razonables para asegurar que los datos personales que reposan en las bases de datos sean precisos y suficientes y, cuando así lo solicite el Titular o cuando el Responsable (sic) haya podido advertirlo, sean actualizados, rectificados o suprimidos, de tal manera que satisfagan los propósitos del tratamiento.”.

114M.P. Diana Fajardo Rivera.

115Decreto 309 de 2017. “Por el cual se modifica la estructura de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)”. “Artículo 5°. Funciones. En desarrollo de su objeto, la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), cumplirá las siguientes funciones: (...) 9. Gestionar la historia laboral y pensional, las cuentas individuales de los vinculados, los registros de novedades y la consistencia de la información. 10. Gestionar el manejo, administración, control, custodia y conservación de los expedientes pensionales, en los términos previstos en las normas vigentes”.

46.6. De igual manera, es importante resaltar que las administradoras de pensiones cuentan con la infraestructura para administrar de manera adecuada la conducción de los datos de sus afiliados. De allí que, los problemas logísticos y operativos no pueden ser trasladados a los usuarios, quienes no cuentan con acceso a dicha información (T-379 de 2017¹¹⁶). En ese sentido, la desorganización y la no sistematización de los datos que deberían estar consignados en la historia laboral, no pueden repercutir negativamente en los afiliados, ni traducirse en la denegación de su derecho a la seguridad social (T-101 de 2020¹¹⁷).

46.7. Tampoco es posible trasladar a los afiliados la negligencia de las administradoras de pensiones que no logran realizar el traslado de los aportes que se encuentran cotizados en otras entidades de esa misma naturaleza. Es necesario, en consecuencia, que los fondos de pensiones ejecuten los trámites tendientes a obtener el traslado de dichos aportes (T-013 de 2020¹¹⁸).

46.8. De igual forma, es importante resaltar el deber de diligencia que tienen las administradoras de pensiones al momento de proponer ajustes en el contenido de las historias laborales de sus afiliados. Dicho deber implica garantizar que las modificaciones se realicen por razones justificadas y que los afiliados tengan las garantías del debido proceso administrativo. Es decir, que puedan ser notificados de dichos cambios, y tengan un tiempo razonable para ejercer sus derechos de contradicción y defensa (SU-405 de 2021¹¹⁹).

46.9. Por último, la Corte Constitucional ha establecido que los empleadores y las administradoras de pensiones son responsables de almacenar correctamente la información que reposa en su poder, sobre la historia laboral de una persona (SU- 182 de 2019¹²⁰). Asimismo, esta corporación expresó que los empleadores incurren en una vulneración a las garantías a la seguridad social y al mínimo vital ante “(...) *la ausencia de acciones para la resolver sus solicitudes tendientes a la revisión y actualización de [la] historia laboral por parte de los fondos de pensiones*” (T-470 de 2019¹²¹).

46.10. Por otro lado, el artículo 53 de la Ley 100 de 1993 dispone que, para asegurar el efectivo cumplimiento de las cotizaciones a pensión, las administradoras de pensiones pueden, entre otras:

“a. Verificar la exactitud de las cotizaciones y aportes u otros informes, cuando lo consideren necesario;

c. Citar o requerir a los empleadores o agentes retenedores de las cotizaciones al régimen, o a terceros, para que rindan informes;

116M.P. Alejandro Linares Cantillo.

117M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

118M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

119M.P. Diana Fajardo Rivera.

120M.P. Diana Fajardo Rivera.

121M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

d. Exigir a los empleadores o agentes retenedores de las cotizaciones al régimen, o a terceros, la presentación de documentos o registros de operaciones, cuando unos u otros estén obligados a llevar libros registrados;

[...]”

Solución al caso concreto

47. A continuación, la Sala realizará el estudio del caso concreto. Para tal efecto, en primer lugar, verificará los hechos que están debidamente probados y, posteriormente, establecerá si las entidades accionadas vulneraron los derechos invocados por la actora. Dentro del trámite están probados los siguientes hechos relevantes:

47.1. Entre el 15 de mayo de 1998 y el 15 de marzo de 2022, la demandante se desempeñó en el cargo de auxiliar de servicios generales de la SED¹²². El vínculo con esa entidad se dio a través de nombramiento en provisionalidad.

47.2. El 14 de mayo de 2019, la CNSC convocó el concurso de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes de la Gobernación de Putumayo¹²³. Entre ellos, ofertó el cargo de auxiliar de servicios generales código 470 que desempeñaba la accionante¹²⁴.

47.3. El 6 de enero de 2022, la SED le manifestó a la accionante que garantizaría su continuidad laboral *“con el fin que no se vea vulnerado el status de prepensionada”*¹²⁵. Lo expuesto, porque encontró que la actora laboró durante 23 años con la entidad, lo que equivale a aproximadamente a 1196 semanas cotizadas a pensión.

47.4 Mediante Resolución No. 1224 del 24 de febrero de 2022, la SED desvinculó a la actora a partir del 15 de marzo siguiente. Lo anterior, con el propósito de nombrar en el mismo cargo a la señora Ingri Paola Cortés Ortiz, quien hacía parte de la lista de elegibles provista por el concurso público de méritos para ocupar dicho empleo¹²⁶.

47.5. Al momento de ser desvinculada de su empleo, la actora tenía 59 años¹²⁷.

122En expediente digital: “*TIEMPO DE SERVICIO GALIMDEZ J. BLANCA.pdf*”

123Acuerdo No. 201900000598 de 2019.

124Artículo 7° del Acuerdo No. 201900000598 de 2019. *“empleos convocados. Los empleos vacantes de la Oferta Pública de Empleos de Carrera – OPEC que se convocan para este proceso de selección son: [...] asistencial, auxiliar de servicios generales, código 470, grado 2, número de empleos 3, número de vacantes 37”*.

125En expediente digital: “*RTA PUT2021032137.pdf*”. Pág. 2.

126Resolución No. 1224 del 24 de febrero de 2022. Tomado de expediente digital: “*ANEXOS_28_6_2022, 8_54_53.pdf*”. Págs.6-8.

127Cedula de Ciudadanía. Blanca Bellanid Galíndez Joven. Fecha de nacimiento: 10/02/1963 Tomado de expediente digital: “*ANEXOS_28_6_2022, 8_54_53.pdf*”. Pág. 1. Fecha de desvinculación 15/03/2022.

47.6. Según la CETIL, entre el 15 de mayo de 1998 y el 30 de junio de 2009, la tutelante cotizó a pensión a la Caja Nacional de Previsión (CAJANAL); y entre el 1° de julio de 2009 y el 15 de marzo de 2022, a COLPENSIONES ¹²⁸.

47.7. El historial laboral informado por COLPENSIONES reconoce 1081,71 semanas cotizadas por la actora al sistema pensional. De acuerdo con esa entidad, en tal documento no están reflejados los aportes a pensión comprendidos entre mayo de 1998 y septiembre de 2002. Al respecto, manifestó que, en ese periodo, el empleador de la demandante hizo aportes simultáneos al extinto Instituto de Seguro Social (ISS) y a CAJANAL. Por lo anterior, señaló que la SED debe aclarar dicha situación. A la fecha esa entidad no lo ha hecho.

48. Para la Sala, la SED y COLPENSIONES vulneraron los derechos fundamentales de la actora a la seguridad social, a la estabilidad laboral reforzada, al trabajo, a la dignidad humana y al mínimo vital. La inconsistencia en la historia laboral respecto al número de semanas cotizadas impactó en el reconocimiento de su condición de prepensionada y su consecuente derecho a la estabilidad laboral reforzada. A continuación, la Sala expondrán las razones que sustentan esta postura.

La inconsistencia en la historia laboral de la actora afecta los derechos fundamentales a la seguridad social, a la dignidad humana y al mínimo vital

49. La Sala observa que COLPENSIONES desconoció el deber de mantener actualizada la historia laboral de la demandada, porque la información consignada en aquel documento no refleja de manera real la trayectoria laboral de la trabajadora y su contenido no es cierto, preciso, fidedigno y actualizado ¹²⁹, en los términos de la jurisprudencia de esta Corporación ¹³⁰. En efecto, según la CETIL, la accionante laboró y cotizó a pensión en CAJANAL en el periodo comprendido entre mayo de 1998 y septiembre de 2002. Tales fechas no están reportadas en la historia laboral de la actora. Según la administradora de pensiones, aquellas fueron efectivamente trasladadas por la UGPP de acuerdo con la Resolución No. 001693 del 26 de enero de 2022. Sin embargo, “*se hicieron aportes al ISS y a CAJANAL por los mismos periodos*” ¹³¹. Por esa razón, debe verificar esta situación con el empleador para su correspondiente aclaración. Bajo ese entendido, afirmó que no podía cargar los ciclos faltantes en la historia laboral de la accionante.

128Certificación Electrónica de Tiempos Laborados del 26 de agosto de 2022.

129Ley 1581 de 2012. “Artículo 4°. Principios para el tratamiento de datos personales. En el desarrollo, interpretación y aplicación de la presente ley, se aplicarán, de manera armónica e integral, los siguientes principios: (...) d) Principio de veracidad o calidad: La información sujeta a Tratamiento debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe el Tratamiento de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error; (...)”.

130Sentencia SU-405 de 2021, M.P. Diana Fajardo Rivera.

131[N]o podemos cargar únicamente los ciclos faltantes 199805 a 200209, puesto que la Resolución de la UGPP informa más periodos y un total a pagar que los incluye. Para dar solución a tal yerro de la entidad certificadora, se realizó solicitud para corregir la certificación en la plataforma cetil 20220000212639 sin que a la fecha la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL PUTUMAYO haya corregido dicha situación.”. Tomado de expediente digital: “Respuesta2023_1115175_2023_1_27_7_56” Pág. 2.

50. De acuerdo con lo expuesto, es claro que la indebida actualización de la historia laboral de la demandante desconoció los esfuerzos que ha hecho la trabajadora a lo largo de su vida laboral en relación con su expectativa legítima de acceder a su derecho a la pensión. Así, la administradora de pensiones descuidó su deber de gestionar y actualizar la información que contiene la historia laboral de acuerdo con el principio de veracidad y con las reglas establecidas en el artículo 17 de la Ley 1581 de 2012¹³², la jurisprudencia constitucional¹³³ y sus funciones legales¹³⁴. Estas omisiones repercutieron negativamente en la demandante porque impidió que le fuera reconocida su calidad de prepensionada por parte de la SED¹³⁵. En efecto, el número de semanas reportadas en la historia laboral (1081,71) no tuvo en cuenta el periodo comprendido entre el 15 de mayo de 1998 y el 30 septiembre de 2002 el cual equivale a 228,3 semanas que la actora cotizó a pensión. Periodo que fue reconocido por la administradora de pensiones y que solamente está pendiente de la validación de posibles dobles aportes por parte del empleador en ese lapso de tiempo. Esta situación configura un déficit de protección en las garantías superiores de la demandante, específicamente las relacionadas con sus derechos fundamentales a la seguridad social, la dignidad humana y el mínimo vital, lo cual es intolerable en términos constitucionales.

51. De igual forma, el artículo 53 de la ley 100 de 1993¹³⁶ concede a COLPENSIONES las facultades para requerir al empleador para que rindan informes para garantizar el cumplimiento de sus funciones dentro del sistema

132Ley 1581 de 2012. “Artículo 17. Deberes de los responsables del tratamiento. Los Responsables del Tratamiento deberán cumplir los siguientes deberes, sin perjuicio de las demás disposiciones previstas en la presente ley y en otras que rijan su actividad: (...) e) Garantizar que la información que se suministre al Encargado del Tratamiento sea veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible;(...)”.

133Sentencia SU-405 de 2021, M.P. Diana Fajardo Rivera.

134Decreto 309 de 2017. “*Por el cual se modifica la estructura de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)*”. “Artículo 5°. Funciones. En desarrollo de su objeto, la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), cumplirá las siguientes funciones: (...) 9. Gestionar la historia laboral y pensional, las cuentas individuales de los vinculados, los registros de novedades y la consistencia de la información. 10. Gestionar el manejo, administración, control, custodia y conservación de los expedientes pensionales, en los términos previstos en las normas vigentes”.

135Esta Corporación ha sostenido de forma pacífica que “*En tanto la historia laboral es un documento que emana de las administradoras de pensiones -el cual se nutre de las bases de datos a su cargo- la desorganización, la no sistematización de los datos o el descuido, no pueden repercutir negativamente en el trabajador*”. Sentencia SU-405 de 2021, M.P. Diana Fajardo Rivera.

136Ley 100 de 1993. “Artículo 53. Focalización e investigación. Las entidades administradoras del régimen solidario de prestación definida tienen amplias facultades de fiscalización e investigación sobre el empleador o agente retenedor de las cotizaciones al régimen, para asegurar el efectivo cumplimiento de la presente Ley. Para tal efecto podrán: || a. Verificar la exactitud de las cotizaciones y aportes u otros informes, cuando lo consideren necesario; || b. Adelantar las investigaciones que estimen convenientes para verificar la ocurrencia de hechos generadores de obligaciones no declarados; || c. Citar o requerir a los empleadores o agentes retenedores de las cotizaciones al régimen, o a terceros, para que rindan informes; || d. Exigir a los empleadores o agentes retenedores de las cotizaciones al régimen, o a terceros, la presentación de documentos o registros de operaciones, cuando unos u otros estén obligados a llevar libros registrados; || e. Ordenar la exhibición y examen de los libros, comprobantes y documentos del empleador o agente retenedor de las cotizaciones al régimen, y realizar las diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinación de las obligaciones”.

pensional. En tal sentido, a pesar de que el 28 de octubre de 2021¹³⁷, COLPENSIONES solicitó a la SED aclarar y ajustar la información certificada en relación con algunos periodos en los que existe aportes a pensión tanto al ISS como a CAJANAL y que tal entidad no atendió el requerimiento. La Sala observa que la administradora de pensiones contaba con los mecanismos jurídicos suficientes para requerir al empleador sobre las cotizaciones aportadas al sistema y actualizar la información laboral de la accionante. Por lo tanto, no es posible alegar que el empleador no atendió la solicitud realizada por esa entidad para persistir en la desactualización de la historia laboral de la accionante. Esta actuación es contraria a los principios de veracidad y buena fe, pues la falta de ejercicio de dicha facultad no puede representar una consecuencia negativa para los derechos fundamentales de la demandante.

52. Por otro lado, la SED también afectó las garantías *ius fundamentales* de la actora. La Sala observa que dicha entidad conocía de las inconsistencias en la historia laboral de la demandante, en relación con las semanas del periodo que va de mayo de 1998 hasta septiembre de 2002, cuyas cotizaciones estuvieron a su cargo. Tal situación le fue comunicada por la administradora de pensiones el 28 de octubre de 2021¹³⁸. Sin embargo, no desplegó ninguna acción para aclarar la información sobre los aportes de la actora¹³⁹. Por lo anterior, la Sala considera que la SED no observó la obligación que tiene de atender oportunamente los requerimientos que sobre la revisión de la historia laboral realice el fondo pensional¹⁴⁰. Tal omisión afectó los derechos a la seguridad social, al mínimo vital, a la estabilidad laboral reforzada, al trabajo y a la dignidad humana de la actora porque impidió su continuidad laboral en la entidad.

La inconsistencia en la historia laboral de la actora afectó su condición de prepensionada

53. A partir de que la historia laboral de la accionante presentó inconsistencias en relación con el número de semanas que efectivamente cotizó a pensión, se presentó una afectación a los derechos de la accionante. Los documentos probatorios que obran en el expediente, le permiten concluir a la Sala que aquella reunía la condición de prepensionada. Lo anterior, porque está acreditado que al momento de la desvinculación, la actora contaba con 59 años y trabajó de manera continua en la SED entre el 15 de mayo de 1998 y el 15 de

137Tomado de expediente digital: “*Respuesta2021_11479895_2021_11_11_17_42.pdf*”. Pág. 1.

138(...) [C]on relación a los periodos 15-05-1998 al 30-06-2009 con el empleador SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL PUTUMAYO, se requirió a la entidad encargada por medio de BZ 2021_12798401 del 28 de octubre de 2021, dar inicio a las gestiones tendientes del traslado de sus aportes con el fin de normalizar su historia laboral. Por lo anterior, se sugiere validar con posterioridad(...)”. Tomado de expediente digital:

“*Respuesta2021_11479895_2021_11_11_17_42.pdf*”. Pág. 1.

139Al respecto, COLPENSIONES afirmó que: “*Vale la pena aclarar que no podemos cargar únicamente los ciclos faltantes 199805 a 200209, puesto que la Resolución de la UGPP informa más periodos y un total a pagar que los incluye. Para dar solución a tal yerro de la entidad certificadora, se realizó solicitud para corregir la certificación en la plataforma cetil 20220000212639 sin que a la fecha la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL PUTUMAYO haya corregido dicha situación*”.

140Sentencia T-470 de 2019 M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

marzo de 2022¹⁴¹. Sin tener en cuenta los tiempos reportados en la historia laboral por parte de otros empleadores¹⁴², tal periodo¹⁴³, por sí solo, es suficiente para acreditar que a la demandante le hacía falta menos de tres años para acceder a la pensión de vejez¹⁴⁴. En tal escenario, la SED frustró las expectativas legítimas de la accionante de beneficiarse de una pensión y desconoció los derechos fundamentales al trabajo, a la estabilidad laboral reforzada, a la seguridad social y al mínimo vital.

54. Para la Sala, la inconsistencia en la información de la historia laboral de la demandante no puede significar la vulneración de sus derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital, a la seguridad social y a la estabilidad laboral reforzada. Al respecto, reprocha que, pese a que la SED conocía de tales irregularidades, decidió desvincular a la trabajadora sin desplegar las actuaciones necesarias para garantizar sus derechos fundamentales. En efecto, esta Corporación ha sostenido que, aunque las entidades están obligadas a realizar el nombramiento de quien hace parte de la lista de elegibles, como resultado del concurso de méritos, lo procedente es ofrecer a las personas en condición de prepensionadas otro cargo equivalente que estén disponible, mientras completa las semanas suficientes para acceder efectivamente a su derecho pensional o si procede el reconocimiento y la inserción en nómina para el pago de la pensión¹⁴⁵. Por otro lado, la Sala estima que la duda del empleador sobre la densidad de las cotizaciones de sus trabajadores, que razonablemente se presuman próximos a pensionarse por el tiempo de servicio laborado en la entidad, debe ser resuelta a favor de estos¹⁴⁶. Lo anterior, implica activar la descrita protección hasta que la

141En expediente digital: “*TIEMPO DE SERVICIO GALIMDEZ J. BLANCA.pdf*”

142Según ese documento, entre el 27 de julio y el 25 de septiembre de 1981, así como entre el 26 de abril y el 26 de agosto de 1982, la tutelante cotizó a pensión con su empleador Industrias Cato S.A.; y, entre el 1 de diciembre de 1982 y el 2 de mayo de 1983, así como entre el 22 de agosto de 1983 y el 1 de septiembre de 1984, con Servicios y Asesorías del Valle. Historia laboral del 26 de enero de 2023 elaborada por COLPENSIONES.

143De acuerdo con el Certificado de Tiempos Laborados (CETIL), la accionante cuenta con los siguientes periodos cotizados: del 15/05/1998 al 30/06/2009 y del 01/07/2009 al 14/03/2022. Lo que equivale a 1.243 semanas cotizadas al sistema pensional. De igual forma la SED en certificado de tiempos de servicios No. 3283 acreditó que la actora trabajó sin solución de continuidad desde su nombramiento el 15/05/1998 hasta su desvinculación 14/03/2022.

144Sentencia SU-003 de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.

145Sentencia T-443 de 2022, M.P. Diana Fajardo Rivera.

146Constitución Política. “*Artículo 53 El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores*”.

entidad tenga certeza de su condición cotizacional en la historia laboral expedida por la administradora de pensiones.

55. Ahora bien, esta Corte también ha señalado que existe una tensión entre los derechos de las personas prepensionadas y el respeto de la carrera administrativa¹⁴⁷. Así, no es posible ordenar el reintegro inmediato al cargo que desempeñaba la actora porque esta decisión vulneraría los derechos fundamentales de la señora Ingri Paola Cortes Ortiz, quien accedió a la vacante a través de concurso de méritos e iría en contra de la jurisprudencia de este Tribunal, que reconoce la carrera administrativa como el mecanismo preferente para el acceso y la gestión de empleos públicos. Por tal razón, la decisión que adopte debe tener en cuenta dicha situación.

Órdenes por proferir

56. En virtud de lo expuesto, la Sala revocará parcialmente la sentencia del 23 de agosto de 2022 proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Mocoa en segunda instancia, mediante la cual revocó la Sentencia del 12 de julio del 2022 emitida por el Juzgado Segundo Civil Municipal de la misma ciudad, y declaró la improcedencia del amparo. En su lugar, tutelaré los derechos fundamentales a la seguridad social, a la dignidad humana, a la estabilidad laboral reforzada, al trabajo y al mínimo vital de la señora Blanca Bellanid Galíndez Joven. En consecuencia, ordenaré a COLPENSIONES y a la SED que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, adelanten de forma coordinada las gestiones a que haya lugar para validar y actualizar todos los aspectos concernientes con la historia laboral de la accionante. En este punto, la SED deberá cumplir con su obligación como empleador en cuanto a certificar, hacer los respectivos aportes y demás gestiones incluido el pago del cálculo actuarial, si hay lugar a aquel, a favor de la accionante en el periodo entre mayo de 1998 y septiembre de 2002. COLPENSIONES deberá realizar todas las gestiones a su cargo para revisar y actualizar completamente la historia laboral de la accionante y, en caso de que estén acreditados los requisitos para acceder a una pensión de vejez, dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del término anterior, deberá brindar a la actora la información y asesoría necesaria para realizar los trámites con el fin de acceder a dicha pensión y, en caso de que la afiliada solicite el reconocimiento y pago de la misma, deberá adelantar de forma ágil las gestiones necesarias para atender su petición, sin dilaciones ni trabas administrativas.

57. Asimismo, ordenaré a la SED que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, vincule a la accionante a un cargo vacante como el que desempeñaba o uno con funciones similares o equivalentes a las que desarrollaba antes de la fecha en la que fue desvinculada y hasta que su derecho pensional sea reconocido y esté incluida en nómina. En caso de no contar con vacantes disponibles, la accionante deberá ser incluida en la lista de servidores con estabilidad laboral a ser reintegrados en cuanto la entidad cuente con disponibilidad de cargos.

147Sentencia T-063 de 2022, M.P. Alberto Rojas Ríos y Sentencia T-443 de 2022, M.P. Diana Fajardo Rivera.

58. Adicionalmente, oficiará a la Procuraduría General de la Nación, para que, dentro del ámbito de sus competencias constitucionales¹⁴⁸, acompañe el cumplimiento de esta sentencia.

Síntesis de la decisión

59. En esta oportunidad, la Sala conoció el caso de una mujer, adulta mayor, que acudió a la acción de tutela con el propósito de que se garantizara su estabilidad laboral debido a su condición de prepensionada. Según la accionante la entidad accionada vulneró sus derechos fundamentales a la seguridad social, a la dignidad humana, a la estabilidad laboral reforzada, al trabajo y al mínimo vital al desvincularla del cargo que ocupó en provisionalidad, para nombrar a quien superó el concurso de méritos sin tener en consideración su calidad de prepensionada.

60. Luego de establecer la procedencia de la acción de tutela únicamente para el reintegro y en relación con COLPENSIONES y la SED, la Sala debió resolver los siguientes problemas jurídicos: (i) ¿COLPENSIONES y la SED vulneraron el derecho fundamental a la seguridad social al no actualizar la información contenida en la historia laboral y los aportes pensionales de la actora?; y, (ii) ¿La SED vulneró los derechos fundamentales, a la estabilidad laboral, al trabajo, a la seguridad social, al mínimo vital y dignidad humana de la accionante al desvincularla del cargo que ocupó en provisionalidad, para nombrar a quien superó el concurso de méritos sin considerar la condición de prepensionada que aquella alegó?

61. Para resolver las mencionadas cuestiones, reiteró las reglas jurisprudenciales sobre: (i) la estabilidad laboral reforzada de los servidores públicos nombrados en provisionalidad que ostentan la condición de prepensionados; y, (ii) los deberes de las administradoras de pensiones y de los empleadores en relación con la información consignada en la historia laboral y la garantía del derecho a la pensión.

62. Al analizar el caso concreto, la Sala encontró que la historia laboral de la demandante presentaba algunas inconsistencias en relación con el número de semanas cotizadas a pensión. En tal sentido, evidenció que COLPENSIONES y la SED afectaron las garantías *ius fundamentales* de la actora porque incumplieron con su deber de validar y mantener actualizada la información relacionada con sus aportes al sistema pensional. Al respecto, la Sala expresó que la accionante no está obligada a soportar las consecuencias negativas de la inexactitud de la información que reposa en su historial laboral. Esta situación impactó en el reconocimiento de la calidad de prepensionada de la demandante, pues la SED se valió de dicha circunstancia para desconocer la garantía de estabilidad laboral reforzada por la condición de prepensionada de la actora.

148Constitución Política. Artículo 277. Numeral 1. “El Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, tendrá las siguientes funciones: // 1. Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos [...]”.

63. En ese sentido, la Sala decidió revocar parcialmente la decisión del Juzgado Civil del Circuito de Mocoa que en segunda instancia declaró la improcedencia de la acción. En su lugar tuteló los derechos fundamentales de la accionante y ordenó a COLPENSIONES y a la SED realizar las gestiones necesarias para validar y actualizar la historia laboral de la accionante. Lo anterior, implica para la SED certificar y hacer los respectivos aportes al sistema pensional incluido el pago del cálculo actuarial, si hay lugar a aquel, a favor de la accionante. Asimismo, COLPENSIONES deberá realizar todas las gestiones a su cargo para revisar y actualizar completamente la historia laboral de la actora. En el evento que encuentre acreditados los requisitos para que ella acceda a una pensión de vejez, deberá informarle sobre los trámites tendientes a su consecución. Y, en caso de que la afiliada solicite el reconocimiento y pago de la misma, deberá adelantar de forma ágil las gestiones para atender su petición. También, ordenó a la SED vincular a la accionante a un cargo vacante como el que desempeñaba o uno con funciones similares a las que desarrollaba antes de la fecha en la que fue desvinculada y hasta que le sea reconocido el derecho a la pensión y se verifique su inclusión en nómina. En caso de no contar con vacantes disponibles, la accionante deberá ser incluida en la lista de servidores con estabilidad laboral a ser reintegrados en cuanto la entidad cuente con vacantes.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución Política,

RESUELVE

PRIMERO.- REVOCAR parcialmente la decisión del 23 de agosto de 2022 proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Mocoa en segunda instancia, mediante la cual revocó la Sentencia del 12 de julio del 2022 emitida por el Juzgado Segundo Civil Municipal de la misma ciudad, y declaró la improcedencia de la acción, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En su lugar, **TUTELAR** los derechos fundamentales a la seguridad social, a la dignidad humana, a la estabilidad laboral reforzada, al trabajo y al mínimo vital de la señora Blanca Bellanid Galíndez Joven.

SEGUNDO.- ORDENAR a COLPENSIONES y a la Secretaría de Educación Departamental de Putumayo (SED) que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, adelanten de forma coordinada las gestiones a que haya lugar para validar y actualizar todos los aspectos concernientes con la historia laboral de la accionante. En este punto, la SED deberá cumplir con su obligación como empleador en cuanto a certificar, hacer los respectivos aportes y demás gestiones incluido el pago del cálculo actuarial, si hay lugar a aquel, a favor de la accionante en el periodo entre mayo de 1998 y septiembre de 2002. COLPENSIONES deberá realizar todas las gestiones a su cargo para revisar y actualizar completamente la historia laboral de la accionante y en caso de que estén acreditados los requisitos para acceder a

una pensión de vejez, dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del término anterior, deberá brindar a la actora la información y asesoría necesaria para realizar los trámites con el fin de acceder a dicha pensión y, en caso de que la afiliada solicite el reconocimiento y pago de la misma, deberá adelantar de forma ágil las gestiones necesarias para atender su petición, sin dilaciones ni trabas administrativas.

TERCERO.- ORDENAR a la Secretaría de Educación Departamental de Putumayo que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, vincule a la accionante a un cargo vacante como el que desempeñaba o uno con funciones similares o equivalentes a las que desarrollaba antes de la fecha en la que fue desvinculada y hasta que le sea reconocido el derecho a la pensión y se verifique su inclusión en nómina. En caso de no contar con vacantes disponibles, la accionante deberá ser incluida en la lista de servidores con estabilidad laboral a ser reintegrados en cuanto la entidad cuente con vacantes.

CUARTO.- OFICIAR a la Procuraduría General de la Nación, para que, dentro del ámbito de sus competencias constitucionales, acompañe el cumplimiento de esta sentencia.

QUINTO.- DESVINCULAR a la Comisión Nacional del Servicio Civil y a la Gobernación de Putumayo del trámite.

SEXTO.- Por Secretaría General, **LÍBRENSE** las comunicaciones a que se refiere el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ
Magistrado

DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR
Magistrado

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General

Sentencia T-063/22

ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL NOMBRADOS EN PROVISIONALIDAD

(...) la entidad accionada desconoció los postulados jurisprudenciales fijados por esta Corporación, destinados a prever en la medida de lo posible, el mayor margen de protección a favor de aquellos funcionarios públicos nombrados en provisionalidad, que ostentan la calidad de sujetos de especial protección constitucional, antes de proceder al nombramiento de quienes superaron el concurso de méritos.

ACCION DE TUTELA CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE DESVINCULAN A SERVIDORES PUBLICOS DE SUS CARGOS-Procedencia excepcional

PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD DE LA ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable

CARRERA ADMINISTRATIVA-Fundada en el mérito como principio constitucional y como regla general para la provisión de cargos públicos

CARGOS PROVISIONALES Y CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA-Diferencias

EMPLEADO NOMBRADO EN PROVISIONALIDAD EN CARGO DE CARRERA ADMINISTRATIVA-Requisitos para su desvinculación cuando goza de estabilidad relativa o intermedia

DESVINCULACION DE SERVIDORES PUBLICOS PROVISIONALES CON ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA CON OCASION DE CONCURSO DE MERITOS-Reiteración de jurisprudencia

(...) en aquellos casos en los que surge, con fundamento en el principio del mérito, la obligación de nombrar de la lista de elegibles a la persona que superó las etapas del concurso, en un cargo de carrera ocupado en provisionalidad por un sujeto de especial protección como los padres o madres cabeza de familia, limitados físicos, psíquicos o sensoriales y pre pensionados, las entidades deben proceder con especial cuidado antes de efectuar los respectivos nombramientos, mediante la adopción de medidas afirmativas, (dispuestas en la constitución art. 13 numeral 3º, y en la materialización del principio de solidaridad social -art. 95 ibídem-), relativas a su reubicación, y en caso de no adoptarse tales medidas, de ser posible, han de ser vinculados de nuevo en provisionalidad en un cargo

similar o equivalente al que venían ocupando, de existir la vacante, siempre y cuando demuestren una de esas condiciones, tanto para la época de su desvinculación, como en el momento del posible nombramiento.

ACCIONES AFIRMATIVAS DE ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA

Referencia: Expediente T-8.342.527

Acción de tutela formulada por Milciades Pérez Vergel y Carmen Alonso Pérez Vergel en contra de la Alcaldía de Ábrego -Secretaría de Gobierno Municipal-, Norte de Santander.

Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintidós (2022).

La Sala Novena de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Diana Fajardo Rivera y los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y Alberto Rojas Ríos –quien la preside– en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política, y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la presente

SENTENCIA

En el trámite de revisión de los fallos del 16 de abril y 31 de mayo de 2021, proferidos por los Juzgados Promiscuo de Abrego Norte de Santander- y Tercero Penal del Circuito Mixto de Conocimiento de Ocaña, en primera y segunda instancia, respectivamente, dentro de la acción de tutela de la referencia.

En virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Mixto de Conocimiento de Ocaña remitió a la Corte Constitucional el Expediente

T-8.342.527. La Sala de Selección de Tutelas Número Nueve¹ de esta Corporación, mediante Auto del 28 de septiembre de 2021, lo eligió² para efectos de su revisión y, según el respectivo sorteo, se repartió al Despacho del Magistrado Alberto Rojas Ríos.

I. ANTECEDENTES

El 16 de abril de 2021, los ciudadanos Milciades Pérez Vergel y Carmen Alonso Pérez Vergel formularon acción de tutela en contra de la Alcaldía de Ábrego -Secretaría de Gobierno Municipal-, Norte de Santander, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, a la seguridad social y al mínimo vital. Pasan a reseñarse los supuestos fácticos que fundamentan la acción de tutela:

1. Hechos:³

1. Milciades Pérez Vergel y Carmen Alonso Pérez Vergel de 63 y 60 años respectivamente, fueron nombrados en provisionalidad para prestar sus servicios en el Municipio de Ábrego –Norte de Santander-, el señor Milciades desde el 3 de febrero de 2009,⁴ en el cargo de auxiliar de servicios generales grado 6, y el señor Carmen Alonso desde el 6 de

1 Integrada por la Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado y el Magistrado Alejandro Linares Cantillo.

2 indicando como criterio orientador para su escogencia la urgencia de Proteger un derecho fundamental y necesidad de materializar un enfoque diferencial (criterio subjetivo), de conformidad con el literal b) del artículo 52 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional. Folio 18 del Cuaderno N° 2 del Expediente.

3 La información sobre los hechos expuestos en el escrito de tutela es complementada con los elementos de juicio que obran en el expediente con el fin de facilitar el entendimiento del asunto.

4 Mediante Decreto 013 de 2009. Informa que al momento de ser retirado del servicio desempeñaba el mismo cargo. Folio 1 y 2 del Cuaderno N° 1

enero de 2012,⁵ en el cargo de técnico administrativo (almacenista) grado 3.⁶

2. Los accionantes afirman que, con fundamento en el artículo 11, (literal c) de la Ley 909 de 2004⁷, la Comisión Nacional del Servicio Civil elaboró la convocatoria al concurso de méritos 779 de 2018, para proveer cargos vacantes en el municipio de Ábrego.
3. Los actores participaron en el concurso de méritos, sin embargo, mediante actos administrativos N° 699 y 701 del 15 de octubre de 2020, se les comunicó que habían sido retirados del cargo, porque no superaron el puntaje exigido para hacer parte de la lista de elegibles, por lo que afirman *“no alcanzamos a ocupar el número de vacantes ofertadas, razón por la cual nos removieron de los cargos, no obstante, nuestra condición.”*⁸
4. Indican que, al momento de ser retirados del servicio, el Municipio no tuvo en cuenta su calidad de padres cabeza de familia, trabajadores pre

del Expediente.

5 Mediante Decreto 006 de 2012. Informa que al momento de ser retirado del servicio desempeñaba el cargo de técnico operativo grado 3. Folios 1 y 2 del Cuaderno N° 1 del Expediente.

6 Los actores indican que desde el momento en que fueron nombrados, prestaron sus servicios con absoluta responsabilidad y competencia, nunca recibieron llamados de atención o sanción alguna. Folio 2 del Cuaderno N° 1 del Expediente.

7 Artículo 11. “Funciones de la Comisión Nacional del Servicio Civil relacionadas con la responsabilidad de la administración de la carrera administrativa. En ejercicio de las atribuciones relacionadas con la responsabilidad de la administración de la carrera administrativa, la Comisión Nacional del Servicio Civil ejercerá las siguientes funciones: (...). c) elaborar las convocatorias a concurso para el desempeño de empleos públicos de carrera, de acuerdo con los términos y condiciones que establezcan la presente ley y el reglamento.”

pensionados y personas calificadas con un grado superior al 50% de pérdida de capacidad laboral. A continuación, se enuncian las particularidades que cada uno afirma enfrentar y por las cuales exigen un trato especial:

Milciades Pérez Vergel	Carmen Alonso Pérez Vergel
Tiene 63 años Indica que como consecuencia de un accidente de trabajo en el 2018 quedó afectado de su hombro izquierdo. Afirma que estando en curso el tratamiento fisiopatológico le fueron detectadas las siguientes patologías: radiculopatía c5 izquierda, hernia discal c4-c5 izquierda c6-c7, discopatía cervical múltiple c2- c3-c4-c6-c7-c4 c5 y c5 y c6, y abombamiento y protrusión discal. A causa de estas patologías tiene una pérdida de capacidad laboral del de 51.12%. Informa que es padre cabeza de hogar. Señala que vive con su esposa e hija, quienes dependen económicamente de él. Su esposa, la señora Carmen Trigos Bayona de 56 años, es ama de casa y sufre hipertensión, así que dadas las condiciones de edad, salud y nivel académico se le dificulta conseguir alternativas de apoyo económico para el hogar, según informa. Su hija Yaneth Pérez Trigos, tiene 23 años y estudiaba psicología en la Universidad Unipamplona, pero debido a que el señor Milciades Pérez Vergel quedó sin trabajo, ella tuvo que postergar sus estudios.	Tiene 60 años Indica que padece de hiperlipidemia mixta, hipertensión arterial y de diabetes mellitus, es insulín dependiente y tiene controles mes a mes. A causa de dichas patologías tiene una pérdida de capacidad laboral del de 59.62%. Señala que es padre cabeza de hogar. Agrega que vive con su esposa y sus dos hijos, quienes dependen económicamente de él. Su esposa, la señora Rosa María Álvarez de 50 años, es ama de casa, desde hace tres años sufre de afectación en los riñones por lo que debe estar en constantes controles, así que, debido a dichos factores se le dificulta conseguir alternativas de apoyo económico para el hogar. Su hijo, Elkin Manuel Pérez Álvarez de 29 años, se encuentra en situación de discapacidad desde hace 14 años, debido a la mielopatía progresiva que le produjo la paraplejia que lo mantiene en silla de ruedas, y Juan Camilo Pérez Álvarez, de 21 años, es estudiante de auxiliar de enfermería.

5. Añaden que el municipio no adoptó ninguna medida afirmativa con el fin de prevenir una grave afectación de sus derechos fundamentales, en concordancia con las disposiciones jurisprudenciales⁹ que regulan la materia, ello, según informan, a pesar del margen de maniobra con el cual cuenta dicho ente territorial.¹⁰ Además aseguran que el municipio cometió irregularidades en el reporte anual de vacantes, en el marco del concurso de méritos 779 de 2018, puesto que solo reportó 7 vacantes disponibles para que fueran ofertadas por la Comisión Nacional del Servicio Civil y omitió 9 de ellas.¹¹
6. Sostienen que, el 16 de noviembre de 2020, ante su inconformidad con la decisión que los retiró del cargo que ocupaban, interpusieron recurso de apelación. En esta oportunidad los accionantes expresaron a la Alcaldía, las razones por las cuales resultaban afectados con el retiro del cargo que cada uno venía ocupando. Sin embargo, el día 17 de noviembre de 2020, la entidad accionada confirmó las decisiones recurridas y señaló que, aunque la Administración Municipal de Ábrego, es consciente del despliegue de acciones afirmativas respecto de los provisionales en circunstancias de debilidad manifiesta, y de que estos deben ser los últimos en removerse de sus cargos o ser reubicados en otra vacante, indicó que dicha posibilidad no es posible en este caso, debido a que no

9 Citan algunas Sentencias emitidas por la Corte Constitucional, por ejemplo, las Sentencias SU-446 de 2011 y T-373 de 2017.

10 Sobre el margen de maniobra al que hacen referencia, indican lo siguiente: *“el municipio de Ábrego está gastando anualmente un promedio de \$ 1.782.000.00 millones de pesos para costear más o menos 99 OPSs, que la prestación de los servicios propios de la naturaleza de la institución demandada, hecho que trae consigo implícita la necesidad crear en la planta por lo menos 70 empleos y en consecuencia vincular inicialmente en provisionalidad el mismo número de nuevos empleados.” (...)* *“Adicionalmente, la administración municipal cuenta con la asignación de un rubro con un fondo de \$ 100.000.000 para llevar a cabo el rediseño institucional, todo esto aprobado en el Acuerdo N° 014 de 2020, por medio del cual fue aprobado el Plan de Desarrollo 2020-2023.”* Folio 37 del Cuaderno N° 1 del Expediente.

11 Los accionantes aseguran que las 9 vacantes referidas también estaban siendo ocupadas en provisionalidad por otros compañeros que no ostentan calidad alguna que los convierta en sujetos de especial protección constitucional, a diferencia de ellos.

existen vacantes en la planta global que permitan garantizar la permanencia de los accionantes en la entidad.¹²

7. Informan que el 2 de marzo de 2021, radicaron solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría Delegada ante los Jueces Administrativos del Circuito de Cúcuta, con el fin de evitar un eventual vencimiento de términos para la iniciación del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.¹³ Sobre este punto es importante advertir que, posteriormente, tal como lo acreditan las pruebas obrantes en el expediente,¹⁴ los actores instauraron la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con fundamento en las mismas pretensiones que motivaron la presente acción de tutela.¹⁵
8. Por último, los actores afirman que el empleo que tenían en el Municipio de Ábrego representaba su único ingreso económico, que ellos y sus familias dependían íntegramente del salario que devengaban y que no ha sido posible encontrar una oportunidad en el mercado laboral que les permita satisfacer sus necesidades básicas y las de su núcleo familiar, así como cumplir las obligaciones financieras que tienen a cargo.¹⁶

12 Folios 123 a 129 y 347 a 353 del Cuaderno N° 2 del Expediente.

13 Folio 10 del Cuaderno N° 1 del Expediente.

14 Pruebas que fueron solicitadas en sede de revisión, mediante Auto del 12 de noviembre de 2021, y posteriormente recaudadas, como se especificará en las páginas siguientes de esta sentencia.

15 Por un lado, se advierte que el señor Milciades Pérez Vergel interpuso la demanda con fecha de radicado del 13 de abril de 2021, ante los jueces administrativos del circuito del Municipio de San José de Cúcuta. Adjuntó el escrito de la demanda y el pantallazo de radicación de la misma. Folios 388 a 418 del Cuaderno N° 2 del Expediente. Por otro lado, el señor Carmen Alonso Pérez Vergel adjuntó escrito de la demanda y pantallazo de radicación de la misma, con fecha del 11 de junio de 2021. Folios 169 a 204 del Cuaderno N° 2 del Expediente.

2. Solicitud

Los accionantes solicitaron el amparo de los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, a la seguridad social y al mínimo vital, y en consecuencia requieren que se ordene a la Alcaldía de Ábrego que, **(i)** efectúe los movimientos necesarios con el fin de que sean reincorporados a un cargo de igual o mayor categoría que aquellos que venían ocupando, en provisionalidad y sin solución de continuidad así como su afiliación, a la red de aseguramiento IVM¹⁷ correspondiente,¹⁸ y que **(ii)** efectúe el pago de las prestaciones sociales que se dejaron de pagar desde el momento de la notificación del retiro del servicio, hasta la fecha en la que se sean incorporados.

3. Traslado y contestación de la acción de tutela

El 5 de abril de 2021, el Juzgado Promiscuo Municipal de Ábrego -Norte de Santander, - admitió la acción de tutela y notificó a Alcaldía de Abrego -Secretaría de Gobierno Municipal-, para que ejerciera su derecho de defensa y contradicción. No dispuso vinculación alguna.

El Alcalde municipal de Ábrego -Norte de Santander-, a través de la oficina de Secretaría de Gobierno Municipal, se opuso a las pretensiones. Señaló que, los accionantes no gozan de estabilidad laboral reforzada, ello de acuerdo con el artículo 125 de la Constitución Política, el acceso al empleo público será de carrera administrativa, y que según lo establece el artículo 41 de la ley 909 la desvinculación del empleo público es permitida siempre y cuando sea motivada mediante acto administrativo. Agregó que, en todo caso, la acción de tutela debe ser declarada improcedente, debido a que los accionantes cuentan con otros mecanismos de defensa judicial y que, de hecho, por esta misma razón, iniciaron el trámite de conciliación extrajudicial ante el Ministerio Público, al tenor de lo dispuesto en el

16 Folio 10 del Cuaderno N° 1 del Expediente.

17 Invalidez, vejez y muerte.

18 Folio 36 del Cuaderno N° 1 del Expediente.

artículo 161 de la Ley 1437 de 2011, Decreto 1716 de 2009, Ley 640 de 2011 y Decreto 1069 de 2015.¹⁹

4. Fallos de tutela objeto de revisión

Sentencia de primera instancia

El 16 de abril de 2021, el Juzgado Promiscuo de Abrego amparó²⁰ los derechos fundamentales invocados por los accionantes. Consideró que *“están en edad muy próximas a obtener sus pensiones (período llamado pre pensional), (...) existe la posibilidad de acudir a los mecanismos de defensa judiciales que consagra la legislación, ya los ex empleados están adelantando los trámites pertinentes sobre tal oportunidad, pero hay que decir que ellos serían más demorados, en las 2 instancias para la parte actora.”*²¹

Así las cosas, el fallador de primera instancia ordenó al Alcalde del Municipio de Ábrego vincular²² a los accionantes a cargos de igual rango y remuneración a los que ocupaban antes de que fueran retirados. Además, ordenó efectuar el pago de las acreencias laborales dejadas de pagar, con

19 Folio 44 del Cuaderno N° 1 del Expediente.

20 Folio 47 del Cuaderno N° 1 del Expediente.

21 Folio 47 del Cuaderno N° 1 del Expediente.

22 Concretamente lo dispuso en los siguientes términos: *“dentro del término de quince (15) días hábiles siguientes a la notificación de dicha providencia, iniciar las gestiones de revisión acerca de cada accionante, a fin de verificar las condiciones de sujetos de especial protección constitucional y perfil laboral e implementar medidas afirmativas con aplicación de la constitución y de la jurisprudencia, vinculándolos*

ocasión de su despido. Por último, ordenó la desvinculación de la Secretaría de Gobierno Municipal, *“teniendo en cuenta que los actos administrativos fueron suscritos por el señor Alcalde Municipal y son decisiones propias de su despacho.”*²³

Impugnación

La Alcaldía de Ábrego impugnó el fallo adoptado por el juez de primera instancia. Reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. Agregó que, respecto de la presunta calidad de pre pensionados de los accionantes, no basta con la edad, sino que es indispensable que en realidad les falten 3 años o menos para el cumplimiento de las semanas mínimas, es decir 156 semanas cotizadas al Sistema General de Seguridad Social.

Agregó que los accionantes no aportaron pruebas suficientes para acreditar la consumación de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela y por tanto solicitaron que la misma fuera declarada improcedente.²⁴

Sentencia de segunda instancia

Mediante sentencia del 31 de mayo de 2021, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Mixto de Conocimiento de Ocaña revocó²⁵ la decisión de primera instancia y declaró la improcedencia de la acción de tutela. Consideró que la entidad accionada no vulneró derecho fundamental alguno de los accionantes. Señaló que las personas nombradas en provisionalidad, no gozan de estabilidad reforzada, sino que tienen una estabilidad intermedia,

nuevamente a cargos de igual rango y remuneración al que ocupaban, (...)”.

23 Folio 48 del Cuaderno N° 1 del Expediente.

24 Folios 58 a 63 del Cuaderno N° 1 del Expediente.

25 Folio 56 del Cuaderno N° 1 del Expediente.

“que se asigna precisamente con el acto administrativo que motiva su desvinculación,” ²⁶ el cual debe ser notificado para que se ejerza el derecho a la defensa, como aquí se evidencia lo hizo la entidad demandada.

Indicó que ellos debieron proveer que su nombramiento en provisionalidad no les generaba estabilidad laboral, pues es de saber público que al momento de llegar quien ostente el cargo en propiedad a través del concurso de méritos, ellos saldrían del cargo.²⁷

5. Actuaciones en sede de revisión

El 12 de noviembre de 2021, con el fin de obtener los elementos probatorios necesarios para adoptar una decisión dentro del presente asunto, el suscrito magistrado sustanciador decretó pruebas²⁸ que debían ser suministradas por parte del Juzgado Tercero Penal del Circuito Mixto de Conocimiento de Ocaña -Norte de Santander-,²⁹ de la Alcaldía³⁰ de Ábrego -Secretaría de Gobierno Municipal-, Norte de Santander y de los accionantes Milciades Pérez Vergel y Carmen Alonso Pérez Vergel.³¹

26 Folio 56 del Cuaderno N° 1 del Expediente.

27 Folio 56 del Cuaderno N° 1 del Expediente.

28 El auto de pruebas obra dentro Cuaderno N° 1 del Expediente.

29 Al Juzgado Tercero Penal del Circuito Mixto de Conocimiento de Ocaña –Norte de Santander- se le solicitó remitir a esta Corporación copia íntegra digitalizada del expediente de tutela con número de radicación 2021-00036-01, promovido por los ciudadanos Milciades Pérez Vergel y Carmen Alonso Pérez Vergel en contra de la Alcaldía de Ábrego -Secretaría de Gobierno Municipal-, Norte de Santander.

30 A la Alcaldía de Ábrego -Secretaría de Gobierno Municipal-, Norte de Santander, se le ordenó la remisión de los documentos que a continuación se solicitan y/o que respondiera junto con los soportes respectivos, las

A continuación, se relacionan cada una de las pruebas allegadas en sede de revisión, cuya copia obra en el expediente.

6. Pruebas relevantes cuya copia obra en el expediente

En relación con el señor Milciades Pérez Vergel:

- (i)** Cédula de ciudadanía de Milciades Pérez Vergel y de su esposa Carmen Trigos, en las cuales se evidencia que él nació el 1 de septiembre
-

siguientes preguntas: **(i)** copia de los actos administrativos mediante los cuales fueron nombrados los señores Milciades Pérez Vergel y Carmen Alonso Pérez Vergel en los cargos que ocupaban al interior de la entidad antes de que finalizara su servicio, así como la copia de aquellos mediante los cuales se les comunicó la decisión de su retiro, **(ii)** copia del recurso de apelación que interpusieron los accionantes en contra de la decisión que los retiró del servicio, y, su correspondiente resolución, **(iii)** ¿cuántos fueron los cargos en provisionalidad ofertados, los concursantes en la lista y los cargos excedentes que resultaron de la convocatoria al concurso de méritos 779 de 2018 para proveer vacantes en el municipio de Ábrego?, **(iv)** ¿antes de ofertar los empleos a la Comisión Nacional del Servicio Civil, llevó a cabo la identificación de los cargos en provisionalidad que estaban siendo ocupados por personas inmersas en alguna condición especial, por ejemplo, padres cabeza de familia, trabajadores pre pensionados o personas con algún grado de discapacidad?.

31 A los ciudadanos Milciades Pérez Vergel y Carmen Alonso Pérez Vergel se les ordenó remitir una serie de documentos y/o que respondieran junto con los soportes respectivos, las siguientes preguntas: **(i)** copia de sus documentos de identidad, los de sus esposas y copia de los registros civiles de nacimiento de sus hijos, **(ii)** copia de las certificaciones o documentos que acrediten el porcentaje de pérdida de capacidad laboral que cada uno afirma padecer, **(iii)** copia de la historia clínica o constancia médica de las señoras Carmen Trigos Bayona y Rosa María Álvarez, en las cuales se acrediten las afectaciones de salud que padecen, **(iv)** copia de la historia clínica o constancia médica del joven Elkin Manuel Pérez Álvarez, en la cual se dé cuenta de su situación de discapacidad, **(v)** constancia de las semanas de cotización que hasta el momento han acumulado los señores Milciades Pérez Vergel y Carmen Alonso Pérez Vergel, **(vi)** ¿el proceso de rehabilitación por las contusiones que afirma padecer el señor Milciades Pérez Vergel sigue en curso o ya finalizó?, **(vii)** ¿luego de ser retirados de los cargos que ocupaban en provisionalidad en la Alcaldía de Ábrego, recibieron alguna suma por concepto de liquidación? Cada uno debe informar la cantidad y los detalles relativos al mismo asunto, **(viii)** ¿en qué fecha radicarón la solicitud de conciliación prejudicial ante los jueces administrativos del Circuito de Cúcuta?, **(ix)** ¿solicitaron la aplicación de

de 1958, (a la fecha tiene 63 años), y ella nació el 21 de enero de 1965, (a la fecha tiene 56 años).³²

(ii) Registro civil de nacimiento de Lina Yaneth Pérez Trigos, en el cual se evidencia que sus padres son Milciades Pérez Vergel y Carmen Trigos. Ella nació el 13 de agosto de 1997, (a la fecha tiene 24 años).³³

(iii) Dictamen pericial realizado a Milciades Pérez Vergel, por parte de la IPS Assot S.A.S, mediante el cual se dictamina un 51.12% de pérdida de su capacidad laboral.³⁴

(iv) Formato de informe para accidente de trabajo diligenciado por Positiva S.A., en el cual se certifica que el señor Milciades Pérez Vergel sufrió un accidente de trabajo³⁵ el 26 de febrero de 2018. A raíz de este accidente se emitieron recomendaciones médicas³⁶ que debería tener en cuenta la Alcaldía de Ábrego como empleador, por un periodo de 2 meses

medidas cautelares y/o promovieron la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en el marco del proceso que ahora nos ocupa?, (x) ¿la joven Yaneth Pérez Trigos retomó sus estudios universitarios?, (xi) ¿el joven Juan Camilo Pérez Álvarez continuó con sus estudios universitarios?, (xii) ¿Cuál es su nivel de estudios académicos y el de sus esposas, las señoras Carmen Trigos Bayona y Rosa María Álvarez?, (xiii) ¿actualmente ustedes y su núcleo familiar se encuentran afiliados al Sistema de Salud?, (xiv) ¿actualmente ustedes, señores accionantes, sus esposas o sus hijos cuentan con un empleo o desempeñan algún oficio del cual perciban ingresos económicos?.

32 Folios 208 a 210 del Cuaderno N° 2 del Expediente.

33 Folio 211 del Cuaderno N° 2 del Expediente.

34 Folios 212 a 224 del Cuaderno N° 2 del Expediente.

35 “*el trabajador se encontraba arreglando una alcantarilla, este se resvala y se cae dentro de la alcantarilla que se encontraba destapada a*

y luego de terminar ese periodo debía ser valorado por un médico laboral de su empresa. De ahí en adelante lo que se aportan son incapacidades médicas hasta el 19 de septiembre de 2019.³⁷

(vi) Historia clínica del señor Milciades Pérez Vergel, con fecha del 27 de enero de 2021, en la cual se emite plan de manejo para enfrentar dolor que refiere el señor Milciades en el hombro derecho. Dicho plan consiste en: *“Rx comparativa de hombros, us de hombro derecho, terapia física, orden para infiltración, control diclofenaco, naproxeno”*.³⁸ Posteriormente se registra un control con fecha del 6 de abril de 2021, en la cual se anota como resultado de una radiografía que le practicaron en el hombro: *“porciones oseas visualizadas no definen trazos de fracturas o lesiones, espacios articulares conservados. IDX: estudio dentro de los límites normales”*.³⁹

una altura de 2 metros, causando inmovilización del miembro superior izquierdo a la altura del hombro, por fractura además de golpe en cadera, se inmoviliza miembro inferior izquierdo y cuello.” Folio 272 del Cuaderno N° 2 del Expediente

36 Las recomendaciones eran las siguientes: *“puede levantar cargas hasta de 10kg, puede realizar movimientos de columna lumbosacra pero no de manera repetitiva y alternando con pausas activas, debe evitar posturas de rodillas o en cuclillas, puede realizar marcha en terreno llano, trayectos cortos, puede trabajar en alturas inferiores a 1.5 metros.”* Folio 278 del Cuaderno N° 2 del Expediente.

37 Folios 225 a 320 del Cuaderno N° 2 del Expediente.

38 Folios 329 a 335 del Cuaderno N° 2 del Expediente.

39 Folios 329 a 335 del Cuaderno N° 2 del Expediente.

(vii) Historia clínica de la señora Carmen Trigos en la cual se refiere que padece hipertensión esencial primaria y trastornos del oído y del mantenimiento del sueño.⁴⁰

(viii) Historia laboral de Milciades Pérez Vergel, expedida por Colpensiones, en la cual se registran 643 semanas de cotización en pensión.⁴¹

(ix) Comprobante del pago de liquidación que efectuó el Municipio de Ábrego a favor del señor Milciades Pérez Vergel, correspondiente a la suma de \$ 3'926.882.⁴²

(x) Resolución N° 699 del 15 de octubre de 2020, mediante la cual se declara insubsistente al señor Milciades Pérez Vergel, *“para poder proveer y tome posesión en periodo de prueba y en el marco del proceso de selección N° 779 de 2018, el señor José Leonardo Bayona, (...) quien ocupó el puesto N° 2 en las listas de elegibles en firme para proveer Auxiliar de Servicios Generales, código opec N° 69169 del sistema general de carrera administrativa de la planta de personal de la Alcaldía de Ábrego (Norte de Santander).”*⁴³

(xi) Recurso de reposición, con fecha del 16 de noviembre de 2020, en contra de la Resolución N° 699 del 15 de octubre de 2020. En dicha oportunidad el señor Milciades Pérez Vergel señaló que padece afectaciones a su salud derivadas del accidente de trabajo que sufrió en el año 2018, que es padre cabeza de familia, que el salario que devengaba era su único sustento y el de su familia, y que con el mismo efectuaba el pago de los estudios de su hija Lina Yaneth Pérez Trigos. En consecuencia, el accionante solicitó a la Alcaldía de Ábrego que hiciera

40 Folios 321 y 322 del Cuaderno N° 2 del Expediente.

41 Folios 323 a 328 del Cuaderno N° 2 del Expediente.

42 Folios 336 a 338 del Cuaderno N° 2 del Expediente.

43 Folios 339 a 346 del Cuaderno N° 2 del Expediente.

uso del margen de maniobra con el que cuenta el municipio para reintegrarlo a su puesto de trabajo.⁴⁴

(xii) Respuesta de la Alcaldía de Ábrego, al recurso de reposición elevado por el actor Milciades Pérez Vergel en contra de la Resolución N° 699 de 2020. La Alcaldía confirmó la decisión apelada bajo el argumento de que la misma respetó los parámetros de motivación, que en este caso obedeció al nombramiento de quienes superaron el proceso de selección N° 779 de 2018. Agregó que, aunque la Administración Municipal de Ábrego, es consciente acerca del despliegue de acciones afirmativas respecto de los provisionales en circunstancias de debilidad manifiesta, y de que estos deben ser los últimos en removerse de sus cargos o ser reubicados en otra vacante, dicha posibilidad no es posible en este caso, debido a que no existen vacantes en la planta global que permitan garantizar la permanencia en el cargo del señor Milciades Pérez Vergel.⁴⁵

(xiii) Solicitud de conciliación prejudicial de Milciades Pérez Vergel, ante la Procuraduría Delegada ante los Jueces Administrativos del Circuito de Cúcuta. Asimismo obra en el expediente la constancia mediante la cual la procuraduría 208 judicial I para para asuntos administrativos, dio por agotado el requisito de procedibilidad exigido para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.⁴⁶

(xiv) Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho radicada el 13 de abril de 2021, por el apoderado judicial⁴⁷ del señor Milciades Pérez Vergel ante los jueces administrativos del circuito del Municipio de San José de Cúcuta en contra de la Resolución N° 699 del 15 de octubre de

44 Folios 339 a 346 del Cuaderno N° 2 del Expediente.

45 Folios 347 a 353 del Cuaderno N° 2 del Expediente.

46 Folios 354 a 387 del Cuaderno N° 2 del Expediente.

47 Álvaro Iván Araque Chiquillo. TP N° 83295.

2020.⁴⁸ Se observa en el escrito de la demanda que el actor solicitó la suspensión provisional de del acto acusado, con fundamento en los hechos expuestos en la acción de tutela que motivó la presente sentencia.⁴⁹

El apoderado judicial del señor Milciades Pérez Vergel, informó⁵⁰ a este Despacho que, la demanda correspondió al Juzgado Noveno Administrativo Mixto de Cúcuta, pero que a la fecha la misma no ha sido admitida ni remitida por falta de competencia a otro juzgado.⁵¹ Refirió que no se allegó notificación alguna sobre el número radicado.

(xv) Declaración extra juicio reunida por Milciades Pérez Vergel ante la Notaría Única de Ábrego, en la cual asegura lo siguiente: *“actualmente nos encontrarnos afiliados al sistema de salud en régimen subsidiado ya que por los padecimientos de salud necesitamos asistir a los controles médicos. De igual manera mi nivel de estudios y el de mi esposa Carmen Trigos es primaria y ninguno de los miembros del núcleo familiar contamos con un empleo o actividad que generen ingresos económicos para nuestro sustento, Mi hija Lina Yaneth Pérez Trigos terminó sus*

48 Por medio de la cual, la Alcaldía de Abrego -Norte de Santander- declaró insubistente al señor Milciades Pérez Vergel con ocasión de los resultados de convocatoria al concurso de méritos 779 de 2018, para proveer cargos vacantes en el municipio de Ábrego.

49 Folios 388 a 418 del Cuaderno N° 2 del Expediente.

50 Mediante correo electrónico recibido el día 1 de marzo de 2022.

51 Folio 422 del Cuaderno N° 2 del Expediente.

estudios con dificultad ya que yo le costeaba sus estudios con el salario que devengaba de mi trabajo.”⁵²

En relación con el señor Carmen Alonso Pérez Vergel:

(i) Cédula de ciudadanía de Carmen Alonso Pérez Vergel y de su esposa Rosa María Álvarez, en las cuales se evidencia que él nació el 16 de julio de 1961, (a la fecha tiene 60 años), y ella nació el 1° de febrero de 1971, (a la fecha cuenta con 50 años).⁵³

(ii) Registros civiles de nacimiento de Elkin Manuel Pérez Álvarez y Juan Camilo Pérez Álvarez, en los cuales consta que sus padres son Carmen Alonso Pérez Vergel y de Rosa María Álvarez. El primero de ellos nació el 13 de abril de 1991 (a la fecha tiene 30 años), el segundo de ellos nació el 8 de julio de 1999 (a la fecha tiene 22 años).⁵⁴

(iii) Dictamen pericial realizado a Carmen Alonso Pérez Vergel, por parte de la IPS Assot S.A.S, mediante el cual se dictamina un 59% de pérdida de su capacidad laboral.⁵⁵

(iv) Historia clínica del señor Carmen Alonso Pérez Vergel, expedida por la Nueva EPS, con fecha del 10 de agosto de 2020, en la cual se certifica que el referido padece hipertensión arterial, diabetes mellitus insulino dependiente e Hiperlipidemia mixta.⁵⁶ Así como la historia

52 Folio 418 a 421 del Cuaderno N° 2 del Expediente.

53 Folios 47 y 48 del Cuaderno N° 2 del Expediente.

54 Folios 49 y 50 del Cuaderno N° 2 del Expediente.

55 Folios 51 a 57 del Cuaderno N° 2 del Expediente.

clínica de su esposa, la señora Rosa María Álvarez Lázaro, expedida por Asmet Salud EPS, en la cual se acredita que padece cálculo de riñón, cálculo de uréter e Hidronefrosis con obstrucción por cálculos del riñón y del uréter.⁵⁷

(v) Historia clínica del joven Elkin Manuel Pérez Álvarez, expedida por Asmet Salud ESS, en la cual se acredita que padece mielopatía progresiva hace 14 años, en condición de discapacidad por paraplejia, usuario de silla de ruedas quien requiere de múltiples cuidados en casa.⁵⁸

(vi) Historia laboral de Carmen Alonso Pérez Vergel, expedida por Colfondos, en la cual se registran 456 semanas de cotización en pensión.⁵⁹

(vii) Comprobante del pago de liquidación que efectuó el Municipio de Ábrego a favor del señor Carmen Alonso Pérez Vergel, correspondiente a la suma de \$ 7'102.293.⁶⁰

(viii) Resolución N° 701 del 15 de octubre de 2020, mediante la cual se declara insubsistente al señor Carmen Alonso Pérez Vergel *“para poder proveer y tome posesión en periodo de prueba y en el marco del proceso de selección N° 779 de 2018, la señora Lucía Ximena Navarro Arias, (...) quien ocupó el puesto N° 1 en las listas de elegibles en firme para proveer técnico operativo, código 314, grado 3, identificado con el*

56 Folios 58 a 92 del Cuaderno N° 2 del Expediente.

57 Folios 93 a 102 del Cuaderno N° 2 del Expediente.

58 Folios 103 a 105 del Cuaderno N° 2 del Expediente.

59 Folios 106 a 107 del Cuaderno N° 2 del Expediente.

60 Folios 108 a 110 del Cuaderno N° 2 del Expediente.

código OPEC N° 19801 del sistema general de carrera administrativa de la planta de personal de la Alcaldía de Ábrego (Norte de Santander). ”⁶¹

(ix) Recurso de reposición en contra de la Resolución N° 701 del 15 de octubre de 2020, mediante el cual el señor Carmen Alonso Pérez Vergel expuso a la Alcaldía de Ábrego diferentes razones por las que resultaba afectado con el retiro del cargo que venía ocupando, entre ellas señaló que, en la actualidad padece diferentes enfermedades que aquejan su salud, una de ellas diabetes mellitus, por la cual es insulino dependiente y tiene controles mes a mes. Indicó que es padre cabeza de familia, que el salario que devengaba era su único sustento y el de su familia, que con el mismo efectuaba el pago de los estudios de su hijo Juan Camilo Pérez Álvarez y que su hijo Elkin Manuel Pérez es una persona en condición de discapacidad. En consecuencia, el accionante solicitó a la Alcaldía de Ábrego que hiciera uso del margen de maniobra con el que cuenta el municipio para reintegrarlo a su puesto de trabajo. ⁶²

(x) Respuesta de la Alcaldía de Ábrego, al recurso de reposición elevado por el actor Carmen Alonso Pérez Vergel en contra de la Resolución N° 701 De 2020. La Alcaldía confirmó la decisión apelada bajo el argumento de que la misma respetó los parámetros de motivación, que en este caso obedeció al nombramiento de quienes superaron el proceso de selección N° 779 de 2018. Agregó que, aunque la Administración Municipal de Ábrego, es consciente acerca del despliegue de acciones afirmativas respecto de los provisionales en circunstancias de debilidad manifiesta, y de que estos deben ser los últimos en removerse de sus cargos o ser reubicados en otra vacante, dicha posibilidad no es posible en este caso, debido a que no existen vacantes en la planta global que permitan garantizar la permanencia en el cargo del señor Carmen Alonso Pérez Vergel. ⁶³

(xi) Solicitud de conciliación prejudicial de Carmen Alonso Pérez Vergel, ante la Procuraduría Delegada ante los Jueces Administrativos del

61 Folios 110 a 114 del Cuaderno N° 2 del Expediente.

62 Folios 115 a 122 del Cuaderno N° 2 del Expediente.

63 Folios 123 a 129 del Cuaderno N° 2 del Expediente.

Circuito de Cúcuta.⁶⁴ Asimismo obra en el expediente la constancia mediante la cual la procuraduría 208 judicial I para para asuntos administrativos, dio por agotado el requisito de procedibilidad exigido para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.⁶⁵

(xii) Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho radicada el 11 de junio de 2021, por el apoderado judicial⁶⁶ de Carmen Alonso Pérez Vergel ante los jueces administrativo del circuito del Municipio de San José de Cúcuta en contra de la Resolución N° 701 del 15 de octubre de 2020.⁶⁷ Se observa en el escrito de la demanda que el actor solicitó la suspensión provisional del acto acusado, con fundamento en los hechos expuestos en la acción de tutela que motivó la presente sentencia.⁶⁸

El apoderado judicial del señor Carmen Alonso Pérez Vergel, informó⁶⁹ a este Despacho que, la demanda correspondió en principio al Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Cúcuta, bajo radicado N° 2021-00803. Sin embargo, el referido juzgado declaró la incompetencia para conocer el

64 Folios 130 a 164 del Cuaderno N° 2 del Expediente.

65 Folios 165 a 168 del Cuaderno N° 2 del Expediente.

66 Álvaro Iván Araque Chiquillo. TP N° 83295.

67 por medio de la cual, la Alcaldía de Abrego -Norte de Santander- declaró insubistente al señor Carmen Alonso Pérez Vergel con ocasión de los resultados de convocatoria al concurso de méritos 779 de 2018, para proveer cargos vacantes en el municipio de Ábrego.

68 Folios 169 a 204 del Cuaderno N° 2 del Expediente.

asunto –por factor territorial- y remitió el expediente al Juzgado Primero Administrativo de Ocaña –Norte de Santander-, en donde le asignaron al caso un nuevo número de radicado, 54-498-33-33-001-2021-00083-00.⁷⁰

Ahora bien, una vez consultado el enlace creado por parte del Juzgado Primero Administrativo de Ocaña, para acceder al expediente electrónico,⁷¹ se evidencia que la última actuación allí consignada es del 12 de julio de 2021, mediante el cual la referida autoridad judicial le informa al abogado del actor que el proceso fue recibido en dicho despacho.⁷²

(xiii) Declaración extra juicio reunida por Carmen Alonso Pérez Vergel ante la Notaría Única de Ábrego, en la cual asegura lo siguiente: *“actualmente nos encontrarnos afiliados al sistema de salud en régimen subsidiado ya que por los padecimientos de salud necesitamos asistir a los controles médicos. De igual manera mi nivel de estudios es de bachiller y el de mi esposa Rosa María Álvarez Lázaró es de tercero de primaria y ninguno de los miembros del núcleo familiar contamos con un empleo o actividad que generen ingresos económicos para nuestro sustento, Mi hijo Juan Camilo Pérez Álvarez terminó sus estudios con dificultad ya que yo le costaba sus estudios con el salario que devengaba de mi trabajo.”*⁷³

69 Mediante correo electrónico recibido el día 1 de marzo de 2022.

70 Folios 422 a 427 del Cuaderno N° 2 del Expediente.

71 Dicho enlace se encuentra en el Folio 426 del Cuaderno N° 2 del Expediente.

72 Folio 428 del Cuaderno N° 2 del Expediente.

73 Folios 205 a 207 del Cuaderno N° 2 del Expediente.

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

1. Competencia

La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos proferidos dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.

2. Análisis de procedencia formal de la acción de tutela

La Sala determinará si concurren los requisitos mínimos de procedencia formal de la acción de tutela **(i)** legitimación en la causa por activa, **(ii)** legitimación en la causa por pasiva, **(iii)** subsidiariedad e **(iv)** inmediatez.

Legitimación en la causa por activa

Decreto 2591 de 1991 señala que: “*la acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante.*”

En virtud del artículo 86 Superior, esta Corporación, en Sentencia SU-377 de 2014, especificó las reglas jurisprudenciales que determinan el requisito de legitimación por activa, a saber: **(i)** la tutela es un medio de defensa de derechos fundamentales, que toda persona puede instaurar “*por sí misma o por quien actúe a su nombre*”; **(ii)** no es necesario que el titular de los derechos interponga directamente el amparo, pues un tercero puede hacerlo a su nombre; y **(iii)** ese tercero debe, sin embargo, tener una de las siguientes calidades: **a)** representante del titular de los derechos,⁷⁴ **b)** agente oficioso, o **c)** Defensor del Pueblo o Personero Municipal.⁷⁵

En el presente caso, los señores Milciades Pérez Vergel y Carmen Alonso Pérez Vergel, actúan en nombre propio. Así las cosas, la Sala encuentra que los accionantes se encuentran legitimados para solicitar el amparo de los derechos fundamentales que estiman vulnerados por parte de Alcaldía de

⁷⁴ Como el caso de personas jurídicas, menores de edad e incapaces absolutos o interdictos.

Ábrego -Secretaría de Gobierno Municipal-, Norte de Santander, luego de que esta, con ocasión de la convocatoria al concurso de méritos 779 de 2018, que se llevó a cabo para proveer cargos vacantes en el municipio de Ábrego, emitiera el acto administrativo mediante el cual se dispuso su desvinculación, presuntamente, sin tener en cuenta las particulares condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran, y por tanto, sin adoptar medidas afirmativas a su favor que permitieran su reubicación.

Legitimación en la causa por pasiva

En virtud de los artículos 1⁷⁶ y 5⁷⁷ del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra toda acción u omisión en la que incurran las autoridades públicas que hayan vulnerado, vulnere o amenace vulnerar cualquier derecho fundamental y excepcionalmente los particulares. Refiere a la aptitud legal y constitucional de la persona (natural o jurídica) contra quien se dirige la acción, de ser la posiblemente llamada a responder por la violación o amenaza del derecho fundamental.⁷⁸

La acción de tutela se dirige contra la Alcaldía de Ábrego -Secretaría de Gobierno Municipal-, Norte de Santander, entidad pública que a su vez es la llamada a responder por la presunta vulneración de los derechos

75 Estas reglas fueron reiteradas en las providencias T-083 de 2016 y T-291 de 2016.

76 “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señale este Decreto. Todos los días y horas son hábiles para interponer la acción de tutela.”

77 “La acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2 de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este Decreto.” Debe señalarse que en el Artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, el cual conforma el enunciado capítulo III, establece aquellos casos frente a los cuales procede la acción de tutela contra particulares.

Como ya lo ha señalado esta Corporación en anteriores oportunidades,⁷⁹ conforme al artículo 86 Superior, la acción de tutela es un medio judicial con carácter residual y subsidiario, que puede utilizarse frente a la vulneración o amenaza de derechos fundamentales cuando no exista otro medio de defensa de lo invocado, o existiéndolo, no resulte eficaz e idóneo, o se requiera acudir al amparo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.⁸⁰

La jurisprudencia constitucional ha reiterado que, por regla general, la acción de tutela es improcedente para solicitar el reintegro de los empleados públicos, ante la existencia de un medio de defensa judicial propio, específico idóneo y eficaz dentro del ordenamiento jurídico, esto es, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Ello debido a que, por medio de esta acción judicial, prevista en el artículo 138 del CPACA,⁸¹

78 Sentencias T-1015 de 2006, T-780 de 2011, T-008 de 2016, T-009 de 2016, T-100 de 2017 y T-651 de 2017, T-176 de 2018, entre otras.

79 Sentencias T-378 de 2018, T-043 de 2019, entre otras.

80 “la procedencia de la acción de tutela, cuando existen otros medios de defensa judicial, se sujeta a las siguientes reglas: **(i)** procede como **mecanismo transitorio**, cuando a pesar de la existencia de un medio ordinario de defensa, este no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable, conforme a la especial situación del peticionario; **(ii)** procede la tutela como **mecanismo definitivo** cuando el medio ordinario dispuesto para resolver las controversias, no es idóneo y eficaz, conforme a las especiales circunstancias del caso que se estudia. Además, **(iii)** cuando la acción de tutela es promovida por personas que requieren especial protección constitucional, como los niños y niñas, mujeres cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, **personas de la tercera edad**, entre otros. El examen de procedibilidad de la acción de tutela es menos estricto, a través de criterios de análisis más amplios, pero no menos rigurosos”. Sentencias T-789 de 2003, T- 456 de 2004, T-328 de 2011, T-079 de 2016, entre otras.

81 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso administrativo.

puede reclamarse ante el juez de lo contencioso administrativo, la efectividad de los derechos constitucionales y legales, la anulación total o parcial del acto administrativo que produce la presunta vulneración de derechos. Así como, obtener la correspondiente reparación del daño causado.⁸²

Medidas cautelares en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo:

Sumado a lo hasta aquí expuesto, debe señalarse que, conforme a lo dispuesto en el artículo 233 del CPACA, en cualquier momento del trámite administrativo es posible solicitar medidas cautelares para proteger y garantizar el objeto del proceso. Estas pueden consistir en la suspensión de efectos del acto administrativo cuestionado. De igual manera, es posible que el juez imponga a la contraparte obligaciones de hacer, como por ejemplo ser nombrado en provisionalidad en otro cargo, mientras se resuelve el asunto de fondo.⁸³

Según lo dispone el artículo 233 del CPACA, la solicitud de medida cautelar debe ser resuelta al cabo de 10 días, luego de surtido el traslado por 5 días a la otra parte. Sin embargo, el artículo 234 dispone que, en casos de urgencia, el juez las puede adoptar sin surtir el correspondiente traslado. Sobre este punto, en Sentencia SU-691 de 2017, esta Corte precisó que *“(...) en casos de urgencia, la solicitud y decreto de la medida cautelar no necesariamente debe realizarse dentro del proceso entablado contra un acto administrativo. Por lo tanto, la urgencia en la protección de los derechos no sólo justifica que el juez debe tomar la medida cautelar sin correr traslados, tal como está previsto en el artículo 234 de la Ley 1437 de 2011 sino que, según el caso, no es necesario presentar demanda de fondo para que el juez tenga competencia para proferir la medida cautelar.”*

Ahora bien, es importante reseñar algunas de las diferencias existentes entre la eficacia que ofrece la acción de tutela por un lado y las medidas

82 Sentencia T-554 de 2019.

83 Sentencia T-554 de 2019.

cautelares desarrolladas por el CPACA, por otro lado, en relación con la protección de los derechos fundamentales de los afectados. En Sentencia SU-691 de 2017, la Corte identificó algunas de ellas. *“la más relevante es que las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho iniciadas ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, deben presentarse por intermedio de un abogado y el procedimiento, a pesar de los avances normativos en pro de la eficacia del derecho de acceso a la administración de justicia, se rige por la formalidad y por la regla de la justicia rogada. Por su parte, la acción de tutela no requiere de apoderado judicial y se rige, en contraposición, por el principio de informalidad y permite la adopción de fallos extra y ultra petita. Además, las medidas provisionales proferidas por el juez de tutela no requieren de caución por parte del accionante, lo que sí ocurre ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, salvo en lo relativo a la suspensión provisional de actos administrativos.*

Procedencia excepcional de la acción de tutela para solicitar el reintegro laboral de los empleados públicos:

A partir de lo expuesto, la Corte ha concluido que si bien (...) *la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo cuenta en la actualidad con las herramientas necesarias para garantizar la protección de los derechos fundamentales de forma igual o superior al de la acción de tutela, por parte de los jueces especializados en los asuntos del contencioso administrativo y también encargados de la protección de los derechos fundamentales, esto no significa la improcedencia ni automática ni absoluta de la acción constitucional de protección subsidiaria de derechos fundamentales, ya que los jueces de tutela tienen la obligación de determinar, de conformidad con el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, la idoneidad y la eficacia -en concreto- de los otros medios de defensa judicial atendiendo a las circunstancias particulares del solicitante. (...)*⁸⁴

Por consiguiente, esta Corporación ha admitido la procedencia excepcional de la tutela para solicitar el reintegro de los servidores públicos, *“cuando en el caso concreto se advierta la vulneración de un derecho fundamental y se evidencia la ocurrencia de un perjuicio irremediable.”*⁸⁵ En esta dirección, se ha señalado que para la comprobación de un perjuicio irremediable que

84 Sentencia SU-691 de 2017.

85 Este Tribunal ha sostenido que el perjuicio irremediable se caracteriza por: (i) la inminencia del daño, es decir, que se trate de una amenaza o de

justifique la procedencia de la acción de tutela se deben observar una serie de criterios, tales como la edad de la persona, su estado de salud y el de su familia, sus condiciones económicas y la de las personas obligadas a acudir a su auxilio.⁸⁶ Sumado a lo anterior, la Corte ha enfatizado que, tratándose de desvinculaciones de funcionarios públicos, la posibilidad de configuración de un perjuicio irremediable gira especialmente, en torno al derecho al mínimo vital, *“debido a que una vez quedan desvinculadas de sus trabajos, pueden quedar expuestas a una situación de extrema vulnerabilidad, cuando su único sustento económico era el salario que devengaban a través del cargo público.”*⁸⁷

Es importante recordar que, según lo ha establecido este Tribunal, existen una serie de categorías poblacionales que demandan una especial protección por parte del Estado, como es el caso de los adultos mayores, en razón a su edad y las debilidades que el avance de esta genera en la realización de ciertas funciones y actividades,⁸⁸ también las personas que por sus condiciones físicas o mentales se encuentran en estado de debilidad manifiesta. Ello en aras de superar las barreras que les impiden acceder al goce efectivo de sus derechos fundamentales,⁸⁹ así como las madres y

un mal irreparable que está pronto a suceder; (ii) la gravedad, que implica que el daño o menoscabo material o moral de la persona que pueda ocurrir sea de gran intensidad, (iii) la urgencia, que exige la adopción de medidas prontas o inmediatas para conjurar la amenaza, y (iv) la impostergabilidad de la tutela, que exige la necesidad de recurrir al amparo como mecanismo expedito y necesario de protección de derechos fundamentales. Sentencias T-016 de 2008, SU-691 de 2017, T-464 de 2019, entre otras.

86 Sentencias SU-691 de 2017, T-146 de 2019, entre otras.

87 Sentencias SU-691 de 2017 y T-464 de 2019.

88 Sentencia C-066 de 2020, entre otras.

89 Sentencias T-662 de 2017, T-225 de 2018, entre otras.

padres cabeza de familia, a causa de la responsabilidad individual y solitaria que tienen a cargo frente al hogar,⁹⁰ entre otros grupos especialmente protegidos.

Factores que acentúan la situación de vulnerabilidad de los accionantes en el caso concreto:

Descendiendo al caso concreto, esta Sala de Revisión advierte que, tanto en el caso del señor Milciades Pérez Vergel, como en el caso del señor Carmen Alonso Pérez Vergel, concurren diferentes factores que acentúan su estado de vulnerabilidad y que por ende ustifican la procedencia de la acción de tutela para solicitar el reintegro laboral deprecado, con el fin de evitar la consumación de un perjuicio irremediable.

Por un lado, el señor Milciades Pérez Vergel (i) es un adulto mayor, pues tiene 60 años de edad; (ii) es una persona en condición de discapacidad, toda vez que padece afectaciones en su hombro izquierdo, hernia discal y discopatía cervical, por lo cual fue calificado con una pérdida de capacidad laboral del 51.12%, (iii) en la actualidad se encuentra desempleado, al igual que su hija Lina Yaneth Pérez Trigos y su esposa Carmen Trigos, quien también presenta problemas de salud,⁹¹ y (iv) está afiliado al SISBEN en el grupo A4, el cual reúne a aquellos sujetos que se encuentran en pobreza extrema.⁹²

Por otro lado, en el caso del señor Carmen Alonso Pérez Vergel, (i) se trata de un adulto mayor, pues tiene 63 años de edad; (ii) es una persona en

90 Sentencia T-803 de 2013.

91 Estos son hipertensión esencial primaria y trastornos del oído y del mantenimiento del sueño. Folios 321 y 322 del Cuaderno N° 2 del Expediente.

92 La referida información se puede consultar en:
https://reportes.sisben.gov.co/dnp_sisbenconsulta

condición de discapacidad, ya que padece hipertensión arterial, diabetes mellitus insulínica e hiperlipidemia mixta; por lo cual, además, fue calificado con una pérdida de capacidad de laboral del 59% ; (iii) es padre cabeza de familia,⁹³ puesto que tiene la responsabilidad permanente de su hijo Elkin Manuel Pérez Álvarez, quien actualmente se encuentra en situación de discapacidad a causa de la paraplejia que padece y que le impide trabajar, asimismo su esposa, quien, aunque se encuentra presente en el hogar no contribuye económicamente al mismo debido a las afectaciones de salud que la aquejan;⁹⁴ (iv) en la actualidad se encuentra desempleado, al igual que su hijo Juan Camilo Pérez Álvarez y su esposa Rosa María Álvarez, y (v) está afiliado al SISBEN en el grupo C1, en la categoría de personas vulnerables.⁹⁵

En cuanto a la calidad de pre pensionados alegada por los actores y por la cual consideran ser merecedores de un trato especial, la Sala debe destacar que, según lo ha reconocido esta Corporación, la misma además de que es insuficiente para demostrar la ineficacia del medio judicial ordinario,⁹⁶ (en este caso la acción de nulidad y restablecimiento del derecho), “*la acreditan*

93 Al respecto debe señalarse que para la Corte, la condición de padre o madre cabeza de familia se acredita cuando “*la persona (i) tiene la responsabilidad permanente de hijos menores o personas incapacitadas para trabajar; (ii) no cuenta con la ayuda de otros miembros de la familia y (iii) su pareja murió, está ausente de manera permanente o abandonó el hogar y se demuestra que esta se sustrae del cumplimiento de sus obligaciones, o cuando su pareja se encuentre presente pero no asuma la responsabilidad que le corresponde por motivos como la incapacidad física, sensorial, síquica o mental*” Sentencia T-003 de 2018

94 La esposa del señor Carmen Alonso padece cálculo de riñón, cálculo de uréter e Hidronefrosis con obstrucción por cálculos del riñón y del uréter y debido a dichas patologías se le dificulta conseguir alternativas de apoyo económico para el hogar. Folios 93 a 102 del Cuaderno N° 2 del Expediente.

95 La referida información se puede consultar en:
<https://www.sisben.gov.co/Paginas/consulta-tu-grupo.aspx>

96 Sentencia T-325 de 2018.

*las personas vinculadas laboralmente al sector público o privado, que están próximas (dentro de los 3 años siguientes) a acreditar los dos requisitos necesarios para obtener la pensión de vejez (la edad y el número de semanas o tiempo de servicio.”*⁹⁷ Dicho esto, en el presente asunto no se satisfacen los mencionados requisitos toda vez que el señor Milciades ha cotizado hasta la fecha 643 semanas y el señor Carmen Alonso ha cotizado 456 semanas, es decir, les hacen falta más de 3 años para reunir la totalidad de las cotizaciones requeridas por ley.

Es importante precisar que, una vez verificada la Base de Datos Única de Afiliados BDUA del Sistema General de Seguridad Social en Salud, se evidencia que el señor Milciades Pérez Vergel se encuentra afiliado a Medimas EPS, en estado activo, y el señor Carmen Alonso Pérez Vergel, está afiliado a la Nueva E.P.S, en estado activo por emergencia.

Ineficacia del medio ordinario de defensa judicial (acción de nulidad y restablecimiento del derecho) para evitar la consumación de un perjuicio irremediable:

Con todo, para la Sala es claro que a pesar de que los accionantes cuentan con un mecanismo de defensa judicial idóneo, como lo es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, (cuya demanda radicaron los días 13 de abril y 11 de junio de 2021,⁹⁸ en contra de las resoluciones N° 699 y 701 del 15 de octubre de 2020, proferidas por la Alcaldía de Ábrego), el mismo carece de eficacia, debido a que a la fecha, esto es, pasados 9 meses- no ha habido pronunciamiento alguno al respecto, según afirmó el apoderado judicial de los accionantes el día 1 de marzo de 2022.

En el caso del señor Milciades Pérez Vergel, la demanda, la cual correspondió por reparto al Juzgado Noveno Administrativo Mixto de Cúcuta, no ha sido ni siquiera admitida, ni remitida por falta de

97 “requerido en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida o el capital necesario en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad) y consolidar así su derecho a la pensión.” Sentencia T-662 de 2017.

98 Información que puede verificarse en los Folios 169 a 204 y 388 a 418 del Cuaderno N° 2 del Expediente.

competencia a otro juzgado.⁹⁹ Y en el caso del señor Carmen Alonso Pérez Vergel, la demanda, que en principio correspondió por reparto al Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Cúcuta, fue remitida por falta de competencia al Juzgado Primero Administrativo de Ocaña -Norte de Santander-, sin que a la fecha se haya adelantado una actuación posterior a la surtida en el mes de julio de 2021, mediante la cual la referida autoridad judicial le informó al abogado del actor que el proceso fue recibido en dicho despacho.¹⁰⁰

Sumado a lo anterior, es evidente que, la desvinculación laboral de los accionantes, implicó una afectación a su mínimo vital y al de las personas bajo su cargo, dado que el salario que devengaban por los puestos que ocupaban al interior de la Alcaldía de Ábrego, constituía su único sustento económico. Con ello, los actores quedaron expuestos a un mayor grado de vulnerabilidad.

A partir de lo expuesto, se evidencia que, pese a que los accionantes promovieron el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en este caso resulta procedente la intervención del juez constitucional, ante la inminente necesidad de salvaguardar el derecho fundamental al mínimo vital de los accionantes. Pues la demora que ha permeado los procesos que adelantaron ante la JCA, ha generado una vulneración prolongada de tal garantía y ha creado un riesgo de perjuicio irremediable, considerando las circunstancias de vulnerabilidad en las que se encuentra cada uno de los accionantes, especialmente por su edad, estado de salud, condición de padres cabeza de familia (en el caso del señor Carmen Alonso Pérez Vergel), desempleados y en situación de pobreza.

Por las mismas razones, resultaría desproporcionado, seguir sometiendo a los actores a un juicio dispendioso que en el caso concreto ha constituido una espera interminable y que además debe surtir por intermedio de un apoderado judicial. Dicha situación refuerza la conclusión de que la eficacia que ofrece la acción de tutela, en relación con la protección de los derechos

99 Folio 422 del Cuaderno N° 2 del Expediente.

100 Folios 422 a 428 del Cuaderno N° 2 del Expediente.

fundamentales de los accionantes en este asunto, supera la eficacia que debería caracterizar un proceso administrativo previsto para estos casos, sobretodo, mediante la adopción de medidas cautelares.

Cabe recalcar que la procedencia de la presente acción de tutela en este caso, como se expuso con antelación, surge únicamente en relación con la solicitud de reincorporación laboral elevada por los actores, cuya viabilidad se estudiará en el respectivo análisis de fondo. En cuanto a la solicitud atinente a los pagos de las prestaciones que se dejaron de pagar desde el momento de la notificación del retiro de los actores hasta la fecha en que sean incorporados, la Sala debe precisar que la misma deberá ser resuelta en el marco del proceso administrativo que ya adelantaron los accionantes, la cual hizo parte de las pretensiones allí expuestas. Ello debido a que la Corte ha delimitado la procedencia de estos casos, solo en relación con el reintegro y no con el pago de prestaciones sociales.

Adicionalmente, se reitera que la presente acción de tutela, procede como un mecanismo transitorio. Es decir, de llegarse a concluir, una vez agotado el estudio de fondo en la presente controversia, que procede el amparo invocado por los accionantes, este solo será transitorio, mientras se resuelven las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho radicadas por los señores Milciades Pérez Vergel y Carmen Alonso Pérez Vergel, los días 13 de abril y 11 de junio de 2021, en contra de las resoluciones N° 699 y 701 del 15 de octubre de 2020, proferidas por la Alcaldía de Ábrego, -Norte de Santander-.

Inmediatez

Según el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela puede interponerse en todo momento y lugar. Sin embargo, la jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que debe existir “*una correlación temporal entre la solicitud de tutela y el hecho vulnerador de los derechos fundamentales*”.¹⁰¹ Lo anterior, en razón a que dicha acción constitucional tiene como finalidad conjurar situaciones urgentes que requieren de la actuación rápida de los jueces.¹⁰²

En este caso el tiempo transcurrido entre el acto administrativo que confirmó la decisión de retirar del servicio a los accionantes (17 de octubre

101 Sentencia SU-241 de 2015.

102 Sentencia T-038 de 2017.

de 2020) y el momento en el que formularon la acción de tutela (4 de marzo de 2021), fue de 5 meses, plazo que la sala estima razonable, considerando además las especiales circunstancias de vulnerabilidad en las que se encuentran los actores.

3. Problema jurídico a resolver

De conformidad con lo expuesto en precedencia, corresponde a la Sala Novena de Revisión resolver el siguiente problema jurídico:

¿La Alcaldía de Ábrego -Norte de Santander- vulneró el derecho fundamental a la estabilidad laboral relativa o intermedia, de los señores Milciades y Carmen Alonso Pérez Vergel, al desvincularlos del cargo de carrera que venían ocupando en provisionalidad, para proceder al nombramiento, a partir de la lista de elegibles, de quien superó el concurso de méritos?

Con el fin de resolver la controversia planteada, la Sala abordará los siguientes ejes temáticos: (i) la provisión de cargos de la lista de elegibles previo concurso de méritos y (ii) la estabilidad laboral de los funcionarios públicos nombrados en provisionalidad que desempeñan cargos de carrera administrativa.

La provisión de cargos de la lista de elegibles previo concurso de méritos

El artículo 125 de la Constitución Política establece el régimen de carrera administrativa para la provisión de los empleos en los órganos y entidades del Estado, salvo las excepciones constitucionales y legales, y los regímenes especiales de creación constitucional, como los cargos de elección popular, de libre nombramiento y remoción, de trabajos oficiales, y los demás que determine la ley. Asimismo, el referido artículo dispone que: “*los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados a través de concurso público. El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes. El retiro se hará por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo, por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en el Constitución o la ley,*” y, por último, establece que “*en ningún caso, la afiliación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción.*”¹⁰³

103 Artículo 125 de la Constitución Política.

Así las cosas, según ha precisado esta Corte en anteriores oportunidades,¹⁰⁴ el objetivo de esta disposición constitucional es crear un mecanismo objetivo de acceso a los cargos públicos, en el cual las condiciones de ingreso, ascenso, permanencia y retiro respondan al mérito, conforme a criterios reglados y no a la discrecionalidad del nominador. De este modo, ha señalado la Corte, la carrera administrativa se convierte en el mecanismo preferente para el acceso y la gestión de los empleos públicos, en donde quien supere satisfactoriamente las etapas del concurso de méritos, adquiere un derecho subjetivo de ingreso al empleo público, el cual puede ser exigible frente a la Administración como a los funcionarios públicos que se encuentran desempeñando el cargo ofertado en provisionalidad.¹⁰⁵ Por esta razón, este Tribunal ha reiterado que existen marcadas diferencias entre los funcionarios inscritos en carrera administrativa y los funcionarios públicos provisionales, en especial en cuanto a su vinculación y retiro:¹⁰⁶

“(...) por una parte, los funcionarios que acceden a los cargos mediante el concurso de méritos cuentan con una mayor estabilidad, al haber superado las etapas propias del concurso, impidiendo así el retiro del cargo a partir de criterios meramente discrecionales. El acto administrativo por medio del cual se desvincula a un funcionario de carrera administrativa debe ser motivado para que la decisión sea ajustada a la Constitución, además de otros requisitos que determina la ley.¹⁰⁷ Por otra parte, los funcionarios que desempeñan en provisionalidad cargos de carrera, gozan de una estabilidad laboral relativa o intermedia, que implica que el acto administrativo por medio del cual se efectúe su desvinculación debe establecer únicamente las

104 Sentencias T-373 de 2017, T-464 de 2019, entre otras.

105 Sentencia T-373 de 2017, parágrafo 2º del artículo 41 de la Ley 909 de 2004.

106 Sentencia T-373 de 2017, parágrafo 2º del artículo 41 de la Ley 909 de 2004.

*razones de la decisión, lo cual para este Tribunal Constitucional constituye una garantía mínima derivada del derecho fundamental al debido proceso y al principio de publicidad.”*¹⁰⁸

La estabilidad laboral de los funcionarios públicos nombrados en provisionalidad que desempeñan cargos de carrera administrativa

En consonancia con el artículo 53 de la Constitución Política, según el cual una de las garantías mínimas que debe tener el trabajador es la estabilidad en el empleo, este Tribunal ha reconocido el *“derecho constitucional a una estabilidad laboral reforzada, que se deriva del principio de derecho a la igualdad de trabajo y que se materializa con medidas diferenciales en favor de aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.”*¹⁰⁹ Así las cosas, la Corte Constitucional ha definido la estabilidad laboral como:

“una garantía que tiene todo trabajador a permanecer en el empleo y a obtener los correspondientes beneficios salariales y prestacionales, incluso contra la voluntad del patrono, si no existe una causa relevante que justifique el despido. La doctrina ha entendido entonces que el principio de estabilidad laboral configura, en cabeza de los trabajadores, un verdadero derecho jurídico de resistencia al despido, el cual es expresión del hecho de que los fenómenos laborales no se rigen exclusivamente por el principio de la autonomía de la voluntad, ya que están en juego otros valores constitucionales, en especial la propia dignidad del trabajador y la búsqueda de una mayor igualdad entre patrono y empleado. Por ello, en función del principio de la estabilidad laboral, y de la especial protección al trabajo (CP arts 25 y 53), no basta el deseo empresarial para que pueda cesar una relación de trabajo, sino que es necesario que

107 Sentencia T-464 de 2017, Artículo 41 de la Ley 909 de 2004.

108 Sentencias T-373 de 2017, T-464 de 2019, entre otras.

109 Sentencias T-014 de 2019 y T-464 de 2019, entre otras.

*se configure una justa causa, en los términos señalados por la ley, y en armonía con los valores constitucionales”.*¹¹⁰

Los titulares de la estabilidad laboral reforzada, tal como lo ha sostenido la Corte, son aquellas personas que se encuentran amparadas por el fuero sindical, en condición de invalidez o discapacidad y las mujeres en estado de embarazo, así como aquellos trabajadores con limitaciones físicas, sensoriales o psicológicas que se encuentran en situación de debilidad manifiesta. Al respecto, este Tribunal ha sostenido que dicha limitación hace referencia a una aplicación extensiva de la Ley 361 de 1997,¹¹¹ a aquellas personas que se encuentran en un estado de debilidad manifiesta por causa de una enfermedad, sin necesidad de que exista una calificación previa que acredite su condición de discapacidad o invalidez.¹¹²

Tratándose de los servidores públicos que ocupan en provisionalidad un cargo de carrera, la Corte ha manifestado que gozan de una estabilidad laboral relativa, lo que implica que únicamente pueden ser removidos por causales legales que deben expresarse de manera clara en el acto de desvinculación. De esta manera, la Corte ha reiterado que *“la terminación de una vinculación en provisionalidad porque la plaza respectiva debe ser provista con una persona que ganó el concurso no desconoce los derechos de esta clase de funcionarios, pues precisamente la estabilidad relativa que se le ha reconocido a quienes están vinculados bajo esta modalidad, cede frente al mejor derecho que tienen las personas que ganaron un concurso público de méritos.”*¹¹³ Sobre este punto, en la sentencia SU-446 de 2011, la Corte señaló que:

110 Sentencias C-470 de 1997, T- 320 de 2016, T-464 de 2019, T-052 de 2020, entre otras.

111 *“Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas en situación de discapacidad y se dictan otras disposiciones”*

112 Sentencias T-198 de 2006, T-504 de 2008, T-263 de 2009, T-065 de 2010, T-663 de 2011, T-464 de 2019, entre otras.

“la situación de quienes ocupan en provisionalidad cargos de carrera administrativa, encuentra protección constitucional, en la medida en que, en igualdad de condiciones pueden participar en los concursos y gozan de estabilidad laboral, condicionada al lapso de duración del proceso de selección y hasta tanto sean reemplazados por quien se haya hecho acreedor a ocupar el cargo en virtud de sus méritos evaluados previamente.”

Sin embargo, teniendo en cuenta que dentro de las personas que ocupan un cargo de carrera en provisionalidad, pueden haber sujetos de especial protección constitucional, como las madres y padres cabeza de familia, quienes estén próximos a pensionarse, o personas que se encuentran en situación de discapacidad o en debilidad manifiesta por causa de una enfermedad, la Corte ha reconocido que *“antes de proceder al nombramiento de quienes superaron el concurso de méritos, los funcionarios que se encuentren en provisionalidad deberán ser los últimos en removerse y en todo caso, en la medida de las posibilidades, deben vincularse nuevamente de manera provisional en cargos vacantes de la misma jerarquía o equivalencia de los que se venían ocupando, siempre y cuando demuestren una de esas condiciones especiales al momento de su desvinculación y al momento del posible nombramiento.”*¹¹⁴ En esta dirección, en sentencia SU-917 de 2010, esta Corporación precisó que *“la vinculación de estos servidores se prolongará hasta tanto los cargos que lleguen a ocupar sean provistos en propiedad mediante el sistema de carrera o su desvinculación cumpla los requisitos exigidos en la jurisprudencia constitucional.”*

A modo de conclusión, tal como se reiteró en las Sentencias T-373 de 2017 y T-464 de 2019, en aquellos casos en los que surge, con fundamento en el

113 Sentencias SU-446 de 2011 y T-464 de 2019.

114 Sentencias T-373 de 2017, T-464 de 2019.

principio del mérito, la obligación de nombrar de la lista de elegibles a la persona que superó las etapas del concurso, en un cargo de carrera ocupado en provisionalidad por un sujeto de especial protección como los padres o madres cabeza de familia, limitados físicos, psíquicos o sensoriales y pre pensionados, las entidades deben proceder con especial cuidado antes de efectuar los respectivos nombramientos, mediante la adopción de medidas afirmativas, (dispuestas en la constitución art. 13 numeral 3º, y en la materialización del principio de solidaridad social -art. 95 ibídem-),¹¹⁵ relativas a su reubicación, y en caso de no adoptarse tales medidas, de ser posible, han de ser vinculados de nuevo en provisionalidad en un cargo similar o equivalente al que venían ocupando, de existir la vacante, siempre y cuando demuestren una de esas condiciones, tanto para la época de su desvinculación, como en el momento del posible nombramiento.

4. Caso concreto

Los señores Milciades Pérez Vergel y Carmen Alonso Pérez Vergel instauraron acción de tutela en contra de la Alcaldía de Ábrego -Norte de Santander-, luego de que la referida entidad los retirara de los cargos que venían ocupando (auxiliar de servicios generales grado 6 y técnico administrativo grado 3), para efectuar los nombramientos de las personas que superaron el concurso de méritos, sin adoptar medidas afirmativas a su favor, dadas las condiciones de vulnerabilidad que los convierten en sujetos de especial protección por parte del Estado, ello, debido a que, son adultos mayores, padres cabeza de familia, personas en situación de discapacidad y trabajadores prepensionados, según afirman.

Examinada la actuación del municipio de Ábrego contenida en los actos administrativos N° 699 y 701 del 15 de octubre de 2020, se encuentra que estos se sustentan en la expedición de las listas de elegibles del concurso de méritos para proveer los cargos de dos concursantes que superaron las etapas del concurso 779 de 2018,¹¹⁶ para proveer cargos vacantes en el municipio de Ábrego. Al respecto debe señalarse que la motivación del retiro del servicio de los actores es razonable y consecuentemente, no se evidencia, *prima facie*, la utilización abusiva y arbitraria de una facultad legal para encubrir un trato discriminatorio, relacionado directamente con las condiciones de vulnerabilidad que alegan los accionantes.

115 Sentencia T-373 de 2017.

116 “Por medio del cual se provén cargos vacantes en el Municipio de Ábrego.”

Ahora bien, como se aclaró en el acápite de subsidiariedad de la presente sentencia, a pesar de que no puede exigirse un trato especial en razón a la alegada condición de pre pensionados de los accionantes, debido que a ambos les hacen falta más de 3 años para reunir la totalidad de las cotizaciones requeridas por ley, lo cierto es que existen otras circunstancias que, sí convierten a los actores en sujetos de especial protección constitucional, y que en consecuencia, evidencian su condición de vulnerabilidad. En el caso del señor Milciades Pérez Vergel, por ser un adulto mayor, que a causa de las afectaciones que padece en su salud fue calificado con una pérdida de capacidad laboral del 51.12%, y estar afiliado al SISBEN en el grupo correspondiente a aquellos que se encuentran en extrema pobreza. Y en el caso del señor Carmen Alonso Pérez Vergel, por ser también un adulto mayor, calificado con un 59% de pérdida de capacidad laboral debido a las patologías que padece, por ser, a su vez, padre cabeza de familia y estar afiliado al SISBEN en la categoría de personas vulnerables.

Tal como se explicó en las consideraciones de esta sentencia, la entidad accionada, tenía la obligación de identificar y en consecuencia adoptar acciones afirmativas a favor de aquellos sujetos de especial protección constitucional que estuvieran ocupando los cargos provisionales, para que, en lo posible, fueran reubicados en otros empleos vacantes. Sin embargo, no se evidencia dentro de las pruebas aportadas y recaudadas en el expediente, alguna actuación por parte de la Alcaldía de Ábrego, destinada a lograr este cometido, antes de proceder con el nombramiento de la lista de elegibles, de quienes superaron las etapas del concurso 779 de 2018.

Debe señalarse que, aún, sin haber identificado los empleos que estaban siendo ocupados por sujetos de especial protección constitucional, la entidad tuvo la oportunidad de conocer las condiciones de vulnerabilidad en las que se encontraban los accionantes en una segunda oportunidad, pues las mismas fueron sustentadas por los actores en el escrito del recurso de reposición que interpusieron en contra de los actos administrativos de retiro. Sin embargo, esta se limitó a manifestarle a los accionantes, sin sustento alguno, que en ese momento no existían vacantes en la planta global que permitieran garantizar su permanencia en la entidad.

Al respecto, cabe precisar que, mediante Auto del 12 de noviembre de 2021, el Magistrado Sustanciador solicitó a la entidad accionada, contestar algunas preguntas, (junto con los soportes probatorios) relacionadas con su actuación en el marco de la convocatoria al concurso de méritos 779 de 2018 y con el proceso de retiro de los actores, por ejemplo: ¿cuántos fueron los cargos en provisionalidad ofertados, los concursantes en la lista y los cargos excedentes que resultaron de la convocatoria al concurso de méritos 779 de 2018 para proveer vacantes en el municipio de Ábrego?; ¿antes de ofertar los empleos a la Comisión Nacional del Servicio Civil, llevó a cabo la identificación de los cargos en provisionalidad que estaban siendo

ocupados por personas inmersas en alguna condición especial, por ejemplo, padres cabeza de familia, trabajadores pre pensionados o personas con algún grado de discapacidad?; ¿adoptó alguna acción afirmativa a favor de los funcionarios señalados en la pregunta anterior para que en lo posible fueran reubicados en otros empleos vacantes o fueran los últimos en ser retirados del servicio?; ¿a la fecha ya fueron nombrados en sus respectivos cargos todos los integrantes de la lista de elegibles que concursaron en la convocatoria 779 de 2018 para proveer vacantes en el municipio de Ábrego?.

Sin embargo, la entidad no contestó ninguna de las preguntas formuladas. Simplemente se limitó a enviar copia de los actos de nombramiento y retiro de los accionantes, de los recursos de reposición que interpusieron en contra de las Resoluciones N° 699 y 701 del 15 de octubre de 2020, y de la respuesta a los mismos. Es decir, una vez más, la Alcaldía de Ábrego redujo su actuación a meras afirmaciones, carentes de sustento, que no solo no bastan para demostrar que en efecto intentó adoptar medidas afirmativas a favor de los accionantes, sino que evidencian su falta de interés en hacerlo.

Así las cosas, para la Sala es claro que la entidad accionada desconoció los postulados jurisprudenciales fijados por esta Corporación, destinados a prever en la medida de lo posible, el mayor margen de protección a favor de aquellos funcionarios públicos nombrados en provisionalidad, que ostentan la calidad de sujetos de especial protección constitucional, antes de proceder al nombramiento de quienes superaron el concurso de méritos. Con ello, la Alcaldía de Ábrego vulneró el derecho fundamental a la estabilidad laboral relativa o intermedia de los accionantes.

Ahora bien, también es cierto que existe una tensión entre la protección de los derechos de los accionantes, de una parte; y el respeto de la carrera administrativa y los resultados del concurso de méritos 779 de 2018, de otra parte. Razón por la cual, la Sala no puede acceder a las pretensiones de los accionantes de ordenar su reincorporación inmediata al mismo cargo que venían desempeñando o a uno de mayor jerarquía, así como su afiliación a la red de aseguramiento IVM¹¹⁷ correspondiente, pues esta decisión vulneraría los derechos fundamentales de la señora Lucía Ximena Navarro Arias y el señor José Leonardo Bayona, quienes accedieron a las vacantes que dejaron los accionantes a través del concurso de méritos, e iría en contra de la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional que reconoce la carrera administrativa como el mecanismo preferente para el acceso y la gestión de empleos públicos.

117 Invalidez, vejez y muerte.

Por este motivo, la Sala considera que, únicamente en el evento de existir vacantes disponibles al momento de la notificación de la presente decisión judicial, o en caso tal de que existan vacantes futuras en provisionalidad, la Alcaldía de Ábrego debe nombrar a los señores Milciades Pérez Vergel y Carmen Alonso Pérez Vergel, a un cargo igual o equivalente al que ocupaban.

Como corolario de lo hasta aquí expuesto, la Sala Novena de Revisión revocará la decisión proferida en segunda instancia, mediante la cual se declaró la improcedencia de la acción de tutela, para en su lugar, amparar transitoriamente el derecho fundamental a la estabilidad laboral relativa de los actores, mientras se resuelven las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho por ellos radicadas, los días 13 de abril y 11 de junio de 2021, ante los jueces administrativos del circuito del Municipio de San José de Cúcuta, en contra de las resoluciones N° 699 y 701 del 15 de octubre de 2020, proferidas por la Alcaldía de Ábrego, -Norte de Santander-.

Así las cosas, la Sala procederá a ordenar a la Alcaldía de Ábrego que, en el término de quince (15) días, contados a partir de la notificación de esta decisión, -en el evento en el que existan vacantes disponibles o en el caso de que existan vacantes futuras en provisionalidad, - vincule a los actores a un cargo igual o equivalente al que ocupaban. Se precisa que, de vincularse nuevamente a los accionantes en las condiciones antes anotadas, su permanencia en provisionalidad, estará supeditada a que los cargos que lleguen a ocupar sean posteriormente provistos en propiedad mediante sistema de carrera. Lo anterior, siempre y cuando al momento de la vinculación se mantengan las condiciones especiales exigidas en la jurisprudencia constitucional que ameriten este trato preferencial, de acuerdo a lo desarrollado en la parte motiva de esta providencia.

Adicionalmente instará a la Alcaldía de Ábrego –Norte de Santander- a que, en adelante, antes de proceder con el nombramiento de la lista de elegibles, de quienes superan las etapas de los concursos de méritos que coordina, identifique con todo rigor, los cargos que están siendo ocupados por sujetos de especial protección constitucional y adopte en cabeza de estos empleados, las acciones afirmativas a que haya lugar, de conformidad con las reglas jurisprudenciales reiteradas en esta sentencia.

5. Síntesis de la decisión

En el presente caso se reiteró la regla jurisprudencial¹¹⁸ según la cual, en aquellos casos en los que surge, con fundamento en el principio del mérito,

118 Sentencias SU-446 de 2011, T-373 de 2017, T-464 de 2019, entre otras.

la obligación de nombrar de la lista de elegibles a la persona que superó las etapas del concurso, en un cargo de carrera ocupado en provisionalidad por un sujeto de especial protección como los padres o madres cabeza de familia, limitados físicos, psíquicos o sensoriales y pre pensionados, las entidades deben otorgar un trato preferencial antes de efectuar los respectivos nombramientos, mediante la adopción de medidas afirmativas en cabeza de dichos empleados, siendo estos los últimos en removerse, o de ser posible, en caso de existir la vacante, han de ser vinculados de nuevo en provisionalidad en un cargo similar o equivalente al que venían ocupando, siempre y cuando demuestren una de esas condiciones, para la época de su desvinculación.

En aplicación al citado parámetro, la Sala constató que la Alcaldía de Ábrego –Norte de Santander- no desplegó ninguna actuación destinada a adoptar acciones afirmativas a favor de los accionantes, en razón de las condiciones de vulnerabilidad¹¹⁹ que los convierten en sujetos de especial protección constitucional, antes de proceder con el nombramiento de la lista de elegibles, de quienes superaron las etapas del concurso 779 de 2018. Así las cosas, la Sala procede a amparar transitoriamente el derecho fundamental a la estabilidad laboral relativa o intermedia de los accionantes, mientras se resuelven las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho por ellos radicadas, los días 13 de abril y 11 de junio de 2021, en contra de las resoluciones N° 699 y 701 del 15 de octubre de 2020, proferidas por la Alcaldía de Ábrego, -Norte de Santander-.

En consecuencia, la Sala ordena a la entidad accionada, que, en el término de quince (15) días, contados a partir de la notificación de esta decisión, -en el evento en el que existan vacantes disponibles o en el caso de que existan vacantes futuras en provisionalidad, - vincule a los señores Milciades Pérez Vergel y Carmen Alonso Pérez Vergel a un cargo igual o equivalente al que ocupaban. Se precisa que, de vincularse nuevamente a los actores en las condiciones antes anotadas, su permanencia en provisionalidad, estará

119 Por un lado, el señor Milciades Pérez Vergel, es un adulto mayor, que a causa de las afectaciones que padece en su salud fue calificado con una pérdida de capacidad laboral del 51.12% y está afiliado al SISBEN en el grupo correspondiente a aquellos que se encuentran en extrema pobreza. Por otro lado, el señor Carmen Alonso Pérez Vergel, es también un adulto mayor, calificado con un 59% de pérdida de capacidad laboral debido a las patologías que padece, es padre cabeza de familia, y está afiliado al SISBEN en la categoría de personas vulnerables.

supeditada a que los cargos que lleguen a ocupar sean posteriormente provistos en propiedad mediante sistema de carrera. Lo anterior, siempre y cuando al momento de la vinculación se mantengan las condiciones especiales exigidas en la jurisprudencia constitucional que ameriten este trato preferencial, de acuerdo a lo desarrollado en la parte motiva de esta providencia.

Adicionalmente la Sala insta a la entidad accionada a que, en adelante, antes de proceder con el nombramiento de la lista de elegibles, de quienes superan las etapas de los concursos de méritos que coordina, identifique con todo rigor, los cargos que están siendo ocupados por sujetos de especial protección constitucional y adopte en cabeza de estos empleados, las acciones afirmativas a que haya lugar, de conformidad con las reglas jurisprudenciales reiteradas en esta sentencia.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,

RESUELVE:

PRIMERO. - REVOCAR la sentencia proferida en segunda instancia, el 31 de mayo de 2021 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Mixto de Conocimiento de Ocaña, mediante el cual se declaró la **IMPROCEDENCIA** de la acción de tutela presentada por los ciudadanos MILCIADES PÉREZ VERGEL Y CARMEN ALONSO PÉREZ VERGEL, en contra de la Alcaldía de Ábrego -Norte de Santander-, para en su lugar, **AMPARAR TRANSITORIAMENTE** el derecho fundamental a la estabilidad laboral relativa o intermedia de los accionantes, mientras se resuelven las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho por ellos radicadas ante los jueces administrativos del circuito del Municipio de San José de Cúcuta, los días 13 de abril y 11 de junio de 2021, en contra de las Resoluciones N° 699 y 701 del 15 de octubre de 2020, proferidas por la Alcaldía de Ábrego, -Norte de Santander-.

SEGUNDO. – ORDENAR a la Alcaldía de Ábrego –Norte de Santander- que, en el término de quince (15) días, contados a partir de la notificación de esta decisión, -en el evento en el que existan vacantes disponibles o en el caso de que existan vacantes futuras en provisionalidad, - vincule a los ciudadanos MILCIADES PÉREZ VERGEL Y CARMEN ALONSO PÉREZ VERGEL a un cargo igual o equivalente al que ocupaban antes de ser retirados mediante las Resoluciones N° 699 y 701 del 15 de octubre de 2020.

Se precisa que, de vincularse nuevamente a los actores en las condiciones antes anotadas, su permanencia en provisionalidad estará supeditada a que los cargos que lleguen a ocupar sean posteriormente provistos en propiedad mediante sistema de carrera. Lo anterior, siempre y cuando, al momento de la vinculación se mantengan las condiciones especiales exigidas en la jurisprudencia constitucional que ameriten este trato preferencial, de acuerdo a lo desarrollado en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO. - INSTAR a la Alcaldía de Ábrego -Norte de Santander-, a que, en adelante, antes de proceder con el nombramiento de la lista de elegibles, de quienes superan las etapas de los concursos de méritos que coordina, identifique con todo rigor, los cargos que están siendo ocupados por sujetos de especial protección constitucional y adopte en cabeza de estos empleados, las acciones afirmativas a que haya lugar, de conformidad con las reglas jurisprudenciales reiteradas en esta sentencia.

CUARTO. –Por Secretaría General de esta Corporación **LÍBRENSE** las comunicaciones previstas en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase

ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado

DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR
Magistrado

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General

TEMAS-SUBTEMAS

Sentencia T-421/24

DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL INTERMEDIA-Deber de mantener la vinculación permanente al Sistema de Seguridad Social en Salud de las personas en estado de debilidad manifiesta que ocupan cargos en provisionalidad

(...) frente a las personas que cuentan con una especial situación de salud cobra relevancia mantener una vinculación permanente al Sistema de Seguridad Social en Salud que les permita acceder a los controles y seguimientos necesarios para contar con diagnósticos oportunos y eficaces.

PERSONA EN CIRCUNSTANCIAS DE DEBILIDAD MANIFIESTA-Protección especial en materia laboral

ENFERMEDAD CATASTROFICA O RUINOSA-Protección constitucional reforzada de personas con cáncer

PREPENSIONADO-Sujeto de especial protección

DESVINCULACION EN CARGO DE CARRERA EN PROVISIONALIDAD-Procedencia de tutela cuando afecta derechos fundamentales

CARRERA ADMINISTRATIVA-Acceso mediante concurso público de méritos

EMPLEADO NOMBRADO EN PROVISIONALIDAD EN CARGO DE CARRERA ADMINISTRATIVA-Goza de estabilidad relativa o intermedia

PROVISION DE CARGOS DE LA LISTA DE ELEGIBLES PREVIO CONCURSO DE MERITOS Y LA PROTECCION ESPECIAL DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD, MADRES Y PADRES CABEZA DE FAMILIA Y PREPENSIONADOS-Reiteración de jurisprudencia

DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL INTERMEDIA-Deber de motivar el acto de desvinculación de sujetos de especial protección constitucional que ocupan cargos en provisionalidad

DERECHO A LA REUBICACION LABORAL-Criterios constitucionales para su viabilidad

REGIMEN PENSIONAL DE DOCENTES-Regulación

DERECHO A LA SALUD-Tratamiento para el cáncer de seno

REPÚBLICA DE COLOMBIA



CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Tercera de Revisión

Sentencia T-421 de 2024

Referencia: expedientes T-10.121.578 y T-10.153.714.

Acción de tutela instaurada por (i) *Lorena* contra la Secretaría de Educación del municipio de Florencia, Caquetá, y (ii) *Adriana* contra la Secretaría de Educación y Cultura de Apartadó, Antioquia.

Magistrada ponente:

Diana Fajardo Rivera

Bogotá, D.C., cuatro (04) de octubre dos mil veinticuatro (2024)

La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Diana Fajardo Rivera, quien la preside, y por los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y Vladimir Fernández Andrade, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política y en el Decreto Ley 2591 de 1991, profiere la siguiente

SENTENCIA

En el trámite de revisión de los fallos de tutela emitidos en los expedientes T-10.121.578, en segunda instancia y T-10.153.714, en primera instancia.

ACLARACIÓN PREVIA

En atención a que en la presente sentencia se expone información relacionada con la historia clínica y la salud física o psíquica de varias personas, en la versión de esta providencia disponible para el público el nombre de los accionantes será reemplazado por uno ficticio que se escribirá en letra cursiva¹. La versión con sus datos de identificación solo estará destinada a integrarse al

¹ En cumplimiento de la Circular Interna n.º 10 de 2020 de la Corte Constitucional, por medio del cual se establece que “se deberán omitir de las providencias que se publican en la página web de la Corte Constitucional los nombres reales de las personas en los siguientes casos: a) Cuando se haga referencia a su historia clínica u otra información relativa a la salud física o psíquica. b) Cuando se trate de niñas, niños o adolescentes, salvo aquellos datos de naturaleza pública. c) Cuando se pueda poner en riesgo el derecho a la vida e integridad personal o el derecho a la intimidad personal y familiar”. (Subrayado fuera del texto original).

expediente de tutela, para que los responsables de dar cumplimiento a las órdenes impartidas ejecuten las decisiones proferidas dentro del fallo.

SÍNTESIS DE LA DECISIÓN

La Sala Tercera de Revisión estudió el caso de *Lorena y Adriana*. Dos docentes vinculadas a instituciones educativas públicas bajo la figura de la provisionalidad quienes, interpusieron acción de tutela contra las secretarías de Educación de los municipios de Florencia y Apartadó, respectivamente, alegando la vulneración de sus derechos fundamentales a la vida, al trabajo, a la salud, la igualdad de oportunidad, a la no discriminación, la remuneración mínima vital y móvil y a la estabilidad laboral relativa.

Esto, en atención a que las entidades en las que estaban vinculadas finalizaron sus nombramientos en provisionalidad debido que tenían que nombrar en sus empleos a personas que habían ganado dichas plazas mediante concurso público de méritos. En ambos casos, al momento de su desvinculación las accionantes tenían acreditadas dificultades de salud importantes, asociadas al hecho de ser sobrevivientes de cáncer. A su vez, *Adriana* también adujo tener la calidad de pre pensionada.

Para analizar su situación, la Sala se refirió a (i) los concursos de méritos para el acceso a empleos públicos; (ii) la estabilidad laboral relativa de los docentes nombrados en provisionalidad y la protección especial derivada de una situación de debilidad manifiesta por razones de salud y por la calidad de pre pensionados; (iii) el régimen pensional general de los docentes de colegios públicos y (iv) el cáncer y los sobrevivientes de cáncer como sujetos a los que se les debe garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud.

Con base en estos elementos, al analizar el caso concreto, la Sala concluyó que ninguna de las secretarías accionadas desconoció los derechos de las accionantes por cuanto ambas acreditaron haber adelantado acciones para atender a su situación. En efecto, las dos Secretarías priorizaron los casos de *Lorena y Adriana* y las incluyeron en un listado de espera con el fin de vincularlas cuando se presente una nueva vacante. Además, en el caso de

Lorena dos años atrás ya se había hecho un traslado hacía otra vacante, y en el de *Adriana*, en sede de revisión también se le ofreció esta posibilidad. Por otra parte, la Sala concluyó que no contaba con elementos suficientes para determinar la calidad de pre pensionada de *Adriana*.

Finalmente, y dada la necesidad de que las dos accionantes contaran con una continuidad en el control y seguimiento a las patologías que les fueron diagnosticadas, la Sala ordenó que se les mantuviera en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, ya sea en el régimen contributivo o en el subsidiado. En ese sentido se ordenó al Ministerio de Educación Nacional establecer algún mecanismo que permita garantizar la continuidad en el Sistema de Seguridad Social en Salud de las docentes a quienes se les finaliza el vínculo mientras se encuentran en una situación de debilidad manifiesta por razones de salud.

I. ANTECEDENTES

1. *Expediente T-10.121.578*

a) Hechos jurídicamente relevantes

§1. *Lorena* actualmente tiene 51 años² y vive junto con su compañera sentimental y su padrastro de 81 años, de quienes es responsable económicamente³. Ingresó en julio de 2015 como docente de aula nombrada

² Según su documento de identidad, *Lorena* nació el 28 de febrero de 1973. Expediente digital T-10.121.578. Archivo “03Anexos”.

³ Expediente digital T-10.121.578. Archivo “Material probatorio y anexos”, p. 1.

en provisionalidad⁴ a la institución educativa “*El Salitre rural*” y trabajó allí hasta enero de 2021. Luego, en este mismo mes, con motivo en la estabilidad laboral relativa que le fue reconocida por la Secretaría de Educación de Florencia tras haber sido diagnosticada en el año 2017 de un cáncer de endometrio, fue trasladada a la institución educativa Técnico Industrial de esta misma ciudad. En diciembre de 2023 se le notificó que en su empleo se vincularía a otra persona que había ganado un concurso de méritos; por lo cual, interpuso una acción de tutela contra la citada Secretaria alegando un fuero por su salud. Durante el tiempo que la accionante estuvo vinculada con la Secretaría de Educación de Florencia, estuvo afiliada a la la EPS FAMAC. A continuación, el detalle de los hechos.

§2. El 7 de julio de 2017⁵, *Lorena* fue diagnosticada con tumor maligno de endometrio. Como consecuencia, se le realizó una histerectomía total y una cirugía re clasificatoria laparoscópica en mayo y septiembre de 2017, respectivamente⁶.

§3. Luego, el 15 de enero de 2019, la accionante fue intervenida quirúrgicamente exitosamente de un tumor benigno en el glúteo izquierdo⁷.

§4. Posteriormente, el 26 de abril de 2019 el médico especialista le ordenó a la accionante una mamografía de los dos senos, la cual fue realizada el 31 de julio de 2020⁸. Después, se le practicó de nuevo este examen el 24 de febrero de 2021 en el que se detectó una masa en el seno derecho⁹. El 24 de abril de 2021, acudió al médico especialista con los exámenes realizados y este ordenó

⁴ *Ibidem*. p. 2. Nombrada en provisionalidad en el Decreto 0610 del 10 de julio de 2015, en el cargo de docente de aula como normalista superior con énfasis en ciencias sociales.

⁵ Expediente digital T-10.121.578. Archivo “03Anexos.pdf”, p. 9. Informe patológico del Instituto Nacional de Cancerología, con fecha del 7 de julio de 2017.

⁶ Expediente digital T-10.121.578. Archivo “Respuesta auto de pruebas-Lorena.pdf”, p. 63.

⁷ Expediente digital T-10.121.578. Archivo “024 Rta. FAMAC LTDA.pdf”, pp. 158-159. Reporte de Corpomedica del Caquetá en el que hace referencia a la cirugía de quiste sebáceo en glúteo izquierdo.

⁸ Expediente digital T-10.121.578. Archivo “024 Rta. FAMAC LTDA.pdf”, pp. 154. Examen médico de mamografía ordenado por el centro oncológico de la Liga contra el Cáncer Seccional Huila.

⁹ Expediente digital T-10.121.578. Archivo “024 Rta. FAMAC LTDA.pdf”, p. 173.

continuar en seguimiento y acudir a cita de control en 3 meses con ecografía abdominal¹⁰.

§5. El 19 de noviembre de 2021 fue intervenida quirúrgicamente de dos lesiones tumorales des aspecto nevico¹¹ en su mentón y nariz¹².

§6. El 4 de mayo de 2023, *Lorena* asistió a sus citas periódicas con el especialista en oncología en la Liga contra el Cáncer Seccional Neiva. En la lectura de la radiografía, el especialista le diagnosticó la existencia de un nódulo mediastinal, al cual se le debía hacer seguimiento¹³.

§7. Posteriormente, el 23 de febrero de 2024¹⁴ se le realizó una ecografía de tejidos blandos en la axila izquierda. En los resultados de dicho examen, se indica que *Lorena* tiene unas “adenopatías de aspecto inflamatorio”.

§8. Por otra parte, la vacante que la accionante ocupaba en la institución educativa “*El Salitre*”, fue ofertada a través de concurso de méritos. Por tal razón, la Secretaría de Educación de Florencia mediante el Decreto 0009 del 19 de enero de 2021¹⁵ decidió trasladar a la accionante a la institución educativa Técnico Industrial (Sede la libertad), ubicada en el municipio de

¹⁰ Expediente digital T-10.121.578. Archivo “024 Rta. FAMAC LTDA.pdf”, p. 5.

¹¹ Según la Clínica de la Universidad de Navarra un “nevus” corresponde a un lunar, esto es, a “una formación cutánea que resulta de la proliferación de uno o más tipos de células de la piel. (En línea). Disponible en: <https://www.cun.es/diccionario-medico/terminos/nevus>. 2023.

¹² Expediente digital T-10.121.578. Archivo “Respuesta auto de pruebas-Lorena.pdf”. p. 69.

¹³ Expediente digital T-10.121.578. Archivo: “*Lorena*. TOMO 1. 300817640066”, p. 205. En este documento se indicó: “Paciente con antecedente de adenocarcinoma endometrial estado IA tratamiento hace 6 años, sin signos de recurrencia loco regional. Imágenes control informan nódulo mediastinal a caracterizar mediante tomografía. Asociados síndrome urogenital que afecta calidad de vida”.

¹⁴ Expediente digital T-10.121.578. Archivo “Respuesta auto de pruebas-Lorena.pdf”, p. 12.

¹⁵ Expediente digital T-10.121.578. Archivo “03Anexos.pdf”, pp. 26-27. Esta resolución tiene por epígrafe “*Por medio de la cual se traslada una docente por reten social*”. En la parte motiva no se hace referencia a que el traslado se debe a la condición de salud de *Lorena*, pero en todo caso se da la orden expresa de realizar el traslado.

Florencia, con la finalidad de garantizarle la estabilidad laboral por motivo de enfermedad catastrófica.

§9. Sin embargo, la vacante que ocupó la accionante en la institución educativa Técnico Industrial (Sede la libertad) también había sido incluida en un concurso de méritos. Concretamente, en el concurso del posconflicto, adelantado a través del proceso de selección n.º 2198 de 2021 que quedó en firme en noviembre de 2023¹⁶.

§10. En consecuencia, el 1º de diciembre de 2023 la Secretaría de Educación de Florencia emitió el Decreto 009000 de 2023¹⁷ en el que nombró en periodo de prueba al señor Duberney Trujillo Osorio en el cargo que *Lorena* ocupaba en provisionalidad. Esto, en atención a que el señor Duberney fue elegido para ocupar el empleo denominado “docente de primaria” en la institución educativa Técnico Industrial (Sede la libertad).

§11. En este mismo acto administrativo se dio por terminado el nombramiento en provisionalidad de *Lorena*.

b) La acción de tutela y las contestaciones de las accionadas

§12. *Acción de tutela*¹⁸. El 22 de enero de 2024 *Lorena* presentó acción de tutela, en nombre propio, en contra de la Secretaría de Educación de Florencia solicitando que se protegieran sus derechos fundamentales a la vida, al trabajo, a la salud, la igualdad de oportunidades, a la no discriminación, la remuneración mínima vital y móvil y a la estabilidad laboral relativa y, en consecuencia (i) ser reintegrada a su trabajo como docente de básica primaria adscrita a la Secretaría de Educación de Florencia, al igual que sucedió con el docente Rosemver Osorio Rodríguez¹⁹ y (ii) que el juez permitiera que su caso pudiese contar con el seguimiento de diferentes instituciones como la

¹⁶ Expediente digital T-10.121.578. Archivo “11ContestacionAccionada.pdf”.

¹⁷ “Por medio del cual se hace nombramiento en periodo de prueba en la planta de cargos de la Secretaría de Educación Municipal de Florencia y se dictan otras disposiciones”. Expediente digital T-10.121.578. Archivo: “03Anexos.pdf”, pp. 29-39.

¹⁸ Expediente digital T-10.121.578. Archivo “02Accion Tutela.pdf”, p. 4.

Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Personería de Florencia Caquetá, la Federación Colombiana de Educadores - Fecode, la Central Unitaria de Trabajadores CUT, entre otras.

§13. La acción de tutela fue contestada por la Secretaría de Educación de Florencia.

§14. *Contestación de la Secretaría de Educación de Florencia*²⁰. El 25 de enero de 2024, solicitó que esta fuera negada. Argumentó que la finalización del nombramiento provisional de la accionante fue justificada, ya que se procedió a nombrar en período de prueba a la persona que superó el concurso de méritos docente. También indicó que tiene el deber legal de respetar el derecho al mérito de cada uno de los elegibles que están en la lista, realizando los nombramientos en las vacantes temporales de acuerdo al puntaje obtenido.

§15. La entidad accionada destacó que ha implementado acciones afirmativas para asegurar la protección especial de la accionante. En una oportunidad, ordenó su traslado al Instituto Técnico Industrial, sede “La Libertad” en el municipio de Florencia, debido a su condición de salud. Asimismo, advirtió que estableció el Comité Técnico de Estabilidad Laboral Reforzada como medida de protección para las personas en situación de vulnerabilidad manifiesta y que ha seguido las directrices del Ministerio de Educación Nacional para proteger a los docentes provisionales que gozan de una protección relativa. En este marco, la accionante forma parte de una lista de protección especial que se consideraría por la entidad para futuras vinculaciones una vez se agote la lista de elegibles. Sin embargo, menciona que no le fue posible trasladar a la docente a otra institución educativa debido a que todas las vacantes urbanas estaban ocupadas por nombramientos en período de prueba y listas de elegibles. Además, señaló que el traslado a una

¹⁹ La pretensión puntual de la accionante es la siguiente: “Solicitar la aplicación de RETÉN SOCIAL Y ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA, con favorecimiento del PRINCIPIO DE IGUALDAD, como al docente ROSEMVER OSORIO RODRIGUEZ, acogido por RETÉN SOCIAL y protección de la ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA a causa de ENFERMEDAD CATASTRÓFICA, de la Institución Educativa José Antonio Galán de Florencia. Según fallo con número de radicado 2021-0065- 00 del 01 de marzo de 2021, proferido por el Juzgado Segundo de Familia”.

²⁰ Expediente digital T-10.121.578. Archivo “11ContestacionAccionada.pdf”.

zona rural tampoco era viable, ya que no había vacantes disponibles en el área de primaria – en la que se desempeña la docente- en dichas zonas²¹.

§16. Por su parte, el señor Duberney Trujillo Osorio, quien fue el docente nombrado en el cargo que era ocupado en provisionalidad por la accionante, no se pronunció.

c) Las decisiones de instancia en el proceso de tutela

§17. *Sentencia de tutela de primera instancia*²². En sentencia del 1 de febrero de 2024, el Juzgado Segundo Penal Municipal de Florencia Caquetá decidió negar el amparo de los derechos fundamentales de *Lorena*. En primer lugar, indicó que el asunto debía ser resuelto por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través del medio de control de la nulidad y restablecimiento del derecho. En segundo lugar, resaltó que la estabilidad laboral que solicita la accionante es de carácter relativo, por lo que, es válido que se haya terminado su nombramiento en provisionalidad para posesionar en periodo de prueba al elegible seleccionado a través de concurso de méritos en el cargo que ocupaba la accionante.

§18. *Impugnación*²³. La accionante presentó escrito en el que argumentó que en su caso la acción de tutela procede como mecanismo judicial transitorio. Afirmó que en la sentencia de primera instancia no se tuvo en cuenta que su condición de salud es crónica, ya que asiste a tratamientos oncológicos, exámenes y controles cada mes, los cuales son garantizados a través de la EPS FAMAC, y mencionó que al ser despedida del cargo como docente perdió los derechos y beneficios que tenía al estar afiliada a la mencionada EPS. Por lo anterior, considera que su vida está en riesgo inminente al dejar de recibir la atención médica especializada que requiere, lo que puede ocasionar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

²¹ *Ibidem*.

²² Se destaca que, en auto del 22 de enero de 2024, el Juzgado Segundo Penal Municipal de Florencia, Caquetá, admitió la acción de tutela interpuesta por *Lorena* en contra de la Secretaría de Educación de Florencia. A su vez, integró al contradictorio al señor Duberney Trujillo Osorio quien fue el docente nombrado en propiedad por concurso de méritos en el cargo que era ocupado por la accionante. Expediente digital T-10.121.578. Archivo “14Fallo.pdf”.

²³ Expediente digital T-10.121.578. Archivo “17EscritoImpugnacion.pdf”.

§19. *Sentencia de segunda instancia*²⁴. En Sentencia del 7 de marzo de 2024, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Florencia Caquetá confirmó la decisión de primera instancia. Manifestó que la acción de tutela es improcedente pues no se satisface el requisito de subsidiariedad. En su criterio, si bien se encuentra probado que la accionante padece de una enfermedad catastrófica, no concurren otras situaciones particulares para que proceda el amparo. Por ende, en el caso en concreto no hay un perjuicio irremediable, por lo que, la accionante debe acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo²⁵.

§20. A su vez señaló que, en caso de que en el presente caso la acción de tutela fuera procedente, se debe hacer una ponderación entre (i) la estabilidad laboral relativa que goza la accionante como docente nombrada en provisionalidad y (ii) el derecho del señor Duberney Trujillo al trabajo y la meritocracia, pues fue nombrado en periodo de prueba a través de un concurso público de méritos; tensión que, en todo caso, conforme a la jurisprudencia²⁶ de la Corte Constitucional ha sido resuelta a favor del segundo grupo de derechos.

2. Expediente T-10.153.714²⁷

a) Hechos jurídicamente relevantes

§21. *Adriana* actualmente tiene 53 años, afirma ser madre cabeza de familia, al ser responsable económicamente de su hija y su nieto menores de edad, así como de su hija mayor de edad²⁸. Señaló que se desempeñó como docente en

²⁴ Expediente digital T-10.121.578. Archivo “02Sentencia2daInstancia.pdf”.

²⁵ *Ibidem*.

²⁶ Sentencias T-326 de 2014. MP. María Victoria Calle y T-464 de 2019. M.P. Antonio José Lizarazo.

²⁷ Expediente digital T-10.153.714. Archivo “002 EscritoDemanda.pdf”.

²⁸ *Adriana* refiere que su hija mayor de edad depende económicamente de ella pues no ha encontrado un trabajo flexible que le permita cuidar de su hijo, su hermana menor (es decir, la otra hija de *Adriana*) y de la propia *Adriana*. Expediente digital T-10.153.714. Archivo “002 EscritoDemanda.pdf”, p. 2.

provisionalidad en la Institución Educativa Campo Alegre²⁹ perteneciente a la Secretaría de Educación de Apartadó desde abril de 2011 hasta enero de 2024 cuando se le notificó que el cargo que estaba ocupando sería asignado a una persona que había ganado un concurso de méritos. Sin embargo, afirma que ha trabajado en instituciones educativas públicas desde hace 32 años; además de que, en abril de 2022 se le diagnosticó un cáncer de seno por el que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente y someterse a radioterapias. Por ello, interpuso acción de tutela contra la Secretaría de Educación de Apartadó con el fin de que se le garantice su estabilidad laboral relativa por tener un doble fuero, dada su situación de salud y su calidad de pre pensionada. A continuación, el detalle de los hechos.

§22. En el mes de abril de 2022³⁰, *Adriana* fue diagnosticada con cáncer de seno.

§23. Luego, el 4 de enero de 2023, a la accionante se le realizó el procedimiento quirúrgico “mastectomía simple unilateral y vaciamiento radial linfático axilar vía abierta”³¹.

§24. Posterior a ello fue sometida a tratamiento con radioterapia. A raíz de esto, estuvo incapacitada desde el 5 de mayo de 2022 hasta el 18 de mayo de 2023³², de manera continua. A partir de la fecha del diagnóstico ha estado en seguimiento con especialistas y le fueron realizadas unas sesiones de quimioterapia.

§25. Actualmente, se encuentra bajo tratamiento con el especialista en oncología, el especialista del dolor y el médico internista con seguimiento

²⁹ *Ibidem*, p. 1. Nombrada en provisionalidad mediante el Decreto n.º 064 del 01 de abril del 2011 en la plaza vacante definitiva de nivel secundaria, área humanidades y lengua castellana.

³⁰ Expediente digital T-10.153.714. Archivo “008 Rta.*Adriana*.pdf.”, pp. 55-56. Historia clínica de Sumimedical del 11 de abril de 2022 en el que se diagnostica con cáncer de seno a la accionante.

³¹ *Ibidem*, pp. 99-102.

³² Expediente digital T-10.153.714. Archivo “02Accion Tutela.pdf”, pp. 175-189. La accionante adjuntó soporte de las incapacidades generadas en ese periodo de tiempo, en total 15 incapacidades las cuales inician el 5 de mayo de 2022 y finalizan el 18 de mayo de 2023.

periódico cada tres meses. También padece de obesidad grado III y enfermedad varicosa³³.

§26. *Adriana* sostiene que cumple con los requisitos para ser considerada prepensionada conforme a lo estipulado en el artículo 1³⁴ de la Ley 33 de 1985³⁵, dado que ha trabajado desde el año 1992, contando con más de 32 años de servicio en el sector público educativo³⁶.

§27. La solicitante señala que la Secretaría de Educación y Cultura de Apartadó conocía de su condición de salud, ya que ella se lo había informado a esta entidad a través de varias comunicaciones³⁷.

§28. A pesar de lo anterior, el 15 de enero de 2024 mediante Decreto 134³⁸ la entidad le notificó la finalización de su nombramiento, por cuenta de la designación en periodo de prueba de la persona que resultó elegida en el concurso de méritos que se realizó para cubrir en propiedad el cargo que se encontraba ocupando en provisionalidad en la institución educativa Campo Alegre.

§29. Posteriormente, el 17 de abril de 2024 mediante el Decreto 647³⁹ la Secretaría de Educación y Cultura de Apartadó nombró nuevamente en provisionalidad a la accionante en una vacante en la institución educativa rural

³³ Expediente digital T-10.153.714. Archivo “Respuesta IPS Sumimedical”.

³⁴ “Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el Sector Público”.

³⁵ “**Artículo 1.** El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio”.

³⁶ Expediente digital T-10.153.714. Archivo “002 EscritoDemanda.pdf”, p.1.

³⁷ Expediente digital T-10.153.714. Archivo “002 EscritoDemanda.pdf”, pp. 198 y 199. Derecho de petición presentado el 6 de julio de 2023 por *Adriana* comunicando su estado de salud y solicitando el reconocimiento de estabilidad laboral reforzada.

³⁸ Expediente digital T-10.153.714. Archivo “002 EscritoDemanda.pdf”, pp. 204 - 207.

³⁹ Expediente digital T-10.153.714. Archivo “Anexos 2”, p. 26.

“*Bartolomé Castaño Vallejo-Cer Playa Larga*” por el periodo de duración de la incapacidad por enfermedad común de la docente que actualmente ocupa esa plaza en propiedad. La accionante señaló que dicha institución se ubica en una zona de difícil acceso y a una hora aproximadamente del casco urbano, incumpliendo con las condiciones que se deben tener en cuenta acorde a su estado de salud y a las recomendaciones suscritas por la EPS Sumimedical⁴⁰.

b) La acción de tutela y las contestaciones de las accionadas

§30. *Acción de tutela*. El 19 de enero de 2024⁴¹, *Adriana* presentó acción de tutela, en nombre propio, contra la Secretaría de Educación y Cultura del municipio de Apartadó (Antioquia) con el objeto de solicitar (i) la protección de sus derechos fundamentales a la salud, a la estabilidad laboral reforzada, al trabajo, a la dignidad y a la vida; (ii) el reintegro a su puesto de trabajo o a otro en las mismas condiciones y (iii) que se ordene a la Secretaría de Educación de Apartadó al pago de los salarios dejados de percibir durante todo el tiempo que estuvo vinculada⁴². En su criterio, estos derechos fueron vulnerados por la accionada al dar por terminado su nombramiento en provisionalidad en virtud de la vinculación en propiedad de un elegible del concurso de méritos sin tener presente que ella cuenta estabilidad laboral reforzada derivada de (a) su fuero de salud, tras haber sido diagnosticada con cáncer de seno y en atención a (b) su calidad de pre pensionada.

§31. *Contestación de la Secretaría de Educación y Cultura de Apartadó, Antioquia*⁴³. Se opuso a las pretensiones de la demanda. Indicó que la finalización del nombramiento en provisionalidad se encuentra justificada, pues obedeció a la necesidad de nombrar en periodo de prueba en el cargo que ocupaba la accionante a la persona que había superado el concurso de méritos⁴⁴. Señaló que no había incapacidad vigente al momento de la

⁴⁰ Expediente digital T-10.153.714. Archivo “002 EscritoDemanda.pdf”, p. 200.

⁴¹ Expediente digital T-10.153.714. Archivo “001 RecepcionTutela .pdf”.

⁴² Expediente digital T-10.153.714. Archivo “002 EscritoDemanda.pdf”, p. 2.

⁴³ Expediente digital T-10.153.714. Archivo “005 ContestaAlcaldiaApartado.pdf”.

⁴⁴ *Ibidem*. p. 3. Proceso de Selección No. 2187 de 2021 — Directivos Docentes y Docentes.

desvinculación y que la condición médica de la accionante le permitía laborar sin contraindicaciones significativas⁴⁵.

§32. También se refirió a que la accionante tiene un tiempo de vinculación en el servicio público educativo de 12 años, 9 meses y 15 días⁴⁶ y no de 32 años, como se menciona en el escrito de tutela. En ese sentido, explicó que la accionante no cumple con la calidad de prepensionada porque no acredita ni la edad ni el número de semanas requerido. Así mismo, sostuvo que al estar vinculada desde el 2011, a *Adriana* le es aplicable el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 en el que se define en 57 años la edad de pensión; pero en la actualidad, la accionante tiene 53 años. Además, indicó que a la accionante le faltan aproximadamente 340 semanas de cotización, por lo que no acreditan los requisitos para cumplir con la calidad de prepensionada⁴⁷.

§33. *Respuesta del Ministerio de Educación Nacional*⁴⁸. Explicó que la competencia para decidir sobre estos asuntos la tienen las entidades territoriales ya que es su responsabilidad administrar el servicio público educativo conforme a la Ley 715 de 2001⁴⁹. También mencionó que no tiene competencia sobre los nombramientos realizados, los cuales deben ser reportados a la Comisión Nacional del Servicio Civil. Por tal razón, adujo que carece de legitimación en la causa por pasiva y solicitó su desvinculación.

⁴⁵ *Ibidem*. p. 7. En la incapacidad se menciona que la docente puede reintegrarse a sus labores.

⁴⁶ La Secretaría de Educación de Apartadó se refirió al formato único para la expedición de certificado de historia laboral consecutivo n.º 58, expedido por el área de talento Humano de esta entidad. La accionante fue vinculada en provisionalidad a la planta a partir del 1 de abril de 2011, por lo tanto, regía lo estipulado en el Decreto Ley 1278 de 2002.

⁴⁷ Expediente digital T-10.153.714. Archivo “005 ContestaAlcaldiaApartado.pdf”, pp. 95-96.

⁴⁸ Expediente digital T-10.153.714. Archivo “006 ContestaMinisteriodeEducacion.pdf”.

⁴⁹ “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros”.

§34. *Respuesta de Fiduprevisora (FOMAG⁵⁰)*. Refirió que no existe ninguna conducta activa u omisiva que derive en la supuesta afectación de los derechos fundamentales de la accionante; por lo que, no está llamada a resolver los conflictos que surjan de la vinculación entre los docentes y las Secretarías de Educación⁵¹.

§35. *Respuesta de Nubia Cecilia Prestán⁵²*. Nubia Cecilia Prestan Pérez indicó que fue designada como docente en la Institución Educativa Campo Alegre luego de superar el respectivo concurso de méritos realizado por la Comisión Nacional del Servicio Civil⁵³. Informó que ocupó el puesto 15 de 16 vacantes disponibles para el cargo ofertado, por lo que, recibió citación de audiencia pública para la escogencia de la vacante en establecimiento educativo rural y no rural conforme a la Resolución 10591 de 2023. Por último, señaló que el concurso fue realizado conforme al marco legal colombiano y que en ningún momento vulneró los derechos fundamentales de la accionante, pues ella participó y quedó elegida en un concurso de méritos por lo que fue nombrada en el cargo.

§36. La IPS Sumimedical S.A.S no brindó respuesta.

c) Las decisiones de instancia en el proceso de tutela

§37. *Trámite de la acción de tutela*. El trámite le correspondió por reparto al Juzgado Segundo Civil Municipal de Apartadó (Antioquia) que profirió sentencia el **1 de febrero de 2024** en la que declaró improcedente la acción de tutela⁵⁴. La accionante impugnó la decisión⁵⁵.

⁵⁰ Fiduprevisora S.A., actúa como vocera y administradora de Patrimonio Autónomo – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).

⁵¹ Expediente digital T-10.153.714. Archivo “011 ContestaFiduPrevisora.pdf”.

⁵² Expediente digital T-10.153.714. Archivo “005 Contesta Nubia vinculada.pdf”.

⁵³ Ibidem, p. 3. Proceso de Selección n.º 2150 a 2237 de 2021, 2316 y 2406 de 2022 - Directivos Docentes y Docentes

⁵⁴ Expediente digital T-10.153.714. Archivo “009 FalloTutela-Improcedente.pdf”.

⁵⁵ Expediente digital T-10.153.714. Archivo “012 ImpugnaAccionante.pdf”.

§38. *Auto que decreta nulidad*. En el trámite de impugnación, el 5 de marzo de 2024 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Apartadó (Antioquia) decretó la nulidad de lo actuado a partir del auto que admitió la acción de tutela en primera instancia y ordenó vincular a Nubia Cecilia Prestán Pérez, quien fue elegida y nombrada en propiedad a través de concurso público de méritos n.º 2187 de 2021 en la vacante que la accionante ocupaba en provisionalidad. Por tal razón, remitió al juzgado de primera instancia para que procediera de conformidad⁵⁶.

§39. *Sentencia de primera instancia*⁵⁷. En sentencia del **15 de marzo de 2024**, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Apartadó decidió declarar improcedente la acción de tutela. Argumentó que no se cumplió con el requisito de subsidiariedad pues la accionante debe acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y presentar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para solicitar la protección de sus derechos fundamentales. A su vez consideró que no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable en razón a (i) su salud, pues en la historia clínica en cita de control por Oncología del 19 de abril de 2023, el médico consideró que se podía “reintegrar a sus labores docentes sin contraindicación, evitar esfuerzos mayores con el brazo izquierdo”, es decir, para ese momento ya se había superado la enfermedad; y (ii) dado que la accionante no cumple con las semanas de cotización para ser considerada pre pensionada⁵⁸.

3. Trámite de selección y actuaciones en sede de revisión comunes a ambos procesos acumulados

§40. *Selección de las acciones de tutela*. Mediante Auto del 24 de mayo de 2024, la Sala de Selección de Tutelas Número Cinco de 2024 de la Corte Constitucional⁵⁹ seleccionó y acumuló para su revisión los expedientes

⁵⁶ Expediente digital T-10.153.714. Archivo “002 DecretaNulidad.pdf”.

⁵⁷ Expediente digital T-10.153.714. Archivo “009 FalloTutela-Improcedente.pdf”.

⁵⁸ *Ibidem*, p. 14.

⁵⁹ La Sala de Selección Número Cinco de 2024 estuvo conformada por los Cristina Pardo Schlesinger y José Fernando Reyes Cuartas.

T-10.121.578 y T-10.153.714. Ambos expedientes fueron repartidos al despacho de la magistrada Diana Fajardo Rivera para su sustanciación⁶⁰.

§41. *Auto de pruebas*. El 15 de julio de 2024, la magistrada sustanciadora profirió un auto de pruebas⁶¹. Posteriormente, mediante Auto del 23 de julio de 2024 se solicitó información relacionada con el expediente T-10.121.578. En concreto, se pidió al Fondo Asistencial del Magisterio del Caquetá (FAMAC) que informara el estado de afiliación de la accionante y remitiera la historia clínica de *Lorena*.

3.1 Respuestas en el Expediente T-10.121.578

§42. Se recibieron respuestas de parte de la Secretaría de Educación de Florencia, el Fondo Asistencial del Magisterio del Caquetá y la accionante *Lorena*.

§43. *Secretaría de Educación de Florencia*⁶². El **19 de julio de 2024**, indicó que ha realizado acciones afirmativas tendientes a garantizar la protección especial y la estabilidad laboral relativa como docente en provisionalidad. A través del Decreto No. 0008 del 19 de enero de 2021, ordenó trasladar a *Lorena* a la institución educativa ‘Instituto Técnico Industrial’⁶³. También

⁶⁰ Los criterios de selección fueron la urgencia de proteger un derecho fundamental (criterio subjetivo) y la posible violación o desconocimiento del precedente constitucional (criterio objetivo).

⁶¹ Este auto de pruebas tuvo por finalidad recaudar información sobre (i) la situación de salud, económica y familiar de los accionantes, así como (ii) las circunstancias en las cuales se había dado la finalización del nombramiento en provisionalidad de las accionantes por parte de las entidades territoriales (Secretaría de Educación de Florencia, Caquetá y Secretaría de Educación y Cultura de Apartadó, Antioquia) y (iii) la información que pudiese tener el Ministerio de Educación Nacional respecto a los docentes nombrados en provisionalidad que puedan ser sujetos de especial protección.

⁶² Expediente digital T-10.121.578. Archivo “Respuesta Secretaría de Educación de Florencia”.

⁶³ Dicha orden de traslado se fundamentó en que en el año 2015 *Lorena* fue nombrada en provisionalidad en una vacante en el ‘Instituto Técnico Industrial, sede la libertad’. En 2018 se realizó una convocatoria por concurso de mérito para proveer, entre otros, la vacante en la que la accionante se desempeñaba como docente. Ahora bien, respecto de la nueva vacante en la institución educativa ‘Técnico Industrial, sede la libertad’ en la que se nombró a la accionante, se

mencionó que creó el Comité Técnico de Estabilidad Laboral Reforzada⁶⁴. Sin embargo, explicó que para el año 2024 no es posible garantizar la continuidad laboral de la accionante porque no hay vacantes disponibles en la zona rural y, respecto de las vacantes disponibles en la zona urbana, tiene el deber legal de proveer estas con la lista de elegibles producto del concurso de méritos.

§44. Con relación a los criterios utilizados para reubicar a los docentes en provisionalidad desvinculados y que gozan de una estabilidad laboral relativa en razón a su condición de salud, manifestó que se aplican las pautas establecidas por el Ministerio de Educación en las circulares 024 de 2023 y 039 de 2013. Por último, señaló que 12 docentes que gozan de estabilidad laboral relativa al ser sujetos de especial protección, quienes se han vinculado nuevamente con la Secretaría de Educación de Florencia. Asimismo, creó una lista de espera de docentes en situación de especial protección para cuando exista una vacante disponible y se agote la lista de elegibles para proveer esa vacante. Esta lista se compone de 25 mujeres y 3 hombres.

§45. *Fondo Asistencial del Magisterio del Caquetá (FAMAC)*⁶⁵. En respuesta del 18 de julio de 2024, indicó que *Lorena* está registrada en la entidad de salud como afiliada activa y en calidad de beneficiaria desde el 22 de julio de 2015. A su vez, adjuntó copia de la historia clínica de la accionante y afirmó que le ha prestado los servicios de salud según su patología ‘tumor maligno de endometrio’⁶⁶. En ese sentido alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva.

§46. *Lorena*⁶⁷. En respuesta del 24 de julio de 2024, la accionante señaló que es docente licenciada en educación básica primaria. Respecto a su situación

debe precisar que se estaba iniciando concurso de méritos para proveer las vacantes definitivas de la zona urbana. Para octubre y noviembre de 2023, la lista de elegibles quedó en firme, por lo que los docentes seleccionados iniciarían labores el 15 de enero de 2024, lo que simultáneamente finaliza el nombramiento en provisionalidad de las personas que ocupaban las vacantes ofertadas.

⁶⁴ Expediente digital T-10.121.578. Archivo “Respuesta Secretaría de Educación de Florencia- Decreto por medio del cual se crea el Comité de Estabilidad Laboral Reforzada en 2023.pdf”.

⁶⁵ Expediente digital T-10.121.578. Archivo “FAMAC”.

⁶⁶ Expediente digital T-10.121.578. Archivo “Historia clínica-FAMAC”.

⁶⁷ Expediente digital T-10.121.578. Archivo “Respuesta *Lorena*.pdf”.

laboral indicó que actualmente se encuentra desempleada. Argumentó que sus ingresos mensuales oscilan entre 800 y 900 mil pesos, siendo inferiores a sus gastos mensuales pues debe cubrir sus necesidades básicas y las de su núcleo familiar que está conformado por su compañera sentimental y su padrastro de 81 años; quienes, dependen económicamente de ella. Señaló que para suplir sus necesidades básicas, esporádicamente, ha realizado reemplazos a otros docentes e incluso ha debido “realizar rifas y vender tamales”⁶⁸.

§47. Respecto a su estado salud, *Lorena* mencionó que no se pudo afiliarse al SISBÉN porque su puntaje era superior al punto de corte para ser beneficiaria en este sistema. Afirmó que el 19 de marzo de 2024 tenía una cita médica con el oncólogo en la Liga contra el Cáncer de Neiva para control y revisión de exámenes. Sin embargo, para esa fecha, ya se encontraba desvinculada del régimen de salud por lo que no logró agendarla a través del FAMAC, sin importar que en la ecografía de tejidos de blandos el diagnóstico era ‘*adenopatía de aspecto inflamatorio*’⁶⁹. Ante tal situación, el docente Jairo Ortiz Hincapié afilió a la accionante de manera provisional como beneficiaria mientras iba a la cita de control en Neiva. En esta cita, el oncólogo ordenó unos medicamentos, una ecografía de abdomen total y cita de control para el mes de septiembre del 2024.

3.2 Respuestas en el Expediente T-10.153.714

§48. Esta Corte recibió respuestas de la accionante *Adriana*, Secretaría de Educación y Cultura de Apartadó, Antioquia, el IPS Sumimedical S.A.S, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Ministerio de Educación Nacional.

§49. *Adriana*⁷⁰. Indicó que es madre cabeza de familia y que, actualmente, se encuentra desempleada. Afirmó ser la responsable económica de su núcleo familiar que está compuesto por sus 2 hijas (una mayor de edad y la otra con

⁶⁸ *Ibidem*, p. 2.

⁶⁹ *Ibidem*.

⁷⁰ Expediente digital T-10.153.714. Archivo “Respuesta *Adriana*.pdf”.

12 años) y su nieto de 8 años. A su vez, allegó una relación de ingresos y gastos mensuales en los que se evidencia que, en la actualidad, su única fuente de ingresos son 350 mil pesos por concepto de un canon de arrendamiento que recibe, mientras que sus gastos y los de su núcleo familiar son alrededor de 5 millones de pesos.

§50. Con relación a la prestación del servicio de salud, la accionante señaló que desconoce las razones por las cuales su estado de afiliación está activo en la EPS Sumimedical-FOMAG si no se encuentra laborando o cotizando como independiente. De la misma manera, afirmó que estuvo inactiva por 3 meses desde febrero de 2024. Durante este tiempo no tuvo acceso a las citas médicas con especialistas ni al medicamento esencial ‘letrozol’, ordenado por el oncólogo. Por consiguiente, indica que presentó un deterioro en su salud pues aumentó la fatiga, los dolores de cabeza y el dolor en huesos y articulaciones.

§51. Respecto a la solicitud de pérdida de capacidad laboral, señaló que hasta el 2 de mayo de 2024 presentó dicha solicitud ya que la accionante tenía entendido que este trámite lo adelantaba directamente la EPS. Por último, mencionó que el 10 de mayo de 2024 se realizó una conciliación extrajudicial en la que la Secretaría de Educación y Cultura de Apartadó no tuvo ánimo conciliatorio. En ese sentido, señaló que presentará la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho⁷¹.

§52. *Secretaría de Educación y Cultura de Apartadó, Antioquia*⁷². En la respuesta relacionó los diferentes derechos de petición presentados por la accionante. Afirmó que solamente *Adriana*⁷³ solicitó su permanencia como docente en provisionalidad en virtud del cáncer padecido; que la accionante había presentado 6 incapacidades que comprendían un periodo continuo entre el 1 de enero de 2023 y el 18 de mayo de 2023. Posteriormente, en septiembre de 2023 presentó dos incapacidades con una duración acumulada de 5 días⁷⁴. Es decir, la accionante se reintegró a sus labores desde el 18 de mayo de 2023

⁷¹ *Ibidem*, p. 8

⁷² Expediente digital T-10.153.714. Archivo “Respuesta Secretaría de educación de Apartadó.pdf”.

⁷³ Radicado APA2024ER000144 del 16 de enero de 2024.

⁷⁴ Expediente digital T-10.153.714. Archivo “Respuesta Secretaría de educación de Apartadó.pdf”, p. 3.

y las incapacidades generadas en septiembre de 2023 fueron producto de otras enfermedades comunes diferentes al cáncer. Señaló que en agosto de 2023 la entidad territorial en articulación con la IPS Sumimedical le realizaron los exámenes ocupacionales periódicos que indican que la accionante se encontraba en condiciones óptimas para realizar sus laborales.

§53. La Secretaría también informó que tras la desvinculación de *Adriana*, el 15 de enero de 2024 solicitó ser incluida en el listado de los docentes que contaban con estabilidad laboral reforzada. Luego, la Secretaría de Educación y Cultura de Apartadó expidió el Decreto 647 del 17 de abril de 2024 mediante el cual nombró en provisionalidad temporal a la accionante hasta que durara la licencia de incapacidad por enfermedad común de la docente Yudithza Moreno Mena, quien fue nombrada en propiedad en la vacante ofrecida. Sin embargo, *Adriana* manifestó telefónicamente a la entidad que “no se presentaría a firmar porque el lugar para el que la enviaban era muy lejos de su domicilio y que se encontraba pendiente de un nombramiento en otra entidad territorial”⁷⁵.

§54. Por último, la entidad mencionó que hasta la fecha no se han generado más vacantes temporales. La única plaza libre fue la que se asignó mediante el citado Decreto municipal 647 del 17 de abril de 2024. Igualmente, afirmó que actualmente hay 6 docentes (4 hombres y 2 mujeres) que están adscritos a la entidad y sufren de algún tipo de cáncer. Por lo anterior, la Secretaría accionada solicitó negar la acción constitucional argumentando que no vulneró los derechos de la accionante y que su retiro obedece al nombramiento en periodo de prueba de un docente que superó el concurso de méritos.

§55. *FOMAG*⁷⁶. En respuesta del 19 de julio de 2024 esta entidad señaló que *Adriana* se encuentra con estado de afiliación activo como cotizante docente desde el 18 de junio de 2011. Actualmente no tiene beneficiarios, pues su hija menor de edad fue retirada el 15 de febrero de 2024.

⁷⁵ *Ibidem*, p. 5.

⁷⁶ Expediente digital T-10.153.714. Archivo “Respuesta FOMAG.pdf”.

§56. *Respuesta de IPS Sumimedical S.A.S*⁷⁷. Brindó respuesta el 17 de julio de 2024 en la que mencionó que la accionante se encuentra en estado activo como cotizante del FOMAG. En la actualidad, la IPS Sumimedical le está prestando los servicios básicos de salud y los que han sido ordenados por la Fiduciaria la Previsora. Respecto a su estado de salud, indicó que padece de ‘carcinoma ductal infiltrante mama izquierda’ y allega la historia clínica en la que se evidencia el proceso de seguimiento y tratamiento de la paciente⁷⁸. Por último, explicó que el contrato entre la IPS Sumimedical y Fiduciaria la Previsora por la responsabilidad del aseguramiento y prestación de servicios de salud de los docentes finalizó el 30 de abril de 2024.

§57. *Ministerio de Educación Nacional*⁷⁹. En respuesta del 15 de julio de 2024, resaltó que corresponde a las entidades territoriales certificadas en educación administrar la planta docente. Respecto al número de docentes vinculados y que hacen parte del grupo de especial protección, 71 entidades territoriales certificadas han reportado la siguiente información en virtud de las orientaciones dadas mediante las Circulares 24, 039 y 040 de 2023⁸⁰ por el Ministerio de Educación Nacional:

- a. Vacantes definitivas docentes que están en la lista de estabilidad laboral reforzada son en total 2.555, de los cuales 484 corresponden al primer orden de protección - Enfermedad catastrófica o algún tipo de discapacidad.
- b. Vacantes temporales docentes que están en la lista de estabilidad laboral reforzada son en total 3.457, de los cuales 705 corresponden al primer orden de protección - Enfermedad catastrófica o algún tipo de discapacidad.

§58. En relación con la acción de tutela promovida por *Adriana* solicitó que se negara la protección de sus derechos fundamentales dado que, estos no fueron vulnerados. Explicó que los funcionarios que son sujetos de especial

⁷⁷ Expediente digital T-10.153.714. Archivo “respuestas IPS Sumimedical”.

⁷⁸ Expediente digital T-10.153.714. Archivo “respuestas IPS Sumimedical-historia laboral.pdf”.

⁷⁹ Expediente digital T-10.153.714. Archivo “respuesta ministerio de educación nacional.pdf”.

⁸⁰ Expediente digital T-10.153.714. Archivo “respuesta ministerio de educación nacional-anexo circulares.pdf”.

protección constitucional en razón de su salud y que están nombrados en provisionalidad gozan de una estabilidad laboral relativa con relación a las personas que son elegidas y nombradas en propiedad a través de un concurso de méritos. Es decir, su vinculación se mantendrá hasta que el docente nombrado en propiedad en período de prueba asuma las funciones del cargo. Por último, señaló que carecía de legitimación por pasiva pues sus competencias frente a los concursos de méritos de la carrera especial docente se circunscriben a la reglamentación que rigen dichos concursos.

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

1. Competencia

§59. La Corte Constitucional es competente para conocer las decisiones judiciales materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política, en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

2. Análisis de procedibilidad de las acciones de tutela

§60. En relación con lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional debe determinar, en primer lugar, si las acciones de tutela cumplen con los requisitos formales de procedencia. De superarse dicho análisis, procederá con el estudio de fondo.

2.1 Análisis de requisitos de procedencia: expediente T-10.121.578

§61. La acción de tutela presentada por *Lorena* en contra de la Secretaría de Educación de Florencia es procedente por cuanto cumple los requisitos de legitimación por activa y pasiva, inmediatez y subsidiariedad.

§62. *Legitimación por activa*⁸¹. La acción de tutela fue presentada a nombre propio por *Lorena*, quien es la titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados, por lo que se cumple la exigencia.

§63. *Legitimación por pasiva*⁸². La Secretaría de Educación de Florencia está legitimada por pasiva en este caso, ya que celebró un concurso de méritos en el cual ofertó la vacante ocupada en provisionalidad por la accionante. En ese sentido, la terminación del nombramiento en provisionalidad se dio en virtud del nombramiento en periodo de prueba del elegido Duberney Trujillo, tras haber ganado un concurso de méritos. Además, se destaca que dentro de las responsabilidades de los entes territoriales, señaladas en la Ley 715 de 2001 se encuentra la administración de la planta de personal de docentes y directivos docentes de los establecimientos educativos oficiales, todo ello con fundamento en la descentralización y la autonomía territorial.

§64. Por otra parte, en relación con el señor Duberney Trujillo, la Sala resalta que él carece de legitimación por pasiva, ya que no es la persona encargada de resolver las pretensiones relacionadas con la protección de la estabilidad laboral relativa de la accionante. Finalmente, en torno al FAMAC, entidad que fue vinculada en sede de revisión, la Sala destaca que sobre esta no recae directamente la posibilidad de resistir las pretensiones de *Lorena*, por lo que, no tiene legitimidad por pasiva.

⁸¹ El artículo 86 de la Constitución Política dispone que “toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces (...), por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales”. En desarrollo de esta disposición, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 precisa que la tutela podrá ser presentada por cualquiera de estas formas: (i) a nombre propio, (ii) mediante representante legal, (iii) por medio de apoderado judicial o (iv) mediante agente oficioso. Igualmente, los artículos 86 de la Constitución y 5 del Decreto 2591 de 1991 disponen que la acción de tutela procede en caso de acción u omisión de entidades públicas o de particulares en los casos estipulados en la Constitución y en la ley.

⁸² Conforme al artículo 86 de la Constitución Política, el requisito de legitimación en la causa por pasiva exige que la acción de tutela sea interpuesta en contra del sujeto -autoridad pública o particular- que cuenta con la aptitud o “capacidad legal” para responder a la acción y ser demandado, bien sea porque es el presunto responsable de la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales o es el llamado a resolver las pretensiones.

§65. *Inmediatez*⁸³. La presunta vulneración de los derechos fundamentales de *Lorena* ocurrió con la expedición del Decreto 095 de 2023 del 1 de diciembre de 2023, en el que se nombró a Duberney Trujillo en periodo de prueba en el empleo que la accionante ejercía en provisionalidad. Posteriormente, el 22 de enero de 2024, ella presentó la acción de tutela. Es decir que, *Lorena* solo tardó un mes y 20 días para interponer la acción constitucional. Esta circunstancia demuestra que la tutela fue interpuesta dentro de un plazo razonable, cumpliendo con el requisito de inmediatez.

§66. *Subsidiariedad*⁸⁴. En el caso de *Lorena* se cumple el requisito de subsidiariedad, dado que es una persona en condición de debilidad manifiesta que, si bien a la fecha no cuenta con el diagnóstico de un cáncer activo, como consecuencia del cáncer de endometrio que le fue diagnosticado en el año 2017 ha tenido que estar bajo controles médicos continuos. Estos controles le han permitido contar con diagnósticos oportunos de otras patologías como (i) un lipoma en el glúteo en el año 2019, (ii) unas lesiones tumorales nevus en su mentón y nariz en el año 2021 y (iii) unas adenopatías de aspecto inflamatorio identificadas en 2024. Luego, aunque en su historia clínica no se menciona que actualmente *Lorena* sea una paciente oncológica, si es razonable considerar que se encuentra en una especial situación dadas las diferentes y continuas patologías que le han sido diagnosticadas y tratadas desde 2017 a la fecha.

⁸³ El artículo 86 de la Constitución dispone que la acción de tutela es un mecanismo de protección inmediata de derechos fundamentales. Aunque ni la Constitución ni el Decreto 2591 de 1991 definen el término para interponer la solicitud de tutela, la jurisprudencia constitucional ha precisado que esta debe ejercerse dentro de un término razonable y proporcionado. Sentencia SU-108 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. S.V. Alberto Rojas Ríos. S.P.V. Diana Fajardo Rivera y Cristina Pardo Schlesinger. A.V. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

⁸⁴ Conforme al artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela solo procede en dos supuestos: (i) como mecanismo de protección definitivo, cuando los accionantes no dispongan de otro medio judicial idóneo y eficaz o (ii) como mecanismo transitorio, en caso de que el accionante pretenda evitar un perjuicio irremediable. Se considera como mecanismo de protección definitivo (i) si el medio ordinario de defensa es idóneo, este debe ser capaz de producir el efecto protector de los derechos fundamentales que se reclaman, y (ii) eficaz, si permite brindar una protección oportuna a los derechos amenazados o vulnerados “atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante”. Sentencia T-195 de 2022 (M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera). Así mismo, se destaca que un mecanismo judicial es a) *idóneo*, si es materialmente apto para resolver el problema jurídico planteado y es capaz de producir el efecto protector de los derechos fundamentales; y b) es *eficaz*, cuando permite brindar una protección oportuna a los derechos amenazados o vulnerados.

§67. Asimismo, tras la terminación de su nombramiento en provisionalidad, *Lorena* indicó que no ha podido volver a vincularse laboralmente y que sus ingresos mensuales que oscilan entre 800 y 900 mil pesos. Suma de dinero que no es suficiente para cubrir sus necesidades básicas y las de su núcleo familiar, el cual está conformado por su compañera sentimental y su padrastro de 81 años, quien depende económicamente de la accionante. Por último, señaló que para suplir sus necesidades básicas, esporádicamente, ha realizado reemplazos a otros docentes, e incluso, ha debido “realizar rifas y vender tamales”⁸⁵.

§68. En el caso en concreto la tutela procede como mecanismo definitivo de protección, pues la accionante no dispone de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para proteger sus derechos fundamentales. Se reitera que, si bien el diagnóstico de cáncer al que hizo referencia la accionante fue del año 2017, tras haber padecido tal enfermedad, la accionante ha estado sometida a exámenes y controles frecuentes que hasta el momento de su desvinculación habían sido garantizados por la EPS FAMAC. Sin embargo, *Lorena* indica que como consecuencia de la terminación de su nombramiento perdió sus derechos como afiliada a la mencionada EPS, debiendo incluso pedir a un amigo docente que la vinculara de manera temporal al FAMAC para poder continuar con su tratamiento en aras de evitar un perjuicio irremediable contra su salud y su vida.

§69. Si la accionante acude a las vías ordinarias, la competencia para resolver sus pretensiones recae en la Jurisdicción Contencioso Administrativa⁸⁶ a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho⁸⁷. No obstante, acudir a dicho medio de control no le garantizaría la protección inmediata que requiere dada su condición de vulnerabilidad. Por el contrario, esta vía supone una carga excesiva para la accionante dado que

⁸⁵ Expediente digital T-10.121.578. Archivo “Respuesta *Lorena*.pdf”, p. 2.

⁸⁶ Artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 - CPACA. “La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer (...) de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas (...)”.

⁸⁷ Artículo 138, Ley 1437 de 2011 - CPACA.

exige un tiempo considerable⁸⁸ y la accionante se encuentra en una situación de riesgo porque por su historial clínico debe efectuarse controles médicos periódicos con diferentes médicos especialistas. En efecto, en la última cita del 19 de marzo de 2024, el oncólogo ordenó unos medicamentos, una ecografía de abdomen total y otra cita de control para el mes de septiembre del 2024⁸⁹.

§70. En suma, todas estas razones hacen que sea necesaria la intervención del juez constitucional a fin de que valore la situación y adopte las medidas a que haya lugar como mecanismo definitivo para la protección de sus derechos fundamentales.

2.2 Análisis de requisitos de procedencia: expediente T-10.153.714

§71. La acción de tutela presentada por *Adriana* en contra de la Secretaría de Educación y Cultura de Apartadó es formalmente procedente por cuanto cumple los requisitos de legitimación por activa y pasiva, inmediatez y subsidiariedad.

§72. *Legitimación por activa.* La Sala encuentra que la acción de tutela en el caso que se analiza cumple con el requisito de legitimación en la causa por activa, porque fue presentada a nombre propio por *Adriana*, quien es la titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados por la terminación de nombramiento en provisionalidad del cargo que desempeñaba en una institución educativa dependiente de la Secretaría de Educación y Cultura de Apartadó.

§73. *Legitimación por pasiva.* Este requisito se satisface porque la Secretaría de Educación y Cultura de Apartadó es la entidad presuntamente responsable de la afectación de los derechos fundamentales de la accionante, al dar por terminado el nombramiento en provisionalidad de la accionante en virtud del nombramiento en propiedad y por concurso de méritos de Nubia Cecilia

⁸⁸Igualmente, la Sala resalta que pese a que preguntó a *Lorena* si había interpuesto alguna acción judicial con motivo en los hechos de la acción de tutela, ella no se pronunció al respecto; por lo que, no es posible determinar si se encuentra o no en curso una acción ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa por estos hechos.

⁸⁹ Expediente digital T-10.121.578. Archivo “Respuesta *Lorena*.pdf”.

Prestán sin tener en cuenta que la accionante padece cáncer de seno. Ahora bien, dentro de las facultades y responsabilidades de las entidades territoriales señaladas en la Ley 715 de 2001, se encuentra la administración de la planta de personal de docentes y directivos docentes de los establecimientos educativos oficiales, todo ello con fundamento en la descentralización y la autonomía territorial.

§74. A continuación, se exponen las razones por las cuales las demás entidades o personas vinculadas en el presente trámite no tienen legitimación por pasiva en el caso en concreto:

a. *El Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)*. La Sala destaca que El FOMAG no influyó en la decisión de dar por terminado el nombramiento en provisionalidad de *Adriana*. Por consiguiente, se estima que no cuenta con legitimidad por pasiva.

b. *Nubia Cecilia Prestan Pérez*. Es la persona elegida y nombrada en propiedad para el cargo de docente de primaria en la institución educativa Campo Alegre luego de superar el respectivo concurso de méritos realizado por la Comisión Nacional del Servicio Civil. En ese sentido, no es responsable de la vulneración de derechos fundamentales alegada por la accionante al finalizar el nombramiento en provisionalidad, pues esta facultad legal le compete a la entidad territorial. Es importante tener presente que la meritocracia es uno de los principios que rigen los empleos de carrera administrativa y participar en un concurso de méritos para ocupar una vacante no es una conducta que se pueda reprochar.

c. *La IPS Sumimedical S.A.S.* Es una empresa de carácter privado que presta la atención en servicios de salud a la accionante en virtud del convenio que tiene con Fiduciaria la Previsora, como patrimonio autónomo que administra el FOMAG. Sin embargo, en la respuesta al trámite de revisión señaló que dicho contrato finalizó el 30 de abril de 2024 por lo que es responsabilidad del FOMAG garantizar la atención y prestación de los servicios de salud a la accionante con otras IPS con las cuales tenga convenio.

d. *El Ministerio de Educación Nacional*. La prestación del servicio educativo se encuentra descentralizado. En este sentido, la dirección, planificación y prestación del servicio educativo está a cargo de las Entidades Territoriales Certificadas en Educación, a través de sus secretarías de educación o quien haga sus veces⁹⁰. En ese sentido, el Ministerio de Educación no es la entidad responsable por la afectación de los derechos de la accionante, pues este Ministerio no tiene dentro de sus competencias la administración de la planta docente en los establecimientos educativos, puesto que su función conforme al marco normativo, es fijar la planta docente y directiva docente de manera global. Sin embargo, como se expondrá más adelante, esta entidad tiene un papel importante en la ejecución de remedios más garantistas para personas que se encuentren en situaciones similares a las de *Adriana*, por lo que, la Sala estima que si cuenta con legitimidad por pasiva.

§75. *Inmediatez*. La presunta vulneración de los derechos fundamentales de la accionante ocurrió el 15 de enero de 2024 con la notificación del Decreto 134 del mismo año. Este Decreto dio por terminado el nombramiento de *Adriana* por cuenta de la designación en periodo de prueba de la persona que resultó elegida en el concurso de méritos que se realizó para cubrir en propiedad el cargo que se encontraba ocupando la accionante en provisionalidad. A su vez, la accionante presentó la acción de tutela el 19 de enero de 2024, por lo que, transcurrieron menos cerca de cuatro (4) días entre el aparente acto vulnerador y la presentación de la tutela⁹¹.

§76. *Subsidiariedad*. En este caso el requisito de subsidiariedad se satisface. La Sala considera que por las condiciones particulares de la accionante (edad, estado de salud, condición económica y laboral), es urgente que el juez constitucional se pronuncie adoptando una decisión de fondo. Para llegar a esta conclusión, la Sala hará referencia a la situación de especial vulnerabilidad en la que se encuentra *Adriana* y, posteriormente, a la falta de eficacia de los mecanismos ordinarios en el caso concreto; incluso, pese a que

⁹⁰ Leyes 115 de 1994 y 715 de 2001.

⁹¹ Si bien no hay certeza de la presentación de la acción de tutela, el auto admisorio de la misma es de fecha del 20 de enero de 2024.

la accionante afirmó que pensaba radicar el medio de control de nulidad y restablecimiento de derecho.

§77. De un lado, la Sala resalta que *Adriana* presenta dificultades económicas y en su estado de salud que la hacen un sujeto de especial protección constitucional. En efecto, la decisión de dar por terminado el nombramiento en provisionalidad de la accionante para nombrar en propiedad al elegido del concurso de méritos inevitablemente impactó el mínimo vital de la accionante. La accionante indicó que es madre cabeza de familia y que, actualmente, se encuentra desempleada. Afirmó ser la responsable económica de su núcleo familiar. A su vez allegó una relación de ingresos y gastos mensuales en los que se evidencia que, en la actualidad, su única fuente de ingresos son 350 mil pesos por concepto de un canon de arrendamiento que recibe, mientras que sus gastos y los de su núcleo familiar son alrededor de 5 millones de pesos⁹².

§78. En la misma línea, el estado de salud de la accionante no está en óptimas condiciones. Tras haber sido diagnosticada con cáncer de seno en abril de 2022, y haberse sometido en enero de 2023, a una ‘mastectomía simple unilateral y vaciamiento radial linfático axilar vía abierta’ seguida por un tratamiento con radioterapia, actualmente *Adriana* se encuentra en un seguimiento periódico que tiene lugar cada tres meses. Este seguimiento es realizado por un especialista en Oncología, un especialista del dolor y un médico internista. Esto último, por cuanto además, la accionante ha sido diagnosticada con obesidad grado III y enfermedad varicosa⁹³.

§79. Todo lo anterior pone de presente la urgencia de garantizar los derechos fundamentales de *Adriana*. Así, si bien en este caso ella también cuenta con la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que incluso ella afirmó que presentaría el 22 de julio de 2024, tras haber radicado la solicitud de conciliación extrajudicial el 10 de mayo de 2024⁹⁴, lo cierto es que dicha acción no es idónea ni efectiva para garantizar sus derechos fundamentales de manera inmediata.

⁹² Expediente digital T-10.121.578. Archivo: “Respuesta Lorena.pdf”.

⁹³ Expediente digital T-10.153.714. Archivo: “Respuesta IPS Sumimedical”.

⁹⁴ Esto fue indicado por *Adriana* en su respuesta en sede de revisión. Expediente digital T-10.153.714. Archivo “RESPUESTA- ANEXOS”, p. 8.

§80. Esto por, al menos, dos razones: (i) es claro que la accionante enfrenta una compleja situación de salud que hace que sea posible considerarla como un sujeto especial de protección, aunado al hecho que como consecuencia de su retiro del servicio público, quedó desempleada y sin la posibilidad de contar con suficientes ingresos para su subsistencia y la de sus familiares pues ella afirma sostener a varios de ellos; y (ii) la definición de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho toma un tiempo considerable si se compara con los términos del proceso de tutela, aunado al hecho que esta Corte solo tiene constancia de la presentación de la solicitud de conciliación⁹⁵, pero no de la radicación de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Ello justifica la intervención excepcional, pero definitiva del juez constitucional.

§81. Por ello, la Sala estima que la acción de tutela de *Adriana* debe asumirse como el remedio definitivo para su situación, sin perjuicio de las determinaciones que adopte la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en torno a las pretensiones económicas de la accionante que, como se expondrá más adelante, no pueden ser objeto de análisis en el marco de la acción de tutela.

§82. Con base en todo lo anterior, la Sala concluye que se satisfacen los presupuestos de procedencia de la acción de tutela en los dos expedientes acumulados en el presente proceso.

3. Problemas jurídicos y metodología de la decisión

§83. Dado que los dos casos acumulados presentan algunas diferencias relevantes, la Sala planteará un problema independiente para cada uno.

§84. De un lado, para el expediente T-10.121.578 la Sala se ocupará de determinar si ¿La Secretaría de Educación de Florencia vulneró los derechos fundamentales a la vida, al trabajo, a la salud, la igualdad de oportunidad, a la no discriminación, la remuneración mínima vital y móvil y a la estabilidad

⁹⁵ *Ibidem*, pp. 425 a 427. La conciliación extrajudicial fue surtida ante la Procuraduría 170 Judicial I para Asuntos Administrativos Turbo (Antioquia) con fecha del 18 de julio de 2024.

laboral relativa⁹⁶ de la accionante tras haberla desvinculado del cargo en provisionalidad que ocupaba desde 2015, con el objetivo de vincular a la persona que ganó un concurso de méritos para ocupar el cargo de la accionante, pese a que ella es una *paciente en remisión* que ha podido contar con un seguimiento oportuno de su estado de salud que le ha permitido detectar otras afectaciones relevantes, tras haber padecido cáncer de endometrio en 2017?

§85. Por otra parte, en torno al expediente T-10.153.714 a la Sala le corresponde analizar si ¿La Secretaría de Educación y Cultura de Apartadó vulneró los derechos fundamentales a la vida, al trabajo, a la dignidad, a la salud y a la estabilidad laboral relativa de la accionante tras haberla desvinculado del cargo en provisionalidad que ocupaba desde 2011, con el objetivo de vincular a la persona que ganó un concurso de méritos para ocupar el cargo de la accionante, pese a que (i) ella padece de obesidad grado III y enfermedad varicosa, (ii) en 2022 fue diagnosticada con un cáncer de mama que requiere un seguimiento frecuente y (iii) alega tener la calidad de pre pensionada?

§86. Con el fin de dar respuesta a los anteriores problemas jurídicos, la Sala mencionará algunas consideraciones sobre (3.1) los concursos de méritos para el acceso a empleos públicos; (3.2) la estabilidad laboral relativa de los docentes nombrados en provisionalidad y la protección especial derivada de una situación de debilidad manifiesta por razones de salud y por la calidad de pre pensionados. Luego, (3.3) se hará referencia al régimen pensional general de los docentes de colegios públicos. En cuarto lugar (3.4), se dedicará un breve acápite al cáncer como enfermedad catastrófica y los impactos que esta enfermedad tiene en las mujeres. Posteriormente, abordará cada uno de los casos con el objetivo de verificar si se deben o no amparar los derechos fundamentales de las accionantes.

3.1 Los concursos de méritos para el acceso a empleos públicos

⁹⁶ Vale la pena destacar que la accionante en todo su escrito de tutela se refiere a la estabilidad laboral reforzada; sin embargo, dado que como se expondrá en la parte considerativa está no opera respecto de los servidores públicos en provisionalidad, la Sala ajusta el término por “estabilidad laboral relativa”.

§87. La carrera administrativa basada en el mérito tiene una especial importancia en nuestro sistema, al tratarse de un instrumento para la materialización de las finalidades institucionales y la garantía de derechos fundamentales⁹⁷. Como lo establece el artículo 125 de la Constitución, es el mecanismo general y preferente de acceso a la función pública⁹⁸ y para asegurar la selección de servidores cuyas capacidades, experiencia, conocimiento y dedicación permitan atender las finalidades del Estado Social de Derecho.

§88. La carrera promueve la igualdad, la imparcialidad y los principios que orientan la función administrativa, al buscar que las personas cualificadas se vinculen al Estado en igualdad de oportunidades y bajo parámetros objetivos, no discriminatorios, transparentes y claros. Además, permite la participación en el ejercicio del poder público⁹⁹, y establece garantías laborales como la estabilidad y la capacitación profesional¹⁰⁰. Esto hace del mérito “el principio transversal y la piedra angular sobre la cual se instituye el servicio público”¹⁰¹, y lo erige como una herramienta que permite erradicar el clientelismo, el favoritismo y el nepotismo¹⁰².

⁹⁷ Sentencias T-443 de 2022. M.P. Diana Fajardo Rivera; C-102 de 2022. M.P. Diana Fajardo Rivera; C-288 de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; C-250 de 2013. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; C-040 de 1995. M.P. Carlos Gaviria Díaz; y C-356 de 1994. M.P. Fabio Morón Díaz; y C-479 de 1992. MM.PP. José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero.

⁹⁸ No se aplica a los cargos de elección popular, de libre nombramiento y remoción y a los trabajadores oficiales.

⁹⁹ Artículo 70 de la Constitución: Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede (...) 7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos (...)."

¹⁰⁰ Sentencia C-102 de 2022. M.P. Diana Fajardo Rivera.

¹⁰¹ Sentencia C-102 de 2022. M.P. Diana Fajardo Rivera.

¹⁰² Sentencias C-102 de 2022. M.P. Diana Fajardo Rivera; C-503 de 2020. M.P. Alejandro Linares Cantillo; SU-917 de 2010. M.P. Jorge Iván Palacio; y C-588 de 2009. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

§89. La jurisprudencia ha reconocido el carácter de principio constitucional del mérito y, como tal, de norma jurídica superior de aplicación inmediata, cuyo desconocimiento vulnera la totalidad del ordenamiento constitucional¹⁰³ y “podría acarrear la sustitución de la Constitución”¹⁰⁴. Como muestra de ello, en la Sentencia C-558 de 2009, la Corte estudió una demanda en contra del Acto Legislativo n.º 01 de 2008 en el que, de manera extraordinaria y sin necesidad de participar en un concurso público, se permitía incluir en la carrera administrativa a los servidores que a la fecha de publicación de la Ley 909 del 2004 estuviesen ocupando cargos de carrera vacantes en calidad de *provisionales*, siempre que cumplieran con los requisitos del cargo ofertado.

§90. La Corte indicó que el artículo 1º del mencionado Acto Legislativo reemplazaba la regulación general sobre la carrera administrativa que consagra el artículo 125 de la Constitución, pues establecía un régimen distinto para acceder a la carrera administrativa. Por tal razón, la Corte declaró la inexecutable del Acto Legislativo 01 de 2008.

§91. En esa misma línea, desde sus primeras decisiones la Corte ha sido clara en que la autoridad nominadora debe respetar el orden en la lista de elegibles que se conforman de acuerdo con los puntajes obtenidos, luego de haberse superado las etapas del concurso¹⁰⁵. Una vez dichas listas de elegibles quedan en firme son inmodificables, y su desconocimiento constituye una flagrante violación de los derechos a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y al acceso a cargos públicos de quienes hayan ocupado los primeros lugares en el concurso.

¹⁰³ Sentencias C-588 de 2009. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; y C-563 de 2000. M. P. Fabio Morón Díaz.

¹⁰⁴ Sentencia C-588 de 2009. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

¹⁰⁵ Sentencia T-443 de 2022. M.P. Diana Fajardo Rivera. Reitera las Sentencias SU-133 de 1998. M.P. José Gregorio Hernández Galindo; SU-086 de 1999. M.P. José Gregorio Hernández Galindo; SU-961 de 1999 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; T-102 de 2001. M.P. Fabio Morón; y T-156 de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa.

§92. Por último, vale la pena destacar que aunque la carrera administrativa debe ser la regla general para el acceso a cargos en el Estado¹⁰⁶, se ha admitido la validez de los *nombramientos provisionales* de personas que no han superado concursos de méritos en eventos excepcionales, con el propósito de que las entidades públicas garanticen la continuidad en la prestación del servicio¹⁰⁷. Sin embargo, no se puede desnaturalizar su carácter transitorio que implica que la duración de estas vinculaciones esté condicionada a la configuración de causales objetivas de retiro del servicio o a la selección de funcionarios a través de la evaluación de sus méritos en un concurso público¹⁰⁸.

§93. *Conclusión.* La Sala concluye que la carrera administrativa basada en el mérito es la regla general para acceder a los empleos públicos que no son de elección popular o de libre nombramiento y remoción. Sin embargo, en algunos escenarios se ha permitido que las personas accedan de manera temporal a empleos públicos a través del nombramiento en provisionalidad, cuando ello es necesario para garantizar la continuidad en la prestación del servicio. En consecuencia, es completamente ajustado a la Constitución terminar la vinculación en provisionalidad de una persona, con el fin de nombrar a una persona que ganó un concurso público de méritos. Ello además se desprende de la *estabilidad laboral relativa* que ostentan los servidores vinculados en provisionalidad y que implica que sus derechos ceden frente al mejor derecho que tienen las personas que ganaron el concurso¹⁰⁹.

3.2 La estabilidad laboral relativa de los servidores nombrados en provisionalidad que desempeñan cargos de carrera administrativa

¹⁰⁶ Sentencia C-588 de 2009. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

¹⁰⁷ Sentencia C-102 de 2022. M.P. Diana Fajardo Rivera

¹⁰⁸ Sentencia T-246 de 2022. M.P. Diana Fajardo Rivera. Cita las sentencias T-373 de 2017. M.P. Cristina Pardo Schlesinger; SU-556 de 2014. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y SU-917 de 2010. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

¹⁰⁹ Sentencia SU-446 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

§94. La estabilidad laboral es un principio mínimo de las relaciones de trabajo previsto en el artículo 53 de la Constitución, que corresponde al derecho de los trabajadores a permanecer en sus empleos, salvo que exista una justa causa para su desvinculación¹¹⁰. En armonía con los principios de igualdad, prohibición de la discriminación, solidaridad e integración social, la jurisprudencia de esta corporación desarrolló el derecho a la estabilidad laboral reforzada, que se concreta en la adopción de medidas especiales de protección para personas en situación de vulnerabilidad.

§95. Sin embargo, esta estabilidad laboral reforzada tiene matices cuando se está frente al empleo público; toda vez que, la estabilidad laboral que se le confiere a los funcionarios públicos varía según la forma de vinculación¹¹¹. En particular, la Corte estableció que, por una parte, los funcionarios que acceden a los cargos mediante el concurso de méritos cuentan con una mayor estabilidad, al haber superado las etapas propias del proceso de selección; lo cual, impide que sean retirados del cargo a partir de criterios meramente discrecionales. Por otra parte, los funcionarios que desempeñan cargos en provisionalidad gozan de una estabilidad laboral relativa o intermedia que, como se indicó implica dos cosas.

§96. Primero, para su desvinculación el nominador solo debe motivar el acto administrativo exponiendo las razones de la decisión, como una garantía mínima derivada del derecho fundamental al debido proceso y al principio de publicidad¹¹². En todo caso, dicha desvinculación solo puede darse por causales legales, como la calificación de desempeño para esta modalidad de servidores, la comisión de faltas disciplinarias, la cesación de la situación que generó la vacancia o la provisión del cargo en propiedad por concurso de

¹¹⁰ Sentencia T-443 de 2022. M.P. Diana Fajardo Rivera.

¹¹¹ Sentencias T-443 de 2022. M.P. Diana Fajardo Rivera; T-063 de 2022. M.P. Alberto Rojas Ríos; T-464 de 2019. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo; T-373 de 2017. M.P. Cristina Pardo Schlesinger; SU-556 de 2014. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y SU-917 de 2010. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

¹¹² Sentencia T-063 de 2022. M.P. Alberto Rojas Ríos, T-373 de 2017. M.P. Cristina Pardo Schlesinger; SU-556 de 2014. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, entre otras.

méritos¹¹³. Segundo, y como se indicó previamente, en este último evento los derechos de las personas nombradas en provisionalidad ceden frente a aquella persona que ganó el concurso de méritos.

§97. Sin perjuicio de esto, la Corte ha reconocido un trato preferencial para sujetos de especial protección constitucional que ocupan un cargo en provisionalidad, como (i) las madres y padres cabeza de familia, (ii) las personas próximas a pensionarse, o (iii) quienes estén en una situación de discapacidad o debilidad manifiesta por causa de una enfermedad¹¹⁴. Si bien por esa sola circunstancia no se les otorga un derecho indefinido a permanecer en ese tipo de vinculación laboral en virtud del derecho ostentado por las personas que acceden por concurso de méritos, sí surge una obligación jurídico constitucional (art. 13) de propiciar un trato preferencial como medida de acción afirmativa¹¹⁵.

§98. Por lo anterior, la entidad nominadora debe adoptar medidas afirmativas dirigidas a proteger los derechos de los citados sujetos de especial protección constitucional. Estas medidas consisten en garantizar (a) que sean los últimos en ser removidos de sus cargos; y (b) que, en lo posible, sean vinculados de manera provisional en cargos vacantes de la misma jerarquía o equivalencia a los que venían ocupando. Esto, “siempre y cuando demuestren una de esas condiciones especiales al momento de su desvinculación y al momento del posible nombramiento”¹¹⁶, tal como se indicó en la Sentencia T- 373 de 2017. En otras palabras, la vinculación provisional en un nuevo cargo vacante requiere que se demuestre alguna circunstancia que implique especial protección constitucional al momento de su desvinculación y en la época del posible nombramiento.

¹¹³ Sentencia T-245 de 2007. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

¹¹⁴ Sentencias T-063 de 2022. M.P. Alberto Rojas Ríos; T-342 de 2021. M.P. Cristina Pardo Schlesinger; T-464 de 2019. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo; T-373 de 2017. M.P. Cristina Pardo Schlesinger; C-640 de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa; y SU-917 de 2010. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

¹¹⁵ Sentencia T-373 de 2017. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

¹¹⁶ *Ibidem*.

§99. Dado que, en el presente caso, la Sala abordará problemas jurídicos relacionados con la *estabilidad laboral relativa* de servidores públicos en provisionalidad por encontrarse en una situación de discapacidad o debilidad manifiesta por causa de una enfermedad, o al tener la calidad de pre pensionados, en las siguientes líneas se expondrán los criterios definidos sobre cada supuesto.

a) La protección especial de los funcionarios nombrados en provisionalidad cuando se encuentran en situación de debilidad manifiesta por razones de salud

§100. Esta Corte ha indicado que “dentro de las personas que ocupan un cargo de carrera en provisionalidad, pueden encontrarse *sujetos de especial protección constitucional* (...) como las personas que se encuentran en situación de discapacidad o en debilidad manifiesta por causa de una enfermedad”¹¹⁷. Por lo tanto, los nominadores deben adelantar acciones afirmativas dirigidas a garantizar sus derechos fundamentales¹¹⁸. Ello se fundamenta en los mandatos contenidos en los incisos 2º y 3º del artículo 13 superior, relativos a la adopción de medidas de protección a favor de grupos vulnerables y personas en condición de debilidad manifiesta¹¹⁹.

§101. Además, esta *protección especial relativa* derivada de la debilidad manifiesta por motivos de salud apunta a garantizar la continuidad en la prestación del servicio de salud en aquellos servidores nombrados en provisionalidad que, al momento de la desvinculación atraviesen una situación especial de salud. Dicha estabilidad relativa por razones de salud reconocida a favor de los servidores públicos vinculados en provisionalidad ha sido objeto de análisis de esta Corte en diferentes decisiones, como las sentencias T- 462 de 2011, T -373 de 2017, T- 464 de 2019, T-342 de 2021 y T- 063 de 2022; las cuales, se referencian brevemente en las siguientes líneas.

¹¹⁷ Sentencia T- 464 de 2019. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

¹¹⁸ Sentencia T-613 de 2011. M.P. Mauricio González Cuervo.

¹¹⁹ Sentencia T-373 de 2017. M.P. Cristina Pardo Schlesinger. S.V. Alberto Rojas Ríos.

§102. En primer lugar, mediante la Sentencia T-462 de 2011¹²⁰ la Corte se refirió a la protección del derecho fundamental al trabajo de una mujer que, aunque no tenía un cáncer activo, debía seguir un tratamiento muy estricto para controlar su enfermedad¹²¹ y que se encontraba en un cargo en provisionalidad en la Rama Judicial. La accionante había sido retirada del servicio porque era necesario nombrar a una persona en propiedad en su cargo, pues esta última había ganado el respectivo concurso de méritos. La Corte ordenó reubicar a la accionante en un cargo similar o equivalente al que venía ocupando, y señaló que en el caso de que no hubiese un cargo vacante, el Consejo Seccional de la Judicatura debía emprender las acciones necesarias para garantizar la vinculación a la seguridad en social en salud, para que la mujer pudiese continuar con su tratamiento, hasta que le fuese reconocida u pagada su pensión de invalidez o jubilación¹²².

§103. Posteriormente, en la Sentencia T-373 de 2017¹²³, la Sala Séptima de Revisión analizó la desvinculación de una ciudadana que tenía cáncer de mama y que desempeñaba un cargo de docente en provisionalidad en una institución educativa del municipio de Tumaco (Nariño). Dado que el retiro de la actora se fundamentó en el nombramiento de la persona que ocupó el primer lugar en la lista de elegibles, la Sala consideró que si bien no se configuró un despido por motivos discriminatorios, la entidad demandada debió prever alguna medida afirmativa para no lesionar los derechos de la accionante, quien por su delicado estado de salud, generado por el cáncer de mama que le fue diagnosticado en 2014, venía siendo objeto de tratamiento médico tendiente a la recuperación de su salud. Por ello, se ordenó que la actora fuese vinculada en un cargo vacante y, en caso de que no hubiese una

¹²⁰ Sentencia T-462 de 2011. M.P. Juan Carlos Henao Pérez.

¹²¹ En este caso, la Sala indicó lo siguiente respecto del estado del cáncer de la accionante: “Actualmente la enfermedad se encuentra controlada pero la accionante debe seguir un tratamiento médico muy estricto que implica la constante toma de placas, radiografías, ecografías, mamografías y exámenes de laboratorio que tienen el fin de establecer que el cáncer no se haya trasladado a otro órgano”.

¹²² La entonces accionante había acreditado cotizaciones equivalentes más de 20 años de servicio, pero no tenía la edad de los 55 años requerida por el régimen de transición de la Ley 33 de 1985, ya que para el momento en el que la Corte realizó el estudio del caso ella tenía 53 años de edad.

¹²³ Sentencia T-373 de 2017. M.P. Cristina Pardo Schlesinger. S.V. Alberto Rojas Ríos.

plaza disponible, se ordenó al Municipio de Tumaco a “afiliar a la accionante al Sistema de Seguridad Social en Salud, hasta tanto finalicen los tratamientos que sean necesarios para la recuperación del cáncer que padece o sea afiliada al sistema por otro empleador”.

§104. Luego, en la Sentencia T-464 de 2019¹²⁴, la Sala Quinta de Revisión estudió el caso de una mujer nombrada en provisionalidad en el ICBF, quien fue desvinculada debido al nombramiento de la persona que ganó el concurso de méritos, cuando se encontraba enferma y estaba en curso una incapacidad médica¹²⁵. En esa oportunidad, la Corte ordenó nombrar a la actora en un cargo igual o equivalente al que ocupaba antes de su retiro en el evento de que hubiera vacantes disponibles. Además, se destaca que en este caso el juez de tutela de primera instancia ordenó al ICBF continuar con el pago de las cotizaciones al sistema de seguridad social en salud para que la actora pudiese continuar con el tratamiento médico que venía adelantando. No obstante, la Sala estimó que “no existe vínculo laboral que obligue al ICBF a realizar la respectiva vinculación y cotización al sistema” y, además, agregó que no era viable ordenar esto, por las siguientes razones: (i) esa no fue la pretensión expuesta en el escrito de tutela; (ii) la accionante expresamente indicó que estaba inconforme con dicha alternativa y (iii) la Sala verificó que se encontraba afiliada al régimen contributivo en calidad de cotizante.

§105. Más adelante, en la Sentencia T-342 de 2021¹²⁶, la Sala Séptima de Revisión estudió el caso de una acción de tutela interpuesta por una docente vinculada en provisionalidad en contra de la Secretaría de Educación del municipio de Fusagasugá, tras haberla desvinculado de su empleo con el fin de nombrar a otra persona que había ganado un concurso de méritos. Como hecho particular, al momento de la desvinculación, la accionante se encontraba con incapacidad vigente y, además, la notificación del acto administrativo que la desvinculaba se realizó tres años después de su expedición. En el caso en concreto, la Sala ordenó a la Secretaría de Educación de Fusagasugá (i) que vinculara a la accionante en forma provisional, en un cargo de igual rango y remuneración al que ocupaba,

¹²⁴ Sentencia T- 464 de 2019. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

¹²⁵ La entonces accionante había sido incapacitada por trastorno mixto de ansiedad y depresión.

¹²⁶ M.P. Cristina Pardo Schlesinger. A.V. Alberto Rojas Ríos. S.P.V. José Fernando Reyes Cuartas.

solamente en el evento de que hubiese un cargo vacante que cumpliera con esas características y (ii) que iniciará las actuaciones necesarias para que la accionante fuese vinculada al Sistema de Seguridad Social en Salud, hasta que sea afiliada por otro empleador.

§106. Posteriormente, en la Sentencia T-063 de 2022¹²⁷, la Sala Novena de Revisión analizó la tutela presentada por dos adultas mayores de 60 y 63 años que tenían un porcentaje de pérdida de capacidad laboral superior al 50%. La tutela se interpuso contra la Alcaldía de Ábrego (Norte de Santander), por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, a la seguridad social y al mínimo vital al terminarse su nombramiento provisional en virtud del nombramiento en propiedad de las personas elegidas en el concurso público de méritos que ofertó las vacantes que ocupaban los accionantes. La Sala evidenció que la entidad territorial no acreditó la adopción de medidas afirmativas, por lo que, se decidió amparar transitoriamente los derechos invocados por los accionantes. En consecuencia, se ordenó que únicamente en el evento de existir vacantes disponibles se vinculara a las accionantes a un cargo igual o equivalente al que ocupaban.

§107. *Conclusión.* En suma, al resolver la tensión entre los derechos de carrera de quien ganó un concurso de méritos y una persona nombrada en provisionalidad que cuenta con alguna afectación a su salud, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha adoptado la decisión de negar la protección a la *estabilidad laboral relativa* de estos últimos; toda vez que, prevalecen los derechos de las personas que fueron elegidas para ocupar las vacantes ofertadas a través de un concurso de méritos.

§108. Sin embargo, la Corte ha analizado si la entidad nominadora adoptó acciones afirmativas dirigidas a reubicar a las personas en provisionalidad que fueron desvinculadas, siempre que al momento del retiro del servicio se encuentren en una situación de debilidad manifiesta por motivos de salud. Si la entidad no procedió de dicha forma, la Corte ha ordenado a las entidades que, en la medida de lo posible y ante la existencia de nuevas vacantes, vinculen de nuevo a estas personas y, además, ha ordenado a las entidades públicas nominadoras realicen el pago de las cotizaciones al Sistema General

¹²⁷ Sentencia T- 063 de 2022. M.P. Alberto Rojas Ríos.

de Seguridad Social (SGSS) en salud para que los accionantes puedan continuar con el tratamiento médico que venían adelantando.

b) Estabilidad laboral de las personas próximas a pensionarse (prepensionados) frente a la lista de elegibles. Reiteración de jurisprudencia

§109. La calidad de pre pensionado de los servidores públicos nombrados en provisionalidad es otra de las situaciones que las autoridades administrativas deben tener en cuenta al momento de su desvinculación, cuando está se deriva del cumplimiento de una lista de elegibles proferida en el marco de un concurso de méritos. En estos escenarios también se presenta una tensión importante entre quien alega estar próximo a tener la calidad de pensionado y, por lo tanto, depende de dicha vinculación para lograr tal estatus y la persona que tras haber sido seleccionada en un concurso público, logró obtener la respectiva vacante gracias a su mérito.

§110. Con todo, al igual que con las personas vinculadas en provisionalidad que tienen una situación de salud especial, por lo menos desde la Sentencia SU-897 de 2012¹²⁸ la Corte ha precisado que las personas pre pensionadas también son *sujetos de especial protección constitucional*. Esa Corte, entre otras, en las sentencias T- 186 del 2013¹²⁹ y T-595 de 2016¹³⁰ han indicado que “la estabilidad laboral de los *prepensionados* tiene origen constitucional y, por ende, resulta aplicable en cada uno de los escenarios en que entren en tensión los derechos al mínimo vital y la igualdad, frente a la aplicación de herramientas jurídicas que lleven al retiro del cargo, entre ellas el concurso público de méritos”¹³¹. Por ello, en la medida de lo posible, las personas pre pensionadas deben ser sujetos de acciones afirmativas¹³².

¹²⁸ Sentencia SU-897 de 2012. M.P. (E) Alexei Julio Estrada. A.V. María Victoria Calle Correa.

¹²⁹ Sentencia T-186 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

¹³⁰ Sentencia T-595 de 2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo. S.V.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

¹³¹ *Ibidem*.

¹³² Sentencia SU-003 de 2018. M.P. Carlos Bernal Pulido. A.V. Alberto Rojas Ríos.

§111. Esta protección especial se concreta en: (i) tomar medidas para que esos servidores sean los últimos en ser desvinculados de sus cargos; y, (ii) garantizar que si existen cargos en vacancia definitiva similares o equivalentes a los que venían ocupando, se nombren a las personas pre pensionadas en esos cargos mientras se proveen a través del concurso de méritos y hasta que logren cumplir los requisitos para obtener su pensión de vejez.

§112. En la Sentencia SU- 003 de 2018¹³³ la Corte unificó las reglas jurisprudenciales que conceden a un servidor público la calidad de pre pensionado. En esta decisión se determinó que son beneficiarios del fuero de estabilidad laboral de prepensionable las personas vinculadas laboralmente al sector público y/o privado a los que les falten lo equivalente a tres años o menos (es decir, 154,44 semanas de cotización o menos¹³⁴) para acreditar el requisito de semanas en el régimen de prima media o el capital necesario en el régimen de ahorro individual con solidaridad, para acceder a la pensión de vejez. En otras palabras, esta Corporación estableció que cuando el único requisito faltante para acceder a la pensión es la edad, en caso de desvinculación, no se frustra su derecho al acceso a la pensión. Esto, porque dicho requisito puede acreditarse de manera posterior, con o sin vinculación laboral.

§113. Ahora bien, para entender como aplica esta regla al caso de los servidores nombrados en provisionalidad, se debe partir por recordar el carácter relativo de la estabilidad laboral que ostentan. En ese contexto, los servidores públicos nombrados en provisionalidad que tengan la calidad de pre pensionados deben ser sujetos de un trato preferencial por parte de la autoridad nominadora que se traduce en que esta deberá prodigarles un trato preferencial, en el sentido de adoptar las medidas necesarias para que sean los últimos en ser desvinculados y, que si existen vacantes en cargos equivalentes a los que venían ocupando, los nombre en provisionalidad mientras se realiza un nuevo concurso. En todo caso, se resalta que las entidades públicas deben cumplir con estas cargas, siempre “en la medida de sus posibilidades”.

¹³³ *Ibidem*.

¹³⁴ Sentencia T- 253 de 2023. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo. S.V. Cristina Pardo Schlesinger.

§114. *Conclusión.* Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala concluye que las personas pre pensionadas son *sujetos de especial protección constitucional*¹³⁵. Por ello, en la medida de lo posible, estas personas deben tener una protección que se deriva de la expectativa que estos trabajadores tienen de obtener su pensión. En esa línea, para validar si se ha brindado o no esa protección especial, la Corte ha analizado si la entidad nominadora (i) motivó el acto de desvinculación, (ii) tenía conocimiento de la condición de pre pensionado del accionante y (iii) si adoptó algún tipo de acciones afirmativas para garantizar que estas personas fueran las últimas en ser removidas de sus cargos o se les hubiese trasladado a otra vacante disponible y similar a la que ocupaban con el objetivo de garantizar su acceso a la pensión de vejez. En los casos en los que la Corte evidenció que la entidad nominadora no adoptó acciones afirmativas, ordenó que en la medida de las posibilidades se realizara la vinculación de estas personas, limitándola al tiempo necesario para lograr las semanas de cotización requeridas para obtener su pensión de vejez.

3.3 El régimen pensional de los docentes de colegios públicos afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)

§115. De conformidad con el artículo 48 de la Constitución Política, la seguridad social es un servicio público obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, *en los términos que establezca la ley*. En desarrollo del referido mandato constitucional, el Legislador adoptó la Ley 100 de 1993¹³⁶, con el propósito de introducir un sistema unificado de seguridad social¹³⁷ para brindar cobertura integral en todo lo relacionado con las contingencias en materia de salud y el reconocimiento pensional.

No obstante, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó del sistema integral de seguridad social contenido en esa norma, entre otros, a los afiliados al FOMAG.

¹³⁵ Sentencia T- 052 de 2023. M.P. Juan Carlos Cortés González.

¹³⁶ "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones".

¹³⁷ Sentencia C- 415 de 2014. M.P. Alberto Rojas Ríos.

§116. En consecuencia, los afiliados al Magisterio se encuentran excluidos de la Ley 100 de 1993 y se regulan por lo dispuesto en la Ley 91 de 1989¹³⁸. A su vez, en el artículo 15 de la citada Ley 91 de 1989 se estableció la aplicación de dos marcos normativos diferenciados que dependían de si la fecha de vinculación de los docentes nacionales había sido antes o después del 31 de diciembre de 1989¹³⁹.

§117. Posteriormente, la Ley 60 de 1993¹⁴⁰ asignó la administración de los servicios educativos estatales a los municipios en conjunto con los departamentos. Teniendo en cuenta esta descentralización de funciones, en el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 se dispuso la incorporación del personal docente de los órdenes departamental distrital y municipal al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), así como la conservación del régimen prestacional anterior, mientras que a las nuevas vinculaciones se les aplicaría la citada Ley 91 de 1989.

§118. Luego, el artículo 81 de la Ley 812 de 2003¹⁴¹ (expedida el 26 de junio de 2003) realizó una modificación importante respecto del régimen pensional aplicable a los docentes de las diferentes categorías (nacionales, nacionalizados y territoriales). Tales disposiciones prevén un doble régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, según si su fecha de vinculación fue anterior o no a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. Así, a los docentes vinculados al servicio público educativo oficial después del 27 de junio de 2003 –fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 del 2003– se les aplicaría el régimen pensional de prima media; mientras que, a aquellos vinculados con anterioridad a dicha fecha, se les

¹³⁸ “Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”.

¹³⁹ De conformidad con este artículo, a los docentes nacionales vinculados a partir del 1º de enero de 1990, se les reconoce una pensión de jubilación bajo el régimen general pensional del sector público, que estuvo regulado por los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el reconocimiento se efectúa de conformidad con el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial, de conformidad con las normas vigentes.

¹⁴⁰ “Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”.

¹⁴¹ “Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario”.

aplicará el régimen establecido para el magisterio en las normas vigentes. De conformidad con el Consejo de Estado¹⁴² este régimen corresponde a aquel previsto en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985¹⁴³.

§119. Esta lectura fue corroborada mediante el Acto legislativo 1 de 2005, y objeto de una unificación jurisprudencial de la Sección Segunda del Consejo de Estado en el año 2019¹⁴⁴.

§120. *Conclusión.* Conforme a la Constitución y la Ley 100 de 1993, la seguridad social es un servicio público obligatorio. Sin embargo, se exceptúan de este sistema a los docentes afiliados al FOMAG. Ahora bien, actualmente, el régimen pensional aplicable a los docentes depende de si su fecha de vinculación al servicio público educativo oficial ocurrió antes o después de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2023). Los docentes vinculados antes de esa fecha se acogen al régimen establecido en la Ley 33 de 1985, mientras que aquellos vinculados después se rigen por los requisitos del régimen de prima media con los derechos pensionales establecidos en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con una edad de pensión fijada en 57 años para ambos géneros.

3.4 El cáncer y la necesidad de garantizar una cobertura en salud a los sobrevivientes

§121. El cáncer es una enfermedad catastrófica que involucra un rápido deterioro en la salud del paciente si no es diagnosticada y tratada a tiempo. Sin pretender invadir las competencias propias de otras áreas del conocimiento, la jurisprudencia constitucional ha señalado que conforme a las reglas de la experiencia y de la lógica, se sabe que el cáncer es una enfermedad que afecta

¹⁴² Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 11 de mayo de 2023. Expediente 68001-23-33-000-2019-00830-01 (1340-2022). 11 de mayo de 2023. CP. Jorge Iván Duque Gutiérrez.

¹⁴³ “Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las cajas de previsión y con las prestaciones sociales para el sector público”.

¹⁴⁴ Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-CE-S2 -2019. Expediente: 680012333000201500569-01 (0935-17).

múltiples aspectos de la vida de quienes la padecen; más allá de su salud, sus actividades diarias y cotidianas pueden verse comprometidas como consecuencia del tratamiento al que deben someterse. Dicho diagnóstico implica una afectación que dificulta significativamente el normal y adecuado desempeño de las actividades en el trabajo¹⁴⁵.

§122. Bajo ese supuesto, los pacientes con cáncer han sido reconocidos como *sujetos de especial protección constitucional* por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, entre otras, en las Sentencias T- 387 de 2018¹⁴⁶ y T-232 de 2022¹⁴⁷ y por parte del Legislador en la reciente Ley 2360 de 2024¹⁴⁸. En dicha normatividad se estableció que (i) el cáncer es una enfermedad de interés en materia de salud pública y de prioridad nacional para la Republica de Colombia, y (ii) se indicó que quienes tengan sospecha o sean son diagnosticados con esta enfermedad son sujetos de especial protección constitucional¹⁴⁹.

§123. En reciente decisión T-326 de 2024¹⁵⁰, esta misma Sala Tercera de Revisión, al analizar el caso de una mujer que se encontraba diagnosticada con cáncer de mama, explicó que existen padecimientos de salud que tienen mayor incidencia en las mujeres, y que estudios epidemiológicos han identificado una asociación de ese tipo de canceres con algunas profesiones, dentro de las cuales se encuentran las docentes. Así mismo, dicha decisión identificó la dificultad que las mujeres que han tenido ese tipo de diagnósticos enfrentan al retornar al trabajo, lo que se suma al deterioro que también padecen las familias en sus finanzas. Por ello, se destacó la necesidad de integrar un enfoque de género al momento de evaluar esta desigualdad estructural y

¹⁴⁵ Sentencia T-386 de 2020. M.P. Diana Fajardo Rivera. S.P.V. Richard Ramírez Aguilar (E). A.V. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

¹⁴⁶ Sentencia T- 387 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

¹⁴⁷ Sentencia T- 232 de 2022. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. S.V. José Fernando Reyes Cuartas.

¹⁴⁸ “Por medio de la cual se modifica y adiciona la Ley 1384 de 2010 reconociendo para los efectos de esta Ley como sujetos de especial protección constitucional a las personas con sospecha o que padecen cáncer”.

¹⁴⁹ Artículo 5 de la Ley 2360 de 2024.

¹⁵⁰ Sentencia T- 326 de 2024. M.P. Diana Fajardo Rivera.

sistémica y adoptar medidas adecuadas para garantizar sus derechos fundamentales.

§124. En consecuencia, las personas que padecen cáncer u otras enfermedades catastróficas tienen el derecho a acceder a una atención integral en salud que incluya la prestación de todos los servicios y tratamientos que requieren para su recuperación, sin que medie obstáculo alguno¹⁵¹. Esta integralidad significa que la atención en salud que se les brinde debe contener “todo cuidado, suministro de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de rehabilitación, exámenes para el diagnóstico y el seguimiento, así como todo otro componente que el médico tratante valore como necesario para el pleno restablecimiento de la salud del paciente o para mitigar las dolencias que le impiden llevar su vida en mejores condiciones”¹⁵².

§125. Para el caso del cáncer, es necesario considerar que aunque inicialmente esta enfermedad está llamada a ser tratada con el fin de que no cause efectos permanentes en la salud de las personas, son muchos sus efectos colaterales. En reconocimiento de esto, la Red Nacional Integral del Cáncer de los Estados Unidos (NCCN) se ha encargado de emitir lineamientos para tratar a las personas que se consideran sobrevivientes del cáncer. Según este Instituto “los sobrevivientes del cáncer son personas viviendo con cáncer o aquellos libres de cáncer. La supervivencia comienza al mismo tiempo del diagnóstico del cáncer y continua a través de la vida”¹⁵³. En efecto, “se considera que un superviviente de cáncer es un individuo que ha completado una terapia con intención curativa, con atención continua centrada en la vigilancia, la prevención de los efectos adversos relacionados con el tratamiento y los tratamientos de mantenimiento, como la terapia endocrina”¹⁵⁴.

¹⁵¹ Sentencia T-066 de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

¹⁵² Sentencia T- 387 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

¹⁵³ National Comprehensive Cancer Network. “*Survivorship Care for Cancer- Related Late and Long Term Effects*”. Marzo de 2024, p. 7. (En línea). Disponible en: <https://www.nccn.org/patients/guidelines/content/PDF/survivorship-crl-patient.pdf> . Consultado el 12 de agosto de 2024.

¹⁵⁴ Consejo de Medicina NR. “*De paciente de cáncer a superviviente de cáncer: perdido en la transición*”. The National Academies Press; 2006.

§126. A su vez, dentro del estándar de cuidados que se deben tener con los sobrevivientes de cáncer, el NCCN destaca los siguientes: “testeo rutinario para identificar el eventual regreso del cáncer (vigilancia) o nuevos cánceres (cribado), testeo rutinario para analizar los efectos a corto y largo plazo del cáncer y de su tratamiento, prevención de efectos dañinos del cáncer y de su tratamiento, manejo de cambios relacionados con el cáncer y planificación para la atención continua de supervivencia”¹⁵⁵.

§127. Sin embargo, recientemente también se ha evidenciado que pueden existir eventos aún más particulares, en donde el cáncer no logra ser erradicado del cuerpo y quienes han sido diagnosticados con esta enfermedad deben vivir con ella durante años, convirtiéndose en una enfermedad crónica¹⁵⁶ de estos pacientes. Esta es una nueva población de sobrevivientes que corresponde a “personas que viven con un cáncer incurable y que viven durante años mientras reciben tratamientos crónicos”¹⁵⁷.

§128. Esto se debe a que, “aunque hace algunos años los tratamientos de quimioterapia aplicados frente a cánceres avanzados rara vez extiendan la vida más allá del año (...) hoy en día los avances en oncología molecular ofrecen una mejor comprensión de los impulsores de la malignidad¹⁵⁸”, permitiendo garantizar una extensión en la vida de estos pacientes. A partir de allí, se ha creado el concepto de los *pacientes en remisión* que según la Sociedad Americana del Cáncer corresponde a “un periodo de tiempo en el que el

¹⁵⁵ National Comprehensive Cancer Network. “*Survivorship Care for Cancer- Related Late and Long Term Effects*”. Marzo de 2024, p. 8.

¹⁵⁶ De conformidad con la Academia Canadiense de las Ciencias de la Salud, una enfermedad crónica se considera una “enfermedad que puede desarrollarse lentamente, durar mucho tiempo (de meses a años), ser incurable y ser progresiva y/o limitar la vida. Algunos ejemplos de tales afecciones incluyen artritis, enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia cardíaca, diabetes, demencia, VIH/SIDA, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica y algunas formas de cáncer”. ACADEMIA CANADIENSE DE CIENCIAS DE LA SALUD. “Transformar la atención para los canadienses con enfermedades crónicas: poner a las personas primero, esperar lo mejor, gestionar para obtener resultados. Ottawa, Ontario”. 2010. <https://www.caahs-acss.ca/wp-content/uploads/2011/09/cdm-final-English.pdf>.

¹⁵⁷ PITUSKIN, Edith. “*Cancer as a new chronic disease: Oncology nursing in the 21st Century*”. 2022 Feb 1;32(1):87-92. PMID: 35280062; PMCID: PMC8849169.

¹⁵⁸ *Ibidem*.

cáncer está respondiendo al tratamiento o está controlado. Algunas personas consideran que la remisión significa que la persona se ha curado del cáncer, pero puede que ese no sea el caso pues (...) la remisión puede durar meses o años”¹⁵⁹.

§129. Por ello, frente a eventos en los que el cáncer se torna como una enfermedad crónica, se debe “estar atento a las necesidades psicosociales y físicas del paciente; explorar las preocupaciones y prioridades del paciente para la atención y legitimar sus experiencias; desarrollar una asociación entre el paciente y el equipo de atención, y facilitar la participación activa del paciente en la toma de decisiones”¹⁶⁰. A su vez, la comprensión de esta situación también se extiende a escenarios como el jurídico, en donde se debe contar con herramientas que garanticen la protección del derecho fundamental a la salud de los sobrevivientes de cáncer y de aquellas personas que viven esta enfermedad como una patología crónica.

4. Análisis de los casos concretos

4.1 Expediente T-10.121.578. La Secretaría de Educación de Florencia no vulneró los derechos fundamentales de Lorena

§130. La Sala considera que de conformidad con los hechos probados en el proceso T-10.121.578 no es posible considerar que la Secretaría de Educación de Florencia haya vulnerado los derechos fundamentales a la vida, al trabajo, a la salud, a la igualdad de oportunidad, a la no discriminación, a la remuneración mínima vital y móvil y a la estabilidad laboral relativa de *Lorena*. Esto, por cuanto dicha Secretaría acreditó que brindó, en la medida de sus posibilidades, importantes alternativas para extender la vinculación en provisionalidad de *Lorena* dada la especial situación de salud que le aquejó

¹⁵⁹ AMERICAN CANCER SOCIETY. ¿Se puede curar el cáncer? 6 de mayo de 2021. (En línea). Disponible en: <https://www.cancer.org/es/cancer/entendimiento-del-cancer/es-el-cancer-una-enfermedad-curable.html>. Consultado el 11 de septiembre de 2024.

¹⁶⁰ PITUSKIN, Edith. “Cancer as a new chronic disease: Oncology nursing in the 21st Century”. 2022 Feb 1;32(1):87-92. PMID: 35280062; PMCID: PMC8849169.

durante varios de los años que estuvo vinculada a dicha Secretaría y que actualmente presenta.

§131. Para soportar esta conclusión, la Sala considera necesario hacer referencia a (i) la situación de salud de *Lorena* y a (ii) las acciones desplegadas por la Secretaría de Educación de Florencia frente a sus solicitudes y frente a la posibilidad de reconocerle una *estabilidad laboral relativa* por su estado de salud.

§132. *Sobre la situación de salud de Lorena.* Dado que uno de los principales hechos que la accionante alega para justificar sus afectaciones en la salud consiste en el cáncer de endometrio que le fue diagnosticado en el 2017, esto es, hace cerca de siete años, la Sala estima pertinente exponer en el siguiente cuadro un recuento con los principales diagnósticos y procedimientos practicados a *Lorena* desde el año 2017 a la fecha¹⁶¹. Esto, de conformidad con la historia clínica allegada por la accionante y por la EPS FAMAC:

Cuadro 1. Principales diagnósticos y tratamientos realizados a *Lorena* (2017 – 2024)

No.	Fecha	Diagnostico o procedimiento
1	7 de julio de 2017	<i>Lorena</i> fue diagnosticada con tumor maligno de endometrio ¹⁶² .
2	Mayo y septiembre de	Se le realiza cirugía de histerectomía y re clasificatoria laparoscópica para tratar cáncer de

¹⁶¹ Vale la pena resaltar que este cuadro solo recoge los eventos que en criterio de la Sala se consideran más relevantes para analizar las afectaciones de salud que ha tenido *Lorena* durante este periodo; toda vez que, la historia clínica de *Lorena* se compone de más de 200 folios en los que se detallan otros múltiples procedimientos y exámenes realizados a la accionante pero que, en términos generales, están asociados a los principales diagnósticos identificados.

¹⁶² Expediente digital T-10.121.578. Archivo “03Anexos.pdf”, p. 9. Informe patológico del Instituto Nacional de Cancerología del 7 de julio de 2017. El diagnóstico es el siguiente: “*adenocarcinoma endometroide de endometrio bien diferenciado figo 1, grado nuclear2, sin invasión al miometro*”.

	2017	endometrio a <i>Lorena</i> ¹⁶³
3	15 de enero de 2019	<i>Lorena</i> fue intervenida quirúrgicamente de un tumor benigno en el glúteo izquierdo ¹⁶⁴ .
4	8 de agosto de 2020	Medico revisa mamografía ¹⁶⁵ de <i>Lorena</i> en la que identifica una masa en el seno derecho
5	24 de abril de 2021	Se realiza una ultrasonografía diagnóstica de mama con transductor en la que se constató que el nódulo en la mama derecha de <i>Lorena</i> permanecía estable ¹⁶⁶ .
6	19 de noviembre de 2021	Se le extirpan dos nevos (lunares) a <i>Lorena</i> en el mentón y en su nariz ¹⁶⁷ .

¹⁶³ Expediente digital T-10.121.578. Archivo “*Respuesta auto de pruebas- Lorena.pdf*” p. 60.

¹⁶⁴ Expediente digital T-10.121.578. Archivo “*024 Rta. FAMAC LTDA.pdf*”, pp. 158-159. Reporte de epicrisis de Corpomedica del Caquetá cuyo diagnóstico pos operatorio es el siguiente: “*D172- Tumor benigno lipomatoso de piel y de tejido subcutáneo de miembros (...) Hallazgos: quiste en glúteo izquierdo*”

¹⁶⁵ Como antecedentes relevantes de dicha mamografía se destaca que (i) el 11 de octubre de 2019 en un control médico cáncer endometrio realizado a *Lorena*, se indicó lo siguiente “Análisis. No signos de recurrencia por cáncer endometrial. PLE 2.5 años. screening mamográfico no satisfactorio por nodularidad. Plan tratamiento: Control por ginecología oncológica en abril de 2020 con eco abdomen total, rx tórax y eco mamaria”. Luego (ii), el 1 de agosto de 2020 en un control oncología médica se estableció lo siguiente: “Eco mamaria (31/07/2020); nódulo sólido ovalado y lobulado de 14.8x8.1 mm en CSE de mama derecha, posible fibroadenoma. Tratamiento y recomendaciones. Paciente con historial anotado sin signos de recidiva/progresión Se contralará nódulo mamario derecho en 6 meses con nueva ecografía mamaria. SS uro análisis y CCV. SS eco pélvica en 6 meses”. Expediente digital T-10.121.578. Archivo “*Respuesta auto de pruebas- Lorena.pdf*”, pp. 61- 65.

¹⁶⁶ Expediente digital T-10.121.578. Archivo: “*024 Rta. FAMAC LTDA.pdf*”, p. 173. Exámenes del 24 de febrero de 2021 en el que se indicó que “persiste nódulo solido ovalado de bordes bien definidos relacionado con fibroadenoma en el radial 10 de la mama derecha estable al comparar con estudio previo”.

¹⁶⁷ Expediente digital T-10.121.578. Archivo “*Respuesta auto de pruebas- Lorena.pdf*”, p. 69. En este documento se menciona lo siguiente: “Diagnóstico. dos lesiones tumorales de aspecto nevico, una en el mentón y la otra de aspecto perlado nivel saio palpebral izquierdo dese su nacimiento. Tratamiento. Se realiza extirpación quirúrgica de dos lesiones tumorales de aspecto nevico (...)”.

7	7 de abril de 2022	Consulta médica de control en la que se establece que <i>Lorena</i> lleva 5 años sin cáncer y que se trata de una enfermedad de bajo riesgo de presentar recurrencias. También se indica que presenta una diabetes sin tratamiento ¹⁶⁸ .
---	--------------------	---

¹⁶⁸ Expediente digital T-10.121.578. Archivo “024 Rta. FAMAC LTDA.pdf”, p. 180. En la historia clínica se indica lo siguiente: “Análisis: intervalo libre de progresión por cáncer endometrial: 5 años, enfermedad con bajo riesgo de presentar recurrencias. Diabetes de novo sin tratamiento”.

8	23 de febrero de 2024	Ecografía en la que se encuentran adenopatías de aspecto inflamatorio en la axila izquierda de <i>Lorena</i> ¹⁶⁹ .
9	19 de marzo de 2024	Última historia clínica ¹⁷⁰ . De este documento, la Sala resalta que (i) <i>Lorena</i> ha tenido controles regulares sobre el cáncer de endometrio que sufrió 7 años atrás y que han arrojado que no tiene signos de recurrencia; (ii) tuvo una ecografía de abdomen negativa para malignidad con fecha del 19 de abril de 2023, pero en otra ecografía posterior del 19 de marzo de 2024 se identificó un “quiste renal simple”; (iii) mediante un TAC de tórax se identificó que no tenía lesiones pulmonares o mediastinales de aspecto secundario; y (iv) reporta

¹⁶⁹ Expediente digital T-10.121.578. Archivo “*Respuesta auto de pruebas- Lorena.pdf*”, p. 12.

¹⁷⁰ Expediente digital T-10.121.578. Archivo “*Respuesta auto de pruebas-Lorena.pdf.*”, p. 15 y “*Respuesta auto de pruebas-FAMAC*”, p. 208. En esta historia clínica se indica lo siguiente:

“Paciente de 51 años (...) con antecedente de adenocarcinoma de endometrio estado pT 1A NxM0 tratado con anexo histerectomía total en mayo de 2017. Controles regulares negativos (...)

1. El 19 de abril de 2023. Eco abdomen total negativo para malignidad.
2. 20 de abril de 2023. Valoración ginecoconco. Paciente con adenocarcinoma endometrial estado 1A tratamiento quirúrgico hace seis años (2017), sin signos de recurrencia loco regional. Imágenes control informan nódulo mediastinal a caracterizar mediante tomografía.

Acude el 9 de octubre de 2023 reportando:

3. Eco abdomen del 19 de abril de 2023: post-histerectomía. Resto normal
4. TAC tórax del 15 de mayo de 2023. No se observan lesiones pulmonares o mediastinales de aspecto secundario
5. Refiere síntomas urinarios recurrentes que ha requerido dos hospitalizaciones

Acude el 19 de marzo de 2024

6. Eco de abdomen; esteatosis hepática leve, litiasis vesicular. Quiste renal simple derecho
7. Refiere episodios de dolor en la axila izquierda
8. Eco de tejidos blandos de axila izquierda del 23 de febrero de 2024. Adenopatías inflamatorias
9. Análisis: Paciente con historial anotado sin signos de recidiva/progresión”.

		síntomas urinarios recurrentes que ha requerido dos hospitalizaciones.
--	--	--

Fuente: elaboración propia con base en la historia clínica de *Lorena*.

§133. De conformidad con la información extraída de la historia clínica de *Lorena*, la Sala concluye que actualmente es una paciente en remisión de cáncer de endometrio que le fue diagnosticado en el año 2017. El hecho de que sea una paciente en remisión implica, - como se expondrá a continuación- que ella debe estar sometida a constantes controles médicos para hacer seguimiento a su estado de salud y evitar eventuales reapariciones de lesiones cancerígenas.

§134. Como muestra de ello, en la historia clínica se señala que ella lleva ya varios años sin signos de recurrencia de dicho cáncer y además que esta patología presente bajos riesgos de presentar reincidencias; pero, a la vez la Sala también encuentra que desde el año 2017 hasta la fecha, *Lorena* ha estado en controles permanentes con el fin de monitorear su estado de salud.

§135. Como consecuencia de dichos controles ha sido posible diagnosticarle otras afecciones de manera oportuna que, han llevado a intervenciones quirúrgicas, como las siguientes: (i) la extracción de un lipoma o tumor benigno en el glúteo que le fue extraído en el año 2019, y (ii) la extirpación de unos lunares en su mentón y nariz que le fueron operados en el año 2021. Además de ello, dentro de los controles de salud realizados a *Lorena* se han identificado (iii) un nódulo en la mama derecha evidenciado en el año 2020 y al que se le ha venido realizando seguimiento, sin advertirse algún peligro para su vida; (iv) unas adenopatías de aspecto inflamatorio halladas en 2024 y, (v) por último un quiste renal simple, dificultades urinarias y una breve mención a una posible diabetes. Así mismo, esta última historia clínica concluye que *Lorena* es una “[P]aciente con historial anotado sin signos de recidiva/progresión”¹⁷¹.

§136. Así las cosas, aunque según la historia clínica de *Lorena* actualmente ella no es una paciente oncológica si es necesario que por sus antecedentes médicos y

¹⁷¹ *Ibidem*.

los de su familia¹⁷² cuente con un seguimiento permanente que le permita identificar, de manera oportuna, cualquier cambio en su cuerpo que implique una modificación de su diagnóstico actual. Muestra de esto, es como después del año 2017 en el que a *Lorena* se le diagnosticó y trató el cáncer de endometrio, ha presentado otras afectaciones diferentes que han requerido desde intervenciones quirúrgicas hasta exámenes médicos de control.

§137. De hecho, en sus últimos exámenes médicos se ordenan citas de control para septiembre de 2024 e incluso, la misma accionante indicó que con el fin de continuar accediendo a los servicios de salud, de manera temporal, un amigo la afilió al FAMAC, pero que posteriormente la desvinculó¹⁷³. En esa misma línea, *Lorena* sostiene que, aunque pudo conseguir el dinero para comprar los medicamentos ordenados por su médico tratante no tiene “la manera de viajar a Neiva ni pagar el especialista pues [mis] gastos superan [mis] ingresos”¹⁷⁴.

§138. Para la Sala todo lo anterior pone de presente la importancia de garantizar los principios de continuidad, oportunidad y atención integral en el acceso al derecho fundamental a la salud de *Lorena*, establecidos en el artículo 6 de la Ley 1751 de 2015¹⁷⁵ y desarrollados por la jurisprudencia de esta Corte. Como se indicó previamente, esta Corte ha sido clara en afirmar que frente a pacientes con cáncer, dada “su gravedad y complejidad requieren un tratamiento continuo que de modo que la integralidad y la oportunidad en la prestación del servicio de salud en estos casos cobra mayor relevancia y debe cumplirse de forma reforzada, de modo que, no puede sujetarse a dilaciones injustificadas ni prestarse de forma incompleta”¹⁷⁶.

§139. A su vez, este deber no desaparece frente a pacientes que, aunque no cuentan con el diagnóstico de un cáncer activo, si padecieron de dicha enfermedad y pueden ser considerados *pacientes en remisión* que, por lo tanto,

¹⁷² En la historia clínica de *Lorena* se refiere que su mama falleció de un cáncer de seno con metástasis en el cerebro. Expediente digital T-10.121.578. Archivo “025 Rta. *Lorena*.pdf”, p. 57.

¹⁷³ Expediente digital T-10.121.578. Archivo “025 Rta *Lorena*.pdf”.

¹⁷⁴ Expediente digital T-10.121.578. Archivo “025 Rta. *Lorena*.pdf”, p. 4.

¹⁷⁵ “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones”.

¹⁷⁶ Sentencia T- 387 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

deben estar sometidos a rigurosos y permanentes controles de su estado de salud en aras de obtener eventuales diagnósticos negativos, de manera oportuna. Así, como fue expuesto líneas atrás, las personas supervivientes de cáncer deben estar sometidas a un testeo rutinario para identificar el eventual regreso del cáncer o la aparición de nuevos cánceres. En consecuencia, frente a personas que como *Lorena*, la garantía de los principios de continuidad, oportunidad y atención integral se extiende en el tiempo e implica que las autoridades que le garantizaban dichos servicios no puedan suspenderlos de manera imprevista.

§140. *Sobre las actuaciones de la Secretaría de Educación de Florencia.* Teniendo claro la situación de salud de *Lorena*, resulta necesario evaluar las actuaciones desplegadas por la Secretaría de Educación de Florencia con el fin de atender a la situación particular de la accionante. Para ello, se partirá del hecho que la accionante puso de presente las afectaciones en su salud a la Secretaría accionada mediante derechos de petición remitidos, entre otras fechas, el 23 de julio de 2023¹⁷⁷, el 30 de noviembre de 2023¹⁷⁸, el 21 de diciembre de 2023¹⁷⁹ y el 4 de enero de 2024¹⁸⁰, en los cuales solicitaba la protección de su estabilidad laboral reforzada.

§141. En respuesta a esta petición, la Secretaría de Educación de Florencia desplegó actuaciones concretas para garantizar, en la medida de las posibilidades, la estabilidad laboral relativa de *Lorena*. Estas actuaciones, además, se encuadran dentro de un marco regulatorio diseñado por la misma Secretaría para tratar casos como el presente, relacionados con funcionarios en provisionalidad que alegan la protección de su estabilidad laboral ante la configuración de alguna de las causales previstas con anterioridad en esta decisión, a saber: (i) ser madres y padres cabeza de familia, (ii) tener la calidad de pre pensionado o (iii) estar en una situación de discapacidad o debilidad manifiesta por causa de una enfermedad.

¹⁷⁷ Expediente digital T-10.121.578. Archivo “Consulta requerimiento FLO2023ER004260”.

¹⁷⁸ Expediente digital T-10.121.578. Archivo “012 Rta. Secretaria de Educación de Florencia-oficio 2023 de noviembre a la secretaria de educacionpdf”.

¹⁷⁹ Expediente digital T-10.121.578. Archivo “Consulta requerimiento FLO2023ER007257”.

¹⁸⁰ *Ibidem*.

§142. En esa línea, se destaca que la Secretaría de Educación de Florencia desarrolló, entre otras, las siguientes acciones afirmativas para tratar casos como el de *Lorena*:

- a) El 25 de septiembre de 2023 emitió el Decreto 00716¹⁸¹ mediante el cual creó un “Comité técnico de estabilidad laboral reforzada en el marco de los procesos de selección para la provisión de vacantes definitivas docentes y directivos docentes de planta”. En este Comité tienen asiento la Secretaría de Educación Municipal y funcionarios de las áreas de planta y personal, jurídica y de seguridad y salud en el trabajo de dicha entidad; así mismo, se permite la asistencia de autoridades como el Defensor del Pueblo o su delegado o la Personería Municipal o su delegado. Su objetivo es definir los parámetros a tener en cuenta frente a cada situación de especial protección, estudiar las solicitudes y determinar el orden de los beneficiarios de la estabilidad laboral.
- b) Emitió la Circular 20230058 del 20 de septiembre de 2023¹⁸², cuyo asunto se titula “Guía para solicitar la PROTECCIÓN LABORAL REFORZADA según directrices impartidas por el Ministerio de Educación Nacional en la Circular 024 de 2023 y precisiones sobre el proceso de audiencias públicas de selección de plaza”. Esta circular se dirige a los docentes que se encuentran vinculados en provisionalidad de vacantes definitivas en el marco del Proceso de Selección No.2160 a 2237 de 2021, 2316 y 2406 de 2022. En dicha guía, tras indicarse las condiciones de especial protección, se establece el plazo del 25 de septiembre de 2023 como la fecha máxima para que los docentes que se encontraran en alguno de esos supuestos, allegaran las pruebas respectivas.

¹⁸¹ “Por medio del cual se crea el Comité técnico de estabilidad laboral reforzada en el marco de los procesos de selección para la provisión de vacantes definitivas docentes y directivos docentes de planta de la Secretaría de Educación Municipal”. Expediente digital T-10.121.578. Archivo “Decreto crea el comité técnico de estabilidad laboral”.

¹⁸² Expediente digital T-10.121.578. Archivo “4. Circular 09-2023 guía protección laboral”.

§143. *Actuaciones particulares para atender a la solicitud de Lorena.* A su vez, la Secretaría de Educación de Florencia ha adelantado las siguientes acciones afirmativas de cara a la situación particular de *Lorena*:

- a) Mediante el Decreto 0009 del 19 de enero de 2021¹⁸³ trasladó a la accionante a la institución educativa Técnico Industrial (Sede la libertad), ubicada en el municipio de Florencia, con la finalidad de garantizarle una protección especial por motivo de enfermedad catastrófica y teniendo en cuenta que para ese entonces “el concurso de méritos para proveer las vacantes definitivas en zona urbana apenas estaba iniciando”¹⁸⁴. Esto por cuando la vacante que la accionante ocupaba en la Institución “El Salitre” había sido incluida en un concurso de méritos iniciado en el año 2018 por la Comisión Nacional de Servicio Civil y era necesario designar a la persona ganadora del concurso¹⁸⁵.

Sin embargo, la vacante que ocupó la accionante en la institución educativa Técnico Industrial (Sede la libertad) había sido incluida en el concurso de méritos del posconflicto adelantado mediante el proceso de selección 2198 de 2021¹⁸⁶.

- b) Incluyó a *Lorena* dentro de un listado de personas con “estabilidad laboral reforzada” a las que se les garantizaría el traslado cuando fuese posible. Esta lista se deriva de una sesión del “Comité técnico de estabilidad laboral reforzada” al que se hizo referencia previamente y está contenida en un acta¹⁸⁷ con fecha del 22 de noviembre de 2023 en la que aparece su nombre relacionado con la situación de “enfermedad”.

¹⁸³ Expediente digital T-10.121.578. Archivo “03Anexos.pdf”, pp 26-27. Esta resolución tiene por epígrafe “*Por medio de la cual se traslada una docente por reten social*”. En la parte motiva no se hace referencia a que el traslado se debe a la condición de salud de *Lorena*, pero en todo caso se da la orden expresa de realizar el traslado.

¹⁸⁴ Expediente digital T-10.121.578. Archivo “INFORME DE LA SECRETARIA”, p. 2.

¹⁸⁵ *Ibidem*.

¹⁸⁶ Expediente digital T-10.121.578. Archivo “11ContestacionAccionada.pdf”.

¹⁸⁷ Expediente digital T-10.121.578. Archivo “2- ACTA 1de 2023 con firmas”. En esta reunión se contó con la participación de la Secretaria de Educación de Florencia.

- c) Dio respuesta a los derechos de petición elevados por *Lorena*, mediante oficios del 21 de diciembre de 2023¹⁸⁸ y del 20 de enero de 2024¹⁸⁹. En las respuestas se le indicó a la accionante que la Secretaría “atenderá dentro de sus posibilidades administrativas, las orientaciones dadas por el Ministerio de Educación en la Circular no. 024 de 21 de julio de 2023, en los casos de especial protección”¹⁹⁰, desatacándose que su caso sería tenido en cuenta.
- d) En la respuesta en sede de revisión informó que “la accionante hace parte de la lista de especial protección que será tomada en cuenta por esta entidad para efectos de vinculación en las vacantes que se generen una vez la lista de elegibles se agote”¹⁹¹. Luego, es claro que la Secretaría de Educación de Florencia tiene la intención de vincular a *Lorena* en el evento en el que llegue a contar con una vacante.

Sobre este punto, la Secretaría de Educación de Florencia resaltó que las listas de elegibles corresponden a un área o empleo particular. Así, *Lorena* hace parte del área de primaria, por lo que debe ser incluida en dicha lista que, se encuentra conformada por un total de 71 elegibles. En noviembre de 2023, se llevó a cabo la audiencia para la escogencia de plaza, habiéndose provisto 60 vacantes definitivas; con lo cual, aún falta nombrar 11 elegibles¹⁹².

Así mismo, la Secretaría de Educación de Florencia precisó que en esta ocasión no fue posible trasladar a *Lorena* como se realizó en el año 2021 ya que, todas las vacantes *urbanas* están provistas con nombramientos en periodo de prueba. De otra parte, tampoco fue viable realizar un traslado a una vacante *rural* en atención a que la Secretaría

¹⁸⁸ Expediente digital T-10.121.578. Archivo “sc_pdf_20240719163825_676 Gral respuesta”. Ambas respuestas fueron suscritas por el Subsecretario de Despacho- Administrativo de la Secretaría de Educación de Florencia.

¹⁸⁹ *Ibidem*.

¹⁹⁰ *Ibidem*.

¹⁹¹ Expediente digital T-10.121.578. Archivo “INFORME DE LA SECRETARIA”, p. 3.

¹⁹² *Ibidem*, p. 4.

no cuenta con vacantes en el área de Primaria¹⁹³. Para justificar este último punto, la Secretaría allegó una constancia con fecha del 18 de julio de 2024¹⁹⁴ en la que indica que a la fecha no cuenta con una vacante definitiva disponible en el cargo de docente de aula en el área de Humanidades y Lengua Castellana o de Primaria en zona rural. Igualmente, se resalta que para el momento de desvinculación de *Lorena* (diciembre de 2023), la Secretaría de Educación de Florencia tampoco contaba con alguna vacante para el cargo de Docente en aula – Primaria, como consta en la certificación proferida el 15 de diciembre de 2023¹⁹⁵.

§144. Adicional a lo anterior, la Sala destaca que el Decreto 009000 del 1 de diciembre de 2023 en el que (i) se nombró en periodo de prueba al señor Duberney Trujillo Osorio en el cargo que *Lorena* ocupaba en provisionalidad y (ii) se dio por terminado su nombramiento en provisionalidad¹⁹⁶, tuvo una motivación razonable. Adicionalmente, en principio, no da cuenta de la utilización abusiva de una facultad legal para encubrir un trato discriminatorio en torno a las circunstancias de debilidad manifiesta, asociadas al estado de salud de *Lorena*.

§145. Puntualmente, en la parte considerativa de este Decreto se indicó que el señor Duberney Trujillo Osorio había ganado la vacante de “Docente en aula en el área de Primaria”, identificado con la OPEC No. 182781 en la planta de la Secretaría de Educación de Florencia en el marco de la convocatoria pública 2198 de 2021 que era ocupado por *Lorena*. Dentro de la extensa motivación del Decreto 009000, además, se indica que se agotaron todas las opciones posibles para garantizarle un trato especial, pero que no fue posible concederle

¹⁹³ *Ibidem*.

¹⁹⁴ Expediente digital T-10.121.578. Archivo “Certificado de vacantes lengua y primaria rural junio de 2024”.

¹⁹⁵ Expediente digital T-10.121.578. Archivo: “Constancia vacantes definitivas PDET”.

¹⁹⁶ En el artículo 6° de dicho acto administrativo se indicó lo siguiente: “**ARTÍCULO SEXTO. Terminación de nombramiento provisional.** Como consecuencia del nombramiento en periodo de prueba contenido en el artículo primero del presente acto administrativo, se procede a dar por terminado el nombramiento provisional en vacante definitiva del (la) empleado (a) público *Lorena* identificado con cedula de ciudadanía No. 12345678, una vez DUBERNEY TRUJILLO OSORIO tome posesión del empleo para el cual fue nombrado”.

un traslado por las razones expuestas. Afirmación que además de respaldarse en el principio de la buena fe, tiene sustento en un antecedente previo del año 2021 en el que la Secretaría ejecutó una acción afirmativa a favor de *Lorena* y la trasladó a otra institución, al enfrentarse a una situación similar a la presentada en esta oportunidad.

§146. Así las cosas, la Sala evidencia una tensión entre la protección de los derechos de la accionante y el respeto de la carrera administrativa y los resultados del concurso adelantado por la Secretaría de Educación de Florencia que, impide que la Sala acceda a sus pretensiones.

§147. De un lado, no es posible ordenar su reincorporación al mismo cargo que venía desempeñando ya que ello vulneraría los derechos fundamentales de Duberney Trujillo Osorio, quien accedió a esta vacante a través del concurso de méritos. Por este motivo, y dado que fue evidenciado con suficiente claridad que la Secretaría de Educación de Florencia ha sido muy diligente para garantizar los derechos de *Lorena*, la Sala considera que solo se podrá ordenar a la entidad accionada a mantener a la accionante dentro del listado de personas en condición de vulnerabilidad por su estado de salud, de modo que, pueda ser vinculada a un cargo igual o equivalente en el evento en el que haya una vacante que se ajuste a su formación y experiencia.

§148. De otro lado, a la Sala no le corresponde pronunciarse sobre hechos diferentes a los relacionados con el caso de *Lorena*. Esta consideración es relevante dado que en sus pretensiones ella solicita que se le extienda el tratamiento favorable dispensado por una autoridad judicial al docente Rosemver Osorio Rodríguez¹⁹⁷. Sobre este punto, el 36 del Decreto 2591 de

¹⁹⁷ La pretensión puntual de la accionante es la siguiente: “Solicitar la aplicación de RETÉN SOCIAL Y ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA, con favorecimiento del PRINCIPIO DE IGUALDAD, como al docente ROSEMVER OSORIO RODRIGUEZ, acogido por RETÉN SOCIAL y protección de la ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA a causa de ENFERMEDAD CATASTROFICA, de la Institución Educativa José Antonio Galán de Florencia. Según fallo con número de radicado 2021-0065- 00 del 01 de marzo de 2021, proferido por el Juzgado Segundo de Familia”. Según afirma la accionante, el señor Rosemver Osorio Rodríguez presentó una acción de tutela solicitando la protección de la estabilidad laboral reforzada y su reintegro a la institución educativa José Antonio Galán. El Juzgado Segundo de Familia en sentencia del 1 de marzo de 2021 amparó sus derechos a la estabilidad laboral reforzada en el proceso con radicado 2021-0065-00 y ordenó a la Secretaría de Educación de Florencia vincularlo nuevamente. El 7 de marzo de 2021, en segunda instancia, el

1991 es claro en afirmar que los efectos de los fallos de tutela son “inter partes”, por lo que, “las decisiones que adopta el juez de tutela no tienen una alcance general, impersonal y abstracto, sino particular y concreto”¹⁹⁸. Así las cosas, no le corresponde a esta Corte establecer si a *Lorena* se le debió haber dado el mismo tratamiento que fue brindado a docente Rosemver Osorio.

§149. *Conclusión.* Con base en todos estos elementos, la Sala concluye que la Secretaría de Educación de Florencia no le vulneró a *Lorena* sus derechos fundamentales a la vida, al trabajo, a la salud, la igualdad de oportunidades, a la no discriminación, la remuneración mínima vital y móvil.

§150. *Remedio constitucional.* La Sala reconoce la imposibilidad inmediata de reincorporar a *Lorena* al cargo que venía desempeñando o incluso a alguno similar. Sin embargo, en aras de garantizar la continuidad en el acceso a los controles médicos y exámenes que le corresponde realizarse – encontrándose incluso pendiente uno para septiembre de 2024–, la Sala ordenará a la Secretaría de Educación de Florencia afiliar a *Lorena* a afiliar al Sistema de Seguridad Social en Salud, ya sea en el régimen contributivo o subsidiado, hasta que ella obtenga la pensión de vejez, o sea afiliada al sistema por otro empleador. Esto, en línea con los remedios judiciales adoptados en las sentencias T- 462 de 2011, T -373 de 2017y T-342 de 2021.

§151. Igualmente, se aclara que la Sala no ordenará la vinculación inmediata de *Lorena* dado que, ella ya se encuentra priorizada para estos efectos por la Secretaría de Educación de Florencia y la posibilidad de que se dé una eventual vinculación depende de la condición de que se cuente con la respectiva vacante.

4.2 Expediente 10.153.71. La Secretaría de Educación y Cultura de Apartadó no vulneró los derechos fundamentales de la accionante

Juzgado Segundo Penal del Circuito de Florencia confirmó la decisión. Esta entidad no dio cumplimiento a dicho fallo por lo que el Juzgado Segundo de Familia abrió un incidente de desacato. A partir de lo anterior, la Secretaría de Educación de Florencia cumplió el fallo de tutela y vinculó nuevamente al señor Rosemver Osorio.

¹⁹⁸ Sentencia T-583 de 2006. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

§152. Para comenzar, la Sala destaca que *Adriana* alegó una presunta estabilidad laboral reforzada con motivo en dos supuestos diferentes – la calidad de pre pensionada y su situación de salud- la Sala debe abordar las actuaciones desplegadas por la Secretaría de Educación y Cultura de Apartadó respecto de cada uno de estos. Como se verá, la Sala comparte las actuaciones desarrolladas en torno a la especial protección que requería la accionante en atención a su condición de salud, pero discrepa del análisis desarrollado por la entidad accionada en torno a la eventual calidad de pre pensionada de la accionante.

§153. Con todo, la Sala concluye que de conformidad con los hechos probados en el proceso T-10.153.714 no es posible considerar que la Secretaría de Educación y Cultura de Apartadó haya vulnerado los derechos fundamentales a la salud, a la estabilidad laboral reforzada, al trabajo, a la dignidad y a la vida de *Adriana*. Esto por cuanto, si bien la Sala tiene algunos reparos sobre el tratamiento dado a la petición de la accionante de ser reconocida como pre pensionada, incluso de manera reciente, la Secretaria accionada demostró que adelantó importantes acciones para garantizar los derechos de la accionante; pese a la estabilidad relativa que ella ostentaba al haber sido vinculada a la administración mediante un nombramiento en provisionalidad.

§154. Así las cosas, a continuación, se aborda el estudio diferenciado sobre las dos situaciones de vulnerabilidad alegadas por la accionante.

Análisis sobre la protección especial alegada por la accionante en atención a su estado de salud

§155. En el escrito de tutela *Adriana* adujo que se le diagnosticó cáncer de seno desde el mes de abril de 2022 y que, adicionalmente, se le han diagnosticado otras enfermedades frente a las cuales, en la actualidad continua en seguimiento y tratamiento con los médicos especialistas. A partir de lo anterior, la Sala estima pertinente hacer un análisis sobre el estado actual de salud de la accionante teniendo en cuenta su historia clínica. Para ello, se

expondrá en la siguiente tabla los principales diagnósticos e intervenciones practicadas a la accionante:

Cuadro n.º 2. Principales diagnósticos y tratamientos efectuados

No.	Fecha	Diagnostico o procedimiento
1	11 de abril de 2022	Diagnostico cáncer de mama (en el seno izquierdo) ¹⁹⁹ .
2	4 de enero de 2023	Intervención quirúrgica denominada “Mastectomía simple unilateral y vaciamiento radical linfático axilar vía abierta” ²⁰⁰ .
3	Desde el 5 de mayo del 2022 hasta el 18 de mayo del 2023	Diferentes incapacidades debido a la afectación de su estado de salud por el cáncer de seno que le fue diagnosticado. Durante parte de este tiempo se le realizaron quimioterapias y radioterapias ²⁰¹ .
4	12 de octubre de 2023	Tomografía de tórax en la que se encuentran quistes simples en ambos riñones ²⁰² .
		Control con Oncología. En esta historia clínica se indica que debe recibir radioterapia en axila y que

¹⁹⁹ Expediente digital T-10.153.714. Archivo “008 Rta. Adriana.pdf.”, pp. 55-56.

²⁰⁰ *Ibidem*, pp. 99-102. En la historia clínica se indica lo siguiente: “Descripción de hallazgos y procedimientos. Mama izquierda, no lesión palpable, no adenopatía. descripción. Mastectomía simple unilateral y vaciamiento radical linfático axilar vía abierta. Intervención quirúrgica ambulatoria (...)”.

²⁰¹ *Ibidem*, pp. 113-120. En la historia clínica del 4 de abril de 2023 se menciona lo siguiente: “Paciente de 51 años con ap de cáncer de mama (carcinoma ductal infiltrante multifocalidad mama izquierda (...)) en manejo con quimioterapia. El 5 de enero de 2023 le realizaron una mastectomía, vaciamiento axilar mama izquierda no complicaciones. Acude a prorroga de incapacidad la cual vence el 4 de marzo de 2023 para acudir a manejo con radioterapia”.

²⁰² Expediente digital T-10.153.714. Archivo “008 Rta.Adriana.pdf-Anexos 2” p. 14. En esta historia clínica se indica lo siguiente: “Corazón algo aumentado de tamaño, quistes simples en ambos riñones, estado poscolecistectomía, cambios postquirúrgicos de la mama izquierda y receso axilar ipsilateral, pequeño seroma de la mama izquierda y cambios degenerativos en la columna dorsal”.

5	11 de enero de 2024	se remite a Urología por un quiste renal que le fue identificado ²⁰³ .
6	11 de abril de 2024	Última historia clínica. Citas médicas asignadas (i) con el oncólogo el 25 de julio de 2024, (ii) con medicina del deporte el 29 de julio de 2024, dado que tiene una obesidad tipo III que según se indica en la historia clínica implica un “riesgo muy severo”; y con (iii) medicinal del dolor el 31 de julio de 2024 ²⁰⁴ .

§156. De conformidad con la información extraída de la historia clínica de *Adriana*, la Sala concluye que ella tuvo un reciente diagnóstico de cáncer que todavía se encuentra en un estado de monitoreo intenso. Como muestra de ello se destaca lo siguiente: (i) aunque no se puede afirmar con total certeza, dado que las historias clínicas no son del todo claras, en el reporte del 11 de enero de 2024 se indica que la accionante debe recibir radioterapia en axila y si bien no precisa si es en la axila derecha o izquierda la Sala no pasa por desapercibido que dicha orden fue emitida en una fecha muy cercana a aquella en la que se dio el despido de *Adriana* (15 de enero de 2024); (ii) en esta misma historia clínica se indica que la accionante debe continuar en seguimiento oncológico por 5 a 10 años y por manejo con terapia endocrina durante 5 años y (iii) la accionante tenía prevista una cita de seguimiento por oncología para el 25 de julio de 2024. Con base en esta información, la Sala estima que es posible considerar que *Adriana* aún se encuentra superando el cáncer que le fue diagnosticado en abril de 2022.

²⁰³ En esta historia clínica se indica lo siguiente: “Con multifocalidad confirmado en RNM de mama solo compromiso multifocal izquierdo y axilar nivel 1 confirmado. Actualmente tiene compromiso inicial positivo y fibrosis deberá recibir radioterapia a axila. (...) continuar seguimiento oncológico por 5-10 años y manejo con terapia endocrina para completar 5 años. Dado quiste renal envió a urología y por obesidad envió a endocrinología”. Expediente digital T-10.153.714. Archivo “008 Rta.*Adriana*.pdf”, pp. 199-203.

²⁰⁴ Expediente digital T-10.153.714. Archivo “008 Rta.*Adriana*.pdf”, p. 482. En la historia clínica se indica lo siguiente: “plan; control en 3 meses mamografía unilateral derecha (...) paciente quien no debe tener trayecto por tierra mayor a 3 horas, dado obesidad y enf varicosa grado 3 congreso de tvp y tep”.

§157. Adicional a lo anterior, la Sala resalta que a la accionante también le han sido diagnosticadas otras patologías como (i) obesidad de grado III; (ii) quistes en ambos riñones y (iii) enfermedad varicosa. Luego, su situación de salud no solamente se ha visto afectada por el cáncer que se le diagnosticó en el año 2022, sino también por otras afecciones a su salud.

§158. Teniendo en cuenta la situación descrita, la Sala considera que a *Adriana* se le deben garantizar los principios de continuidad, oportunidad y atención integral en el acceso al derecho fundamental a la salud que, además tienen un carácter reforzado dado que ella es un *sujeto de especial protección constitucional* por su estado de salud. Sumado a ello, la necesidad de asegurar, especialmente, la continuidad en los controles médicos también fue reconocida de manera expresa por sus médicos tratantes, quienes ordenaron extender el seguimiento de la situación de salud de *Adriana* por un amplio periodo de hasta 10 años; destacándose que su monitoreo constante no solo implica validar la eventual aparición de alguna lesión tumoral, sino también la necesidad de controlar las otras enfermedades que la accionante padece y que, de no ser tratadas, podrían poner en riesgo su salud.

§159. Aunado a lo expuesto, la Sala llama la atención sobre el hecho que en el escrito remitido en sede de revisión la accionante manifestó que, aunque a la fecha se encuentra vinculada al FOMAG, desconoce las razones de ello. Sin embargo, esta vinculación inexplicable no sucedió una vez fue retirada del servicio ya que, según afirma, estuvo inactiva en el Sistema General de Seguridad Social en salud durante tres meses contados desde febrero de 2024.

§160. Esta situación le impidió tener acceso a los controles que tenía ordenados con diferentes especialistas médicos, así como al medicamento esencial como LETROZOL 2.5mg diagnosticado por el Oncólogo en historia clínica desde el 19 de octubre del 2023. En su criterio, ello conllevó a que se hubiese deteriorado “significativamente su salud, habiendo aumentado la fatiga, dolores de cabeza, dolor en los huesos, articulaciones y malestar general”²⁰⁵. Todo ello da cuenta de que se materializó el riesgo de que la salud de la accionante se pudiera ver comprometida con la desvinculación del

²⁰⁵ Expediente digital T-10.153.714. Archivo “008 Rta. *Adriana*.pdf.”, p. 482.

Sistema General de Seguridad Social en salud. tras la finalización de su nombramiento en provisionalidad.

§161. *Sobre las actuaciones de la Secretaría de Educación y Cultura de Apartadó, Antioquia.* La Sala pasa a evaluar las actuaciones desplegadas por la Secretaria de Educación de Apartadó para atender a la situación particular de *Adriana*.

§162. En primer lugar, se resalta que la accionante puso de presente su situación de salud a la Secretaría de Educación y Cultura de Apartadó mediante derechos de petición del 6 de julio de 2023²⁰⁶ y el 15 de enero de 2024²⁰⁷.

§163. Por su parte, la Secretaría accionada manifestó que no había incapacidad vigente al momento de la desvinculación y que la condición médica de la accionante le permitía laborar sin contraindicaciones significativas, de acuerdo con la historia clínica de la accionante y las recomendaciones médicas²⁰⁸ contenidas en el certificado médico de aptitud laboral emitido por la EPS Sumimedical²⁰⁹. A su vez, respecto a la finalización del nombramiento en provisionalidad, la Secretaría accionada indicó que este se encuentra justificado, pues obedeció a la necesidad de nombrar en periodo de prueba en el cargo a la persona que superó el concurso de méritos. En ese sentido argumentó que los derechos de las personas que fueron elegidas para ocupar las vacantes ofertadas en un concurso de méritos prevalecen respecto a aquellas personas nombradas en provisionalidad que gozan de una estabilidad laboral relativa debido a su estado de salud.

§164. La Sala resalta que esta entidad también emprendió acciones afirmativas para atender a la especial situación de *Adriana*. De un lado, estima que no era pertinente valorar las recomendaciones médicas de la accionante como único criterio para evaluar su estado de salud, como si se debiese hacer

²⁰⁶ Expediente digital T-10.153.714. Archivo “002 EscritoDemanda.pdf”, pp. 198-199. Derecho de petición presentado el 6 de julio de 2023.

²⁰⁷ Expediente digital T-10.153.714. Archivo “005 ContestaAlcaldiaApartado.pdf”.

²⁰⁸ *Ibidem*, p. 2.

²⁰⁹ Expediente digital T-10.153.714. Archivo “013 Rta. Sumimedical.pdf”, p. 6.

un análisis propio de la estabilidad laboral reforzada que implica, entre otras cosas, analizar si las afecciones del trabajador impiden el efectivo desarrollo de sus funciones. La Sala se aparta de esta lectura por cuanto, como se indicó previamente, el análisis de la estabilidad laboral relativa supone evaluar que el servidor público nombrado en provisionalidad tenía alguna situación especial de salud al momento de la desvinculación, sin necesidad de ponderar elementos adicionales.

§165. Sin embargo, por otra parte, la Sala reconoce que la Secretaría de Educación y Cultura de Apartadó adelantó medidas afirmativas para tratar de garantizar la protección a la estabilidad laboral relativa de *Adriana*. Especialmente, se destacan las siguientes:

- a) En un primer momento, cuando la accionante fue desvinculada de su cargo, la Secretaría de Educación y Cultura de Apartadó la incluyó en un listado de docentes que se envió al Ministerio de Educación Nacional para que las personas que presenten enfermedades catastróficas u otras situaciones de protección especial sean tenidas en cuenta después de agotar el listado de elegibles del concurso de méritos, en el evento que se presenten vacantes temporales. Esto, teniendo en cuenta que no había vacantes disponibles que fueran similares al cargo que ocupaba.

Incluso la Secretaría accionada indica que, pese a que la accionante allegó de manera tardía la documentación solicitada para ser incluida en el citado listado, garantizó que ella fuese incorporada²¹⁰.

- b) La Secretaría de Educación y Cultura de Apartadó expidió el Decreto 647 del 17 de abril de 2024²¹¹ mediante el cual se nombró en

²¹⁰Expediente digital T-10.153.714. Archivo “T-10.153.714- Adriana respuesta Corte”. Al respecto, la Secretaría accionada indicó lo siguiente: “La accionante solicita la inclusión el día después que se envía el reporte, el cual revisando los soportes se le aceptó la inclusión en el mismo como se puede constatar en el radicado APA2024ER000144 Estabilidad laboral reforzada.pdf”.

²¹¹ Expediente digital T-10.153.714. Archivo “Anexos 2”, p. 26. El epígrafe de este Decreto es el siguiente: “Por el cual se hace un nombramiento provisional en una plaza docente vacante temporal de la planta de cargos del personal docente y directivo docente por necesidad del servicio en la institución educativa rural Bartolomé Cataño Vallejo-Cer Playa larga de la jurisdicción

provisionalidad temporal a *Adriana* en una vacante en la institución educativa rural Bartolomé Castaño Vallejo-Cer Playa Larga hasta que durara la licencia de incapacidad por enfermedad común de la docente Yudithza Moreno Mena, quien fue nombrada en propiedad en la vacante mencionada. En el considerando 8 de este Decreto se indica que Yudithza Moreno Mena tenía una incapacidad desde el 8 de abril hasta el 7 de mayo de 2024.

No obstante, la Secretaría de Educación y Cultura de Apartadó informó que la accionante rechazó este nombramiento, argumentando que dicha institución se ubica en una zona de difícil acceso y a una hora aproximadamente del casco urbano, incumpliendo con las condiciones que se deben tener en cuenta acorde a su estado de salud y a las recomendaciones suscritas por la EPS Sumimedical²¹².

§166. Con esta actuación se evidencia que la Secretaría de Educación y Cultura de Apartadó adoptó acciones afirmativas dirigidas a garantizar la protección especial relativa que ostentaba *Adriana* dada su especial situación de salud.

§167. Adicionalmente, la Sala evidencia que el Decreto 134²¹³ del 15 de enero de 2024, en el que la Secretaría de Educación y Cultura de Apartadó le notificó a la accionante la finalización de su nombramiento en provisionalidad por cuenta del nombramiento en propiedad de Nubia Cecilia Prestán, tuvo una motivación razonable. En efecto, tras revisar el contenido de dicho Decreto la Sala encontró que este es claro en indicar que el motivo de la desvinculación

del municipio de Apartadó".

²¹² Expediente digital T-10.153.714. Archivo "002 EscritoDemanda.pdf", p. 200.

²¹³ Expediente digital T-10.153.714. Archivo "002 EscritoDemanda.pdf", pp. 204 - 207. El epígrafe de este decreto es el siguiente: "Por el cual se termina un nombramiento provisional en plaza docente vacante, área humanidades y lengua castellana en la Institución Educativa Campo Alegre de la Jurisdicción del Municipio de Apartadó". En el resolutivo primero se indica lo siguiente: "**ARTÍCULO 1.** De la terminación de la provisionalidad. Terminar el nombramiento en provisionalidad en plaza de docente de aula vacante definitiva del nivel secundaria, Área Humanidades y Lengua Castellana asignada a la institución educativa Campo Alegre a la docente *Adriana*, identificada con la cedula de ciudadanía número 98765432, de acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo".

de *Adriana* consistió en la necesidad de vincular a Nubia Cecilia dado que había ganado el empleo denominado “Docente de área humanidades y lengua castellana”, identificado con el OPEC 183043 que fue incluido en el proceso de selección n.º 2187 de 2021, adelantado por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

§168. Por consiguiente, la Sala estima que el citado Decreto 134 de 2024 no da cuenta de la utilización abusiva de una facultad legal para encubrir un trato discriminatorio en torno a las circunstancias de debilidad manifiesta, en relación con el estado de salud de *Adriana*. Este decreto tan solo resuelve la tensión entre la protección de los derechos de la accionante y el respeto de la carrera administrativa y los resultados del concurso adelantado por la Secretaría de Educación y Cultura de Apartadó, aplicando los mandatos expresos de la Constitución Política de 1991 y la necesidad de privilegiar el mérito en el acceso al servicio público.

§169. Pese a todo lo anterior, la Sala no puede desconocer, de acuerdo con su precedente constitucional, especialmente la Sentencia T-326 de 2024²¹⁴, que ante la terminación del nombramiento en provisionalidad de *Adriana*, quedó expuesta a que su situación de salud se vea considerablemente afectada. Como se indicó previamente, al analizar el estado de salud de la accionante, es claro que, por su reciente diagnóstico de cáncer, junto a las demás patologías que le han sido diagnosticadas, es indispensable que ella cuenta con un seguimiento y tratamiento continuo. En ese sentido, se debe proteger el derecho a la salud de la accionante para que pueda acudir a los servicios médicos de manera continua e integral conforme a las enfermedades que padece.

§170. *Conclusión.* Con base en todo lo expuesto, la Sala concluye que la Secretaría de Educación y Cultura de Apartadó no le vulneró a *Adriana* sus derechos fundamentales a la vida, al trabajo, a la salud, a la igualdad de oportunidades, a la no discriminación, ni a la remuneración mínima vital y móvil.

§171. *Remedio constitucional.* La Sala reconoce la imposibilidad inmediata de reincorporar a *Adriana* al cargo que venía desempeñando y en el que fue nombrada Nubia Cecilia Prestán. Sin embargo, en aras de garantizar la

²¹⁴ M.P. Diana Fajardo Rivera.

continuidad en el acceso a los controles médicos y exámenes que le corresponde, se ordenará a la Secretaría de Educación y Cultura de Apartadó que, en caso que la docente no esté afiliada al Sistema de Salud, realice todas las gestiones, bien sea en el sistema contributivo o en el subsidiado hasta que obtenga la pensión de vejez, o sea afiliada al sistema por otro empleador.

§172. Igualmente, se aclara que la Sala no ordenará la vinculación inmediata de la accionante dado que, ella ya se encuentra priorizada para estos efectos por la Secretaría de Educación y Cultura de Apartadó y la posibilidad de que se dé una eventual vinculación depende de la condición de que se cuente con la respectiva vacante.

§173. Por último, la Sala considera necesario hacer un llamado de atención a la Secretaría de Educación y Cultura de Apartadó y la accionante en relación con la infructuosa expedición del Decreto 647 del 17 de abril de 2024 en el que se nombró a *Adriana* en provisionalidad durante un corto periodo comprendido desde el 8 de abril hasta el 7 de mayo de 2024. Esto por cuanto, con independencia de la proporcionalidad de las razones esgrimidas por la accionante, el hecho que ella haya rechazado dicho nombramiento representa una situación de ineficiencia administrativa que, además redundante en la afectación de los derechos de otros posibles servidores que, al igual que la accionante estaban a la espera de cualquier eventual vinculación tras haberseles finalizado sus nombramientos en provisionalidad y que, muy posiblemente, si hubiesen aceptado la plaza propuesta. No se debe perder de vista que las vacantes de empleos públicos son limitadas.

§174. Por lo anterior, se ordenará a la Secretaría de Educación y Cultura de Apartadó que antes de expedir cualquier acto administrativo en el que vincule a las personas que se encuentran en las listas de prioridad por su especial situación de indefensión, valide si están o no dispuestos a aceptar la vacante. Esto es necesario para evitar que en el futuro se repita una situación como esta ya que, por el corto tiempo de la incapacidad de la servidora que debía ser reemplazada, podría ser más difícil emitir un nuevo acto administrativo y es posible que se haya desaprovechado dicha oportunidad que otras personas sí podrían haber aceptado.

Análisis sobre la protección especial alegada por la accionante en atención a su eventual calidad de pre pensionada

§175. El primer hecho narrado por *Adriana* en su acción de tutela se dirige a establecer que ella ha trabajado como docente desde el año 1992 en diferentes instituciones educativas, contando con más de 32 años de servicio en el sector público educativo. Pese a lo anterior, este es un debate que puede trascender del análisis propio del juez de tutela, máxime cuando quedó claro que la accionante ya cuenta con la calidad de sujeto especial de protección por su situación de salud. Además de que la Sala no cuenta con los elementos suficientes para definir la calidad de pre pensionada de la accionante²¹⁵.

§176. Aun cuando se acogiera la presunción de veracidad sobre las afirmaciones de la accionante, lo cierto es que no sería viable el amparo pues la estabilidad laboral reforzada del prepensionada genera la obligación de trato preferencial que debe cumplir la entidad nominadora “en la medida de las posibilidades”. Esa obligación se concreta en: (i) tomar medidas para que esos servidores sean los últimos en ser desvinculados de sus cargos; y, (ii) si existen cargos en vacancia definitiva similares o equivalentes a los que venían ocupando, nombrarlos en esos cargos mientras se proveen a través del concurso de méritos y hasta que logren cumplir los requisitos para obtener su pensión de vejez. Esto, teniendo en cuenta las reglas previstas en la Sentencia SU-003 de 2018 como se explicó en el apartado de reglas generales.

²¹⁵ Esto, por cuatro razones: (i) en los reportes de la historia laboral de Colpensiones y Porvenir se encuentran considerables coincidencias en los tiempos cotizados (las dos historias laborales comprenden información de 1995 a 1998 y de 2003 a 2010, pero en aquella de Colpensiones además hay cotizaciones de 2001 a 2003 y del año 2011), por lo que, es posible que se trate de historias laborales que repliquen las mismas semanas; (ii) aunque fuese posible contar con el número exacto de las semanas cotizadas por *Adriana* durante los 32 años que afirma haber estado trabajando, con el fin de saber el número de semanas que le debe ser exigido, en todo caso, se debería hacer un análisis adicional dirigido a determinar el régimen legal que le es aplicable para efectos de acceder a la pensión de vejez; (iii) pese a que *Adriana* indicó de manera reiterada que tiene la calidad de pre pensionada, dadas las dudas que tenía la Sala sobre dicha afirmación, en el auto de pruebas proferido por la magistrada sustanciadora se le solicitó expresamente que indicara “las razones por las cuales sostiene que tiene la calidad de prepensionada”; in embargo, no se tuvo una respuesta asertiva y (iv) *Adriana* expone que es posible que no le hayan sido reconocidas semanas e incluso años de cotizaciones ante su fondo de pensiones, sin precisar a cuál hace referencia.

§177. *Remedio general.* Para la Sala está fuera de discusión que las secretarías accionadas en los dos casos objeto de análisis actuaron conforme a lo prescrito en la Constitución, dando prelación a las personas que ganaron concursos de méritos que les permitieron ocupar los cargos ocupados en los que las accionantes estaban vinculadas bajo la figura de la provisionalidad; toda vez que, como lo ha expresado la jurisprudencia constitucional, en estos casos el mérito debe primar y además las personas desvinculadas cuentan con toda la libertad para presentarse a nuevos concursos de méritos.

§178. Sin embargo, la Sala observa que una decisión exclusiva en ese sentido generó una afectación intensa al derecho fundamental a la salud que resulta de especial importancia frente a personas que cuentan con una especial situación de salud dada la necesidad de contar con una vinculación permanente al Sistema de Seguridad Social en Salud que les permita acceder a los controles y seguimientos necesarios para contar con diagnósticos oportunos y eficaces.

§179. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala adoptará dos medidas que recaerán sobre la Circular 024 de 2023 y, en consecuencia, sobre el Ministerio de Educación Nacional que es la autoridad que la profirió.

§180. *Primera medida.* La primera consiste en ordenar al Ministerio que incorpore a la citada circular una estrategia que permita garantizar la continuidad en la afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud de las y los funcionarios en provisionalidad a quienes se les finaliza su nombramiento y que se encuentran en una situación de debilidad manifiesta por razones de salud, esto implica garantizar la continuidad del servicio ya sea en el régimen contributivo o en el subsidiado. Este mecanismo debe implicar que, se garantice que estas personas contarán con la afiliación inmediata en el régimen subsidiado de salud, una vez se les desvincule de la EPS en la que estaban registrados. Para ello, el Ministerio se deberá articular con las entidades que estime pertinentes.

§181. La anterior medida se deriva del hecho que frente a las personas que cuentan con una especial situación de salud cobra relevancia mantener una vinculación permanente al Sistema de Seguridad Social en Salud que les

permita acceder a los controles y seguimientos necesarios para contar con diagnósticos oportunos y eficaces.

§182. Incluso parece que la afectación sobre la que *Lorena y Adriana* hacen mayor énfasis consiste en la desvinculación del Sistema de Salud a la que deberían enfrentarse tras haberse terminado su nombramiento en provisionalidad. La Sala estima que este puede ser un riesgo inminente al que seguramente se enfrentan muchas personas que, tras estas vinculadas en provisionalidad, son retiradas del servicio público con el fin nombrar a quien cuenta con un mejor derecho tras haber ganado un concurso de méritos. Por ello, la Sala considera pertinente establecer una medida dirigida a que personas que se encuentren en situaciones como las de las accionantes puedan tener garantizada la continuidad en su atención a salud y una ruta conocida para el transito al régimen subsidiado, de no contar con otro empleo, en aras de mantener la continuidad del servicio. A esta conclusión se llega, teniendo en cuenta los hechos analizados y la aparente ausencia de una medida sobre el tema.

§183. En efecto, la Sala llama la atención sobre el hecho que en la Circular 024 del 21 de julio de 2023²¹⁶ proferida por el Ministerio de Educación Nacional y en la que se dan orientaciones generales para adelantar acciones afirmativas antes de dar por terminados los nombramientos en provisionalidad, solo se hace referencia a la posibilidad de reincorporar a las personas desvinculadas al servicio público. Sin embargo, no se evidencia ninguna medida adicional para hacer frente a la problemática evidenciada por esta Corte en los casos analizados. Esto es, no se adopta ninguna determinación que permita que las y los servidores públicos desvinculados puedan continuar con una afiliación al Sistema de Seguridad Social en salud y especialmente a verificar su inclusión en el régimen subsidiado que, como se indicó, resulta aún más relevante cuando las personas desvinculadas tenían alguna situación de debilidad manifiesta por razones de salud.

§184. Igualmente, vale la pena aclarar que esta medida general no riñe con aquella adoptada en los casos concretos. De un lado, el remedio adoptado en

²¹⁶ Esta Circular se dirige a “Gobernadores, Alcaldes, Secretarios de Educación de Entidades Territoriales Certificadas en Educación, Jefes de Personal Docente de las Secretarías de Educación o quien haga sus veces”.

sus casos particulares se deriva de la aplicación de la jurisprudencia reseñada en el acápite considerativo de esta ponencia.

§185. De otro lado, el remedio general que apunta al establecimiento de un mecanismo que permita afiliarse al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud a las personas vinculadas en provisionalidad en razón a que tienen alguna situación de salud compleja, se soporta en las siguientes tres razones:

- i. Primero, como ha sido expuesto, la principal preocupación de las personas vinculadas en provisionalidad que presentan una compleja situación de salud o que incluso son pacientes en remisión y que son retiradas del servicio en razón al mérito reside en la no continuidad en la prestación de sus servicios de salud. Por ello, garantizar esta permanencia en el sistema permitiría reducir la litigiosidad en estos casos que, como también se señaló, no tienen un mayor margen de discusión dado que la regla de decisión de la Corte en estos asuntos es clara y apunta a que el mérito prevalece por mandato constitucional.
- ii. Segundo, esta es una medida que reivindica la valía del régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud, como una parte importante del esquema diseñado por el legislador para garantizar el derecho fundamental a la salud. Además de que esta medida aliviaría las afectaciones administrativas y presupuestales que podrían derivarse para las entidades públicas accionadas al dar cumplimiento a la orden de afiliación al régimen contributivo de las personas en provisionalidad con complicaciones de salud que son desvinculadas del servicio público.

Igualmente, se destaca que esta no puede ser entendida como una medida regresiva ya que, ello implicaría asumir que el régimen subsidiado de salud tiene una menor cobertura o garantías respecto del régimen contributivo, cuando ello no es cierto. En efecto, por lo menos, desde la Ley 1122 de 2007²¹⁷ (art. 14²¹⁸) se estableció la obligación de

²¹⁷ “Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”.

²¹⁸ “Artículo 14º. Organización del Aseguramiento. (...) A partir de la vigencia de la presente Ley el Sistema tendrá las siguientes reglas adicionales para su operación:// e. La Comisión de Regulación

definir estrategias que permitieran unificar las prestaciones de ambos regímenes; situación que, como ha indicado esta Corte, entre otras, en la Sentencia T-001 de 2018²¹⁹ ha permitido que hoy en día en desarrollo del principio de equidad, exista un único e idéntico Plan de Beneficios en Salud (PBS) para el régimen contributivo y subsidiado.

- iii. En tercer lugar, esta es una medida que en cualquier escenario maximiza el derecho fundamental a la salud de quienes se encuentran en situaciones como las de las accionantes, al permitirles contar con un proceso expedito que garantice la continuidad en la prestación de sus servicios de salud.

§186. Con todo, se aclara que para adoptar esta medida, el Ministerio de Educación deberá garantizar que mientras que se realiza la efectiva afiliación al régimen subsidiado en salud, los trabajadores deberán contar con una afiliación temporal al régimen contributivo. Todo ello, se reitera, con el fin de proteger su derecho fundamental a la salud y maximizar el principio de continuidad.

§187. *Segunda medida.* La segunda apunta a ordenar al Ministerio de Educación que modifique la Circular 024 de 2023 con el propósito de suprimir las referencias a los requisitos propios a la *estabilidad laboral reforzada*²²⁰ por

en Salud actualizará anualmente el Plan Obligatorio de Salud buscando el acercamiento progresivo de los contenidos de los planes de los dos regímenes con tendencia hacia el que se encuentra previsto para el régimen contributivo”.

²¹⁹ Sentencia T-001 de 2018. 15 de enero de 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

²²⁰ En efecto, en esta Circular se indica lo siguiente: “Para dar aplicación a lo antes referido por parte de los Gobernadores, Alcaldes, Secretarios de Educación de Entidades Territoriales Certificadas en Educación, Jefes de Personal Docente de las Secretarías de Educación o quien haga sus veces, es pertinente tener en cuenta lo expuesto en la **Sentencia SU- 087 de 2022** de la Corte Constitucional (...). Una vez agotado todo lo anterior, y se identifique que no fue posible mantener la vinculación del docente provisional, mediante acto administrativo motivado se procederá a la terminación del nombramiento provisional. La efectividad de la terminación del nombramiento provisional será la fecha en que el docente con derechos de carrera o el elegible nombrado en periodo de prueba asuma efectivamente las funciones del cargo”. Circular 024 de 2023, p. 9. Como se observa, parece que el Ministerio referencia la Sentencia SU-087 de 2022 y los parámetros definidos en esta respecto de la estabilidad laboral reforzada como requisitos necesarios para

fuero de salud que, como se indicó no aplican frente a la *estabilidad laboral relativa* que ostentan los servidores vinculados en provisionalidad con complicaciones de salud.

§188. Por lo anterior, la Sala estima necesario ordenar al Ministerio de Educación Nacional que en la Circular 024 de 2023 incluya las reglas mucho más generales que la Corte ha establecido para determinar la procedencia de la garantía de la estabilidad laboral relativa por razones de salud a favor de los servidores públicos vinculados en provisionalidad.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE

Primero. Con relación al expediente T-10.121.578, **REVOCAR** por las razones expuestas, la sentencia de tutela proferida el 7 de marzo de 2024 en segunda instancia por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Florencia Caquetá, mediante la cual se negó el amparo solicitado y en su lugar **TUTELAR**, únicamente, los derechos fundamentales a la salud y vida digna de *Lorena*.

Segundo. Por tal razón y con relación al expediente T-10.121.578, **ORDENAR** a la Secretaría de Educación de Florencia (Caquetá) que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, inicie las actuaciones necesarias para que *Lorena* sea vinculada al Sistema de Seguridad Social en Salud en caso de no estarlo, en los términos de esta sentencia.

validar la posibilidad de trasladar a un funcionario en provisionalidad en los eventos en los que su empleo es ocupado por otra persona que ganó un concurso de méritos.

Tercero. Con relación al expediente T-10.153.714, **REVOCAR** por las razones expuestas, la sentencia de tutela proferida el 15 de marzo de 2024 por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Apartadó (Antioquia) en el que declaró improcedente la acción de tutela, y en su lugar **TUTELAR**, únicamente, los derechos fundamentales a la salud y vida digna de *Adriana*.

Cuarto. En ese sentido, con relación al expediente T-10.153.714, **ORDENAR** a la Secretaría de Educación y Cultura de Apartadó (Antioquia) que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, inicie las actuaciones necesarias para que *Adriana* sea vinculada al Sistema de Seguridad Social en Salud en caso de no estarlo, en los términos de esta sentencia.

Quinto. Con relación al expediente T-10.153.714, **ORDENAR** a la Secretaría de Educación y Cultura de Apartadó (Antioquia) que antes de expedir cualquier acto administrativo en el que vincule a las personas cuyo nombramiento en provisionalidad se haya finalizado tras el nombramiento de un servidor en propiedad en el cargo que ocupaban y que se encuentren en las listas de prioridad por su especial situación de indefensión, valide si están o no dispuestos a aceptar la vacante. Esto, con el fin de evitar situaciones de ineficiencia administrativa y maximizar recursos escasos como las vacantes en empleos públicos.

Sexto. Como medida conjunta a los expedientes T-10.121.578 y T-10.153.714 **ORDENAR** al Ministerio de Educación Nacional a que en el término de tres (3) meses contados desde la publicación de esta providencia incorpore en la citada Circular 24 de 2023 una estrategia que permita garantizar la continuidad en la afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud de las y los funcionarios en provisionalidad a quienes se les finaliza su nombramiento y que se encuentran en una situación de debilidad manifiesta por razones de salud. Este mecanismo debe permitir que estas personas cuenten con la afiliación inmediata en el régimen subsidiado de salud, una vez

se les desvincule de la EPS en la que estaban registrados. Para ello, el Ministerio se deberá articular con las entidades que estime pertinentes.

Séptimo. Como medida conjunta a los expedientes T-10.121.578 y T-10.153.714 **ORDENAR** al Ministerio de Educación Nacional a que en el término de tres (3) meses contados desde la publicación de esta providencia modifique la Circular 024 de 2023 con el propósito de suprimir las referencias a los requisitos propios a la *estabilidad laboral reforzada* por fuero de salud. Esta modificación también implica que el Ministerio incluya las reglas mucho más generales que la Corte ha establecido para determinar la procedencia de la garantía de la *estabilidad laboral relativa* por razones de salud a favor de los servidores públicos vinculados en provisionalidad.

Octavo. LIBRAR las comunicaciones –por la secretaría general de la Corte Constitucional–, así como **DISPONER** las notificaciones a las partes –a través del juez de tutela de instancia–, previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.

Cópiese, comuníquese y cúmplase.

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

Con salvamento de voto

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

Sentencia SU446/11

SISTEMA DE CARRERA ADMINISTRATIVA-Importancia como pilar fundamental de Estado

La importancia de la carrera administrativa como pilar del Estado Social de Derecho, se puso de relieve por esta Corporación en la sentencia C-588 de 2009, al declarar la inexequibilidad del Acto Legislativo No 01 de 2008, que suspendía por el término de tres años la vigencia del artículo 125 constitucional. En el mencionado pronunciamiento se indicó que el sistema de carrera administrativa tiene como soporte principios y fundamentos propios de la definición de Estado que se consagra en el artículo 1 constitucional, cuyo incumplimiento o inobservancia implica el desconocimiento de los fines estatales; del derecho a la igualdad y la prevalencia de derechos fundamentales de los ciudadanos, tales como el acceso a cargos públicos y el debido proceso.

CONCURSO PUBLICO DE MERITOS DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION-Obligatoriedad de las reglas y sus alcances

REGISTRO DE ELEGIBLES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION-Naturaleza, alcance y fuerza vinculante

MERITO-Criterio para provisión de cargos públicos dentro de la administración/**MERITO**-Concepto/**CONCURSO PUBLICO**-Mecanismo idóneo para hacer efectivo el mérito

El mérito como criterio para la provisión de cargos públicos dentro de la administración y que consiste en los términos de la jurisprudencia de esta Corporación, en que el Estado pueda “contar con servidores cuya experiencia, conocimiento y dedicación garanticen, cada vez con mejores índices de resultados, su verdadera aptitud para atender las altas responsabilidades confiadas a los entes públicos, a partir del concepto según el cual el Estado Social de Derecho exige la aplicación de criterios de excelencia en la administración pública”. Igualmente, el mismo precepto establece que el mecanismo idóneo para hacer efectivo el mérito es el concurso público. En los términos de este artículo: “Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.

CONCURSO DE MERITOS-Etapas

La sentencia C-040 de 1995 reiterada en la SU-913 de 2009, explicó cada una de esas fases, las que por demás fueron recogidas por el legislador en el artículo 31 de la Ley 909 de 2004. Así: 1. Convocatoria. ... es la norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a la administración, como a las entidades contratadas para la realización del concurso y a los participantes. 2. Reclutamiento. Esta etapa tiene como objetivo atraer e inscribir el mayor número de aspirantes que reúnan los requisitos para el desempeño de los empleos objeto del concurso. 3. Pruebas. Las pruebas o instrumentos de selección tienen como finalidad apreciar la capacidad, idoneidad y adecuación de los aspirantes a los diferentes empleos que se convoquen, así como establecer una clasificación de los candidatos respecto a las calidades requeridas para desempeñar con efectividad las funciones de un empleo o cuadro funcional de empleos. La valoración de estos factores se efectuará a través de medios técnicos, los cuales deben responder a criterios de objetividad e imparcialidad. 4. Listas de elegibles. Con los resultados de las pruebas...se elaborará en estricto orden de mérito la lista de elegibles que tendrá una vigencia de dos (2) años. Con ésta y en estricto orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso. 5. Período de prueba. La persona no inscrita en carrera administrativa que haya sido seleccionada por concurso será nombrada en período de prueba, por el término de seis (6) meses, al final de los cuales le será evaluado el desempeño, de acuerdo con lo previsto en el reglamento. “Aprobado dicho período, al obtener evaluación satisfactoria, el empleado adquiere los derechos de la carrera, los que deberán ser declarados mediante la inscripción en el Registro Público de la Carrera Administrativa. De no obtener calificación satisfactoria del período de prueba, el nombramiento del empleado será declarado insubsistente”.

CONVOCATORIA A CONCURSO DE MERITOS-Importancia

La convocatoria es “la norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a la administración, como a las entidades contratadas para la realización del concurso y a los participantes”, y como tal impone las reglas que son obligatorias para todos, entiéndase administración y administrados-concursantes. Por tanto, como en ella se delinean los parámetros que guiarán el proceso, los participantes, en ejercicio de los principios de buena fe y confianza legítima, esperan su estricto cumplimiento. La Corte Constitucional ha considerado, entonces, que el Estado debe respetar y observar todas y cada una de las reglas y condiciones que se imponen en las convocatorias, porque su desconocimiento se convertiría en una trasgresión de principios axiales de nuestro ordenamiento constitucional, entre otros, la transparencia, la publicidad, la imparcialidad, así como el respeto por las legítimas expectativas de los concursantes. En consecuencia, las normas de la convocatoria sirven de autovinculación y autocontrol porque la administración debe “respetarlas y que su actividad, en cuanto a la selección de los aspirantes que califiquen para acceder al empleo o empleos correspondientes, se encuentra previamente regulada

REGLAS DEL CONCURSO DE MERITOS-Son invariables

Las reglas del concurso son invariables tal como lo reiteró esta Corporación en la sentencia SU-913 de 2009 al señalar “...resulta imperativo recordar la intangibilidad de las reglas que rigen las convocatorias de los concursos públicos para acceder a cargos de carrera en tanto no vulneren la ley, la Constitución y los derechos fundamentales en aras de garantizar el derecho fundamental a la igualdad, así como la inmodificabilidad de las listas de elegibles una vez éstas se encuentran en firme como garantía de los principios de buena fe y confianza legítima que deben acompañar estos procesos.”

CONVOCATORIA A CONCURSO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION-Tesis de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado sobre la utilización del registro definitivo de elegibles

CONVOCATORIA A CONCURSO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION-Análisis del régimen jurídico

CONVOCATORIA A CONCURSO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION-Análisis sobre el uso del registro de elegibles para proveer las vacantes que registra la entidad en plazas que no fueron ofertadas

LISTA DE ELEGIBLES EN FISCALIA GENERAL DE LA NACION PARA PROVEER CARGOS POR FUERA DEL NUMERO DE CONVOCADOS-Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia

LISTA DE ELEGIBLES EN FISCALIA GENERAL DE LA NACION PARA PROVEER CARGOS POR FUERA DEL NUMERO DE CONVOCADOS-Jurisprudencia del Consejo de Estado

LISTA DE ELEGIBLES-Naturaleza/**LISTA DE ELEGIBLES**-Concepto

La lista o registro de elegibles es un acto administrativo de carácter particular que tiene por finalidad establecer la forma de provisión de los cargos objeto de concurso, con un carácter obligatorio para la administración. Junto con la etapa de la convocatoria, es una fase hito y concluyente del sistema de nombramiento por vía del concurso público, dado que a través de su conformación, la entidad pública con fundamento en los resultados de las distintas fases de selección, organiza en estricto orden de mérito el nombre de las personas que deben ser designadas en las plazas ofertadas en la convocatoria, observando para ello, las precisas reglas fijadas

en ésta. Este acto tiene una vocación transitoria toda vez que tiene una vigencia específica en el tiempo. Esta vocación temporal tiene dos objetivos fundamentales. El primero, hace referencia a la obligatoriedad del registro de elegibles, porque durante su vigencia la administración debe hacer uso de él para llenar las vacantes que originaron el llamamiento a concurso. El segundo, que mientras esté vigente ese acto, la entidad correspondiente no podrá realizar concurso para proveer las plazas a las que él se refiere, hasta tanto no se agoten las vacantes que fueron ofertadas, de forma que se satisfagan no solo los derechos subjetivos de quienes hacen parte de este acto administrativo sino principios esenciales de la organización estatal como el mérito para ocupar cargos públicos y los específicos del artículo 209 constitucional. Con la conformación de la lista o registro de elegibles se materializa el principio del mérito del artículo 125 de la Constitución, en la medida en que con él, la administración debe proveer los cargos de carrera que se encuentren vacantes o los que están ocupados en provisionalidad debidamente ofertados.

CONVOCATORIA A CONCURSO PUBLICO-Obligación del Estado cuando se presentan vacantes en los cargos de carrera

La obligación del Estado en cumplimiento del artículo 125 constitucional es convocar a concurso público cuando se presenten vacantes en los cargos de carrera, con el objeto de cumplir la regla de la provisión por la vía del mérito y los principios que rigen la función pública, artículo 209 de la Constitución, específicamente los de igualdad, eficacia, economía, celeridad e imparcialidad, en donde la lista de elegibles producto de ese concurso tiene una vigencia en el tiempo que, por regla general, es de dos años, para que en el evento de vacantes en la entidad y en relación con los cargos específicamente convocados y no otros, se puedan proveer de forma inmediata sin necesidad de recurrir a nombramientos excepcionales como lo son el encargo o la provisionalidad.

CONFORMACION DE LA LISTA DE ELEGIBLES-Derecho de carácter subjetivo para quienes hacen parte de ella

La conformación de la lista de elegibles, así entendida, genera para quienes hacen parte de ella, un derecho de carácter subjetivo, que consiste en ser nombradas en el cargo para el que concursó, cuando el mismo quede vacante o esté desempeñando por un funcionario o empleado en encargo o provisionalidad. En ese sentido, la consolidación de este derecho “se encuentra indisolublemente determinado por el lugar que se ocupó dentro de la lista y el número de plazas o vacantes a proveer”.

LISTA DE ELEGIBLES-Finalidad

Es importante señalar, que la lista o registro de elegibles tiene dos cometidos, el primero, que se provean las vacantes, los encargos o las provisionalidades

para las cuales se convocó el respectivo concurso y no para otros, porque ello implicaría el desconocimiento de una de las reglas específicas de aquel: el de las plazas a proveer. El segundo, que durante su vigencia, la administración haga uso de ese acto administrativo para ocupar sólo las vacantes que se presenten en los cargos objeto de la convocatoria y no otros. Por tanto, no se puede afirmar que existe desconocimiento de derechos fundamentales ni de principios constitucionales cuando la autoridad correspondiente se abstiene de proveer con dicho acto empleos no ofertados. ¿Qué significa esta última función de la lista o registro de elegibles? Nada diverso a que las entidades públicas en cumplimiento del artículo 125 de la Constitución Política están obligadas a proveer únicamente las vacantes que se presenten en la respectiva entidad y que correspondan estrictamente a los cargos ofertados, respetando siempre el orden de su conformación. Cuando esta Corporación afirma que la lista o registro de elegibles tiene por vocación servir para que se provean las vacantes que se presenten durante su vigencia, se está refiriendo a los cargos objeto de la convocatoria y no a otros, pese a que estos últimos puedan tener la misma naturaleza e identidad de los ofrecidos. En otros términos, el acto administrativo en análisis tiene la finalidad de servir de soporte para la provisión de los empleos que fueron objeto de concurso y no de otros. En consecuencia, si en vigencia de la lista se presenta una vacante, ésta se podrá proveer con ella si la plaza vacante fue expresamente objeto de la convocatoria que le dio origen. Los cargos que se encuentren por fuera de ésta, requerirán de un concurso nuevo para su provisión. Se puede concluir, entonces, que el uso del registro o lista de elegibles se impone sólo para proveer las vacantes y los cargos en provisionalidad que registre la entidad durante su vigencia, siempre y cuando se trate de las plazas ofertadas en el respectivo concurso.

REGIMENES DE CARRERA ADMINISTRATIVA-Potestad de configuración del legislador

Es potestad del legislador señalar en la ley general de carrera o en las leyes de carrera especial que con el registro de elegibles se pueden proveer cargos diversos a los que fueron ofertados cuando sean de la misma naturaleza, perfil y denominación de aquellos. Facultad que también puede ostentar la entidad convocante, quien en las reglas que regirán el concurso puede señalar expresamente que la lista que se configure servirá para proveer las vacantes que se lleguen a presentar en vigencia de la lista para empleos de la misma naturaleza y perfil. La introducción de este criterio es una pauta de obligatoria observancia para la administración, que le permitirá, en el término de vigencia del registro de elegibles que se llegue a conformar, proveer las vacantes que se lleguen a presentar, por cuanto expresamente habilitó el uso de ese acto administrativo para tal efecto.

CONCURSO PUBLICO-Reglas son obligatorias tanto para la administración como para los administrados-concursantes

Las reglas del concurso son obligatorias tanto para la administración como para los administrados-concursantes, en donde admitir la utilización del registro de elegibles para proveer un número mayor de empleos a los que fueron ofertados, quebrantaría una de las normas que lo regían.

REGISTRO DE ELEGIBLES EN LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION PARA PROVEER CARGOS POR FUERA DEL NUMERO DE CONVOCADOS-Utilización implicaría una modificación e inobservancia de las pautas de las diversas convocatorias por vulneración del principio de confianza legítima, seguridad jurídica y mandato del artículo 125 constitucional

SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Efectos inter comunis

FISCALIA GENERAL DE LA NACION-Fijación de término para la realización de nuevos concursos

CARGOS TRANSITORIOS PARA JUSTICIA Y PAZ-Término de vigencia/**CARGOS TRANSITORIOS PARA JUSTICIA Y PAZ**-Pese a su carácter transitorio, deben ser igualmente llamados a concurso

El Decreto 122 de 2008, creó unos cargos de carácter transitorio para atender las necesidades de la Ley de Justicia y Paz y fijó como término de vigencia para esas plazas el de 12 años. El número de empleos de carácter transitorio creados por este decreto fue de 753. En relación con estos nuevos puestos de trabajo y pese a su carácter transitorio, considera la Corte que deben ser igualmente llamados a concurso, pues su naturaleza transitoria no puede entenderse como una excepción al cumplimiento de la regla del artículo 125 constitucional, en relación con el mérito y la calidad. Es precisamente ese carácter transitorio el que debe ser puesto en evidencia en la respectiva convocatoria, para que los aspirantes tengan claro que una de las reglas de la convocatoria es el carácter temporal de los cargos razón por la que los mismos serán suprimidos una vez venza el término señalado por el legislador, sino llega a disponer lo contrario. Supresión que en los términos del artículo 76 de la Ley 938 de 2004 “es una situación de carácter administrativo, que pone fin a la inscripción en el régimen de carrera y desvincula al servidor de la entidad...”. En consecuencia, la Fiscalía General de la Nación debe llamar a concurso los empleos temporales que creó el legislador extraordinario y establecer expresamente ese carácter para que quienes concursan, conozcan de antemano y en forma clara la regla que ha de regir su designación, en el evento de ser acreedores a ocupar una de esas plazas.

REGISTRO DE ELEGIBLES-Actualización

FISCAL GENERAL DE LA NACION-Grado de discrecionalidad para definir en el marco de la planta global, los cargos específicos que serían provistos con el registro de elegibles

SERVIDORES EN PROVISIONALIDAD-Estabilidad relativa

Los servidores en provisionalidad, tal como reiteradamente lo ha expuesto esta Corporación, gozan de una estabilidad relativa, en la medida en que sólo pueden ser desvinculados para proveer el cargo que ocupan con una persona de carrera, tal como ocurrió en el caso en estudio o por razones objetivas que deben ser claramente expuestas en el acto de desvinculación. En consecuencia, la terminación de una vinculación en provisionalidad porque la plaza respectiva debe ser provista con una persona que ganó el concurso, no desconoce los derechos de esta clase de funcionarios, pues precisamente la estabilidad relativa que se le ha reconocido a quienes están vinculados bajo esta modalidad, cede frente al mejor derecho que tienen las personas que ganaron un concurso público de méritos.

FISCAL GENERAL DE LA NACION-Límites a la discrecionalidad para provisión de cargos con registro de elegibles

FISCALIA GENERAL DE LA NACION-Vinculación de servidores en provisionalidad que son sujetos de especial protección mientras se realiza nuevo concurso

FISCALIA GENERAL DE LA NACION-Reglas para desvinculación de servidores en provisionalidad que son sujetos de especial protección previo acto administrativo motivado en los términos de la sentencia SU-917 de 2010

SERVIDORES EN PROVISIONALIDAD DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION-Definición

SERVIDORES EN PROVISIONALIDAD DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION QUE SON SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION-Condiciones para vinculación de aquellos que fueron retirados con fundamento en el concurso de 2007

Referencia: expedientes T-2.643.464
(Acumulados)

Acción de tutela instaurada por Nelson Triana Cárdenas y otros en contra de la Comisión Nacional de la Carrera de la Fiscalía General de la Nación.

Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil once (2011)

La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Juan Carlos Henao Pérez, -quien la preside-, María Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio, Nilson Pinilla Pinilla, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Humberto Antonio Sierra Porto y Luís Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente sentencia, teniendo en cuenta los siguientes

1. ANTECEDENTES

- 1.1.1. La Sala Sexta de Selección de la Corte Constitucional, mediante auto del 24 de junio de 2010, seleccionó para revisión, el expediente **T-2.643.464**, cuyo reparto correspondió al Despacho del Magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, expediente que se recibió el 7 de julio de 2010.
- 1.1.2. La Sala Séptima de Selección, mediante decisión del 7 de julio de 2010, decidió acumular los expedientes **T-2.648.563**, T-2.656.968, T-2.699.804, T-2.699.927, T-2.700.019, T-2.701.827, T-2.701.828, T-2.701.934, T-2.707.718, al expediente **T-2.643.464**. Estos expedientes se recibieron en el despacho el 28 de julio de 2010.
- 1.1.3. La misma sala de Revisión, mediante decisión del 22 de julio de 2010, decidió seleccionar el expediente T-2.667.567, que igualmente se acumuló al expediente **T-2.648.563**. Este último expediente se recibió en el despacho el 12 de agosto de 2010.
- 1.1.4. En la sesión del día 10 de agosto de 2010, la Sala Plena, con fundamento en el artículo 54A del Reglamento Interno de la Corte Constitucional, dispuso avocar el conocimiento de los expedientes de la referencia, razón por la que serán fallados por la Sala Plena de la Corporación en una sentencia de unificación y no por una de sus salas.
- 1.1.5. En la sesión del día 14 de enero de 2011, por la identidad de hechos, la Sala Plena decidió acumular al expediente de la referencia, la acción de tutela radicada bajo el número T-2.734.433, que fue seleccionada por la Sala de Selección No. 9 por auto del 7 de septiembre y asignada al despacho del doctor Jorge Iván Palacio Palacio, con el fin de que dicho caso hiciera parte de la sentencia de unificación que debe ser proferida en los términos del reglamento interno de la Corporación.

1.1.6. En la sesión del día 26 de enero de 2011, por la identidad de hechos, la Sala Plena decidió acumular al expediente de la referencia, la acción de tutela radicada bajo el número T-2.743.538, que fue seleccionada por la Sala de Selección No. 9 por auto del 22 de septiembre y asignada al despacho del doctor Luís Ernesto Vargas Silva, con el fin de que dicho caso hiciera parte de la sentencia de unificación que debe ser proferida en los términos del reglamento interno de la Corporación.

1.2. HECHOS

1.2.1. La Fiscalía General de la Nación, mediante Acuerdo 01 de 2006, expidió el reglamento para los procesos de selección y concurso de méritos en la entidad, teniendo en cuenta que por disposición del artículo 253 constitucional goza de autonomía para determinar el ingreso a la carrera, en los términos en que lo establezca el legislador.

En cumplimiento del mencionado acuerdo, el 9 septiembre de 2007 se publicaron 6 convocatorias para proveer distintos cargos de carrera en la entidad. En total fueron convocados a concurso **4697** cargos, de la siguiente manera¹:

1.2.1.1. Convocatoria 001-2007 para proveer 744 cargos de **Fiscal delegado ante jueces municipales y promiscuos.**

1.2.1.2. Convocatoria 002-2007 para proveer 732 cargos de **Fiscal delegado ante jueces del circuito.**

1.2.1.3. Convocatoria 003-2007 para proveer 298 cargos de **Fiscal delegado ante jueces penales del circuito especializado.**

1.2.1.4. Convocatoria 004-2007 para proveer 52 cargos de **Fiscal delegado ante Tribunal de Distrito.**

1.2.1.5. Convocatoria 005-2007 para proveer los cargos de **Asistente de Fiscal así:** Asistente de Fiscal I- **610** cargos; Asistente de Fiscal II- **819** cargos; Asistente de Fiscal III-**530** cargos; Asistente de Fiscal IV-**288** cargos.

1.2.1.6. Convocatoria 006-2007 para proveer 684 cargos de **Asistente judicial IV.**

1.2.2. Una vez concluidas las distintas fases del concurso para las seis convocatorias, se profirió el Acuerdo 007 de 2008, mediante el cual se expidió el registro definitivo de elegibles.

¹ <http://fgn.fiscalia.gov.co:8080/Fiscalia/contenido/html/carrera2007.jsp#>. Consulta efectuada el 15 de septiembre de 2010.

1.2.3. Con la expedición de dicho acto la entidad tenía la obligación de hacer lo nombramientos en los términos fijados en cada una de las convocatorias, lo que efectivamente empezó a cumplirse un año y medio después la ejecutoria del mencionado acto administrativo.

1.2.4. Un sinnúmero de concursantes e integrantes de ese registro, le solicitaron a la entidad hacer uso de ese acto administrativo para nombrarlos en período de prueba en cargos vacantes u ocupados en provisionalidad por ser de la misma naturaleza, perfil y grado de los ofertados.

1.2.5. La entidad se negó a hacer uso del registro de elegibles para efectuar los nombramientos que solicitaron los distintos concursantes, aduciendo que el número de plazas convocadas fue expresamente determinada y, en consecuencia, se requería de un nuevo concurso para llenar las vacantes que presentaba la entidad, pese a ser de la misma naturaleza y perfil de los cargos a que se refería el registro de elegibles.

1.2.6. Teniendo en cuenta lo anterior, en los expedientes seleccionados podemos identificar dos grupos:

1.2.6.1. En el primero están quienes participaron en una o dos de las convocatorias que se reseñaron y aunque quedaron en el registro de elegibles, la Fiscalía General de la Nación no los nombró porque el puesto que ocuparon excedía el del número de plazas ofertadas. Sin embargo, alegan que en la entidad hay un número suficiente de cargos iguales a los que fueron objeto de concurso que son desempeñados por empleados en provisionalidad o que están vacantes, razón por la que consideran que tienen el derecho a ser nombrados por estar vigente una lista de elegibles que debe ser empleada para proveer los empleos de la misma naturaleza de los que fueron ofertados.

Este grupo de accionantes arguye que la negativa de la entidad afecta sus derechos fundamentales a la igualdad, artículo 13; el acceso a cargos públicos, artículo 40, numeral 7; y el principio del mérito que consagra el artículo 125 de la Constitución.

1.2.6.2. En el segundo están quienes desempeñaban un cargo en la Fiscalía en provisionalidad y no participaron en ninguna de las convocatorias que se reseñaron, o participaron, pero no alcanzaron el puntaje mínimo, o se encuentran en la lista de elegibles, pero no han sido llamados. Estos accionantes consideran que tienen el derecho a permanecer en sus cargos provisionalmente, bien porque tienen una condición especial que obliga a una protección particular; o porque la entidad ha debido tener unos criterios para dar por terminada su provisionalidad.

Estos funcionarios y empleados consideran que cuando la entidad accionada decidió dar por terminada su relación laboral, afectó, entre otros, sus derechos fundamentales a la igualdad, artículo 13; al trabajo, artículo 25; a la seguridad social, artículo 48 y al debido proceso, artículo 29 de la Constitución.

A continuación se hace un resumen de cada uno de los expedientes seleccionados, discriminados en los grupos antes reseñados.

1.2.6.2.1. Primer grupo

1.2.6.2.1.1. Expediente T-2.643.464. Actor: Nelson Triana Cárdenas. Este ciudadano participó en las convocatorias 001-2007 para Fiscal Delegado ante los Jueces Penales Municipales y Promiscuos y en la 002-2007 para Fiscal Delegado ante los Jueces Penales del Circuito. En la primera convocatoria ocupó el lugar **1468** y en la segunda el **2010**. La Fiscalía General de la Nación le informó que su nombramiento no era posible por cuanto el número de cargos convocados para la convocatoria 001-2007 sólo fue de **744** y para la 002-2007 de **734**.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en decisión del 4 de marzo de 2010, declaró improcedente la acción de tutela al considerar que los derechos fundamentales que el señor **Triana Cárdenas** argüía como vulnerados no lo estaban.

La Sala de Tutelas de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia², en sentencia del 8 de abril de 2010, confirmó la anterior providencia, pero con fundamento en razones distintas. Se señaló que el señor **Triana Cárdenas** tenía otros mecanismos de defensa judicial. En criterio de la Sala de Tutelas, como quiera que el actor estaba cuestionando la decisión administrativa contenida en las convocatorias 001 y 002 de 2007 por medio de las cuales se ofertaron a concurso de méritos sólo 744 cargos de Fiscal Delegado ante los Jueces Municipales y 734 de Fiscal Delegado ante los Jueces del Circuito, éste ha debido acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y, a través de la acción de nulidad, cuestionar las reseñadas convocatorias, por tratarse de un acto administrativo de carácter general e impersonal.

1.2.6.2.1.2. Expediente T-2.648.563. Actor: Joaquín González Bohórquez. Este actor participó en la convocatoria 02-2007 para el cargo de Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito en la que ocupó el puesto **70** con **77** puntos y en la convocatoria 004-2007 de Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior de Distrito en la que logró el puesto **112**, con **74** puntos. Alega que como la Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Penal, en providencia del 11 de febrero de 2010, ordenó al Fiscal

² M.P. María del Rosario González Lemos.

General de la Nación el nombramiento de la totalidad de los cargos existentes, hasta agotar la lista de elegibles publicada mediante Acuerdo 007 de noviembre de 2008, tenía el derecho a ser nombrado como Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior de Distrito por cuanto en la entidad hay 144 cargos de esa naturaleza, de los cuales sólo 52 fueron ocupados por quienes ganaron el concurso, las restantes plazas las ejercen funcionarios en provisionalidad frente a los cuales el actor aduce tener un mejor derecho por estar en la lista de elegibles.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, en providencia del 8 de marzo de 2010, negó el amparo por la existencia de otros mecanismos de defensa judicial.

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Tutelas de la Sala de Casación Penal³, mediante providencia del 13 de abril de 2010, confirmó el fallo de primera instancia al considerar que los reparos contra las convocatorias, por ejemplo, por el número de puestos a proveer, debían alegarse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, porque el juez de tutela no tiene la competencia para variar una convocatoria para un concurso público. Como fundamento de su decisión, la Sala de Tutelas a la Sala de Casación Penal citó una consulta que absolvió la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado⁴.

1.2.6.2.1.3. Expediente T-2.656.968. Actoras: Luisa Gineth Pinto Ochoa y Gloria Mariño Quiñónez. Estas ciudadanas participaron en la convocatoria 004-2007 para el cargo de Fiscal Delegado ante Tribunal de Distrito. Las accionantes ocuparon los puestos 77 y 87 respectivamente y no fueron nombradas porque los cargos convocados sólo fueron 52.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, Sala Penal, en providencia del 18 de marzo de 2010, negó la acción tutela, aduciendo que las accionantes no pusieron en conocimiento del nominador los argumentos de orden fáctico y jurídico en los cuales fundamentaban su derecho a ser nombradas en la entidad acusada, como tampoco agotaron la vía gubernativa a través de la cual podían solicitar la suspensión del acto administrativo mediante el cual se efectuó la convocatoria para los 52 empleos de Fiscal Delegado ante Tribunal de Distrito.

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Tutelas de la Sala de Casación Penal⁵, en providencia del 22 de abril de 2010, confirmó el fallo de primera instancia por la falta de cumplimiento del requisito de

³ M.P. José Leonidas Bustos Martínez.

⁴ Cfr. Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Consejero Ponente, Luís Fernando Álvarez Jaramillo. Radicación 1976 de febrero 4 de 2010. Al contenido de esta consulta haremos referencia en el considerando 5.1.1.3.2 de esta providencia.

⁵ M.P. María del Rosario González Lemos.

inmediatez, por cuanto la acción de tutela se interpuso luego de transcurridos dos años de la fecha de la convocatoria a concurso, es decir, septiembre de 2007.

1.2.6.2.1.4. Expediente T-2.699.804. Actora: Beatriz Alicia Idarraga Piedrahita. Esta ciudadana se presentó a la convocatoria 004-2007 para el cargo de Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior, en el registro de elegibles se encuentra en **el puesto 118** con 74 puntos. Su inconformidad radica en el hecho de que la Fiscalía General de la Nación solamente designó en período de prueba a los 52 primeros de la lista para proveer los cargos convocados, a pesar de que existen más de 90 cargos del mismo rango que son desempeñados por funcionarios en provisionalidad y que en virtud de la orden de la Corte Suprema de Justicia⁶ debían ser provistos con el registro de elegibles.

La Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira, en fallo del 7 de abril de 2010, negó el amparo por cuanto no encontró que le asistiera derecho alguno a la peticionaria para ser nombrada por la entidad accionada, toda vez que la convocatoria 004-2007 sólo llamó a concurso a 52 plazas, las cuales ya están ocupadas por quienes alcanzaron los primeros 52 lugares en la lista.

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Tutelas de la Sala de Casación Penal⁷, mediante fallo del 28 de mayo de 2010, confirmó la decisión de primera instancia, al considerar que no se justificaba la intervención del juez constitucional para impartir la orden al nominador de nombrar a quien a pesar de integrar el registro de elegibles no alcanzó uno de los puestos que debía proveerse conforme con el número de plazas convocadas.

1.2.6.2.1.5. Expediente T-2.699.927. Actora: Cielo del Pilar Bonilla Arias. Se inscribió para participar en la convocatoria 001-2007 para Fiscal Delegado ante Jueces Municipales y Promiscuos y ocupó el puesto **1731** con 51 puntos. Así mismo, participó en la convocatoria 005-2007, para el cargo de Asistente de Fiscal II, en la que ocupó el **puesto 99** con 68 puntos.

El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, el 14 de abril de 2010, declaró improcedente la acción de tutela, por la existencia de otros medios de defensa judicial y agregó que el juez de tutela no podía ordenar la prolongación de una lista que a la fecha se encontraba vigente.

⁶ Se refiere al fallo del 11 de febrero de 2010, proferido por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. M.P. Alfredo Gómez Quintero, que ordenó a la Fiscalía General de la Nación hacer los nombramientos con fundamento en el registro de elegibles.

⁷ M.P. Alfredo Gómez Quintero.

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Tutelas de la Sala de Casación Penal⁸, el 27 de mayo de 2010, confirmó el fallo y señaló que a la accionante no le asistía ningún derecho sobre los cargos convocados.

1.2.6.2.1.6. Expediente T-2.701.827. Actora: Luz Alieth Molina Raigosa.

Esta ciudadana participó en la convocatoria 001 de 2007 para el cargo de Fiscal Delegado ante los Jueces Penales Municipales y Promiscuos, ocupó el **puesto 902** con 61 puntos. Así mismo, se presentó en la convocatoria 002-2007 para el cargo de Fiscal Delegado ante los Jueces del Circuito, que no aprobó porque sólo obtuvo 57 puntos. Considera que aunque sólo se ofertaron **744** plazas para Fiscal Delegado ante los Jueces Penales Municipales y Promiscuos, debe darse cumplimiento a lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 4 de febrero de 2010, en el sentido de proveer la totalidad de los cargos vacantes que, en el caso de los Fiscales Delegados ante los Jueces Penales Municipales, ascienden a más de **1547**.

El Tribunal Superior de Medellín, Sala Penal, el 22 de abril de 2010, tuteló los derechos fundamentales de acceso a ocupar un cargo público; al debido proceso y a la igualdad de la accionante y, en consecuencia, ordenó a la Fiscalía depurar las listas de elegibles y ampliar los cargos a proveer mediante concurso.

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Tutelas de la Sala de Casación Penal⁹, en fallo del 27 de mayo de 2010, confirmó la decisión, al considerar que una vez ocupados los cargos que fueron ofertados, le correspondía a la Fiscalía General de la Nación hacer uso del registro de elegibles, en cumplimiento del artículo 66 de la Ley 938 de 2004, según el cual dicho acto debe utilizarse para proveer las vacantes que se den durante su vigencia. Por tanto, en aplicación de los principios de eficacia y economía, se ordenó al Fiscal General de la Nación hacer uso de la lista de elegibles vigente para proveer todos los cargos de la misma naturaleza de los convocados.

1.2.6.2.1.7. Expediente T-2.701.828. Actor: Robinson González Pérez.

Este actor participó en la convocatoria 001-2007 para el cargo de Fiscal Delegado ante los Jueces Municipales y Promiscuos y ocupó el **puesto 1501** con 54 puntos. Señala que a nivel nacional hay más de 1500 cargos de Fiscal Delegado ante los Jueces Municipales y Promiscuos, razón por la que tiene derecho a ser nombrado en uno de esos cargos, los cuales están desempeñados por personas en provisionalidad. Con ese objetivo, elevó un derecho de petición ante la entidad, sin que a la fecha de la interposición de la acción de tutela le fuera resuelto. Es importante señalar que también participó en la convocatoria 005-2007, para Asistente de Fiscal IV, en la que ocupó el **puesto 280** con 64 puntos.

⁸ M.P. Alfredo Gómez Quintero.

⁹ M.P. Alfredo Gómez Quintero.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, Sala Penal de Decisión, el 2 de marzo de 2010, amparó el derecho fundamental de petición del actor y, en consecuencia, ordenó a la Fiscalía General de la Nación dar respuesta a la solicitud elevada por éste. En relación con la pretensión principal: ser designado en uno de los cargos que están siendo desempeñados en provisionalidad, declaró su improcedencia.

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Tutelas de la Sala de Casación Penal¹⁰, el 27 de mayo de 2010, revocó el fallo y ordenó a la Fiscalía retomar el proceso de designación de los cargos que salieron a concurso con el registro de elegibles vigente hasta su agotamiento.

1.2.6.2.1.8. Expediente T-2.667.567. Actora: Ronit Janet Caldas Rueda, Esta ciudadana participó en la convocatoria 004-2007 para Fiscal Delegado ante los Tribunales Superiores y ocupó el **puesto 107** con 74 puntos. Afirma que a nivel nacional la institución tiene más de 100 cargos de esa misma naturaleza, razón por la que dice tener derecho a ser nombrada en una de las plazas que están siendo desempeñadas por personas en provisionalidad.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, el 2 de marzo de 2010, denegó el amparo solicitado por cuanto la solicitante aceptó las reglas de la convocatoria y una de ellas era el número de puestos ofertados.

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Tutelas de la Sala de Casación Penal¹¹, el 27 de mayo de 2010, confirmó la decisión al considerar que los reparos contra la convocatoria, por ejemplo, el número de puestos a proveer, debían ser resueltos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. El juez de tutela no tiene competencia para variar la convocatoria que efectuó la Fiscalía General de la Nación, para el efecto, se cita la consulta que absolvió la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado¹².

1.2.6.2.2. Segundo grupo

1.2.6.2.2.1. Expediente T-2.700.019. Actora: Bolivia Renza Bacca. Esta ciudadana ocupaba el cargo de Fiscal Delegada ante los Jueces Municipales y Promiscuos en provisionalidad desde el 10 de febrero de 2005. Participó en una de las convocatorias pero sólo obtuvo 59 puntos sobre los 60 requeridos para pasar. El 2 de marzo de 2010, la Fiscalía General de la Nación, mediante acto administrativo, dio por terminado

¹⁰ M.P. Alfredo Gómez Quintero.

¹¹ M.P. José Leonidas Bustos.

¹² Tal como se advirtió en precedencia, al contenido de esta consulta nos referiremos en otro acápite de esta providencia.

su nombramiento en provisionalidad, desconociendo su condición de madre cabeza de familia, hecho que considera discriminatorio y desigual, porque otros funcionarios que, como ella, no superaron el concurso, siguen vinculados a la entidad. Solicita la protección transitoria de sus derechos, mientras se surte el proceso ante la jurisdicción contencioso administrativa.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali-Sala de Decisión Constitucional-, mediante decisión del 19 de abril de 2010, negó el amparo solicitado, por considerar que tiene un mejor derecho quien ha ocupado los primeros puestos en un concurso de méritos frente a uno en provisionalidad.

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Tutelas de la Sala de Casación Penal¹³, en fallo del 27 de mayo de 2010, decidió confirmar en su integridad el fallo de primera instancia.

1.2.6.2.2.2. Expediente T-2.701.934. Actor: Mauro de Jesús Ávila Tibatá.

Este accionante se encontraba ocupando un cargo en provisionalidad en la Fiscalía General de la Nación y se presentó a la convocatoria 003-2007 para proveer 298 cargos de Fiscal Delegado ante los Jueces Penales del Circuito Especializados y ocupó el puesto **405** con un puntaje de 65 puntos. Igualmente, participó en la convocatoria 002-2007 para Fiscal Delegado ante los Jueces Penales del Circuito, en la que ocupó el puesto **855** con 66 puntos.

La entidad demandada nombró en el puesto que desempeñaba a quien aprobó el concurso y, en consecuencia, dio por terminada su vinculación con la entidad. Sin embargo, considera que la entidad ha debido remover primero a los funcionarios que no tenían ninguna opción de permanencia, bien porque no concursaron o porque no pasaron el concurso. En ese sentido, considera desconocido su derecho fundamental a la igualdad, puesto que la Fiscalía ha debido cesar la provisionalidad en estricto orden, iniciando por quienes no se presentaron al concurso, siguiendo con quienes no lo pasaron y terminando con los concursantes que se encontraban en los últimos puestos de la lista de elegibles.

La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Villavicencio resolvió amparar los derechos fundamentales del demandante y ordenó su vinculación en un cargo de provisionalidad que ostente un funcionario que no haya concursado o no hubiere aprobado el concurso.

La Sala de Decisión Penal de la Corte Suprema de Justicia¹⁴, revocó el fallo y, en su lugar, negó por improcedente la acción, por no ser el

¹³ M.P. Alfredo Gómez Quintero.

¹⁴ M.P. Yesid Ramírez Bastidas

medio idóneo para dar respuesta a la inconformidad del señor Ávila Tibatá.

1.2.6.2.2.3. Expediente T-2.707.718. Actor: Tomás Florentino Serrano Serrano. Este ciudadano se presentó en la convocatoria 003-2007 para el cargo de Fiscal Delegado ante los Jueces Especializados de Pereira, ocupó el puesto 60 con un puntaje de 70 puntos, razón por la que fue designado para ocupar uno de los cargos disponibles. Igualmente, participó en la convocatoria 004-2007 para Fiscal Delegado ante Tribunal Superior, en la que ocupó el puesto 146 con 73 puntos.

Frente a este último cargo, solicitó a la Comisión Nacional de Administración de Carrera de la Fiscalía la actualización de su hoja de vida, con el fin de ser designado Fiscal Delegado ante los Tribunales. La Comisión Nacional de Administración de Carrera negó la petición aduciendo que este ciudadano ocupó el puesto 146 de los 52 que fueron convocados a concurso.

El Tribunal Superior de Medellín, Sala de Decisión Penal, en fallo del 22 de abril de 2010, negó la tutela de los derechos fundamentales invocados.

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal¹⁵, mediante providencia del 27 de mayo de 2010, amparó los derechos al debido proceso y a la igualdad en el acceso a cargos públicos del actor, previniendo a la Comisión Nacional de Administración de Carrera de la Fiscalía, para que en el término de diez (10) días, informara a todos los integrantes del registro de elegibles sobre la posibilidad de solicitar la actualización del mismo.

1.2.6.2.2.4. Expediente T-2.734.433. Actor: Reinaldo de Jesús Gómez Muñetón. Este ciudadano ingresó a la Fiscalía General en abril de 2007 en donde ocupó el cargo de Fiscal Delegado ante los Jueces Municipales y Promiscuos en diversas sedes. Para el año 2009 ocupaba la Fiscalía 29 de Guayabetal. Dice haber participado en una de las convocatorias pero sólo obtuvo 51 puntos en la primera prueba eliminatoria. El 7 de abril de 2010, la Fiscalía General de la Nación dio por terminado su nombramiento en provisionalidad, desconociendo su condición de invidente en razón del desprendimiento de retina total de ambos ojos, según certificación médica que obra en el expediente¹⁶, hecho que considera discriminatorio y desigual, porque otros funcionarios que, como él, no superaron el concurso y no tienen limitaciones físicas, siguen vinculados a la entidad. Señala que con la decisión del ente investigador se desconocieron sus derechos al debido proceso, a la igualdad, al mínimo vital de él y su familia, compuesta por su esposa y

¹⁵ M.P. Alfredo Gómez Quintero.

¹⁶ Folio 18 del cuaderno principal.

tres hijos, uno de ellos con una incapacidad laboral del 69.15%, quienes dependen económicamente del accionante. En consecuencia, solicita la suspensión del acto que dio por terminada su provisionalidad y se le reintegre a un cargo igual o de mejor jerarquía al que venía ocupando.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio –Sala Civil –, mediante decisión del 28 de abril de 2010, amparó los derechos del señor Gómez Muñetón al considerar que si bien es cierto los ganadores de un concurso tienen un mejor derecho que el de los provisionales, también lo es que la administración debe tener especial cuidado con las personas que se encuentren en una situación de debilidad manifiesta, tal como lo ordena el artículo 13 de la Constitución y los tratados internacionales que, por disposición del artículo 93 constitucional hacen parte del bloque de constitucionalidad. En ese sentido, encontró que la Fiscalía ordenó terminar la provisionalidad únicamente del demandante, pese a su especial condición, existiendo en la misma unidad 16 provisionales, frente a los cuales no se probó que tuvieran una condición especial para mantenerlos en la entidad con una preferencia frente al actor, pues, al parecer, tampoco aprobaron el concurso.

En consecuencia, ordenó que en el término de los cinco (5) días siguientes al fallo, la Fiscalía tenía que suspender el acto administrativo mediante el cual se desvinculó al actor, reintegrarlo y decidir que otro fiscal debía salir de la institución, siempre y cuando no estuviera en una situación de especial protección. La acción se concedió como mecanismo transitorio, mientras se acudía a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil¹⁷, en fallo del 19 de junio de 2010, decidió revocar en su integridad el fallo de primera instancia, toda vez que el accionante podía recurrir el acto de desvinculación ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en donde se podía ordenar la suspensión provisional para la protección de los derechos que se dicen vulnerados. En otros términos, el señor Gómez Muñetón contaba con otros medios de defensa judicial que hacían improcedente la acción de tutela.

1.2.6.2.2.5. Expediente T-2.743.538. Actora: Gloria Nelly Delgado Castañeda. Esta ciudadana ingresó a la Fiscalía General en febrero 14 de 2002 para ocupar el cargo de Fiscal Delegada ante los Jueces Promiscuos y Municipales en Bucaramanga. Dice haber participado en una de las convocatorias pero sólo obtuvo 59 puntos en la primera prueba eliminatoria, razón por la que no aparece en el registro de elegibles. El 16 de marzo de 2010, la Fiscalía General de la Nación mediante acto administrativo, dio por terminado su nombramiento en

¹⁷ M.P. Cesar Julio Valencia Copete.

provisionalidad, para nombrar a una persona que ganó el concurso, desconociendo no sólo su condición física y de salud, pues según se lee en la historia clínica sufrió amputación del brazo derecho y actualmente padece de síndrome del tunel carpiano izquierdo¹⁸, sino la de madre cabeza de familia y el estar a menos de un año para cumplir los requisitos para obtener la pensión, razones suficientes para solicitar la suspensión del acto que dio por terminada su provisionalidad, como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y el reintegro a un cargo de igual o de mejor jerarquía al que venía ocupando, máxime cuando en la entidad permanecen vinculadas otras personas en provisionalidad que no están en las condiciones especiales en que se encuentra la solicitante.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga– Sala Civil-Familia, mediante decisión del 21 de abril de 2010, amparó los derechos a la igualdad, al trabajo y al mínimo vital de la accionante, al considerar que si bien existían otros mecanismos de defensa judicial como la acción de nulidad y reestablecimiento del derecho para la protección de los derechos que se dicen vulnerados, la especial situación física de la doctora **Delgado Castañeda** imponía su protección, razón por la que le ordenó a la Fiscalía General de la Nación reubicarla en un cargo vacante acorde con su situación laboral, siempre que no implique desmejora de sus condiciones laborales.

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil¹⁹, en fallo del 24 de junio de 2010, decidió revocar en su integridad el fallo de primera instancia, toda vez que la tutelante podía recurrir el acto de desvinculación ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en donde se puede ordenar la suspensión provisional del acto de desvinculación para la protección de los derechos que se dicen vulnerados. En otros términos, la accionante contaba con otros medios de defensa judicial que hacían improcedente la acción de tutela.

1.3. PRUEBAS SOLICITADAS EN SEDE DE REVISIÓN

1.3.1. Con el objeto de despejar algunos interrogantes en relación con el concurso que convocó la Fiscalía General de la Nación, el Magistrado sustanciador, por auto del 23 de septiembre de 2010, le formuló un cuestionario al Fiscal General de la Nación (e) de doce preguntas, así:

“1.1. ¿Cuál es el número total de la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación? Especificar número de cargos de libre nombramiento y remoción y los de carrera; 1.2. Del número de la planta total de cargos de carrera, ¿cuál fue el

¹⁸ Folio 7 del cuaderno original. Razón por la cual se recomienda no realizar labores que generen exposición a sobre esfuerzo y fatigas o posturas inadecuadas de las manos

¹⁹ M.P. Edgardo Villamil Portilla.

criterio que se tuvo para convocar sólo una parte de ella? Explicar las razones por las cuales sólo se convocó un número específico de cargos y no la totalidad de la planta?; 1.3. ¿Con qué criterio se determinó el cargo que sería provisto mediante concurso? En otros términos, cómo se estableció cuáles eran, por ejemplo, los 52 cargos de Fiscal Delegado ante Tribunal que serían provistos; los 744 de Fiscal Delegado ante Jueces Municipales y Promiscuos y así sucesivamente con cada convocatoria. ¿Hubo una escogencia previa al concurso o ésta se hizo posterior? ¿Los concursantes y los empleados provisionales tenían conocimientos de cuáles plazas, específicamente, salían a concurso?; 1.4. ¿Existe alguna diferencia de rango, perfil o de otra clase, entre los cargos que fueron convocados a concurso y los que posteriormente fueron creados o cuya eliminación fue descartada? ¿Cuál es la situación de los Fiscales adscritos a Justicia y Paz? ¿Hubo un examen específico para atender la exigencia del sistema de responsabilidad penal juvenil?; 1.5. ¿Cuál fue el costo total de la convocatoria que se efectuó mediante el Acuerdo No. 001 de 2006?; 1.6. ¿Cuáles son los criterios que ha empleado la Fiscalía General de la Nación para asignar los cargos una vez se conformó el registro de elegible, teniendo en cuenta que se trata de una planta global a nivel nacional? ¿Los concursantes podían escoger la plaza, era esa una decisión vinculante?; 1.7. ¿Cuál fue el puntaje mínimo que impuso la entidad para pasar el concurso?; 1.8. A la fecha ¿cuántos cargos de la planta de personal de carrera ha sido provisto con fundamento en el registro de elegibles producto del Acuerdo No.001 de 2006? ¿A qué criterios ha respondido esa provisión?; 1.9. ¿Cuál es la fecha de vencimiento del registro de elegibles que se conformó para el concurso en mención?; 1.10. ¿Cuántas personas se presentaron al concurso y cuántos superaron las diferentes pruebas? ¿Es posible determinar de ese número de concursantes cuántos eran funcionarios de la entidad y que número de ellos obtuvo el puntaje mínimo para hacer parte del registro de elegibles?; 1.11. ¿Se tiene o tuvo previsto algún plan para aquellas personas que están ocupando un cargo de carrera en provisionalidad y están próximos a obtener su derecho a la pensión?; 1.12. ¿Se ha efectuado la actualización de datos a los que se refiere el artículo 24 del Acuerdo 001 de 2006? En caso afirmativo, qué variaciones ha sufrido el registro de elegibles.”

La respuesta al anterior cuestionario fue radicada en esta Corporación el 6 de octubre y a ella se hará referencia en los acápites correspondientes.

En el mismo auto, se ordenó a la Secretaria General de la Corte Constitucional, informar a todos los interesados la existencia del proceso de la referencia para que, si así lo consideraban, intervinieran en él. Para el efecto, se ordenó la publicación de un aviso en un medio de amplia circulación, para que el público en general y específicamente las personas que intervinieron en las seis (6) convocatorias, como a los empleados en provisionalidad del mencionado organismo, presentaran sus intervenciones dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación del respectivo aviso.

En cumplimiento de la orden anterior, se publicó en el diario “El Tiempo” del domingo 3 de octubre un aviso para que todos los interesados en el proceso de la referencia i) presentaran su intervención y ii) notificarlos de la existencia del asunto y vincularlos con la decisión que se llegare a adoptar.

Como consecuencia de la publicación se presentaron cientos de intervenciones que apoyan a uno de los dos grupos reseñados en los numerales 1.2.5.1 y 1.2.5.2.

1.3.2. El Magistrado sustanciador, por auto del 25 de octubre de 2010, le formuló otros interrogantes al Fiscal General de la Nación (e), así:

“1.1. Especificar el efecto de cada uno de los siguientes actos, Acuerdos 002 y 004 de septiembre 30 de 2008, Acuerdo 007 del 24 de noviembre de 2008, Acuerdo 032 de 30 de diciembre de 2009 y Acuerdo 001 del 19 de enero de 2010. 1.2 ¿Explicar por qué, a pesar de las variaciones que ha tenido el registro de elegibles, se afirma que su fecha de vencimiento se cuenta a partir del 24 de noviembre de 2008? 1.3. ¿ La provisión de cargos que se hizo con fundamento en la orden de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha cubierto cargos creados por el Decreto 122 de 2008 o la Ley 975 de 2005? En el evento en que la respuesta sea positiva, se pueden determinar qué plazas o cargos son esos?”

La respuesta fue recibida en esta Corporación el 29 de octubre y a ella se hará referencia en el momento oportuno.

2. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

2.1. COMPETENCIA

Esta Corte es competente de conformidad con los artículos 86 y 241 de la Constitución Política, y con el Decreto 2591 de 1991, para revisar los fallos de tutela en los expedientes de la referencia y que fueron

acumulados por decisiones de la Sala de Selección competente y de la Sala Plena.

2.2. PROBLEMA JURÍDICO

La Sala Plena debe establecer el alcance del registro de elegibles que profirió la Fiscalía General de la Nación para las seis convocatorias, de tal forma que se pueda dar respuesta a las pretensiones de los dos grupos de accionantes que fueron identificados según sus solicitudes a los diferentes jueces de tutela en otro acápite de esta providencia.

2.2.1. En el primer grupo de casos seleccionados, se hallan quienes participaron en una o dos de las seis convocatorias que abrió la Fiscalía General de la Nación en el año 2007 y aunque superaron el concurso, por el puesto que ocuparon en el registro de elegibles y que excedía el número de plazas a proveer según los términos de cada una de ella, no fueron nombrados. Respecto a este grupo, corresponde a la Corte determinar si la Fiscalía General de la Nación vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad, artículo 13; al acceso a cargos públicos, artículo 40, numeral 7; y el principio del mérito que consagra el artículo 125 de la Constitución.

2.1.2. En el segundo grupo de casos seleccionados, están quienes desempeñaban un cargo en la Fiscalía en provisionalidad y **i)** no participaron en ninguna de las convocatorias, o **ii)** participaron, pero no alcanzaron el puntaje mínimo, o **iii)** se encontraban en la lista de elegibles en un puesto que excedía el número de plazas convocadas, razón por la cual no fueron nombrados. Estos accionantes, que fueron desvinculados y reemplazados por personas que superaron el concurso o cobijados por una decisión judicial, consideran que tienen derecho a permanecer en sus cargos provisionalmente porque: **a)** tienen una condición especial que obliga a que se les brinde un trato preferente, por ejemplo, porque se hallan en situación de discapacidad; o **b)** la entidad ha debido formular unos criterios objetivos en virtud del principio de igualdad para seleccionar a los provisionales que serían desvinculados.

Respecto a este grupo, le corresponde a la Corte resolver dos interrogantes: **i)** si la Fiscalía General de la Nación vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, a la seguridad social y al debido proceso de quienes están en una situación de especial protección constitucional, al desvincularlos del cargo que ocupaban en provisionalidad, pese a su condición, cuando era posible desvincular a otros servidores en provisionalidad no sujetos a un trato preferente y **ii)** Determinar si la entidad demandada desconoció los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso de los demás provisionales –no sujetos de especial protección- al no señalar de

antemano los criterios de selección de los cargos específicos que serían provistos con personas que superaron el concurso.

- 2.1.3.** Para resolver los anteriores problemas, la Sala determinará, **i)** el alcance y la obligatoriedad de las reglas del concurso que efectuó la Fiscalía General de la Nación y **ii)** la naturaleza, alcance y fuerza vinculante del registro de elegibles que se elaboró.

3. EL SISTEMA DE CARRERA ADMINISTRATIVA, EL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS: LA OBLIGATORIEDAD DE LAS REGLAS Y SUS ALCANCES

- 3.1.** El artículo 125 de la Constitución establece **el mérito** como criterio para la provisión de cargos públicos dentro de la administración y que consiste en los términos de la jurisprudencia de esta Corporación, en que el Estado pueda *“contar con servidores cuya experiencia, conocimiento y dedicación garanticen, cada vez con mejores índices de resultados, su verdadera aptitud para atender las altas responsabilidades confiadas a los entes públicos, a partir del concepto según el cual el Estado Social de Derecho exige la aplicación de criterios de excelencia en la administración pública”*²⁰. Igualmente, el mismo precepto establece que el mecanismo idóneo para hacer efectivo el mérito es el concurso público. En los términos de este artículo: *“Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.”*²¹
- 3.2.** La importancia de la carrera administrativa como pilar del Estado Social de Derecho, se puso de relieve por esta Corporación en la sentencia C-588 de 2009, al declarar la inexecutable del Acto Legislativo No 01 de 2008, que suspendía por el término de tres años la vigencia del artículo 125 constitucional. En el mencionado pronunciamiento se indicó que el sistema de carrera administrativa tiene como soporte principios y fundamentos propios de la definición de Estado que se consagra en el artículo 1 constitucional, cuyo incumplimiento o inobservancia implica el desconocimiento de los fines estatales; del derecho a la igualdad y la prevalencia de derechos fundamentales de los ciudadanos, tales como el acceso a cargos públicos y el debido proceso.

Como consecuencia de lo anterior, en dicho pronunciamiento se concluyó que *“la carrera administrativa es, entonces, un principio*

²⁰ Cfr. Corte Constitucional sentencia SU-086 de 1999. M.P. José Gregorio Hernández Martínez.

²¹ Son innumerables las decisiones de la Corte Constitucional, desde sus inicios, que han defendido el sistema de concurso público como el que debe imperar para la provisión de cargos de carrera en la administración. Entre otras, en las sentencias T-410 del 8 de junio de 1992.M.P. Alejandro Martínez Caballero y Fabio Morón Díaz; C-479 del 13 de agosto de 1992.M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-515 de 9 de noviembre de 1993; T-181 del C-126 de marzo 27 de 1996.M.P. Fabio Morón Díaz; C-063 del 11 de febrero de 1997. M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-522 de noviembre 16 de 1995. M.P. Hernando Herrera Vergara; C-753 de 30 junio de 2008.M.P. Jaime Araujo Rentarías, entre otras.

constitucional y, por lo mismo, una de las garantías cuyo desconocimiento podría acarrear la sustitución de la Constitución”²², en donde la inscripción automática, sin el agotamiento de las etapas del proceso de selección, resultaba abiertamente contraria a los principios y derechos en los que se erige la Constitución de 1991.

- 3.3.** Por tanto, si lo que inspira el sistema de carrera son el mérito y la calidad, son de suma importancia las diversas etapas que debe agotar el concurso público. En las diversas fases de éste, se busca observar y garantizar los derechos y los principios fundamentales que lo inspiran, entre otros, los generales del artículo 209 de la Constitución Política y los específicos del artículo 2 de la Ley 909 de 2004²³. La sentencia C-040 de 1995²⁴ reiterada en la SU-913 de 2009²⁵, explicó cada una de esas fases, las que por demás fueron recogidas por el legislador en el artículo 31 de la Ley 909 de 2004. Así:

*“1. **Convocatoria.** ... es la norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a la administración, como a las entidades contratadas para la realización del concurso y a los participantes. (subrayas fuera de texto).*

*2. **Reclutamiento.** Esta etapa tiene como objetivo atraer e inscribir el mayor número de aspirantes que reúnan los requisitos para el desempeño de los empleos objeto del concurso.*

*3. **Pruebas.** Las pruebas o instrumentos de selección tienen como finalidad apreciar la capacidad, idoneidad y adecuación de los aspirantes a los diferentes empleos que se convoquen, así como establecer una clasificación de los candidatos respecto a las calidades requeridas para desempeñar con efectividad las funciones de un empleo o cuadro funcional de empleos.*

La valoración de estos factores se efectuará a través de medios técnicos, los cuales deben responder a criterios de objetividad e imparcialidad.

²² Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-588 de 2009. M.P. Eduardo Mendoza Martelo, considerando 6.1.1.3, página 73.

²³ 1. La función pública se desarrolla teniendo en cuenta los principios constitucionales de igualdad, mérito, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad, transparencia, celeridad y publicidad. 2. El criterio de mérito, de las calidades personales y de la capacidad profesional, son los elementos sustantivos de los procesos de selección del personal que integra la función pública. Tales criterios se podrán ajustar a los empleos públicos de libre nombramiento y remoción, de acuerdo con lo previsto en la presente ley. 3. Esta ley se orienta al logro de la satisfacción de los intereses generales y de la efectiva prestación del servicio, de lo que derivan tres criterios básicos: a) La profesionalización de los recursos humanos al servicio de la Administración Pública que busca la consolidación del principio de mérito y la calidad en la prestación del servicio público a los ciudadanos; b) La flexibilidad en la organización y gestión de la función pública para adecuarse a las necesidades cambiantes de la sociedad, flexibilidad que ha de entenderse sin detrimento de la estabilidad de que trata el artículo 27 de la presente ley; c) La responsabilidad de los servidores públicos por el trabajo desarrollado, que se concretará a través de los instrumentos de evaluación del desempeño y de los acuerdos de gestión; d) Capacitación para aumentar los niveles de eficacia.

²⁴ M.P. Carlos Gaviria Díaz, febrero 9 de 1995.

²⁵ M.P. Juan Carlos Henao Pérez, diciembre 11 de 2009.

*4. **Listas de elegibles.** Con los resultados de las pruebas...se elaborará en estricto orden de mérito la lista de elegibles que tendrá una vigencia de dos (2) años. Con ésta y en estricto orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso.*

*5. **Período de prueba.** La persona no inscrita en carrera administrativa que haya sido seleccionada por concurso será nombrada en período de prueba, por el término de seis (6) meses, al final de los cuales le será evaluado el desempeño, de acuerdo con lo previsto en el reglamento.*

“Aprobado dicho período, al obtener evaluación satisfactoria, el empleado adquiere los derechos de la carrera, los que deberán ser declarados mediante la inscripción en el Registro Público de la Carrera Administrativa. De no obtener calificación satisfactoria del período de prueba, el nombramiento del empleado será declarado insubsistente”(subrayas fuera de texto).

- 3.4.** Dentro de este contexto, la convocatoria es, entonces, ***“la norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a la administración, como a las entidades contratadas para la realización del concurso y a los participantes”***, y como tal impone las reglas que son obligatorias para todos, entiéndase administración y administrados-concursantes. Por tanto, como en ella se delinean los parámetros que guiarán el proceso, los participantes, en ejercicio de los principios de buena fe y confianza legítima, esperan su estricto cumplimiento. La Corte Constitucional ha considerado, entonces, que el Estado debe respetar y observar todas y cada una de las reglas y condiciones que se imponen en las convocatorias, porque su desconocimiento se convertiría en una trasgresión de principios axiales de nuestro ordenamiento constitucional, entre otros, la transparencia, la publicidad, la imparcialidad, así como el respeto por las legítimas expectativas de los concursantes. En consecuencia, las normas de la convocatoria sirven de autovinculación y autocontrol porque la administración debe ***“respetarlas y que su actividad, en cuanto a la selección de los aspirantes que califiquen para acceder al empleo o empleos correspondientes, se encuentra previamente regulada”***²⁶

Es por ello que en la sentencia C-1040 de 2007²⁷, reiterada en la C-878 de 2008²⁸, se sostuvo:

²⁶ Cfr. Sentencia T-256 de 1995.

²⁷ M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, 4 de diciembre de 2007.

²⁸ M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, 10 de septiembre de 2008.

“[...] el principio de transparencia de la actividad administrativa se empaña si en contravía de las legítimas expectativas del aspirante, su posición en el concurso se modifica durante su desarrollo; el principio de publicidad (art. 209 C.P.) se afecta si las reglas y condiciones pactadas del concurso se modifican sin el consentimiento de quien desde el comienzo se sujetó a ellas; los principios de moralidad e imparcialidad (ídem) de la función administrativa se desvanecen por la inevitable sospecha de que un cambio sobreviniente en las reglas de juego no podría estar motivado más que en el interés de favorecer a uno de los concursantes; el principio de confianza legítima es violentado si el aspirante no puede descansar en la convicción de que la autoridad se acogerá a las reglas que ella misma se comprometió a respetar; se vulnera el principio de la buena fe (art. 83 C.P.) si la autoridad irrespeta el pacto que suscribió con el particular al diseñar las condiciones en que habría de calificarlo; el orden justo, fin constitutivo del Estado (art. 22 C.P.), se vulnera si la autoridad desconoce el código de comportamiento implícito en las condiciones de participación del concurso, y, en fin, distintos principios de raigambre constitucional como la igualdad, la dignidad humana, el trabajo, etc., se ven comprometidos cuando la autoridad competente transforma las condiciones y requisitos de participación y calificación de un concurso de estas características. Adicionalmente, el derecho que todo ciudadano tiene al acceso a cargos públicos, consagrado en el artículo 40 constitucional, se ve vulnerado si durante el trámite de un concurso abierto, en el que debe operar el principio de transparencia, se modifican las condiciones de acceso y evaluación...”

De la misma manera, en sentencia C-588 de 2009²⁹ se afirmó categóricamente que en el desarrollo de un concurso público de méritos *“cuando se fijan en forma precisa y concreta cuáles son las condiciones que han de concurrir en los aspirantes y se establecen las pautas o procedimientos con arreglo a los cuales se han de regir los concursos, no existe posibilidad legítima alguna para desconocerlos”*.

En ese sentido, **es claro que las reglas del concurso son invariables** tal como lo reiteró esta Corporación en la sentencia SU-913 de 2009 al señalar *“...resulta imperativo recordar la intangibilidad de las reglas que rigen las convocatorias de los concursos públicos para acceder a cargos de carrera en tanto no vulneren la ley, la Constitución y los derechos fundamentales en aras de garantizar el derecho fundamental a*

²⁹ M.P. Eduardo Mendoza Martelo.

la igualdad, así como la inmodificabilidad de las listas de elegibles una vez éstas se encuentran en firme como garantía de los principios de buena fe y confianza legítima que deben acompañar estos procesos.”³⁰

Es indiscutible, entonces, que las pautas del concurso son inmodificables y, en consecuencia, a las entidades no le es dado variarlas en ninguna fase del proceso, por cuanto se afectarían principios básicos de nuestra organización, como derechos fundamentales de los asociados en general y de los participantes en particular.

Sentadas las anteriores premisas, entra la Sala a analizar el caso concreto del concurso que convocó la Fiscalía General de la Nación en 2007. Para el efecto, **i)** se esbozarán las tesis opuestas de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado sobre la utilización del Acuerdo 007 de 2008, mediante el cual se expidió el registro definitivo de elegibles, **ii)** se analizará el concurso que efectuó la Fiscalía General de la Nación, su régimen jurídico y **iii)** se establecerá si el mencionado registro de elegibles se puede utilizar para proveer las vacantes que registra la entidad en plazas que no fueron ofertadas.

4. LA POSIBILIDAD DE UTILIZAR EL REGISTRO DE ELEGIBLES: RESPUESTAS DIVERSAS FRENTE AL MISMO INTERROGANTE Y LOS DISTINTOS INTERESES EN JUEGO EN EL CASO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION

4.1. El interrogante sobre si era posible utilizar la lista de elegibles que conformó la Fiscalía General de la Nación para proveer cargos por fuera del número de los convocados, fue resuelto en forma diversa por los máximos tribunales de la jurisdicción ordinaria y la administrativa. El primero en su calidad de juez de tutela y el segundo, a través de su Sala de Consulta y como juez de tutela. Veamos:

4.1.1. Posición de la Corte Suprema de Justicia.

La Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, en sede de tutela, profirió cuatro decisiones de importancia en el asunto objeto de discusión.

4.1.1.1. La primera de ellas, un **fallo del 4 de febrero de 2010**, en el que la Sala Penal como Sala de Decisión de Tutela³¹, al estudiar el caso de una persona que estaba en el registro de elegibles, conminó al Fiscal General de la Nación para que, en un término de *“quince (15) días hábiles siguientes a la notificación de la providencia, procediera a culminar la aplicación del sistema de carrera en la Fiscalía General de la Nación proveyendo los cargos a que se refieren las convocatorias 001-2007,*

³⁰ Ibidem, pág 129.

³¹ M.P. Alfredo Gómez Quintero. Expediente de tutela No. 45366 Actor. Fernando Fernández Celedón.

002-2007, 003-2007, 004-2007, 005-2007 y 006-2007 con el registro de elegibles publicado mediante acuerdo 007 del 24 de noviembre de 2008”

Esa decisión fue objeto de una solicitud de aclaración que presentó el señor Fiscal General de la Nación en la que pidió determinar “*el alcance del referido fallo, en cuanto a los cargos que debían ser provistos con el registro definitivo de elegibles, porque con fundamento en la jurisprudencia constitucional vigente, sólo es posible llenar los cargos convocados al concurso*”.

4.1.1.2. Mediante auto del 17 de febrero de 2010, en respuesta a la solicitud de aclaración señaló “*..., en relación con el alcance de las reseñadas consideraciones expresadas en la tutela materia de aclaración, quiere ser categórica la Sala para informarle al señor Fiscal que la Corte **no emitió en ese sentido orden alguna**, como perfectamente puede comprobarse con la lectura de la parte resolutive del fallo. Lo allí escrito no tiene -hasta este momento- más que el carácter de obiter dicta, dado que ni la petición de amparo comportaba un alcance de tal naturaleza (porque -por ejemplo- el accionante formara parte de la lista de elegibles pero ubicado por fuera del rango de los convocados) ni la Corte podía impartir órdenes oficiosamente con esa dimensión.*” (negrilla fuera de texto)

Se entendió que la orden de la Corte Suprema de Justicia hacía referencia a que la Fiscalía General de la Nación debía proveer en su totalidad los cargos ofertados en las seis convocatorias que hizo el ente fiscal, porque después de un año y tres meses de la expedición del registro de elegibles no se habían provisto todas las plazas que salieron a concurso. Esta misma orden la había emitido la Sala Séptima de esta Corporación en la sentencia T-843 de 2009³².

4.1.1.3. En sentencia del 11 de febrero de 2010³³, se hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que en la provisión de cargos con el registro de elegibles, se proveyeran **todos los cargos** que estaban siendo ocupados por provisionales. En esa oportunidad, pese a que se negó el amparo, se dijo:

“...se considera oportuno hacer un llamado a la Fiscalía General de la Nación -aprovechando un punto tangencialmente tocado por la accionante- en el sentido de reiterar el pronunciamiento³⁴ de esta misma Sala referido a que si bien en las convocatorias efectuadas en su momento no se cobijó el número de cargos totales a proveer en el país,

³² M.P. Jorge Ignacio Pretlt Chaljud, noviembre 24 de 2009.

³³ M.P. Alfredo Gómez Quintero. Expediente de tutela No.46338.

³⁴ Radicados 45237 del 16 de diciembre de 2009 y 46131 del 4 de febrero de 2010.

desde luego atendiendo las diversas jerarquías (fiscales locales, seccionales, especializados, etc.), ello no impide que existiendo en cambio muchos aspirantes que –por aprobar el concurso- forman parte del registro de elegibles y sin que por ahora tengan cabida en las designaciones que en carrera se están ejecutando sean una vez culminadas las primeras llamados a ocupar la totalidad de las plazas.

“Piensa esta Célula que el concurso convocado jamás podrá concebirse como limitado o restringido al número de cargos consignados en las convocatorias, que –como todo parece indicar- no alcanza siquiera al 50% de la totalidad de los actualmente existentes, de tal modo que agotada prioritariamente la provisión de los convocados, los restantes integrantes del registro de elegibles adquirirán el derecho a que en orden de posicionamiento sean designados en carrera en el cargo para el que concursaron y aprobaron.

“La razón del anterior planteamiento es muy clara: una convocatoria para proveer plazas en carrera, como fruto de un concurso, ha de efectuarse y/o entenderse (como en el actual que se surte en la Fiscalía) para la totalidad de cargos correspondiente a cada categoría. De valorarse este concurso en forma distinta, esto es, la restringida que se aludió antes, ello equivaldría a realizar una nueva convocatoria y un nuevo concurso para cubrir en su totalidad la planta de fiscales, lo cual –además de absurdo- comportaría un derroche de recursos, rayando en una conducta reprochable y eventualmente sancionable.

“Un ingrediente adicional: si conforme al artículo 66 de la Ley 938 de 2004, Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación, el registro de elegibles tiene una vigencia de dos años, contabilizados desde luego a partir de noviembre 24 de 2008, fecha en que por el resultado del concurso fue conformado el señalado registro de elegibles, no hay duda que ese período de vigencia –al día de hoy- ya cuenta con menos de un año para tornarse ineficaz, evento que podría abortar las aspiraciones de quienes oportunamente participaron en el concurso, se sometieron a sus reglas y superaron las pruebas, adquiriendo el derecho a su designación dentro del número de vacantes nacionales a proveer.” (Subrayado fuera del texto)

Pese a estas puntuales consideraciones no se impartió una orden en concreto, sólo se dejó sentado el criterio sobre la forma como debería procederse una vez los cargos convocados fueran provistos con el registro de elegibles, **para señalar que éste debía ser utilizado para**

proveer las plazas en provisionalidad o vacantes de la misma naturaleza de los cargos para los cuales se abrió el concurso.

4.1.1.4. Finalmente, en sentencia del 27 de mayo de 2010³⁵, se señaló que era obligación de la Fiscalía General de la Nación **agotar** el registro de elegibles para proveer los cargos de la misma naturaleza de los que fueron objeto de las seis convocatorias de 2007 y que estaban ocupados en provisionalidad. Sobre el particular se dijo:

“..., en el caso de la Fiscalía, no puede perderse el esfuerzo que la administración ha empleado para sacar adelante el concurso de méritos, los recursos económicos empleados así como el talento humano que se ha desplegado, para ahora sencillamente considerar que el proceso finiquita con la provisión de los 4697 cargos convocados, pues ello igualmente desconocería los principios de la función pública contenidos en el artículo 209 de la Carta.

“Ahora, no resulta válido afirmar que con la tesis de esta Corte (vale decir la obligación de proveer con el residual registro de elegibles las vacantes existentes que superen el número de las convocadas) se quebranta el debido proceso – como se anunciaba folios atrás- pues se irrespetarían así las reglas del concurso. NO! Al contrario, fue justamente esta Sala de Tutelas la que –de alguna manera- obligó a la Fiscalía a que cumpliera su deber de proveer la totalidad de cargos convocados (4.697), cumpliéndose tal orden a 19 de abril de 2010, con lo cual, NINGUNO de los aspirantes que clasificaron en el concurso dentro de aquel rango puede decir hoy que se violó derecho alguno, así como puede también hoy en día la Fiscalía pregonar que a cabalidad cumplió (aún en la forma conocida) con la convocatoria y el concurso.

“El problema ahora planteado es otro, y casi podría limitarse al cumplimiento del artículo 66 del Estatuto que rige el concurso, ya transcrito antes, de tal modo que con el residual registro de elegibles, mientras perdure su vida jurídica –que es de dos años- deben proveerse las vacantes que se presenten durante su vigencia, como paladinamente lo precisa el reseñado dispositivo legal, vale decir para cargos de fiscal local los 1530, seccional 1607, especializados 399, delegado ante Tribunal 144 que queden vacantes, esto es, aún en provisionalidad, hasta proveer todas estas plazas o hasta el agotamiento del registro, según lo que se cumpla primero. En ello –sustancialmente- radica la discrepancia

³⁵ M.P. Alfredo Gómez Quintero. Expediente de tutela 48023. Actora Luz Alieth Molina Raigosa.

de esta Sala con el concepto (además no vinculante) del Consejo de Estado, al que también ya se hizo referencia.
(subrayas y negrilla fuera de texto).³⁶

4.1.2. Posición del Consejo de Estado.

El Consejo de Estado, en relación con el punto en controversia, emitió dos pronunciamientos, el primero, con ocasión de una consulta que le fue elevada por el Gobierno Nacional y, el segundo, como juez de tutela. Veamos:

4.1.1.1. La Sala de Consulta y Servicio Civil³⁷, con fundamento en una solicitud que elevó el Ministro del Interior y de Justicia por petición expresa del Fiscal General de la Nación (e), contestó el siguiente interrogante: ¿entraña la convocatoria una regla del concurso de carácter vinculante para la entidad convocante y los aspirantes, de manera que la Fiscalía General de la Nación sólo puede proveer los 4697 cargos ofertados?

Después de un análisis de la jurisprudencia de la Corte Constitucional relativa a la carrera administrativa y al concurso público, la Sala de Consulta señaló que la convocatoria es la **regla del concurso** que es **inmodificable**. En consecuencia, señaló que:

“No cabe duda entonces que las convocatorias realizadas por la Fiscalía General de la Nación en el año 2007, tienen un marco constitucional y legal que las regula, de cuya aplicación puede deducirse que tales convocatorias: i) son las reglas del concurso, ii) vinculan a la entidad y a los participantes y, por tanto, son inmodificables, so pena de transgredir derechos fundamentales de éstos, y iii) durante el termino de 2 años o hasta que se agote el registro de elegibles de la convocatoria realizada, no se podrán realizar procesos de selección para proveer los cargos para los cuales se conformó la lista”.

Para concluir lo siguiente:

“...si como lo señala en la consulta, en la Fiscalía General de la Nación existen cargos de la planta de personal que pertenecen al sistema de carrera de esa entidad, los cuales están vacantes o no han sido provistos por ese sistema, lo

³⁶ Estas decisiones fueron reiteradas en las decisiones del 17 de junio de 2010 y del 8 de Julio de 2010, en los que se especificó que era necesario agotar el registro de elegibles para ocupar los cargos vacantes y ocupados en provisionalidad, excepción hecha de las Unidades de Justicia y Paz e Infancia y adolescencia.

³⁷ Cfr. Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Consejero Ponente, Luis Fernando Álvarez Jaramillo. Radicación 1976 de febrero 4 de 2010.

pertinente sería realizar las convocatorias correspondientes con el lleno de los requisitos constitucionales señalados en este concepto, así como las reglas aplicables de la Ley 938 de 2004.

“...

“Sí, la convocatoria es la regla del concurso y, por lo mismo, vinculante para la entidad convocante y los aspirantes. Con el registro definitivo de elegibles correspondiente a las convocatorias 001,002, 003, 004,005 y 006, todas del año 2007, sólo podrán proveerse los 4697 cargos convocados”³⁸(negrilla fuera de texto).

4.1.1.2. Con fundamento en la anterior tesis, la Sección Segunda, Sub sección A del Consejo de Estado, como juez de tutela, protegió los derechos de algunos funcionarios y empleados en provisionalidad que sostenían que no podían ser retirados de sus cargos hasta tanto no se convocara a un nuevo concurso para proveer el número de plazas que no hizo parte de las seis convocatorias de 2007. En criterio de dicha Sala, los cargos que no salieron a concurso no podían ser provistos con el registro de elegibles vigente. Al respecto se dijo:

“En el asunto objeto de estudio, los cargos que se tenían que proveer mediante concurso eran 52 Delegados ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial y ante la existencia de otras vacantes en dichos cargos, la entidad no podía extender los alcances de la Convocatoria 004-2007”

“Con el registro de elegibles se termina el concurso de méritos el cual estaba restringido a la normas reguladoras y obligatorias que contienen las convocatorias 01 a 06 de 2007, las cuales limitan el número y los cargos en ella determinados, pues es a partir del registro que se procede a efectuar la provisión de las vacantes para las que se realizó el concurso, es decir, si de esos 52 cargos provistos mediante concurso se originan vacantes, se debe recurrir al registro de elegibles constituido para proveer las mismas.

“Al haberse efectuado por parte de la entidad demandada los 52 nombramientos de Fiscales Delegados ante el Tribunal Superior que fueron objeto de la convocatoria No.004-2007, se agotó el concurso y por esa razón no podía la entidad designar otras personas incluidas en el registro de elegibles para proveer los cargos que se encontraban vacantes en la

³⁸ Cfr. Ibidem,pág 11.

entidad, pues el concurso se había agotado y el registro sólo podía suplir las vacantes de los 52 cargos que fueron materia de convocatoria.

“Lo anterior significa que respecto de los demás cargos no existe concurso y por esa razón es que la entidad debía designar sólo a los registrados que se encontraban en los primeros lugares hasta completar las 52 vacantes materia de la convocatoria.

“...

“En consecuencia, se confirmará la decisión del Tribunal que amparó el derecho al trabajo del actor, ordenó al Fiscal General de la Nación abstenerse de proveer el cargo de Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior del Florencia con personas que ingresaron al registro de elegibles conformado en virtud de la Convocatoria No. 004-2007, hasta tanto se surta un nuevo concurso o se presenten circunstancias que ameriten su remoción por cualquier otra causa y levantó la medida provisional decretada en auto de 11 de junio de 2010, consistente en prorrogar el término con el que contaba el actor para aceptar la designación como Fiscal Seccional hasta que se profiriera pronunciamiento.”³⁹

4.2. LOS DISTINTOS INTERESES EN JUEGO

La forma disímil como se resolvió el problema planteado por los jueces de tutela, generó una enorme incertidumbre en la Fiscalía General de la Nación, en relación con la forma como debía entenderse agotado el registro de elegibles contenido en el Acuerdo 007 de 2008. Cada uno de los interesados en este conflicto sustentó una tesis diversa sobre su solución.

4.2.1. La Fiscalía General de la Nación consideró que el registro de elegibles que se conformó para las seis convocatorias del 2007, sólo podía ser utilizado para proveer el número de cargos ofertados en cada una de ella y para dar respuesta a las posibles eventualidades que, en vigencia de la lista y en relación con dichos cargos, se pudieran presentar, v.gr. una vacancia⁴⁰. En ese orden, las plazas ocupadas por provisionales debían salir a concurso y por ende, el registro de elegibles que se conformó

³⁹ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Ref: Expediente 1800123310002010-00239-01. Actor: Mario Enrique Armenta. Consejero Ponente: Alfonso Vargas Rincón, fallo del 5 de agosto de 2010.

⁴⁰ Así se desprende de la respuesta que dio la apoderada especial de la Fiscalía General de la Nación en todos los procesos de tutela que ha conocido esta Corporación, doctora CLAUDIA MILENA CASTELLANOS AVENDAÑO.

mediante el Acuerdo 07 de 2008 no era utilizable. Esta postura encontró sustento en la tesis del Consejo de Estado ya esbozada.

4.2.2. El grupo de personas que conformaron el registro de elegibles, sostuvieron que tenían el derecho a ocupar uno de los cargos de carrera existentes en la entidad porque concursaron y pasaron las diversas pruebas, lo que los facultaba a ser nombrados en las plazas vacantes y las ocupadas por personas en provisionalidad, pues ese derecho se derivada de la lista de elegibles. Así lo evidencian las múltiples intervenciones que se presentaron en el transcurso de los cinco días dispuestos para que cualquier persona participara en el proceso de la referencia⁴¹. Los derechos e intereses de este grupo de personas resultaba protegido por el planteamiento de la Sala de Decisión de Tutelas de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

4.2.3. El grupo de funcionarios y empleados en provisionalidad señalaron que tenían el derecho a permanecer en los cargos de carrera que ocupaban, hasta tanto la entidad no convocara a un nuevo concurso. En el transcurso del término que se dio para presentar intervenciones se presentaron múltiples solicitudes en este sentido⁴². Los intereses de este conjunto de funcionarios y empleados, resultaba favorecido con la tesis del Consejo de Estado.

Por tanto, es preciso analizar cada una de las convocatorias que efectuó la Fiscalía General de la Nación en el año 2007, para determinar si se i) imponía la utilización del registro de elegibles que se conformó mediante el Acuerdo 007 de 2008, como lo señaló la Corte Suprema de Justicia o ii) requería convocar a nuevo concurso como lo sostuvo el Consejo de Estado. La respuesta positiva o negativa a estos cuestionamientos dependerá sin lugar a dudas de las reglas específicas de cada una de las seis convocatorias que efectuó el ente fiscal

5. EL CONCURSO PÚBLICO EN LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN: TRÁNSITOS NORMATIVOS. EL CONCURSO DEL 2007.

5.1. La Fiscalía General de la Nación en el año 2007 efectuó seis (6) convocatorias⁴³ para ocupar diferentes cargos de carrera en la entidad, así:

⁴¹ Fueron cientos las intervenciones que se presentaron y que resultaría interminable y dispendioso reseñarlas individualmente en esta providencia.

⁴² Al igual que las anteriores intervenciones, fueron centenares los escritos que se recibieron en la entidad defendiendo esta posición y que no resultaría útil reseñar individualmente.

⁴³ <http://fgn.fiscalia.gov.co:8080/Fiscalia/contenido/html/carrera2007.jsp#>. Consulta efectuada el 15 de septiembre de 2010.

- 5.1.1.** Convocatoria 001-2007 para proveer los cargos de **Fiscal delegado ante Jueces Municipales y Promiscuos. Número: 744. Ubicación: Nivel nacional.**
- 5.1.2.** Convocatoria 002-2007 para proveer los cargos de **Fiscal delegado ante Jueces del Circuito. Número: 732. Ubicación: Nivel nacional.**
- 5.1.3.** Convocatoria 003-2007 para proveer los cargos de **Fiscal delegado ante Jueces Penales del Circuito Especializado. Número: 298. Ubicación: Nivel nacional.**
- 5.1.4.** Convocatoria 004-2007 para proveer los cargos de **Fiscal Delegado ante Tribunal de Distrito. Número: 52. Ubicación: Nivel nacional.**
- 5.1.5.** Convocatoria 005-2007 para proveer los cargos de **Asistente de Fiscal I; II; III; IV. Número: Asistente de Fiscal I - 610 cargos. Asistente de Fiscal II - 819 cargos. Asistente de Fiscal III - 530 cargos. Asistente de Fiscal IV - 288 cargos. Ubicación: Nivel nacional.**
- 5.1.6.** Convocatoria 006-2007 para proveer los cargos de **Asistente judicial IV. Número de cargos: 684. Ubicación: Nivel nacional.**

En total fueron **4697** las plazas que salieron a concurso. Sin embargo, para esa fecha, el número total de cargos de carrera de la misma naturaleza y perfil de los convocados ascendían a **9498**, número en el que un grupo de los accionantes fundan su solicitud de ser nombrados, dado que existe la disponibilidad para tal objetivo.

¿Cuáles fueron las razones que tuvo el ente fiscal para no convocar a concurso todos los cargos de carrera de la misma naturaleza que había en la entidad? La respuesta a este interrogante se encuentra en el tránsito normativo al que estuvo sujeta la entidad entre los años 2004 y 2008.

5.2. El tránsito normativo

Entre los años 2004 y 2008, la Fiscalía General de la Nación sufrió una serie de modificaciones normativas que, entre otras, afectó la planta global de personal de la entidad. Esos cambios se pueden resumir de la siguiente manera:

- 5.2.1. La Ley 938 de 2004.** El artículo 1 transitorio de la Ley 938 de 2004, estableció que *con el objeto de dar cumplimiento a la implementación gradual del sistema penal acusatorio, previsto en el Acto Legislativo 03 de 2002 y en el Código de Procedimiento Penal, la planta de cargos para la Fiscalía General de la Nación debía ir transformándose gradualmente en la forma que lo estableció el legislador. En términos generales, se consideró que la entrada en vigencia del sistema penal*

acusatorio imponía una disminución de la estructura orgánica de la entidad.

Para los cargos objeto de las convocatorias, el mencionado artículo señaló el siguiente número por año.

	200	2006	2007	2008	200
Fiscal Delegado ante Tribunal Superior	144	144	144	144	83
Fiscal Delegado ante Jueces Especializados	322	322	322	322	302
Fiscal Delegado ante Jueces municipales y promiscuos	156	1427	1257	990	880
Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito	160	1464	1318	1151	104
Asistente de Fiscal I	125	1137	977	754	663
Asistente de Fiscal II	198	1812	1665	1511	130
Asistente de Fiscal III	766	766	766	754	754
Asistente de Fiscal IV	396	396	396	372	372
Asistente Judicial IV	148	1488	1488	1488	138

(Cuadro 1)

5.2.2. La ley 975 de 2005. El 25 de julio de 2005, se expide esta ley con el objeto de “*facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación*”. Para el logro de ese objetivo, el legislador ve la necesidad de ampliar la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación, razón por la que en el artículo 33 señaló lo siguiente:

“Adicionar a la planta de cargos de la Fiscalía General de la Nación, para el año 2005 establecida en el artículo transitorio 1 de la Ley 938 de 2004, los siguientes cargos:

- 150 Investigador Criminalístico VII*
- 15 Secretario IV*
- 15 Asistente Judicial IV*
- 20 Conductor III*
- 40 Escolta III*
- 15 Asistente de Investigación Criminalística IV*
- 20 Asistente de Fiscal II.*

“Parágrafo: La Fiscalía General de la Nación destacará de su planta de personal, para conformar la Unidad Nacional de

*Fiscalía para la Justicia y la Paz, los siguientes cargos: **20 Fiscal Delegado ante Tribunal**” (negrilla fuera de texto) (Los cargos en negrilla son los que fueron objeto de las convocatorias objeto de este pronunciamiento).*

5.2.3. Ley 1024 de 2006. El 20 de mayo de 2006, se expidió la Ley 1024 que en su artículo 7 señaló que a partir de la fecha de su promulgación, la Fiscalía General de la Nación **tendría la misma planta de personal vigente para el año 2005**, adicionada con los cargos creados por la Ley 975 de 2005. En consecuencia, se ordenó la suspensión por el término de cinco años del artículo 78 y los transitorios 1º. y 2º. de la Ley 938 de 2004.

Este mismo artículo contempló que vencido el término de suspensión, la adecuación de la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación se haría en forma gradual, de conformidad con las plantas previstas en el artículo transitorio 1º de la Ley 938 de 2004, hasta llegar a la planta contemplada en el artículo 78 de la misma ley. En otras palabras, la reducción de la planta de personal del ente fiscal empezaría a operar desde el año 2011 hasta concluir en el 2016.

5.2.4. Decreto 122 de 2008. El Presidente de la República dictó el Decreto 122 del 18 de enero de 2008⁴⁴, mediante el cual modificó la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación y **creó nuevos cargos**, unos de carácter permanente y otros de carácter transitorio. En relación con los cargos que salieron a concurso en el año 2007, este decreto creó nuevas plazas, así:

5.2.4.1. Cargos de carácter permanente.

Fiscal Delegado ante Tribunal Superior	5
Fiscal Delegado ante Jueces Especializados	77
Fiscal Delegado ante Jueces Municipales y Promiscuos	33
Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito	55
Asistente de Fiscal I	100
Asistente de Fiscal II	55

⁴⁴ En las motivaciones de este decreto se lee “Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 147 de la Ley 1151 del 24 de julio de 2007, se efectuó el estudio técnico respectivo, en el cual se establecieron nuevas necesidades que en materia de personal requiere la Fiscalía General de la Nación para atender sus funciones, especialmente las relacionadas con las Investigaciones sobre Violación de Derechos Humanos e Infracciones al Derecho Internacional Humanitario, homicidios presuntamente cometidos por agentes institucionales, extinción de dominio, el fortalecimiento para la aplicación de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), la ejecución del Plan Nacional para Búsqueda, Hallazgo e Identificación de Desaparecidos, el fortalecimiento del Programa de Protección a Víctimas y Testigos, y la implementación del Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006 y las normas que lo reglamenten); Que el Gobierno Nacional, previa disponibilidad presupuestal, considera procedente modificar la actual planta de personal de la Fiscalía General de la Nación contemplada en el artículo transitorio 1º de la Ley 938 del 2004 y la Ley 975 del 2005”

Asistente de Fiscal III	3
Asistente de Fiscal IV	0
Asistente Judicial IV	2

(Cuadro 2)

Igualmente, señaló que a partir de la vigencia fiscal 2009 deberían crearse más cargos, razón por la que en el artículo 2 se señalaron dos plazos de implementación: el primero, el 1º de abril de 2009, fecha en la que se crearían, en relación con las convocatorias, las siguientes plazas.

Fiscal Delegado ante Jueces Municipales y Promiscuos	23
Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito	31

(Cuadro 3)

El segundo, para el 1º de octubre de 2009, fecha en la que se crearían, en relación con las convocatorias, los siguientes cargos.

Fiscal Delegado ante Jueces Municipales y Promiscuos	13
Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito	17
Asistente de Fiscal I	30

(Cuadro 4)

5.2.4.2. Cargos de carácter transitorio.

Para atender las necesidades de la Ley de Justicia y Paz, en el artículo 3 del decreto en mención se crearon 753 plazas. En relación con los empleos convocados en el año 2007, se crearon los siguientes:

Fiscal Delegado ante Tribunal Superior	39
Fiscal Delegado ante Jueces Especializados	32
Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito	93
Asistente de Fiscal II	82

(Cuadro 5)

Así mismo, en el artículo 5 se **derogó expresamente** el artículo 78 de la Ley 938 de 2004 y parcialmente el artículo transitorio en cuanto a la disminución gradual de la planta para los años 2006, 2007 y 2008, y el artículo 7 de la Ley 1024 de 2006. Como consecuencia de estas derogatorias, la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación quedó como estaba en 2005 y aumentada con los nuevos cargos que creó tanto la Ley 975 de 2005 como el Decreto 122 de 2008.

Las distintas normas expuestas dieron lugar a que la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación pasará de 18.200 funcionarios y empleados para el año 2005 a una de 20.822 para el año 2009.

El anterior recuento normativo explica porqué en el año 2007 cuando la Fiscalía General de la Nación abrió las **6 convocatorias** que dieron origen a la discusión que ahora ocupa la atención de la Sala, no sacó a concurso todas las plazas que tenía disponibles, pues tenía como referente la planta de personal que el legislador tenía prevista para el año 2009⁴⁵ que era **menor** a la que presentaba la entidad para el momento de las convocatorias de 2007.

Por tanto, para la Corte es claro que hubo una razón objetiva y razonable para que el número de cargos convocados en 2007 fuera inferior al que para la fecha de las convocatorias tenía la Fiscalía, toda vez que no resultaba lógico convocar a concurso un número de cargos mayor, cuando al término de éste muchas de esas plazas iban a estar suprimidas por una decisión legítima del legislador. Lo contrario hubiera implicado una vulneración, entre otros, de los principios de la buena fe y la confianza legítima de los concursantes y posibles nombrados, que una vez nombrados se verían avocados a la supresión de la plaza correspondiente.

Entendido el porqué el número de cargos ofertados en el año 2007 fue menor a la planta que actualmente posee la Fiscalía General de la Nación, le corresponde a la Sala determinar si ¿era posible utilizar el registro de elegibles que se conformó en el 2008 para proveer aquellos empleos que, por decisión del legislador, no fueron eliminados o suprimidos y, por tanto, ocupados por servidores en provisionalidad?

6. LA LISTA DE ELEGIBLES SU NATURALEZA Y RAZÓN DE SER

- 6.1. La lista o registro de elegibles es un acto administrativo de carácter particular que tiene por finalidad establecer la forma de provisión de los cargos objeto de concurso, con un carácter obligatorio para la administración. Junto con la etapa de la convocatoria, es una fase hito y concluyente del sistema de nombramiento por vía del concurso público, dado que a través de su conformación, la entidad pública con fundamento en los resultados de las distintas fases de selección, organiza en estricto orden de mérito el nombre de las personas que **deben** ser designadas en las plazas ofertadas en la convocatoria, observando para ello, las precisas reglas fijadas en ésta.
- 6.2. Este acto tiene una vocación transitoria toda vez que tiene una vigencia específica en el tiempo. Esta vocación temporal tiene dos objetivos fundamentales. El primero, hace referencia a la obligatoriedad del registro de elegibles, porque durante su vigencia la administración **debe** hacer uso de él para llenar las vacantes que originaron el llamamiento a

⁴⁵ Según la planta que se fijó en el artículo 78 de la Ley 938 de 2004, posteriormente modificada por la Ley 1024 de 2006, que suspendió por cinco años la reducción de la planta de la Fiscalía General de la Nación.

concurso. El segundo, que mientras esté vigente ese acto, la entidad correspondiente no podrá realizar concurso para proveer las plazas a las que él se refiere, hasta tanto no se agoten las vacantes que fueron ofertadas, de forma que se satisfagan no solo los derechos subjetivos de quienes hacen parte de este acto administrativo sino principios esenciales de la organización estatal como el mérito para ocupar cargos públicos y los específicos del artículo 209 constitucional.

- 6.3. Con la conformación de la lista o registro de elegibles se materializa el principio del mérito del artículo 125 de la Constitución, en la medida en que con él, la administración debe proveer los cargos de carrera que se encuentren vacantes o los que están ocupados en provisionalidad debidamente ofertados. En términos generales, debemos decirlo, el Estado convoca a un concurso público porque tiene plazas vacantes u ocupadas en provisionalidad que deben ser provistas mediante el sistema de concurso público, pues, tal como lo señaló esta Corporación en la sentencia T-455 de 2000 *“Se entiende que cuando una entidad pública efectúa una convocatoria para proveer un empleo de carrera administrativa, es porque indudablemente existe el cargo (pues) carece de toda razonabilidad someter a un particular interesado en el mismo a las pruebas, exámenes y entrevistas que pueden resultar tensionantes para la mayoría de las personas, sin que el proceso adelantado y sus resultados se traduzcan en el efectivo nombramiento. En consecuencia, una vez que se han publicado los resultados, es perentorio que la entidad que ha convocado al concurso entre a proveer el cargo respectivo”*.

Así, cuando hay un registro de elegibles vigente y se presenta una vacante en el cargo objeto del concurso, la administración debe nombrar para ocuparla a quien se encuentre en el primer lugar de ese acto y a los que se encuentren en estricto orden descendente, si se ofertó más de una plaza y se presenta la necesidad de su provisión, pues ello garantiza no solo la continuidad en la función y su prestación efectiva, sino el respeto por los derechos fundamentales de quienes participaron en el respectivo concurso y superaron sus exigencias.

- 6.4. En consecuencia, la obligación del Estado en cumplimiento del artículo 125 constitucional es convocar a concurso público cuando se presenten vacantes en los cargos de carrera, con el objeto de cumplir la regla de la provisión por la vía del mérito y los principios que rigen la función pública, artículo 209 de la Constitución, específicamente los de igualdad, eficacia, economía, celeridad e imparcialidad, en donde la lista de elegibles producto de ese concurso tiene una vigencia en el tiempo que, por regla general, es de dos años, para que en el evento de vacantes en la entidad y en relación con los cargos **específicamente convocados y no otros**, se puedan proveer de forma inmediata sin necesidad de

recurrir a nombramientos excepcionales como lo son el encargo o la provisionalidad.

La conformación de la lista de elegibles, así entendida, genera para quienes hacen parte de ella, un derecho de carácter subjetivo, que consiste en ser nombradas en el cargo para el que concursó, cuando el mismo quede vacante o esté desempeñando por un funcionario o empleado en encargo o provisionalidad. En ese sentido, la consolidación de este derecho *“se encuentra indisolublemente determinado por el lugar que se ocupó dentro de la lista y el número de plazas o vacantes a proveer”*⁴⁶.

Es importante señalar, entonces, que la lista o registro de elegibles tiene dos cometidos, el primero, que se provean las vacantes, los encargos o las provisionalidades para las cuales se convocó el respectivo concurso **y no para otros**, porque ello implicaría el desconocimiento de una de las reglas específicas de aquel: **el de las plazas a proveer**. El segundo, que durante su vigencia, la administración haga uso de ese acto administrativo para ocupar **sólo** las vacantes que se presenten en los cargos objeto de la convocatoria y no otros. Por tanto, no se puede afirmar que existe desconocimiento de derechos fundamentales ni de principios constitucionales cuando la autoridad correspondiente se abstiene de proveer con dicho acto empleos no ofertados.

¿Qué significa esta última función de la lista o registro de elegibles? Nada diverso a que las entidades públicas en cumplimiento del artículo 125 de la Constitución Política están obligadas a proveer **únicamente** las vacantes que se presenten en la respectiva entidad y que correspondan **estrictamente** a los cargos ofertados, respetando siempre el orden de su conformación.

Cuando esta Corporación afirma que la lista o registro de elegibles tiene por vocación servir para que se provean las vacantes que se presenten durante su vigencia, se está refiriendo a los cargos objeto de la convocatoria y no a otros, pese a que estos últimos puedan tener la misma naturaleza e identidad de los ofrecidos. En otros términos, el acto administrativo en análisis tiene la finalidad de servir de soporte para la provisión de los empleos que fueron objeto de concurso y no de otros. En consecuencia, si en vigencia de la lista se presenta una vacante, ésta se podrá proveer con ella si la plaza vacante fue expresamente objeto de la convocatoria que le dio origen. Los cargos que se encuentren por fuera de ésta, requerirán de un concurso nuevo para su provisión.

Fuerza concluir, entonces, que el uso del registro o lista de elegibles se impone sólo para proveer las vacantes y los cargos en provisionalidad

⁴⁶ Cfr. Corte Constitucional. Sentencia SU-913 del 11 de diciembre de 2009. M.P. Juan Carlos Henao Pérez., pág 134.

que registre la entidad durante su vigencia, siempre y cuando se trate de las plazas ofertadas en el respectivo concurso.

- 6.5. Es importante señalar que lo expresado hasta aquí no contradice ni desconoce lo expuesto en la sentencia C-319 de 2010⁴⁷ sobre el *deber* de la administración de hacer uso del registro de elegibles cuando existan vacantes de la misma identidad de los cargos convocados, por cuanto en dicho fallo se analizó una norma especial que el legislador, en ejercicio de su libertad de configuración, creó para la Defensoría del Pueblo, entidad con un régimen especial de carrera. Es cierto que la Fiscalía General de la Nación también tiene un régimen especial de carrera, frente a la cual el legislador no consagró una norma igual o similar a la que fue analizada en esa oportunidad por esta Sala, razón por la que no se puede afirmar que nos encontremos ante supuestos de hecho iguales que exijan el mismo tratamiento jurídico.

Lo anterior significa que es potestad del legislador señalar en la ley general de carrera o en las leyes de carrera especial que con el registro de elegibles se pueden proveer cargos diversos a los que fueron ofertados cuando sean de la misma naturaleza, perfil y denominación de aquellos. Facultad que también puede ostentar la entidad convocante, quien en las reglas que regirán el concurso puede señalar expresamente que la lista que se configure servirá para proveer las vacantes que se lleguen a presentar en vigencia de la lista para empleos de la misma naturaleza y perfil. La introducción de este criterio es una pauta de obligatoria observancia para la administración, que le permitirá, en el término de vigencia del registro de elegibles que se llegue a conformar, proveer las vacantes que se lleguen a presentar, por cuanto expresamente habilitó el uso de ese acto administrativo para tal efecto.

- 6.6. Lo expuesto en precedencia implica que la respuesta obligada de esta Corporación al interrogante planteado en el aparte final del anterior acápite sobre si era posible utilizar el registro de elegibles que se conformó en el 2008 para proveer aquellos empleos que, por decisión del legislador, no fueron eliminados o suprimidos y, por tanto, ocupados por servidores en provisionalidad en la Fiscalía General de la Nación no puede ser otra que señalar que las plazas que no fueron suprimidas por decisión del legislador extraordinario, Decreto 122 de 2008, no podían ser provistas con la lista de elegibles que se conformó mediante el Acuerdo 007 de 2008 y los actos administrativos subsiguientes, porque ello implicaría el desconocimiento de una de las reglas que gobernaban las convocatorias: **la relativa al número de cargos a proveer**, máxime cuando ni el legislador al regular el régimen de carrera de la Fiscalía ni la entidad, al momento de establecer las pautas del concurso, previó que el registro de elegibles que se llegaré a conformar debería utilizarse para

⁴⁷ M.P. Humberto Sierra Porto

proveer las vacantes que se presentaren en su vigencia en empleos de la misma naturaleza y perfil de los ofertados.

Por tanto, la Sala no duda en afirmar que la Fiscalía General de la Nación estaba obligada a proveer única y exclusivamente el número de cargos ofertados en cada una de las seis convocatorias que efectuó en 2007, porque: **i)** la decisión inicial del legislador de eliminar plazas **determinó** el número de las que se podían ofertar; **ii)** la cantidad de empleos a proveer con el concurso era una regla específica que no se podía inobservar **iii)** ni el legislador ni la entidad previeron expresamente que el registro de elegibles debería ser utilizado para ocupar empleos por fuera del número de los convocados.

Sobre este particular, vale la pena señalar que el artículo 66 de la Ley 938 de 2004, en relación con el registro de elegibles señaló que con él se llenarían los cargos a proveer y las vacantes que se presenten durante su vigencia, pero no estipuló la posibilidad de su utilización para empleos no ofertados, como sí se previó para el caso de la Defensoría del Pueblo.

En consecuencia, se le imponía a la Fiscalía General de la Nación cumplir estrictamente con los términos de las convocatorias y, en cumplimiento de la regla constitucional del artículo 125, le correspondía llamar a un nuevo concurso para llenar todas aquellas plazas que por decisión del legislador extraordinario no fueron suprimidas como aquellas que posteriormente se crearon.

- 6.7. Esta conclusión se ajusta a los precedentes jurisprudenciales reseñados en otros apartes de esta providencia, en el sentido según el cual las reglas del concurso son obligatorias tanto para la administración como para los administrados-concursantes, en donde admitir la utilización del registro de elegibles para proveer un número mayor de empleos a los que fueron ofertados, quebrantaría una de las normas que lo regían. En ese sentido, no duda la Sala en afirmar que los concursantes tenían pleno conocimiento del número de plazas a proveer y, en consecuencia, no podían alegar derecho alguno a ser designados en las plazas no ofertadas. precisamente porque ellas no hicieron parte de la convocatoria.

En consecuencia, una vez la Fiscalía General de la Nación proveyó los cargos objeto de concurso con el registro de elegibles, Acuerdo 007 de 2008 y sus actos aclaratorios, ese acto administrativo cumplió su razón de ser y por ende se agotó. Su uso sólo era posible si se hubiese presentado una situación administrativa en relación con los empleos ofertados, que hiciera necesaria su activación, por ejemplo, la vacancia por renuncia, muerte, edad de retiro forzoso, sanción disciplinaria o

penal, así como la no aceptación del empleo ni la posesión en los términos legales.

Así las cosas, a aquellos concursantes que estaban en el registro de elegibles por fuera del rango de los cargos ofertados sólo les asistía una expectativa legítima a ser nombrados en el evento de una vacante en esas plazas, siempre y cuando la lista estuviera vigente.

- 6.8.** Por tanto, la respuesta a la pregunta de si era posible la utilización del registro de elegibles en la Fiscalía General de la Nación para un número mayor de plazas de las que fueron convocadas no puede ser sino una: **No**. Porque la lista de elegibles sólo tiene la vocación de servir para la provisión de los empleos objeto de la convocatoria, en donde el número de éstos es una regla de forzosa observancia, excepción hecha de los casos en que el legislador o la entidad convocante, expresamente incluyan una cláusula que admita su utilización para un número mayor de plazas ofertadas en el evento de vacantes en su vigencia.

La utilización de la lista o registro de elegible desconociendo esta regla, implicaría una modificación e inobservancia de las pautas de las diversas convocatorias, hecho que la Sala no puede aceptar, porque se vulnerarían, entre otros, los principios de confianza legítima, seguridad jurídica y el mandato del artículo 125 constitucional.

En ese sentido, se debe señalar que en el caso de la Fiscalía General de la Nación, las personas que ingresaron al registro de elegibles por virtud de los Acuerdos 007 de 2008, 02 de 30 de diciembre de 2009 y 01 del 19 de enero de 2010, tenían el derecho a ser nombrada en período de prueba si se encontraban en el rango de las plazas convocadas, **hasta el 24 de noviembre de 2010**, fecha en que perdió fuerza ejecutoria dicho acto administrativo.

En ese orden de ideas, la Sala concluye que los tutelantes del primer grupo no tenían el derecho a ser nombrados en propiedad en la Fiscalía General de la Nación y, por tanto, sus derechos fundamentales no fueron vulnerados cuando en el ente fiscal se negó a vincularlos en la carrera de la entidad.

7. DE LAS ÓRDENES Y SUS EFECTOS

- 7.1.** Las anteriores precisiones imponen a esta Corporación **REVOCAR** la decisión que emitió la Sala de Decisión de Tutelas de la Penal de la Corte Suprema de Justicia en mayo 27 de 2010, en el sentido de ordenar a la Fiscalía General de la Nación **agotar** el registro de elegibles, Acuerdo 007 de 2008, para proveer **todos** los cargos vacantes o en provisionalidad a los que hacían referencia las convocatorias 001 a 006

de 2007, por cuanto dicho mandato implicó el desconocimiento de una de sus reglas: *el número de plazas a proveer*.

- 7.2. La interpretación que hizo la mencionada Sala de Decisión de Tutelas, generó que personas que no alcanzaron el rango de los puestos ofertados, es decir, que no cumplieron uno de los requisitos del concurso, estén ocupando un cargo en propiedad pese a que su designación se hizo desconociendo una de sus reglas

La revocatoria de la decisión de la Sala de Decisión de Tutelas de la Corte Suprema de Justicia, impone a esta Corporación señalar una medida expresa frente a esos nombramientos, porque la consecuencia lógica es que las personas nombradas en las plazas que no fueron ofertadas carezcan de un título legítimo para aducir derechos propios de la carrera, tales como la permanencia, la estabilidad, el ascenso, etc.

Por tanto, se impone precisar que los concursantes que fueron nombrados con fundamento en la orden que profirió la Sala de Decisión de Tutelas de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, no pueden alegar un derecho adquirido a permanecer en la carrera de la Fiscalía General de la Nación, por cuanto su acceso tuvo como sustento la decisión judicial que ahora se revoca y que, en consecuencia, hace que las medidas que se basaron en ella queden sin soporte jurídico, razón por la que la Sala debe ordenar a la Fiscal General de la Nación que todos los servidores designados en la entidad con fundamento o como consecuencia de la orden de tutela que se deja sin efecto, permanezcan en los cargos en los que fueron nombrados **pero bajo el entendido de que su vinculación es de carácter provisional y no de carrera**, puesto que el puesto que ocuparon en la lista de elegibles no les daba el derecho a acceder a ella, por cuanto la lista de elegibles se **agotó** cuando los cargos ofertados fueron provistos.

La decisión de mantener la vinculación de las personas que fueron designadas con fundamento en el fallo que esta Sala revocará, **pero con un carácter provisional**, busca garantizar el principio de confianza legítima que a ellos les asiste, pues la Corte Constitucional no pudo alterar súbitamente su situación jurídica permitiendo que el ente fiscal los desvincule de la institución por no estar amparados en el régimen de carrera⁴⁸. Se impone, entonces, en aplicación de dicho principio, que las personas designadas en los cargos de carrera sin derecho a ello, se mantengan en dichas plazas pero como servidores en provisionalidad.

Es importante señalar, igualmente, que la Fiscal General de la Nación o quien haga sus veces, no podrá desvincular a estos provisionales ni a ningún otro sin cumplir previamente el **requisito de la motivación**

⁴⁸ Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-131 de 2004. M.P. Clara Inés Vargas.

expresa del acto, tal como lo viene exigiendo la jurisprudencia constitucional desde hace más de doce años, la cual se encuentra resumida en la sentencia **SU-917 de 2010**.

7.3. Los efectos *inter comunis*

La Fiscalía General de la Nación en cumplimiento de la orden de tutela que por esta providencia quedará sin efectos y de otras que con fundamento en ella dictaron otros jueces de tutela, produjo un sin número de nombramientos **pese al agotamiento** del registro de elegibles, nombramientos cuyo número se resume en el siguiente cuadro:

	Planta 2005	Cargos a Proveer	Cargos Provistos
Fiscal Delegado ante Tribunal Superior	144	98	95
Fiscal Delegado ante Jueces Especializados	322	318	441
Fiscal Delegado ante Jueces Municipales y Promiscuos.	1566	1466	1040
Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito	1608	1280	1030
Asistente de Fiscal I	1257	1379	812
Asistente de Fiscal II	1981	1609	1060
Asistente de Fiscal III	766	588	646*
Asistente de Fiscal IV	396	312	353*
Asistente Judicial IV	1488	1052	737
Totales	9528	8102	6214

(Cuadro 6)

Teniendo en cuenta los efectos de la decisión que se adoptará y el número de nombramientos efectuados, la presente sentencia tendrá efectos ***inter comunis***⁴⁹, toda vez que debe cobijar no solo a quienes interpusieron las tutelas cuya decisión ahora se revoca, sino a todos aquellos que se encuentren en situaciones jurídicas análogas a las que dieron origen a este fallo, como una forma de proteger el derecho a la igualdad. En ese sentido, **todas** las personas nombradas en la Fiscalía General de la Nación con desconocimiento de la regla del concurso relativa al número de cargos a proveer, quedarán obligadas por esta decisión y no podrán alegar los derechos propios de la carrera de la Fiscalía.

⁴⁹ Sobre los efectos *inter comunis* pueden ser consultadas las sentencias SU-1023 de 2001; T-203 de 2002, T-451, T-843 y SU-913 de 2009, entre otras.

8. LA REALIZACIÓN DE NUEVOS CONCURSOS EN LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN

- 8.1. Teniendo en cuenta lo expuesto en numerales anteriores, en el sentido de que la Fiscalía General de la Nación debe convocar a nuevos concursos para satisfacer los requerimientos específicos que el legislador le ha impuesto y teniendo en cuenta que su planta de personal ha ido en aumento, pues de 18.200 cargos de carrera que tenía en el año 2005 pasó a 20.659, de los cuales un alto porcentaje todavía están ocupados por empleados en provisionalidad, se requiere **que, de forma inmediata**, la Fiscal General de la Nación ordene el estudio de perfiles para que, en un término máximo de seis (6), a partir de la notificación de este fallo, inicie los trámites para convocar el concurso o concursos públicos necesarios para proveer **todos y cada uno de** los cargos de carrera que en la actualidad son ejercidos en provisionalidad y los que se encuentren vacantes, incluidos los cargos permanentes y transitorios creados por la Ley 975 de 2005 y el Decreto 122 de 2008. Lo anterior significa que **todos y cada uno** de los cargos de carrera de la Fiscalía General de la Nación deben quedar provistos mediante el sistema de concurso público en un término no mayor a los dos (2) años, contados a partir de la notificación de este fallo.

Esta es la tercera orden que la Sala Plena de esta Corporación emite en ese sentido. La última orden fue en la sentencia **C-279 de 2007**, en la que se estableció que la Fiscalía General de la Nación tenía que implementar definitivamente el sistema de carrera en **toda la entidad**. En esa oportunidad, se fijó el plazo del 31 de diciembre de 2008 para culminar el proceso de vinculación mediante concursos públicos de mérito, fecha que se incumplió porque pese a las convocatorias de 2007 y otras de 2008, que no fueron objeto de esta tutela, son numerosos los empleos de carrera que siguen ocupados en provisionalidad y sin una convocatoria a concurso.

Por tanto, nuevamente la Sala Plena ordenará que en el término máximo de dos (2) años, contados a partir de la notificación de este fallo, la Fiscal General de la Nación **convoque y concluya** el o los concursos públicos que sean necesarios para proveer **todos y cada uno** de los cargos de carrera que en la actualidad son ejercidos en provisionalidad o que se encuentren vacantes. Dicho concurso o concursos, si el legislador no expide la ley correspondiente, deberán regirse por las normas pertinentes de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y de la Ley 909 de 2004, como expresamente lo indicó esta Corporación en la sentencia C-878 de 2008.

El plazo que aquí se fija tiene como fundamento el hecho que la Fiscalía General empleó un año y dos meses para la culminación del concurso de 2007, con seis convocatorias, lapso al que hay que sumarle un período

razonable para que la entidad efectué un estudio de los perfiles que se requieren para cumplir de forma eficiente y eficaz la función constitucional que le fue asignada, así como para organizar y satisfacer los requerimientos de un concurso como el que debe convocar el ente fiscal en cumplimiento del requerimiento que se hace esta providencia. La Sala busca con esta decisión, que para el año 2013, la Fiscalía General de la Nación ingrese definitivamente en el sistema de carrera.

Algunos podrán argumentar que una orden de esta naturaleza generará caos en el ente fiscal, porque el concurso puede producir una alta renovación de la fuerza laboral, que necesariamente ha de impactar en la función que constitucionalmente le asignó el Constituyente a la Fiscalía General de la Nación. Si bien esta afirmación puede ser cierta y nada deleznable, también lo es que después de 20 años de vigencia de la Constitución, la Corte Constitucional está obligada a velar por su supremacía y vigencia, razón por la que no puede permitir que se siga aplazando el cumplimiento de la regla constitucional contenida en el artículo 125. No puede olvidarse, tampoco, que éste es el tercer requerimiento que hace la Corte Constitucional para que la Fiscalía General de la Nación supere la situación de hecho que se presenta en relación con la vinculación de sus servidores por fuera de los cánones constitucionales.

Por tanto, esa institución debe prepararse desde ahora para afrontar las eventualidades que puede generar una renovación parcial de sus empleados, sin que ello sea excusa para que se cumpla y observe la Constitución.

Tampoco es de recibo el argumento según el cual, la realización de un concurso masivo haría inanes los esfuerzos presupuestales y humanos que la Fiscalía General de la Nación ha desplegado para capacitar a los servidores de la entidad, porque la lógica impone suponer que quienes han sido capacitados a lo largo de estos años en las funciones del ente de investigación tendrán mayores posibilidades de acceder a los cargos ofertados mediante el concurso o concursos públicos que deben realizarse.

- 8.2. Igualmente, es necesario precisar que la orden de concurso que aquí se imparte, incluye los cargos **permanentes y transitorios** creados por la **Ley 975 de 2005** y el **Decreto 122 de 2008**. Sobre el particular, es necesario puntualizar lo siguiente:

- 8.2.1. La **Ley 975 de 2005** creó una serie de cargos en la Fiscalía General de la Nación y de esa forma amplió la planta de personal que la entidad tenía para 2005, hecho que confirmó el legislador mediante la Ley 1024 de 2006. En las mencionadas leyes se previó que una vez finalizada la vigencia de la Ley 975 de 2005, las **275** plazas que fueron creadas a su

expedición para hacer viable su implementación, deben ser conservadas y las personas que las ocupen reubicadas en la entidad, por cuanto esos cargos hacen parte de la planta permanente prevista por el legislador. En consecuencia, pese a la especialidad y conocimientos que exige la aplicación e interpretación de la mencionada ley, la Fiscalía General de la Nación está en la obligación de hacer su provisión mediante el sistema de carrera y, en consecuencia, **todos** los cargos creados mediante la Ley 975 de 2005 deben ser convocados a concurso sin excepción y su provisión debe hacerse en el término máximo señalado en la parte resolutive de esta sentencia.

8.2.2. Por su parte, para la Sala no puede pasar inadvertido que **el Decreto 122 de 2008** se expidió después de un estudio técnico que evidenció las necesidades de nuevo de personal en la Fiscalía General de la Nación, especialmente para atender las funciones relacionadas con las Investigaciones sobre Violación de Derechos Humanos e Infracciones al Derecho Internacional Humanitario, homicidios presuntamente cometidos por agentes institucionales, extinción de dominio, el fortalecimiento para la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, Ley 975 de 2005; la ejecución del Plan Nacional para Búsqueda; hallazgo e identificación de desaparecidos; el fortalecimiento del Programa de Protección a Víctimas y Testigos, y la implementación del Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de 2006.

En esta última ley, se exigió un perfil específico para atender las necesidades y requerimientos del nuevo sistema de responsabilidad juvenil y otros aspectos referentes a los niños, niñas y adolescentes.

Después de cinco años de expedición de la Ley de la Infancia y la Adolescencia, se habla de los problemas que aquejan no sólo al sistema de responsabilidad juvenil, sino la aplicación efectiva del sistema de protección para los niños, niñas y adolescentes, una de esas dificultades, sin lugar a dudas, reposa en el hecho de que los fiscales y los jueces no tienen la preparación, experiencia y conocimientos que requiere esta legislación, en la que los menores de diez y ocho años pasaron de ser sujetos de protección a ser verdaderos sujetos de derecho de especial protección, que requieren de unos funcionarios que logren entender esta dimensión que, desde la Convención del Niño adquirieron los menores de 18 años, y que como tal, exigen funcionarios y empleados capaces de afrontar y satisfacer en debida forma los retos y las necesidades que reclama esta población.

Lo expuesto en precedencia, significa que los nuevos cargos que decidió crear el legislador extraordinario deben **responder a un perfil específico** para atender no sólo las necesidades que fueron descubiertas en el estudio técnico al que se hace mención en las motivaciones del Decreto 122 de 2008 sino en la Ley 1098 de 2006.

En consecuencia, la Corte considera que las personas que ocupen dichos cargos deben poseer unos conocimientos, destrezas y experiencia que deben ser claramente establecidas por la entidad, razón por la que el concurso deberá dar cuenta de las necesidades y particulares que evidenció el legislador extraordinario. Sólo así, se podrá tener un ente de investigación especializado.

- 8.2.3. El Decreto 122 de 2008**, creó, igualmente, unos cargos de **carácter transitorio** para atender las necesidades de la Ley de Justicia y Paz y fijó como término de vigencia para esas plazas el de **12 años**. El número de empleos de carácter transitorio creados por este decreto fue de **753**. En relación con estos nuevos puestos de trabajo y pese a su carácter transitorio, considera la Corte que deben ser igualmente llamados a concurso, pues su naturaleza transitoria no puede entenderse como una excepción al cumplimiento de la regla del artículo 125 constitucional, en relación con el mérito y la calidad. Es precisamente ese carácter transitorio el que debe ser puesto en evidencia en la respectiva convocatoria, para que los aspirantes tengan claro que una de las reglas de la convocatoria es el carácter temporal de los cargos razón por la que los mismos serán suprimidos una vez venza el término señalado por el legislador, sino llega a disponer lo contrario. Supresión que en los términos del artículo 76 de la Ley 938 de 2004 *“es una situación de carácter administrativo, que pone fin a la inscripción en el régimen de carrera y desvincula al servidor de la entidad...”*.

En consecuencia, la Fiscalía General de la Nación debe llamar a concurso los empleos temporales que creó el legislador extraordinario y establecer expresamente ese carácter para que quienes concursen, conozcan de antemano y en forma clara la regla que ha de regir su designación, en el evento de ser acreedores a ocupar una de esas plazas.

- 8.3.** Igualmente, es importante recordar que la Comisión Nacional de Administración de la Carrera de la Fiscalía General de la Nación sólo puede regular los aspectos técnicos y operativos para hacer aplicables las normas que rigen el sistema autónomo de carrera de dicho ente, tal como expresamente se indicó en la sentencia C-878 de 2008.

En este punto, cobra relevancia señalar que la Comisión de Carrera al momento de elaborar los criterios de selección debe dar estricto cumplimiento al artículo 4 del reglamento del proceso de selección y el concurso de méritos, Acuerdo 01 de 2006, si no se expide otro, en cuanto a los factores de selección, en donde deben primar las aptitudes, conocimientos y habilidades relacionadas con la función a desempeñar, así como las calidades académicas y experiencia en el tipo de función según el manual correspondiente.

En este sentido, la Sala Plena considera trascendental que entre los factores a calificar, la *experiencia específica* o cualificada en el ejercicio de las funciones propias del cargo objeto de concurso o cargos iguales o similares debe tener una valoración. Porque si bien esta Corporación ha proscrito todo trato distinto entre los aspirantes que se desempeñaban un cargo en provisionalidad con el resto de los aspirantes⁵⁰, no resulta ni discriminatorio ni irrazonable que en los criterios de selección que debe fijar la Comisión de Carrera, la experiencia en funciones iguales o similares sea valorada. No se trata de un privilegio para las personas que han podido desempeñar un cargo en provisionalidad o carrera en la entidad, como se señaló en la sentencia C-733 de 2005⁵¹, sino de permitir que las personas que han ejercido las funciones del cargo en concurso o similares puedan tener una calificación *por experiencia específica*, factor que sumado con los otros debe permitir escoger a quien de conformidad con el artículo 125 constitucional esté *mejor y más* calificado para cumplir la respectiva función. La experiencia no se puede despreciar y como tal el contacto y conocimiento de la función debe ser enjuiciado y ponderado por la respectiva entidad.

Tampoco se trata de crear una evaluación adicional, caso analizado en la sentencia C-733 de 2005. No. Se trata de ponderar entre los factores comunes de evaluación, la *experiencia en la función objeto de la convocatoria o similares*.

Así mismo, no se trata de eximir a un grupo de concursantes de requisitos que se imponen a los otros participantes, caso que analizó la Corte en la sentencia C-901 de 2008⁵², en donde la sola circunstancia de haber desempeñado en provisionalidad un cargo de carrera, le permitía al servidor su inscripción en ésta.

Igualmente, está orden no pueden entenderse como otra forma de concursos cerrados, los cuales están expresamente por esta Corporación, por cuanto todas las personas que cumplan los requisitos de las

⁵⁰ Cfr, Corte Constitucional, sentencias C-733 de 2005. M.P. Clara Inés Vargas, reiterada en la sentencia C-901 de 2008. M.P. Mauricio González Cuervo, entre otras.

⁵¹ En esa oportunidad, la Corte analizó la constitucionalidad del artículo 56 de la Ley 909 de 2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”, que expresamente consagraba: “EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES A EMPLEADOS PROVISIONALES. A los empleados que a la vigencia de la presente ley se encuentren desempeñando cargos de carrera, sin estar inscritos en ella, y se presenten a los concursos convocados para conformar listas de elegibles para proveer dichos cargos, destinadas a proveerlos en forma definitiva, se les evaluará y reconocerá la experiencia, antigüedad, conocimiento y eficiencia en su ejercicio”. La Comisión Nacional del Servicio Civil adoptará los instrumentos para tal efecto.

⁵² Este fallo se dictó al analizar unas objeciones presidenciales del proyecto de ley N° 117 de 2007 Senado – 171 de 2007 Cámara, “Por la cual se reforman algunos artículos de la Ley 909 de 2004, algunos artículos de las disposiciones que contienen los concursos de los sistemas específicos y especiales de origen legal y constitucional y se dictan otras disposiciones en materia de Carrera Administrativa”

convocatorias podrán participar, sólo que la experiencia de unos y otros debe ser valorada en forma diversa.

9. LA ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE ELEGIBLES

- 9.1. De conformidad con el artículo 24 del Acuerdo 002 de 2006, que regía las convocatorias de 2007, *“en los primeros tres meses de cada año en que se encuentre vigente el registro de elegibles, quienes figuren en él podrán obtener la actualización de sus respectivos puntajes, previa solicitud a la Comisión debidamente acompañada de la documentación que acredite la nueva condición del solicitante”*.

Estas actualizaciones implicaban modificaciones sustanciales al registro de elegibles, porque generaban el reconocimiento de un mejor derecho para quienes en vigencia de la lista pudieran acreditar el cumplimiento de requisitos que no ostentaban al momento de la calificación correspondiente. Esa actualización, así entendida, permitía que el puntaje inicialmente obtenido fuera superado, lo que le permitía al concursante que solicitaba la actualización, una mejor posición en la lista frente a quienes originalmente estaban en ella y no hicieron uso de esta prerrogativa.

- 9.2. La facultad de establecer actualizaciones por parte de la Comisión de Carrera de la Fiscalía fue declarada inexecutable por esta Corporación en la sentencia C-878 de 2008⁵³, por cuanto se consideró que el ente en mención no podía tener tal potestad. No obstante, en la misma providencia se precisó que como el concurso de 2007 estaba en desarrollo, se reconocería la posibilidad de actualización de la lista sólo para ese concurso, como una forma de preservar los principios de buena fe y confianza legítima de los participantes en esas convocatorias.

En el primer año de vigencia del registro de elegibles de la Fiscalía General de la Nación objeto de la acción de tutela de la referencia, Acuerdo 007 de 2008, la actualización no se efectuó. Se requirió de una decisión de la Sala de Decisión de Tutelas de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal,⁵⁴ que mediante providencia del 27 de mayo de 2010 y como una forma de proteger los derechos al debido proceso y a la igualdad en el acceso a cargos públicos de quien interpuso la acción de tutela, ordenó a la Comisión Nacional de Administración de Carrera de la Fiscalía la actualización, por cuanto la misma no se produjo en los términos del Acuerdo 002 de 2006.

⁵³ M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. En este fallo se declararon inexecutable los incisos segundo y tercero del artículo 66 de la Ley 938 de 2004. El inciso segundo, se refería a la facultad otorgada a la Comisión de Carrera de la Fiscalía de actualizar el registro de elegibles.

⁵⁴ M.P. Alfredo Gómez Quintero.

En cumplimiento de la orden antes reseñada, la Fiscalía General de la Nación expidió el Acuerdo 002 de octubre 22 de 2010, por medio del cual se actualizó el registro de elegibles contenido en el Acuerdo 007 de 2008.

- 9.3.** Esta actualización necesariamente incidía en la adjudicación de las plazas ofertadas, sin embargo, el que la Fiscalía General no hubiese cumplido los tiempos señalados en el Acuerdo 002 de 2006, no puede ser remediado por la Corte Constitucional en sede de tutela. Si bien es cierto, la no actualización pudo ocasionar el desconocimiento de derechos de quienes se encontraban en el registro de elegibles y tenían la opción de actualizar y mejorar su posición en él, también lo es que la entidad demoró injustificadamente el nombramiento de las personas que ganaron el concurso y que adquirieron el derecho a ser designadas en una de las plazas ofertadas, un año y medio, en donde una actualización hubiese resultado lesiva de sus derechos fundamentales.

En consecuencia, la Sala Plena no se pronunciará sobre la actualización que la Fiscalía General de la Nación dejó de hacer en el primer año de vigencia del registro de elegibles por cuanto con ello se desconocería el derecho de acceso a cargos públicos de quienes originalmente ocuparon un puesto en la lista, que les permitía acceder a uno de los empleos ofertados y porque no habría razón a ello después de la pérdida de fuerza vinculante de dicho acto administrativo, hecho que se produjo el 24 de noviembre de 2010.

10. SOLUCIÓN DEL SEGUNDO PROBLEMA JURÍDICO: DISCRECIONALIDAD DEL FISCAL GENERAL PARA DEFINIR, EN EL MARCO DE UNA PLANTA GLOBAL, LOS CARGOS ESPECÍFICOS QUE SERÍAN PROVISTOS CON EL REGISTRO DE ELEGIBLES Y LA PROTECCIÓN ESPECIAL DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, LAS MADRES Y PADRES CABEZA DE FAMILIA Y LOS PREPENSIONADOS.

- 10.1.** En razón de la naturaleza global de la planta de personal de la Fiscalía, tal como la definió el legislador, y el carácter provisional de la vinculación que ostentaban quienes hacen parte de este grupo de accionantes, la Sala considera que el Fiscal General gozaba de discrecionalidad para determinar los cargos que serían provistos por quienes superaron el concurso; por tanto, no se podía afirmar la vulneración de los derechos a la igualdad y al debido proceso de estos servidores, al no haberse previsto por parte de la entidad, unos criterios para determinar qué cargos serían lo que expresamente se ocuparían con la lista de elegibles.

La única limitación que tenía la Fiscalía General de la Nación era reemplazar a estos provisionales con una persona que hubiere ganado el concurso y ocupado un lugar que le permitiera acceder a una de las plazas ofertadas. En este caso, los provisionales no podían alegar vulneración de derecho alguno al ser desvinculados de la entidad toda vez que lo fueron para ser reemplazados por una persona que ganó el concurso.

Los servidores en provisionalidad, tal como reiteradamente lo ha expuesto esta Corporación⁵⁵, gozan de una estabilidad relativa, en la medida en que sólo pueden ser desvinculados para proveer el cargo que ocupan con una persona de carrera, tal como ocurrió en el caso en estudio o por razones objetivas que deben ser claramente expuestas en el acto de desvinculación⁵⁶. En consecuencia, la terminación de una vinculación en provisionalidad porque la plaza respectiva debe ser provista con una persona que ganó el concurso, no desconoce los derechos de esta clase de funcionarios, pues precisamente la estabilidad relativa que se le ha reconocido a quienes están vinculados bajo esta modalidad, cede frente al mejor derecho que tienen las personas que ganaron un concurso público de méritos.

En la sentencia C-588 de 2009⁵⁷, se manifestó sobre este punto, así: “... *la situación de quienes ocupan en provisionalidad cargos de carrera administrativa es objeto de protección constitucional, en el sentido de que, en igualdad de condiciones, pueden participar en los concursos y gozan de estabilidad mientras dura el proceso de selección y hasta el momento en que sean reemplazados por la persona que se haya hecho acreedora a ocupar el cargo en razón de sus méritos previamente evaluados*”⁵⁸

- 10.2.** Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación, pese a la discrecionalidad de la que gozaba, **sí** tenía la obligación de dar un trato preferencial, como una medida de acción afirmativa a: **i)** las madres y padres cabeza de familia; **ii)** las personas que estaban próximas a pensionarse, entiéndase a quienes para el 24 de noviembre de 2008 -fecha en que se expidió el Acuerdo 007 de 2008- les faltaren tres años o menos para cumplir los requisitos para obtener la respectiva pensión; y **iii)** las personas en situación de discapacidad.

⁵⁵ La línea jurisprudencial en esta materia se encuentra recogida en la sentencia SU-917 de 2010. M.P. Jorge Iván Palacios Palacios.

⁵⁶ Cfr. Corte Constitucional T-1011 de 2003; T-951 de 2004; T-031 de 2005; T-267 de 2005; T-1059 de 2005; T-1117 de 2005; T-245 de 2007; T-887 de 2007; T-010 de 2008; T-437 de 2008; T-087 de 2009 y T-269 de 2009. Así mismo, la sentencia SU-917 de 2010, que recoge toda la jurisprudencia sobre este particular y fija las órdenes que debe dar el juez de tutela en estos casos.

⁵⁷ M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

⁵⁸ Véanse, por ejemplo, las Sentencias C-064 de 2007. M. P. Rodrigo Escobar Gil y T-951 de 2004. M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

En estos tres eventos la Fiscalía General de la Nación ha debido prever mecanismos para garantizar que las personas en las condiciones antedichas, fueran las últimas en ser desvinculadas, porque si bien una cualquiera de las situaciones descritas no otorga un derecho indefinido a permanecer en un empleo de carrera, toda vez que prevalecen los derechos de quienes ganan el concurso público de méritos. Como el ente fiscal no previó dispositivo alguno para no lesionar los derechos de ese grupo de personas, estando obligado a hacerlo, en los términos del artículo 13 de la Constitución, esta Corte le ordenará a la entidad que dichas personas, **de ser posible**, sean nuevamente vinculadas en forma provisional en cargos vacantes de la misma jerarquía de los que venían ocupando.

Es claro que los órganos del Estado en sus actuaciones deben cumplir los fines del Estado, uno de ellos, garantizar la efectividad de los derechos consagrados en la Constitución, entre los cuales la igualdad juega un papel trascendental, en la medida que obliga a las autoridades en un Estado Social de Derecho, a prodigar una protección especial a las personas que, por su condición física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta, artículo 13, inciso 3 de la Constitución. Este mandato fue ignorado por la Fiscalía General cuando hizo la provisión de los empleos de carrera y dejó de atender las especiales circunstancias descritas para los tres grupos antes reseñados.

En relación con el llamado retén social es necesario precisar que si bien la Fiscalía General de la Nación no hace parte de la rama ejecutiva del poder público y como tal no está obligada por el programa de renovación de la administración pública contenido en la Ley 790 de 2002, razones de igualdad material propias del Estado Social de Derecho que nos rige, imponen a la Sala ordenar al ente fiscal tener especial cuidado con las personas en las situaciones antedichas.

En consecuencia, la entidad deberá prever las especiales situaciones descritas en este apartado, al momento en que deba ocupar los cargos con el o los concursos que tiene que efectuar en cumplimiento de esta providencia.

- 10.3. Lo expuesto, le permite a la Sala concluir que debe negar la protección que solicitaron los accionantes que ocupaban empleos en provisionalidad y que alegaron la vulneración de sus derechos a la igualdad y al debido proceso, entre otros, por la inexistencia de criterios para definir a quiénes se les terminaría su vinculación para ser reemplazados por personal de carrera, en los términos del concurso.

En el caso de los provisionales que son sujetos de especial de protección, si bien la Corte **no concederá la tutela** porque no ostentaban un derecho a permanecer en el empleo, sí se ordenará a la

Fiscalía General de la Nación que, en el evento en que a la fecha de expedición del fallo existan vacantes disponibles en cargos iguales o equivalentes a aquellos que venían ocupando, sean vinculados en provisionalidad mientras se realiza un nuevo concurso. La desvinculación de estos servidores sólo será posible previo acto administrativo motivado en los términos de la sentencia **SU-917 de 2010**.

11. DE LOS CASOS CONCRETOS

11.1. EL GRUPO DE QUIENES ESTÁN EN LA LISTA DE ELEGIBLES Y NO FUERON DESIGNADOS

11.1.1. Los señores **Joaquín González Bohórquez; Luisa Gineth Pinto Ochoa; Gloria Mariño Quiñónez, Beatriz Alicia Idarraga Piedrahita y Ronit Janet Caldas Rueda**, hacían parte de la lista de elegibles para Fiscal Delegado ante Tribunal Superior, pero por fuera del número límite de plazas a proveer y que para este cargo sólo era de 52. Así, por ejemplo, el señor **Joaquín González Bohórquez**, ocupó el puesto **112** en la lista con 74 puntos; **Luisa Gineth Pinto Ochoa**, el **77** con 76 puntos; **Gloria Mariño Quiñónez**, el **87** con 75 puntos; **Beatriz Alicia Idarraga Piedrahita**, el **118** con 74 puntos y **Ronit Janet Caldas Rueda**, el **107** con 74 puntos también.

Teniendo en cuenta que para el cargo para el cual concursaron estos accionantes sólo fueron ofertadas 52 plazas, en ninguno de ellos concurría el derecho a ser designado, dado que ocuparon en la lista un lugar inferior al número de cargos a proveer.

Por tanto, se impone **CONFIRMAR** los fallos de instancia en cada uno de los expedientes de tutela que promovieron los mencionados ciudadanos, por cuanto la Fiscalía General de la Nación no desconoció sus derechos fundamentales de acceso a cargos públicos, igualdad y debido proceso.

No obstante, si alguno de estos accionantes fue nombrado en la entidad por hacer parte del registro de elegibles contenido en el Acuerdo 07 de 2008 y actos complementarios, sin sujeción a la regla del número de plazas a proveer, seguirán vinculados a la entidad hasta tanto sus cargos sean provistos en propiedad mediante el sistema de carrera o su desvinculación cumpla los requisitos exigidos en la jurisprudencia constitucional, contenida, entre otras, en la sentencia **SU-917 de 2010**.

11.1.2. En relación con el señor **Robinson González Pérez** debemos señalar que se presentó en dos convocatorias. En la de Asistente Fiscal IV en la que obtuvo 64 puntos y ocupó el puesto 280 y en la de Fiscal Delegado

ante los Jueces Municipales y Promiscuos, que no aprobó, pues sólo obtuvo 54 puntos.

En consecuencia, su derecho a ser nombrado en el cargo de Asistente Fiscal IV sí se configuró, pues fueron ofertadas 288 plazas y ocupó el puesto 280. En ese orden, la Fiscal General de la Nación debe ordenar su nombramiento de forma inmediata, una vez se notifique esta providencia, siempre y cuando no existan concursantes en una mejor posición. En el evento en que este accionante no hubiere aceptado el empleo, se entenderá cumplida la decisión de tutela que aquí se imparte.

Por tanto, se **CONFIRMARÁ PARCIALMENTE** la sentencia de la Sala de Decisión de Tutela de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, proferida dentro del expediente **T-2.701.828**, **Demandante: Robinson González Pérez**, en la medida en que le asistía el derecho a ocupar un cargo en propiedad de Asistente de Fiscal IV.

- 11.1.3.** En el caso de la señora **Alieth Molina Raigosa**, quien participó en la convocatoria para Fiscal Delegado ante los Jueces del Circuito, que no aprobó, pues sólo obtuvo 57 puntos y en la de Fiscal Delegado ante los Jueces Municipales y Promiscuos en la que ocupó el puesto **902** con 61 puntos, se debe señalar que en razón del puesto que ocupó en el registro de elegibles frente al número de plazas a proveer, no le asistía derecho alguno a ser nombrada.

En consecuencia, se **REVOCARÁ** la sentencia proferida por la Sala de Decisión de Tutela de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dentro del expediente **T-2.701.827**, **Demandante: Luz Alieth Molina Raigosa**, que le tuteló sus derechos fundamentales, por cuanto no le asistía derecho a ser designada en un cargo de carrera, por cuanto el lugar que ocupó excedía el de las plazas por proveer. Se debe aclarar sí, que en el evento en que la señora **Molina Raigosa** esté ocupando un cargo de carrera con desconocimiento de la mencionada regla, continuará vinculada a la entidad pero con **carácter provisional**, hasta tanto el cargo que ocupe sea provisto en propiedad mediante el sistema de carrera o su desvinculación cumpla los requisitos exigidos en la jurisprudencia constitucional, contenida, entre otras, en la sentencia **SU-917 de 2010**.

- 11.1.4.** En el caso de la señora **Cielo del Pilar Bonilla Arias**, quien participó en dos convocatorias: en la de Asistente de Fiscal II, en la que ocupó el puesto **99** con 68 puntos y en la de Fiscal Delegado ante los Jueces Municipales y Promiscuos que no aprobó, porque sólo obtuvo 51 puntos, su derecho a ser designada en un empleo de carrera sólo se configuró frente a la primera convocatoria, plaza en la que la Fiscalía General de la Nación le hizo en tiempo la designación correspondiente. En consecuencia, se **CONFIRMARÁ** la decisión de la Corte Suprema

de Justicia, Sala de Tutelas de la Sala de Casación Penal⁵⁹, que confirmó el fallo de primera instancia y señaló que a la accionante no le asistía derecho a ocupar un cargo de carrera por no haber aprobado el concurso.

11.2. EL GRUPO DE LOS PROVISIONALES Y OTROS

11.2.1. Expediente T-2.700.019. Actora: Bolivia Renza Bacca. Esta ciudadana ocupaba el cargo de Fiscal Delegada ante los Jueces Municipales y Promiscuos, en provisionalidad desde el 10 de febrero de 2005. Dice haber participado en una de las convocatorias sin obtener el puntaje mínimo requerido, según ella, su calificación fue de 59 puntos. No obstante, revisado el registro que expidió la Fiscalía General su número de identificación no aparece.

El 12 de marzo de 2010, la Fiscalía General de la Nación dio por terminado su nombramiento en provisionalidad para designar a la persona que ganó una de las plazas ofertadas. Aduce su condición de madre cabeza de familia y el hecho de que otros provisionales que no se encuentran en su especial circunstancia siguen ocupando el cargo, para solicitar su reintegro mientras demanda el acto administrativo de desvinculación ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

En este caso, se **CONFIRMARÁ** la decisión de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal⁶⁰, que negó el amparo solicitado, porque si bien la condición de madre cabeza de familia ha debido ser tomada en cuenta por la Fiscalía General de la Nación para determinar el orden en que se terminarían las provisionalidades, también es cierto que por su condición no podía alegar un mejor derecho frente a quien en su reemplazo fue nombrado, por cuanto éste tenía un mejor derecho para estar vinculado con el ente fiscal.

No obstante lo anterior, se ordenará a la Fiscal General de la Nación que en el evento de existir vacantes en un cargo igual o equivalente al que ocupaba la señora **Renza Bacca**, ésta deberá ser nuevamente vinculada en provisionalidad hasta tanto su cargo sea provisto en propiedad mediante el sistema de carrera o su desvinculación cumpla los requisitos exigidos en la jurisprudencia constitucional, contenida, entre otras, en la sentencia **SU-917 de 2010**. Para el efecto, ha de demostrar que a la fecha de la desvinculación ostentaba la condición de madre cabeza de familia.

11.2.2. Expediente T-2.701.934. Actor: Mauro de Jesús Ávila Tibatá. Este accionante se encontraba ocupando un cargo en provisionalidad en la Fiscalía General de la Nación y se presentó a la convocatoria 003-2007, para proveer el cargo de Fiscal Delegado ante los Jueces Penales del

⁵⁹ M.P. Alfredo Gómez Quintero.

⁶⁰ M.P. Alfredo Gómez Quintero.

Circuito Especializados en la que ocupó el puesto **405** con 65 puntos. Igualmente, se presentó en la convocatoria 004-2007 para el cargo de Fiscal Delegado ante los Jueces del Circuito, en la que ocupó el puesto **855** con 66 puntos.

La entidad demandada nombró en el puesto que el actor desempeñaba a quien aprobó con un mejor puntaje al suyo el concurso y, en consecuencia, dio por terminado su nombramiento en provisionalidad. Sin embargo, considera que la institución ha debido remover primero a los funcionarios que no tenían ninguna opción de permanencia, bien porque no concursaron o porque no pasaron el concurso. En ese sentido, considera desconocido su derecho fundamental a la igualdad, ya que la Fiscalía ha debido cesar la provisionalidad en estricto orden, iniciando por quienes no se presentaron a ninguna de las convocatorias, siguiendo con los que no pasaron y finalmente con quienes estaban ubicados en los últimos puestos de la lista de elegibles.

En relación con esta pretensión, la Fiscalía informó en su primera respuesta a esta Corporación, que desde un comienzo tomó previsiones para terminar la provisionalidad primero de quienes no concursaron o no aprobaron el concurso. Sin embargo, en el caso concreto no se explicó exactamente ocurrió.

De todas formas, es claro que el nombramiento de quien ganó la plaza que ocupaba el señor **Ávila Tibatá** no puede ser considerado contrario a los derechos de este último, por tanto, se confirmará la decisión de la Sala de Decisión Penal de la Corte Suprema de Justicia, que revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, negó por improcedente la acción interpuesta por el señor Ávila Tibatá.

Se debe aclarar sí, que en el evento en que el señor **Ávila Tibatá** esté ocupando un cargo de carrera con desconocimiento de la regla del número de cargos a proveer, de conformidad con la convocatoria en la que concursó, continuará vinculado a la entidad pero con **carácter provisional**, hasta tanto el cargo que ocupe sea provisto en propiedad mediante el sistema de carrera o su desvinculación cumpla los requisitos exigidos en la jurisprudencia constitucional, contenida, entre otras, en la sentencia **SU-917 de 2010**.

11.2.3. Expediente T-2.707.718. Actor: Tomás Florentino Serrano Serrano. Este ciudadano se presentó en dos convocatorias. En la de Fiscal Delegado ante los Jueces Especializados, en la que ocupó el puesto **60** con 76 puntos, razón por la que fue nombrado el 20 de noviembre de 2009.

Igualmente, se presentó en la convocatoria para Fiscal Delegado ante Tribunal Superior, en la que obtuvo **73** puntos y ocupó el puesto 141, el

cual comparte con más de 30 candidatos. En relación con esta convocatoria, le solicitó a la Comisión Nacional de Administración de Carrera de la Fiscalía actualizar su hoja de vida de conformidad con el Acuerdo 01 de 2006, que establecía que en los tres primeros meses de los dos años de vigencia de la lista de elegibles, los concursantes podían solicitar la actualización de su hoja de vida. En ese sentido, el señor Serrano Serrano buscaba que se le tuvieran en cuenta una serie de publicaciones que hizo entre 2007 y 2009, así como la experiencia adquirida después de haberse presentado al concurso, entre otras, con el fin de poder obtener una mayor ponderación de su hoja de vida y lograr de esa manera mejorar su posición en la lista de elegibles lo que le podía permitir acceder, seguramente, a una plaza de Fiscal Delegado ante los Tribunales.

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal⁶¹, mediante providencia del 27 de mayo de 2010, amparó los derechos al debido proceso, a la igualdad y el acceso a cargos públicos del actor, previniendo a la Comisión Nacional de Administración de Carrera de la Fiscalía, para que, en el término de diez (10) días, informara a todos los integrantes del registro de elegibles sobre la posibilidad de solicitar su actualización.

Por medio del Acuerdo 002 del 22 de octubre 2010 y en cumplimiento de la orden de tutela que se profirió en este caso, se actualizó el registro de elegibles y el señor Serrano Serrano quedó en el puesto **81** con 74 puntos⁶².

Tal como se señaló en el numeral **9** de esta providencia, es verdad que la entidad ha debido hacer la **primera** actualización entre diciembre del 2009 y febrero de 2010 y la **segunda** entre diciembre del 2010 y febrero de 2011, que corresponde a los primeros tres meses de cada año de vigencia de la lista, términos que incumplió la entidad toda vez que para la época en que le correspondía llevar a cabo esta actividad, la entidad aún no había provisto todos los cargos ofertados con la lista de elegibles, prueba de ello es que esta Corporación, en sentencia T-843 del 24 de noviembre de 2009⁶³, ordenó hacer la provisión de todos los cargos ofertados, pues un año después de la vigencia del registro de elegibles éste no se había agotado.

Sin embargo, la única actualización que se hizo le permitió al actor ganar algunos puestos en el registro pero no los suficientes para tener derecho a una plaza de Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior del Distrito, por cuanto sólo se ofertaron 52 empleos. Desconoce la Sala si

⁶¹ M.P. Alfredo Gómez Quintero

⁶² <http://fgn.fiscalia.gov.co:8080/Fiscalia/contenido/html/Carrera2007.jsp#>. Consultada efectuada el 7 de diciembre de 2010.

⁶³ M.P. Jorge Ignacio Pretlt Chaljud, noviembre 24 de 2009.

las eventuales situaciones administrativas que se pudieron presentar después del fallo de instancia le permitieron al señor **Serrano Serrano** acceder a dicho cargo.

Por lo anterior, se **CONFIRMARÁ** la decisión de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, que amparó los derechos al debido proceso y a la igualdad en el acceso a cargos públicos del señor **Serrano Serrano**, y que ordenó la actualización del registro de elegibles, la que como ya se indicó ya se efectuó.

11.2.4. Expediente T-2.643.464. Actor: Nelson Triana Cárdenas. Este actor se presentó a dos convocatorias. En la primera, para la 001-2007, correspondiente al cargo de Fiscal Delegado ante los Jueces Municipales y Promiscuos, en la que no obtuvo el puntaje mínimo, sólo alcanzó 54 de los 60 puntos requeridos. En la segunda, en la 002-2007, para el cargo de Fiscal Delegado ante los Jueces del Circuito, tampoco obtuvo el puntaje mínimo, sólo llegó a los 49 puntos. En consecuencia, no tenía derecho a ser designado en un cargo de carrera, razón por la que la Sala Plena debe confirmar el fallo de la Corte Suprema- Sala Penal que confirmó el de primera instancia, pero por razones diversas, toda vez que el señor Nelson Triana Cárdenas **no tenía** derecho a ocupar un cargo de carrera en la Fiscalía General por no aprobar el correspondiente concurso.

11.2.5. Expediente T-2.734.433. Actor: Reinaldo de Jesús Gómez Muñetón. En este caso nos encontramos ante un funcionario que venía ocupando el cargo de Fiscal Delegado ante los Jueces Municipales y Promiscuos en diversas sedes y pese a que participó en el concurso para el cargo de Fiscal Delegado ante los Jueces Especializados no aprobó la prueba eliminatoria. Por tanto, el 7 de abril de 2010 se dio por terminado su nombramiento en provisionalidad como Fiscal 29 de Guayabetal-Cundinamarca.

Según se desprende de las pruebas que obran en el expediente, el señor Gómez Muñetón es invidente, sufrió un desprendimiento de retina total de ambos ojos, según certificación médica que obra en el expediente⁶⁴. El actor afirma que es el único que provee el sustento de su familia, entre ellos, un hijo de 21 años que tiene una incapacidad laboral del 69.15%, quien perdió su ojo derecho y en el izquierdo presenta una miopía severa y un glaucoma abierto⁶⁵. Solicitó la suspensión del acto que dio por terminada su provisionalidad y el reintegro a un cargo igual o de mejor jerarquía al que venía ocupando.

Como se indicó en otro acápite de esta providencia, está demostrado que la Fiscalía General de la Nación al momento de proveer los cargos con el registro de elegibles no tuvo en cuenta ningún criterio para proceder

⁶⁴ Folio 18 del cuaderno principal.

⁶⁵ Folio 34 del cuaderno principal.

a dar por terminadas las vinculaciones en provisionalidad porque, según se desprende de la respuesta que obra en el expediente que ahora es objeto de análisis, se consideró que hacer distinciones *“haría necesaria toda una reglamentación que establezca a quien se le puede terminar la provisionalidad y a quien no y a quien primero y luego a quien, y así sería imposible nombrar a quien sí tiene un mejor derecho, esto es a quien concursó y se hizo acreedor al derecho de ser nombrado”*⁶⁶.

No podemos olvidar que los órganos del Estado en sus actuaciones deben cumplir los fines del Estado, uno de ellos, garantizar la efectividad de los derechos consagrados en la Constitución, entre los cuales la igualdad juega un papel trascendental, en la medida que obliga a las autoridades en un Estado Social de Derecho a dar una protección especial a las personas que por su condición física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta, artículo 13, inciso 3 de la Constitución.

En ese orden, es cierto que las personas que ganaron el concurso tenían un mejor derecho frente a quienes ocupaban un cargo en provisionalidad, asunto que en esta providencia se busca proteger y garantizar. Sin embargo, también está demostrado que en la asignación de las plazas en la Fiscalía General no se fijaron criterios para proteger a quienes por sus especiales condiciones deberían ser los últimos en desvincularse de la entidad por razón del concurso público.

En ese sentido, está probado, por ejemplo, que en una sede podían existir varias plazas de la misma naturaleza y perfil de las que fueron objeto de concurso ocupadas por provisionales y sólo a unos pocos de ellos se le terminó la provisionalidad, sin que existieran lineamientos claros para determinar cuáles eran las razones de la entidad para terminar una provisionalidad y no la otra. Es decir, el Fiscal General utilizó al extremo su facultad discrecional, pues el único criterio válido para la entidad era *“estar ocupando un cargo en provisionalidad”*⁶⁷

Así, por ejemplo, la Fiscalía General confirma que en la sede en donde el actor se encontraba desempeñando el cargo de Fiscal Delegado antes los Jueces Municipales y Promiscuos, las plazas eran 40. De los funcionarios que desempeñaban ese cargo, 25 no estaban en la lista de elegibles, es decir 25 funcionarios en provisionalidad que se encontraba en la misma situación del actor, es decir, fuera del registro de elegibles⁶⁸. No obstante, al único que al parecer se le terminó la provisionalidad fue al señor Gómez Muñetón, pese a su especial situación, hecho que es reprochable pero que no es suficiente para ordenar el reintegro que se solicita en el escrito de tutela, como una

⁶⁶ Folio 75 del cuaderno principal.

⁶⁷ Impugnación del fallo de primera instancia, folio 76 del cuaderno principal,

⁶⁸ Folio 96 del cuaderno principal.

forma de proteger sus derechos, por cuanto ello implicaría alterar los nombramientos que ha efectuado la entidad.

En ese orden, si bien se **CONFIRMARÁ** el fallo de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil del 19 de junio de 2010, mediante el cual se decidió revocar en su integridad el fallo de primera instancia que concedió el amparo solicitado, por cuanto al actor se le terminó su provisionalidad para proveer el cargo que ocupaba por una persona que ganó el concurso y, que por ende, tenía un mejor derecho, se ordenará a la Fiscal General de la Nación que, en el evento de existir vacantes en un cargo igual o equivalente al que ocupaba el actor, éste deberá ser nuevamente vinculado en provisionalidad hasta tanto la plaza correspondiente sea provista en propiedad mediante el sistema de carrera o su desvinculación cumpla los requisitos exigidos en la jurisprudencia constitucional, contenida, entre otras, en la sentencia **SU-917 de 2010**.

11.2.6. Expediente T-2.743.538. Actora: Gloria Nelly Delgado Castañeda.

En este caso nos encontramos ante una funcionaria que venía ocupando el cargo de Fiscal Delegada ante los Jueces Municipales y Promiscuos en Bucaramanga y no aprobó la prueba eliminatoria. Por tanto, el 16 de marzo de 2010 se dio por terminado su nombramiento en provisionalidad.

Igualmente están demostradas dos circunstancias, la primera, su condición física, persona a la que le amputaron su brazo derecho hace mas de treinta años y que actualmente padece de síndrome del túnel carpiano izquierdo⁶⁹, la segunda, estar a menos de un año para cumplir los requisitos para obtener la pensión.

Como se señaló en el caso anterior, está demostrado que la Fiscalía General de la Nación al momento de proveer los cargos con el registro de elegibles no tuvo en cuenta ningún criterio para proceder a finalizar las vinculaciones en provisionalidad. Un ejemplo de ello, es el caso de la accionante, que imponían crear criterios de distinción al momento de dar por terminadas las provisionalidades, que permitieran garantizar la efectividad de los derechos consagrados en la Constitución, entre los cuales la igualdad material jugaba un papel trascendental, que obligaba a la entidad a prodigar una protección especial a las personas que por su condición física se encontraban en circunstancias de debilidad manifiesta, en los términos del artículo 13, inciso 3 de la Constitución.

Se reitera que si bien es cierto las personas que ganaron el concurso tenían un mejor derecho frente a quienes ocupaban un cargo en provisionalidad, también está demostrado que en la asignación de las

⁶⁹ Folio 7 del cuaderno original.

plazas en la Fiscalía General no hubo un criterio claro, objetivo y razonable para su reparto que permitiera inferir que condiciones especiales fueran tenidas en cuenta, lo que produjo que los nombramientos de estas personas fueran terminados, manteniéndose el de otros sin razones objetivas para ello.

Así las cosas y tal como se decidió el caso anterior, la Sala no puede ordenar el reintegro de la doctora **Delgado Castañeda**, pero si ordenará a la Fiscal General de la Nación que, en el evento de existir vacantes en un cargo igual o equivalente al que ocupaba la accionante, ésta deberá ser nuevamente vinculada en provisionalidad hasta que la plaza correspondiente sea provista en propiedad mediante el sistema de carrera o su desvinculación cumpla los requisitos exigidos en la jurisprudencia constitucional, contenida, entre otras, en la sentencia **SU-917 de 2010**.

Por tanto, se confirmará el fallo de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil del 24 de junio de 2010, mediante la cual se decidió revocar en su integridad el fallo de primera instancia, pero por razones diversas a las expuestas por esa Corporación.

La misma solución debe prodigarse a todas las personas que fueron desvinculadas de la entidad y se encuentran en las situaciones descritas en el acápite **10.2** de esta providencia. Así mismo, esas especiales situaciones deben ser tenidas en cuenta por la entidad a la hora de proveer vacantes en la entidad.

12. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución

RESUELVE

PRIMERO.- En razón del *efecto inter comunis* de este fallo, **ENTIÉNDASE** como servidores de carrera de la Fiscalía General de la Nación y en virtud de las convocatorias que efectuó la entidad en el año 2007, sólo aquellas personas que fueron nombradas según el registro de elegibles contenido en el Acuerdo 007 de 2008 y actos complementarios, con observancia estricta de la regla referente al número de plazas por proveer, según cada una de las convocatorias.

SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, **ENTIÉNDASE** como servidores en provisionalidad, además de los que no concursaron y se mantienen en provisionalidad en la Fiscalía General de la Nación, todas

aquellas personas que fueron nombradas por hacer parte del registro de elegibles contenido en el Acuerdo 007 de 2008 y actos complementarios, pero sin sujeción a la regla del número de plazas a proveer, en los términos de cada una de las convocatorias. Estos servidores seguirán vinculados a la entidad hasta tanto sus cargos sean provistos en propiedad mediante el sistema de carrera o su desvinculación cumpla los requisitos exigidos en la jurisprudencia constitucional, contenidos, entre otras, en la sentencia **SU-917 de 2010**, es decir, que se requerirá resolución motivada para su desvinculación.

TERCERO.- ORDÉNASE a la Fiscalía General de la Nación **VINCULAR** en forma provisional, en el evento de existir vacantes en un cargo igual o equivalente al que ocupaban, a todos aquellos servidores que fueron retirados de la entidad con fundamento en el concurso convocado en el año 2007, siempre y cuando demuestren al momento de su desvinculación y al momento del posible nombramiento, una de estas tres condiciones: **i)** ser madres o padres cabeza de familia; **ii)** ser personas próximas a pensionarse, entiéndase a quienes para el 24 de noviembre de 2008 -fecha en que se expidió el Acuerdo 007 de 2008- les faltaren tres años o menos para cumplir los requisitos para obtener la respectiva pensión; y **iii)** estar en situación de discapacidad, como una medida de acción afirmativa, por ser todos ellos sujetos de especial protección.

La vinculación de estos servidores se prolongará hasta tanto los cargos que lleguen a ocupar sean provistos en propiedad mediante el sistema de carrera o su desvinculación cumpla los requisitos exigidos en la jurisprudencia constitucional, contenidos, entre otras, en la sentencia **SU-917 de 2010**.

CUARTO.- CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia de la Sala de Decisión de Tutela de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, proferida dentro del expediente **T-2.701.828**, **Demandante: Robinson González Pérez**, en la medida en que le asistía el derecho a ocupar un cargo en propiedad de Asistente de Fiscal IV.

QUINTO.- CONFIRMAR las sentencias de las Salas de Decisión de Tutela de la Sala Penal y de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, proferidas dentro de los expedientes **T-2.700.019**, **Demandante: Bolivia Renza Bacca**; **T-2.734.433**. **Demandante: Reinaldo de Jesús Gómez Muñetón** y **T-2.743.538**. **Demandante: Gloria Nelly Delgado Castañeda**. No obstante, se ordenará a la Fiscalía General de la Nación que, en el evento de existir vacantes en un cargo igual o equivalente al que ocupaban, estos accionantes sean nombrados en provisionalidad hasta tanto sus cargos se provean en propiedad mediante el sistema de carrera o su desvinculación cumpla los requisitos exigidos en la jurisprudencia constitucional, contenidos, entre otras, en la sentencia **SU-917 de 2010**.

SEXTO.- REVOCAR la sentencia proferida por la Sala de Decisión de Tutela de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dentro del expediente

T-2.701.827, Demandante: Luz Alieth Molina Raigosa, que tuteló sus derechos fundamentales, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En el evento en que esta demandante esté ocupando un cargo de carrera con desconocimiento de la regla del número de cargos a proveer, de conformidad con la convocatoria en la que concursó, continuará vinculada a la entidad pero con carácter provisional, hasta tanto el cargo que ocupe sea provisto en propiedad mediante el sistema de carrera o su desvinculación cumpla los requisitos exigidos en la jurisprudencia constitucional, contenidos, entre otras, en la sentencia **SU-917 de 2010**.

SÉPTIMO.- CONFIRMAR por las razones expuestas en esta providencia, las sentencias de las distintas Salas de Decisión de Tutelas de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, proferidas dentro de los expedientes **T-2.701.934, Demandante: Mauro de Jesús Ávila Tibatá; T-2.643.464, Demandante: Nelson Triana Cárdenas; T-2.648.563, Demandante: Joaquín González Bohórquez; T-2.699.927 Demandante: Cielo del Pilar Bonilla Arias; T-2.656.968, Demandantes: Luisa Gineth Pinto Ochoa y Gloria Mariño Quiñónez; T-2.699.804, Demandante: Beatriz Alicia Idarraga Piedrahita y T-2.667.567 Demandante: Ronit Janet Caldas Rueda**, que denegaron la protección de sus derechos de acceso a un cargo público, debido proceso e igualdad.

No obstante, si estos accionantes fueron nombrados en la entidad por hacer parte del registro de elegibles contenido en el Acuerdo 07 de 2008 y actos complementarios, pero sin sujeción a la regla del número de plazas a proveer, en los términos de cada una de las convocatorias, seguirán vinculados a la entidad hasta tanto sus cargos sean provistos en propiedad mediante el sistema de carrera o su desvinculación cumpla los requisitos exigidos en la jurisprudencia constitucional, contenidos, entre otras, en la sentencia **SU-917 de 2010**.

OCTAVO.- CONFIRMAR el fallo proferido dentro del expediente **T-2.707.718**, por la Sala de Decisión de Tutela de la Sala de Casación Penal, que amparó los derechos al debido proceso y a la igualdad en el acceso a cargos públicos del señor **Tomás Florentino Serrano Serrano**, en relación con la actualización del registro de elegibles.

NOVENO.- ORDENAR a la Fiscal General de la Nación que, en el término máximo de seis (6) meses contados a partir de la notificación de este fallo, inicie los trámites para convocar el concurso o concursos públicos necesarios para proveer **todos y cada uno de** los cargos de carrera que en la actualidad son ejercidos en provisionalidad y los que se encuentren vacantes, incluidos los cargos permanentes y transitorios creados por la Ley 975 de 2005 y el Decreto 122 de 2008. En dicho concurso o concursos, la Comisión de Carrera de la Fiscalía General de la Nación, al definir los factores de calificación, tendrá en cuenta la experiencia en el tipo de funciones a desempeñar.

En todo caso, en un término máximo de dos (2) años contados a partir de la notificación de esta sentencia, la Fiscalía General de la Nación deberá haber culminado dichos concursos y provisto los respectivos cargos.

DÉCIMO.- La Sala Plena de la Corte Constitucional hará un seguimiento estricto del cumplimiento de las órdenes contenidas en la presente providencia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.

JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Presidente

MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrado
Ausente en comisión

MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Magistrado

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
Con salvamento de voto

JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
Con salvamento de voto

NILSON ELIAS PINILLA PINILLA
Magistrado

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado

HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
Con salvamento parcial de voto

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Con aclaración de voto

MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General

**SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
A LA SENTENCIA SU-446/11**

Expediente T-2.643.464 (Acumulados)

Acción de tutela instaurada por Nelson Triana Cárdenas y otros contra la Comisión Nacional de la Carrera de la Fiscalía General de la Nación.

Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

Con el debido respeto, me permito presentar las razones que me llevaron a salvar el voto en el asunto de la referencia.

1. Le correspondió a la Sala Plena en este caso, revisar un número considerable de acciones de tutela, que fueron oportunamente acumuladas para ser resueltas en una misma sentencia, promovidas por particulares y personal al servicio de la Fiscalía General de la Nación, que participaron en las convocatorias abiertas por la citada entidad en el año 2007, para proveer los cargos de Fiscal y Asistente de Fiscal que en los distintos niveles se encontraban vacantes o provistos en provisionalidad.

2. De manera general, las solicitudes de amparo le atribuían a la Comisión Nacional de la Carrera de la Fiscalía General de la Nación, una presunta violación de los derechos a la igualdad, al debido proceso y al acceso a cargos públicos conforme al principio del mérito, derivada de la interpretación dada a las reglas del concurso, en el sentido de negarse a hacer uso del registro de elegibles para efectuar nombramientos en cargos de carrera que no fueron expresamente convocados, pero que eran de la misma naturaleza y perfil de las plazas a que se refería el respectivo registro.

La posición adoptada por dicha entidad, y que a juicio de los actores resultaba violatoria de sus derechos, encontraba sustento en la tesis esbozada por el Consejo de Estado, según la cual, la convocatoria es la regla del concurso y es inmodificable, lo que conlleva que los cargos que no hayan salido a concurso no pueden ser provistos con el registro de elegibles vigente, debiéndose para el efecto llevar a cabo un nuevo concurso público. La citada postura, a su vez, resultaba contraria a la asumida por la Corte Suprema de Justicia, quien, al resolver en segunda instancia algunas de las acciones de tutela que hacían parte del paquete objeto de revisión, dejó sentado el criterio sobre la forma como tenía que procederse una vez los cargos convocados hubieren sido provistos, en el sentido de señalar que el registro de elegibles debía ser

utilizado no solo para llenar las plazas convocadas, sino también aquellas que con posterioridad al concurso hubieran quedado vacantes o en provisionalidad, y que tuvieran la misma naturaleza de los cargos para los cuales se había abierto el concurso.

3. Así planteado el debate, en sede de Revisión, le correspondió a la Corte establecer el verdadero alcance del registro de elegibles, en particular el proferido por la Fiscalía General de la Nación para las distintas convocatorias del año 2007, a partir de los postulados constitucionales que regulan la materia.

4. La sentencia de la que me aparto, aun cuando le reconoce al sistema de carrera el carácter de pilar fundamental del Estado Social de Derecho, llegó a la conclusión, equivocada a mi juicio, de que las pautas o reglas de los concursos públicos para el acceso a la carrera son inmodificables y, por tanto, que a la administración no le es dado hacer ninguna variación de ellas porque se lesionan los derechos y principios constitucionales. En ese contexto, consideró que la Fiscalía General de la Nación solo podía utilizar el registro de elegibles que expidió mediante el acuerdo 07 de 2008, para proveer únicamente el número de cargos ofertados en cada una de las convocatorias del año 2007, toda vez que esa era una de las reglas del concurso.

5. En contraposición a lo resuelto por la mayoría de los miembros de la Sala, soy de la opinión que la posición que se ajusta a la jurisprudencia constitucional, a las disposiciones constitucionales sobre la materia, y a las normas legales que regulan el régimen de carrera de la Fiscalía General de la Nación, es aquella según la cual el registro o lista de elegibles, mientras esté vigente, debe utilizarse para proveer todos los cargos que se encuentren vacantes o en provisionalidad, y que sean de la misma categoría a los que fueron objeto del concurso público de méritos.

6. El artículo 125 Superior consagra, como regla general, que los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, y que el acceso a la carrera debe estar basado en los méritos y calidades de los aspirantes. La misma norma se refiere al concurso público como un mecanismo idóneo para establecer el mérito y así impedir que criterios diferentes a él puedan constituirse en factores determinantes del ingreso y permanencia en la carrera administrativa.

Con respecto a dicho mandato, esta Corporación ha dejado sentado que la carrera y el sistema de concurso público de méritos, constituyen instrumentos técnicos de administración de personal y mecanismos de promoción de los principios de igualdad e imparcialidad, en cuanto buscan garantizar que a la función pública accedan los mejores y los más capaces funcionarios o servidores estatales.

7. En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que, dentro de la estructura institucional del Estado, la carrera administrativa es un *“principio constitucional y, por lo mismo, una garantía cuyo incumplimiento puede acarrear la sustitución de la Constitución”*, pues la misma tiene relación directa con distintos contenidos constitucionales que se despliegan en tres órdenes: (i) los relativos al cumplimiento de los fines del Estado, (ii) a la vigencia de algunos derechos fundamentales -como el acceso a cargos públicos y el debido proceso-, y (iii) al respeto del principio de igualdad.

8. Así entendida, la regla general de la carrera, como mecanismo preferente de acceso al servicio público, tiene un claro significado constitucional, cual es el de que todos aquellos cargos que hayan sido definidos previamente como de carrera, deben ser provistos con quienes han superado el concurso público de méritos, de acuerdo con su ubicación en la respectiva lista o registro de elegibles, comenzando por quien obtuvo el primer lugar, pues tal es el proceder que se deriva del mandato consagrado en el artículo 125 Superior.

9. Sobre esa base, este Tribunal también viene afirmando que quienes participaron en un concurso público de méritos, lo aprobaron y hacen parte de una lista de elegibles, mientras ésta se encuentre vigente, son titulares de un derecho subjetivo: el de ser nombrados en los cargos para los que concursaron, cuando exista una vacante o aquellos se encuentren provistos en provisionalidad.

10. Desde ese punto de vista, el registro o lista de elegibles, entendido como el acto administrativo que contiene las personas que aprobaron el concurso y que debe ser nombradas en los cargos de carrera, cumple un doble propósito: **(i)** proveer las vacantes para las cuales se convocó el respectivo concurso, y, además, **(ii)** proveer las demás vacantes que se produzcan durante su vigencia, siempre que se trate de los mismos cargos que fueron objeto del concurso.

11. A la luz de los criterios expuestos, sobre la base de que la Constitución privilegia el acceso al servicio público mediante el sistema de carrera, la interpretación conforme a la Constitución, es que el registro de elegibles, mientras esté vigente, debe ser utilizado para proveer los cargos que fueron convocados a concurso, y también, para proveer los cargos que no lo fueron pero que tienen la misma categoría de los primeros, y que se encuentran vacantes o provistos en provisionalidad.

12. Dicha interpretación, respeta la filosofía que inspira la incorporación constitucional de acceso al servicio público por el sistema carrera, por las siguientes razones: **(i)** inicialmente, por cuanto se están nombrando a personas que han superado un concurso de mérito, diseñado de acuerdo a las necesidades del servicio y, especialmente, para cargos de igual naturaleza y categoría, es decir, no se trata de un mecanismo de ingreso automático a la función pública, arbitrario e inconsulto; **(ii)** además, el nombramiento de

personal incluidos en la lista de elegibles, apunta a hacer más eficiente el uso del talento humano, en cuanto se acude a personal capacitado y previamente evaluado sobre las condiciones necesarias para el ejercicio de los cargos por proveer; **(iii)** también permite un uso racional de los recursos públicos, ya que se evita tener que convocar nuevos concursos a muy corto plazo, tantos como vacantes se vayan presentando, con los altos costos que ello demanda para el erario público; **(iv)** de igual manera, se asegura que a la función pública accedan los mejores y los más capaces funcionarios, descartándose la inclusión de otros factores de valoración que repugnan con la esencia misma del Estado Social de Derecho, y con la filosofía que inspira el sistema de carrera, tales como el clientelismo, el favoritismo y el nepotismo, pues, mientras se surten los nuevos concursos, los cargos de carrera a proveer quedarían sujetos a la sola voluntad del nominador y lo serían a través de la figura de la provisionalidad; **(v)** asimismo, se garantiza el ejercicio del derecho subjetivo de que son titulares quienes hacen parte de la lista de elegibles, en cuanto permite que éstos accedan a un cargo igual para el que concursaron y demostraron su idoneidad; y, finalmente, **(vi)** se permite el desarrollo de los principios que gobiernan la función pública, en particular, los que propugnan por su eficiencia, celeridad y economía, por cuanto no se obliga a la administración a efectuar concursos cada vez que se presenten vacantes, haciéndose uso del registro de elegibles que se encuentre vigente, el cual existe para llevar a cabo la provisión de cargos en forma rápida y eficaz, conforme con las reglas del mérito.

13. La posición que avala el uso de la lista de elegibles para proveer cargos de carrera -vacantes o en provisionalidad-, iguales a los que fueron objeto de la convocatoria, además de coincidir con el criterio esbozado por la Corte Suprema de Justicia en materia de tutela, recoge fielmente el precedente constitucional fijado por la propia Corte Constitucional en la Sentencia C-319 de 2010, en la que la Corporación llevó a cabo el estudio de constitucionalidad del artículo 145 de la Ley 201 de 1995, que regula uno de los pasos esenciales del proceso de ingreso a la carrera administrativa de la Defensoría del Pueblo, cual es la conformación de la lista de elegibles. En dicho pronunciamiento, la Corte sentó como regla, que cuando se trate de proveer cargos de grado y denominación igual a los que fueron objeto de concurso público de méritos, el uso de la lista de elegibles es un **deber** y no una facultad del nominador. Al respecto, dijo la Corte en el mencionado fallo:

“Así las cosas, la Corte considera necesario condicionar en primer lugar la exequibilidad de la norma en el sentido de que cuando se trate de proveer una vacante de grado igual, correspondiente a la misma denominación, el empleo de la lista de elegibles es un deber y no una facultad del nominador”.

“...”

“El nominador no cuenta con una facultad sino con un deber al momento de recurrir a la lista de elegibles, a efectos de proveer un cargo de grado y denominación iguales para el cual se abrió

originalmente el concurso de méritos. Lo anterior, bien entendido, durante el tiempo de vigencia de la lista de elegibles...”

14. Ahora bien, las normas que regulan el régimen de acceso, permanencia y retiro de los empleados al servicio de la Fiscalía General de la Nación, se aviene también al criterio que permite utilizar el registro de elegibles para proveer cargos de carrera que no fueron ofertados al momento de la convocatoria al concurso, pero que son iguales a los que fueron convocados originalmente, y que se encuentran vacantes o provistos en provisionalidad. Al respecto, el artículo 66 de la Ley 938 de 2004, *“Por la cual se expide el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación”*, consagra expresamente que el Registro de Elegibles debe utilizarse para la provisión de los cargos a proveer y también para proveer las vacantes que se presenten durante su vigencia. Dice la norma:

“Artículo 66. Registro de elegibles. Con base en los resultados del concurso se conformará el Registro de elegibles para a provisión de los cargos a proveer y las vacantes que se presenten durante su vigencia, la cual será de dos (2) años”.

15. En plena concordancia con la norma citada, el Acuerdo 0001 del 30 de junio de 2006, *“Por el cual se expide el reglamento del proceso de selección y el concurso de méritos”* de la Fiscalía General de la Nación, en sus artículos 22 y 23, dejan en claro que el registro de elegibles, mientras este vigente, debe utilizarse para llenar los cargos de carrera vacantes en dicha entidad. Sobre el particular, disponen tales mandatos:

Artículo 22. Registro de Elegibles. Con base en los resultados del concurso de méritos se conformará el Registro de Elegibles para la provisión de los cargos y las vacantes que se presenten durante su vigencia, en estricto orden descendente del puntaje.

“ ... ”

Artículo 23. Elaboración del Registro de Elegibles y Nombramientos. Corresponde a la Oficina de Personal, previa instrucción de la Comisión Nacional de Administración de la Carrera, elaborar y actualizar el Registro de Elegibles. El Registro estará conformado por los candidatos que hayan aprobado el concurso de méritos y que no hayan sido nombrados”.

“ ... ”

“El registro de elegibles deberá utilizarse para la provisión de los cargos vacantes en la entidad”

16. Así las cosas, la premisa de la cual parte la decisión mayoritaria no es entonces acertada, toda vez que las convocatorias hechas por la Comisión Nacional de la Carrera de la Fiscalía General de la Nación no constituían propiamente la ley del concurso de méritos, ya que tales convocatorias debían sujetarse a la Ley 938 de 2004 y al Acuerdo 001 del 30 de julio de 2006. De

acuerdo con lo prescrito por esta normatividad, todas las personas que se encontraban registradas en la correspondiente lista de elegibles, por haber superado el puntaje mínimo establecido para este concurso, tenían el derecho a ser nombrados en los cargos de carrera de la Fiscalía General de la Nación, en consonancia con el mandato del artículo 125 de la Constitución Política.

17. En esos términos, no cabe duda que la interpretación mayoritaria, que lleva a sostener que el registro de elegibles debe ser utilizado únicamente *“para llenar exclusivamente las vacantes señaladas en la respectiva convocatoria”*, contradice abiertamente el régimen constitucional de la carrera como mecanismo de acceso al servicio público, y desconoce abiertamente los principios que gobiernan la función pública, pues permite que, a pesar de existir personal capacitado, que ha sido seleccionado por méritos para ocupar los cargos que se encuentran vacantes, éstos deban ser ocupados por vía de la selección automática -en provisionalidad- mientras se surte un nuevo concurso.

17. Tal proceder, antes que desarrollar el mandato de la carrera previsto expresamente en el artículo 125 de la Carta, lo contradice, pues, como se dijo, tiende a promover la selección del personal al servicio del Estado por vías distinta a la del concurso de méritos, facilitando que en la escogencia de los servidores estatales incidan factores de valoración que han sido proscritos por la propia Constitución y que resultan contrarios al Estado Social de Derecho, tales como el clientelismo, el favoritismo y el nepotismo, los cuales, a su vez, no permiten garantizar la eficacia y la eficiencia en el servicio público.

18. Si la posición que prevaleció se sustenta en el criterio acogido por el Consejo de Estado, que afirma que las reglas del concurso son invariables y, por tanto, que el registro de elegibles debe ser utilizado únicamente *“para llenar exclusivamente las vacantes señaladas en la respectiva convocatoria”*, tal criterio resulta ser equivocado, pues, como ha quedado visto, las normas de mayor jerarquía que gobiernan el concurso de méritos de la Fiscalía, prevén expresamente lo contrario, es decir, que el registro de elegibles, mientras esté vigente, debe ser utilizado para proveer cargos de carrera que no fueron ofertados al momento de la convocatoria al concurso, pero que son iguales a los que fueron convocados originalmente, y que se encuentran vacantes o que fueron provistos en provisionalidad.

19. En efecto, las normas del concurso de la Fiscalía General de la Nación constituyen un acto complejo, en el sentido que de ellas hacen parte, tanto las respectivas convocatorias, como las normas que le sirven de sustento a éstas, es decir, la Ley 938 de 2004 y el Acuerdo 001 de 2006. Con lo cual, acoger la interpretación que limita la lista de elegibles a las vacantes señaladas en la convocatoria, no está respetando las reglas del concurso, pues éstas imponen que el registro de elegibles sea usado para llenar las vacantes que no fueron convocadas, pero que corresponden a cargos iguales de los que sí lo fueron.

En los términos descritos, dejo entonces sentada mi posición contra-
mayoritaria.

Fecha ut supra,

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado

**SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
A LA SENTENCIA SU446/11**

Referencia: expedientes acumulados
T-2.643.464 y otros

Acción de tutela instaurada por Nelson Triana Cárdenas y otros en contra de la Comisión Nacional de la Carrera de la Fiscalía General de la Nación.

Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

Con el respeto acostumbrado con las decisiones que toma esta Corporación, me permito disentir del fallo adoptado por la Sala Plena dentro de los expedientes de la referencia. Las breves razones que apoyan mi postura son las siguientes:

La tesis que se aparta de la posición mayoritaria se resume en lo siguiente: en virtud del mérito, la lista de elegibles vigente debe ser utilizada para proveer la totalidad de los cargos vacantes o que se encuentran ocupados en provisionalidad en cualquier dependencia de la Fiscalía General de la Nación, inclusive sobre aquellos que sean creados durante el trámite del concurso. Cualquier excepción a esta regla debe estar prevista claramente en la Carta, so pena de desnaturalizar la figura e incurrir y favorecer las mismas prácticas de clientela que se multiplicaron años atrás, que subsisten hoy en día y que desnaturalizan los fundamentos de la administración pública.

Esta proposición, que hasta ahora venía siendo defendida por la Corte de manera pacífica, aplicada a los casos clasificados dentro del primer grupo de expedientes, habría llevado a conceder los derechos fundamentales invocados y a ordenar que las plazas vacantes o que se encuentran ocupadas en provisionalidad sean proveídas en su totalidad por quienes cumplieron los requisitos establecidos en el concurso.

Para sustentar tal argumento, me permitiré abordar los siguientes puntos teóricos: primero, mostraré que la sentencia SU-446 de 2011 desconoce la Constitución y el precedente que había fijado esta Corporación en varias providencias y especialmente en la sentencia C-319 de 2010, sin que aquella presente planteamientos suficientes para cambiar la jurisprudencia. En segundo lugar, advertiré que el concurso de la Fiscalía contaba con las herramientas jurídicas suficientes para extender la lista de elegibles a los diferentes cargos que se fueron creando con posterioridad a la convocatoria; y,

por último, expondré que los efectos del fallo son contrarios de manera frontal a la Carta Política.

1. Curiosamente la sentencia de unificación concluyó que no es posible extender la utilidad de las listas de elegibles para ocupar la gran mayoría de cargos en esa entidad, a partir de la cita de varias sentencias de esta Corporación. Aunque reconoció que la base constitucional para la provisión de los empleos estatales es el mérito y que este a su vez es compatible con los fines esenciales del Estado, así como con los derechos a la igualdad, al debido proceso y a la provisión de cargos públicos, terminó por concluir, dando un alcance supra constitucional a la intangibilidad de las normas de la convocatoria, que los resultados del concurso sólo aplican estrictamente a las vacantes expresamente ofertadas por el término de dos años.

Tal postura tiene como único sustento la naturaleza de las reglas adscritas al concurso. La Sala olvidó precisar cuidadosamente cuál es la utilidad de esas normas y cuál sería la real afectación de sus fundamentos constitucionales, es decir, en qué medida se desconocería la buena fe, la confianza legítima de los concursantes, así como la transparencia, la publicidad y la imparcialidad, frente a la extensión de la lista de elegibles respecto del número de cargos a proveer.

De dichos valores sólo se cita un apartado de la sentencia C-1040 de 2007 (num. 3.4.), en la que se hace un análisis de las modificaciones que implican restricciones a los derechos de los concursantes. Ese escenario no se presenta en este asunto ya que, por el contrario, la extensión de los cargos ofertados maximiza los derechos y expectativas de los participantes que logran cumplir las exigencias mínimas de este y ejecuta a cabalidad el mandato previsto en el artículo 125 de la Carta. ¿Acaso, qué accionante vería disminuido su derecho en caso de ampliar el número de cargos a proveer? Ninguno. Por el contrario, la postura consignada en la sentencia SU-446 de 2011 sólo favorece a algunas de las personas que se encontraban vinculadas en condición de provisionalidad y a las vicisitudes planteadas por las entidades para no implementar el mérito como la regla general del servicio público-estatal.

Por otra parte, la providencia de la que me aparto también se refiere a un párrafo de la sentencia SU-913 de 2009, en la que se indica con claridad que la intangibilidad del registro permanece, salvo que éste implique el desconocimiento de la Constitución o de la ley. En contraste, la sentencia SU-446 de 2011 fijó un límite sin sustento al mérito de la carrera administrativa al fraccionar la provisión de los cargos de una entidad en aquellos eventos en los que inconstitucionalmente una institución sólo oferte algunos de sus empleos de manera parcial, cree unos nuevos o incluya cualquier regla que restrinja el alcance del concurso. El resultado: la preferencia de la forma de la convocatoria sobre su objetivo, termina cohonestando que las entidades estatales mantengan una gran cantidad de empleos en provisionalidad y de contratistas, promoviendo que el acceso de la

administración pública se efectúe a través de las prácticas propias de las redes de clientela. Muy a pesar de que la vigencia de la Constitución está próxima a cumplir una veintena de años, en esta oportunidad la Corte perdió la oportunidad de declarar el incumplimiento reiterado y sistemático de su mandato, escenario que –incluso– podría configurar un estado de cosas inconstitucional.

Adicionalmente, la sentencia de unificación negó que la sentencia C-319 de 2010 constituyera un precedente a este caso, debido a que en aquella se estudió una “norma especial” creada por el legislador únicamente para la Defensoría del Pueblo. En contraste, considero que la ausencia de una norma igual a la que se estudió en la sentencia de constitucionalidad, no impedía que la Corte confrontara los fundamentos de tal fallo y en especial la regla jurisprudencial derivada de este y que, en razón a la Carta Política, **obliga** a proveer todos los cargos con el mismo grado y denominación, aunque no hayan sido incluidos en la convocatoria.

Recuérdese que en tal providencia no se restringió el objeto de análisis al régimen de carrera de la Defensoría del Pueblo. Allí se valoró si es facultativo del nominador extender la utilidad de la lista de elegibles para los cargos con la misma denominación y grado. La respuesta tajante a la que se llegó fue la siguiente:

“Así las cosas, según esta primera interpretación de la norma acusada se tiene que se trata de una facultad, que no de un deber, con que cuenta el Defensor del Pueblo para emplear una lista de elegibles, debidamente conformada, a efectos de nombrar en propiedad a una persona que superó un concurso de méritos, si bien no en el cargo para el cual inicialmente se inscribió y superó todas las etapas del concurso público, en un cargo que termina siendo de igual o inferior categoría, aunque con la misma denominación.

Por el contrario, una interpretación conforme con la Constitución, la cual será acogida por la Corte, apunta a señalar que se trata realmente de un deber y no de una facultad, por cuanto la única forma de ingresar a la carrera administrativa, es decir, a ocupar un cargo público en propiedad, es mediante la superación de un concurso público de méritos. En otras palabras, un nominador no puede contar con la facultad de decidir si hace nombramientos en propiedad en relación con personas que han superado un concurso de méritos.”

De manera restrictiva y peligrosa, la SU-446 de 2011 argumentó que constituye una potestad del legislador y, peor aún, de la entidad convocante la decisión de extender la lista de elegibles a cargos diferentes a los que fueron ofertados. Obviamente, una tesis así sólo puede ser sustentando a partir de la minimización de los derechos fundamentales y los valores adscritos a la puesta en marcha de la carrera administrativa; los mismos que fueron

ponderados en la sentencia C-588 de 2009 en donde, paradójicamente, se rechazó la facultad del Congreso para efectuar una inscripción automática en la carrera administrativa; de este fallo basta con citar los siguientes párrafos:

“Cabe apuntar que la competencia para excepcionar, mediante ley, la carrera administrativa ha sido objeto de una amplia jurisprudencia en la cual, reiteradamente, la Corte ha reivindicado el carácter de regla general que le corresponde a la carrera y llamado la atención acerca de la necesaria limitación del legislador al fijar los cargos exceptuados, para evitar que el ordenamiento constitucional resulte alterado por una multiplicación de las excepciones que reduzca a extremos marginales el ámbito de la carrera administrativa, pues esta, en cuanto regla general, está llamada a predominar cuando se trate de la provisión de los empleos estatales, de la permanencia en el cargo, de los ascensos y del retiro.

(...)

Así las cosas, cuando se excluya del régimen de carrera administrativa un cargo y falte un principio de razón suficiente que justifique la exclusión, “prima la regla general, establecida por la Constitución, esto es, la carrera administrativa”⁷⁰, pues la Constitución de 1991 “estableció un régimen que reforzó las garantías en favor de la prioridad de la Carrera Administrativa, que opera como principio especial del ordenamiento jurídico, y que antecede y prevalece ante el régimen de libre nombramiento y remoción de los funcionarios públicos”⁷¹.

Aunque en la sentencia SU-446 de 2011 no se efectúa una inscripción automática a la carrera administrativa, sí se afecta gravemente la implementación de esta, en la medida en que autoriza el fraccionamiento paulatino, crónico y –por qué no- permanente de los concursos, al permitir que sólo se oferten algunos empleos y al fijar un límite a la utilidad sustantiva de la lista de elegibles. Esto, tal y como se advirtió en la sentencia C-319 de 2010, también constituye una afrenta al principio de economía previsto en el artículo 209 constitucional, en la medida en que somete a la administración a la posibilidad de convocar a costosos procesos de selección sobre cargos que se encuentran disponibles en el registro de elegibles.

2. Con todo, el suscrito Magistrado considera que el régimen legal de carrera aplicable a la Fiscalía General de la Nación sí posee normas que bajo una interpretación conforme a la Constitución, llevarían a una sola conclusión: la lista de elegibles vigente puede aplicarse a aquellos cargos que no hayan sido inicialmente convocados. No otra inferencia puede obtenerse de los artículos 47 y 52 de la Ley 938 de 2004, a saber:

⁷⁰ Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-334 de 1996.

⁷¹ Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-405 de 1995.

“ARTÍCULO 47. PRINCIPIO DE EXCELENCIA. El principio de excelencia tiene por objeto garantizar la calidad y el mejoramiento continuo del trabajo y de los servidores de la Fiscalía General de la Nación.

En virtud del principio de excelencia, los servidores que se rigen por el presente régimen, deberán ser seleccionados, los concursos aprobados y su trabajo desempeñado, con excelencia de méritos, procurando otorgar el ingreso al mejor candidato o servidor.”

“ARTÍCULO 52. PRINCIPIO DEL MÉRITO. El principio del mérito tiene vocación constitucional, que surge del interés general y público en proveer los cargos de carrera con un sistema de méritos que garantice el ingreso y la permanencia de quienes reúnan las mejores condiciones académicas, profesionales, laborales y personales para ocupar los cargos públicos.

En ese sentido, el mérito es el presupuesto y principio básico para evaluar y calificar la calidad, la excelencia y las condiciones de los aspirantes y servidores que pretendan ingresar y permanecer dentro del régimen de carrera de la Fiscalía General de la Nación.

El mérito así establecido en el presente estatuto, asegura y procura la excelencia y calidad del servicio en el ejercicio de la función pública.”

La entidad del mérito adoptada en la sentencia de unificación, dista radicalmente de la definición consignada por la Ley 938 de 2004. ¿Acaso el criterio adoptado en este fallo garantiza que los cargos de la Fiscalía General de la Nación serán ocupados por los mejores?

3. Finalmente, juzgo necesario señalar que los resultados de la decisión adoptada en la sentencia de unificación vulneran el principio de igualdad previsto en la Constitución (art. 13) y en la Ley 938 de 2004. Este último dispone lo siguiente:

“ARTÍCULO 48. PRINCIPIO DE IGUALDAD. El principio de igualdad tiene por objeto garantizar el ingreso y permanencia en la carrera de los servidores de la Fiscalía General de la Nación en igualdad de condiciones.”

Los casos del segundo grupo denuncian –a grandes rasgos- que el fraccionamiento de la provisión de cargos en carrera desconoce sus condiciones particulares porque, siendo empleados en provisionalidad y en razón del concurso de méritos, fueron retirados de la entidad mientras que otros compañeros, con circunstancias similares, siguieron vinculados. Algunas acciones plantean que dicho trato constituye una discriminación, ya que no tiene en cuenta que se trata de sujetos de especial protección constitucional.

La respuesta que la Corte Constitucional da a tales acciones en la sentencia de unificación es insatisfactoria. De haber protegido el mérito como principal factor definitorio de ingreso a la Fiscalía General de la Nación, se habría dado una solución provechosa a tales demandas, declarando que todos los cargos en provisionalidad deben ser ocupados por las personas que aprobaron el concurso en estricto orden y, solo en caso de persistir las vacantes, darle prevalencia a quienes tuvieran una especial protección en la Carta.

Por último, hay que aclarar que el presente fallo solo aplica de manera estricta al régimen de carrera aplicable a la Fiscalía General de la Nación. Para las demás entidades, tal y como pienso que lo entendió la mayoría, se mantienen incólumes los alcances del mérito, la utilidad de la lista de elegibles y los derechos de los participantes.

Fecha ut supra,

JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado

**SALVAMENTO DE VOTO PARCIAL DEL MAGISTRADO
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
A LA SENTENCIA SU-446/11**

1.- Con el acostumbrado respeto por la postura mayoritaria de la Sala Plena, el suscrito Magistrado procede a sustentar el presente salvamento de voto parcial respecto de la sentencia SU-446 de 2011.

2.- La sentencia en mención estudió varios fallos de tutela originados en demandas ciudadanas para aplicar el Acuerdo 007 de 2008 expedido por la Fiscalía General de la Nación, que contiene la lista de elegibles resultante del concurso de méritos celebrado por dicha entidad para proveer algunos cargos. La controversia se suscitó a propósito del alcance y carácter vinculante de aquellos puestos de la lista de elegibles que excedían el número de plazas que se sacaron a concurso. Esto es, el problema genérico del que se desprende el debate jurídico en cada uno de los casos, pretende responder al siguiente cuestionamiento: ¿resulta vinculante la lista de elegibles en aquellos puestos cuya ubicación se encuentra en un lugar numérico que excede el número de plazas que se sacaron a concurso?

Así, sobre lo anterior la mayoría resolvió, (i) que las personas nombradas en el estricto orden de la lista y dentro del rango de cargos sacados al concurso, tenían derecho a ser nombradas en caso de que esto no hubiera ocurrido, o a mantenerse en el cargo en propiedad, si en virtud de la lista ya se habían incorporado a la planta de personal; (ii) que las personas nombradas de acuerdo a la lista en mención, pero que ocuparon un lugar numérico en la misma que excedió el número de plazas sacadas a concurso, podían mantenerse en provisionalidad en dichos cargos hasta la realización de un nuevo concurso; y (iii) que las personas que ocupaban, tanto aquellos cargos sacados a concurso como los que no, y que fueron excluidas de la planta de personal por personas de la lista; debían tener prioridad en nombramientos futuros, siempre que por su condición, estuviera incluidas en alguna de las categorías del reten social (madres y padres cabeza de familia, discapacitados y los llamados *prepensionados*).

Con base en las anteriores reglas genéricas, la Mayoría de la Sala resolvió los casos concretos estudiados y dio las órdenes respectivas. Tanto con los criterios normativos esbozados como con las órdenes derivadas de ellos, estoy de acuerdo.

3.- Ahora bien, además de lo anterior, el numeral noveno de la parte resolutive de la presente providencia, ordenó además a la Fiscalía General de la Nación iniciar los trámites de un nuevo concurso para proveer la totalidad de las plazas de la entidad, con lo que también estoy de acuerdo. Sin embargo agregé en la mencionada orden lo siguiente: “*En dicho concurso o concursos, la*

Comisión de carrera de la Fiscalía General de la Nación, al definir los factores de calificación, tendrá en cuenta la experiencia en el tipo de funciones a desempeñar". Así pues, no comparto el complemento de la orden de proveer la totalidad de los cargos por concurso, dirigido a considerar como factor de evaluación la experiencia del concursante en las funciones del cargo al que aspira; y a continuación expresaré las razones de dicho desacuerdo.

3.- Considero que la orden de la que disiento implica en la práctica favorecer en desarrollo de los concursos, a las personas que ocupan la plaza que se saca a concurso. Esto, en tanto el criterio consistente en incluir como factor de calificación la experiencia en las funciones no es cosa distinta que otorgar puntos por desempeñar labores propias del cargo, en el mismo cargo que se pretende proveer mediante la celebración del concurso. Y, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que esta situación significa que los demás aspirantes al cargo nunca tendrán la oportunidad de acceder a dichos puntos, por cuanto sólo quien ocupa el cargo en provisionalidad podría cumplir con la condición para ello.

Lo anterior es contrario al diseño constitucional de los concursos de méritos, pues –insisto– favorece a uno de los concursantes, aquel que ocupa el cargo en provisionalidad.

4.- En efecto, acerca de la provisión de cargos de la carrera administrativa con fundamento en el concurso de méritos, establecida en el inciso tercero del artículo 125 constitucional, ha establecido esta Corporación que el punto de partida es tanto la noción como los fines⁷² que enmarcan a la carrera administrativa en Colombia. De esto modo, se ha definido que “...la carrera y el sistema de concurso de méritos constituyen (...) un sistema técnico de administración de personal y un mecanismo de promoción de los principios de igualdad e imparcialidad, en cuanto garantizan que a la organización estatal, y concretamente a la función pública, accedan los mejores y los más capaces funcionarios, <descartándose de manera definitiva la inclusión de otros factores de valoración que repugnan a la esencia misma del Estado social de derecho, tales como el clientelismo, el favoritismo y el nepotismo>⁷³ que, por lo demás, se identifican en el área de la sociología política, el derecho público y la ciencia administrativa, como criterios de selección de personal que se contraponen a los nuevos roles del Estado contemporáneo y que afectan en gran medida su proceso de modernización y racionalización, el cual resulta consustancial a la consecución y cumplimiento de los deberes públicos.”⁷⁴

De este modo la jurisprudencia ha evolucionado al punto de afirmar que: (i) no hay lugar a distinguir entre modalidades de concursos para el acceso o ingreso

⁷² Ver entre otras, sentencias C-733 de 2005, C- 1177 de 2001; C- 517 de 2002; C- 1079 de 2002; C- 969 de 2003 y C- 077 de 2004.

⁷³ [Cita del aparte transcrito] Sentencia C-563/2000, M.P. Fabio Morón Díaz.

⁷⁴ Sentencia C- 1079 de 2002 (FJ # 3.3)

a la carrera y modalidades de concursos para ascenso, pues el artículo 125 constitucional no establece dicha distinción; (ii) el fundamento sustancial para la provisión de cargos de carrera (ingreso o ascenso) es el mérito, que prohíbe incluir dentro de los parámetros de selección de personal criterios diferentes a aquellos que pretendan medir objetivamente el mencionado mérito de los aspirantes; y (iii) **el reconocimiento de factores que sólo sean aplicables a unos concursantes y a otros no, como criterio de selección en los concursos, resulta desproporcionado incluso frente al derecho al reconocimiento e incentivo laboral a que tienen todos los trabajadores.**

5.- En este orden, el fundamento sustancial que ampara la realización de los concursos es garantizar la provisión de cargos de carrera con base en el mérito, lo que significa para esta Corporación, la obligación de velar por el establecimiento de normas que garanticen una evaluación objetiva del mérito de quienes concursan para quedar en el cargo. De este modo se ha limitado la libertad del legislador para regular los sistemas de concurso “...de modo que se garantice la adecuada prestación del servicio público, [por lo que] no pueden desconocer los derechos fundamentales de los aspirantes que se satisfacen mediante la participación igualitaria en los procedimientos legales de selección de los funcionarios del Estado. El derecho a la igualdad no significa que el aspirante que toma parte en un concurso adquiere sin más el derecho a ser designado en el cargo. La ley está facultada para señalar los requisitos y condiciones necesarios para ingresar a los cargos de carrera y para determinar los méritos y calidades de los aspirantes (CP art. 125). El principio de igualdad, sin embargo, se opone a que la ley al regular el mecanismo de ingreso a la función pública, establezca requisitos o condiciones incompatibles y extraños al mérito y a la capacidad de los aspirantes teniendo en cuenta el cargo a proveer, que serían barreras ilegítimas y discriminatorias que obstruirían el ejercicio igualitario de los derechos fundamentales. Para asegurar la igualdad, de otra parte, es indispensable que las convocatorias sean generales y que los méritos y requisitos que se tomen en consideración tengan suficiente fundamentación objetiva y reciban, junto a las diferentes pruebas que se practiquen, una valoración razonable y proporcional a su importancia intrínseca.”⁷⁵ [Énfasis fuera del texto]

Igualmente, de manera reiterada y consistente la Corte Constitucional ha reconocido en el mérito un criterio fundamental “...para determinar el acceso el ascenso y el retiro de la función pública.”⁷⁶ En la sentencia C-266 de 2002 se hizo mención a pronunciamientos de la Corte en dicho sentido, por ejemplo las sentencias “...relativas al ascenso en la carrera diplomática y consular”⁷⁷, a la inconstitucionalidad de la imposibilidad de participar en concursos de ascenso en la DIAN diferentes al correspondiente a la categoría

⁷⁵ C-371 de 2000, reiterada en la C-733 de 2005

⁷⁶ C-266 de 2002

⁷⁷ [Cita del aparte transcrito] Corte Constitucional, Sentencia C-292 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

*inmediatamente superior*⁷⁸, a las calidades requeridas para el cargo de notario⁷⁹ y a los méritos para la promoción en la carrera docente⁸⁰. Lo anterior porque cualquier tipo de trato privilegiado o preferencial a servidores públicos, así sean de carrera, es contrario a la calidad y al mérito como criterios para el ingreso, el ascenso y la permanencia en la función pública (art. 125 C.P.).”

6.- En mi opinión, la observancia del mérito como elemento fundamental que debe inspirar los concursos al cabo de los cuales se proveerán los cargos de carrera, trae como consecuencia la verificación - por parte del juez constitucional - de la disposición de condiciones de igualdad en la evaluación de los aspirantes que participan en un concurso para acceder a un cargo de la carrera. En este orden, como lo ha afirmado la misma jurisprudencia, quedaron proscritas aquellas formas de evaluación de los aspirantes en donde se establecen requisitos que aplican para unos aspirantes pero no para otros. Esto es consecuencia lógica entre otros, por ejemplo de la declaratoria de inconstitucionalidad de los concursos cerrados por excluir de la posibilidad de participación en ellos a algunas personas, pues de nada serviría permitir que todas las personas que cumplen con los requisitos del cargo participen en el concurso para su provisión, si a todas no se les evalúa igual.

Así pues, sobre la inconveniencia e inconstitucionalidad de la hipótesis planteada en la presente sentencia consistente en la posibilidad de reconocer a los empleados inscritos en carrera su experiencia y desempeño en su cargo, en la realización de un concurso en el participen aspirantes inscritos en carrera como no-inscritos, ha dicho la Corte:

*“A juicio de este Tribunal, aún considerando que el sistema de concurso cerrado puede resultar adecuado para hacer realidad el objetivo de estimular a los funcionarios escalafonados o inscritos en carrera y reconocerles su experiencia y buen desempeño en el ejercicio de sus funciones, dicho proceder “es innecesario” en el entendido que puede acudir a otros métodos menos lesivos de las garantías reconocidas a terceros -quienes también por sus calidades podrían acceder al cargo- y, a su vez, más apropiados e idóneos para asegurar tanto la observancia de tales fines lícitos, como la eficiencia de la función pública y la igualdad en la posibilidad de acceso a la misma en todas sus fases.”*⁸¹ [Énfasis fuera de texto]

8.- Como se ve, para la Corte Constitucional ha sido claro que la noción de carrera administrativa como reguladora de la provisión de cargos en las entidades del Estado, propone privilegiar la igualdad en el acceso a las plazas de la carrera

⁷⁸ [Cita del aparte transcrito] Corte Constitucional, Sentencia C-725 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

⁷⁹ [Cita del aparte transcrito] Corte Constitucional, Sentencia C-097 de 2001, M.P. Fabio Morón Díaz.

⁸⁰ [Cita del aparte transcrito] Corte Constitucional, Sentencia C-973 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

⁸¹ C-1079 de 2002, reiterando lo dispuesto en la C-266 de 2002

y reconocimiento objetivo del mérito en quien lo tenga, independientemente de si se está o no inscrito en la misma o si ocupa o no el cargo que se saca a concurso.

Y por último, en concreto sobre el reconocimiento de la experiencia, antigüedad, conocimiento y eficiencia en el desempeño del cargo, como elemento constitutivo de la selección en las listas de elegibles en desarrollo del concurso; se consideró que esto consagra “...un trato distinto entre los aspirantes que se desempeñan en provisionalidad y los demás, pues prevé una evaluación adicional para los empleados nombrados en provisionalidad en cargos de carrera, a la fecha de la vigencia de la ley, y que aspiren a dichos cargos, que termina estableciendo a favor de éstos una ventaja injustificada con respecto a los demás aspirantes, y por lo tanto violatoria del derecho a la igualdad y del derecho de acceso a cargos públicos. El privilegio consiste en que a estos empleados, además de los factores comunes que se les tendrán en cuenta a todos los aspirantes, relativos a sus calidades académicas y experiencia, también se les toma en cuenta, de manera adicional, una evaluación de antecedentes, de experiencia, de antigüedad, de conocimiento y de eficiencia en el ejercicio del cargo para el cual se concursa, lo que representan una ventaja frente a quienes concursan y no se encuentran ocupando el cargo respectivo, según lo disponga la Comisión Nacional del Servicio Civil, la cual no se encuentra justificada.” [Énfasis fuera de texto]

9.- De lo anterior concluyo categóricamente, que las regulaciones de los sistemas de concursos no pueden establecer criterios de selección, cuya evaluación no sea susceptible de ser aplicada a todos los concursantes. El establecimiento de factores que pretenden incentivar a los empleados de carrera mediante la oportunidad de promoción, incorporados como elementos constitutivos de la selección de personal para cargos de carrera mediante concurso, es contrario a la Constitución en tanto privilegia injustificadamente a algunos participantes en detrimento de otros.

En los anteriores términos salvo el voto.

Fecha ut supra,

HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado

**ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
A LA SENTENCIA SU446/11**

1. Manifesté mi acuerdo con las decisiones adoptadas por la Sala Plena de esta Corporación en lo concerniente a la imposibilidad de utilizar el registro de elegibles resultante de la convocatoria a concurso público, hecha por la Fiscalía General de la Nación en el año 2007 para proveer cargos por fuera del número de convocados, teniendo en cuenta que por razones ajenas a la voluntad del convocante el número de plazas con un perfil similar aumentó luego de la realización del concurso.

También concordé con la mayoría en cuanto consideró que el Fiscal General era discrecional para definir los cargos específicos que serían provistos con el registro de elegibles. Sin embargo, no estoy de acuerdo con las razones por las cuales la Sala Plena llegó a esta última decisión y la regla jurisprudencial que de ellas podría colegirse. Por esta razón, estimo indispensable *aclarar mi voto* en los términos que expondré a continuación:

2. El concurso que dio lugar a esta controversia consistió en seis convocatorias para ocupar diferentes cargos de carrera en la Fiscalía General de la Nación, identificadas por la denominación del cargo y el número de plazas ofertadas, todas ellas ubicadas en el nivel nacional. Como en el momento en que se emitió la convocatoria se preveía que ese número de plazas cubría la totalidad de cargos con el mismo perfil en el país, era de esperarse que todos los funcionarios que ocupaban en provisionalidad los cargos objeto del concurso tuvieran que ceder su derecho a quienes hubieran adquirido derechos de carrera. En este escenario, la naturaleza global de la planta del personal no presentaba ningún reparo para la implementación del concurso.

No obstante, para el momento en que fue definida la lista de elegibles, el número de cargos con el mismo perfil y denominación excedía el número de plazas convocadas en el concurso. Por esta razón, la entidad tuvo que enfrentarse a una dificultad derivada del carácter global de la planta, consistente en que, luego de proveer todos los cargos ofertados, algunas de las plazas no serán provistas y los provisionales que las ocupan podrán permanecer en ellas. Pese a lo anterior, la convocatoria no estableció criterios para determinar cuáles serían las plazas específicas a llenar con la lista de elegibles.

3. Sobre este punto, la posición mayoritaria fue que el Fiscal General goza de discrecionalidad plena para determinar los cargos provistos por quienes superaron el concurso objeto de las acciones de tutelas. Las razones expuestas para ello son que esta facultad se deriva directamente de la naturaleza global de la planta de personal, y que todos los servidores públicos que ocupan los cargos objeto del debate son provisionales, de suerte que todos tienen una estabilidad laboral precaria que en cualquier caso debe ceder frente a cualquier otro funcionario con mejor derecho, máxime cuando todos tienen conocimiento del concurso.

Atendiendo a estas razones, continuó la mayoría, no se puede afirmar que se vulneraron los derechos a la igualdad y al debido proceso de los provisionales que se vieron obligados a ceder su cargo frente a quienes ganaron el concurso, aun cuando otros sujetos en la misma condición no hubieran sido removidos de su cargo. Se exceptúan de esta conclusión las madres y padres cabezas de familia, las personas que están próximas a pensionarse, y las personas en situación de discapacidad, frente a quienes la Fiscalía General tenía el deber de garantizar que fueran las últimas en ser desvinculadas.

4. A mi juicio, era necesario concluir que el Fiscal General podía determinar con discrecionalidad los cargos en provisionalidad que serían afectados con los resultados del concurso, excepto en lo que tiene que ver con las personas en condiciones de especial vulnerabilidad señaladas en la sentencia. Considero, sin embargo, que esta conclusión es excepcional, solo obedece a las particularidades del caso concreto y que, de ninguna manera, podría concluirse que el Fiscal General o cualquier otra entidad pública con plantas globales de personal puede llamar a concursos sin definir los cargos específicos de los que trata la convocatoria.

En consideración a los derechos a la confianza legítima, el debido proceso, y la igualdad entre quienes ocupan los cargos en provisionalidad, la regla general debe ser que, incluso en las convocatorias relativas a plantas globales, la entidad pública está obligada a individualizar de forma suficiente los cargos que se proveerán mediante concurso o a establecer criterios razonables para dilucidar este punto, en caso de que el número de plazas existentes no sea equivalente al número sometido a concurso de méritos.

5. En este caso la Corte pudo establecer que el concurso realizado por la Fiscalía General de la Nación pretendía cubrir la totalidad de las plazas en el país de determinados perfiles, pero que por cambios legislativos posteriores éste número de plazas se vio afectado. Por ello, y debido a que nada decía la convocatoria en relación con la especificación de las plazas, no podía entrar la Corte a precisar cuáles exactamente eran las plazas ocupadas por servidores públicos de carrera. La Corporación en pleno carecía de información técnica suficiente para hacerlo y su injerencia hubiera sido inconveniente pues, terminaría haciendo lo que pretendió evitar al resolver el primer problema jurídico: modificar las reglas del concurso.

Además, aun cuando no puede negarse que esta situación genera situaciones disímiles e incertidumbre entre quienes ocupan los cargos en provisionalidad, por el carácter precario de la estabilidad laboral de los peticionarios y el cambio inesperado de las condiciones materiales de provisión de los cargos de carrera, era dable concluir que dichas diferencias no constituían para el caso concreto afectaciones a los derechos a la confianza legítima y a la igualdad.

Pero lo cierto es que de convertirse esta en una regla general, ésta puede convertirse en una verdadera vulneración a derechos fundamentales de los

servidores públicos pues avalaría conductas tales como que las entidades públicas convoquen un número de plazas menor a la existente, sin especificación alguna, y luego seleccionen a los provisionales que dejarán su cargo, con criterios que nada tienen que ver con las necesidades del servicio, con el mérito de los trabajadores o con los demás parámetros constitucionales de selección de los servidores públicos, abriendo espacios para el ejercicio arbitrario del poder de nominación. Por eso, es mi posición que la regla general debe ser determinar o hacer determinables los cargos que se someten a concurso, aun cuando pertenezcan a plantas globales.

6. La misma Corte reconoció que la necesidad constitucional de dichos criterios al señalar que, como mínimo, la Fiscalía debió tener como parámetro para establecer los cargos sobre los que el concurso repercutió las condiciones de especial vulnerabilidad de ciertas poblaciones, a saber, las madres y padres cabezas de familia, las personas próximas a pensionarse tomando en consideración la fecha en que se expidió la lista de elegibles, y las personas con discapacidad. En este sentido, la propia Corporación reconoció que la Fiscalía erró al no prever criterios mínimos para la asignación de las plazas. Del mismo modo, dejó claro que este proceso de especificación de las plazas no puede ser totalmente discrecional sino que debe obedecer a criterios objetivos y razonables, que sean susceptibles de control mediante los mecanismos administrativos y judiciales correspondientes.

7. Por estas razones, y debido a que nada dijo la mayoría en relación con este aspecto que reviste especial importancia desde el punto de vista de los derechos de los servidores que ocupan en provisionalidad cargos del Estado, considero pertinente aclarar mi voto señalando que, más allá del excepcional caso particular, las obligaciones de claridad y certeza en las normas que regulan los concursos de méritos –regla general para la provisión de los cargos del Estado- se extienden al deber de especificar o establecer criterios suficientes para hacer especificables los cargos que serán provistos dentro de una planta global de personal.

Fecha *ut supra*,

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado

Sentencia T-084/18

RETEN SOCIAL EN CASO DE MADRE CABEZA DE FAMILIA-
Protección

LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA-Formas previstas por
ordenamiento jurídico

LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA-Persona natural que
actúa en defensa de sus propios intereses

LEGITIMACION EN LA CAUSA POR ACTIVA Y AGENCIA
OFICIOSA EN LA ACCION DE TUTELA-Requisitos

PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD DE LA ACCION DE
TUTELA-Juez debe verificar si ante la existencia de otro medio de
defensa judicial, éste es eficaz e idóneo

ACCION DE TUTELA Y REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD-
Flexibilidad en caso de sujetos de especial protección constitucional

Cuando el amparo es promovido por personas que requieren especial protección constitucional, como niños, niñas y adolescentes, mujeres en estado de gestación o de lactancia, madres cabeza de familia, personas en situación de discapacidad, de la tercera edad o población desplazada, entre otros, el examen de procedencia de la tutela se hace menos estricto, a través de criterios de análisis más amplios, pero no menos rigurosos.

ACCION DE TUTELA PARA SOLICITAR LA APLICACION
DEL RETEN SOCIAL-Procedencia

En el escenario específico de quienes alegan su calidad de beneficiarios del denominado “retén social”, la jurisprudencia constitucional ha sostenido, de manera reiterada y uniforme, que la acción de tutela es procedente para reclamar dicha condición por dos motivos principalmente: (i) Las personas beneficiarias del “retén social” son sujetos de especial protección que, además, se encuentran en situaciones de particular vulnerabilidad, dado que se trata de madres o padres cabeza de familia, personas en situación de discapacidad o próximas a pensionarse. (ii) Los efectos del “retén social” se producen dentro del marco de procesos de reestructuración administrativa que culminan rápidamente. Por tanto, la jurisdicción contencioso administrativa no es el mecanismo idóneo ni eficaz para reclamar los beneficios derivados de estos programas pues se hace predecible que para cuando se produzca el fallo contencioso administrativo “la respectiva entidad ya se encuentre liquidada y no se tenga a quien reclamar el reintegro laboral y el pago de los respectivos salarios”.

MADRE CABEZA DE FAMILIA-Presupuestos jurisprudenciales para
que una mujer sea considerada como tal

La condición de madre cabeza de familia requiere la confluencia de los siguientes elementos, a saber: (i) que la mujer tenga a su cargo la responsabilidad de hijos menores de edad o de otras personas “incapacitadas” para trabajar; (ii) que la responsabilidad exclusiva de la mujer en la jefatura del hogar sea de carácter permanente; (iii) que exista una auténtica sustracción de los deberes legales de manutención por parte de la pareja o del padre de los menores de edad a cargo; y (iv) que exista una deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros de la familia. De igual modo, la verificación de las circunstancias anteriormente enunciadas debe realizarse en el marco de un procedimiento administrativo, que otorgue la plenitud de las garantías propias del derecho fundamental al debido proceso.

MADRE CABEZA DE FAMILIA-Extensión de la protección al padre cabeza de familia

PROTECCION ESPECIAL DE LAS PERSONAS CABEZA DE FAMILIA EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE REESTRUCTURACION ADMINISTRATIVA-Condiciones para pertenecer al retén social

RETEN SOCIAL-Mecanismo de garantía de la estabilidad laboral reforzada

PROTECCION DEL RETEN SOCIAL-No es absoluta ni ilimitada

DESVINCULACION DE TRABAJADORES AMPARADOS POR EL RETEN SOCIAL-Puede ocurrir cuando se presenten causales objetivas

CARGO DE CARRERA EN PROVISIONALIDAD-Goza de estabilidad laboral relativa

FUNCIONARIOS VINCULADOS EN PROVISIONALIDAD POR UN PERIODO DE TIEMPO DETERMINADO PREVISTO DESDE SU NOMBRAMIENTO-Titulares de protección especial derivada del retén social

La Sala considera que los funcionarios vinculados en provisionalidad por un período de tiempo determinado, previsto de antemano desde su nombramiento, son titulares de la protección especial derivada del “retén social” y, en esta medida, son beneficiarios de estabilidad laboral reforzada en el curso de los procesos de reestructuración administrativa de las instituciones públicas. No obstante, la entidad respectiva puede desvincular a estos servidores siempre que satisfaga la carga argumentativa requerida para tal efecto, es decir, que justifique plenamente la existencia de razones objetivas del servicio para el retiro de los trabajadores que se encuentran en esta condición.

RETEN SOCIAL-Acción afirmativa que materializa el deber constitucional que tiene el Estado de conceder un trato diferenciado a las mujeres cabeza de familia en estado de debilidad manifiesta

El llamado “retén social” es una acción afirmativa que materializa el deber constitucional que tiene el Estado de conceder un trato diferenciado a las mujeres cabeza de familia que se encuentran en estado de debilidad manifiesta. Además, es uno de los mecanismos previstos por el Legislador para garantizar la estabilidad laboral de las madres y padres cabeza de familia. Esta medida de protección especial deriva directamente de los mandatos constitucionales de protección a la igualdad material y a los grupos poblacionales anteriormente mencionados, dado que podrían sufrir consecuencias especialmente graves con su desvinculación.

ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DERIVADA DEL RETEN SOCIAL-No es de carácter absoluto

La estabilidad laboral reforzada derivada del llamado “retén social”, no es de carácter absoluto, pues no existe un derecho fundamental a la conservación perpetua del trabajo o a la permanencia indefinida en el mismo. Así, en el marco de los ajustes institucionales propios de los procesos de reestructuración de la administración pública, se debe garantizar la permanencia de los servidores públicos que tengan derecho a la protección especial derivada del “retén social”.

APLICACION DEL RETEN SOCIAL RESPECTO DE LAS MADRES Y LOS PADRES CABEZA DE FAMILIA-Reglas jurisprudenciales

Corresponde ahora precisar algunas de las principales reglas que ha establecido la jurisprudencia constitucional en la aplicación del denominado “retén social” respecto de la desvinculación de madres o padres cabeza de familia en el marco de ajustes institucionales de la administración: (i) En los procesos de modificación de la estructura de la administración pública (reestructuración, fusión, o liquidación de entidades, por ejemplo) en los que exista supresión de cargos, las entidades públicas deben observar los parámetros propios de la estabilidad laboral de los servidores públicos beneficiarios del denominado “retén social”. (ii) La estabilidad laboral derivada del “retén social” es aplicable tanto para funcionarios de carrera administrativa como para servidores vinculados en provisionalidad, así como para trabajadores oficiales. No obstante, cuando se trata de la permanencia de trabajadores beneficiarios del “retén social” vinculados en provisionalidad por un término definido, la administración puede retirarlos cuando existan razones objetivas del servicio que justifiquen de manera suficiente la desvinculación de dichos funcionarios. (iii) Los trabajadores que alegan ser beneficiarios del “retén social” deben informar oportunamente a su empleador esta circunstancia, so pena de perder su derecho a recibir la protección especial derivada de su condición, en razón de su falta de diligencia. (iv) La estabilidad laboral reforzada de la cual son titulares los

beneficiarios del “retén social” cubija tanto al sector central de la administración pública como al descentralizado. Así mismo, es predicable de los servidores públicos vinculados a instituciones del orden nacional y de las entidades territoriales. (v) Las medidas que adopten las entidades públicas en el marco de la aplicación de la protección derivada del denominado “retén social” no pueden implicar un trato discriminatorio entre las personas o grupos que son titulares de especial protección. Por tanto, no sería admisible garantizar la estabilidad laboral de las personas en situación de discapacidad y excluir de protección a los “pre pensionados”. (vi) Finalmente, se reitera que la estabilidad laboral originada en el llamado “retén social” no es absoluta. Por tanto, los titulares de esta protección pueden ser desvinculados cuando medie una justa causa de terminación de la relación laboral debidamente comprobada. Además, su estabilidad laboral se materializa mediante el reintegro —siempre y cuando ello se encuentre dentro de las posibilidades fácticas y jurídicas— y se extiende hasta la terminación definitiva del proceso liquidatorio de la entidad respectiva o hasta que cesen las condiciones que originan la especial protección.

MADRE CABEZA DE FAMILIA AMPARADA POR RETEN SOCIAL-Orden a municipio reintegrar a accionante, si ella así lo desea, a un cargo de iguales o mejores condiciones al que ocupaba

Referencia: Expediente T-6.351.900.

Acción de tutela interpuesta por Omaira Jaqueline Nandar de la Cruz (en nombre propio y como agente oficiosa de Guillermo Alfonso Pasijojoa Nandar) contra el Municipio de Ipiales.

Procedencia: Juzgado Primero Civil del Circuito de Ipiales.

Asunto: Protección de mujeres cabeza de familia en el marco del denominado “*retén social*”. Requisitos para acreditar la condición de padre o madre cabeza de familia.

Magistrada Ponente:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Bogotá, D. C., cinco (5) de marzo de dos mil dieciocho (2018).

La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por el Magistrado José Fernando Reyes Cuartas y las Magistradas Cristina Pardo Schlesinger y Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente

SENTENCIA

En el trámite de revisión del fallo de segunda instancia, dictado por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ipiales el 17 de mayo de 2017, que a su vez revocó la decisión adoptada por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Ipiales el 24 de marzo de 2017, en el proceso de tutela promovido por Omaira Jaqueline Nandar de la Cruz (en nombre propio y como agente oficiosa de Guillermo Alfonso Pasijojoa Nandar) contra el Municipio de Ipiales.

Conforme a lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección Número Diez de la Corte Constitucional escogió, para efectos de su revisión, el asunto de la referencia¹.

I. ANTECEDENTES

Omaira Jaqueline Nandar de la Cruz presentó acción de tutela en contra del Municipio de Ipiales, por considerar que la entidad accionada vulneró sus derechos fundamentales a la vida digna, al trabajo, a la seguridad social, al mínimo vital, a la estabilidad laboral reforzada y a la educación y formación integral de los adolescentes. También, asegura que se desconoció la protección especial a las personas en situación de debilidad manifiesta.

A. Hechos y pretensiones

1. La señora Omaira Jaqueline Nandar de la Cruz fue nombrada en provisionalidad y por un término de seis meses en el cargo de “*Profesional Universitario Código 219, Nivel 2, Grado 2*”, mediante el Decreto No. 085 del 23 de enero de 2015, expedido por la Alcaldía Municipal de Ipiales². Dicho nombramiento fue prorrogado por un período idéntico a través del Decreto 154 del 22 de julio de 2016³.

1 El expediente de la referencia fue insistido por la Defensoría del Pueblo (folios 3 a 19. Cuaderno de Revisión de la Corte Constitucional) y fue seleccionado y repartido a la Magistrada Sustanciadora por la Sala de Selección Número Diez de la Corte Constitucional, conformada por la Magistrada Diana Fajardo Rivera y el Magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo el día 27 de octubre de 2017, de acuerdo con el criterio orientador del proceso de selección de carácter objetivo, denominado ‘*Desconocimiento de un precedente jurisprudencial*’.

2 Cuaderno de Primera Instancia (en adelante, Cuaderno No. 1), folios 17 a 20.

3 Cuaderno No. 1, folios 21 a 24.

2. Mediante oficio fechado el 5 de agosto de 2016, la Alcaldía Municipal de Ipiales solicitó a los servidores vinculados a la entidad que estuvieran *“dentro de las condiciones enmarcadas en el denominado RETÉN SOCIAL”*, que remitieran la información que acreditara dichas circunstancias, conforme a los criterios establecidos en el referido documento. Así, entre las categorías enlistadas se encontraban las siguientes: *“pensionables”, “madre y padre cabeza de familia”, “protección especial, discapacidades y limitaciones”*⁴.

En relación con la condición de *“madre y padre cabeza de familia”*, la entidad accionada estableció la siguiente definición: *“quien tenga bajo su cargo, económica o socialmente en forma permanente, hijos menores o dependientes incapacitados, ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los miembros del núcleo familiar; es decir, que haya una deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros de la familia, lo cual significa la responsabilidad solitaria de la persona para sostener el hogar”*.

3. La actora manifiesta que, en atención a dicho requerimiento, el 16 de agosto de 2016 remitió a la entidad accionada los documentos que daban cuenta de su condición de madre cabeza de familia⁵.

4. El 9 de septiembre de 2016, la Subsecretaría de Talento Humano de la Alcaldía de Ipiales dirigió un oficio a la señora Omaira Nandar, en el cual se informó que la declaración extraprocesal aportada por la funcionaria no expresaba la conformación de su grupo familiar. En este sentido, se solicitó a la servidora indicar *“con precisión el nombre e identificación de las personas que componen su núcleo familiar, señalando el tipo de relación con cada una de ellas. En caso de la existencia de hijos, indicar si convive con el padre o madre de ellos”*. Para subsanar el referido medio de prueba, se otorgó un plazo de cinco días hábiles⁶.

5. El 12 de septiembre de 2016, la tutelante allegó una declaración extraprocesal en la cual indicaba que su núcleo familiar estaba conformado únicamente por ella y su hijo menor de edad (quien, para entonces, tenía 17 años), dado que no convivía con el padre de aquel⁷.

6. En el marco del proceso de modernización y reestructuración de la Alcaldía Municipal de Ipiales, el Decreto 016 del 31 de enero de 2017 suprimió de la

4Cuaderno No. 1, folios 25 y 26.

5 Cuaderno No. 1, folios 27 y 28.

6Cuaderno No. 1, folio 29.

7Cuaderno No. 1, folios 30 y 31. La tutelante expresó en la comunicación dirigida a la Subsecretaría de Talento Humano de la Alcaldía Municipal de Ipiales que la declaración extra proceso que aportaba tenía como propósito *“acceder a la Protección Constitucional de Reten Social (sic)”*.

planta de personal el cargo que desempeñaba la tutelante⁸, decisión que le fue informada el día 1 de febrero de 2017⁹ mediante un oficio que no señalaba si procedían recursos en contra de dicho acto administrativo.

7. De conformidad con lo narrado en el escrito de tutela, la actora tiene a su cargo exclusivamente los gastos de manutención y de educación superior de su hijo, así como sus propios gastos de sostenimiento.

8. Debido a lo anterior, el 10 de marzo de 2017, la señora Omaira Jaqueline Nandar de la Cruz (en nombre propio y como agente oficiosa de su hijo Guillermo Alfonso Pasijojoa Nandar), a través de apoderado judicial¹⁰, presentó acción de tutela en contra del Municipio de Ipiales, por considerar que la determinación de dicha entidad territorial de desvincularla sin tener en cuenta su condición de madre cabeza de familia vulneró sus derechos fundamentales al trabajo, a la seguridad social, al mínimo vital, a la estabilidad laboral reforzada y a la especial protección de las personas en condición de debilidad manifiesta.

Por consiguiente, la actora solicitó su reintegro a un cargo equivalente o de mejores condiciones y el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el momento de su retiro.

B. Actuación procesal en primera instancia

Mediante auto de 10 de marzo de 2017¹¹, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Ipiales avocó conocimiento de la acción de tutela, solicitó al Municipio de Ipiales rendir un informe sobre el asunto en el término de dos días¹² y ordenó correr traslado a la parte demandada.

Posteriormente, a través de auto de 15 de marzo de 2017, el referido despacho judicial otorgó un término de un día adicional a la entidad accionada para presentar su contestación¹³. Además, citó a la accionante para que rindiera su declaración ante el juzgado y requirió a la Oficina de Instrumentos Públicos de

8Cuaderno No. 1, folios 48-55. El referido acto administrativo se fundamentó en que el alcalde municipal de Ipiales modificó la estructura organizacional del municipio, con lo cual se requirió actualizar la planta global de empleos para incorporar las modificaciones necesarias para implementar y desarrollar la nueva estructura. En tal sentido, se evidencia que la reforma de la planta de personal se enmarca en un proceso de modernización institucional.

9Cuaderno No. 1, folio 32.

10Obra a folio 16 del Cuaderno No. 1 el poder especial otorgado por la accionante.

11 Cuaderno No. 1, folio 59.

12 En este sentido, la autoridad judicial ordenó al Municipio de Ipiales que informara acerca de los hechos que motivaron la acción de tutela y que indicara las gestiones y decisiones que se habían tomado sobre el caso.

Ipiales y a la Cámara de Comercio de la misma ciudad para que certificaran si la accionante era propietaria de algún bien inmueble o de un establecimiento de comercio, respectivamente.

Finalmente, mediante proveído de 23 de marzo de 2017, el *a quo* vinculó a la Personería Municipal de Ipiales y a la Comisaría de Familia de la misma ciudad, dado que uno de los actores era menor de edad para el momento de la decisión.

Respuesta del Municipio de Ipiales

La Oficina Jurídica de la Alcaldía Municipal solicitó desestimar las pretensiones de la actora toda vez que, en criterio de la entidad, su desvinculación obedeció a que no cumplía con los requisitos para ser beneficiaria del denominado “*retén social*” en calidad de madre cabeza de familia.

En primer lugar, señaló que el padre de Guillermo Alfonso Pasijojoa Nandar, hijo de la accionante, “*ostenta condición de pensionado por invalidez por riesgo común*”¹⁴ y, por tanto, tiene el deber legal de sufragar los gastos derivados de la subsistencia del menor de edad.

En este sentido, la entidad adujo que, en atención al “*deber de autogestión*”, la actora tiene a su disposición varios mecanismos judiciales para exigir el cumplimiento de las obligaciones legales que debe asumir el progenitor de su hijo¹⁵. Por consiguiente, expresó que la tutelante “*evidencia una actitud omisiva o displicente*”¹⁶, dado que no acudió a los medios jurídicos idóneos para reclamar al padre de su hijo la observancia de sus obligaciones alimentarias.

Así mismo, manifestó que la accionante tiene estudios profesionales en contaduría y un título de secretaria ejecutiva, por lo que puede ejercer su profesión “*liberalmente*” y sostener a su familia. También, advirtió que la

13 Esta decisión se motivó en la solicitud del apoderado de la entidad accionada, en la cual requirió un plazo adicional para rendir el informe señalado en el auto admisorio (Cuaderno No. 1, folio 65).

14 Cuaderno No. 1, folio 73. El apoderado de la parte demandada indicó que la entidad había consultado el Registro Único de Afiliados a la Protección Social (RUAF) en la cual se evidenciaba que el señor Javier Guillermo Pasijojoa Cujar estaba afiliado al Sistema General de Seguridad Social en calidad de pensionado por invalidez por riesgo común. La accionada aportó la constancia de esta consulta, la cual obra a folios 79 y 80 del Cuaderno No. 1.

15 Al respecto, el Municipio de Ipiales señaló que la tutelante podía acudir al proceso verbal sumario de alimentos y a los procesos penales por inasistencia alimentaria.

16 Cuaderno No. 1, folio 74.

peticionaria acudió al proceso por medio de apoderado judicial, lo cual, en criterio de la entidad accionada, desvirtúa la afectación de su mínimo vital.

Por último, destacó que no cumple con el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela, en la medida en que la tutelante puede acudir a las acciones ante la jurisdicción ordinaria laboral o contenciosa administrativa para hacer valer su eventual condición de beneficiaria del “*retén social*”.

Declaración presentada por la accionante Omaira Jaqueline Nandar de la Cruz ante el juez de primera instancia

El 17 de marzo de 2017, la accionante rindió declaración ante el Juzgado Segundo Civil Municipal de Ipiales. En la diligencia, ratificó los hechos que expuestos en el escrito de tutela. Adicionalmente, explicó que, aunque el padre de su hijo era titular de la patria potestad para ese momento, nunca se hizo responsable de las necesidades del menor de edad¹⁷. Respecto de lo anterior, señaló: “*mi hijo no tiene contacto con él. Nunca he vivido con él, no vivo, no viviré ni conviviré ni convivo con el papá de mi hijo.*”¹⁸ Además, indicó que no tenía conocimiento de la calidad de pensionado del señor Javier Guillermo Pasijojoa Cujar.

De igual modo, describió en detalle su situación económica, en los siguientes términos: (i) señaló que tiene varias obligaciones económicas y que, además de su propio sustento, debe asumir los gastos de su hijo Guillermo Alfonso, quien reside en una ciudad distinta de la suya debido a que se actualmente estudia en la universidad y (ii) añadió que es propietaria de una casa en el corregimiento de El Pedregal, la cual manifestó haber heredado.

Respuesta de la Cámara de Comercio de Ipiales

Mediante oficio del 22 de marzo de 2017, la entidad informó que no figuraba inscripción alguna a nombre de la accionante relacionada con bienes, negocios o establecimientos mercantiles.

Respuesta de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ipiales

A través de oficio No. 147 de 17 de marzo de 2017, la institución manifestó que la actora no aparecía inscrita como propietaria de bienes inmuebles sujetos a registro en dicho círculo registral.

C. Sentencia de primera instancia

¹⁷ Acerca de la relación que sostenía la accionante con el progenitor de su hijo, aclaró que “*ni lo busqué ni él nos busca, no tengo noticias desde hace unos 11 años, en este momento no sé dónde está*”. (Cuaderno No. 1, folio 90 reverso).

¹⁸ Cuaderno No. 1, folio 90 reverso.

El 24 de marzo de 2017, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Ipiales declaró improcedente la acción de tutela por considerar que la accionante no era beneficiaria de la figura del “*retén social*”. Sobre el particular, indicó que la Ley 790 de 2002 no resultaba aplicable al Municipio de Ipiales pues dicha normativa fue expedida para reglamentar el proceso de renovación de la administración pública de las entidades pertenecientes a la Rama Ejecutiva. No obstante, la institución accionada no se encuentra en liquidación, tal como lo prevé la citada norma.

Por otra parte, aunque reconoció que las madres cabeza de familia tienen derechos de estabilidad laboral reforzada, destacó que dicha protección no es automática y que es indispensable acreditar las condiciones específicas para su aplicación. Empero, consideró que esta valoración corresponde al juez de lo contencioso administrativo y no al fallador de tutela, dado que las atribuciones de este último “*no revisten la declaración de derechos sino la salvaguarda de aquellos*”¹⁹. Por tanto, estimó que no se satisfacía el requisito de subsidiariedad de la tutela.

Igualmente, el juzgador resaltó que la accionante no está en situación de debilidad manifiesta dado que cuenta con un inmueble propio, tiene un título profesional y sus deudas no están en cobro prejurídico. Además, adujo que la actora no ha adelantado ninguna acción judicial para reclamar al progenitor de su hijo menor de edad los alimentos correspondientes o para privarlo de la patria potestad por haberse sustraído de sus obligaciones.

D. Impugnación

En desacuerdo con la decisión de primera instancia, el apoderado de la tutelante impugnó la providencia anterior²⁰. En primer lugar, argumentó que el amparo es procedente para la defensa de derechos fundamentales de personas que alegan ser titulares de la protección derivada del “*retén social*”, de conformidad con lo establecido por la jurisprudencia constitucional²¹.

Así mismo, recalcó que el denominado “*retén social*” se deriva de mandatos constitucionales más allá de las consagraciones normativas de orden legal. Añadió que la Corte Constitucional ha reconocido que esta protección se extiende a servidores públicos del nivel territorial.

De igual manera, señaló que el fallo impugnado no tuvo en cuenta las declaraciones extrajuicio allegadas por la actora y adujo que no se

¹⁹ Cuaderno No. 1, folio 117.

²⁰ La impugnación del apoderado de la accionante, radicada el 28 de marzo de 2017, obra a folios 112 a 122 del Cuaderno No. 1.

²¹ El recurrente refirió varias decisiones de la Corte Constitucional para sustentar su argumento, entre las cuales se enlistan las sentencias T-444 de 2010, T-034 de 2010, T-345 de 2015, T-040 de 2016, T-320 de 2016 y T-346 de 2016.

desvirtuaron las afirmaciones propuestas por la parte demandante respecto de la afectación de sus derechos fundamentales. También, resaltó que la situación de la accionante se enmarca en la definición de madre cabeza de familia contenida en el artículo 13 del Decreto 190 de 2003²².

Por último, advirtió que la exigencia formulada por el *a quo*, de acuerdo con la cual la peticionaria debía iniciar acciones judiciales en contra del padre de su hijo para demostrar que el progenitor se sustrajo de sus deberes familiares, era incorrecta en la medida en que no existe una tarifa legal para probar tal hecho.

Respuesta del Municipio de Ipiales al escrito de impugnación.

La entidad territorial aseveró que la argumentación contenida en el escrito de impugnación no guardaba relación con el fallo impugnado. Reiteró que la tutelante no era beneficiaria del “*retén social*”, dado que el padre de su hijo cuenta con una pensión de invalidez por riesgo común, e insistió en que la actora obró con “*pasividad*” y “*negligencia*” para exigir sus derechos ante el progenitor del menor de edad.

Por otra parte, afirmó que “*se conoce que la accionante actualmente labora como asistente o asesora en la Dirección Local de Salud de Pupiales*”²³ y agregó que en la casa de propiedad de la peticionaria, ubicada en el municipio de Imués, funcionaba un establecimiento de comercio.

Finalmente, recordó que la actora disponía de los medios de control ante la jurisdicción contencioso administrativa para discutir los actos de la entidad territorial que culminaron con su desvinculación, proceso en el cual también podría solicitar la suspensión provisional de tales actos administrativos.

E. Actuación procesal en segunda instancia

Por medio de auto de 18 de abril de 2017, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ipiales admitió el conocimiento de la impugnación²⁴. Así mismo, por solicitud de la parte demandada, el *ad quem*: (i) ofició a la Dirección Local de Salud del Municipio de Pupiales para que certificara si la tutelante se encontraba vinculada a dicha dependencia; y (ii) decretó la práctica de una

22Decreto 190 de 2003. Artículo 1. “*Madre cabeza de familia sin alternativa económica: Mujer con hijos menores de 18 años de edad, biológicos o adoptivos, o hijos inválidos que dependan económicamente y de manera exclusiva de ellas, y cuyo ingreso familiar corresponde únicamente al salario que devenga del organismo o entidad pública a la cual se encuentra vinculada*”.

²³ Cuaderno No. 1, folio 132.

²⁴ Cuaderno de Segunda Instancia (en adelante Cuaderno No. 2), folio 4.

inspección judicial en el bien inmueble de la accionante, ubicado en El Pedregal (Nariño)²⁵.

Respuesta de la Secretaría de Salud del Municipio de Pupiales

La entidad certificó que la tutelante Omaira Jaqueline Nandar de la Cruz no tenía vinculación laboral, legal, reglamentaria o mediante contrato de prestación de servicios con la Secretaría de Salud Municipal de Pupiales²⁶.

Diligencia de inspección judicial

Mediante oficio del 5 de mayo de 2017, el juzgado de segunda instancia dejó constancia de la imposibilidad de adelantar la diligencia, dado que la parte interesada no se hizo presente, pese a que tenía a su cargo trasladar al personal del despacho hasta el lugar de la inspección judicial.

F. Sentencia de segunda instancia

Mediante sentencia de 17 de mayo de 2017, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ipiales revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, denegó la acción de tutela interpuesta.

En efecto, explicó que la Corte Constitucional ha considerado procedente la acción de tutela para los casos en los que se desconoce la protección derivada del denominado “*retén social*”. En tal sentido, estimó que la decisión del *a quo* debía ser revocada.

No obstante, precisó que la actora no tenía derecho a la estabilidad laboral reforzada prevista para las madres cabeza de familia pues no cumplía los requisitos señalados por la jurisprudencia para acreditar tal calidad. Así, para el fallador este concepto trasciende la custodia del menor de edad y su cuidado personal ya que, además de la condición de cabeza de hogar, se exige que la trabajadora carezca de alternativa económica. Por consiguiente, se requiere que exista una imposibilidad de desarrollar una actividad económica para que pueda predicarse la calidad de persona cabeza de familia.

Igualmente, el *ad quem* aseveró que la actora no había probado la deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros de la familia, dado que su hijo residía en un municipio diferente al de la tutelante, por lo cual el fallador presumió que otras personas concurrían a su cuidado.

25En este mismo proveído, se aclaró que el traslado del personal del despacho que practicaría la diligencia estaría a cargo del Municipio de Ipiales, dado que dicha entidad solicitó la prueba decretada (Cuaderno No. 2. Folio 4).

26Dicha certificación se expidió con fecha de 26 de abril de 2017 (Cuaderno No. 2, folios 17 y 18).

Por último, el juzgador señaló que no se demostró que el padre se sustrajo de la obligación alimentaria “*por un motivo tal que no le permitiera cumplir con el compromiso que como progenitor adquirió*”.

G. Actuaciones llevadas a cabo por la Corte Constitucional en sede de revisión

Por medio del auto de 5 de diciembre de 2017, esta Corporación vinculó al señor Guillermo Alfonso Pasijojoa Nandar, pues se advirtió que había cumplido la mayoría de edad desde agosto de 2017²⁷. Así mismo, la Magistrada Sustanciadora solicitó algunas pruebas con el fin de contar con elementos de juicio adicionales para resolver el asunto sometido a consideración de la Corte²⁸.

Respuesta de la accionante Omaira Jaqueline Nandar de la Cruz

Mediante escrito remitido a esta Corporación el 14 de diciembre de 2017, la actora manifestó que, desde la supresión del cargo que ocupaba en la Secretaría de Salud de Ipiales, ha derivado su subsistencia de las prestaciones sociales sufragadas por la parte demandada, del pago de sus cesantías y de préstamos de personas de su familia.

Así mismo, informó que se encontraba vinculada a la Alcaldía Municipal de Pupiales en calidad de contratista desde el 1 de junio de 2017 y que el referido vínculo terminaría el 26 de diciembre del mismo año. De este modo, afirmó que sus ingresos se derivaron de los honorarios que percibió en razón de

Cuaderno No. 2, folio 25.

27“*En el caso objeto de estudio, este Despacho advierte que la acción de tutela fue formulada por la señora Omaira Jaqueline Nandar de la Cruz en nombre propio y como agente oficiosa de su hijo Guillermo Alfonso Pasijojoa Nandar, quien al momento de presentación del amparo era menor de edad. No obstante, a partir de la copia del documento de identidad del agenciado que fue allegada por la parte actora, se constata que aquel cumplió la mayoría de edad (...) En este sentido, se debe recordar que la Corte Constitucional ha establecido que la figura procesal de la agencia oficiosa requiere de la imposibilidad del interesado para actuar en defensa de sus propios intereses, circunstancia que se entiende superada con el cumplimiento de la mayoría de edad, pues esta situación permite presumir que el agenciado actualmente cuenta con la facultad de actuar por sí mismo en procura de sus derechos.*” (Folios 38 a 42. Cuaderno de Revisión de la Corte Constitucional).

28En particular, se solicitó información acerca de la situación económica, laboral y familiar de la accionante Omaira Jaqueline Nandar de la Cruz y de su hijo Guillermo Alfonso Pasijojoa Nandar. En relación con este último, se indagó también acerca de la continuidad de su proceso educativo. Adicionalmente, el Despacho requirió a la parte accionante que anexara los documentos que demostraran sus afirmaciones. (Folios 38 a 42. Cuaderno de Revisión de la Corte Constitucional).

dicho contrato de prestación de servicios²⁹. De igual modo, presentó una relación detallada de sus gastos³⁰, tanto de aquellos que correspondían a sus erogaciones personales como los derivados de la manutención y sostenimiento de su hijo.

Añadió que es propietaria de una casa de habitación ubicada en el corregimiento de El Pedregal. No obstante, señaló que se vio obligada a hipotecar dicho inmueble debido a su sorpresiva desvinculación del cargo que desempeñaba en la Secretaría de Salud de Ipiales³¹.

Adicionalmente, reiteró que es la única persona que asume los gastos de sostenimiento de su hijo Guillermo Alfonso, dado que no recibe colaboración alguna del padre de aquel ni de sus demás familiares.

Respuesta del accionante Guillermo Alfonso Pasijojoa Nandar

En respuesta al requerimiento formulado en sede de revisión, el actor relató que ha estado bajo el cuidado exclusivo de su madre y que depende económicamente de ella. Al respecto, manifestó que sus compromisos académicos no le permiten trabajar y que sus gastos de arrendamiento, alimentación, transporte y aquellos derivados de su educación han sido asumidos en su totalidad por su progenitora³².

En relación con su formación educativa, señaló que es estudiante del programa de mercadeo y ventas en la Universidad Mariana de Pasto y que, al momento de la declaración, había culminado el segundo semestre de dicha carrera profesional, la cual aspira a terminar en el año 2022.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

1. La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional es competente para conocer los fallos de tutela proferidos dentro del trámite de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la

29La actora indicó que sus honorarios netos ascendían a un poco más de tres salarios mínimos (Cuaderno de Revisión de la Corte Constitucional, folios 47 a 51).

30La tutelante relató que es arrendataria de una habitación y que contrata el servicio de alimentación en el municipio de Pupiales (Cuaderno de Revisión de la Corte Constitucional, folios 47 a 51).

31A folio 59 del Cuaderno de Revisión de la Corte Constitucional, consta la copia del certificado de tradición y libertad del inmueble de la accionante. En dicho documento, se advierte que en la anotación del 9 de junio de 2017 se registró la constitución del gravamen hipotecario sobre dicho inmueble.

32Cuaderno de Revisión de la Corte Constitucional, folios 67 a 69.

Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

Asunto objeto de análisis y problema jurídico

2. La accionante, en nombre propio y como agente oficiosa de su hijo menor de edad, presentó acción de tutela en contra del Municipio de Ipiales, por considerar que la entidad accionada vulneró sus derechos fundamentales a la vida digna, al trabajo, a la seguridad social, al mínimo vital, a la estabilidad laboral reforzada y a la educación y formación integral de los adolescentes. Afirmó que la transgresión de tales garantías se originó en la decisión de la institución accionada de suprimir el cargo que ocupaba, pese a su condición de madre cabeza de familia.

3. La entidad territorial demandada sostuvo que la actora no cumple con los requisitos para ser beneficiaria del “*retén social*”. Por una parte, indicó que el progenitor del hijo de la accionante es pensionado por invalidez, motivo por el cual recibe ingresos económicos y está obligado a sufragar los gastos derivados de la manutención de aquel. En consecuencia, la tutelante ha omitido su deber de agotar los mecanismos judiciales respectivos para exigir al padre de su hijo el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias. Por otro lado, señaló que la peticionaria dispone de medios para afrontar su situación, dado que: (i) es contadora; (ii) es propietaria de un inmueble y, además, (iii) interpuso la acción de amparo a través de un apoderado judicial.

4. El juez de primera instancia declaró improcedente la acción de tutela por estimar que la actora no cumplía con los requisitos para ser beneficiaria del “*retén social*”. En este sentido, estimó que las normas relativas a esta modalidad de estabilidad laboral reforzada no resultaban aplicables a las entidades territoriales y, además, que la accionante no había acudido a los mecanismos judiciales idóneos, tanto para discutir los actos administrativos de desvinculación como para reclamar al progenitor de su hijo los alimentos correspondientes.

5. A su turno, el juez de segunda instancia revocó el fallo proferido por el *a quo* y, en su lugar, denegó la acción de tutela. Fundamentó tal decisión en que la Corte Constitucional ha reconocido la procedencia de la acción de tutela cuando se pretende reclamar la protección derivada del denominado “*retén social*”.

Pese a lo anterior, el fallador precisó que la tutelante no acreditaba los requisitos para acceder a la estabilidad laboral reforzada prevista para las personas cabeza de familia, debido a que no había probado la ausencia de una ayuda sustancial de los demás miembros de su familia. Agregó que la actora podía desarrollar otras alternativas económicas, dada su profesión de contadora y adujo que no se había probado que el padre del hijo de la solicitante estuviera imposibilitado para cumplir con sus deberes alimentarios.

6. De conformidad con los antecedentes reseñados, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional deberá determinar si la acción de tutela es procedente para analizar el posible desconocimiento de los derechos fundamentales de los peticionarios. Establecido lo anterior, deberá resolver el siguiente problema jurídico:

¿Se vulneran los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, al debido proceso, a la dignidad humana, al mínimo vital y a la seguridad social de una mujer que alega ser cabeza de familia —y de su hijo estudiante que depende económicamente de ella— cuando una entidad territorial suprime el cargo que aquella ocupaba, sin garantizar su estabilidad laboral reforzada en el marco del denominado “*retén social*”?

Para abordar los asuntos formulados, la Sala examinará inicialmente la procedencia de la acción de tutela para solicitar la protección de las garantías derivadas de la figura conocida como “*retén social*”. De superarse el análisis de procedibilidad del amparo, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) la condición de madre o padre cabeza de familia en el ordenamiento jurídico, así como los requisitos para acreditarla; (ii) la protección especial de las personas cabeza de familia en el marco de los procesos de restructuración administrativa y las condiciones para pertenecer al denominado “*retén social*”; y, por último, (iii) la solución del caso concreto.

Procedencia de la acción de tutela³³.

Legitimación en la causa por activa y por pasiva

7. Conforme al artículo 86 de la Carta Política, toda persona podrá presentar acción de tutela ante los jueces para procurar la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o algún particular.

Por su parte, el artículo 10º del Decreto 2591 de 1991, regula la legitimación para el ejercicio de la acción de tutela. Dicha norma establece que la solicitud de amparo puede ser presentada: (i) a nombre propio; (ii) a través de representante legal; (iii) por medio de apoderado judicial; o (iv) mediante agente oficioso.

33 Con el objetivo de respetar el precedente constitucional, promover una mayor eficiencia en la administración de justicia y habida cuenta de que la Corte Constitucional ha decantado un estándar para resumir de manera detallada las reglas jurisprudenciales sobre los requisitos de procedencia de la acción de tutela se tomarán como modelo de reiteración los parámetros fijados por la Magistrada Sustanciadora en las sentencias T-583 de 2017, T-401 de 2017, T-340 de 2017, T-163 de 2017, T-662 de 2016, T-594 de 2016 y T-144 de 2016.

8. En particular, respecto de la agencia oficiosa, la Corte Constitucional ha manifestado que esta figura encuentra su fundamento en el principio de solidaridad y pretende proteger los derechos fundamentales de las personas por encima de los requisitos procesales, de conformidad con la prevalencia del derecho sustancial en las actuaciones judiciales.

De este modo, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la agencia oficiosa presenta cuatro elementos característicos: (i) el agente oficioso debe manifestar que actúa como tal; (ii) del escrito de tutela se debe inferir que el titular del derecho está imposibilitado para ejercer la acción de tutela; (iii) la informalidad de la agencia, pues ésta no implica una relación formal entre el agente y el agenciado; y (iv) la ratificación de lo actuado dentro del proceso³⁴.

9. En el caso objeto de estudio, se encuentra acreditado que la ciudadana Omaira Jaqueline Nandar de la Cruz tiene **legitimación por activa** para formular la acción de tutela de la referencia, toda vez que es una persona natural que reclama la protección de sus derechos constitucionales fundamentales, presuntamente vulnerados por la entidad accionada³⁵.

Ahora bien, es oportuno aclarar que Guillermo Alfonso Pasijojoa Nandar era menor de edad para el momento de la interposición de la acción de tutela, motivo por el cual resultaba válido el uso de la agencia oficiosa para la protección de sus derechos. Sin embargo, una vez cumplida su mayoría de edad, el agenciado concurrió al proceso y aportó pruebas, razón por la cual se entiende ratificado el ejercicio desplegado por su madre, en calidad de agente oficiosa, al inicio del trámite de amparo. En consecuencia, se acredita el requisito de legitimación por activa en relación con el joven Pasijojoa Nandar.

10. Por su parte, la **legitimación por pasiva** dentro del trámite de amparo hace referencia a la capacidad legal del destinatario de la acción de tutela para ser demandado, pues está llamado a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental en el evento en que se acredite la misma en el proceso³⁶. Según el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad pública y, excepcionalmente, contra particulares.

34 Véanse, entre otras, las sentencias T-529 de 2015 (M.P. María Victoria Calle Correa), T-294 de 2014 (M.P. Mauricio González Cuervo). *“Los dos primeros elementos, es decir la manifestación del agente y la imposibilidad del agenciado para actuar son constitutivos y necesarios para que opere esta figura. El tercer elemento es de carácter interpretativo y el cuarto que versa sobre la ratificación, se refiere cuando el agenciado ha realizado actos positivos e inequívocos, esta actitud permite sustituir al agente”*.

35 Sentencia T-340 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

36 Sentencias T-401 de 2017 y T-373 de 2015 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

En el asunto de la referencia, se advierte que el Municipio de Ipiales es una entidad territorial y, por tanto, es una autoridad pública con capacidad para ser parte. Por ende, se encuentra legitimado en la causa por pasiva para actuar en este proceso, según los artículos 86 Superior y el 5° del Decreto 2591 de 1991.

Subsidiariedad

11. El principio de subsidiariedad, conforme al artículo 86 de la Constitución, implica que la acción de tutela solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que esta se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En otras palabras, las personas deben hacer uso de todos los recursos ordinarios y extraordinarios que el sistema judicial ha dispuesto para conjurar la situación que amenaza o lesiona sus derechos, de tal manera que se impida el uso indebido de este mecanismo constitucional como vía preferente o instancia judicial adicional de protección.

12. No obstante, como ha sido reiterado por la jurisprudencia constitucional, el presupuesto de subsidiariedad que rige la acción de tutela, debe analizarse en cada caso concreto. Por ende, en aquellos eventos en los que existan otros medios de defensa judicial, esta Corporación ha determinado que existen dos excepciones que justifican su procedibilidad³⁷:

(i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las controversias no es **idóneo y eficaz** conforme a las especiales circunstancias del caso estudiado, procede el amparo como mecanismo definitivo; y,

(ii) cuando, pese a existir un medio de defensa judicial idóneo, éste no impide la ocurrencia de un **perjuicio irremediable**, caso en el cual la acción de tutela procede como **mecanismo transitorio**.

Adicionalmente, cuando el amparo es promovido por personas que requieren especial protección constitucional, como niños, niñas y adolescentes, mujeres en estado de gestación o de lactancia, madres cabeza de familia, personas en situación de discapacidad, de la tercera edad o población desplazada, entre otros, el examen de procedencia de la tutela se hace menos estricto, a través de criterios de análisis más amplios, pero no menos rigurosos³⁸.

Las anteriores reglas implican que, de verificarse la existencia de otros medios judiciales, siempre se debe realizar una evaluación de la idoneidad de los mismos en el caso concreto, para determinar si aquellos tienen la capacidad de restablecer de forma efectiva e integral los derechos invocados. Este análisis debe ser sustancial (no simplemente formal) y reconocer que el juez de tutela

37 Sentencia T-662 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

38 Sentencias T-163 de 2017 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado); T-328 de 2011 M.P. (Jorge Ignacio Pretelt Chaljub); T-456 de 2004 (M.P. Jaime Araujo Rentería), T-789 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-136 de 2001 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes), entre otras.

no puede suplantar al juez ordinario. Por tanto, en caso de evidenciar la falta de idoneidad del otro mecanismo formalmente disponible, la acción puede proceder de forma definitiva.

13. Así, dentro del ordenamiento jurídico colombiano existen varios mecanismos de defensa para salvaguardar los derechos laborales, competencia asignada a las jurisdicciones ordinaria laboral o contencioso administrativa, según el caso. Como consecuencia de ello, la Corte Constitucional ha manifestado que la acción de tutela, en principio, no resulta procedente para solicitar el reintegro de empleados públicos a los cargos que ocupaban, pues para controvertir los actos administrativos por medio de los cuales la administración decide separarlos de los mismos, existe la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso administrativa, la cual desplaza a la acción de tutela³⁹.

No obstante lo anterior, este Tribunal ha admitido la procedencia excepcional de la tutela para solicitar el reintegro de servidores públicos a los cargos de los que han sido desvinculados, cuando en el caso concreto se advierte la vulneración de un derecho fundamental y se evidencia la ocurrencia de un perjuicio irremediable, toda vez que en estos eventos la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en principio, no proporciona una protección eficaz y adecuada a los derechos amenazados o vulnerados⁴⁰.

14. Ahora bien, en el escenario específico de quienes alegan su calidad de beneficiarios del denominado “*retén social*”, la jurisprudencia constitucional ha sostenido, **de manera reiterada y uniforme**, que la acción de tutela es procedente para reclamar dicha condición por dos motivos principalmente:

(i) Las personas beneficiarias del “*retén social*” son sujetos de especial protección que, además, se encuentran en situaciones de particular vulnerabilidad, dado que se trata de madres o padres cabeza de familia, personas en situación de discapacidad o próximas a pensionarse⁴¹.

(ii) Los efectos del “*retén social*” se producen dentro del marco de procesos de reestructuración administrativa que culminan rápidamente. Por tanto, la jurisdicción contencioso administrativa no es el mecanismo idóneo ni eficaz para reclamar los beneficios derivados de estos programas pues se hace

39 Véanse, entre otras: sentencia T-595 de 2016 (M.P. Alejandro Linares Cantillo), sentencia T-326 de 2014 (M.P. María Victoria Calle Correa).

40 Véanse, entre otras: sentencia T-595 de 2016 (M.P. Alejandro Linares Cantillo), sentencia T-326 de 2014 (M.P. María Victoria Calle Correa).

41 Sentencia T-420 de 2017. M.P. Cristina Pardo Schlesinger; sentencia SU-897 de 2012 (M.P. Alexei Julio Estrada); sentencia T-034 de 2010. (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio); sentencia T-179 de 2008. (M.P. Cristina Pardo Schlesinger); sentencia T-200 de 2006 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra); sentencia SU-388 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández); sentencia SU-389 de 2005 (M.P. Jaime Araújo Rentería).

predecible que para cuando se produzca el fallo contencioso administrativo “la respectiva entidad ya se encuentre liquidada y no se tenga a quien reclamar el reintegro laboral y el pago de los respectivos salarios”⁴².

Acerca de esta última fundamentación, la Sala recuerda que las características propias de los procesos de reestructuración tanto para la administración como para los trabajadores, implican que resulte necesario acudir a la acción de tutela en este tipo de situaciones, cuando los mecanismos ordinarios sean insuficientes para proteger los derechos fundamentales con la prontitud suficiente. De este modo, aunque no se trate de la supresión o liquidación de una entidad pública, es necesario reconocer que **los procesos de reestructuración también implican un grado importante de celeridad en su ejecución**, por lo que las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo pueden devenir ineficaces en este tipo de casos.

Adicionalmente, pese a que las entidades no desaparecen con posterioridad a su reestructuración, cabe destacar que estos procesos se caracterizan por la supresión de cargos, la modificación de sus funciones y, en general, la reacomodación de la planta de personal de la institución respectiva. Por ende, es necesario resaltar que estos cambios en la estructura de la administración pueden implicar que los medios judiciales ordinarios no resulten idóneos ni efectivos para asegurar las garantías constitucionales de los trabajadores que afirman su pertenencia al retén social, pues es probable que la reorganización administrativa haya concluido y se haya consolidado la reestructuración para el momento en que se produzca la decisión definitiva en sede jurisdiccional.

15. En consonancia con lo anterior, la Corte Constitucional ha admitido invariablemente que **la acción de tutela es procedente para solicitar la protección derivada del “retén social” en procesos de reestructuración administrativa, aun cuando no se presenta la supresión o liquidación de la entidad pública**. Esta ha sido la *ratio decidendi* que esta Corporación

42 Ver sentencias SU-897 de 2012 (M.P. Alexei Julio Estrada); T-1239 de 2008 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-989 de 2008 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández) y T-009 de 2008 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), entre otras.

acogió en las sentencias **T-846 de 2005**⁴³, **T-724 de 2009**⁴⁴, **T-862 de 2009**⁴⁵, **T-623 de 2011**⁴⁶, **T-802 de 2012**⁴⁷, **T-316 de 2013**⁴⁸ y **T-420 de 2017**⁴⁹, entre otras.

16. En el asunto bajo estudio, se estima que los mecanismos de la jurisdicción contencioso administrativa no gozan de la idoneidad y efectividad suficientes para garantizar la protección de los derechos fundamentales invocados por la accionante Omaira Jaqueline Nandar de la Cruz.

43Sentencia T-846 de 2005 (M.P. Rodrigo Escobar Gil). La accionante se desempeñaba como funcionaria del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y alegaba su condición de madre cabeza de familia. En el marco de un proceso de reestructuración administrativa, el cargo que ocupaba fue suprimido de la planta de personal. En esta oportunidad, la Sala Quinta de Revisión consideró que la acción de tutela era procedente para la protección de los derechos fundamentales de la actora de manera definitiva.

44Sentencia T-724 de 2009 (M.P. Mauricio González Cuervo). El actor ocupaba el cargo de Agente de Tránsito Grado 1 en la Alcaldía Municipal de Palmira, el cual fue suprimido en desarrollo de un proceso de reestructuración administrativa. En razón de esta circunstancia, el trabajador desvinculado presentó una acción de tutela, por considerar que tenía la calidad de padre cabeza de familia. La Sala Quinta de Revisión estimó que el amparo constitucional era el mecanismo procedente para determinar la vulneración de los derechos de la tutelante.

45Sentencia T-862 de 2009 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio). La actora se encontraba vinculada al Municipio de Palmira. No obstante, su cargo fue suprimido en el marco de un proceso de renovación administrativa iniciado por la entidad territorial. La tutelante alegaba su calidad de prepensionada. La Sala Novena de Revisión consideró que la acción de tutela era el mecanismo judicial procedente para proteger los derechos fundamentales de la solicitante.

46Sentencia T-623 de 2011 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). El actor ocupaba en provisionalidad un cargo dentro de la planta de personal del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). No obstante, en el marco de un proceso de reestructuración administrativa, el tutelante fue desvinculado y acudió a la acción de tutela para solicitar la protección derivada del “*retén social*”. La Sala Octava de Revisión indicó que el amparo constitucional era el medio idóneo y procedente para determinar si existía una violación a los derechos fundamentales del tutelante.

47Sentencia T-802 de 2012 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio). El accionante fue desvinculado de la Contraloría Departamental de Antioquia en desarrollo del proceso de reestructuración de dicha entidad. El tutelante indicaba que tenía la condición de prepensionado y que, por tanto, no podía ser retirado de la institución. La Sala Quinta de Revisión estimó que la acción de tutela era el medio judicial que procedía para salvaguardar los derechos fundamentales del actor.

En este sentido, la Sala evidencia que en el presente caso concurren los supuestos que, para la Corte Constitucional, justifican la procedencia de la acción de tutela cuando se alega el desconocimiento de la garantía de estabilidad laboral derivada del denominado “*retén social*”.

17. Por una parte, **la accionante se encuentra en una situación de vulnerabilidad agravada por la desvinculación de su cargo**, en la medida en que ha debido contraer varias deudas y hasta recurrir a hipotecar sus bienes con el fin de garantizar su propio sustento y la educación de su hijo⁵⁰. Por otra, es claro que el retiro de la actora se produjo en el marco de un proceso de reestructuración administrativa, de conformidad con la motivación del Decreto 016 de 2017⁵¹, expedido por la administración municipal de Ipiales.

48Sentencia T-316 de 2013 (M.P. Alberto Rojas Ríos). En el caso del expediente T-3.755.895, la accionante se desempeñaba en provisionalidad como Técnico Administrativo en la Alcaldía Municipal de Momil (Córdoba). En el marco del proceso de modernización y reestructuración de la administración central del municipio, se suprimió el cargo que ocupaba la actora. En este caso, la tutelante solicitaba la protección derivada del “*retén social*”, debido a que alegaba su calidad de madre cabeza de familia y la Sala Octava de Revisión consideró que la acción de tutela era el mecanismo procedente para la protección de los derechos de la solicitante. Al respecto, señaló la Corte: “[b]aste mencionar que esta posición de la Sala Octava es acorde con una línea jurisprudencial pacífica y constante respecto de la procedibilidad de la acción de tutela en casos como el que ahora se decide”.

49Sentencia T-420 de 2017 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger). La tutelante ocupaba el cargo de Inspectora de Policía y Tránsito en la Alcaldía de Toro (Valle del Cauca), el cual fue suprimido en el marco de un proceso de reestructuración administrativa. Debido a lo anterior, la funcionaria presentó una acción de tutela por considerar que tenía las calidades de madre cabeza de familia y persona con discapacidad. La Sala Séptima de Revisión estimó que el amparo constitucional es el mecanismo procedente para estudiar si la actora era titular de los derechos fundamentales invocados. Al respecto, indico que: “*la acción de tutela es procedente, toda vez que esta hace parte del retén social, pues i) la entidad para la cual laboraba fue objeto de reestructuración administrativa, ii) por aducir tener una pérdida de capacidad laboral y iii) ser madre cabeza de familia, es decir, al encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad*”.

50 La accionante precisó que, entre marzo y diciembre de 2016, se vio obligada a asumir deudas por \$10.300.000, para el pago de la matrícula y los gastos de sostenimiento de su hijo. Por tal motivo, relata que en junio de 2017 hipotecó el inmueble del cual es propietaria por un valor de \$20.000.000. (Folio 49, Cuaderno de Revisión de la Corte Constitucional). Adicionalmente, a folios 54 a 56 del Cuaderno de Revisión de la Corte Constitucional constan los recibos de servicios públicos de dicha vivienda que se encuentran en mora y con aviso de suspensión.

51 Cuaderno No. 1, folios 48-55. El referido acto administrativo se fundamentó en que el alcalde municipal de Ipiales modificó la estructura

Sobre este aspecto, es pertinente resaltar que con posterioridad a la decisión de tutela de segunda instancia, la tutelante celebró un contrato de prestación de servicios con la Alcaldía Municipal de Pupiales cuyos honorarios ascendían a un poco más de tres salarios mínimos. No obstante, **este aspecto por sí solo no descarta la procedencia de la acción de tutela**, en la medida en que las condiciones de vulnerabilidad de la accionante **no pueden ser analizadas en abstracto sino que deben ser consideradas en función de las circunstancias particulares y concretas de la actora**⁵². Además, se debe resaltar que dicha vinculación ya culminó⁵³ y fue temporal⁵⁴ y posterior a la presentación de la acción de tutela.

Por consiguiente, aunque estos recursos económicos hayan podido aliviar temporalmente algunas de las dificultades por las que atraviesa la accionante, la Sala estima que la situación de vulnerabilidad no se superó definitivamente, habida cuenta de las necesidades que tanto la accionante como su hijo demostraron en el proceso. De este modo, persiste el riesgo de que el joven Guillermo Alfonso Pasijojoa Nandar deba suspender o abandonar sus estudios o que la actora vea amenazado o vulnerado gravemente su mínimo vital, en razón de las condiciones económicas que demostró en el expediente⁵⁵.

Por otro lado, se encuentra probado que **el Municipio de Ipiales emprendió un proceso de reestructuración administrativa**. Al respecto, cabe señalar que, como se expuso en párrafos anteriores, este tipo de modificaciones a la

organizacional del municipio, con lo cual se requirió actualizar la planta global de empleos para incorporar las modificaciones necesarias para implementar y desarrollar la nueva estructura. En tal sentido, se evidencia que la reforma de la planta de personal se enmarca en un proceso de modernización institucional.

52Sentencia T-269 de 2017 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez).

53De conformidad con la información pública disponible en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), el contrato de prestación de servicios profesionales CD 062-2017, suscrito entre la Alcaldía Municipal de Pupiales y Omaira Jaqueline Nandar de la Cruz, **registra como fecha de terminación el 26 de diciembre de 2017** y fue liquidado el 15 de enero de 2018.

54De acuerdo con la información disponible en el SECOP, el contrato duró menos de seis meses.

55La accionante precisó que, entre marzo y diciembre de 2016, se vio obligada a asumir deudas por \$10.300.000, para el pago de la matrícula y los gastos de sostenimiento de su hijo. Por tal motivo, relata que en junio de 2017 hipotecó el inmueble del cual es propietaria por un valor de \$20.000.000. (Folio 49, Cuaderno de Revisión de la Corte Constitucional). Adicionalmente, a folios 54 a 56 del Cuaderno de Revisión de la Corte Constitucional constan los recibos de servicios públicos de dicha vivienda que se encuentran en mora y con aviso de suspensión.

estructura de la administración se caracterizan por su celeridad, pues con ellas se busca optimizar el cumplimiento de la función administrativa.

En consecuencia, se acreditan las dos circunstancias que tornan procedente la acción de tutela cuando se alega el desconocimiento de los derechos fundamentales de una persona que afirma ser titular de la protección derivada del “*retén social*”.

18. Con todo, no puede perderse de vista que las modificaciones legislativas introducidas mediante la Ley 1437 de 2011 para garantizar la protección de los derechos fundamentales en el marco de los procesos contenciosos administrativos, en particular aquellas orientadas a mejorar la efectividad de las medidas cautelares⁵⁶, podrían implicar la improcedencia de la acción de tutela para los casos en los cuales se reclama el desconocimiento de la estabilidad reforzada propia del llamado “*retén social*”.

No obstante, la Sala advierte que, con posterioridad a la expedición de la Ley 1437 de 2011, la jurisprudencia constitucional ha estimado de manera uniforme y reiterada que la acción de tutela es el mecanismo judicial procedente para discutir la posible vulneración de derechos fundamentales originada en la desvinculación de servidores públicos que alegan ser titulares de estabilidad laboral en el marco de procesos de reestructuración administrativa⁵⁷.

Además, se debe recordar que esta Corporación ha señalado que, pese a “*los importantes cambios legislativos que en materia de medidas cautelares introdujo la Ley 1437 de 2011 (...) la acción de tutela podría proceder; entre otros eventos, (i) cuando la aplicación de las normas del CPACA no proporcione una protección oportuna de los derechos fundamentales o (ii) cuando el contenido o interpretación de las disposiciones de dicho Código no provean un amparo integral de tales derechos*”⁵⁸.

19. Finalmente, es pertinente resaltar que la supresión del cargo que ocupaba la actora fue comunicada mediante un oficio, en el cual no se informaba acerca de la posibilidad de presentar los recursos respectivos en sede

56 Véanse, entre otras, las sentencias: T-595 de 2016 (M.P. Alejandro Linares Cantillo), T-376 de 2016 (M.P. Alejandro Linares Cantillo), SU-355 de 2015 (M.P. Mauricio González Cuervo), T-733 de 2014 (M.P. Mauricio González Cuervo).

57 Sentencias T-802 de 2012 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio); T-835 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva); SU-897 de 2012 (M.P. Alexei Julio Estrada); T-186 de 2013 (M.P. Alberto Rojas Ríos); T-316 de 2013 (M.P. Alberto Rojas Ríos); T-326 de 2014 (M.P. María Victoria Calle Correa); T-400 de 2014 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio); T-595 de 2016 (M.P. Alejandro Linares Cantillo); T-638 de 2016 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio); T-420 de 2017 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger); T-460 de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos), entre otras.

58 Sentencia SU-355 de 2015 (M.P. Mauricio González Cuervo).

administrativa. En este sentido, aunque la tutelante no agotó tales medios de impugnación, ello no conduce a la improcedencia de la acción de tutela por cuanto: (i) el acto administrativo que desvinculó a la accionante no señaló expresamente que cabían recursos en contra del mismo, con lo cual se configura la hipótesis prevista en el segundo inciso del numeral 2° del artículo 161 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)⁵⁹. Además, se debe tener en cuenta que la solicitante no posee formación jurídica; y (ii) en cualquier caso, de conformidad con el artículo 9° del Decreto 2591 de 1991⁶⁰, no resulta necesario interponer recursos administrativos como requisito previo a la formulación de la acción de tutela.

20. Por consiguiente, la acción de tutela es el mecanismo judicial idóneo para la protección de los derechos fundamentales de la accionante Omaira Jaqueline Nandar de la Cruz y de su hijo Guillermo Alfonso Pasijojoa Nandar. En efecto, como lo advirtió el juez de segunda instancia, la Corte Constitucional ha considerado que el amparo es el medio judicial procedente cuando se invoca la protección derivada del “*retén social*”, debido a la celeridad que requieren los procesos de reestructuración de la administración pública.

De este modo, de conformidad con la jurisprudencia constitucional previamente expuesta, la acción de tutela es procedente en el presente caso dado que la tutelante fue desvinculada en el marco de un proceso de reestructuración y alega su condición de mujer cabeza de familia (asunto que es objeto de debate en el proceso de la referencia).

Inmediatez

21. El principio de inmediatez previsto en el referido artículo 86 Superior, es un límite temporal para la procedencia de la acción de tutela. De acuerdo con este mandato, la interposición del amparo debe hacerse dentro de un plazo razonable, oportuno y justo⁶¹, toda vez que su razón de ser es la protección

59 “**Artículo 161. Requisitos previos para demandar.** La presentación de la demanda se someterá al cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos: (...) 2. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular deberán haberse ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios. (...) **Si las autoridades administrativas no hubieran dado oportunidad de interponer los recursos procedentes, no será exigible el requisito al que se refiere este numeral.**”

60 “**Artículo 9°. Agotamiento opcional de la vía gubernativa.** No será necesario interponer previamente la reposición y otro recurso administrativo para presentar la solicitud de tutela. El interesado podrá interponer los recursos administrativos, sin perjuicio de que ejerza directamente en cualquier momento la acción de tutela”.

61 Sentencia T-834 de 2005. (M.P. Clara Inés Vargas Hernández); sentencia T-887 de 2009. (M.P. Mauricio González Cuervo).

inmediata y urgente de los derechos fundamentales⁶². En este orden de ideas, la Corte Constitucional ha establecido que para acreditar el cumplimiento del requisito de inmediatez, el juez debe constatar si el tiempo transcurrido entre la supuesta violación o amenaza y la presentación de la acción de tutela es razonable⁶³.

22. En el asunto de la referencia, el requisito de inmediatez se encuentra verificado toda vez que entre la fecha en que la accionante Omaira Jaqueline Nandar de la Cruz fue notificada de la supresión del cargo que desempeñaba (2 de febrero de 2017, en virtud de la comunicación recibida el día anterior) y el momento en el cual se interpuso la acción de tutela (10 de marzo de 2017), transcurrió un lapso de un mes y ocho días.

23. Con fundamento en lo anterior, se encuentra establecida la procedencia de la acción de tutela en el presente caso. Por tanto, a continuación se presentarán los aspectos de fondo anunciados para pasar a la solución del problema jurídico formulado.

La condición de madre cabeza de familia en el ordenamiento jurídico y los requisitos para acreditarla.

24. Desde sus primeros pronunciamientos, esta Corporación ha destacado que las mujeres cabeza de familia son titulares de una especial protección constitucional⁶⁴, garantía que se deriva de varias fuentes⁶⁵:

(i) El principio de igualdad, que implica el deber de reconocer y brindar un trato especial y diferenciado a los grupos de personas que tienen un alto grado de vulnerabilidad o que se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y la consecuente obligación del Estado de promover acciones y medidas para que la igualdad sea real y efectiva⁶⁶.

(ii) El mandato constitucional específico contenido en el artículo 43 Superior, según el cual, es deber del Estado apoyar “*de manera especial a la mujer*

62 Sentencia T-401 de 2017. (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado); sentencia T-246 de 2015. M.P. (Martha Victoria Sáchica Méndez).

63 Sentencia T-246 de 2015. (M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez).

64 Véanse, entre muchas otras, las sentencias: T-692 de 2016 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo); T-1163 de 2008 (M.P. Jaime Araújo Rentería); C-722 de 2004 (M.P. Rodrigo Escobar Gil); C-184 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa); T-414 de 1993 (M.P. Carlos Gaviria Díaz).

65 Sentencias SU-389 de 2005. (M.P. Jaime Araújo Rentería); SU-388 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández); C-722 de 2004 (M.P. Rodrigo Escobar Gil); C-044 de 2004 (M.P. Jaime Araújo Rentería); C-1039 de 2003 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra); C-964 de 2003 (M.P. Álvaro Tafur Galvis); C-184 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).

66 Sentencias C-722 de 2004 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).

cabeza de familia”.

(iii) Los instrumentos internacionales de derechos humanos, particularmente la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), en cuyo artículo 11 se establece la obligación de los Estados Partes de adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación en la esfera del empleo, así como los prejuicios y las funciones estereotipadas de cada uno de los sexos⁶⁷.

(iv) La garantía del derecho de toda persona a recibir protección integral para su grupo familiar, establecido en el artículo 42 de la Constitución Política, así como la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, prevista en el artículo 44 Superior⁶⁸.

25. En razón de lo anterior y en cumplimiento de su deber constitucional de garantizar la igualdad material de los grupos vulnerables o históricamente discriminados, el Legislador ha diseñado e implementado diversas medidas, las cuales se conocen como **acciones afirmativas**⁶⁹. Particularmente, en el

67Sobre este particular, es conveniente citar el análisis vertido en la sentencia C-184 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), en el cual se explicó lo siguiente: *“Como se indicó, uno de los roles que culturalmente se impuso a la mujer fue el de “encargada del hogar” como una consecuencia del ser “madre”, de tal suerte que era educada y formada para desempeñar las tareas del hogar, encargarse de los hijos y velar por aquellas personas dependientes, como los ancianos. Sin desconocer la importancia que juega toda mujer, al igual que todo hombre, dentro de su hogar, el constituyente de 1991 quiso equilibrar las cargas al interior de la familia, tanto en las relaciones de poder intrafamiliar, como en cuanto a los deberes y las obligaciones de las que cada uno es titular. // Suponer que el hecho de la “maternidad” implica que la mujer debe desempeñar ciertas funciones en la familia, ha llevado, por ejemplo, a que tengan que soportar dobles jornadas laborales: una durante el día como cualquier otro trabajador y otra en la noche y en sus ratos libres, desempeñando las labores propias de la vida doméstica. Esta imagen cultural respecto a cuál es el papel que debe desempeñar la mujer dentro de la familia y a cuál “no” es el papel del hombre respecto de los hijos, sumada al incremento de separaciones, así como al número creciente de familias sin padre por cuenta del conflicto armado y la violencia generalizada, trajo como consecuencia que una cantidad considerable de grupos familiares tuvieran una mujer como cabeza del mismo”.*

68Sentencia C-044 de 2004 (M.P. Jaime Araújo Rentería).

69Sobre la naturaleza de las acciones afirmativas, la Sentencia C-371 de 2000 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) explicó lo siguiente: *“con esta expresión se designan políticas o medidas dirigidas a favorecer a determinadas personas o grupos, ya sea con el fin de eliminar o reducir las desigualdades de tipo social, cultural o económico que los afectan, bien de lograr que los miembros de un grupo subrepresentado, usualmente un grupo que ha sido discriminado,*

caso de las mujeres cabeza de familia, existen varias normas encaminadas a este propósito⁷⁰.

26. En este sentido, el Congreso de la República expidió la **Ley 82 de 1993**⁷¹. En esta normativa, se estableció una definición de mujer cabeza de familia y se incorporaron medidas de protección especial en materia educativa, de seguridad social, apoyo al emprendimiento, acceso a vivienda, entre otros incentivos especiales.

El artículo 2° de la ley reseñada definió a la mujer cabeza de familia como aquella que, sin importar su estado civil, tuviera bajo su cargo *“económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar”*⁷².

27. La **Ley 1232 de 2008**⁷³, reformó la anterior normativa e introdujo dos elementos a la anterior definición: (i) precisó que la mujer cabeza de familia es quien ejerce la *“jefatura femenina del hogar”* y (ii) señaló que aquella puede tener personas a cargo en el plano económico, social o afectivo. Adicionalmente, fortaleció las medidas de protección en favor de las mujeres cabeza de familia.

28. En suma, esta Corporación ha establecido que *“el apoyo especial a la mujer cabeza de familia es un mandato constitucional dirigido a todas las autoridades públicas. Con él se buscó (i) promover la igualdad real y efectiva entre ambos sexos; (ii) reconocer la pesada carga que recae sobre una mujer cabeza de familia y crear un deber estatal de apoyo en todas las esferas de su tengan una mayor representación”*.

70En el caso de las madres cabeza de familia, el Legislador y el Gobierno Nacional **han implementado varias acciones afirmativas** con el fin de proteger especialmente sus derechos. Dentro de este marco normativo, se destacan las siguientes:

(i) En materia penal, cuando el infractor o infractora es padre o madre cabeza de familia, se permite ejecutar la pena privativa de la libertad en su residencia o en el lugar señalado por el juez, de conformidad con las condiciones previstas en la ley (Ley 750 de 2002 y Sentencia C-184 de 2003).

(ii) La calidad de mujer cabeza de familia es un criterio de priorización para la entrega de ayuda humanitaria de emergencia y de indemnización administrativa para las víctimas del conflicto armado, así como para el acceso a diversos programas educativos y sociales diseñados para esta población (Véanse, entre otros instrumentos: la Ley 1448 de 2011, la Ley 1232 de 2008 y el Decreto 1377 de 2014).

(iii) La posibilidad de constituir el único bien inmueble de la mujer o el hombre cabeza de familia como patrimonio familiar inembargable (Ley 861 de 2003).

(iv) El derecho a acceder a la pensión especial de vejez, prevista por la ley para las madres y padres cabeza de familia que tengan a su cargo un hijo con discapacidad (Ley 797 de 2003).

71 *“Por la cual se expiden normas para apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia”*

72Artículo 2° de la Ley 82 de 1993.

73 *“Por la cual se modifica la Ley 82 de 1993, Ley Mujer Cabeza de Familia y se dictan otras disposiciones”*

*vida y de su desarrollo personal, para compensar, aliviar y hacer menos gravosa la carga de sostener su familia; y (iii) brindar, de esta manera, una protección a la familia como núcleo básico de la sociedad”*⁷⁴.

29. Ahora bien, la Corte Constitucional ha señalado que algunas acciones afirmativas que se diseñaron para beneficiar a las mujeres cabeza de familia también son aplicables a los hombres que se encuentran a cargo de hijos menores de edad o en situación de discapacidad⁷⁵.

Sin embargo, el fundamento de dicha extensión **no radica en el principio de igualdad**, en la medida en que la situación de las mujeres cabeza de familia no es equiparable a la de los hombres que se encuentran en esta misma condición, como lo ha establecido este Tribunal⁷⁶.

En efecto, la Corte ha considerado que el Legislador está facultado para establecer acciones afirmativas exclusivamente en favor de las mujeres cabeza de familia pues, *“si todos los beneficios que se establecen para la mujer cabeza de familia debieran otorgarse al hombre que se encuentra en la misma situación, ningún efecto tendría entonces la protección especial ordenada por el Constituyente para la mujer cabeza de familia”*⁷⁷.

No obstante, la prevalencia de los derechos de los niños y la especial protección de las personas en situación de discapacidad exigen que aquellas acciones afirmativas en favor de las mujeres cabeza de familia que también se orientan a la salvaguarda de los sujetos vulnerables a su cargo, deban

74 Sentencia C-184 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

75 Sentencia C-722 de 2004. M.P. Rodrigo Escobar Gil; sentencia C-044 de 2004 M.P. Jaime Araújo Rentería; sentencia C-1039 de 2003. M.P. Alfredo Beltrán Sierra; sentencia C-964 de 2003. M.P. Álvaro Tafur Galvis; sentencia C-184 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

76 *“No se pueden confundir dos derechos claramente distintos, ambos protegidos por el principio de igualdad. El primer derecho consiste en que los hombres y las mujeres sean tratados por igual, es decir, se consagra la específica prohibición de discriminación por razones de sexo. El segundo derecho consiste en que las mujeres, habida cuenta de una histórica e innegable tradición de discriminación sexual que el constituyente no sólo quiso abolir sino remediar, sean titulares de medidas legislativas específicas en favor de ellas, no de los hombres. Son las ya relacionadas acciones afirmativas, dirigidas a eliminar situaciones de discriminación existentes. En este orden de ideas, (...) el derecho a la igualdad de trato no exige, por sí solo, extender a un hombre un beneficio creado por el legislador para desarrollar el derecho constitucional -específicamente consagrado en el artículo 43- en favor de las mujeres a recibir medidas de apoyo o protección especial como un tipo de acción afirmativa”*. (Sentencia SU-389 de 2005. M.P. Jaime Araújo Rentería). Véase también, sentencia T-846 de 2005 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).

77 Sentencia C-964 de 2003. M.P. Álvaro Tafur Galvis.

extenderse igualmente a los padres cabeza de familia⁷⁸. Lo anterior, por cuanto “no es posible establecer una diferencia entre los hijos que dependen de la mujer cabeza de familia frente a los que dependen del hombre”⁷⁹ que se encuentra en una situación fáctica similar.

30. En este orden de ideas, es claro que **la condición de mujer cabeza de familia presenta características particulares** que se derivan del contexto histórico de la desigualdad entre ambos sexos, por lo cual tiene connotaciones diversas a la situación de los hombres que ejercen la jefatura del hogar de manera exclusiva.

Sin embargo, desde el punto de vista de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, personas en situación de discapacidad y otros sujetos vulnerables que dependen de la persona cabeza de familia, sería contrario a la Constitución establecer diferencias de trato entre los hogares, fundadas en el sexo de la persona que se encuentra a cargo de la familia.

Por lo tanto, en atención al principio de igualdad respecto de los menores de edad y sus derechos prevalentes, la Corte Constitucional ha extendido a los padres cabeza de familia varias medidas de protección que el Legislador adoptó para las mujeres cabeza de familia, entre ellas la inclusión en el denominado “*retén social*”.

31. Corresponde ahora abordar los elementos de la definición de madre cabeza de familia desarrollados por la jurisprudencia constitucional, a partir del concepto establecido en la ley.

Al respecto, es indispensable aclarar —como lo ha hecho la Corte Constitucional en reiterados pronunciamientos⁸⁰— que **no toda mujer, por el hecho de que esté a su cargo la dirección del hogar, ostenta la calidad de cabeza de familia**, pues para tener tal condición se requiere la constatación de varios elementos⁸¹, los cuales se enuncian en los párrafos siguientes.

78Sentencia C-722 de 2004. M.P. Rodrigo Escobar Gil; sentencia C-044 de 2004 M.P. Jaime Araújo Rentería; sentencia C-1039 de 2003. M.P. Alfredo Beltrán Sierra; sentencia C-964 de 2003. M.P. Álvaro Tafur Galvis; sentencia C-184 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

79Sentencia C-964 de 2003. M.P. Álvaro Tafur Galvis.

80 Véanse, entre otras, las sentencias T-420 de 2017 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger); T-400 de 2014 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio); SU-377 de 2014 (M.P. María Victoria Calle Correa); T-835 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva); T-034 de 2010 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio); T-200 de 2006 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra); T-834 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández) SU-388 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández).

81Las consideraciones que se presentan a continuación, particularmente aquellas que se refieren a los requisitos que se deben cumplir para acreditar la condición de madre cabeza de familia, se retoman a partir de la sentencia de unificación SU-388 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), la cual ha

32. En primer lugar, se requiere que la mujer **tenga a su cargo la responsabilidad de hijos menores de edad o de otras personas “incapacitadas” para trabajar**, exigencia respecto de la cual la Corte Constitucional ha formulado varias precisiones:

- i) Esta noción implica que la madre cabeza de familia es quien brinda un sustento económico, social o afectivo al hogar, de modo que aquella debe cumplir con sus obligaciones de apoyo, cuidado y manutención con los sujetos a cargo⁸².

sido utilizada como fundamento para definir tales exigencias en la mayoría de decisiones posteriores. Estos elementos han sido reiterados en las sentencias T-420 de 2017 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger); T-400 de 2014 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio); SU-377 de 2014 (M.P. María Victoria Calle Correa); T-316 de 2013 (M.P. Alberto Rojas Ríos); T-835 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva); T-034 de 2010 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio); T-827 de 2009 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez); T-993 de 2007 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa); T-200 de 2006 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra); T-1030 de 2005 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto); T-834 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández).

82En esta materia, son aplicables las consideraciones que al respecto presentó la sentencia SU-389 de 2005 (M.P. Jaime Araújo Rentería), en la cual se estableció como requisito para los padres cabeza de familia *“que sus obligaciones de apoyo, cuidado y manutención sean efectivamente asumidas y cumplidas, pues se descarta todo tipo de procesos judiciales y demandas que se sigan contra los trabajadores por inasistencia de tales compromisos (...)”*. Así mismo, la Corte Constitucional ha sostenido que *“al momento de estudiar los requisitos que debe reunir un servidor público que alega tener la condición de padre cabeza de familia para acceder a la estabilidad laboral reforzada que brinda el denominado retén social, debe observarse el cumplimiento de los mismos en función de las personas sobre las cuales se pretende hacer efectivo el beneficio, con una valoración que lleve al convencimiento acerca del efectivo cuidado brindado al menor o al hijo mayor discapacitado, y no únicamente sobre la base de análisis abstractos en torno al comportamiento del padre de familia en la satisfacción de obligaciones simplemente pecuniarias.”* (Sentencia T-353 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).

- ii) Igualmente, la Corte Constitucional⁸³ y la Corte Suprema de Justicia⁸⁴ han explicado que se consideran mujeres cabeza de familia aquellas que, aun cuando no ejercen la maternidad por no tener hijos propios, se hacen cargo de sus padres o de personas muy allegadas siempre y cuando ellas constituyan el “*núcleo y soporte exclusivo de su hogar*”.
- iii) Así mismo, la jurisprudencia constitucional ha aclarado que una mujer no pierde su condición de *cabeza de familia* por el hecho de que las personas a su cargo alcancen la mayoría de edad⁸⁵. De este modo, cuando se trata de hijos mayores de edad pero menores de 25 años que se encuentran estudiando, esta Corporación ha considerado que siguen siendo dependientes de la madre cabeza de familia⁸⁶.

83 Véase, por ejemplo, la **sentencia T-200 de 2006 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra)**. En este fallo, la Sala Sexta de Revisión amparó los derechos fundamentales de varias personas desvinculadas del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), entre las que se encontraban dos trabajadoras quienes alegaban su calidad de “*mujeres cabeza de familia*”. La primera de ellas, señaló que dependían de ella su padre -85 años-, su madre -76 años-, quienes sufrían de enfermedades cardiovasculares severas, y dos sobrinas menores de edad abandonadas por su madre a muy corta edad. Respecto de su caso, la Sala consideró que “*que la demandante probó su condición de madre cabeza de familia, dado que la misma es núcleo y soporte exclusivo de su hogar*”. La segunda, indicó que, a pesar de tener una hija mayor de edad, respondía por su madre de 71 años, “*que padece de cáncer de piel, entre otras dolencias – hipertensión y osteoporosis- y no recibe pensión por concepto alguno*”, por lo que dependía en su totalidad del salario que la actora devengaba.

84 **Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia de 12 de febrero de 2014. Rad. 43.118 M.P. Rigoberto Echeverri Bueno.** Sobre el particular, la providencia indicó: “*Una lectura exegética de la anterior definición de «madre cabeza de familia», conllevaría a determinar que bajo dicho rótulo sólo se puede ubicar a las «mujeres», que tienen «hijos» menores de edad o inválidos que dependen económicamente y de manera exclusiva de ellas. Sin embargo, para la Corte el concepto de «madre cabeza de familia» debe integrarse armónicamente con el de «mujer cabeza de familia», a la que el Estado le debe una especial protección, según el artículo 43 de la Constitución Política, y que se encuentra desarrollado en el artículo 2 de la Ley 82 de 1993 (...) // Así las cosas, **madre cabeza de familia no sólo es la mujer con hijos menores o inválidos, sino también aquella que tiene a su cargo exclusivo la responsabilidad económica del hogar, por la incapacidad para trabajar de los demás miembros, debidamente comprobada.**”*

85 Véanse, entre otras: sentencia T-420 de 2017 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger); sentencia T-835 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva); sentencia T-827 de 2009 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez); sentencia T-034 de 2010 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio); sentencia T-283 de 2006 (M.P. Álvaro Tafur Galvis).

86 Lo anterior, por cuanto se ha interpretado que, cuando en la definición legal de madre cabeza de familia se alude a las personas “*incapacitadas para*

33. En segundo lugar, se requiere que **la responsabilidad exclusiva** de la mujer en la jefatura del hogar **sea de carácter permanente**. Es por esta razón que *“la mera circunstancia del desempleo y la vacancia temporal de la pareja, o su ausencia transitoria, por prolongada y desafortunada que resulte, no constituyen elementos a partir de los cuales pueda predicarse que una madre tiene la responsabilidad exclusiva del hogar en su condición de madre cabeza de familia”*.

Aunado a ello, se debe destacar que el trabajo doméstico, con independencia de quién lo realice, es un valioso apoyo para la familia y debe ser tenido en cuenta como aporte social. En esa medida, dado que existen otras formas de colaboración en el hogar, la ausencia de un ingreso económico fijo para una persona no puede ser utilizada por su pareja para reclamar la condición de cabeza de familia⁸⁷.

34. En tercer lugar, es necesario que exista una auténtica **sustracción de los deberes legales de manutención** por parte del progenitor de los menores de edad que conforman el grupo familiar. Esta situación puede ocurrir, bien cuando la pareja abandona el hogar y, además, omite el cumplimiento de sus deberes como progenitor o bien, cuando no asume la responsabilidad que le corresponde debido a un motivo externo a su voluntad *“como la incapacidad física, sensorial, síquica o mental o, como es obvio, la muerte”*.

Acerca de la sustracción de los deberes legales del progenitor de los hijos a cargo, esta Corporación ha señalado que no es admisible exigir a la madre o al padre cabeza de familia el inicio de las acciones legales correspondientes en

trabajar”, ello incluye a los hijos estudiantes.

En este sentido, ha establecido la Corte Constitucional: *“[U]na mujer no deja de ser cabeza de familia por el simple hecho de que las personas a su cargo cumplan la mayoría de edad, sino que habrá de constatarse si éstas se encuentran imposibilitadas para trabajar, como sucede a los hijos mayores de 18 años, pero menores de 25 que continúan estudiando.”* (sentencia T-827 de 2009. M.P. Juan Carlos Henao Pérez). Igualmente, ver: sentencia T-420 de 2017 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger); sentencia T-835 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva); sentencia T-400 de 2014 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio); sentencia T-993 de 2007 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa); sentencia SU-388 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández),

87 Sentencia T-420 de 2017 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger); sentencia T-400 de 2014 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio); sentencia T-993 de 2007 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa); sentencia SU-388 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández).

Sentencia T-316 de 2013 (M.P. Alberto Rojas Ríos); sentencia T-835 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva); sentencia T-827 de 2009 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez); sentencia T-206 de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto); sentencia T-493 de 2005 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa); sentencia SU-388 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández).

contra del progenitor para demostrar este requisito. Lo anterior, por cuanto no existe tarifa legal para probar este hecho y, por ende, *“las autoridades no están autorizadas a exigir un medio de convicción específico que evidencie la sustracción del padre de sus deberes legales”* .

35. En cuarto lugar, se requiere que haya una **deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros de la familia**, lo cual implica la responsabilidad solitaria de la madre para sostener el hogar.

36. Adicionalmente, es necesario resaltar que existe una regla de interpretación para verificar el cumplimiento de los anteriores requisitos. En efecto, la Corte Constitucional ha señalado que la condición de madre cabeza de familia **no depende de una formalidad jurídica sino de las circunstancias materiales que la configuran**.

Así, por ejemplo, este Tribunal ha determinado que la declaración ante notario acerca de la condición de mujer cabeza de familia, prevista en el parágrafo del artículo 2° de la Ley 82 de 1993⁸⁸, no es constitutiva de dicha calidad ni es una exigencia probatoria indispensable para acreditarla⁸⁹. En similar sentido, esta Corporación ha señalado que el estado civil es irrelevante al momento de determinar si una mujer tiene la condición de cabeza de familia, pues lo decisivo son las circunstancias materiales⁹⁰.

Sentencia T-835 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).

88 **“PARÁGRAFO.** *La condición de Mujer Cabeza de Familia y la cesación de la misma, desde el momento en que ocurra el respectivo evento, deberá ser declarada ante notario por cada una de ellas, expresando las circunstancias básicas del respectivo caso y sin que por este concepto se causen emolumentos notariales a su cargo.”*

89 En la sentencia C-034 de 1999 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), la Corte declaró exequible la expresión *“siendo soltera o casada”* contenida en el artículo 2° de la Ley 82 de 1993, por considerar irrelevante el estado civil de la mujer a la hora de establecer si es cabeza de familia. Según la Corte, *“lo esencial, de acuerdo con la definición que sobre el particular adoptó el legislador en la norma acusada, es que ella “tenga bajo su cargo, económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios o de otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar”*. Véase, en el mismo sentido, sentencia T-925 de 2004 (M.P. Álvaro Tafur Galvis).

90 Sentencia C-184 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa). *“Una mujer es cabeza de familia cuando, en efecto, el grupo familiar está a su cargo. Aunque en el mismo artículo se incluye un parágrafo en el que se indica que la mujer deberá declarar ante notario dicha situación, tanto cuando la adquiera como cuando la pierda, para efectos de prueba, no es una condición que dependa de una formalidad jurídica.”*

Por consiguiente, corresponde al operador jurídico en el caso concreto valorar las condiciones de quien alega su condición de mujer cabeza de familia, sin que dicha calidad pueda determinarse exclusivamente por el cumplimiento de alguna formalidad.

En este orden de ideas, conviene resaltar que el análisis probatorio que ha llevado a cabo la Corte Constitucional para establecer que una persona reúne las condiciones necesarias para considerarse madre o padre cabeza de familia de conformidad con el ordenamiento jurídico, se ha fundamentado en distintos medios de convicción, entre los cuales se encuentran con frecuencia las declaraciones extraprocesales de los solicitantes y personas allegadas así como sus manifestaciones dentro del proceso de tutela y los procedimientos administrativos adelantados por las entidades respectivas⁹¹. También, se han valorado los certificados de estudios de los hijos a cargo menores de 25 años y la copia del documento de identificación de estos últimos⁹².

37. Finalmente, la Corte Constitucional ha sostenido que la constatación de los requisitos para acreditar la calidad de madre o padre cabeza de familia **deberá adelantarse en el marco de un procedimiento administrativo con respeto al derecho al debido proceso**, *“en el cual la autoridad respectiva valore todas las pruebas que se someten a su consideración y que le permitan decidir con certeza que las trabajadoras [o trabajadores] no cumplen con las condiciones para ser considerados madres o padres cabeza de familia”*⁹³.

Esta conclusión se fundamenta, a su turno, en dos razones. Por una parte, en el mandato previsto en el artículo 29 Superior, de conformidad con el cual *“[e]l debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”*. Por otra, en la especial protección constitucional de la cual son titulares las madres y padres cabeza de familia, quienes pueden quedar en situación de vulnerabilidad en caso de perder su empleo⁹⁴.

38. Ahora bien, en cuanto al contenido del derecho fundamental al debido proceso, este Tribunal ha expresado que, entre las garantías que conforman el núcleo esencial del debido proceso se encuentran *“el derecho al juez natural, el derecho a un proceso público, el derecho a la independencia e imparcialidad del juez, el derecho a presentar pruebas y controvertirlas, el derecho a impugnar la sentencia condenatoria, y el derecho a la defensa*

91 Sentencias SU-389 de 2005 (M.P. Jaime Araújo Rentería); T-200 de 2006 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra); T-206 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa); T-835 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva); y T-420 de 2017 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger).

92 Sentencia T-034 de 2010 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio)

93 Sentencia T-835 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva). Igualmente, véase sentencia T-862 de 2009 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).

94 Sentencia T-835 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).

entendido como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable”⁹⁵.

Igualmente, en relación con el contenido del debido proceso administrativo, la Corte ha distinguido entre las **garantías previas y posteriores** que implica el derecho al debido proceso. Las *garantías mínimas previas* son aquellas que necesariamente deben cobijar la expedición y ejecución de cualquier acto o procedimiento administrativo, tales como el acceso libre y en condiciones de igualdad a la justicia, el juez natural, el derecho de defensa, la razonabilidad de los plazos y la imparcialidad, autonomía e independencia de los jueces, entre otras.⁹⁶ De otro lado, las *garantías mínimas posteriores* se refieren a la posibilidad de cuestionar la validez jurídica de una decisión administrativa, mediante los recursos de la vía gubernativa y la jurisdicción contenciosa administrativa.⁹⁷

39. También, esta Corporación ha señalado que, en el marco de procesos de modificación de su estructura administrativa, cuando las entidades públicas deciden llevar a cabo procedimientos para asegurar la protección especial a los servidores que son titulares del “*retén social*”, deben observar rigurosamente los parámetros que la Corte Constitucional ha fijado en tales casos, con el propósito de garantizar la igualdad material⁹⁸.

40. En consecuencia, de conformidad con lo expuesto anteriormente, existe un mandato constitucional y legal de protección especial a la mujer cabeza de familia, el cual ha sido implementado mediante acciones afirmativas orientadas al logro de la igualdad material entre ambos sexos. No obstante, algunas de estas medidas pueden extenderse también a los padres cabeza de familia, en razón del interés superior de los niños, niñas y adolescentes y con fundamento en la garantía de los derechos de las personas en situación de discapacidad.

Así pues, **la condición de madre cabeza de familia requiere la confluencia de los siguientes elementos**, a saber: (i) que la mujer tenga a su cargo la responsabilidad de hijos menores de edad o de otras personas “*incapacitadas*” para trabajar⁹⁹; (ii) que la responsabilidad exclusiva de la mujer en la jefatura

95Sentencias C-166 de 2017 (M.P. José Antonio Cepeda Amarís).

96 Sentencias C-089 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva); C-034 de 2014 (M.P. María Victoria Calle Correa) y C-361 de 2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).

97 Sentencias C-1189 de 2005 (M.P. Humberto Sierra Porto); C-089 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva); C-034 de 2014 (M.P. María Victoria Calle Correa) y C-361 de 2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).

98 Sentencia T-444 de 2010 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto) y sentencia T-455 de 2011 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).

99Este requisito se entiende en los términos del fundamento jurídico 32 de la presente decisión.

del hogar sea de carácter permanente; (iii) que exista una auténtica sustracción de los deberes legales de manutención por parte de la pareja o del padre de los menores de edad a cargo; y (iv) que exista una deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros de la familia. De igual modo, la verificación de las circunstancias anteriormente enunciadas debe realizarse en el marco de un procedimiento administrativo, que otorgue la plenitud de las garantías propias del derecho fundamental al debido proceso.

Protección especial de las personas cabeza de familia en el marco de los procesos de reestructuración administrativa y las condiciones para pertenecer al denominado “retén social”.

41. De conformidad con el artículo 209 de la Constitución Política, la administración pública está al servicio del interés general y debe desarrollarse con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía y celeridad, entre otros.

Por consiguiente, el cumplimiento de los fines del Estado exige una actividad permanente de los órganos que ejercen la función administrativa y, por tanto, es natural que existan procesos de reforma institucional con el fin de adaptar la estructura de la administración a las necesidades sociales, entre las que se encuentran: la adecuada garantía de la prestación de los servicios públicos, la sostenibilidad económica y la eficiencia de la administración pública¹⁰⁰.

En este sentido, la Corte Constitucional ha reconocido que los procesos de reestructuración pueden tener intensidades distintas, cuyos efectos inciden en mayor o menor medida según el caso. No obstante, siempre debe tenerse en cuenta que estas transformaciones originan múltiples consecuencias tanto para los trabajadores como para la comunidad en general¹⁰¹.

42. Con todo, la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en sostener que los procesos de reestructuración administrativa no pueden desconocer los derechos de los trabajadores, especialmente cuando se trata de servidores que, por sus condiciones particulares, se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad que, a su vez, dificulta su inserción en el mercado laboral una vez son desvinculados de su empleo¹⁰².

100 Sentencia T-034 de 2010 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio); sentencia T-587 de 2008 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto); sentencia SU-388 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández).

101 Sentencia T-034 de 2010 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio); sentencia T-587 de 2008 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto); sentencia SU-388 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández).

102 En este sentido, la Corte Constitucional ha afirmado que “[e]s un hecho notorio que hoy en día [las personas con discapacidad] y los padres y madres cabeza de familia no son objeto de preferencia a la hora de contratación laboral. Ciertamente, en procura de un eficientismo se busca (...) que la disposición de tiempo mental y físico sea plena, e incluso mayor a la del

Así, cuando la supresión de cargos en el marco de los procesos de reestructuración involucra los derechos de trabajadores que pueden resultar perjudicados en mayor grado con tales decisiones administrativas, se deben tomar medidas para garantizar la especial protección de la cual son titulares dichas personas, con fundamento en los artículos 13, 43, 46 y 47 de la Constitución.

43. Ahora bien, como se expresó anteriormente, el Legislador ha adoptado diversas acciones afirmativas en cumplimiento de su deber de garantizar la igualdad material de las madres cabeza de familia. En particular, una de las medidas más importantes que ha expedido el Congreso de la República en esta materia es el artículo 12 de la Ley 790 de 2002¹⁰³, en el cual se estableció la política comúnmente denominada “*retén social*” en el marco del Programa de Renovación de la Administración Pública (PRAP).

Es pertinente destacar que la Ley 790 de 2002 fue expedida dentro del marco de un proceso de modernización de la administración pública, que tenía como objetivo crear, suprimir y fusionar diversas entidades públicas del orden nacional. Sin embargo, el Legislador decidió incorporar mecanismos de protección de los derechos de algunos trabajadores que, debido a sus especiales condiciones, podrían resultar gravemente perjudicados durante el proceso de reestructuración.

Por consiguiente, el artículo 12 de la Ley 790 de 2002 dispone que, de conformidad con la reglamentación establecida por el Gobierno Nacional, **no podrán ser retirados** en el desarrollo del Programa de Renovación de la Administración Pública (PRAP): (i) las madres cabeza de familia sin alternativa económica¹⁰⁴, (ii) las personas con limitación física, mental, visual o auditiva y (iii) las personas próximas a pensionarse.

tiempo reglado de trabajo, cuando las necesidades de la empresa así lo impliquen, rasgo que, en términos generales, madres y padres cabeza de familia, que deben velar por la seria responsabilidad del manejo del núcleo familiar, no tienen. Así las cosas, es casi nula la posibilidad de que las personas con estas características que fueron desvinculadas en el proceso de Reestructuración de la Administración consigan trabajo.”(Sentencia C-964 de 2003. M.P. Álvaro Tafur Galvis).

103“*Por la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de renovación de la administración pública y se otorgan unas facultades Extraordinarias al Presidente de la República*”.

104Cabe resaltar que mediante la sentencia C-044 de 2004 (M.P. Jaime Araújo Rentería) la Corte Constitucional consideró que la protección de la cual son titulares las madres cabeza de familia “***debe extenderse a los padres que se encuentren en la misma situación, en aras de proteger la prevalencia de los derechos de los niños y el grupo familiar al que pertenecen***”.

44. A su vez, el Decreto 190 de 2003 reglamentó la Ley 790 de 2002, el cual estableció las principales condiciones para el ejercicio de la protección especial consagrada en la norma legal. Particularmente, en relación con las madres cabeza de familia, el citado decreto definió, para los efectos de la citada ley: (i) el concepto de madre cabeza de familia sin alternativa económica¹⁰⁵; (ii) el trámite para acreditar la referida condición¹⁰⁶; y (iii) la duración de la estabilidad laboral reforzada¹⁰⁷, la cual se circunscribe al tiempo en el cual persistan las circunstancias que la originan.

45. Igualmente, es oportuno aclarar que en la **sentencia C-991 de 2004**, se declaró la inexecutable del límite temporal establecido para la protección derivada del “*retén social*” pues la Corte Constitucional estimó que se trataba de una medida desproporcionada con sujetos en condiciones de debilidad

105 Decreto 190 de 2003. Artículo 1. “*Madre cabeza de familia sin alternativa económica: Mujer con hijos menores de 18 años de edad, biológicos o adoptivos, o hijos inválidos que dependan económicamente y de manera exclusiva de ellas, y cuyo ingreso familiar corresponde únicamente al salario que devenga del organismo o entidad pública a la cual se encuentra vinculada.*”

106 Decreto 190 de 2003. Artículo 13. “*Para hacer efectiva la estabilidad laboral de que trata el artículo anterior, los organismos y entidades que modifiquen sus plantas de personal dentro del Programa de Renovación de la Administración Pública en el orden nacional respetarán las siguientes reglas:*

13.1 Acreditación de la causal de protección (...) a) Madres cabeza de familia sin alternativa económica: Los jefes de personal, o quienes hagan sus veces, verificarán en las hojas de vida de las servidoras públicas, que pretendan beneficiarse de la protección especial y en el sistema de información de la respectiva Entidad Promotora de Salud, EPS, y en las Cajas de Compensación Familiar, que se cumplan las condiciones señaladas en el presente decreto y que en el grupo familiar de la solicitante no existe otra persona con capacidad económica que aporte al sistema de seguridad social. Así mismo, la condición de invalidez de los hijos, siempre que dependan económica y exclusivamente de quien pretenda ser beneficiaria de la protección especial, debe ser probada por la servidora pública con un dictamen de la respectiva Junta de Calificación de Invalidez // (...) 13.2 Aplicación de la protección especial: Con base en las certificaciones expedidas por los jefes de personal o quienes hagan sus veces y en las valoraciones del tipo de limitación previstas en el numeral anterior, el secretario general de la respectiva entidad analizará, dentro del estudio técnico correspondiente a la modificación de la planta de personal y teniendo en cuenta la misión y los objetivos del organismo o entidad, el cargo del cual es titular el servidor público que se encuentra en alguno de los grupos de la protección especial y comunicará a los jefes de la entidad respectiva los cargos que de manera definitiva no podrán ser suprimidos o las personas a quienes se les deberá respetar la estabilidad laboral.”

107 Decreto 190 de 2003. Artículo 14. “*Pérdida del derecho. La estabilidad laboral a la que hace referencia este capítulo cesará cuando se constate que el ex empleado ya no hace parte del grupo de personas beneficiarias de la protección especial.*”

manifiesta que, además, desconocía la prohibición de retroceso en materia de derechos económicos, sociales y culturales¹⁰⁸.

46. Sin perjuicio de lo anterior, la Corte Constitucional ha estimado que la protección de las mujeres cabeza de familia en el marco de procesos de reestructuración es un *“mandato constitucional y por tanto **no puede limitarse su aplicación a las precisas circunstancias de la Ley 790 de 2002**”*. En este orden de ideas, esta Corporación ha reconocido que la protección a la mujer por su especial condición de madre cabeza de familia es de origen

108En relación con el límite temporal del retén social, resulta pertinente referir las consideraciones expuestas en la **sentencia SU-377 de 2014** (M.P. María Victoria Calle Correa): *“El retén social tenía inicialmente una duración definida en la Ley 790 de 2002. El artículo 13 dispuso que debía durar “hasta el vencimiento de las facultades extraordinarias que se conceden en la presente ley”. No obstante, como lo sostuvo la Corte en la sentencia C-991 de 2004, esa norma fue tácitamente derogada por el artículo 8, literal d), de la Ley 812 de 2003, en tanto esta última dispuso que la protección especial del retén social se aplicaría hasta el treinta y uno (31) de enero de dos mil cuatro (2004) “salvo en lo relacionado con los servidores próximos a pensionarse, cuya garantía deberá respetarse hasta el reconocimiento de la pensión de jubilación o vejez”. En esa misma sentencia la Corte declaró inexecutable el aparte del artículo 8, literal d), de la Ley 812 de 2003, que limitaba en el tiempo la vigencia del retén social. Una Sala de Revisión ya había inaplicado esa norma en un caso concreto. Pero esta vez fue la Sala Plena de la Corporación la que consideró que esta restricción interfería de un modo desproporcionado en los derechos de “las madres y padres cabeza de familia y los disminuidos físicos, mentales y psíquicos”. // (...) También el Decreto 190 de 2003, reglamentario de la Ley 790 de 2002, contemplaba un término de duración del retén social (Dcto 190 de 2003 art. 14 y 16). Y luego el Decreto 1615 de 2003, que ordenó el inicio de la liquidación de TELECOM, se remitió a ese término para definir la duración del retén social en esa entidad (art. 16). De acuerdo con estos preceptos, el retén debía aplicarse hasta la culminación del Programa de Renovación de la Administración Pública, y en cualquier caso sin exceder el treinta y uno (31) de enero de dos mil cuatro (2004). La Sección Segunda del Consejo de Estado anuló, sin embargo, esta normatividad mediante sentencia del diecinueve (19) de abril de dos mil cinco (2005). Luego de tomar en cuenta lo resuelto por esta Corte en la sentencia C-991 de 2004, el Consejo de Estado decidió declarar que se daba una inconstitucionalidad por consecuencia, toda vez que el sustento de las disposiciones entonces demandadas como nulas eran las que habían sido encontradas inexecutables por la Corte Constitucional. Por consiguiente, declaró nulos un fragmento del artículo 14 y todo el artículo 16. Luego, en la sentencia del dieciocho (18) de mayo de dos mil once (2011), la Sección Segunda decidió estarse a lo resuelto en la primera providencia, al resolver la acción de nulidad instaurada contra el mismo objeto normativo.”*

Sentencia T-827 de 2009 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez). Véanse también: sentencia T-326 de 2014 (M.P. María Victoria Calle Correa); sentencia SU-897

supralegal¹⁰⁹. Por lo tanto, la estabilidad laboral derivada del retén social no se restringe a la modificación de la estructura de la administración en el orden nacional o en el nivel central de la Rama Ejecutiva¹¹⁰.

47. Así las cosas, ha dicho la Corte que el denominado “*retén social*” “*es uno de los mecanismos para proteger la estabilidad laboral reforzada*”¹¹¹ de los grupos de servidores públicos que, por sus condiciones de especial vulnerabilidad, son titulares de esta protección. En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha considerado que el llamado “*retén social*” es apenas una de las medidas que puede garantizar los derechos fundamentales involucrados en la permanencia en el empleo público de los trabajadores próximos a pensionarse, de las personas cabeza de familia y de las personas en situación de discapacidad¹¹².

48. Con todo, es importante resaltar que la protección especial prevista en el ordenamiento jurídico para las madres y los padres cabeza de familia en el marco de los procesos de reestructuración **no es ilimitada ni absoluta**¹¹³. Por el contrario, esta Corporación ha considerado que la estabilidad laboral que se deriva del “*retén social*” tiene dos restricciones principales¹¹⁴:

de 2012 (M.P. Alexei Julio Estrada); sentencia T-587 de 2008 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto); sentencia T-1076 de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil); sentencia C-991 de 2004 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).

109 Sentencia C-184 de 2003, C-964 de 2003; sentencia C-044 de 2004 (M.P. Jaime Araújo Rentería); sentencia T-768 de 2005 (M.P. Jaime Araújo Rentería), sentencia T-326 de 2014 (M.P. María Victoria Calle Correa), entre otras.

110 Véanse, entre otras: sentencia T-638 de 2016 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio); sentencia T-824 de 2014 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez); sentencia T-326 de 2014 (M.P. María Victoria Calle Correa); sentencia T-802 de 2012 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez); sentencia SU-897 de 2012 (M.P. Alexei Julio Estrada); sentencia T-768 de 2005 (M.P. Jaime Araújo Rentería);

111 Sentencia T-638 de 2016 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).

112 Sentencia T-638 de 2016 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio); sentencia T-326 de 2014 (M.P. María Victoria Calle Correa).

113 Sentencias T-269 de 2017 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez); T-595 de 2016 (M.P. Alejandro Linares Cantillo); SU-377 de 2014 (M.P. María Victoria Calle Correa); T-353 de 2010 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva); T-194 de 2010 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva); T-001 de 2010 (M.P. Mauricio González Cuervo); C-759 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva); T-692 de 2009 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio); C-991 de 2004 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), entre otras.

114 Sentencia T-835 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) “*La permanencia de las trabajadoras en sus empleos se dará hasta que: i) se termine el proceso de liquidación de la institución; ii) pierdan las condiciones*

(i) Por una parte, los servidores públicos que se encuentran cobijados por la garantía de estabilidad laboral como consecuencia del denominado “*retén social*” pueden ser desvinculados siempre que exista una **justa causa de terminación de la relación laboral debidamente comprobada**¹¹⁵; y

(ii) Por otra parte, la estabilidad laboral reforzada de los servidores públicos derivada del “*retén social*” se extiende hasta la terminación definitiva del proceso liquidatorio de la entidad respectiva¹¹⁶ o hasta que cesen las condiciones que originan la especial protección¹¹⁷.

En consecuencia, ha dicho la Corte, “*la estabilidad laboral reforzada derivada del llamado retén social, no es de carácter absoluto, pues no existe un derecho fundamental a la conservación perpetua del trabajo o a la permanencia indefinida en el mismo*”¹¹⁸. De esta manera, se armoniza la garantía de la igualdad material de los trabajadores cobijados por el “*retén social*” y los principios de la función administrativa que justifican los procesos de reestructuración en el sector público.

49. En consecuencia de lo anterior, en cuanto al **alcance de la protección derivada del denominado “*retén social*”**, debe señalarse que la jurisprudencia constitucional ha reconocido que la mejor forma de garantizar los derechos fundamentales de las madres cabeza de familia en el marco de esta política “*consiste en ordenar su reintegro y dejar sin efecto las indemnizaciones reconocidas*”¹¹⁹. De hecho, ha sostenido la Corte que “*el*

establecidas para ser titulares de dicha salvaguarda; o iii) incurran en hechos que funden la terminación del contrato en una justa causa o que constituyan causal de destitución del cargo en el caso de las empleadas públicas.”

115 Sentencias T-420 de 2017 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger); SU-377 de 2014 (M.P. María Victoria Calle Correa); T-835 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva); T-802 de 2012 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio); T-1167 de 2005 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), entre otras.; SU-388 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández); T- C-991 de 2004 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).

116 Sentencias T-114 de 2014 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez); T-001 de 2010 (M.P. Mauricio González Cuervo); T-873 de 2009 (M.P. Mauricio González Cuervo); (M.P. María Victoria Calle Correa); T-993 de 2007 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa); SU-388 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), entre otras.

117 Sentencias T-833 de 2009 (M.P. María Victoria Calle Correa); T-846 de 2005 (M.P. Rodrigo Escobar Gil); T-200 de 2006 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).

118 Sentencia T-353 de 2010 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva). Véanse, entre otras: sentencia T-194 de 2010 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva); sentencia T-001 de 2010 (M.P. Mauricio González Cuervo).

119 Sentencia SU-388 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández).

*pago de la indemnización debe ser concebida como la última alternativa para reparar el daño derivado de la liquidación de la empresa, por cuanto corresponde al derecho en cabeza de todos los servidores públicos y no sólo de los sujetos de especial protección”*¹²⁰.

50. No obstante, la Corte Constitucional también ha reconocido que la protección especial derivada del “*retén social*” **“sólo puede ser extendida hasta que haya posibilidades fácticas y jurídicas de otorgarla”**. Por ende, es indispensable tener en cuenta las limitaciones propias de los procesos de reestructuración, fusión o liquidación de entidades y se deben ponderar los principios constitucionales de la función administrativa con la especial protección de la que son titulares los servidores públicos beneficiarios del “*retén social*”.

En razón de lo anterior, **en el marco del “retén social”, esta Corporación ha acudido a dicha ponderación en los siguientes escenarios:**

(i) *Cuando se pretende el reintegro a una entidad cuyo proceso de liquidación ya ha concluido*. En estos casos, ante la terminación de la existencia jurídica de la institución correspondiente, no procede ordenar el reintegro sino el pago de los salarios y prestaciones dejadas de percibir desde el momento de la desvinculación hasta la liquidación definitiva de la empresa¹²¹.

(ii) *En el caso de los “prepensionados”, cuando se trata de procesos liquidatorios, la Corte Constitucional ha establecido que “la orden no puede ser el reintegro del trabajador al cargo que desempeña”, pues es lógico que en desarrollo del proceso liquidatorio se supriman paulatinamente los puestos de trabajo existentes, haciéndose innecesario, por consiguiente, mantener el mismo número de empleados o funcionarios en la planta de personal de la institución en liquidación*¹²². Por consiguiente, en un ejercicio de

120Acerca de este punto, conviene recordar lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia SU-388 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández) para justificar que el reintegro sea la primera opción de protección en los casos en que se desconoce el denominado “*retén social*”: “*Y si a lo anterior se suma que las mujeres han sido excluidas a lo largo de la historia del escenario laboral, es claro que las acciones afirmativas diseñadas en su favor revisten un componente que va más allá de la simple presencia de un ingreso fijo para asegurar la manutención de su núcleo familiar, puesto que en estos casos también se protege la idea de reconocer especial valor al trabajo como expresión de una opción personal o profesional negada por muchos años*”.

Sentencia T-889 de 2008 (M.P. Mauricio González Cuervo).

121Sentencia T-114 de 2014 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez); sentencia T-1059 de 2010 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo); sentencia T-001 de 2010 (M.P. Mauricio González Cuervo).

122Sentencia SU-897 de 2012 (M.P. Alexei Julio Estrada).

armonización de los principios implicados¹²³, la Corte determinó que, una vez suprimido el cargo, además del pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales correspondientes, se debía garantizar el pago de los aportes al régimen pensional respectivo hasta tanto se cumplieran los requisitos para acceder a la pensión de vejez¹²⁴.

(iii) *Finalmente, en los procesos de reestructuración, cuando se suprime el cargo que ocupa una persona beneficiaria del denominado “retén social” y en la nueva planta de la entidad no existe un cargo igual o equivalente, por lo que el reintegro se torna imposible.* En estos supuestos, corresponde el pago de las acreencias laborales correspondientes y, si se trata de servidores de carrera administrativa, se debe sufragar la indemnización prevista en el artículo 44 de la Ley 909 de 2004¹²⁵.

51. Igualmente, debe advertirse que la Corte Constitucional ha estimado que la estabilidad laboral reforzada derivada del llamado “retén social” es una protección que “*depende o está en función, en cualquier escenario, de la naturaleza del vínculo o la causa y el contexto de su terminación*”¹²⁶. Por ende, el alcance de esta figura debe analizarse **en atención a la naturaleza y los elementos esenciales del vínculo laboral establecido entre la administración y los servidores públicos.**

De este modo, en aplicación de dicha regla jurisprudencial, esta Corporación ha sostenido que: (i) la protección originada en el llamado “retén social” no se extiende a los servidores públicos que ocupan cargos en la planta de personal temporal de las entidades públicas¹²⁷; (ii) por regla general, los empleados públicos de libre nombramiento y remoción, que relaciona el

123Sentencia SU-897 de 2012 (M.P. Alexei Julio Estrada). Sobre este particular, explicó la Corte Constitucional: “*Así, en el presente caso se presenta ante la Corte una situación concreta en la que colisionan dos principios constitucionales: de un lado estaría la garantía de la seguridad social en pensiones, en una de sus formas de concreción, cual es la protección diseñada para las personas que, siendo empelados de una de las entidades afectadas por el PRAP, están próximas a cumplir los requisitos para acceder a la pensión de jubilación o de vejez; y, del otro, los principios de eficacia, economía y celeridad de la administración –artículo 209 de la Constitución-, que se concretan en procesos liquidatorios de las entidades de la administración incluidas en el PRAP desarrollados sin inconvenientes, ni dilaciones injustificadas. // La armonización en concreto de dichos principios no puede dar como resultado la absoluta preponderancia de uno sobre el otro, de manera que se anule por completo alguno de dichos contenidos, a favor de la aplicación irrestricta del otro. Un ejercicio de armonización obliga a determinar cuál es la interpretación que en términos constitucionales resulta ponderada en este específico caso*”.

124Sentencia SU-897 de 2012 (M.P. Alexei Julio Estrada).

125Sentencia T-420 de 2017 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger).

126Sentencia T-269 de 2017 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez).

numeral 2 del artículo 5 de la Ley 909 de 2004, no gozan de estabilidad laboral reforzada¹²⁸; y (iii) cuando se trata de servidores públicos que ocupan en provisionalidad cargos de carrera administrativa y que pertenecen a alguno de los grupos titulares de la especial protección derivada del “*retén social*”, el amparo de la estabilidad laboral reforzada prospera únicamente si existe un margen de maniobra para la administración en cuanto a la provisión del empleo, en razón de la diferencia entre las plazas ofertadas y aquellas efectivamente proveídas mediante la lista de elegibles correspondiente¹²⁹.

52. Así las cosas, como fue expuesto en los fundamentos jurídicos 48 a 51 de la presente decisión, la Corte Constitucional ha considerado que la protección derivada del “*retén social*” no es absoluta ni ilimitada. Por tanto, dado que dicha salvaguarda sólo puede garantizarse en el marco de las posibilidades fácticas y jurídicas de otorgarla, resulta indispensable ponderar los principios de la función administrativa (y, a partir de ellos, las circunstancias propias de los procesos de reestructuración de la administración) con los derechos fundamentales de los titulares de la protección laboral reforzada.

De este modo, se reitera la regla jurisprudencial que indica que **la desvinculación de los trabajadores del “*retén social*” puede ocurrir cuando se presenten causales objetivas** que no tengan relación con la condición que precisamente origina su protección especial, como la existencia de una justa causa de terminación de la relación laboral debidamente comprobada, la conclusión definitiva del proceso liquidatorio de la entidad respectiva o el cese de las condiciones que originan la especial protección.

53. A continuación, la Sala se referirá al caso particular de los servidores públicos **vinculados en provisionalidad por un período de tiempo determinado**, previsto desde su nombramiento. En este tipo de casos, se estima que estos funcionarios son titulares de la protección derivada del “*retén social*”. Sin embargo, la entidad correspondiente está facultada para desvincularlos **siempre que existan razones objetivas del servicio que justifiquen de manera suficiente el retiro de dichos funcionarios en cada caso particular**. Como es evidente, en tales casos no bastará con que se afirme la existencia de un proceso de reestructuración o liquidatorio.

Esta precisión se sustenta en que la vinculación de funcionarios en provisionalidad por un período establecido obedece a unas lógicas temporales y de necesidades concretas del servicio que pueden desaparecer. Por tanto, resultaría desproporcionado que se obligara a la entidad pública a mantener una relación laboral, que desde un principio se sujetó a un plazo determinado, cuando se extinguieron completamente las razones que justifican la permanencia del trabajador vinculado en provisionalidad.

127Sentencia SU-003 de 2018 (M.P. Carlos Bernal Pulido).

128Sentencia T-269 de 2017 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez).

129Sentencias T-186 de 2013 (M.P. Alberto Rojas Ríos); T-017 de 2012 (M.P. María Victoria Calle Correa); T-729 de 2010 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).

En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que los servidores públicos que se encuentran en provisionalidad gozan de cierta estabilidad laboral que ha denominado como *relativa o intermedia*, en la medida en que no se puede asimilar completamente a aquella a la cual tienen derecho los funcionarios de carrera administrativa¹³⁰.

Con todo, es indispensable resaltar que, en cualquier caso, la carga argumentativa de demostrar plenamente que existen razones objetivas del servicio, que justifican con suficiencia la desvinculación del funcionario nombrado en provisionalidad por un término definido, recae en la administración.

En consecuencia, la Sala considera que los funcionarios vinculados en provisionalidad por un período de tiempo determinado, previsto de antemano desde su nombramiento, son titulares de la protección especial derivada del “*retén social*” y, en esta medida, son beneficiarios de estabilidad laboral reforzada en el curso de los procesos de reestructuración administrativa de las instituciones públicas. No obstante, la entidad respectiva puede desvincular a estos servidores siempre que satisfaga la carga argumentativa requerida para tal efecto, es decir, que justifique plenamente la existencia de razones objetivas del servicio para el retiro de los trabajadores que se encuentran en esta condición.

De esta manera, se protegen adecuadamente los derechos fundamentales de los funcionarios públicos que se encuentran en la situación referida, pues para su desvinculación por razones del servicio no basta con la existencia de un proceso de reestructuración, sino que se debe justificar debidamente que, en el caso concreto, existen razones objetivas para el retiro del servidor público titular de la protección especial derivada del “*retén social*”.

54. En suma, el llamado “*retén social*” es una acción afirmativa que materializa el deber constitucional que tiene el Estado de conceder un trato diferenciado a las mujeres cabeza de familia que se encuentran en estado de

130Sentencia SU-054 de 2015 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez). En esta providencia, la Sala Plena de la Corte Constitucional sostuvo que “*tales funcionarios, si bien no tienen las prerrogativas de los empleados de carrera, y no gozan de la estabilidad laboral reforzada que se adquiere solamente superando un concurso de méritos, tampoco pueden asimilarse a los de libre nombramiento y remoción, pues su empleador no tiene tal discrecionalidad para disponer del cargo (...) A tono con la jurisprudencia sentada por esta Corporación, la estabilidad relativa se manifiesta en que el acto de retiro de los funcionarios que en provisionalidad ocupan cargos de carrera, debe contener una motivación coherente con la función pública en el Estado Social de Derecho, para garantizar la protección efectiva de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, y al acceso en condiciones de igualdad al servicio público*”. En idéntico sentido, véase la sentencia SU-556 de 2014 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez).

debilidad manifiesta¹³¹. Además, es uno de los mecanismos previstos por el Legislador para garantizar la estabilidad laboral de las madres y padres cabeza de familia. Esta medida de protección especial deriva directamente de los mandatos constitucionales de protección a la igualdad material y a los grupos poblacionales anteriormente mencionados, dado que podrían sufrir consecuencias especialmente graves con su desvinculación.

No obstante, la estabilidad laboral reforzada derivada del llamado “*retén social*”, no es de carácter absoluto, pues no existe un derecho fundamental a la conservación perpetua del trabajo o a la permanencia indefinida en el mismo. Así, en el marco de los ajustes institucionales propios de los procesos de reestructuración de la administración pública, se debe garantizar la permanencia de los servidores públicos que tengan derecho a la protección especial derivada del “*retén social*”, en los términos señalados en los párrafos anteriores.

Reglas jurisprudenciales sobre la aplicación del denominado “retén social” respecto de las madres y los padres cabeza de familia.

55. Con fundamento en las consideraciones precedentes, corresponde ahora precisar algunas de las principales reglas que ha establecido la jurisprudencia constitucional en la aplicación del denominado “*retén social*” respecto de la desvinculación de madres o padres cabeza de familia en el marco de ajustes institucionales de la administración:

(i) En los procesos de modificación de la estructura de la administración pública (reestructuración, fusión, o liquidación de entidades, por ejemplo) en los que exista supresión de cargos, las entidades públicas deben observar los parámetros propios de la estabilidad laboral de los servidores públicos beneficiarios del denominado “*retén social*”.

(ii) La estabilidad laboral derivada del “*retén social*” es aplicable tanto para funcionarios de carrera administrativa como para servidores vinculados en provisionalidad, así como para trabajadores oficiales¹³².

131Sentencia T-835 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).

Sentencias T-400 de 2014 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio); T-802 de 2012 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio); T-444 de 2010 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto); T-833 de 2009 (M.P. María Victoria Calle Correa).

132En este sentido, la Corte Constitucional sostuvo en la sentencia T-623 de 2011 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto): “*La Sala reitera que la distinción, para efectos de determinar los beneficiarios del retén social, entre quienes ocupan cargos de forma permanente y aquellos que están en provisionalidad, no tiene un fundamento constitucional que la avale y, por el contrario, vulnera los derechos a la igualdad, a la seguridad social en pensiones y, en ocasiones, al mínimo vital*”. Véanse también las sentencias: T-400 de 2014 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio); T-326 de 2014 (M.P. María Victoria Calle Correa); T-316 de 2013 (M.P. Alberto Rojas Ríos); T-186 de 2013 (M.P. Alberto Rojas

No obstante, cuando se trata de la permanencia de trabajadores beneficiarios del “*retén social*” vinculados en provisionalidad por un término definido, la administración puede retirarlos cuando existan razones objetivas del servicio que justifiquen de manera suficiente la desvinculación de dichos funcionarios.

(iii) Los trabajadores que alegan ser beneficiarios del “*retén social*” deben informar oportunamente a su empleador esta circunstancia, so pena de perder su derecho a recibir la protección especial derivada de su condición, en razón de su falta de diligencia¹³³.

(iv) La estabilidad laboral reforzada de la cual son titulares los beneficiarios del “*retén social*” cubre tanto al sector central de la administración pública como al descentralizado¹³⁴. Así mismo, es predicable de los servidores públicos vinculados a instituciones del orden nacional y de las entidades territoriales¹³⁵.

(v) Las medidas que adopten las entidades públicas en el marco de la aplicación de la protección derivada del denominado “*retén social*” no pueden implicar un trato discriminatorio entre las personas o grupos que son

Ríos); T-802 de 2012 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio); T-729 de 2010 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva); T-353 de 2010 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva); T-1239 de 2008 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra); T-200 de 2006 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra); T-1030 de 2005 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto); T-846 de 2005 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).

133Sentencia T-662 de 2009 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).

134Sentencia T-1238 de 2008 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra); T-645 de 2009 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez); SU-388 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández).

135En la sentencia T-724 de 2009 (M.P. Mauricio González Cuervo) esta Corporación precisó sobre el particular: “*En este orden de ideas, no cabe duda que si bien es cierto la Ley 790 de 2002 solamente se aplica a los procesos de reestructuración de las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional, no lo es menos que las entidades territoriales que deciden modernizar, actualizar y modificar las plantas de personal también deben diseñar programas dirigidos a proteger la estabilidad laboral reforzada de los trabajadores que se ubican en el sector de los sujetos de especial protección del Estado, tales como los previstos en esa normativa. Luego, se concluye que en aplicación directa de los artículos 1º, 13, 25, 43 y 44 de la Constitución, los beneficios previstos en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002, también se aplican a los trabajadores de las entidades de la rama ejecutiva del sector territorial.*”. Igualmente, son pertinentes las sentencias T-420 de 2017 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger); T-835 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva); T-444 de 2010 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto); T-353 de 2010 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva); T-862 de 2009 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio); T-1031 de 2006 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), entre otras.

titulares de especial protección. Por tanto, no sería admisible garantizar la estabilidad laboral de las personas en situación de discapacidad y excluir de protección a los “*pre pensionados*”¹³⁶.

(vi) Finalmente, se reitera que la estabilidad laboral originada en el llamado “*retén social*” no es absoluta. Por tanto, los titulares de esta protección pueden ser desvinculados cuando medie una justa causa de terminación de la relación laboral debidamente comprobada. Además, su estabilidad laboral se materializa mediante el reintegro —siempre y cuando ello se encuentre dentro de las posibilidades fácticas y jurídicas— y se extiende hasta la terminación definitiva del proceso liquidatorio de la entidad respectiva o hasta que cesen las condiciones que originan la especial protección¹³⁷.

Solución del caso concreto

56. Omaira Jaqueline Nandar de la Cruz y Guillermo Alfonso Pasijojoa Nandar presentaron acción de tutela en contra del Municipio de Ipiales, por considerar que la decisión de esta entidad de suprimir el cargo que ocupaba la tutelante pese a su condición de madre cabeza de familia, tomada en el marco del proceso de modernización y reestructuración del Municipio de Ipiales, vulneró sus derechos fundamentales a la vida digna, al trabajo, a la seguridad social, al mínimo vital, a la estabilidad laboral reforzada y a la educación y formación integral de los adolescentes.

La accionante fue designada con carácter de provisionalidad en el cargo de “*Profesional Universitario Código 219, Nivel 2, Grado 2*” y mientras se encontraba vinculada a la entidad accionada, la Subsecretaria de Talento Humano convocó a todos los servidores públicos de la entidad que estuvieran en las circunstancias enmarcadas en el denominado “*retén social*” para que acreditaran dicha condición.

Así, en cumplimiento de los requisitos previstos por el Municipio de Ipiales, la actora allegó la documentación requerida. Incluso, dicha dependencia le solicitó que precisara ciertos aspectos de su declaración extraproceso, con el fin de demostrar su calidad de madre cabeza de familia, requerimiento que la tutelante absolvió oportunamente.

57. El Municipio de Ipiales solicitó desestimar las pretensiones de la actora, por considerar que no cumplía los requisitos para ser beneficiaria del denominado “*retén social*” en calidad de madre cabeza de familia.

136 “[L]a Sala considera que el no aplicar la protección especial a los trabajadores próximos a pensionarse –como sí se hizo con los padres y madres cabeza de familia y los trabajadores discapacitados- resulta en una vulneración del principio de igualdad, consagrado en el artículo 13 de la Constitución.” Sentencia T-444 de 2010 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).

137 Fundamentos jurídicos 48 a 51.

Por una parte, adujo que el padre del hijo de la accionante es pensionado por invalidez y, por tanto, tiene una obligación legal de sufragar los gastos de subsistencia de aquel. Además, indicó que la tutelante había asumido “*una actitud omisiva o displicente*”¹³⁸, dado que no acudió a los mecanismos judiciales para reclamar al progenitor de su hijo la observancia de sus obligaciones alimentarias.

Por otra, señaló que la actora tiene estudios profesionales en contaduría y un título de secretaria ejecutiva y, además, es propietaria de un bien inmueble por lo que cuenta con una “*alternativa económica*” para obtener ingresos.

58. El juzgado de primera instancia declaró improcedente la acción de tutela. En su criterio, la solicitante no era beneficiaria de la figura del “*retén social*” dado que la Ley 790 de 2002 no resulta aplicable al Municipio de Ipiales por no ser una entidad del orden nacional y no encontrarse en proceso de liquidación. Así mismo, sostuvo que la accionante no se encontraba en una situación de debilidad manifiesta dado que contaba con un inmueble propio, tenía un título profesional, sus deudas no se encontraban en estado de cobro prejurídico y no había adelantado ninguna acción judicial para reclamar al progenitor de su hijo el cumplimiento de sus deberes familiares.

59. Por su parte, el juez de segunda instancia revocó la decisión anterior y, en su lugar, negó la protección de los derechos invocados. Así, aunque aseveró que la acción de tutela era procedente para discutir la vulneración de derechos fundamentales en el marco del llamado “*retén social*”, sostuvo que la accionante no tenía derecho a la estabilidad laboral prevista para las madres cabeza de familia, dado que; (i) contaba con una alternativa económica, dada su actividad profesional; (ii) no había demostrado la deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros de la familia; y (iii) no se había probado que el padre de su hijo se había sustraído de sus obligaciones alimentarias por un motivo que le impidiera cumplir con las mismas.

60. A partir de los hechos anteriormente relatados, la Sala Sexta de Revisión debe determinar si el Municipio de Ipiales desconoció los derechos fundamentales de la accionante Omaira Jaqueline Nandar de la Cruz y de su hijo Guillermo Alfonso Pasijojoa Nandar con su decisión de suprimir el cargo que aquella ocupaba, sin garantizar la estabilidad laboral reforzada que se deriva del denominado “*retén social*”, por considerar que la actora no tenía derecho a tal prerrogativa.

Por consiguiente, a partir de las reglas jurisprudenciales enunciadas en los acápites precedentes, corresponde ahora establecer si la tutelante tiene derecho a la estabilidad laboral reforzada originada en el “*retén social*”. Para tal efecto, resulta necesario **(i) que la solicitante haya acreditado debidamente los requisitos para ser considerada madre cabeza de familia y (ii) que sea aplicable a su caso la protección derivada del “retén social”.**

138 Cuaderno No. 1, folio 74.

Verificación de los requisitos exigidos para que la accionante Omaira Jaqueline Nandar de la Cruz sea considerada como madre cabeza de familia.

61. Como fue explicado en los acápites anteriores, para acreditar la condición de madre cabeza de familia, de conformidad con la jurisprudencia constitucional y el ordenamiento jurídico, se deben cumplir los siguientes presupuestos: (i) que la mujer tenga a cargo la responsabilidad de hijos menores de edad o de otras personas “*incapacitadas*” para trabajar; (ii) que la responsabilidad exclusiva de la mujer en la jefatura del hogar sea de carácter permanente; (iii) que exista una auténtica sustracción de los deberes legales de manutención por parte de la pareja o del padre de los menores de edad a cargo; y (iv) que exista una deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros de la familia.

62. En primer lugar, se encuentra suficientemente demostrado en el expediente que *la actora es la persona que brinda sustento económico, social y afectivo a su hijo* Guillermo Alfonso Pasijojoa Nandar. Esta circunstancia se encuentra sustentada en los siguientes medios probatorios:

(i) declaración juramentada de la accionante en la cual afirma su calidad de madre cabeza de familia¹³⁹; (ii) Registro Civil de Nacimiento en el cual consta que la señora Omaira Jaqueline Nandar de la Cruz es la madre de Guillermo Alfonso Pasijojoa Nandar¹⁴⁰; (iii) testimonios anticipados para fines judiciales (previstos en el artículo 188 del Código General del Proceso), rendidos bajo la gravedad del juramento por las señora Fabiola Estela Luna, María Lucila Tobar Miranda, Yuli del Rosario Estacio Bravo, y Fanny Patricia Acte Ramírez, en los cuales se indica que la accionante tiene a su cargo exclusivo el sostenimiento de su hijo y ofrecen detalles acerca de las responsabilidades que aquella asume respecto de su mantención¹⁴¹; (iv) declaración rendida por la accionante ante el juzgado de primera instancia, en la cual ratifica su condición de madre cabeza de familia y expresa que es la única responsable del sostenimiento de su hijo¹⁴²; (v) respuesta de la tutelante Omaira Jaqueline Nandar de la Cruz al cuestionario formulado por la Corte Constitucional en sede de revisión, en el cual se presenta una relación de gastos detallada y se afirma una vez más que es la persona que tiene a cargo de forma exclusiva la responsabilidad sobre su hijo¹⁴³; (vi) respuesta del accionante Guillermo Alfonso Pasijojoa Nandar en sede de revisión, en la cual ratifica lo

139Folio 31, Cuaderno No. 1.

140Folio 38, Cuaderno No. 1.

141Folios 42 a 45, Cuaderno No. 1.

142Folios 90 a 92, Cuaderno No. 1. En esta declaración, en relación con el progenitor de Guillermo Alfonso Pasijojoa Nandar, la actora indicó “*nunca he vivido con él, no vivo, no viviré ni convivo con el papá de mi hijo*”.

143Folios 47 a 66, Cuaderno de Revisión de la Corte Constitucional.

establecido por su madre en el presente proceso¹⁴⁴; (vii) ficha de base certificada del SISBEN, en la cual se constata que el hogar de la señora Omaira Jaqueline Nandar de la Cruz únicamente está conformado por ella y por su hijo¹⁴⁵.

Además, como fue expuesto anteriormente, una mujer no pierde su condición de cabeza de familia por el hecho de que las personas a su cargo alcancen la mayoría de edad¹⁴⁶. Por tanto, dado que el hijo de la tutelante actualmente está matriculado en el programa de mercadeo y ventas en la Universidad Mariana de Pasto¹⁴⁷, se configura el presupuesto de dependencia en relación con su madre.

63. En segundo lugar, está probado que la responsabilidad de la accionante Omaira Jaqueline Nandar de la Cruz en relación con su hijo estudiante mayor de edad *es permanente y exclusiva*, conclusión a la cual se arriba a partir de los medios de convicción allegados por la parte actora¹⁴⁸.

64. En tercer lugar, se considera acreditada la *sustracción de los deberes legales de manutención* por parte del padre de Guillermo Alfonso Pasijojoa Nandar. Sobre este particular, es evidente que la condición de pensionado por invalidez del señor Javier Guillermo Pasijojoa Cujar es insuficiente para concluir que la accionante no cumple con esta exigencia. En otras palabras, no resulta posible colegir que, si el progenitor del hijo de la actora recibe un ingreso económico, ello implica que dichos recursos contribuyen al sostenimiento del joven Pasijojoa Nandar.

En este punto, es preciso señalar que la Corte Constitucional ha tenido ocasión de pronunciarse acerca de la **imposibilidad de exigir** a las mujeres que alegan su condición de cabeza de familia “*el inicio de las acciones judiciales para demostrar la sustracción de los deberes legales*” del progenitor de sus hijos, toda vez que no existe una tarifa legal para demostrar este hecho.

144 Folios 67 a 71, Cuaderno de Revisión de la Corte Constitucional.

145 Folios 65 y 66, Cuaderno de Revisión de la Corte Constitucional.

146 Fundamento jurídico 32.

147 Esta circunstancia se encuentra sustentada en los siguientes medios probatorios: (i) certificado de estudios de Guillermo Alfonso Pasijojoa Nandar donde se informa que estaba inscrito en el programa de Mercadeo y Ventas de la Universidad Mariana de Pasto en el primer semestre de 2017 (folios 40 y 41, Cuaderno No.1); y (ii) respuesta del accionante Guillermo Alfonso Pasijojoa Nandar en sede de revisión (folios 67 a 71, Cuaderno de Revisión de la Corte Constitucional).

148 La Sala se remite a los aspectos enunciados en el fundamento jurídico 62, los cuales dan cuenta del cumplimiento del presente requisito.

Sentencia T-835 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).

Así, por ejemplo, en la **sentencia T-835 de 2012**, la Sala Novena de Revisión estudió el caso de una mujer cabeza de familia que había sido desvinculada de CAJANAL. Una de las razones que esgrimió la entidad accionada para el retiro de la actora fue que no cumplía los requisitos para formar parte del retén social. CAJANAL sostuvo que la solicitante tenía “*una alternativa de ingresos diferente a su salario, representado en el vehículo de servicio público de propiedad del padre de los menores*”. La Corte Constitucional llamó la atención de la entidad demandada (CAJANAL) por exigir a la accionante el inicio de las acciones judiciales para demostrar la sustracción de la obligación alimentaria del padre de los menores y concedió el amparo solicitado¹⁴⁹.

Así mismo, es oportuno resaltar que la condición de madre cabeza de familia no depende de una formalidad jurídica, debido a que esta calidad **se adquiere con las circunstancias materiales** que la configuran¹⁵⁰. Por tanto, la exigencia a la madre cabeza de familia de promover acciones judiciales para demostrar la sustracción de los deberes legales del padre de sus hijos, contradice esta regla general de interpretación.

65. Para la Sala, la conducta de la entidad accionada en relación con las exigencias impuestas para demostrar el requisito consistente en que el otro progenitor se haya sustraído de sus deberes legales de manutención, desconoció los derechos fundamentales de la accionante. En efecto, al sostener que la actora estaba obligada a reclamar judicialmente al progenitor de su hijo el cumplimiento de las responsabilidades propias de la paternidad, en atención al “*deber de autogestión*”, se desconoció el derecho fundamental a la dignidad humana de la accionante, como pasa a demostrarse.

De este modo, al calificar de “*omisiva*”, “*displicente*”, “*negligente*” y “*pasiva*” la decisión de la señora Omaira Jaqueline Nandar de la Cruz de abstenerse de emprender los mecanismos judiciales en contra del padre de su hijo, el Municipio de Ipiales **desconoció el contexto social y familiar en el cual tiene lugar la jefatura femenina del hogar cuando el padre de los hijos desatiende completamente sus deberes legales**.

En este sentido, la Corte ha recordado que el fenómeno de las familias monoparentales es predominantemente femenino¹⁵¹ y obedece a factores propios del contexto social y cultural¹⁵². Sobre el particular, ha dicho esta Corporación:

149Sentencia T-835 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).

150 Sentencias C-034 de 1999 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra) y SU-388 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández).

151Sentencia C-964 de 2003 (M.P. Álvaro Tafur Galvis). En igual sentido, la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) del año 2015 ha destacado el aumento en los hogares con jefatura femenina que pasó de 30.3%

en 2005 a 34% en 2010 y a 36.4% en 2015.

152Sentencia C-184 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

“Suponer que el hecho de la “maternidad” implica que la mujer debe desempeñar ciertas funciones en la familia, ha llevado, por ejemplo, a que tengan que soportar dobles jornadas laborales: una durante el día como cualquier otro trabajador y otra en la noche y en sus ratos libres, desempeñando las labores propias de la vida doméstica. Esta imagen cultural respecto a cuál es el papel que debe desempeñar la mujer dentro de la familia y a cuál “no” es el papel del hombre respecto de los hijos, sumada al incremento de separaciones, así como al número creciente de familias sin padre por cuenta del conflicto armado y la violencia generalizada, trajo como consecuencia que una cantidad considerable de grupos familiares tuvieran una mujer como cabeza del mismo” .

Por tanto, la calidad de mujer cabeza de familia no puede entenderse de manera aislada del entorno que rodea las instituciones familiares toda vez que es precisamente del contexto en que se desenvuelve tal situación de donde se deriva una especial protección para aquellas. En tal sentido, la protección especial no sólo se desprende de la carga económica que la mujer cabeza de familia debe asumir, sino también de la situación emocional que tal circunstancia implica.

No obstante, cuando se exige el inicio de las acciones judiciales respectivas a una mujer que ha asumido la jefatura femenina del hogar ante la omisión de los deberes legales del progenitor de su hijo, se debe tener en cuenta que ello desconoce las cargas que afrontan las madres cabeza de familia. A su vez, la imposición de este requisito entraña relaciones de poder como, por ejemplo, las derivadas de la sujeción que sufrió la mujer en el plano económico o de los roles y estereotipos de género que caracterizan al hombre como responsable del sustento de la familia.

De lo anterior, se infiere que es desproporcionado exigir determinadas acciones legales como presupuesto para la protección de las mujeres cabeza de familia en el plano laboral, pues el escenario del proceso judicial en el cual se reclama el cumplimiento de la obligación alimentaria o se persigue la privación de la patria potestad puede conllevar situaciones de violencia emocional o de revictimización, respecto de las cuales no es admisible que una persona sea obligada a asumir en contra de su voluntad en el marco de un Estado Social de Derecho fundado en la dignidad humana.

66. Con todo, la Sala advierte que la conducta de un padre que se sustrae de sus obligaciones como progenitor pese a tener capacidad económica desconoce las leyes civiles, es contraria a los deberes que la Constitución asigna a los miembros de la familia e, incluso, podría configurar un delito.

Por consiguiente, aunque la Sala no desconoce que, por regla general, ambos padres tienen deberes legales respecto de sus hijos y que resulta reprochable el incumplimiento de las obligaciones de manutención que tienen a su cargo,

ello no implica que la manera adecuada de proteger los derechos de las madres cabeza de familia sea mediante la imposición de exigencias desproporcionadas, que les impiden acceder a las garantías constitucionales de las cuales son titulares. Así, **el medio utilizado para racionalizar la protección de las personas cabeza de familia no es conducente para garantizar este fin.**

67. En este sentido, la administración impuso una exigencia implícita, consistente en que la mujer cabeza de hogar debe iniciar un proceso de alimentos o de privación de patria potestad, aspecto que está reservado a la decisión propia y a la intimidad de quien considera que es potencial beneficiario de la obligación alimentaria.

Además, la Sala insiste en que el requisito de sustracción del padre de los deberes legales a su cargo **puede ser probado mediante cualquier medio de convicción idóneo y conducente.**

68. Es de anotar que el Municipio de Ipiales estableció un procedimiento para determinar cuáles servidores públicos tenían derecho a la protección derivada del “*retén social*”, en el marco del cual **la entidad demandada consideró, en general, que las declaraciones extraproceso constituían prueba suficiente** de la responsabilidad solitaria de la madre en la manutención de su familia.

En concreto, los documentos solicitados por la administración municipal fueron: (i) registros civiles de nacimiento de los hijos; (ii) “*declaración extra proceso sobre su condición, ingresos y conformación del hogar*”; (iii) “*si se trata de estudios superiores, declaración de la dedicación exclusiva al estudio*”; y (iv) certificaciones de estudio originales¹⁵³. Así las cosas, la propia entidad demandada consideró que la declaración extraprocesal constituía un medio de convicción idóneo y conducente para demostrar el requisito de sustracción de los deberes legales del padre pues, como se evidencia, en el listado anterior no se incluyó ningún otro medio probatorio orientado a acreditar este hecho.

En consecuencia, la entidad accionada vulneró los derechos de la tutelante a la estabilidad laboral reforzada y a la igualdad, debido al modo en el que valoró su condición de madre cabeza de familia, por cuanto: (i) la calidad de madre cabeza de familia no depende de una formalidad jurídica sino de las circunstancias materiales que la configuran; y (ii) resulta contrario a la dignidad humana que se condicione la protección a la cual tiene derecho como madre cabeza de familia al inicio de un proceso judicial especialmente sensible, dado que involucra su situación familiar.

69. En cuarto lugar, respecto del requisito de la existencia de la responsabilidad solitaria de la madre para sostener el hogar, debe precisarse que en el caso concreto hay pruebas de la deficiencia sustancial de ayuda de

153Folio 15, Cuaderno No. 1.

los demás familiares¹⁵⁴ y no se comprobó que la demandante reciba alguna ayuda en la manutención de su hijo por parte de sus allegados.

En este sentido, la Sala encuentra que las declaraciones que la accionante Omaira Jaqueline Nandar de la Cruz ha realizado en varios momentos del proceso, las manifestaciones del joven Guillermo Alfonso Pasijojoa Nandar y los testimonios de las señoras Fabiola Estela Luna, María Lucila Tobar Miranda, Yuli del Rosario Estacio Bravo, y Fanny Patricia Acte Ramírez coinciden plenamente en afirmar que la responsabilidad de la tutelante es exclusiva y permanente y que, además, no recibe ningún tipo de ayuda de sus familiares o de otras personas cercanas.

70. Finalmente, cabe señalar que, a diferencia de lo esgrimido por la entidad accionada, para la Sala es claro que la tutelante carece de una “*alternativa económica*” distinta al ingreso que devengaba de su trabajo. En tal sentido, no son de recibo las afirmaciones según las cuales la accionante no es madre cabeza de familia en la medida en que (i) tiene estudios profesionales en contaduría y un título de secretaria ejecutiva, por lo que puede ejercer su profesión “*liberalmente*” y (ii) es propietaria de un bien inmueble.

Al respecto, es oportuno indicar que el Decreto 190 de 2003 establece una definición de madre cabeza de familia sin alternativa económica y se entiende como tal la mujer que tiene a cargo hijos menores o “*incapacitados*” para trabajar “*cuyo ingreso familiar corresponde únicamente al salario que devenga del organismo o entidad pública a la cual se encuentra vinculada*”¹⁵⁵.

Por tal motivo, el hecho de que la accionante sea contadora pública y secretaria no desvirtúa que su salario hubiera sido su única fuente de ingresos al momento de su desvinculación. Así mismo, su calidad de propietaria de un inmueble tampoco permite colegir que reciba ingresos a partir del mismo, aspecto que fue afirmado pero nunca probado por la parte demandada. Por el contrario, lo que se evidencia en el plenario es que la accionante adeuda varios servicios públicos de dicha propiedad¹⁵⁶, la cual además se encuentra hipotecada¹⁵⁷.

71. La Sala resalta que la entidad accionada y los jueces de instancia consideraron que la tutelante contaba con una alternativa económica, pues

154La Sala se remite a los aspectos enunciados en el fundamento jurídico 62, los cuales dan cuenta del cumplimiento del presente requisito.

155Artículo 1º del Decreto 190 de 2003.

156Folios 54 a 56, Cuaderno de Revisión de la Corte Constitucional.

157A folio 59 del Cuaderno de Revisión de la Corte Constitucional, consta la copia del certificado de tradición y libertad del inmueble de la accionante. En dicho documento, se advierte que en la anotación del 9 de junio de 2017 se registró la constitución del gravamen hipotecario sobre dicho inmueble.

tenía la posibilidad de reclamar judicialmente al padre de su hijo el cumplimiento de sus deberes como progenitor.

Este análisis es irrazonable por cuanto **se valora como actual y real una situación incierta y no consolidada**, pues actualmente la actora no cuenta con ese ingreso, por lo que cumple con las condiciones para considerarse madre cabeza de hogar. Además, este análisis tiene consecuencias desproporcionadas para la solicitante, pues implica que su condición de madre cabeza de familia depende necesariamente de la existencia y de los resultados de un proceso judicial que no es de carácter oficioso sino que está sujeto a la voluntad de iniciarlo del interesado.

Adicionalmente, la Corte advierte que este tipo de análisis sobre las “*alternativas económicas*” de las cuales dispone una madre cabeza de hogar deben hacerse sin perder de vista el contexto social, económico y cultural, así como las relaciones de poder y los estereotipos sobre roles de género que pueden estar involucrados. En el caso concreto, por ejemplo, el Municipio de Ipiales asumió que la accionante podía acudir al progenitor de su hijo, pese a que no tenía ningún contacto con él.

Por tanto, la entidad desconoció los derechos fundamentales de la accionante a la igualdad, al debido proceso, al trabajo y a la estabilidad laboral reforzada por cuanto omitió analizar debidamente su condición de madre cabeza de familia.

72. Aunado a lo anterior, la Sala resalta que el Municipio de Ipiales estableció un procedimiento administrativo para determinar cuáles servidores públicos eran beneficiarios del “*retén social*”. En el marco de dicho proceso: (i) la entidad accionada solicitó a los funcionarios que se consideraran titulares de la protección laboral reforzada, que allegaran la información para acreditar dichas circunstancias¹⁵⁸; (ii) la tutelante remitió varios documentos que daban cuenta de su condición de madre cabeza de familia¹⁵⁹; (iii) la Alcaldía de Ipiales solicitó que se subsanara una de las declaraciones extraprocesales aportadas por la actora¹⁶⁰; y (iv) la accionante presentó la declaración en la forma indicada por la autoridad administrativa¹⁶¹.

Sin embargo, a pesar de haberse surtido las etapas procesales expuestas, el Municipio de Ipiales desvinculó a la accionante **sin informarle previamente** acerca de la razón por la que consideró que aquella no tenía derecho a la

158 Cuaderno No. 1, folios 25 y 26.

159 Cuaderno No. 1, folios 27 y 28.

160 Cuaderno No. 1, folio 29.

161 Cuaderno No. 1, folios 30 y 31. La tutelante expresó en la comunicación dirigida a la Subsecretaría de Talento Humano de la Alcaldía Municipal de Ipiales que la declaración extra proceso que aportaba tenía como propósito “*acceder a la Protección Constitucional de Reten Social (sic)*”.

estabilidad laboral reforzada prevista para las madres cabeza de familia en desarrollo del “*retén social*”.

Dicha circunstancia, **impidió que la actora pudiera ejercer sus derechos de defensa y contradicción**¹⁶² en relación con la circunstancia por la cual fue excluida de los beneficios del “*retén social*”, es decir, la calidad de pensionado por invalidez que tenía el padre de Guillermo Alfonso Pasijojoa Nandar. En este sentido, la tutelante en ningún momento tuvo la oportunidad para desvirtuar la situación puesta de presente por la demandada en el proceso de tutela. Incluso, la actora manifiesta que se enteró de que el progenitor de su hijo devengaba una prestación económica durante el trámite del amparo constitucional.

Por ende, en criterio de la Sala, el Municipio de Ipiales debió haber informado a la accionante acerca de los motivos que condujeron a excluirla del listado de titulares de la protección derivada del “*retén social*”, habida cuenta de que aquella había surtido las etapas del procedimiento administrativo respectivo cuando fue requerida por la entidad territorial. No obstante, con su omisión respecto de este deber, desconoció una de las *garantías previas* que configuran el derecho al debido proceso administrativo, las cuales se predicán de la expedición y ejecución de las decisiones proferidas por la administración.

Adicionalmente, la Corte Constitucional estima que la indebida valoración de las circunstancias de la accionante también desconoció los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad de la actora Omaira Jaqueline Nandar de la Cruz, toda vez que, por una parte, **no existe una tarifa legal** para demostrar que el progenitor de los hijos de una madre cabeza de familia se sustrajo de sus deberes legales¹⁶³; por otra, porque la entidad accionada consideró, de manera general, que las declaraciones extraprocesales eran idóneas para acreditar la condición de madre cabeza de familia. Sin embargo, en el caso bajo estudio, la accionada estimó que este medio de convicción no constituía una prueba suficiente sin que se justifique debidamente la razón de este trato diferenciado.

En consecuencia, con base en las facultades *ultra* y *extra petita* del juez de tutela¹⁶⁴ y en la medida en que las circunstancias comprobadas en esta sede evidencian que se configuró una vulneración del derecho fundamental al debido proceso de la accionante, la Corte declarará su existencia.

162 En torno al derecho de defensa, este ha sido definido por la Corte Constitucional como “*el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso*” (Sentencia C-341 de 2014. M.P. Mauricio González Cuervo).

163 Sentencia T-420 de 2017 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger).

73. A partir de las consideraciones formuladas previamente, la Sala concluye que la señora Omaira Jaqueline Nandar de la Cruz tiene la condición de madre cabeza de familia, en la medida en que cumple con todos los requisitos que han sido señalados por la jurisprudencia constitucional para acreditar tal calidad.

Aplicabilidad al caso de la accionante Omaira Jaqueline Nandar de la Cruz de la protección especial derivada del denominado “retén social”.

74. Ahora bien, corresponde a la Sala Sexta de Revisión establecer si la accionante tiene derecho a la protección derivada del llamado “retén social”, dada su condición de madre cabeza de familia, que ha sido constatada por la Sala de conformidad con lo expuesto en los párrafos anteriores.

75. En este sentido, la Sala expondrá, con base en las consideraciones formuladas en los acápites anteriores¹⁶⁵, únicamente las reglas de decisión que se consideran **aplicables al caso concreto**:

(i) La protección de las mujeres cabeza de familia en el marco de procesos de reestructuración es “*un mandato constitucional*”¹⁶⁶. Por ende, su aplicación va más allá de las precisas circunstancias de la Ley 790 de 2002.

(ii) Las entidades públicas que se encuentran en procesos de modificación de la estructura de la administración (reestructuración, fusión, o liquidación de entidades, por ejemplo) deben aplicar las medidas propias del “retén social”, en los términos establecidos por la jurisprudencia constitucional.

(iii) La estabilidad laboral derivada del “retén social” es aplicable para servidores vinculados en provisionalidad. Sin embargo, es pertinente aclarar que cuando se trata de funcionarios nombrados en provisionalidad por un

164Esta Corporación ha sostenido que el juez de tutela está habilitado para fallar *ultra y extra petita*, cuando así lo requiera la vigencia de los derechos fundamentales pues “*la naturaleza especialísima de la acción de tutela permite su distinción respecto de las demás acciones legales, autorizando al juez asumir un papel activo en el análisis del caso bajo su conocimiento, en aras de la eficaz protección de los derechos fundamentales*” (Sentencia SU-195 de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio). Sobre este particular, véanse también: sentencias T-634 de 2017 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger); SU-484 de 2008 (M.P. Jaime Araújo Rentería); y T-886 de 2000 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).

165 Fundamentos jurídicos 41 a 55.

166 Sentencia T-827 de 2009 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez). Véanse también: sentencia T-326 de 2014 (M.P. María Victoria Calle Correa); sentencia T-587 de 2008 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto); sentencia T-1076 de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil); sentencia C-991 de 2004 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).

período de tiempo previamente delimitado, el alcance de la protección es diferente, en razón del carácter temporal que, de antemano, tenía la relación laboral.

(iv) La protección especial originada en el “*retén social*” cobija también a los servidores públicos vinculados a las entidades territoriales.

(v) Los trabajadores que alegan ser beneficiarios del “*retén social*” deben informar oportunamente a su empleador esta circunstancia, so pena de perder su derecho a recibir dicha protección especial.

76. En este sentido, se observa que el Municipio de Ipiales es una entidad territorial que llevó a cabo un proceso de modernización y reestructuración, en el marco del cual expidió el Decreto 016 del 31 de enero de 2017¹⁶⁷. Dicho acto administrativo suprimió de la planta de personal varios cargos, entre ellos el que desempeñaba la accionante, quien se encontraba vinculada en provisionalidad.

77. A partir del marco fáctico anterior, la Sala estima que la protección especial derivada del denominado “*retén social*” es aplicable al caso de la accionante. Dicha conclusión se sustenta en los siguientes razonamientos:

(i) El derecho a la estabilidad laboral reforzada de la accionante no se deriva de la Ley 790 de 2002.

(ii) El Municipio de Ipiales llevó a cabo un proceso de modernización y reestructuración.

(iii) La accionante se encontraba vinculada en provisionalidad por un término definido. En efecto, fue nombrada en provisionalidad por un lapso de seis meses en el cargo de “*Profesional Universitario Código 219, Nivel 2, Grado 2*”. Dicho nombramiento fue prorrogado por un período idéntico¹⁶⁸. En este sentido, la Sala observa que el acto administrativo que comunicó la supresión del cargo a la actora se limitó a manifestar esta circunstancia sin presentar de manera suficiente las razones del servicio que justificaban su retiro, en los términos de la parte motiva de esta providencia. Por tanto, es pertinente resaltar que la entidad accionada pudo haber desvinculado a la tutelante, si hubiera cumplido con la carga argumentativa respectiva, habida cuenta de la condición de servidora pública vinculada en provisionalidad por un plazo determinado.

167 Cuaderno No. 1, folios 48-55. El referido acto administrativo se fundamentó en que el alcalde municipal de Ipiales modificó la estructura organizacional del municipio, con lo cual se requirió actualizar la planta global de empleos para incorporar las modificaciones necesarias para implementar y desarrollar la nueva estructura. En tal sentido, se evidencia que la reforma de la planta de personal se enmarca en un proceso de modernización institucional.

168 Cuaderno No. 1, folios 17 a 24.

(iv) El Municipio de Ipiales es una entidad territorial.

(v) La actora informó oportunamente acerca de su calidad de madre cabeza de familia, toda vez que remitió, dentro de los plazos indicados por la entidad, la documentación requerida por la institución demandada¹⁶⁹.

78. Finalmente, el deber del Municipio de Ipiales de aplicar medidas para garantizar la estabilidad laboral reforzada de las personas cabeza de familia tiene una fuente adicional: **la propia entidad territorial decidió llevar a cabo un procedimiento para identificar a los posibles titulares de la protección especial derivada del “retén social”**. Por consiguiente, en virtud del principio de buena fe y la prohibición de desconocer los actos propios¹⁷⁰, la parte accionada tenía la obligación de respetar la estabilidad laboral reforzada para aquellos servidores que, como en el caso de la accionante, acreditaran debidamente las calidades para ser beneficiarios de la estabilidad laboral referida.

Además, la jurisprudencia constitucional ha destacado que, cuando las entidades públicas, en el marco de procesos de modificación de su estructura administrativa, deciden llevar a cabo procedimientos para garantizar la protección especial a los servidores que son titulares del llamado “*retén social*”, deben observar rigurosamente los parámetros que la Corte Constitucional ha fijado en tales casos, con el propósito de garantizar la igualdad material¹⁷¹.

79. Con fundamento en lo anterior, se concluye que la accionante tiene la condición de madre cabeza de familia y que es titular de la protección derivada del denominado “*retén social*” debido a las circunstancias en las que ocurrió su desvinculación.

Conclusiones y órdenes a proferir

80. La Sala Sexta de Revisión considera que la entidad accionada vulneró los derechos fundamentales de la accionante y de su hijo al suprimir el cargo que desempeñaba la actora sin garantizar la protección especial a la que tenía derecho en su condición de madre cabeza de familia, dentro del denominado “*retén social*”.

81. Para fundamentar la conclusión anterior, la Corte Constitucional verificó que la tutelante acredita la condición de madre cabeza de familia, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, toda vez que: (i) tiene a su

169 Cuaderno No. 1, folios 27 a 31.

170 Acerca de la prohibición de desconocer los actos propios, ver: sentencia T-295 de 1999 (M.P. Alejandro Martínez Caballero); sentencia C-131 de 2004 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández).

171 Sentencia T-444 de 2010 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto) y sentencia T-455 de 2011 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).

cargo la responsabilidad de su hijo que, aunque es mayor de edad, actualmente cursa estudios universitarios por lo que es una persona dependiente de ella; (ii) la responsabilidad de la actora en la jefatura del hogar es permanente y exclusiva; (iii) existe una auténtica sustracción de los deberes legales de manutención por parte del padre de su hijo; y (iv) existe una deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros de la familia. Posteriormente, se analizó si resultaba aplicable la protección especial derivada del denominado “*retén social*” al caso de la accionante y se estableció que el Municipio de Ipiales debía respetar la condición de la tutelante como madre cabeza de familia en el marco del proceso de reestructuración llevado a cabo mediante Decreto 016 del 31 de enero de 2017.

82. En este orden de ideas, dado que la accionante tiene la calidad de madre cabeza de familia y en su caso es aplicable la protección derivada del denominado “*retén social*”, la Sala **revocará** la decisión de segunda instancia para, en su lugar, **conceder** de manera definitiva la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, al debido proceso, a la dignidad humana, al mínimo vital y a la seguridad social.

Como consecuencia de ello, se ordenará al Municipio de Ipiales que, dentro del término de cinco (5) días, **reintegre** a la accionante, si ella así lo desea, a un cargo de iguales o mejores condiciones al que ocupaba, sin solución de continuidad desde el 2 de febrero de 2017. En relación con la orden de reintegro, la Sala advierte que la entidad accionada en ningún momento alegó la existencia de una imposibilidad fáctica o jurídica para que la accionante fuera incorporada a un cargo igual, equivalente o de mejores condiciones. Por tanto, se estima que esta medida, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, es la que protege de mejor manera los derechos fundamentales de la accionante y de su hijo. No obstante, se observa que la accionante fue vinculada en provisionalidad por un término de seis meses y dicho nombramiento fue prorrogado por un período idéntico. En este sentido, resulta forzoso precisar que la tutelante podrá ser desvinculada por la entidad accionada siempre y cuando (i) exista una justa causa de terminación de la relación laboral debidamente comprobada; (ii) cesen las condiciones que originan la especial protección; y (iii) existan razones objetivas del servicio que justifiquen de manera suficiente la desvinculación de la funcionaria en particular, caso en el cual la carga argumentativa recae en la administración.

83. Así mismo, se dispondrá que la entidad accionada **reconozca y pague** a la accionante todos los salarios y prestaciones sociales a las cuales tenía derecho desde la fecha en la cual fue desvinculada y hasta el momento en que sea efectivamente incorporada a la nómina de la entidad. Sin embargo, la Sala advierte que el pago de la compensación tiene origen en el despido de la peticionaria, razón por la cual la señora Nandar de la Cruz debe, a su turno, **reintegrar** a la administración municipal el dinero que le fue cancelado a título de indemnización.

En tal sentido, el Municipio de Ipiales deberá adelantar el cruce de cuentas correspondiente y, en caso de resultar saldos a favor de la entidad, **deberá** ofrecer facilidades de pago a la accionante, de modo que se garantice su subsistencia digna y la de su hijo, toda vez que, si la restitución de la indemnización se exige en un solo momento, tales derechos podrían resultar afectados.

Por otra parte, dado que la accionante se desempeñó como contratista del Municipio de Pupiales entre los meses de junio y diciembre de 2017, en el referido cruce de cuentas la entidad accionada **deberá tener en cuenta esta circunstancia** con el objetivo de observar estrictamente la prohibición de percibir más de una asignación del tesoro público, prevista en el artículo 128 de la Constitución Política¹⁷².

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución Política,

RESUELVE

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia de segunda instancia dictada el 17 de mayo de 2017 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ipiales que, a su vez, revocó la decisión de primera instancia, proferida el 24 de marzo de 2017 por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Ipiales. En su lugar, **CONCEDER** el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, al debido proceso, a la dignidad humana, al mínimo vital y a la seguridad social de Omaira Jaqueline Nandar de la Cruz y Guillermo Alfonso Pasijojoa Nandar, por las razones expuestas en este fallo.

SEGUNDO.- ORDENAR al Municipio de Ipiales que, dentro del término de cinco (5) días, contados a partir de la notificación del presente fallo, proceda a **REINTEGRAR** a la accionante Omaira Jaqueline Nandar de la Cruz, si ella así lo desea, a un cargo de iguales o mejores condiciones al que ocupaba, sin solución de continuidad desde el 2 de febrero de 2017 y hasta cuando (i) exista una justa causa de terminación de la relación laboral debidamente comprobada; (ii) cesen las condiciones que originan la especial protección; y/o (iii) existan razones objetivas del servicio que justifiquen de manera suficiente la desvinculación de la funcionaria en particular, caso en el cual la carga argumentativa recae en la administración.

172“**Artículo 128.** Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas”.

TERCERO.- ORDENAR al Municipio de Ipiales que **reconozca y pague** a la accionante todos los salarios y prestaciones sociales a las cuales tenía derecho desde la fecha en la cual fue desvinculada y hasta el momento en que sea efectivamente incorporada a la nómina de la entidad.

El Municipio de Ipiales deberá adelantar el cruce de cuentas correspondiente y, en caso de resultar saldos a favor de la entidad, **deberá** ofrecer facilidades de pago a la accionante, de modo que se garantice su subsistencia digna y la de su hijo, toda vez que, si la restitución de la indemnización se exige en un solo momento, tales derechos podrían resultar afectados.

Igualmente, dado que la accionante se desempeñó como contratista del Municipio de Pupiales entre los meses de junio y diciembre de 2017, en el referido cruce de cuentas la entidad accionada **deberá tener en cuenta esta circunstancia** con el objetivo de observar estrictamente la prohibición de percibir más de una asignación del tesoro público, prevista en el artículo 128 de la Constitución Política.

CUARTO.- Por Secretaría General de esta Corporación, **LÍBRESE** la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada

CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General

TEMAS-SUBTEMAS

Sentencia C-197/25

SISTEMA ESPECIFICO DE CARRERA DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN-Restricción para utilizar listas de elegibles cuando el cargo está siendo ocupado en encargo o provisionalidad desconoce el principio del mérito y los derechos a la igualdad, al debido proceso y al acceso a cargos públicos

La Corte Constitucional concluye que el inciso tercero del párrafo transitorio del artículo 36 del Decreto Ley 927 de 2023 es inconstitucional. Lo anterior, porque el fragmento cuestionado no superó los juicios de igualdad y proporcionalidad en su dimensión estricta; si bien la norma cumple una finalidad imperiosa y constitucionalmente importante, como lo es la de garantizar una continuidad y eficiencia del servicio que presta la DIAN y el medio empleado de restringir que se utilicen las listas de elegibles cuando el cargo está siendo provisto en encargo o provisionalidad es efectivamente conducente para la consecución del fin., la medida no es necesaria, en tanto existen otras alternativas que no comprometen el principio constitucional del mérito y los derecho fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a cargos públicos Además, es evidentemente desproporcionada porque el beneficio que otorga la medida a propósito de alcanzar la finalidad no es proporcional al impacto que ocasiona a las prerrogativas constitucionales mencionadas.

COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Inexistencia por objeto y contenidos normativos diferentes

PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DEL MERITO-Criterio rector del acceso a la función pública

CARRERA ADMINISTRATIVA-Fundada en el mérito como principio constitucional y como regla general para la provisión de cargos públicos

CARRERA ADMINISTRATIVA Y PRINCIPIO DEL MERITO-Jurisprudencia constitucional

CARRERA ADMINISTRATIVA Y CONCURSO DE MERITOS-Reglas

CONCURSO DE MERITOS-Etapas

LISTA DE ELEGIBLES-Concepto

APLICACION DE LA LISTA DE ELEGIBLES-Jurisprudencia constitucional

(...) en virtud de la jurisprudencia constitucional, el uso de las listas de elegibles es obligatorio -y no facultativo- para la administración, indistintamente al tipo de sistema de carrera al que pertenezca; sean los que se gobiernan por la Ley 909 de 2004 o aquellos en que ese marco regulatorio se aplica de forma supletiva. Pues

bien, en ambas circunstancias, el nominador debe utilizar las listas de elegibles vigentes para cubrir las nuevas vacantes definitivas que se produzcan con posterioridad a la convocatoria del concurso y que tengan correspondencia con el empleo que fue ofertado. Finalmente, ha dicho la jurisprudencia, la conformación de las listas de elegibles genera o un derecho subjetivo o una mera expectativa; si los aspirantes ocupan las primeras plazas ofertadas, tienen un derecho subjetivo a ser nombrados en periodo de prueba en los cargos vacantes, mientras que si no alcanzan los primeros lugares, tienen solamente una mera expectativa.

PRINCIPIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN ACCESO A CARGOS PUBLICOS-Provisión de vacantes atendiendo lista de elegibles

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD O ENCARGO-Naturaleza/NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD O ENCARGO-Reglas

(...) los cargos en provisionalidad y encargo son constitucionales, porque permiten darle continuidad al servicio de la administración, y con ello, alcanzar los fines del Estado Social de Derecho y, además, preserva el derecho de acceder a cargos públicos en igualdad de condiciones. Sin embargo, el Legislador debe limitar su aplicación, a fin de preservar la naturaleza excepcional y temporal del nombramiento en provisionalidad y encargo, al cumplimiento de las siguientes reglas: (i) la estricta necesidad de proveer el cargo debe encontrarse identificada y explicada en un acto administrativo motivado, en procura del principio de transparencia; (ii) su duración no puede prolongarse indefinidamente, pues ello va en desmedro de la carrera administrativa y del derecho a la igualdad en el acceso a empleos y funciones públicas y (iii) su utilización se justifica siempre que no se emplee como un mecanismo para eludir la obligación de proveer cargos mediante procesos de selección objetivos e igualitarios, sino como una medida para asegurar la continuidad del servicio. Además, los cargos provistos en encargo o provisionalidad también revisten de ciertas diferencias.

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD O ENCARGO-Diferencia

(...) la jurisprudencia constitucional también ha sabido diferenciar los cargos por encargo y en provisionalidad. Al respecto, ha sostenido que si bien se trata -en ambos casos- de personas que desean ocupar transitoriamente un empleo público, los encargos son ocupados por empleados públicos inscritos en la carrera administrativa de la entidad, mientras que los provisionales son provistos por particulares que adquieren la calidad de empleados públicos en provisionalidad. La Corte Constitucional ha dicho que se trata de sujetos distintos; los empleados públicos de carrera son servidores públicos que demuestran los méritos requeridos para el ejercicio del cargo, en cambio, el nombramiento de empleados en provisionalidad es una figura excepcional en la que personas que no detentan previamente la calidad de servidores públicos y que no son seleccionados mediante concurso de méritos, aspiran a ser seleccionadas para el ejercicio transitorio de empleos de carrera y cuya estabilidad relativa depende de la provisión del cargo

mediante el correspondiente concurso de méritos. En este último supuesto, no se otorgan derechos propios de carrera ni se generan expectativas indefinidas en el cargo.

SISTEMA DE CARRERA ADMINISTRATIVA-Categorías

SISTEMAS ESPECIFICOS DE CARRERA-Se ajustan a la Constitución siempre que respeten el principio general en virtud de la previsión de procedimientos de selección y acceso basados en el mérito

(...) la jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en sostener que estos sistemas específicos se ajustan a la Constitución y se enmarcan en las competencias del Legislador, en la medida en que respeten el interés general. Esto es, que garanticen los procesos de selección y contribuyan a la realización de los principios de la Constitución y los derechos fundamentales, entre ellos, el del mérito.

SISTEMAS ESPECIFICOS DE CARRERA-Características

(i) tanto los sistemas generales como los específicos de carrera, por mandato constitucional del artículo 130, deben ser administrativos y vigilados por la CNSC, lo que implica la unificación de criterios para la estructura de los concursos y la competencia en la operatividad de los mismos en cabeza de esa entidad; (ii) los sistemas específicos de carrera están sometidos a los principios que gobiernan los sistemas generales de carrera, por lo que no pueden rebasarlos y (iii) las regulaciones específicas en materia de ingreso, capacitación, permanencia, ascenso y retiro del personal de la entidad no pueden interpretarse en desmedro de los principios generales del sistema general de carrera, como lo son la igualdad, la imparcialidad, el mérito, entre otros.

SISTEMA ESPECIFICO DE CARRERA DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN-Jurisprudencia constitucional

El sistema específico de carrera administrativa de la DIAN: (i) está sujeto a la administración y vigilancia de la CNSC; (ii) las regulaciones específicas para el ingreso, capacitación, permanencia, ascenso y retiro del sistema responden a las necesidades técnicas y especializadas de la entidad; no obstante, deben interpretarse a la luz de los principios que gobiernan los sistemas generales de carrera administrativa, entre los que se encuentran la igualdad, la imparcialidad y el mérito, entre otros; y, (iii) existen unos elementos mínimos para determinar la conformidad de las regulaciones especiales de los sistemas de concursos de carrera con la Constitución, por lo que si alguno se desvirtúa, la regulación es inconstitucional.

CONFIGURACION LEGISLATIVA PARA REGULAR CONDICIONES Y REQUISITOS PARA ACCESO A CARGOS PUBLICOS-Criterios de razonabilidad y proporcionalidad

JUICIO DE PROPORCIONALIDAD Estricto-Aplicación

REPÚBLICA DE COLOMBIA



**CORTE CONSTITUCIONAL
Sala Plena**

SENTENCIA C-197 DE 2025

Expedientes: D-15.948 y D-15.971 AC

Demandas de inconstitucionalidad en contra del artículo 36 (parcial) del Decreto Ley 927 de 2023, “[p]or el cual se modifica el Sistema Específico de Carrera de los empleados públicos de la Unidad Administrativa Especial -DIAN y la regulación de la administración y gestión de su talento humano.”

Magistrado ponente: Jorge Enrique Ibáñez Najar

Bogotá, D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

La Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial, de las consagradas en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, así como en el artículo 40.6 del Decreto 2067 de 1991, con motivo de la demanda de inconstitucionalidad presentada en contra del artículo 36 (parcial) del Decreto Ley 927 de 2023, “[p]or el cual se modifica el Sistema Específico de Carrera de los empleados públicos de la Unidad Administrativa Especial -DIAN y la regulación de la administración y gestión de su talento humano,” ha proferido la siguiente,

SENTENCIA

Síntesis de la decisión

La Corte Constitucional resolvió una demanda de inconstitucionalidad en contra del inciso tercero del párrafo transitorio del artículo 36 del Decreto Ley 927 de 2023, la

cual consideró que la norma en cuestión vulneraba los artículos 13, 29, 40.7, 125, 209 y 334 de la Constitución. Antes de pronunciarse sobre el fondo de la controversia, la Corte absolvió dos cuestiones preliminares: (i) concluyó que los cargos de las demandas son aptos, con excepción del cargo por la vulneración de los artículos 209 y 334 de la constitución, que no superó el presupuesto de *especificidad y suficiencia* y, (ii) encontró que no hay lugar a la configuración de la cosa juzgada material en tanto no existe *identidad de objeto* entre la disposición analizada en la Sentencia C-331 de 2022 y la que originó el análisis de constitucionalidad en el presente caso.

Para efectos de resolver el problema jurídico, la Corte se pronunció sobre: (i) el mérito y el régimen de carrera administrativa (ii) los sistemas especiales de carrera administrativa y la carrera administrativa específica en la DIAN y, finalmente (iii) resolvió sobre la constitucionalidad del inciso tercero del párrafo transitorio del artículo 36 del Decreto Ley 927 de 2023.

La Corte Constitucional concluyó que el inciso tercero del párrafo transitorio del artículo 36 del Decreto Ley 927 de 2023 es inexecutable. Lo anterior, porque el fragmento cuestionado no superó el juicio de proporcionalidad en su dimensión *estricta*. Si bien la norma cumple una finalidad imperiosa, como lo es la de garantizar una continuidad y eficiencia del servicio que presta la DIAN y el medio empleado, esto es, restringir que se utilicen las listas de elegibles cuando el cargo está siendo provisto en encargo o provisionalidad es efectivamente conducente para la consecución del fin, no es necesario, pues la administración cuenta con otros mecanismos que le permitirían alcanzar dicho propósito.

Además, es desproporcionada en sentido *estricto*, ya que la norma privilegia los nombramientos en encargo o en provisionalidad, al punto de desconocer el principio del mérito, el debido proceso, el acceso a cargos públicos y, además, propiciar un tratamiento discriminatorio que beneficia a los ocupantes de cargos de forma temporal en detrimento de los derechos de quienes ocuparon los primeros puestos en las listas de elegibles como resultado de un concurso de méritos. En consecuencia, la consecución de la continuidad y la eficiencia en la prestación del servicio no amerita que se desconozcan las mencionadas prerrogativas constitucionales, las cuales además de que gozan de una connotación *iusfundamental per se*, son el cimiento del principio constitucional del mérito como eje axial de la Constitución

I. ANTECEDENTES

Los ciudadanos Jeison Eduardo García Ariza y Luis Fernando Lozada Elizalde presentaron demandas de inconstitucionalidad, en escritos separados pero que fueron acumulados por disposición de la Sala Plena,¹ en contra del inciso tercero del

¹ Expediente digital D-15.948 AC contenido en *Siicor*, documento denominado “D0015948-Acta de Reparto-(2024-07-15 08-16-09).pdf.”

parágrafo transitorio del artículo 36 del Decreto Ley 927 de 2023 “[p]or el cual se modifica el Sistema Específico de Carrera de los empleados públicos de la Unidad Administrativa Especial (DIAN) y la regulación de la administración y gestión de su talento humano.” En su criterio, la norma objeto de censura desconoce los artículos 13, 29, 40, 125, 209 y 334 de la Constitución Política porque prohíbe el uso de las listas de elegibles cuando el cargo está siendo ocupado en encargo o provisionalidad, lo que va en desmedro del mérito, del acceso a cargos públicos en igualdad de oportunidades y del uso eficiente de los recursos públicos por parte del Estado.

La norma demandada

A continuación, se transcribe la norma demandada y se subrayan las expresiones objeto de admisión:

“DECRETO LEY 927 DE 2023 *(junio 7)*²

Por el cual se modifica el Sistema Específico de Carrera de los empleados públicos de la Unidad Administrativa Especial -DIAN y la regulación de la administración y gestión de su talento humano

DECRETA:

(...)

ARTÍCULO 36. USO DE LISTA DE ELEGIBLES. *Una vez provistos los empleos objeto del concurso, la lista de elegibles tendrá una vigencia de un (1) año, contado a partir de su firmeza.*

La lista de elegibles deberá ser utilizada en estricto orden descendente para vacantes generadas con posterioridad a la convocatoria, siempre y cuando los requisitos del empleo sean los mismos y sus funciones iguales o equivalentes.

PARÁGRAFO 1. *Si al hacer uso de la lista de elegibles no se acepta el nombramiento o no se acude a la posesión dentro del término establecido en las normas legales se entenderá que la persona queda excluida de la lista y se continuará con la provisión de los empleos en estricto orden de resultados.*

PARÁGRAFO 2. *Para asegurar que la Entidad adelante sus competencias en todas las seccionales y delegadas con altos niveles de excelencia y con los mejores perfiles profesionales, los empleados públicos que superen el periodo de prueba deberán permanecer en el lugar o sede donde se encuentra el empleo público mínimo dos (2) años. Lo anterior sin perjuicio de las potestades que corresponde al Director de reubicación de los empleos públicos en la planta*

² Diario Oficial No. 52.419 de 7 de junio de 2023.

global y flexible y, en general, de manejo de personal para atender las necesidades del servicio.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. *En aplicación de los principios de economía, sostenibilidad fiscal y austeridad del gasto, las listas de elegibles resultantes de los concursos realizados en virtud del parágrafo transitorio del artículo 32 del Decreto-Ley 071 de 2020, luego de que los empleos ofertados sean provistos en estricto orden de méritos, deberán ser utilizadas dentro del término de su vigencia para proveer vacantes generadas con posterioridad a las convocatorias, así como aquellas derivadas de la ampliación de la planta de personal, siempre y cuando los requisitos del empleo sean los mismos y sus funciones iguales o equivalentes.*

El proceso de selección cuya convocatoria y reglas se encuentran establecidas en el Acuerdo No. CNT2022AC000008 del 29 de diciembre de 2022, seguirá su curso con independencia de la etapa en que se encuentre y, una vez conformada la lista de elegibles, esta deberá ser utilizada dentro del término de su vigencia para proveer las vacantes ofertadas y aquellas que se generen con posterioridad derivadas de la ampliación de la planta de personal, siempre y cuando los requisitos del empleo sean los mismos y sus funciones iguales o equivalentes.

En todo caso, las listas de elegibles a que hace referencia el presente parágrafo transitorio no podrán utilizarse si el empleo público se encuentra provisto mediante encargo o provisionalidad. Estos cargos públicos deberán ser ofertados en una nueva convocatoria aplicando las reglas previstas en este Decreto-Ley.”

Contenido de las demandas

1. En Auto mixto del 29 de julio de 2024, se admitió la demanda radicada con el número D-15.948 respecto de los cargos *primero* (presunto desconocimiento del artículo 29 de la Constitución Política) y *segundo* (presunto desconocimiento del artículo 125 de la Constitución Política). Por su parte, en lo relativo al expediente D-15.971, fue admitido parcialmente el cargo *primero* (únicamente por el presunto desconocimiento del artículo 125 de la Constitución Política) e inadmitido el resto del cargo *primero* (en lo referido al presunto desconocimiento de los artículos 13 y 40 de la Constitución Política) y el cargo *segundo* (por el presunto desconocimiento de los artículos 209 y 334 de la Constitución).³

³ Expediente digital D-15.948 AC contenido en Siicor, documento denominado “D0015948-Auto Mixto-(2024-07-31 03-17-20).pdf.”

2. A su turno, en sede de admisión se evidenció que no se configuraba el fenómeno de cosa juzgada constitucional respecto de la Sentencia C-331 de 2022, al no darse una *identidad de objeto* entre la disposición demandada que motivó la providencia en mención -el artículo 34⁴ del Decreto Ley 071 de 2020⁵- y la que originó el análisis de constitucionalidad en esta oportunidad -el artículo 36 del Decreto Ley 927 de 2023-. En el primer supuesto, la disposición normativa que establecía el uso de las listas de elegibles debía leerse en términos imperativos y no facultativos, mientras que el acápite que se discute a continuación prohíbe que se utilicen las listas cuando están siendo provistas en encargo o provisionalidad. En consecuencia, el nominador no está facultado para elegir si las usa o no, simplemente tiene ordenado no hacerlo. A su turno, se indicó que no se encuentra pronunciamiento alguno por parte de esta Corte respecto de la norma demandada en este caso.⁶

3. En Auto del 22 de agosto de 2024, se reiteró el ordinal primero del Auto del 29 de julio de 2024 en el sentido de admitir la demanda radicada con el número D-15.948 respecto de los cargos *primero* y *segundo*, relacionados respectivamente con el desconocimiento de los artículos 29 y 125 de la Constitución. Asimismo, se admitió en su totalidad el cargo *primero* (presunto desconocimiento de los artículos 13, 40 y 125 de la Constitución Política) y el *segundo* (presunto desconocimiento de los artículos 209 y 334 de la Constitución) de la demanda radicada con el número D-15.971. Por último, ordenó la práctica de determinadas pruebas con el objeto de que la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) dieran respuesta a unas preguntas y elementos de juicio que permitieran resolver sobre la presunta inconstitucionalidad de la norma censurada.⁷

4. En consecuencia, se ordenó comunicar del proceso a la Presidencia de la República, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al director del Departamento Administrativo de la Función Pública, correr traslado a la Procuradora General de la Nación, fijar en lista el proceso e invitar a diferentes expertos y sectores de la administración pública, de la academia y de la sociedad civil para recibir sus conceptos.⁸

⁴ “ARTÍCULO 34. USO DE LISTA DE ELEGIBLES. <Decreto derogado por el artículo 152 del Decreto Ley 927 de 2023> Una vez provistos los empleos objeto del concurso, la lista de elegibles tendrá una vigencia de dos (2) años, contados a partir de la firmeza de dicha lista. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Siempre y cuando la convocatoria así lo prevea, la lista de elegibles podrá <deberá*> ser utilizado en estricto orden descendente para proveer única y exclusivamente las vacantes que pudieren presentarse en los empleos que fueron ofertados como consecuencia del retiro del servicio del titular.”

⁵ “Por el cual se establece y regula el Sistema Específico de Carrera de los empleados públicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y se expiden normas relacionadas con la administración y gestión del talento humano de la DIAN. Norma derogada por el artículo 152 del Decreto 927 de 2023.”

⁶ *Ibidem*, pp. 8 y 9.

⁷ Expediente digital D-15.948 AC contenido en *Siicor*, documento denominado “D0015948-Auto Admisorio-(2024-08-26 04-35-46).pdf.”

⁸ Expediente digital D-15.948 AC contenido en *Siicor*, documento denominado “D0015948-Auto Mixto-(2024-07-31 03-17-20).pdf.” En concreto, se invitó a participar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales; al Departamento Administrativo de la Función Pública; a la Comisión Nacional del Servicio Civil; a la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo; al Ministerio de Hacienda y Crédito Público; al Sindicato Nacional de Trabajadores de

Demanda D-15.948

5. Primer cargo: presunto desconocimiento del artículo 29 de la Constitución Política. El demandante indicó que el acápite demandado desconoce el derecho fundamental al debido proceso, así como la confianza legítima, de los aspirantes que participan en un concurso de méritos, por ejemplo en el 2238 de 2021 - DIAN ASCENSO y DIAN 2022, en la medida en que los dos primeros incisos del párrafo transitorio establecen que los procesos de selección que se fundamentaron en el Decreto Ley 071 de 2020 seguirán su curso con independencia de la expedición del Decreto Ley 927 de 2023, mientras que el tercer inciso dispone una regla que se contrapone a lo regulado en los dos primeros incisos. Ello, en tanto que incluye una condición nueva en lo que respecta al uso de las listas de elegibles, consistente en que “no podrán utilizarse si el empleo público se encuentra provisto mediante encargo o provisionalidad estos cargos públicos deberán ser ofertados en una nueva convocatoria (...).”⁹ Según lo expuso el demandante:

*“Este apartado al generar una nueva condición en el uso de las listas de elegibles y pretender que la misma se aplique de forma retroactiva a los concursos de la DIAN de los años 2021 y 2022, concursos que fueron fundamentados en el Decreto Ley 71 de 2020, vulnera el derecho al debido proceso de los aspirantes al no respetar el principio de legalidad y confianza legítima y por someter a los elegibles a nuevas condiciones de las cuales no pudieron tener conocimiento, condiciones que no eran previsibles cuando se inscribieron a los concursos de méritos indicados.”*¹⁰

6. Segundo cargo: presunto desconocimiento del principio del mérito (artículo 125 de la Constitución). El ciudadano adujo que la norma objeto de censura desconoce el principio del mérito cuando “confiere a los empleados vinculados a la DIAN mediante encargo o provisionalidad una protección y derecho superior al adquirido por los integrantes de las listas de elegibles de los concursos 2238 de 2021- DIAN Ascenso y DIAN 2022.”¹¹ En su criterio, la indeterminación del inciso demandado permite que se soslaye el derecho a integrar las respectivas listas de

la Hacienda Pública; a la Federación Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado; a la Unión Nacional de Trabajadores y Empleados de la DIAN; a la Escuela Superior de la Administración Pública (ESAP); a la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes; a la Facultad de Derecho de la Universidad de la Sabana; a la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana; a la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario; a la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia; a la Facultad de Derecho de la Universidad Libre; a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional y a la Facultad de Derecho de la Universidad de Nariño. Además, se invitó a participar en el proceso, en calidad de expertos, a la Doctora María Amparo Cortés Morales, y a los Doctores Jorge Iván Rincón Córdoba, Jairo Villegas Arbeláez y Hernán Darío Vergara Mesa.

⁹ *Ibidem*, p. 6.

¹⁰ *Ídem*.

¹¹ *Ibidem*, pp. 6 y 7.

elegibles pues impide que sean nombradas en periodo de prueba a pesar de que existan vacantes definitivas del mismo empleo o de uno equivalente.¹²

7. Manifestó que la norma desnaturalizó el carácter temporal de los nombramientos provisionales o encargados, dado que impide la provisión definitiva de los empleos ofertados por las listas de elegibles provenientes de los concursos de mérito. Es decir, el inciso tercero prolonga la vinculación del personal provisional y encargado a la DIAN, desnaturalizando su carácter temporal, a pesar de que el Decreto Ley 927 de 2023 establece lo contrario.¹³

8. En consecuencia, por estas dos razones, solicitó declarar la inexequibilidad del acápite del inciso tercero del párrafo transitorio subrayado, que hace parte del artículo 36 del Decreto Ley 927 de 2023.

Demanda D-15.971

9. El demandante de manera preliminar puso de presente que la norma acusada desconoce la cosa juzgada constitucional, en la medida que esta Corte ya se pronunció sobre el artículo 34 del Decreto Ley 071 de 2020 en la Sentencia C-331 de 2022. En sus palabras, “la cosa juzgada en el ámbito constitucional implica que si una norma demandada ya tiene un fallo de constitucionalidad existe una prohibición al legislador de reproducir nuevamente el contenido de la norma declarada inconstitucional, pues bastaría con que el legislador expida una nueva norma -también inconstitucional- para así burlar los efectos prácticos del fallo de constitucionalidad y afectar de paso la seguridad jurídica.”¹⁴

10. Señaló que con la expedición del inciso 3 del párrafo transitorio del artículo 36 del Decreto Ley 927 de 2023, el Ejecutivo -en uso de las facultades extraordinarias- dispuso que estos cargos fueran cubiertos mediante provisionales, y con ello, evadió los efectos de la Sentencia C-331 de 2022.¹⁵ Pues bien, en esa decisión, la Corte Constitucional declaró inconstitucional las expresiones “[s]iempre y cuando la convocatoria así lo prevea” y “podrá,” contenidas en el artículo 34 del Decreto Ley 071 de 2020, con fundamento en el carácter vinculante de las listas de elegibles, el cual coincide con los principios de mérito en la provisión de los cargos públicos y de igualdad, de eficacia, de economía, de celeridad y de imparcialidad que rigen la función pública.¹⁶

¹² Ibidem, p. 7.

¹³ Ello, según lo explicó el demandante, a pesar de lo dispuesto en los artículos 26 y 27 del Decreto Ley 927 de 2023 que establecen los supuestos para la terminación anticipada del encargo y la terminación del nombramiento en provisionalidad.

¹⁴ Expediente digital D-15.971 AC contenido en *Siicor*, documento denominado “D0015971-Presentación Demanda- (2024-07-09 09-11-45).pdf,” p. 7.

¹⁵ Ibidem, pp. 5 y 9.

¹⁶ Ibidem, pp. 6 y 7.

11. Primer cargo: presunto desconocimiento del derecho a la igualdad, del derecho a acceder a cargos públicos y del principio del mérito (artículos 13, 40 y 125 de la Constitución). El demandante señaló que la norma otorga un tratamiento desigual, injustificado, desproporcional e irrazonable a quienes se prepararon para participar en el concurso de méritos, frente a quienes de forma provisional ocupan transitoriamente los cargos de carrera administrativa. Ello, debido a que a estos últimos “se les garantiza que seguirán ocupando dichas vacantes definitivas sin someterse al criterio meritocrático, vulnerando el trato y posición de igualdad que exige la ley.” Lo cual pugna con la naturaleza misma del encargo y la provisionalidad, que es precisamente ocupar la vacante de manera temporal hasta que sea provista mediante concurso.¹⁷

12. Frente a la presunta violación del artículo 13 de la Constitución, precisó que los grupos objeto de comparación son “por un lado, los provisionales y los funcionarios de carrera vinculados a la DIAN que se encuentran ocupando un cargo de carrera transitoriamente, pero sobre el cual no ostentan derechos de carrera propiamente dichos -pues los primeros solo son provisionales y los segundos están encargados en cargos superiores a sus cargos de origen y por el otro, el resto de aspirantes externos con expectativa de poder acceder a dichos cargos a través del concurso de méritos.” En palabras del demandante, ambos grupos son comparables porque “se encuentran en la misma posición jurídica, que sería la de ser aspirantes a dichos cargos por no ostentar derechos de carrera frente a dichos cargos que se encuentran en vacancia definitiva.” En consecuencia, pese a estar en la misma situación jurídica, la norma le otorga un tratamiento preferente al primer grupo.¹⁸

13. Sobre la vulneración del artículo 40 de la Constitución, agregó que la norma en cuestión limita injustificada y desproporcionalmente el derecho al acceso a cargos públicos, en razón a que los elegibles de esas listas ven reducidas sus posibilidades para acceder a esos puestos, después de uno o dos años de concurso.¹⁹ Asimismo, sostuvo que el concurso de méritos es la mejor forma en que se garantizan las mismas oportunidades para acceder a cargos públicos. Por lo cual, no le encuentra razón a que se prohíba acudir a las listas de elegibles cuando los empleos estén ocupados en encargo o provisionalidad. En su opinión, esa cuestión ya fue resuelta por esta Corporación en la Sentencia C-331 de 2022.²⁰

¹⁷ *Ibidem*, p. 10.

¹⁸ Expediente digital D-15.971 AC contenido en *Siicor*, documento denominado “D0015948-Corrección a la Demanda-(2024-08-06 09-16-09).pdf,” p. 5.

¹⁹ *Idem*.

²⁰ *Ibidem*, p. 7. Además, reprochó el argumento de la DIAN de que la finalidad del acápite de la norma demandado es conservar la curva de conocimiento y reconocer el trabajo de sus trabajadores, pues considero que: (i) ese propósito no puede realizarse en desmedro de los derechos de los integrantes de las listas; (ii) la carrera administrativa es la figura que mejor preserva la curva de aprendizaje; (iii) existen funcionarios de carrera que conservan ese conocimiento; (iv) la realización de tres concursos evidencia que la provisión de personal se ha realizado muy lentamente (v) la intención de la DIAN es proteger a su personal en provisionalidad y que no ingresaron mediante un criterio meritocrático sino político.

14. Finalmente, sostuvo que la norma acusada viola el principio constitucional del mérito como regla general para acceder a cargos públicos. En su sentir, la carrera administrativa, junto con los concursos de mérito, son la principal forma de cubrir las vacantes definitivas, ya sea del régimen general, de uno especial de origen constitucional o de uno específico de origen legal.²¹ *A contrario sensu*, las figuras del encargo y provisionalidad son excepcionales y transitorias, las cuales se utilizan en el evento en que no haya sido posible suplir la vacante con el concurso y hasta tanto se realice uno nuevo. En consecuencia, *“de ninguna manera es procedente que habiendo una lista de elegibles vigente los encargos y provisionalidad se mantengan en dichas vacantes provisionales.”* Así, precisó que desconocer estas reglas va en contravía del principio meritocrático que quiso exaltar y proteger el constituyente, y además, genera un juego perverso de intereses políticos sobre la forma de proveer las vacantes, mismo que quiso dejarse a un lado.²²

15. Segundo cargo: presunto desconocimiento de los principios de eficiencia, moralidad y economía de la función administrativa y del criterio de sostenibilidad fiscal (artículos 209 y 334 de la Constitución). A fin de explicar cómo el acápite de la norma en cuestión vulnera los mencionados postulados constitucionales, el demandante trajo a colación tres concursos de méritos adelantados por la DIAN para proveer cargos de carrera administrativa durante los años 2020, 2021 y 2022.²³ Ello, para sostener que es desproporcionado que la norma obligue a realizar un nuevo concurso para proveer los cargos que se encuentran ocupados por encargo o provisionalidad, en tanto prohíbe que las listas de elegibles de los concursos referidos (parágrafo transitorio del artículo 32 del Decreto Ley 071 de 2020) sean usados para ocupar esas vacantes definitivas. Según el demandante, realizar cuatro concursos de méritos para proveer vacantes definitivas es hacer un uso inadecuado de los recursos públicos. Máxime, cuando conforme lo resaltó la Corte Constitucional, para el 2020 más del 61.14% de la planta de carrera administrativa de la DIAN estaba vacante, pero de ella, 31% estaba provista mediante encargo y 63% en provisionalidad. Ello, sumado a que por virtud del Decreto Ley 0419 de 2023, se crearon 10.207 cargos, lo que significó una ampliación de la planta de personal de la DIAN.²⁴

²¹ *Ídem*. Esto es, de acuerdo con lo establecido en el numeral 25.1 del Artículo 25 del Decreto Ley 927 de 2023.

²² *Ídem*.

²³ *Ibidem*, p. 12. En particular, refirió la siguiente información respecto a los tres concursos de mérito: *“A través del Acuerdo No. 0285 de 2020, la CNSC inició el concurso identificado como “Proceso de Selección DIAN, No. 1461 de 2020”, el cual buscaba proveer 1.500 vacantes definitivas en modalidad de ingreso. Dicho concurso ya finalizó, puesto que las listas de elegibles del mismo cobraron vigencia, en su mayoría, en noviembre y diciembre de 2021. A través del Acuerdo No. 2212 de 2021, la CNSC inició el concurso identificado como “Proceso de Selección DIAN, No. 2238 de 2021”, el cual buscaba proveer 622 vacantes definitivas en modalidad de ascenso. Dicho concurso ya finalizó, puesto que las listas de elegibles del mismo cobraron vigencia, en su mayoría, en febrero y marzo de 2023. Igualmente, mediante Acuerdo No. 08 del 29 de diciembre de 2022, la CNSC inició el concurso identificado como “Proceso de Selección DIAN 2022”, el cual busca actualmente proveer 3.290 vacantes definitivas en modalidad de ingreso y 1.410 en modalidad de ascenso. Este concurso se encuentra finalizando, pues aún no se han terminado de expedir todas las listas de elegibles de todos los cargos ofertados.”*

²⁴ *Ídem*. Con el fin de soportar su argumento de que proveer vacantes es costoso, el demandante adjuntó como prueba un oficio en el que se certifica que el concurso de méritos que adelantará la Contraloría General de la República, el cual proveerá 3.144 vacantes y tendrá un costo ascendente de \$40.000.000.000. Adicionalmente, adjuntó la respuesta a una solicitud presentada por él, la cual data del 7 de septiembre de 2021, en la cual la DIAN informó que existían 6.692 vacantes, 185 cargos de libre nombramiento y remoción y 11.556 de carrera administrativa, de los cuales 4.613 están

16. Precisó que el mismo texto de la norma ordena de manera expresa la realización de un concurso de méritos adicional a los dos concursos que ya se han adelantado y distinto al que ya estaba en curso al momento de la expedición de la norma demandada. Agregó, además, que el criterio de sostenibilidad fiscal es vinculante siempre que no se use como obstáculo para inobservar garantías y principios constitucionales. Entonces, sostuvo que el mandato expreso de adelantar un nuevo concurso de méritos no consideró el impacto fiscal que ello conllevaría, razón suficiente para que se vulnere el aludido criterio.²⁵

Intervenciones y conceptos

17. Dentro del término de fijación en lista y en el marco de los artículos 7, 11 y 13 del Decreto 2067 de 1991, se recibieron cuatro conceptos de entidades y organizaciones invitadas y cuatro intervenciones ciudadanas. Así mismo, se recibieron algunos escritos extemporáneos.²⁶ A continuación, se enuncia cada una de ellas y, posteriormente, se resume su contenido.

Interviniente	Solicitud
Mayra Alejandra de la Hoz Ballesteros	Inexequibilidad
Ana Lizeth López Cárdenas, Santiago Granados Vargas, Iván Leonardo Rincón Agudelo, Leidy Johana Pulido Arias, Wilson Leandro Pinzón Aguilar y Deirys Juliana Jaime Camacho	Inexequibilidad
Juan David Moreno Pulido	Inexequibilidad
Leidy Milena Zapata González y otros 517 ciudadanos ²⁷	Inexequibilidad

Invitado
Comisión Nacional del Servicio Civil
Departamento Administrativo de la Función Pública
Universidad de Antioquia
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)

Intervenciones en virtud del artículo 7 del Decreto 2067 de 1991

siento ocupados por personal de carrera administrativa. Además, la entidad precisó que, de los cargos de carrera administrativa, 3.014 están provistos por encargos y 6.147 están ocupados con nombramientos provisionales. Por último, precisó que existen 66 contratos de prestación de servicios. Ver expediente digital D-15.971 AC contenido en *Siicor*, documento denominado “D0015971-Presentación Demanda-(2024-07-09 09-13-35).pdf,” pp. 63 a la 71.

²⁵ *Ibidem*, pp. 9 y 10.

²⁶ A su turno, se recibieron otro grupo de peticiones interpuestas por ciudadanos que solicitan la protección de sus derechos al trabajo, al acceso a cargos públicos y al debido proceso, como integrantes de las listas de elegibles de una variedad de empleos misionales y no misionales de la planta de personal de la DIAN.

²⁷ <https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/archivo.php?id=88865>

18. Mediante escrito separado, los ciudadanos Mayra Alejandra de la Hoz Ballesteros y Juan David Moreno Pulido, y por medio de un solo texto, Ana Lizeth López Cárdenas y otros 5 ciudadanos y Leidy Milena Zapata González y otros 517 ciudadanos, le solicitaron a la Corte Constitucional declarar la inexecutable del inciso tercero del párrafo transitorio del artículo 36 del Decreto Ley 927 de 2023.

19. La ciudadana *Mayra Alejandra de la Hoz Ballesteros* consideró que el fragmento de la disposición acusada es inconstitucional, en tanto que la administración no puede sustituir la regla general por la excepción. Del artículo 125 de la Constitución no se desprende que la provisionalidad y/o el encargo prevalezcan sobre el uso de las listas de elegibles, ni de una lectura armónica del Decreto Ley 927 de 2023.²⁸

20. Los ciudadanos *Ana Lizeth López Cárdenas, Santiago Granados Vargas, Leidy Johana Pulido Arias, Iván Leonardo Rincón Agudelo, Wilson Leonardo Pinzón Aguilar y Deirys Juliana Jaime Camacho* presentaron un escrito de intervención en el que le solicitaron a la Corte Constitucional declarar la inexecutable del inciso tercero de la disposición demandada.²⁹ En su criterio, ese acápite restringe irrazonable y desproporcionadamente los artículos 40.7, 122 y 125 de la Constitución. En síntesis, argumentaron que el acápite en cuestión les da prelación a las figuras de encargo y provisionalidad sobre el mérito, lo que afecta la transparencia y la eficiencia de la administración pública, así como el acceso equitativo a los cargos públicos.³⁰ A su vez, sostuvieron que la provisión de cargos públicos mediante la figura de la provisionalidad afecta la estabilidad y profesionalismo del servicio público y de la carrera administrativa, dando cabida a arbitrariedades y abusos.³¹

21. El ciudadano *Juan David Moreno Pulido* le solicitó a la Corte Constitucional declarar la inconstitucionalidad del acápite demandado, pues justificó que aquel va en contravía de los derechos políticos de los aspirantes, así como de los artículos 29 y 125 de la Constitución.³² En su criterio, desconocer los concursos de méritos implica darle cabida al clientelismo y favoritismo. Asimismo, precisó que la parte demandada le da una connotación superior a la estabilidad laboral reforzada de las personas que ostentan cargos en encargo o en provisionalidad, en desmedro de las personas que verdaderamente son titulares de ese derecho.³³ Seguidamente, explicó que el acápite en cuestión viola el principio de igualdad, puesto que desconoce que

²⁸ Expediente digital D-15.948 AC contenido en *Siicor*, documento del 30 de agosto de 2024 que contiene la intervención de Mayra Alejandra de la Hoz Ballesteros, pp. 6 y 7.

²⁹ Expediente digital D-15.948 AC contenido en *Siicor*, documento del 12 de noviembre de 2024 que contiene la intervención de los ciudadanos Ana Lizeth López Cárdenas, Santiago Granados Vargas, Leidy Johana Pulido Arias, Iván Leonardo Rincón Agudelo, Wilson Leonardo Pinzón Aguilar y Deirys Juliana Jaime Camacho, p. 1.

³⁰ *Ibidem*, pp. 2 a 6.

³¹ *Ibidem*, p. 4.

³² Expediente digital D-15.948 AC contenido en *Siicor*, documento del 12 de noviembre de 2024 que contiene la intervención de Juan David Moreno Pulido, pp. 1 y 5.

³³ *Ibidem*, p. 3.

todos los candidatos tienen las mismas oportunidades de acceder al empleo público. Además, su implementación requiere que se realicen concursos en un corto periodo de tiempo, lo que devengaría en demoras en la provisión de los cargos, en una inestabilidad en los empleos públicos existentes y en una carga administrativa y financiera excesiva.³⁴

22. En el escrito suscrito por *Leidy Milena Zapata González* y otros 517 ciudadanos, se solicitó a la Corte Constitucional declarar la inexequibilidad de la disposición acusada.³⁵ En su opinión, el acápite en cuestión transgrede los artículos 40.7, 122, 125 y otros de la Constitución, en tanto restringe irrazonable y desproporcionadamente el principio del mérito y el derecho a acceder a los cargos públicos de la carrera administrativa de la DIAN, mediante la inversión de la regla general del mérito a la de la provisionalidad.³⁶ Además, agregaron que el acápite acusado difiere de su mismo cuerpo normativo, toda vez que en el artículo 24 del mismo decreto ley, se le dio prioridad a la provisión definitiva de empleos de carrera administrativa.³⁷

23. Para fundamentar sus argumentos, relacionaron *in extenso* la jurisprudencia constitucional sobre el derecho al acceso a cargos públicos, a la carrera administrativa y al principio del mérito³⁸ y otras cuestiones normativas y de índole práctico sobre la materia.³⁹ En particular, adujeron que la temática constitucional del caso *sub examine* ya fue zanjada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-588 de 2009, en la cual se declaró inexequible la totalidad del Acto Legislativo 1 de 2008 que pretendía darle prelación a la figura de la provisionalidad sobre el mérito en el sistema de carrera administrativa de la DIAN.⁴⁰ Todo, para solicitarle a esta Corporación que declare inexequible con efectos retroactivos el fragmento en cuestión, en el entendido de que la parte de la norma demandada tiene por objeto suspender una parte de la Constitución, sustitución que es a todas luces inconstitucional.⁴¹

³⁴ *Ibidem*, p. 4.

³⁵ Expediente digital D-15.948 AC contenido en *Siicor*, documento del 4 de septiembre de 2024 que contiene la intervención de Leidy Johana Pulido Arias y otros 517 intervinientes, como elegibles del concurso de méritos DIAN 2022, pp. 2 y 3. El listado de los integrantes del grupo elegibles DIAN 2022 está contenido en la parte final del escrito de intervención (pp. 62 en adelante).

³⁶ *Ibidem*, p. 3. A su turno, los ciudadanos precisaron que la restricción contenida en el fragmento demandado hace que los integrantes de las listas de elegibles deban disputarse las vacantes de los empleos que no están ocupados por provisionales, lo que confirma el establecimiento de la provisionalidad como regla general, encima de la carrera administrativa y el mérito, estas últimas de índole constitucional.

³⁷ *Ibidem*, p. 28.

³⁸ *Ibidem*, pp. 30 a 44.

³⁹ Los intervinientes miembros del grupo elegibles DIAN 2022 trajeron a colación argumentos relacionados con otras disposiciones constitucionales, entre ellos, el presunto desconocimiento del artículo 122 de la Constitución (p. 13) y del principio de legalidad contenido en los artículos 121, 122 y 123 de la Constitución (pp. 29 y siguientes). Además, refirieron el marco normativo aplicable al sistema especial de carrera de la DIAN (pp. 16 y siguientes) e hicieron énfasis en otros principios constitucionales que a su juicio, deben hacer parte del análisis que realice esta Corporación, entre ellos, los dispuestos en los artículos 1 y 2 de la Constitución (p. 46). Finalmente, trajeron a colación las sentencias que han delimitado el contenido y alcance del derecho a acceder a cargos públicos de la carrera administrativa.

⁴⁰ *Ibidem*, pp. 9 a 11.

⁴¹ *Ibidem*, pp. 60 y 61. desarrollado el principio de carrera administrativa, al principio del mérito y a los concursos (pp. 47 y siguientes).

Conceptos de los invitados en virtud del artículo 13 del Decreto 2067 de 1991

24. Comisión Nacional del Servicio Civil. La entidad sugirió que la disposición acusada es inconstitucional.⁴² Enfatizó en que el uso de las listas de elegibles es imperativo para proveer las vacantes definitivas, sin que el hecho de que estén ocupadas en encargo o provisionalidad sea una excepción. Hacer caso omiso de esta regla, implica vulnerar los derechos fundamentales a la igualdad y al acceso a la carrera administrativa de los participantes, así como desconocer el principio del mérito, de planeación, de economía y de austeridad del gasto. En su criterio, esa restricción implica un tratamiento discriminatorio e injustificado hacia quienes han demostrado sus capacidades mediante el mérito, que si bien no tienen un derecho consolidado, si cuentan con una expectativa a ser nombrados en periodo de prueba en las vacantes para las que se postularon o en unas equivalentes.⁴³ Además, refirió que el acápite en cuestión transgrede el enunciado del párrafo transitorio que le antecede.⁴⁴

25. Recordó que había adelantado dos procesos de selección de la DIAN; el No. 1461 de 2020, regulado mediante el Acuerdo no. 0285 de 2020 y el DIAN-2022, ceñido a las reglas del Acuerdo No. CNT2022AC00000 del 29 de diciembre de 2022. En ambos procesos de selección se ofertaron cargos en vacancia definitiva pertenecientes al sistema específico de carrera administrativa de la planta de personal de la DIAN. La conformación de las listas de elegibles de los dos procesos de selección estaría regulada por lo dispuesto en el numeral 28.3 del artículo 28 y el artículo 34 del Decreto Ley 071 de 2020.⁴⁵

26. Agregó que la promulgación del fragmento de la norma en cuestión dio lugar a que muchos aspirantes que integraban la lista de elegibles del proceso de selección DIAN 2022 reclamaran, en sede de tutela, su derecho a acceder a la carrera administrativa, y con él, a ser nombrados y posesionados en los empleos en vacancia definitiva que cumplieran con las características de ser iguales o equivalentes a los ofertados.⁴⁶

27. Asimismo, trajo a colación la importancia de hacer uso de las listas de elegibles para empleos iguales o equivalentes, en garantía de la transparencia,

⁴² Expediente digital D-15.948 AC contenido en *Siicor*, documento del 15 de agosto de 2024 que contiene la intervención de la Comisión Nacional de Servicio Civil, remitida por Sixta Zúñiga Lindao, del Despacho de la Presidencia de la entidad, p. 14.

⁴³ *Ibidem*, p. 13.

⁴⁴ *Ídem*.

⁴⁵ *Ibidem*, pp. 5 y 6.

⁴⁶ *Ibidem*, pp. 7 y 8. Al respecto, trajo a colación una decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca del 15 de diciembre de 2023, en la cual el operador judicial concluyó que la entidad dejó vencer las listas de elegibles de quienes eran titulares de su derecho por meritocracia, y con ello, incurrió en un detrimento del erario que agotó recursos cuantiosos en los procesos de convocatoria y selección, privilegiando el manejo burocrático y subjetivo de los nombramientos de turno.

equidad y el principio del mérito en la carrera administrativa. En consecuencia, dijo, cualquier disposición legal que desconozca la designación objetiva como derecho de rango constitucional que le asiste al concursante que se encuentra en una lista de elegibles por sus méritos, está llamada a ser declarada inconstitucional.⁴⁷ Esto, sin desconocer que la utilización de las listas de elegibles también optimiza el recurso público, al evitar que se realicen más concursos -aun cuando existen listas de elegibles vigentes- y agilizar la provisión de empleos vacantes.⁴⁸

28. Tan es así, que la entidad se cuestionó si pese a encontrarse vigente una lista de elegibles, se hace necesario esperar a que se provea un empleo mediante la realización de un nuevo proceso de selección. Máxime, cuando lo cierto es que el empleo se encuentra en vacancia definitiva, nada más que está siendo ocupado mediante provisionalidad o encargo. De hecho, agregó que la prohibición contenida en el acápite demandado podría a su turno afectar a quienes provean cargos en provisionalidad, pues estarían obligadas a mantenerse en esa modalidad, perdiendo la oportunidad de ser nombrados en un empleo de carrera que hubiese surgido en vigencia de la lista.⁴⁹

29. Finalmente, añadió que, conforme al tránsito legislativo, la única convocatoria existente para la fecha de expedición del Acuerdo CNT2022AC000008 del 29 de diciembre de 2022, es el proceso de selección DIAN 2022. Situación que quedó plasmada en el párrafo transitorio del artículo censurado.⁵⁰

30. Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP. La entidad adujo que las demandas de inconstitucionalidad del asunto no superaron los requisitos mínimos argumentativos de *claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia*, mismos que le permiten a esta Corporación realizar un pronunciamiento de fondo.⁵¹ En concreto, argumentó que la demanda comporta una interpretación arbitraria y subjetiva del actor y no de una confrontación directa con el texto constitucional.⁵² Además, tampoco expuso las razones por las cuales el fragmento de la norma demandada contraría los artículos 29, 40.7 y 125 de la Constitución.⁵³ Asimismo, señaló que los hechos en que se funda la inconstitucionalidad no responden a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, conforme lo ha dispuesto la jurisprudencia constitucional.⁵⁴

⁴⁷ *Ibidem*, pp. 8 y 12. Además, agregó que conforme lo dijo esta Corporación en la Sentencia SU-446 de 2011, las reglas del concurso de méritos son de obligatorio cumplimiento para la administración, la Comisión Nacional del Servicio Civil, las entidades contratantes y los participantes, entre las cuales se encuentran el respeto por el principio de legalidad y la protección de los derechos de los participantes.

⁴⁸ *Ibidem*, pp. 9 y 10.

⁴⁹ *Ibidem*, p. 11.

⁵⁰ *Ibidem*, p. 14.

⁵¹ Expediente digital D-15.948 AC contenido en *Siicor*, documento del 1 de noviembre de 2024 que contiene la intervención del Departamento Administrativo de la Función Pública, remitida por Armando López Cortés, Director Jurídico de la entidad.

⁵² *Ibidem*, p. 14.

⁵³ *Ibidem*, p. 17.

⁵⁴ *Ibidem*, pp. 14 a 17. Adicionalmente, la entidad sugirió que tampoco se cumplen con los requisitos que ha decantado la jurisprudencia constitucional para declarar la exequibilidad condicionada de la norma. Esto es, con fundamento en

31. Paralelo a lo explicado, la entidad sugirió que el acápite de la norma en cuestión es constitucional.⁵⁵ Al comparar el artículo 34 del Decreto Ley 071 de 2020 y el párrafo transitorio del artículo 36 del Decreto Ley 927 de 2023, concluyó que la primera disposición normativa limitaba el mérito, bajo el entendido de que las listas de elegibles solo se utilizarían en los empleos ofertados. Sin embargo, respecto a la segunda disposición, ella no contiene ninguna limitación, pues le da uso a las listas de elegibles para las vacantes generadas con posterioridad a la convocatoria.⁵⁶ Además, refirió que la excepción a la regla para cargos en encargo o provisionalidad se justifica en: (i) la gradualidad en el acceso al sistema de carrera; (ii) el aseguramiento en la adaptación al cargo y el desempeño laboral; (iii) el esquema progresivo de implementación y (iv) la no afectación de la continuidad en la prestación del servicio.⁵⁷

32. Por último, hizo referencia a las reglas específicas de los sistemas especiales de carrera, entre ellos, el de la Fiscalía General de la Nación y la DIAN. Esto, a fin de justificar que las listas de elegibles provistas mediante los procesos de selección de estos regímenes se podrán utilizar para las vacantes definitivas de cargos equivalentes no convocados que surjan con posterioridad a la convocatoria, así como restringirlos cuando estén ocupados mediante encargo o provisionalidad.⁵⁸

33. *Universidad de Antioquia.* La institución académica conceptuó que la norma es inconstitucional.⁵⁹ Lo anterior, porque va en contravía del derecho al trabajo y del derecho a acceder por mérito a los cargos públicos al establecer un mejor derecho para quienes fueron nombrados en encargo o provisionalidad.⁶⁰ Además, desconoce los principios de la función administrativa, el manejo de recursos públicos y la sostenibilidad fiscal. Señaló que el acápite en cuestión es desproporcionado, debido a que para lograr la finalidad de garantizar la continuidad y eficiencia en la prestación de los servicios a cargo de la entidad, afectó la operatividad del sistema de carrera, así como los principios constitucionales orientados a cumplir la función pública.⁶¹ La institución anotó que el acápite demandado es contradictorio e incoherente respecto al resto del artículo 36 del Decreto Ley 927 de 2023, mismo que reconoce que el uso de las listas de elegibles es el medio de realización de los principios de economía, sostenibilidad fiscal y austeridad del gasto.⁶²

las sentencias C-029 de 2021 y C-284 de 2011. Al explicar las razones del incumplimiento, hizo referencia a las normas y especificidades del sistema especial de carrera de la Fiscalía General de la Nación.

⁵⁵ *Ibidem*, p. 20.

⁵⁶ *Ibidem*, p. 9.

⁵⁷ *Ídem*. Los argumentos referidos por la entidad fueron tomados de la Sentencia C-387 de 2023, decisión en la cual se analizó el sistema especial de carrera de la Fiscalía General de la Nación.

⁵⁸ *Ibidem*, pp. 9 a 13.

⁵⁹ Expediente digital D-15.948 AC contenido en *Siicor*, documento del 8 de noviembre de 2024 que contiene la intervención de la Universidad de Antioquia, remitida por Hernán Darío Vergara Mesa, profesor de la universidad, p. 2.

⁶⁰ *Ibidem*, p. 12.

⁶¹ *Ídem*.

⁶² *Ibidem*, p. 11.

34. Afirmó que las listas de elegibles son medios de realización de múltiples prerrogativas constitucionales, entre ellos, los principios del mérito, igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad y el derecho a acceder al desempeño de funciones y cargos públicos.⁶³ Es por ello, que a las listas de elegibles se les confiere el valor de acto administrativo definitivo con capacidad de crear expectativas legítimas; o con grado de certeza en favor de quienes las integran, o temporales, pero al mismo tiempo, obligatorias. En palabras de la universidad, “[e]sta característica resalta [d]el hecho de que, para la provisión de los empleos públicos, la lista de elegibles no es una alternativa al concurso público de méritos, por lo menos mientras mantenga su vigencia,” y en consecuencia, la restricción contenida en el acápite demandado es inconstitucional.⁶⁴

35. Sobre la diferencia entre el encargo y la provisionalidad, especificó que el encargo recae sobre personas que ostentan derechos de carrera, mientras que la provisionalidad no, y es por ello por lo que se le da prelación al primero a la hora de efectuar nombramientos en los cargos del Estado. Al margen de ello, adujo que se trata de figuras de carácter excepcional y temporal. Frente a las vacantes definitivas, habiendo listas de elegibles conformadas y vigentes resultantes de la realización de varios concursos de méritos, estas no se pueden utilizar para proveer esas vacantes, por mención expresa de la disposición demandada.⁶⁵ En suma, sin perjuicio de la amplia configuración legislativa que tiene el Legislador -extraordinario- ella no puede ir en desmedro del artículo 125 constitucional, el cual ordena la provisión de empleos de carrera mediante la elaboración de concursos de mérito y listas de elegibles; procedimiento que el acápite acusado desconoce.⁶⁶

36. La universidad analizó la constitucionalidad del fragmento demandado a partir del juicio de razonabilidad y proporcionalidad.⁶⁷ Al respecto, concluyó que la medida es legítima, en razón a que no está prohibida expresamente por la Constitución y hace parte del amplio espectro de la facultad de libre configuración legislativa. Sugirió que la medida es útil e idónea para garantizar la continuidad y eficiencia en los procesos y servicios a cargo de la entidad, al margen de que sea el más idóneo para ello. Por último, refirió que la medida no es necesaria. Esto es, porque la administración está facultada para tomar otro tipo de acciones, entre ellas, la realización de empalmes que eviten contratiempos en la prestación regular y eficiente de los servicios, hasta tanto se realice la adaptación definitiva y el cumplimiento de los periodos de prueba.

⁶³ *Ibidem*, pp. 2 y 3.

⁶⁴ *Ibidem*, pp. 3 y 4.

⁶⁵ *Ibidem*, p. 5.

⁶⁶ *Ibidem*, p. 6.

⁶⁷ La institución parece haber justificado la aplicación del test, primero, en su intensidad *débil* o *leve*, y luego, *estricta*. Sobre esta última, agregó que la adopción de la medida también afecta principios constitucionales como el del interés general, de un lado, y los principios de administración de recursos públicos de forma eficiente y de sostenibilidad fiscal, de otro. En su criterio, la afectación es desproporcionada, puesto que la preservación del primer grupo de principios no conlleva una afectación cierta sobre derechos fundamentales, mientras que el segundo sí.

37. Incluso, indicó que existen otras medidas a fin de alcanzar ese propósito, como lo son las comisiones de servicio, los traslados entre dependencias, el uso de la figura del supernumerario, el contrato de prestación de servicios y finalmente, la diferenciación entre los cargos que conllevan mayores riesgos para la continuidad y eficiencia del servicio y aquellos que no. De hecho, agregó que pueden existir otras medidas consecutivas del objetivo, mismas que se derivan de la auto-capacidad de la entidad y que causan menos afectaciones al sistema de carrera y a los derechos de los aspirantes.⁶⁸

38. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). La entidad argumentó, primeramente, que la Corte debía declararse inhibida para pronunciarse de fondo sobre la controversia, pues los argumentos de los demandantes son “*genéricos, imprecisos y vagos*.”⁶⁹ En lo que respecta a la demanda del proceso D-15.948, sostuvo que el demandante no aportó planteamientos concretos y específicos que justifiquen la presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso. Además, en lo que respecta al cargo por vulneración del artículo 125, éste carece de certeza, en tanto parte de la interpretación subjetiva de que al no utilizarse las listas de elegibles, los empleos en encargo o provisionalidad se perpetuarán. Ello no es cierto, porque el mismo Decreto Ley 927 de 2023 establece la obligación, en cabeza de la DIAN, de organizar concursos de mérito cada año.⁷⁰

39. En cuanto a la demanda del proceso D-15.971, la DIAN afirmó que no se cumplió con la carga argumentativa propia del cargo por violación del principio de igualdad. El demandante explicó que los dos grupos de sujetos -las personas que participan en los concursos de méritos y quienes ocupan los cargos en encargo o provisionalidad- son comparables porque se encuentran en una misma posición jurídica, como lo es la de aspirar a cargos en vacancia definitiva por no ostentar derechos de carrera. Conforme a la entidad, esos argumentos son imprecisos e inciertos, en tanto parten de la premisa subjetiva de que quienes están en encargo o provisionalidad siempre aspiran a ser nombrados en propiedad y, además, no explica cómo esos grupos son comparables, a pesar de tener regímenes jurídicos distintos. En suma, agregó que el demandante no supo explicar el supuesto tratamiento diferenciado ni la falta de razonabilidad o proporcionalidad de la medida.⁷¹

40. Por último, el demandante tampoco ofreció razones suficientes que permitieran colegir por qué el acápite demandado vulnera el artículo 40.7, y que en cualquier caso, quienes ocupan los cargos en provisionalidad o encargo también son ciudadanos colombianos que tienen derecho a acceder a cargos públicos. Sumado a que no ofreció argumentos específicos ni certeros respecto al presunto desconocimiento de los principios de eficacia, moralidad y economía de la

⁶⁸ *Ibidem*, pp. 7 y 8.

⁶⁹ Expediente digital D-15.948 AC contenido en *Siicor*, documento del 13 de noviembre de 2024 que contiene la intervención de la UAE-Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, remitida por Nelson Javier Otálora Vargas, apoderado de la entidad, p. 9.

⁷⁰ *Ibidem*, pp. 9 y 10.

⁷¹ *Ibidem*, p. 10.

administración pública ni del criterio de sostenibilidad fiscal. Sobre esto último, indicó que no es claro si los argumentos planteados se refieren al texto normativo o a las consecuencias prácticas de su implementación. Además, ignoró el hecho de que los concursos públicos materializan el principio de interés general y de la necesidad de ampliar la planta de personal, en cumplimiento de la normativa nacional y los compromisos internacionales.⁷²

41. La DIAN argumentó que el fragmento de la norma demandada es constitucional, en tanto establece un régimen razonable y proporcional. En su concepto, la disposición normativa no vulnera ningún derecho ni principio constitucional, en tanto y cuanto responde a las necesidades de eficiencia de la administración, a la estabilidad en la prestación del servicio y a la continuidad de los empleos actualmente provistos por encargo o provisionalidad, misma que preserva el conocimiento teórico y práctico de los funcionarios. En palabras de la entidad, se preserva el principio del mérito, pues la restricción del acápite en cuestión busca:

“garantizar una efectiva provisión y ampliación de la planta de personal, manteniendo una estabilidad transitoria, adecuada y necesaria del conocimiento y la experiencia de los funcionarios vinculados en cualquier calidad. Esto le permite a la entidad pasar de tener alrededor de 11.000 funcionarios a un poco más de 21.000, con lo que se logra un aumento progresivo en la provisión de la planta y, en consecuencia, el cumplimiento de las metas de recaudo y sostenibilidad fiscal esperada. (...)”

En efecto, los cargos que actualmente están ocupados de manera provisional o mediante encargo serán ofertados en los concursos anuales siguientes a la expedición del Decreto Ley 927 de 2023 que la entidad está obligada a realizar. Quienes actualmente ocupan esos cargos no tienen derechos derivados del sistema específico de carrera, ni se les está garantizando una estabilidad. No obstante, su ocupación garantiza la continuidad del relevante servicio que la DIAN presta al Estado.

Si no se hubiera contemplado dicho régimen de transición, indudablemente se habría generado un efecto adverso, pues no se habrían podido utilizar las listas de elegibles de los concursos adelantados en vigencia del Decreto Ley 071 de 2020, para proveer las vacantes de empleos iguales o equivalentes que surgieran con posterioridad a la convocatoria, por el fenómeno de la pérdida de fuerza ejecutoria.”⁷³

⁷² Ibidem, p. 11.

⁷³ Ibidem, pp. 7 y 8. La DIAN precisó que de ninguna manera el párrafo transitorio demandado hace nugatorio el proceso de provisión de empleos de la planta de la entidad. Pues bien, *“a los empleos efectivamente ofertados se suman alrededor de 1.900 empleos provistos mediante las listas de elegibles de las convocatorias DIAN 1461 de 2020 y 2238 de 2021. Además, se proyecta que 1.600 empleos serán provistos con las listas de elegibles de la Convocatoria DIAN 2497 de 2022, adicionales a los 4.700 empleos ofertados en la misma convocatoria.”* Además, refirió que de no haberse incluido el mencionado inciso en el régimen de transición, se afectarían los planes de ampliación de la planta de personal, *“con el agravante de que no se hubiese podido proveer la totalidad de vacantes disponibles, al no contar con*

42. En resumen, la entidad sostuvo que: (i) el inciso demandado, lejos de vulnerar el derecho a la igualdad,⁷⁴ a acceder a cargos públicos, al mérito y al debido proceso,⁷⁵ regula el tránsito legislativo entre el Decreto Ley 071 de 2020 y el Decreto Ley 927 de 2023, siendo éste último, más favorable para los integrantes de las listas de elegibles;⁷⁶ (ii) el artículo 36 del Decreto Ley 927 de 2023 amplía la vigencia y uso de las listas de elegibles de los concursos de mérito desarrollados en virtud del Decreto Ley 071 de 2020 para cargos no ofertados en las convocatorias iniciales; (iii) el régimen de transición es razonable y proporcional, en razón de la especialidad y tecnicismo del régimen de la DIAN, de la adecuada gestión de conocimiento y de la garantía de continuidad del servicio y (iv) el acápite en cuestión no otorga derechos de carrera a los funcionarios vinculados mediante encargo o provisionalidad, pues establece claramente que el régimen de transición finalizará cuando estos cargos sean ofertados en un nuevo concurso público.⁷⁷

43. Sostuvo, además, que la norma promueve la economía fiscal, pues hace un uso racional de las listas de elegibles y evita la duplicidad de esfuerzos y costos, lo que va en línea con el criterio de sostenibilidad fiscal y eficiencia en el uso de recursos públicos. En suma, la exigencia de una nueva convocatoria para los cargos actualmente ocupados en provisionalidad racionaliza los recursos, pues diferencia las vacantes transitorias y definitivas y permite atender de forma ordenada las necesidades de la entidad. Asimismo, la disposición normativa fortalece el sistema de carrera administrativa mediante un sistema escalonado y planificado de conocimiento y de ampliación de la planta de personal.⁷⁸ Lo anterior, en línea con lo

las listas de elegibles vigentes y suficientes.”

⁷⁴ La entidad trajo a colación los elementos del juicio intermedio de proporcionalidad para concluir que la medida en cuestión no vulneró el derecho a la igualdad. Primero, la finalidad de la norma es legítima, en tanto buscó darles utilidad a las listas de elegibles de concursos anteriores. Segundo, la medida es efectivamente conducente para alcanzar la finalidad de gradualidad y adaptación. En conclusión, la medida responde al amplio margen de configuración legislativa y a la Constitución. (*Ibidem*, pp. 14 y 15).

⁷⁵ La DIAN sostuvo que la norma en cuestión no vulnera el derecho fundamental al debido proceso, sino que al contrario, mantuvo las reglas de los concursos previstos en el marco del Decreto Ley 071 de 2020, pues incluyó las vacantes definitivas ofertadas incluso después del concurso y establece que los cargos provistos por encargo o provisionalidad deberán ofertarse en un nuevo concurso, cargos a los que no podían acceder quienes se hubieran postulado en desarrollo del mencionado decreto. (*Ibidem*, p. 21). Finalmente, la norma en cuestión también garantiza el debido proceso de las personas que ocupan los empleos en encargo o provisionalidad, en tanto podrán concursar para esos cargos cuando se oferten en la modalidad de ingreso.

⁷⁶ Sobre ese punto, la entidad agregó lo siguiente: “*el régimen de transición no ha afectado la garantía de la provisión de los empleos por mérito. De una parte, en el año 2023 se proveyeron cerca de 1.900 vacantes mediante el uso de las listas de elegibles de las convocatorias 1461 de 2020 y 2238 de 2021, hasta el término de su vigencia y/o agotamiento. Por otra parte, en la presente vigencia, se está adelantando la provisión de 1.623 vacantes con el uso de las listas de elegibles de la Convocatoria 2497 de 2022, adicionales a las 4.700 vacantes ofertadas en dicha convocatoria.*”

⁷⁷ *Ibidem*, pp. 11 y 12.

⁷⁸ Sobre el particular, la DIAN sostuvo que “*la experiencia, los conocimientos y las habilidades con los que cuentan los empleados nombrados en provisionalidad son fundamentales para el cumplimiento de las metas del Estado. Si bien, en virtud del principio de economía, la provisión de estas vacantes podría darse mediante el uso de listas, también es cierto que la sustitución intempestiva de cerca de 5.000 funcionarios en provisionalidad por funcionarios nuevos generaría un riesgo muy alto para el cumplimiento de las metas, teniendo en cuenta las curvas de aprendizaje, la adaptación de los nuevos servidores a los cargos, la evaluación del periodo de prueba, entre otros aspectos que impactarían negativamente a la entidad.*” Asimismo, agregó que “*la curva de aprendizaje de toda persona ante nuevos retos laborales y profesionales puede tomar entre 6 y 12 meses, que corresponden a las fases de aprendizaje y estructuración del conocimiento. En efecto, se trata de un proceso gradual y multidimensional en el que intervienen*

dicho por esta Corporación en relación con el régimen especial de la Fiscalía General de la Nación en la Sentencia C-387 de 2023.⁷⁹

44. Como fundamento de lo anterior, la DIAN referenció los datos que se ilustran en la tabla a continuación, correspondientes a los cargos provisionales en áreas técnicas y altamente calificadas. Esos datos evidencian que **las vinculaciones en provisionalidad corresponden entre el 42% y el 50% del personal de la entidad**, por lo que su retiro masivo conllevaría un impacto muy negativo sobre la entidad.

HISTORICO PROVISIONAL POR PROCESO						
Etiquetas de fila	Dic. - 2019	Dic. - 2020	Dic. - 2021	Dic. - 2022	Dic. - 2023	Oct. - 2024
Cercanía al Ciudadano	476	480	503	447	428	360
Fiscalización y Liquidación	1.314	1.447	1.534	1.266	1.264	1.233
Operación Aduanera	794	792	772	772	763	714
Otro Proceso	2.213	2.397	2.088	1.935	1.948	1.796
Recaudo y Cobranzas	781	919	1.270	1.187	1.145	1.157
Total general	5.578	6.035	6.167	5.607	5.548	5.260
Total	10.686	10.963	10.830	11.151	11.694	13.097
% Provisionalidad	52%	55%	57%	50%	47%	40%

80

Intervenciones extemporáneas

45. El Sindicato Nacional de Empleados de la DIAN – SINEDIAN, la Unión Sindical de Trabajadores del Estado, James Núñez Dueñas, el Sindicato SIHTAC – Sindicato de la DIAN, Natalia Barahona Zuluaga, María Beatriz Torrez Martínez, Ivonne Lisset Borda Cortés y otros, Brenda Marcela Ceballos Moreno, Juan David Melo, Efraín Andrés Rodríguez Ovalle y el Sindicato Unido de Trabajadores de la

diversos factores, según la complejidad de las funciones asignadas y los procedimientos que se aplican. En el caso de la DIAN, valga anotar, se requiere de un aprendizaje en temas altamente técnicos y calificados.” (Ibidem, p. 22).

⁷⁹ Ibidem, pp. 25 y 26. 51. A su turno, la DIAN trajo a colación los antecedentes normativos de la norma demandada. En síntesis, señaló que en virtud de la Ley 2277 de 2022 y el Decreto 419 de 2023, se le otorgaron facultades extraordinarias al Gobierno para que modificara el sistema especial de carrera de la entidad, así como la ampliación de su planta de personal. Lo anterior, porque según informes internacionales, el recurso humano de la administración tributaria del país está reducido, en comparación con otros países. En línea con ello, se expidió el Decreto Ley 927 de 2023, en el cual se estableció que las vacantes definitivas se debían proveer mediante concursos de méritos adelantados por la CNSC, y excepcionalmente, por medio de encargo o provisionalidad. Esto, en garantía del principio del mérito. En particular, anotó que el artículo 36 del Decreto Ley 927 de 2023 previó la posibilidad de usar las listas de elegibles para ocupar vacantes generadas con posterioridad a las convocatorias, en contraposición a lo dispuesto en el artículo 34 del Decreto Ley 071 de 2020, que establecía que aquellas sólo se usarían para las vacantes generadas en los empleos ofertados. Además, refirió que el artículo 34 de la norma demandada dispuso que cada año se convocara a concurso para la provisión definitiva de empleos de la planta de persona, a diferencia de lo dispuesto en el Decreto Ley 071 de 2020, en el sentido de que se haría cada dos años. (Ibidem, pp. 5 a 7).

⁸⁰ Ibidem, p. 23. En adición a lo anterior, precisó que “[a]nte una planta con 21.937 vacantes, contando 8.840 vacantes sin proveer, la norma demandada permite que la provisión mediante el uso de listas de elegibles y concursos de méritos se concentre en este tipo de vacantes (aquellas que no están actualmente ocupadas mediante la figura de la provisionalidad o el encargo), con la expectativa de que, al finalizar dicha provisión, el porcentaje de empleos en provisionalidad se sitúe en el 24%. A partir de ese momento, será apropiado ofertar estas vacantes en procesos de selección meritocrática, garantizando la transición, la trasferencia de conocimientos y el fortalecimiento de la entidad.” (Ibidem, p. 24).

Dian – Sintradian, Jaime Arévalo Galindo, presentaron escritos en los que manifestaron sus posturas sobre el asunto bajo examen.⁸¹

46. El artículo 13 del Código General del Proceso, establece que “[l]as normas procesales son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley”. Por su parte, el artículo 7º del Decreto 2067 de 1991, establece 10 días como término perentorio de fijación en lista para que los ciudadanos impugnen o defiendan las normas acusadas. De la lectura de estas disposiciones puede concluirse que dejar transcurrir este tiempo en silencio excluye la posibilidad de intervenir en el proceso de constitucionalidad⁸².

47. En consecuencia, dado que el periodo de fijación en lista del proceso bajo examen transcurrió entre el 28 de octubre de 2024 y el 12 de noviembre de la misma anualidad, las intervenciones allegadas con posterioridad a ese periodo son extemporáneas.⁸³

Pruebas decretadas

48. Por medio del Auto del 22 de agosto de 2024, el Magistrado sustanciador ordenó la práctica de determinadas pruebas a fin de que la CNSC y la DIAN dieran respuesta a las preguntas allí referidas, las cuales se relacionan en la tabla más adelante.

49. Antes de dar respuesta al auto de pruebas, la DIAN realizó unas consideraciones preliminares.⁸⁴ En primer lugar, adujo que el acápite de la norma acusada es de carácter transitorio, por lo que no busca beneficiar los empleos provistos en provisionalidad y/o encargo, sino establecer un régimen de transición entre el Decreto Ley 071 de 2020 y el Decreto Ley 927 de 2023.⁸⁵ Mencionó que lo que pretende ese régimen de transición es ampliar la vigencia de las listas de elegibles bajo el régimen del Decreto Ley 071 de 2020, a fin de que no pierdan fuerza de ejecutoria y puedan ser utilizadas para proveer los cargos convocados y los equivalentes y en los que no se haya presentado provisión mediante encargos o

⁸¹ A su turno, se deja constancia de que en el expediente se recibieron otro tipo de solicitudes relacionadas con el acceso a información contenida en el expediente digital, así como sobre la obtención de copias de la sentencia, fecha de emisión del fallo, sentido y alcance de la decisión, entre otras.

⁸² En ese sentido, por ejemplo, en la Sentencia C-323 de 2006, la Corte Constitucional determinó que algunas de las intervenciones allegadas fueron declaradas extemporáneas.

⁸³ Expediente digital D-15.948 AC contenido en *Siicor*.

⁸⁴ Expediente digital D-15.948 AC contenido en *Siicor*, documento del 9 de septiembre de 2024 que contiene la respuesta a las pruebas solicitadas por parte de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), remitida por Nelson Javier Otálora Vargas, en su condición de apoderado de la entidad.

⁸⁵ Sobre el particular, precisó lo siguiente: “[a]demás, la situación de los provisionales es una medida aplicable sólo en el tránsito normativo aquí señalado, pues el propio Decreto 927 de 2023 establece la obligatoriedad de hacer concursos anualmente, así las cosas, la situación de los provisionales y encargados debe ceder ante los derechos de quienes superen los procesos selectivos en aplicación de los principios de igualdad y mérito.”

provisionalidad. Esto es, en virtud de las listas que fueron cerradas con ocasión de la Sentencia C-331 de 2022 y de la garantía del principio de economía y del criterio de sostenibilidad fiscal. Además, hizo énfasis en que el régimen de transición es proporcional y constitucionalmente admisible, debido a la especialidad del régimen de carrera de la DIAN, la gestión del conocimiento al interior de la entidad y a los servicios esenciales prestados por ella.⁸⁶

50. En la siguiente tabla se resumen las respuestas dadas por la DIAN y la CNSC a las preguntas formuladas en el auto de pruebas:

Pregunta	DIAN	CNSC
¿Cuántos y cuáles son los empleos de la DIAN que están sometidos al sistema de carrera administrativa?	- El Decreto 416 del 21 de marzo de 2023 creó 10.166 empleos. - El Decreto 2153 del 20 de diciembre de 2017 creó 1.761 empleos. - El Decreto 2393 del 11 de diciembre de 2015 creó 1.498 empleos. - El Decreto 2394 del 11 de diciembre de 2015 creó 900 empleos. - El Decreto 4051 del 22 de octubre de 2008 creó 7.351 empleos. - El Decreto 4953 del 30 de diciembre de 2011 creó 33 cargos Para un total de 21.709 empleos.⁸⁷	Mediante comunicación 2024RS131691 del 29 de agosto de 2024, le dio traslado a la DIAN, en el entendido que la información solicitada recae sobre su competencia. ⁸⁸

⁸⁶ Ibidem, pp. 3 y 4.
⁸⁷ Ibidem 49, pp. 5 a 7. Seguidamente, la DIAN discriminó el total de empleos por descripción del cargo, código el grado y cantidad.
⁸⁸ Expediente digital D-15.948 AC contenido en Siicor, documento del 9 de septiembre de 2024 que contiene la respuesta a las pruebas solicitadas por parte de la Comisión Nacional del Servicio civil (CNSC), remitida por Jhonatan Daniel Alejandro Sánchez Murcia, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad, pp. 4 y 7.

<i>¿De todos los cargos de carrera que existen en la DIAN, cuántos se encuentran vacantes de manera definitiva y, al tiempo, están ocupados en provisionalidad o encargo?</i>	Respecto a los cargos en vacancia definitiva, la provisión en provisionalidad equivale a 4.249 empleos y en encargo a 1.413, para un total de 5.662.⁸⁹ Agregó que, en razón a la aplicación transitoria de la norma acusada, ésta va hasta la convocatoria DIAN 2497 de 2022, respecto de la cual avanzan las acciones para el nombramiento en periodo de prueba de la lista de elegibles, conforme al numeral 24.5 del artículo 24 del Decreto ley 927 de 2023.⁹⁰ De igual forma, sostuvieron que para la vigencia del 2024, esperan proveer 1.600 empleos para perfiles misionales, conforme se le informó a la CNSC.⁹¹	Mediante comunicación 2024RS131691 del 29 de agosto de 2024, le dio traslado a la DIAN, en el entendido que la información solicitada recae sobre su competencia.⁹²
<i>¿De todos los cargos de carrera que existen en la DIAN, cuántos han sido provistos por medio de concurso de mérito?</i>	- Provistos en carrera administrativa por concursos de mérito, 7.220. - En proceso de provisión, uso de lista de elegibles (convocatoria 1461 de 2020), 298. - Elegibles nombrados pendientes de tomar posesión (convocatoria DIAN 2497 de 2022), 737. - Pendientes de ser provistos	La entidad adjuntó una base de datos con la información remitida por el Grupo de Registro de Carrera Administrativa y el Banco Nacional de Listas de Elegibles, la cual contiene la información de los procesos de selección desde el 2020, adelantados por la entidad.⁹⁴ Revisada la base de datos, se constató que sumados los

⁸⁹ *Ibidem*, p. 7.

⁹⁰ *Ídem*. A su turno, precisó que “la DIAN ha provisto un total de 1.840 empleos a través del uso de listas de elegibles de las Convocatorias DIAN 1461 de 2020 y 2238 de 2021 y 79 más se encuentran en términos para posesión, realidad que claramente demuestra que la DIAN ha hecho grandes esfuerzos por proveer su planta de personal a través del mérito (concursos públicos y uso de lista de elegibles) con las restricciones y supuestos que no pueden pasarse por alto en dicho ejercicio, a saber: i) Disponibilidad Presupuestal y ii) Priorización de empleos a proveer según necesidades del servicio en autonomía de la Alta Dirección.”

⁹¹ En oficio No. 100000202-01685 del 16 de agosto de 2024.

⁹² *Ídem* 53.

⁹⁴ *Ibidem* 53, p. 5. Ello, en cumplimiento de la Ley 906 de 2004, el Decreto 1083 de 2015 y la Circular CNSC 11 de 2020.

	por nombramiento en período de prueba (convocatoria DIAN 2497 de 2022), 3.134 Para un total de 11.389 cargos.⁹³	procesos de selección, hay un total de 6.471 empleos, discriminados así: 1699 del proceso de selección DIAN 2020, 553 del proceso de selección DIAN 2021 (ascenso), 79 del proceso de selección DIAN 2022 (ascenso), 6 del proceso DIAN 2022 (ingreso) y 4.134 cargos de procesos de selección sin información.⁹⁵
<i>¿Qué concursos o convocatorias se han llevado a cabo para proveer vacantes definitivas, en cumplimiento del Decreto Ley 071 de 2020, y cuánto ha costado la realización de estos concursos?</i>	- Proceso de Selección DIAN 1461 de 2020, en el cual se ofertaron 1.500 empleos en la modalidad de ingreso. (CDP 36620 por valor de \$5.750.944.500,00).⁹⁶ - Proceso de Selección DIAN 2238 de 2021, en el que se ofertaron 622 empleos en la modalidad de ascenso. (CDP 54321 por valor de \$6.172.473.210,00).⁹⁷ - Proceso de Selección DIAN 2497 de 2022, el cual ofertó 4.700 empleos en la modalidad de ascenso. (CDP 67722 por valor de \$18.871.063.500,00) y que está en desarrollo.⁹⁸	- Proceso de Selección DIAN 1461 de 2020, en dónde se ofertaron 1.500 empleos en la modalidad de ingreso, Conforme al cierre financiero, el valor estimado de este proceso de selección fue de \$13.828.638.487.⁹⁹ - Proceso de Selección DIAN 2238 de 2021, en el que se ofertaron 622 empleos en la modalidad de ascenso. Según los trámites que están adelantando el trámite financiero, el presupuesto estimado fue de \$7.051.695.287.¹⁰⁰ - Proceso de Selección DIAN 2497 de 2022, en cuyo caso se ofertaron 4.700 empleos en la modalidad de ascenso. Se está en la etapa de expedición de listas, razón

⁹³ *Ibidem* 49, p. 8.

⁹⁵ Adjunto a la intervención de la CNSC, se encuentra la tabla dinámica contentiva de la información mencionada.

⁹⁶ Adjunto a la intervención de la DIAN, se encuentra el comprobante presupuestal del gasto descargado de la plataforma SIIF, del 3 de septiembre de 2024, p. 90.

⁹⁷ Adjunto a la intervención de la DIAN, se encuentra el comprobante presupuestal del gasto descargado de la plataforma SIIF, del 3 de septiembre de 2024, p. 91.

⁹⁸ Adjunto a la intervención de la DIAN, se encuentra el comprobante presupuestal del gasto descargado de la plataforma SIIF, del 3 de septiembre de 2024, p. 92.

⁹⁹ *Ibidem* 53, pp. 11 y 12

¹⁰⁰ *Ibidem* 53, pp. 13 y 14.

		por la cual aún no se cuenta con cierre financiero, no obstante, los costos reflejados arrojan una suma de \$29.320.365.418.¹⁰¹
¿Cuántas y cuáles son las listas de elegibles que hoy se encuentran vigentes en la DIAN?	Actualmente están vigentes las listas de elegibles de las convocatorias DIAN 2238 de 2021 y DIAN 2497 de 2022. Respecto de las listas de la primera convocatoria, informaron que fueron utilizadas en su totalidad.¹⁰²	Se adjuntó base de datos con la información que reposa en el Banco Nacional de Listas de Elegibles.¹⁰³ En ella, se constata que las listas que se encuentran vigentes son las siguientes: DIAN 2022 (modalidad ascenso), DIAN 2022 (modalidad ingreso) y DIAN 2238 de 2021 (modalidad ascenso). El número OPEC o de empleo de carrera por cada una es de 64, 147 y 56 respectivamente, para un total de 267.¹⁰⁴
¿Cuántos cargos se encuentran vacantes de manera definitiva en la DIAN, y cuántos concursos se espera realizar para proveerlos?	En la planta de personal de la DIAN, se registra un total de 10.320 cargos en vacancia definitiva, mismos que se espera proveer con la utilización de las listas de elegibles de la convocatoria DIAN 2497 de 2022 y mediante procesos de selección anuales entre el 2024 y el 2026.¹⁰⁵	Mediante comunicación 2024RS131691 del 29 de agosto de 2024, le dio traslado a la DIAN, en el entendido que la información solicitada recae sobre su competencia. Sin perjuicio de lo anterior, agregó que conforme al artículo 34 del Decreto Ley 927 de 2023, cada año se deberá convocar a concurso para la provisión definitiva de empleos de la planta de personal de la entidad.¹⁰⁶

¹⁰¹ *Ibidem* 53, pp. 5, 6, 15 y 16.

¹⁰² *Ibidem* 49, pp. 9 a 16. La DIAN describió, en una tabla por cada convocatoria, el número OPEC del cargo ofertado y la fecha de firmeza y finalización de firmeza de la lista. Al respecto, precisó que “*las firmezas individuales se refieren al primero de la lista respecto de quien operó dicho fenómeno.*”

¹⁰³ *Ibidem* 53, p. 6.

¹⁰⁴ *Ibidem* 53, p. 17.

¹⁰⁵ *Ibidem* 49, p. 16.

¹⁰⁶ *Ibidem* 53, pp. 6 y 7.

51. El ciudadano *Luis Fernando Lozada Elizalde*, demandante en el proceso de constitucionalidad D-15.971, se pronunció sobre las pruebas practicadas.¹⁰⁷ Sobre la totalidad de vacantes definitivas en la planta de la DIAN, observó que se acreditaron muchas más vacantes (entre 10.320 y 14.354) que las 3.290 en la modalidad de ingreso que ofertó la DIAN en el último concurso 2497 2022. De igual manera, indicó que la cifra aún está en duda. Si bien la DIAN certificó un total de 10.320, en el Plan Estratégico de Talento Humano de 2024, la entidad certificó un total de 15.350 vacantes a corte del 31 de diciembre de 2023¹⁰⁸ y en un informe de la Subdirección de Gestión del Empleo de la DIAN con fecha del 5 de agosto de 2024, se certificaron 14.354 vacantes definitivas.¹⁰⁹ Al respecto, el demandante concluyó que es posible que el valor de 10.320 se refiera únicamente a las vacantes no provistas, sin contar las ocupadas por un funcionario en encargo o provisionalidad o que se hayan descontado las 3.290 vacantes definitivas en modalidad de ingreso que se proveerán con las listas actuales provenientes del concurso DIAN 497 de 2022.¹¹⁰

52. Sostuvo, además, que se acreditó el valor correspondiente a la realización de los tres concursos de méritos, equivalente a \$30.794.481.210 -según la DIAN- y a \$50.200.699.192 -conforme a la CSNC. Ello, sin contar el gasto en que incurrieron los 14.000 elegibles del último concurso para la etapa de exámenes médicos y psicofísicas equivalente a \$3.710.000.000 (\$265.000 por concursante)¹¹¹ y los tres concursos anuales que la entidad planea realizar entre el 2024 y el 2026, supuestos fácticos que comprueban la afectación a los principios de mérito, igualdad, economía y eficiencia y al criterio de sostenibilidad fiscal.¹¹²

Concepto de la Procuradora General de la Nación

53. En cumplimiento de los artículos 242.2 y 278.5 de la Constitución, la Procuradora General de la Nación rindió el Concepto No. 7411.¹¹³ En él, solicitó declarar inexecutable el inciso de la norma acusada, pues éste además de que vulnera las disposiciones constitucionales listadas en la demanda, tampoco supera el denominado juicio de razonabilidad, en tanto persigue una finalidad ilegítima e introduce un medio prohibido por la Constitución.¹¹⁴

¹⁰⁷ Expediente digital D-15.948 AC contenido en *Siicor*, documento del 17 de septiembre de 2024 que contiene la intervención de Luis Fernando Lozada Elizalde, p. 1.

¹⁰⁸ El interviniente adjuntó el denominado Plan Estratégico de Talento Humano 2024, en donde consta la cifra mencionada (p. 6).

¹⁰⁹ El interviniente adjuntó el denominado CONCURSO 2024 Mesa de Revisión Sindical- Dirección de Gestión Corporativa, Subdirección de Gestión del Empleo Público (5 y 6 de agosto de 2024), en donde consta la cifra mencionada (p. 5).

¹¹⁰ *Ibidem*, p. 5.

¹¹¹ *Ídem*.

¹¹² *Ibidem*, p. 6.

¹¹³ Expediente digital D-15.948 AC contenido en *Siicor*, documento del 14 de enero de 2025 que contiene el concepto de la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, p. 2.

¹¹⁴ *Ibidem*, pp. 4 a 6.

54. En especial, indicó que “la Procuraduría comparte la posición de los intervinientes que solicitan declarar la inconstitucionalidad de la norma demandada, puesto que "no solo contradice la esencia del mismo artículo al hacer hincapié en los principios de economía, sostenibilidad fiscal y austeridad del gasto, sino que también se enfrenta a al principio del mérito al negar el uso de listas de elegibles para los empleos existentes en condición de vacancia definitiva". Ciertamente:

- (i) *"La negativa de la norma expone a quienes integran las listas de elegibles a tener que enfrentarse a nuevos concursos y, a su vez, para la entidad, un desgaste administrativo y económico para proveer estas vacantes"; y*
- (ii) *"Durante la vigencia de las listas de elegibles, es obligatorio su uso para proveer las vacantes definitivas, sin que el hecho de estar ocupadas en encargo o provisionalidad sea una excepción, contrario sensu, al no ser provistas por quienes ocupan un lugar meritorio en las listas, se puede incurrir en una vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la carrera administrativa y por consiguiente desconocimiento del principio del mérito".*

55. Mencionó que la optimización de los principios de la administración pública impone al órgano de producción normativa, el deber de garantizar el nombramiento de los aspirantes que ocuparon los primeros puestos de un concurso de mérito, incluso desplazando a los servidores que ocupan los puestos en encargo o provisionalidad y de darle uso a las listas de elegibles para racionalizar el gasto y el manejo del personal. En cambio, con la disposición normativa se pretendió garantizar la estabilidad de los trabajadores en encargo y provisionalidad, desprotegiendo los derechos de quienes aprobaron satisfactoriamente los concursos de méritos, además de pretender realizar nuevas convocatorias en desmedro de la correcta gestión de los recursos del Estado.¹¹⁵

II. CONSIDERACIONES

Competencia

56. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 241.5 y 242 de la Constitución, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir sobre las acciones públicas de inconstitucionalidad acumuladas en contra del inciso tercero del párrafo transitorio del artículo 36 del Decreto Ley 927 de 2023.

Cuestiones previas

¹¹⁵ *Ibidem*, pp. 4 y 5.

1. Aptitud de la demanda

57. El DAFP¹¹⁶ y la DIAN le solicitaron a esta Corporación declararse inhibida para pronunciarse de fondo sobre la controversia. A partir de estos planteamientos, le corresponde a esta Corte decidir si la demanda cumple o no con los presupuestos de aptitud para la conformación de un cargo de inconstitucionalidad. Esto, con miras a determinar si es factible realizar un pronunciamiento de mérito.

58. En reiterada jurisprudencia,¹¹⁷ la Corte ha señalado que el análisis de aptitud de la demanda realizado en el auto admisorio no impide que la Sala Plena de la Corte se pronuncie nuevamente sobre él, pues sobre ella reside la función constitucional de decidir sobre las demandas presentadas en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad.¹¹⁸ Máxime, cuando algún interviniente en el proceso así lo sugiere, pues ello le permite a la Sala contar con mayores elementos de juicio para realizar un estudio completo y detallado sobre su competencia para pronunciarse de fondo sobre la controversia.¹¹⁹

59. Con fundamento en los artículos 2 y 3 del Decreto 2067 de 1991, la Corte Constitucional ha sostenido que la demanda no puede acudir a acusaciones *vagas, abstractas, imprecisas o globales*, sino que debe desarrollar razones o motivos que sean “*claros, ciertos, específicos, pertinentes y suficientes*.”¹²⁰ De ahí que se hayan previsto los presupuestos de *claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia*, cuyo alcance ha sido previsto por la Corte, así:

Presupuesto	Explicación
<i>Claridad</i>	Le impone al demandante el deber de seguir un hilo conductor argumentativo que le permita al lector comprender fácilmente el contenido de la demanda y las justificaciones inmersas en ella. ¹²¹

¹¹⁶ Si bien el DAFP le solicitó a la Corte Constitucional declararse inhibida para fallar el caso del asunto, lo cierto es que no expuso razones que explicaran porque las demandas de inconstitucionalidad no superaron los presupuestos argumentativos de *claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia* que establece el Decreto 2067 de 1991. La entidad, en cambio, se limitó a afirmar que los cargos de inconstitucionalidad provienen de una interpretación arbitraria y subjetiva del actor, más no de una confrontación directa con la Constitución, que no se expusieron razones suficientes que permitieran concluir que el fragmento cuestionado vulnera los artículos 29, 40.7 y 125 de la Constitución y que los hechos en que se funda la demanda no responden a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Por consiguiente, procederá a aplicar la regla de la Sentencia C-100 de 2022, según la cual, ante la generalidad y simpleza de una solicitud de inaptitud, la Sala reafirmará que si se cumplieron con los mínimos argumentativos que habilitan a esta Corporación a efectuar un análisis de fondo.

¹¹⁷ Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-1115 de 2004, C-1300 de 2005, C-074 de 2006, C-929 de 2007, C-623 de 2008, C-035 de 2020, C-493 de 2020, C-138 de 2023, C-120 de 2024 y C-513 de 2024.

¹¹⁸ Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-623 de 2008.

¹¹⁹ Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-623 de 2008, C-212 de 2022, C-138 de 2023 y C-337 de 2024. En palabras de esta Corporación: “(...) *Aun cuando en principio, es en el auto admisorio donde se define si la demanda cumple o no con los requisitos mínimos de procedibilidad, ese primer análisis responde a una valoración apenas sumaria de la acción, llevada a cabo únicamente por cuenta del Magistrado Ponente, razón por la cual, la misma no compromete ni define la competencia del Pleno de la corte, que es en quien reside la función constitucional de decidir de fondo sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes y los decretos con fuerza de ley (C.P. art. 241-4-5).*”

¹²⁰ Cfr. Corte Constitucional, Sentencias C-1052 de 2001, C-623 de 2008, C-303 de 2021, C-138 de 2023, C-470 de 2023, C-513 de 2024, entre otras.

Certeza	Se refiere a la necesidad de que la demanda recaiga sobre “ <i>una proposición jurídica real y existente</i> ” y no simplemente sobre una deducida por el actor, implícita o que se refiere a otras normas vigentes que no son objeto de la demanda. Igualmente, deberán presentarse interpretaciones que se fundamentan en un contenido verificable del mandato demandado. ¹²²
Especificidad	Debe demostrar de forma diáfana que la disposición demandada desconoce la Constitución, “ <i>a través de la formulación de por lo menos un cargo constitucional concreto contra la demanda.</i> ” Lo anterior conlleva la necesidad de presentar una oposición objetiva y verificable entre lo que dispone la demanda y el texto constitucional, por lo que resulta inadmisibile la presentación de argumentos <i>vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales.</i> ¹²³
Pertinencia	Hace referencia a la importancia de que el reproche puesto a consideración de la Corte sea de naturaleza constitucional, y no responda a razones de orden legal, personal, doctrinal o de simple conveniencia.
Suficiencia	Se predica de la exposición de todos los elementos de juicio, tanto argumentativos como probatorios, necesarios para iniciar el juicio de constitucionalidad requerido. Asimismo, apela al alcance persuasivo de la demanda, esto es, de incoar argumentos que generen una duda mínima sobre la constitucionalidad de la disposición demandada.

60. Ahora bien, esta Corporación también ha sostenido que estas exigencias argumentativas no pueden interpretarse de forma extremadamente rigurosa, al punto de disuadir al ciudadano de ejercer su derecho político. De ahí que para declarar una sentencia inhibitoria por ineptitud sustantiva de la demanda, se requiere que ésta sea manifiesta.¹²⁴

61. En lo que respecta a los cargos de inconstitucionalidad por el desconocimiento del principio de igualdad, la jurisprudencia reiterada de esta Corporación ha exigido una carga argumentativa mayor frente al presupuesto de *especificidad*. En ese sentido, la Corte Constitucional ha determinado que cuando se cuestiona una norma

¹²¹ Cfr., Corte Constitucional, Sentencia C-623 de 2008.

¹²² Cfr., Corte Constitucional, Sentencias C-509 de 1996, C-1048 de 2000, C-011 de 2001 y C-623 de 2008.

¹²³ Cfr., Corte Constitucional, Sentencia C-623 de 2008.

¹²⁴ Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-295 de 2021. En esa decisión, la Corte Constitucional dijo: “*Así, lo contenido en los dos fundamentos jurídicos anteriores, debe analizarse tomando en consideración los siguientes elementos: 1) que, como se mencionó con anterioridad, a los ciudadanos no se les exige cualificación académica alguna como requisito para demandar. 2) Que un análisis estricto de estos requerimientos puede afectar la democracia participativa. 3) Que las sentencias inhibitorias deben ser excepcionales, pues es necesario proteger el derecho de acceso a la justicia. Y 4) que la propia Sentencia C-1052 de 2001 resaltó la importancia del principio pro actione, según el cual, siempre que exista duda sobre el cumplimiento de los requisitos adjetivos de una demanda, aquella debe resolverse en favor del actor. Prefiriéndose, en tal caso, un fallo de fondo.*”

por violación del principio de igualdad, el requisito de *especificidad* del cargo también exige: (i) identificar cuáles son los sujetos comparables y a partir de qué criterio de comparación; (ii) explicar en qué consiste el trato discriminatorio que la norma establece; y (iii) presente las razones por las cuales dicho trato resulta desproporcionado o irrazonable.¹²⁵

1.1. Análisis de aptitud de la demanda

62. La Corte analizará la aptitud de la demanda de cara a los cargos presentados en ambas demandas -correspondientes a los expedientes D-15.948 y D-15.971- vistos de forma conjunta, de acuerdo con su temática. Así, la Corte identifica tres cargos; (i) cargo primero (presunto desconocimiento del debido proceso, contenido en el artículo 29 de la Constitución) contenido de la demanda D-15.948 (ii) cargo segundo (presunto desconocimiento del derecho a la igualdad, del derecho a acceder a cargos públicos y del principio del mérito, contenidos en los artículos 13, 40.7 y 125 de la Constitución) tal como se refirió en la demanda D-15.0971, pero que al replicar las mismas razones del primer cargo de la demanda D-15.948, más otras adicionales, serán analizados conjuntamente y (iii) cargo tercero (presunto desconocimiento de los principios de eficiencia, moralidad y economía de la función administrativa y del criterio de sostenibilidad fiscal, conforme a los artículos 209 y 334 de la Constitución) referido en la demanda D-15.971.

63. La Corte Constitucional concluye que la demanda es apta, respecto a los *cargos primero y segundo*. En lo que respecta al cargo primero, la demanda con el radicado D-15.948 expuso que el acápite demandado desconoce el derecho fundamental al debido proceso de los aspirantes a los concursos de mérito, pues emplea una nueva condición para el uso de las listas de elegibles aplicable de forma retroactiva a los concursos de la DIAN adoptados conforme al Decreto Ley 071 de 2020 y que no era previsible para el momento de su postulación. Además, adujo que con ello desconoció también los principios de confianza legítima y legalidad.

64. Sobre este cargo, la DIAN sostuvo que el demandante no aportó planteamientos concretos y específicos que justificaran la aparente vulneración al debido proceso. Al respecto, la Corte advierte que esta razón responde a un enunciado genérico de ineptitud que no está fundamentada en ningún argumento concreto que lo sustente. Puesto que el interviniente se limitó a cuestionar los argumentos del demandante sin proveer razones del incumplimiento de cada uno de los requisitos de la carga argumentativa mínima requerida, la Sala aplicará la regla de la Sentencia C-100 de 2022. Según ella, ante la generalidad y simpleza de una solicitud de inaptitud, la Sala procederá a reafirmar que sí se cumplieron con los mínimos argumentativos que habilitan a esta Corporación a efectuar un análisis de fondo.

¹²⁵ Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-050 de 2021.

65. Ahora bien, la Sala considera necesario indicar que a pesar de que el actor hizo referencia a los principios de confianza legítima y legalidad -al exponer las razones por la cuales consideraba vulnerado el derecho fundamental al debido proceso- no desarrolló argumentos adicionales que permitieran colegir su aparente trasgresión, y con ello, el cumplimiento de la carga mínima argumentativa exigida. Por consiguiente, la Sala Plena no se pronunciará sobre ellos.

66. Sobre el *cargo segundo*, ambas demandas presentaron argumentos similares respecto a la presunta vulneración del derecho a acceder a cargos públicos y del principio del mérito, previstos en los artículos 40.7 y 125 de la Constitución. En esencia, expusieron que el acápite demandado desconoce el principio del mérito porque le otorga a quienes ocupan cargos en provisionalidad o encargo un derecho superior, por encima del de quienes integran las listas de elegibles. Esa proposición jurídica, en su opinión, además de que desnaturalizó el carácter temporal de los nombramientos de provisionalidad y encargo, lo convirtió en la regla general y les dio cabida a intereses políticos. A criterio de los demandantes, el inciso en cuestión también vulnera el derecho a acceder a cargos públicos porque los elegibles de esas listas ven reducidas sus posibilidades para acceder a esos cargos.

67. Sobre la presunta vulneración del artículo 40.7 de la Constitución, puesto que la DIAN solamente afirmó que no se ofrecieron razones suficientes, la Sala adoptará la misma razón de la decisión de la Sentencia C-100 de 2022, mencionada previamente.

68. En cuanto a la presunta violación del artículo 125 de la Constitución, la DIAN adujo que este cargo carece de *certeza* porque parte de la lectura subjetiva de que al no utilizarse las listas de elegibles, los empleos en encargo o provisionalidad se perpetuarán. En su criterio, ello no es cierto, porque el Decreto 927 de 2023 establece la obligación de gestionar concursos de mérito cada año. Sobre el particular, la Sala observa que sí se cumple con el mencionado presupuesto, pues lo que sí es *cierto* es que a raíz de la prohibición decantada en el inciso tercero, las listas de elegibles no podrán utilizarse si los cargos están provistos en provisionalidad o encargo. Además, si bien el artículo 34 del Decreto 927 de 2023 dispone que cada año se convocará a un nuevo concurso para la provisión definitiva de los empleos de la planta de personal de la entidad, lo cierto es que cuando el parágrafo acusado dispuso repetir el concurso para proveer los cargos que se encuentran provistos en provisionalidad o encargo, no establece el plazo para la realización del nuevo concurso. Además, las razones de los demandantes no se agotaban con el argumento de la perpetuidad, sino que iban más allá; el mayor derecho de quienes ocupan el cargo en provisionalidad o encargo, sobre quienes integran las listas de elegibles.

69. Ahora, la demanda D-15.971 también integró dentro del *cargo segundo*, la presunta vulneración del artículo 13 de la Constitución. Sobre éste, la Sala encuentra que si se cumplió con la carga mínima argumentativa exigida para la aptitud del

cargo, particularmente respecto al presupuesto de *especificidad*. Pues bien, el demandante identificó los grupos de sujetos comparables, precisó el criterio de comparación, expuso en qué consistió el trato diferente y las razones por las que considera que dicho trato no es justificado.

70. En el escrito de corrección de la demanda, el actor señaló que “los grupos objeto de comparación para poder establecer el parámetro de igualdad, son los provisionales y los funcionarios de carrera vinculados a la DIAN que se encuentran ocupando un cargo de carrera transitoriamente, pero sobre el cual no ostentan derechos de carrera propiamente dichos -pues los primeros solo son provisionales y los segundos están encargados en cargos superiores a sus cargos de origen- el otro, el resto de aspirantes externos con expectativa de poder acceder a dichos cargos a través del concurso de méritos.”¹²⁶ También indicó que los grupos referidos “se encuentran en la misma posición jurídica de querer acceder a dichos cargos vacantes sobre los que no tienen aun derechos de carrera.”¹²⁷

71. Además explicó que la norma demandada privilegia “al primer grupo, al prohibir que las eventuales listas de elegibles que se generen en el concurso público de méritos que se estaba adelantando al momento de expedirse la norma -y que aún no culmina en la actualidad- puedan usarse para proveer vacantes que estén ocupadas transitoriamente por dicho primer grupo -provisionales y funcionarios de carrera encargados”¹²⁸ Ambos grupos son comparables en la medida en que ambos buscan aspirar a empleos públicos de vacancia *definitiva*, respecto de los cuales no ostentan derechos de carrera *per se*.

72. Finalmente el actor señaló que de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el concurso de méritos es la forma en que se protege igualdad de trato y el acceso a cargos públicos. Por esa razón “las listas de elegibles que surgen de dichos procesos de selección son obligatorias y vinculantes, pues de lo contrario, se otorga un trato discriminatorio a los aspirantes en dichos concursos respecto a quienes ya ocupan dichos cargos transitoriamente (provisionales y encargos), pues los primeros, obviamente, no tendrían las mismas oportunidades que los segundos de acceder a los mismos, ya que los primeros no podrían posesionarse en estos cargos pese a pasar un proceso meritocrático, mientras que los segundos podrían seguir ocupándolos, sin haber pasado un proceso meritocrático de manera, supuestamente ‘transitoria’, alargando de manera irregular y sin ninguna justificación dicha interinidad.”¹²⁹

73. De lo anterior se desprende que el demandante si definió como grupos comparables, por un lado, a los integrantes de la lista de elegibles, y por el otro, a los

¹²⁶ Expediente digital D-15.971 AC contenido en *Siicor*, documento denominado “D0015948-Corrección a la Demanda-(2024-08-06 09-16-09).pdf,”

¹²⁷ *Ibidem*.

¹²⁸ *Ibidem*.

¹²⁹ *Ibidem*.

que ocupan el cargo de manera transitoria. Además, indicó como criterio de comparación, la intención de acceder a dicho cargo, y finalmente, explicó las razones por las cuales ese tratamiento -el de darle prelación a quienes ocupan los cargos en provisionalidad o encargo- no está justificado en términos constitucionales.

74. Por último, la demanda D-15.971 incluyó un *cargo tercero* relacionado con la presunta vulneración de los principios de eficacia, moralidad y economía de la administración pública, así como del criterio de sostenibilidad fiscal. Sobre este, la Sala coincide con la DIAN en que no se superaron los mínimos argumentativos. En esta oportunidad, la Sala constata que no se cumplió con los presupuestos de *especificidad y suficiencia* puesto que los argumentos expuestos se basan en una lectura subjetiva realizada por el actor acerca de los efectos que la disposición podría estar causando en el erario público. Si bien el demandante cuestiona la gestión de los recursos para el desarrollo de los concursos de méritos, no expone argumentos de índole constitucional y mucho menos genera dudas sobre la constitucionalidad de la disposición demandada.

75. En conclusión, la Corte reitera que la demanda es apta respecto de los cargos; *primero* (presunto desconocimiento del debido proceso, contenido en el artículo 29 de la Constitución) y *segundo* (presunto desconocimiento del derecho a la igualdad, a acceder a cargos públicos y al principio del mérito, contenidos en los artículos 13, 40.7 y 125 de la Constitución). En cambio, no es apta frente al cargo *tercero* (presunto desconocimiento de los principios de eficiencia, moralidad y economía de la función administrativa y del criterio de sostenibilidad fiscal, conforme a los artículos 209 y 334 de la Constitución).

2. Cosa juzgada material constitucional

76. El fenómeno de la cosa juzgada constitucional es una institución jurídico procesal que encuentra su fundamento en el artículo 243 de la Constitución y en el artículo 22 del Decreto 2067 de 1991, mediante el cual a las decisiones judiciales se les concede el carácter inmutable y vinculante.¹³⁰ Ello, a fin de hacer prevalecer los principios de igualdad, seguridad jurídica, primacía del interés general y confianza legítima, lo cual se traduce en la obligación de la Corte Constitucional de ser consistente con las decisiones que se adopten.¹³¹

77. Para examinar su configuración, esta Corporación ha insistido en la necesidad de verificar los siguientes elementos: (i) *identidad de objeto*, es decir, que el estudio

¹³⁰ Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-774 de 2001. De manera particular, el artículo 243 de la Constitución indica que “[l]os fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material de un acto jurídico declarado inexecutable por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución.”

¹³¹ Cfr. Corte Constitucional, Sentencias C-061 de 2010, C-007 de 2016, C-096 de 2018, C-233 de 2021, C-147 de 2022 y C-449 de 2022.

recaiga sobre el mismo contenido normativo; (ii) *identidad de causa*, que se refiere a que el juicio de constitucionalidad se fundamente en las mismas razones, lo que incluye la misma norma presuntamente vulnerada e (iii) *identidad de parámetro de control*, es decir, que no exista un cambio en el contexto normativo o el surgimiento de nuevas razones que ameriten la revisión, lo que daría lugar a un nuevo contexto de valoración.¹³²

78. En suma, la garantía del fenómeno de la cosa juzgada constitucional resulta fundamental, pues impide volver a pronunciarse sobre una cuestión sobre la que se produjo una decisión de mérito, de manera que la Corte deberá estarse a lo resuelto en la sentencia anterior. Ahora, sobre los efectos y alcance de la cosa juzgada, la jurisprudencia constitucional ha referido que no siempre son iguales, sino que existen distintos tipos que pueden, *“incluso, modular el alcance y los efectos del fallo.”*¹³³

79. Entre los diferentes tipos de cosa juzgada, se encuentra la cosa juzgada constitucional material. Ésta, en palabras de esta Corporación, ocurre:

*“cuando existen dos disposiciones formalmente distintas que, sin embargo, tienen el mismo contenido normativo. En estos casos, es claro que, si ya se emitió un juicio de constitucionalidad previo en torno a una de esas disposiciones, este involucró la evaluación del contenido normativo como tal, que se reitera en la nueva norma, más allá de los aspectos gramaticales o formales que pueden ser diferentes en las disposiciones comparadas. Según la jurisprudencia, ‘la materia juzgada’ está conformada por dos extremos ligados entre sí: la norma jurídica objeto de control y el cargo de inconstitucionalidad, esto independientemente del cuerpo normativo formal en el que se encuentre la norma.”*¹³⁴

2.1. Inexistencia de cosa juzgada constitucional material respecto de la Sentencia C-331 de 2022

80. El actor de la demanda D-15.971 mencionó que la Corte Constitucional ya se había pronunciado sobre el artículo 34 del Decreto Ley 071 de 2020 en la Sentencia C-331 de 2022, cuya norma es de contenido similar al fragmento estudiado en el caso *sub judice*. En opinión del actor, ambas normas buscan limitar el uso de las listas de elegibles, inobservando el régimen general de carrera; la primera norma lo hacía dándole la potestad a la CNSC y a la DIAN de usar o no las listas, mientras que la segunda norma lo hace prohibiendo expresamente su uso si la vacante definitiva está siendo ocupada en provisionalidad o encargo. Por consiguiente, con el acápite demandado se evadieron los efectos de la Sentencia C-331 de 2022, decisión que

¹³² Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-507 de 2023.

¹³³ Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-600 de 2010.

¹³⁴ Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-290 de 2019.

también tuvo en cuenta los principios del mérito, de la provisión de cargos públicos y de la administración pública.

81. La Corte constata que no existe *identidad de objeto* entre la disposición estudiada en la Sentencia C-331 de 2022 y la norma acusada en este caso. En la sentencia en cita, la Corte declaró inexecutable las expresiones subrayadas del inciso segundo del artículo 34 del Decreto Ley 071 de 2020, que decían: “(...). Siempre y cuando la convocatoria así lo prevea, la lista de elegibles podrá ser utilizada en estricto orden descendente para proveer única y exclusivamente las vacantes que pudieren presentarse en los empleos que fueron ofertados como consecuencia del retiro del servicio del titular.” En su lugar, suprimió el primer fragmento y sustituyó la palabra “podrá” por el vocablo “deberá”.¹³⁵

82. En cambio, el inciso tercero del párrafo transitorio del artículo 36 del Decreto Ley 927 de 2023 que se analiza en esta oportunidad, dice: “[e]n todo caso, las listas de elegibles a que hace referencia el presente párrafo transitorio no podrán utilizarse si el empleo público se encuentra provisto mediante encargo o provisionalidad. Estos cargos públicos deberán ser ofertados en una nueva convocatoria aplicando las reglas previstas en este Decreto-Ley.”

83. Véase que en el primer supuesto -el del inciso segundo del artículo 34 del Decreto Ley 071 de 2020- la Corte sostuvo que la disposición normativa debía leerse en el sentido de que el uso de las listas de elegibles era imperativo y no facultativo. Mientras que, en este caso, la Corte debe analizar una prohibición para utilizar las listas de elegibles cuando el cargo está siendo ocupado en encargo o provisionalidad. Además de que la norma no es la misma, tampoco reproduce su contenido. Una cosa es una disposición que obliga -bajo la lectura de la Corte- a usar las listas de elegibles y otra muy distinta es aquella que establece una prohibición absoluta de utilizar las listas, solamente en el supuesto en que el cargo esté siendo ocupado transitoriamente por un encargo o por provisionalidad. Además de que la acción a emplear en la norma no es la misma -en el primer supuesto la acción es *de hacer*, mientras que en el segundo supuesto es de *no hacer*, los elementos normativos tampoco son los mismos; el inciso segundo del artículo 34 se refiere a las vacantes ofertadas como consecuencia del retiro del servicio del titular, en cambio, el inciso tercero del párrafo transitorio del artículo 36 hace referencia a los cargos ocupados en encargo o provisionalidad.

3. Problemas jurídicos y esquema de resolución

¹³⁵ En consecuencia, el inciso segundo mencionado se leerá así: “[l]a lista de elegibles deberá ser utilizada en estricto orden descendente para proveer única y exclusivamente las vacantes que pudieren presentarse en los empleos que fueron ofertados como consecuencia del retiro del servicio del titular”.

84. En atención a los antecedentes expuestos, le corresponde a esta Corte Constitucional resolver el siguiente problema jurídico: ¿La restricción al uso de las listas de elegibles cuando el empleo público se encuentre provisto mediante encargo o provisionalidad, así como la realización de una nueva convocatoria con ocasión de dicha restricción, viola el derecho fundamental a la igualdad, al debido proceso, al acceso a cargos públicos, así como al principio del mérito?

85. Con el propósito de absolver el problema jurídico formulado, la Corte se referirá a la jurisprudencia sobre: (i) el principio constitucional del mérito y el régimen de carrera administrativa (ii) los sistemas especiales de carrera administrativa y la carrera administrativa específica en la DIAN y, finalmente (iii) se pronunciará sobre la constitucionalidad del inciso tercero del parágrafo transitorio del artículo 36 del Decreto Ley 927 de 2023.

(i) El principio constitucional del mérito y el régimen de carrera administrativa. Reiteración jurisprudencial

El principio constitucional del mérito y la carrera administrativa como mecanismo técnico de su implementación

86. El mérito fue reconocido popularmente como consecuencia de la adopción del plebiscito de 1957, en concreto, de sus artículos 5,¹³⁶ y 7.¹³⁷ En palabras de esta Corporación, la causa de dicha evolución fue “*garantizar la estabilidad en los cargos públicos, con base en la experiencia, la eficiencia y la honestidad en el desempeño de los mismos, sustrayéndolos a los vaivenes, manipulaciones y contingencias de la lucha político partidista, que hasta entonces había llevado a que cada vez que se producía un cambio de gobierno y el poder político era conquistado por uno de los partidos tradicionales, sistemáticamente excluía a los miembros del otro partido de la participación en los cargos públicos, aun en los niveles más bajo.*”¹³⁸

89. En desarrollo de lo aprobado en el plebiscito¹³⁹ se creó el Departamento Administrativo del Servicio Civil y la Escuela Superior de Administración Pública.¹⁴⁰ Asimismo, se distribuyeron los empleos públicos en (i) los de carrera administrativa y (ii) los de libre nombramiento y remoción¹⁴¹ y se definió la carrera

¹³⁶ “Artículo 5. El Presidente de la República, los Gobernadores, los Alcaldes, y en general todos los funcionarios que tengan facultad de nombrar y remover empleados administrativos, no podrán ejercerla, sino dentro de las normas que expida el Congreso, para establecer y regular las condiciones de acceso al servicio público, de ascensos por mérito y antigüedad, y de jubilación, retiro o despido.”

¹³⁷ “en ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo o cargo público de la carrera administrativa o su destitución o promoción”.

¹³⁸ Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-195 de 1994, reiterada en la Sentencia C-588 de 2009.

¹³⁹ Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-195 de 1994.

¹⁴⁰ Ley 19 de 1958.

¹⁴¹ Decreto 1732 de 1960, que rigió hasta la expedición del Decreto 2400 de 1968, en atención a las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 65 de 1967, para “modificar las normas que regulan la clasificación de los

administrativa como un “*mecanismo de administración de personal que no reconoce para el acceso al servicio y para la permanencia y promoción dentro de él, factores distintos al mérito personal, demostrado mediante un serio proceso de selección. Proceso que tiene las siguientes etapas: La convocatoria, el reclutamiento, la oposición, la lista de elegibles, el período de prueba y el escalonamiento.*”¹⁴² A su vez, se reguló la pérdida de los derechos de carrera, la calificación de servicios y los nombramientos provisionales.¹⁴³

90. Posteriormente, en la Asamblea Nacional Constituyente, se presentaron consensos frente a la importancia del sistema del mérito y la carrera administrativa, así como el reconocimiento de la existencia de problemas estructurales en la función pública, particularmente relacionados con la corrupción en la provisión de cargos públicos y la ineficiencia de los empleados del Estado que impedían la efectiva y adecuada prestación de servicios. Sobre el asunto, la Gaceta No. 68 publicó el acta de la reunión del 6 de mayo de 1991 en la que se lee el siguiente apartado¹⁴⁴:

“Para cumplir la finalidad del Estado consagrados en que el servidor público está al servicio exclusivo de la comunidad, y en consecuencia en una de las alternativas del articulado se propone la adopción de las carreras en todos los órganos, órdenes y niveles. Eso sí, como lo señalara la comisión presidencial para la reforma de la administración pública, convocada durante la administración Barco: ‘la carrera administrativa no puede distorsionarse como garantía de estabilidad de funcionarios ineficientes ni de protección de intereses puramente gremiales, sino que, ‘es un adecuado desarrollo, constituye el sistema técnico de administración de personal propio del sector público, dirigido a asegurar la eficiencia de la administración...’ Como lo precisara igualmente la Comisión Preparatoria sobre Administración pública: ‘El país demanda ahora como prioridad la mayor eficiencia y eficacia en la gestión pública, como condición básica para desarrollar la legitimidad institucional. Esto unido a la elevación general de los niveles de calificación exige criterios que garanticen la mayor profesionalización del servidor público, promoviendo el desempeño y la eficiencia, buscando la mayor competitividad en el acceso al servicio público en la permanencia en el mismo, y siempre acorde con la necesidad del servicio.’”

91. La Constitución Política dispuso que el régimen de carrera administrativa es la regla general de vinculación y el mecanismo que busca satisfacer los fines del Estado y garantizar un adecuado ejercicio de la función pública. Al impartir dicho mandato, el artículo 125 constitucional también dispuso; (i) que el concurso es el mecanismo para acreditar el mérito y las calidades, cuando la Constitución o la ley no dispone de

empleos”. Posteriormente, la Ley 61 de 1987 introdujo cambios en la clasificación de los empleos de libre nombramiento u remoción. *Cfr.* Corte Constitucional, Sentencia C-195 de 1994.

¹⁴² Decreto 1950 de 1973. *Cfr.* Corte Constitucional, Sentencia C-356 de 1994.

¹⁴³ Ley 61 de 1987. *Cfr.* Corte Constitucional, Sentencia C-195 de 1994.

¹⁴⁴ *Ídem.*

otro sistema para el nombramiento; (ii) el cumplimiento de los requisitos legales como indicativo del mérito y las calidades del aspirante, para el acceso y el ascenso; (iii) que el retiro del servicio se produzca como consecuencia de una calificación insatisfactoria, violación al régimen disciplinario o la configuración de las demás causales constitucionales o legales y (iv) la prohibición de que la filiación política influya en el acceso, ascenso o retiro de un empleado de carrera.¹⁴⁵

92. Respecto del principio constitucional del mérito, en la **Sentencia C 071 de 1993**, la Corte indicó que *“la ratio iuris de una carrera no es otra que la de racionalizar la administración mediante una normatividad que regule el mérito para el ingreso, el ascenso, los concursos, la capacitación, las situaciones administrativas y el retiro del servicio. Con ello se objetiviza el manejo del personal y se sustraen los empleos de factores subjetivos.”* En ese sentido, en la **Sentencia C-315 de 2007**, esta Corporación reconoció que la carrera administrativa era el mecanismo que permitía organizar el servicio público fundado en el mérito como la base para el ingreso y permanencia en un cargo.

93. En la **Sentencia C-588 de 2009** la Corte reiteró que de acuerdo con la interpretación de las disposiciones superiores, *“la carrera administrativa ‘se fundamenta única y exclusivamente en el mérito y la capacidad del funcionario público’, mérito que, en tanto elemento destacado de la carrera administrativa, comparte el carácter de regla general que a ésta le corresponde”*. Así mismo señaló que *“los principios generales de la carrera administrativa se enfocan ‘todos ellos a la eficacia del criterio del mérito como factor definitorio para el acceso, permanencia y retiro del empleo público’¹⁴⁶”*.

94. Es preciso señalar que en la referida Sentencia C- 588 de 2009, la Corte, al declarar la inexecutable del acto Legislativo No. 01 de 2008 *“Por medio del cual se adicionaba el artículo 125 de la Constitución Política”*, concluyó que la carrera administrativa constituía un eje definitorio de la identidad de la Constitución y que su ausencia trastocaba contenidos constitucionales relevantes. Lo anterior, porque la carrera administrativa es un principio constitucional que *“contiene una base axiológico-jurídica de interpretación, cuyo desconocimiento vulnera la totalidad del ordenamiento constitucional y, por lo mismo, una de las garantías cuyo desconocimiento podría acarrear la sustitución de la Constitución, cuando se la desconoce en conjunto con otras garantías constitucionales, y en el caso presente, la carrera administrativa no constituye un referente aislado, pues sus relaciones con distintos contenidos constitucionales se despliegan en tres órdenes, relativos al cumplimiento de los fines del Estado, a la vigencia de algunos derechos fundamentales y al respeto del principio de igualdad.”*. Postura que fue reiterada en las sentencias C-533 de 2010, C-249 de 2012, C-285 de 2012 y C-097 de 2019, entre otras.

¹⁴⁵ Cfr. Corte Constitucional, Sentencias C-077 de 2021 y C-387 de 2023.

¹⁴⁶ Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-315 de 2007.

95. Con el paso del tiempo, la Corte cambió su postura a fin de afianzar que el principio del mérito es transversal y piedra angular del acceso al empleo público y que la carrera administrativa es un mecanismo técnico a través del cual se concreta el principio constitucional del mérito. Es así como, en la **Sentencia C- 077 de 2021** la Corte afirmó que *“es válido afirmar que el Constituyente de 1991 consideró como elemento fundamental del ejercicio de la función pública el principio del mérito y que previó a la carrera, sistema técnico de administración del componente humano, como un mecanismo general de vinculaciones”*¹⁴⁷

96. Ahora bien, en la **Sentencia SU-067 de 2022**, la Corte recordó que si bien inicialmente entendía el principio del mérito como un elemento de la carrera administrativa, la jurisprudencia reciente destacó la importancia del principio constitucional al mérito, como postulado autónomo.¹⁴⁸ A su turno, en la **Sentencia C-102 de 2022**, la Corte indicó que el *mérito* es el principio transversal y la piedra angular sobre el cual se instituye el servicio público. Lo anterior, luego de precisar que el principio del mérito no es aplicable únicamente a los empleos de carrera administrativa, sino que también permea y es la base de la selección de quien ocupe cualquier cargo en el Estado, sin importar que se trate de uno de libre nombramiento y remoción, un trabajo oficial o uno de elección popular, mismos que no exigen la realización de un concurso. Además, reiteró que:

*“no es sólo en la carrera administrativa, en donde [el mérito] su mayor expresión encuentra sentido, dado que con independencia del cargo de que se trate, lo cierto es que la prestación eficiente de los servicios a cargo del estado exige, como condición necesaria, la concurrencia de capacidades en quienes están encargados de su prestación.”*¹⁴⁹,

*“[a] pesar de la relevancia del concurso en la provisión de empleos públicos, dicha modalidad de vinculación no es exclusiva de la carrera administrativa, como tampoco lo es el criterio del mérito para la selección de los aspirantes. En efecto, la acreditación de las respectivas calidades para el empleo también se exige respecto de cargos que no sean de carrera, en virtud de los distintos mecanismos que se dispongan para establecer la idoneidad de los aspirantes.”*¹⁵⁰

“aunque tradicionalmente se ha asimilado el principio del mérito con el sistema de manejo del personal denominado de carrera, ya que es allí donde se materializa el mérito de la manera más palpable y exigente, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que se trata de un mandato transversal

¹⁴⁷ Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-172 de 2021.

¹⁴⁸ Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-077 y C-172 de 2021.

¹⁴⁹ Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C- 534 de 2016.

¹⁵⁰ Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-084 de 2018.

predicable no únicamente de los empleos de carrera, sino de todo empleo público y, en general, del ejercicio de las funciones públicas.”¹⁵¹

97. Finalmente, la referida sentencia señaló, sobre las excepciones a la carrera administrativa, que *“no implican que esas formas de elección o designación no expresen el mérito o se contrapongan al mismo. El mérito no necesariamente es sinónimo de capacidades técnicas y títulos académicos, pues en un sentido amplio cubija tanto calificaciones objetivas como la valoración –transparente– de aspectos subjetivos necesarios para acreditar la aptitud, como lo es la idoneidad moral del aspirante.”*

98. En esta línea, la **Sentencia C-387 de 2023**¹⁵² explicó que la constitucionalización del principio del mérito persigue tres propósitos:

- El cumplimiento de los fines del Estado y de la función administrativa y con ello, lograr que al empleo público accedan personas calificadas que desempeñen sus funciones con eficacia y eficiencia.
- Materializar derechos a los ciudadanos. A modo de ejemplo, el de desempeñar y acceder a cargos públicos, el debido proceso a partir de la definición de reglas y criterios de selección y, al trabajo, pues la remoción del servicio en principio solo procede por la falta de mérito.
- La igualdad de trato y oportunidades, proscribiendo los tratos diferenciados o arbitrarios en el proceso de selección. La Corte ha sostenido que el principio de mérito *“constituye plena garantía que desarrolla el principio a la igualdad, en la medida en que contribuye a depurar las prácticas clientelistas o políticas en cuanto hace al nombramiento de los servidores públicos o cuando fuese necesario el ascenso o remoción de los mismos, lo que les permite brindarles protección y trato sin discriminación de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.”¹⁵³*

99. Por último, recientemente esta Corporación, en la **Sentencia C- 069 de 2025**, reiteró que por regla general, los empleos de carrera administrativa deben ser provistos mediante concurso de méritos.¹⁵⁴

¹⁵¹ Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-503 de 2020.

¹⁵² Reiterados en la Sentencia SU- 452 de 2024.

¹⁵³ Cfr. Corte Constitucional, Sentencia SU-086 de 1999.

¹⁵⁴ En esta oportunidad, la Corte Constitucional declaró constitucional una disposición del Decreto Ley 2037 de 2019 que desarrolla la estructura de la Contraloría General de la República. En ese caso, se concluyó que la clasificación como de libre nombramiento y remoción no contraría la regla general de carrera administrativa ni afecta los principios del mérito y transparencia, por cuanto “se enmarca en el margen de configuración normativa del legislador extraordinario y se justifica por la necesidad de dotar a la entidad de figuras de dirección con capacidad de gestión, coordinación y liderazgo estratégico.”

100. Lo anterior le permite a la Corte concluir que el principio constitucional del mérito es un elemento fundamental para el ejercicio de la función pública¹⁵⁵ y que “*constituye una piedra angular sobre la cual se funda el sistema de carrera administrativa.*”¹⁵⁶ Y que “*la implementación de un sistema de burocracia basado en el mérito y la igualdad de oportunidades contribuye a la consolidación de la democracia en el marco de un Estado social de derecho.*”¹⁵⁷

101. Ahora bien, la Constitución de 1991 definió la carrera administrativa como el mecanismo general y preferente para el ingreso al servicio público¹⁵⁸ y al hacerlo, precisó las siguientes reglas:

*(i) los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera; (ii) se exceptúan de ello los cargos de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de los trabajadores oficiales y los demás que determine la ley; (iii) para el caso de los cargos en que ni la Constitución ni la ley haya fijado el sistema de nombramiento, este se realizará mediante concurso público; (iv) el ingreso y ascenso en los cargos de carrera, se harán previo cumplimiento de los requisitos que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes; y (v) en ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento, ascenso o remoción en un empleo de carrera.*¹⁵⁹

102. La Corte Constitucional ha exaltado la importancia de la carrera administrativa en la realización de los fines del Estado¹⁶⁰ y de la función administrativa; esta última, bajo parámetros de eficacia y eficiencia y bajo las pautas de moralidad, imparcialidad y transparencia,¹⁶¹ así como en la garantía de los derechos fundamentales de participación, de las posiciones de los trabajadores y del derecho a la igualdad, tanto en el trato como en las oportunidades.¹⁶²

El concurso de méritos y el uso de las listas de elegibles

103. La jurisprudencia constitucional ha reiterado de forma pacífica que, en los sistemas de carrera administrativa, el concurso de méritos se erige como la

¹⁵⁵ Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-387 de 2023.

¹⁵⁶ Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-673 de 2015, C-534 de 2016, C-645 de 2017, SU-067 de 2022 y SU-452 de 2024.

¹⁵⁷ Cfr. Corte Constitucional. Sentencia SU-917 de 2017, reiterada en la Sentencia SU-452 de 2024.

¹⁵⁸ Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-040 de 1995, C-588 de 2009, C-553 de 2010, entre otras.

¹⁵⁹ Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-553 de 2010, reiterada en las sentencias SU-539 de 2012, C-85 de 2015 y C-371 de 2019. Recientemente, en la Sentencia C- 069 de 2025, la Corte Constitucional al pronunciarse sobre los cargos de libre nombramiento y remoción en la Contraloría General de la República, reiteró que la Corte ha sostenido que, si bien, una de las modalidades de empleo público es la de libre nombramiento y remoción, esta es excepcional, ya que, por regla general, “[l]os empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera” (apartado primero del inciso primero del artículo 125 de la Carta), y estos, los empleos de carrera, en el caso de la CGR, deben ser provistos ‘mediante concurso público’ (artículo 268.10 de la Constitución).”

¹⁶⁰ Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-631 de 1996, C-954 de 2001, C-645 de 2016, C-371 de 2019, entre otras.

¹⁶¹ Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-588 de 2009, C-249 de 2012, C-102 de 2022 y C-387 de 2023.

¹⁶² Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-102 de 2022 y C-387 de 2023.

herramienta más idónea para su concreción. Ello, salvo que la Constitución o la ley dispongan lo contrario. En la **Sentencia T-256 de 1996**, la Corte definió el concurso público como un procedimiento complejo, frente al cual la administración señala de forma clara las bases y normas en virtud de las cuales se seleccionarán las personas que, por razón de sus méritos y calidades, adquieren el derecho a ser nombradas en un cargo público.¹⁶³ A su turno, sostuvo que sirve de instrumento para que, bajo parámetros objetivos, no discriminatorios, transparentes y claros, se garantice la selección de las personas mejor cualificadas.¹⁶⁴ Así, por conducto de los concursos, se determina la idoneidad, capacidad y aptitud de los aspirantes, teniendo en cuenta la categoría del empleo y las necesidades de la entidad que lo oferta. Por lo anterior, cada una de las etapas y pruebas que se aplican durante el concurso deben estar dirigidas a identificar “*las cualidades, calidades y competencias de los candidatos, para –con base en dichos resultados– designar a quien mayor mérito tiene para ocupar el cargo.*”¹⁶⁵

104. En este sentido, en la **Sentencia C-588 de 2009**, la Corte precisó:

“Así pues, el sistema de concurso ‘como regla general regula el ingreso y el ascenso’ dentro de la carrera¹⁶⁶ y, por ello, ‘el proceso de selección entero se dirige a comprobar las calidades académicas, la experiencia y las competencias requeridas para el desempeño de los empleos’, pues solo de esta manera se da cumplimiento al precepto superior conforme al cual ‘el ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes’¹⁶⁷.

El concurso es así un instrumento que garantiza la selección fundada en la evaluación y la determinación de la capacidad e idoneidad del aspirante para desempeñar las funciones y asumir las responsabilidades propias de un cargo, e impide que prevalezca la arbitrariedad del nominador y que, en lugar del mérito, favorezca criterios ‘subjetivos e irrazonables, tales como la filiación política del aspirante, su lugar de origen (...), motivos ocultos, preferencias personales, animadversión o criterios tales como el sexo, la raza, el origen nacional o familiar, la lengua, la religión, o la opinión pública o filosófica, para descalificar al aspirante’¹⁶⁸.”

105. En lo que se refiere a la estructura del concurso de méritos, éste debe desarrollar las siguientes etapas¹⁶⁹ convocatoria, reclutamiento, pruebas, lista de

¹⁶³ En igual sentido fue definido en las sentencias T-380 de 1998, SU-067 de 2022

¹⁶⁴ Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-172 de 2021 y C-102 de 2022.

¹⁶⁵ Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C- 387 de 2023.

¹⁶⁶ Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-349 de 2004.

¹⁶⁷ Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-1122 de 2005.

¹⁶⁸ Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-211 de 2007.

¹⁶⁹ Las fases mencionadas fueron recogidas en el artículo 31 de la Ley 909 de 2004.

elegibles y periodo de prueba.¹⁷⁰ Sobre la cuarta etapa, esto es, la lista de elegibles, en la **Sentencia C-040 de 1995** la Corte explicó que *[c]on los resultados de las pruebas...se elaborará en estricto orden de mérito la lista de elegibles que tendrá una vigencia de dos (2) años. Con ésta y en estricto orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso.*¹⁷¹

106. Para la realización de los concursos de mérito, las autoridades responsables deben señalar de forma clara las bases y condiciones a partir de las cuales se seleccionará a las personas que ocuparán los cargos. Así, las reglas que los rigen son de obligatorio cumplimiento.

107. En similar sentido, en la **Sentencia C-084 de 2018**, esta Corporación estableció que *“deben respetarse de principio a fin, tanto por sus destinatarios como por la administración, lo que incluye obviamente la actividad a cargo del Legislador, sin que resulte válido proceder a modificar o cambiar sus bases o los efectos que de él derivan, pues ello equivaldría no solo a un desconocimiento de la confianza legítima, sino de múltiples derechos y principios de raigambre constitucional, como ocurre con los principios de transparencia, publicidad, buena fe, moralidad e imparcialidad, y los derechos a la igualdad, al debido proceso y al trabajo.”*

108. Como se dijo con anterioridad, surtidas las etapas de convocatoria, reclutamiento y pruebas, corresponde a la administración conformar la lista de elegibles que permitirá proveer los cargos ofertados. Las listas de elegibles son actos administrativos de contenido particular, que tienen por finalidad establecer la forma de provisión de los cargos objeto de concurso; para ello, organizan en estricto orden descendiente los nombres de las personas que deben ser designadas por haber obtenido los mejores resultados en las pruebas de selección del concurso de méritos.¹⁷² La Corte Constitucional ha hecho especial énfasis en que, durante su vigencia, el uso de las listas de elegibles para la provisión de cargos es vinculante para la administración.

109. La jurisprudencia constitucional también ha señalado que la lista de elegibles tiene una vocación temporal, por dos razones. La primera, porque el registro de elegibles le impone a la administración el deber de hacer uso de dicha lista para proveer las vacantes ofertadas. La segunda, porque *“mientras esté vigente ese acto, la entidad correspondiente no podrá realizar concurso para proveer las plazas a las que él se refiere, hasta tanto no se agoten las vacantes que fueron ofertadas, de forma que se satisfagan no solo los derechos subjetivos de quienes hacen parte de este acto administrativo sino principios esenciales de la organización estatal como el mérito para ocupar cargos públicos y los específicos del artículo 209*

¹⁷⁰ Ley 909 de 2004, artículo 31.

¹⁷¹ Esta descripción fue reiterada en las sentencias SU-913 de 2009, SU-446 de 2011 y C-084 de 2018.

¹⁷² Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-040 de 1995, SU-446 de 2011 y C-331 de 2022, entre otras.

constitucional.”¹⁷³ En ese sentido, ha explicado que con independencia del tipo de sistema de carrera, el uso de las listas de elegibles es obligatorio, pues de él se deriva la preservación del principio del mérito en la provisión de cargos públicos, de la igualdad, de la eficacia, de la economía, de la celeridad y de la imparcialidad que rigen la administración pública. Igualmente, ha dicho que no puede quedar al arbitrio del nominador el nombramiento, pues aquel debe obedecer siempre a quien haya obtenido el mayor número de puntos.¹⁷⁴

110. Ahora, la evolución normativa -y con ella la jurisprudencial- han variado respecto al carácter vinculante de las listas de elegibles. El numeral 4 del artículo 6 de la Ley 1960 de 2019¹⁷⁵ varió parcialmente la regla de utilización de las listas que traía el numeral 4 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, en el sentido de que con la utilización de las listas, también se pueden proveer vacantes definitivas de cargos equivalentes a los que salieron a concurso, aunque no hayan sido convocados y que surjan con posterioridad a la convocatoria del concurso de la misma entidad. Ello, en contraposición a la regla de que la lista de elegibles solo podía utilizarse para proveer las vacantes *“para las cuales se efectuó el concurso.”*

111. Así mismo, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el nominador está obligado a usar las listas para cubrir las vacantes que correspondan al mismo empleo en términos de denominación, grado, código, funciones, propósitos y asignación básica. Incluso, en los sistemas especiales de carrera, la Corte también ha reconocido que el Legislador puede estipular que las listas de elegibles se utilicen para proveer cargos diferentes a los ofertados en la convocatoria, *“siempre que ambos tipos de empleos compartan la misma naturaleza, perfil y denominación”*.¹⁷⁶

112. En sentido similar, lo dijo en la **Sentencia C-319 de 2010**, en donde declaró la exequibilidad condicionada del artículo 45 de la Ley 201 de 1995 que facultaba al Defensor del Pueblo a usar la lista de elegibles para *“proveer vacantes de grado igual o inferior, correspondientes a la misma denominación.”* En esa oportunidad, la Corte sostuvo que la palabra *“podrá”* contenida en la norma estudiada era constitucional *“en el entendido de que cuando se trate de proveer una vacante de grado igual, correspondiente a la misma denominación, el empleo de la lista de elegibles es un deber y no una facultad del nominador.”*

113. A su turno, en la **Sentencia C-331 de 2022**, la Corte declaró la inexequibilidad de las expresiones *“Siempre y cuando la convocatoria así lo prevea”* y *“podrá”*, contenidas en el inciso segundo del artículo 34 del Decreto Ley 071 de 2020,¹⁷⁷ y en

¹⁷³ Cfr. Corte Constitucional, Sentencia SU-446 de 2011.

¹⁷⁴ Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-040 de 1995.

¹⁷⁵ *“Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 1567 de 1998 y se dictan otras disposiciones.”*

¹⁷⁶ Cfr. Corte Constitucional, SU-446 de 2011.

¹⁷⁷ El artículo 34, decía así: *“Uso de lista de elegibles. Una vez provistos los empleos objeto del concurso, la lista de elegibles tendrá una vigencia de dos (2) años, contado a partir de la firmeza de dicha lista. Siempre y cuando la convocatoria así lo prevea, la lista de elegibles podrá ser utilizada en estricto orden descendente para proveer única y exclusivamente las vacantes que pudieren presentarse en los empleos que fueron ofertados como consecuencia del*

su lugar, pronunció una sentencia integradora sustitutiva a fin de sustituir esta última palabra por el vocablo “*deberá*”. En consecuencia, la lectura del acápite demandado sería: “[l]a lista de elegibles *deberá ser utilizada en estricto orden descendente para proveer única y exclusivamente las vacantes que pudieren presentarse en los empleos que fueron ofertados como consecuencia del retiro del servicio del titular.*”

114. En aquella oportunidad, además de reiterar el carácter vinculante de las listas de elegibles de cualquier sistema de carrera, agregó que su conformación genera un derecho subjetivo en cabeza de las personas inscritas, cuya consolidación está determinada por el lugar que ocupó en la lista y el número de plazas a proveer.¹⁷⁸ Es decir, que las personas que ocupan los primeros lugares del concurso tienen derecho a ser nombrados en periodo de prueba en los cargos ofertados cuando los mismos estén vacantes.¹⁷⁹ Por el contrario, quienes conformen la lista, pero no alcancen a ocupar las primeras plazas, solo tienen una mera expectativa de ser nombrados en el cargo, pues el derecho al nombramiento solamente se consolida cuando se acredita que “(a) la persona participó en un concurso de méritos; ([b]) que el nombre fue incluido en la lista de elegibles y (c) que existe una vacante para ser designado.”¹⁸⁰

115. En ese caso, la Corte Constitucional concluyó que el vocablo “*podrá*” contenido en la norma demandada vulneraba el principio del mérito porque facultaba al nominador a proveer vacantes sin tener en cuenta el orden descendiente dispuesto por las listas de elegibles. A juicio de la Sala, el principio del mérito limita la facultad de regulación del Legislador porque obliga a que la provisión definitiva de empleos públicos se realice a partir de los resultados obtenidos en un concurso de méritos, de manera que sean los candidatos más capacitados y meritorios los que ocupen esas plazas. En consecuencia, el uso de las listas de elegibles es vinculante, pues es allí donde se inscriben y organizan, por orden de méritos, los concursantes que aprobaron las pruebas del concurso y obtuvieron las mejores calificaciones. Además, sostuvo, el carácter obligatorio de las listas de elegibles garantiza los derechos subjetivos de los aspirantes más meritorios del proceso de selección.

116. A su vez, en lo que respecta al acápite “[s]iempre y cuando la convocatoria así lo prevea,” sostuvo que también vulnera el principio del mérito, así como el uso eficiente de recursos públicos y humanos. Pues bien, en un contexto en que la organización de concursos de mérito implica una importante inversión de tiempo y dinero, la solución que mejor garantiza el uso de recursos públicos es la utilización de la lista de elegibles para cubrir las vacantes definitivas sobrevinientes que se presenten en los cargos originalmente convocados. Máxime, en una carrera administrativa como la de la DIAN, en dónde “*más de la mitad de los empleos de la DIAN están vacantes de manera definitiva.*” Asimismo, la expresión en mención

retiro del servicio del titular.”

¹⁷⁸ Cfr. Corte Constitucional, sentencias SU-913 de 2009, SU-446 de 2011, T-340 de 2020, T-081 de 2021 y C-331 de 2022.

¹⁷⁹ Cfr. Corte Constitucional, sentencias SU-446 de 2011 y C-331 de 2022.

¹⁸⁰ Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-084 de 2018 y C-331 de 2022.

también impide que las personas más meritorias sean las que ocupen esos cargos públicos, pues le da vía a la CNSC para que restrinja el uso de las listas en un contexto como el de la DIAN, en el que se requieren de funcionarios de altos niveles de competencia y especialización y en el que es más difícil encontrar talento humano altamente calificado.¹⁸¹ Por último, agregó que la declaratoria de inexequibilidad de ese fragmento garantiza el derecho al acceso a funciones públicas de los aspirantes que ocupan los primeros lugares del concurso, pues les permiten obtener vacantes definitivas que se produzcan con posterioridad a la convocatoria y que correspondan al mismo empleo que fue ofertado. Incluso, a proveer vacantes definitivas a partir de la elaboración de un nuevo concurso, una vez se termine la vigencia de la lista de elegibles anterior.

117. En conclusión, en virtud de la jurisprudencia constitucional, el uso de las listas de elegibles es obligatorio -y no facultativo- para la administración, indistintamente al tipo de sistema de carrera al que pertenezca; sean los que se gobiernan por la Ley 909 de 2004 o aquellos en que ese marco regulatorio se aplica de forma supletiva. Pues bien, en ambas circunstancias, el nominador debe utilizar las listas de elegibles vigentes para cubrir las nuevas vacantes definitivas que se produzcan con posterioridad a la convocatoria del concurso y que tengan correspondencia con el empleo que fue ofertado. Finalmente, ha dicho la jurisprudencia, la conformación de las listas de elegibles genera o un derecho subjetivo o una mera expectativa; si los aspirantes ocupan las primeras plazas ofertadas, tienen un derecho subjetivo a ser nombrados en periodo de prueba en los cargos vacantes, mientras que si no alcanzan los primeros lugares, tienen solamente una mera expectativa.

El derecho a acceder a cargos públicos en igualdad de oportunidades

118. En la Constitución Política, el precepto de igualdad se reconoce como un principio constitucional, como un valor y como un derecho, y es por ello por lo que se incluyen en ella varias prerrogativas constitucionales que lo salvaguardan. Entre ellas, el artículo 13 que garantiza la igualdad de trato, el artículo 40.7 que propende por la igualdad frente al acceso al desempeño de funciones y cargos públicos, la igualdad de oportunidades para los trabajadores protegida en virtud del artículo 53, aquella que se deriva del principio del mérito conforme al artículo 125 y la que se origina en los principios de la función pública enunciados en el artículo 209.

¹⁸¹ En esa decisión, la Corte se refirió al sistema de carrera administrativa de la DIAN, así: “cuando en la DIAN no es posible proveer una vacante definitiva por medio de alguno de los cuatro primeros órdenes de prioridad establecidos en el artículo 21.4 del Decreto Ley 071 de 2020, es necesario organizar un concurso de méritos y, mientras tanto, nombrar a una persona en encargo o, si ello no es posible, recurrir a un nombramiento en provisionalidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 22.1 del Decreto Ley 071 de 2020. Al respecto, las cifras disponibles muestran que, aunque la regla general debe ser el encargo, lo cierto es que la DIAN no cuenta con suficientes empleados escalafonados para ocupar las vacantes disponibles. Por ejemplo, en el 2020, de las 6,719 vacantes definitivas existentes, el 31% (2,131) estaba ocupado por medio de la figura del encargo, mientras que el 63% (4,237) correspondía a nombramientos en provisionalidad.”

119. Seguidamente, el derecho a la igualdad de oportunidades también encuentra sustento en el derecho internacional de los derechos humanos. Concretamente, en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,¹⁸² en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,¹⁸³ en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,¹⁸⁴ en la Observación General No. 25 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales¹⁸⁵ y en el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),¹⁸⁶ entre otras.

120. Ahora bien, esta Corporación en la **Sentencia C-319 de 2010** señaló que la igualdad de oportunidades debe ser garantizada en todos los ámbitos del servicio público, en sus facetas negativa y positiva. La primera se refiere a *“un mandato de tratamiento igualitario para todos los ciudadanos que deseen aspirar a ocupar un cargo público, sin distingo alguno por motivos de género, raza, condición social, creencia religiosa o militancia política,”* y la segunda a *“la adopción de medidas positivas frente a grupos sociales que inveteradamente han sido discriminados en términos de acceso a cargos públicos, en especial, de dirección.”*¹⁸⁷

121. Así, la Corte ha reconocido que los principios que rigen el acceso a la función pública no son incompatibles con la implementación de medidas en favor de determinado grupo poblacional, ya que en atención al artículo 13 de la Constitución, el Estado tiene el deber de promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva. Sin embargo, ha precisado que las políticas de trato diferenciado no carecen de limitaciones y por consiguiente, no pueden desconocer el principio constitucional del mérito como único criterio.¹⁸⁸

El carácter excepcional y temporal de los cargos en encargo o provisionalidad

¹⁸² “Artículo 23. Derechos Políticos

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:

a) De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; ‘...’

c) De tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”

¹⁸³ “artículo 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país...”

¹⁸⁴ “Artículo 25: Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; ‘...’

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.”

¹⁸⁵ “23. ‘...’ Para garantizar el acceso en condiciones generales de igualdad, los criterios y procedimientos para el nombramiento, ascenso, suspensión y destitución deben ser razonables y objetivos.

Podrán adoptarse medidas positivas para promover la igualdad de oportunidades en los casos apropiados a fin de que todos los ciudadanos tengan igual acceso”.

Si el acceso a la administración pública se basa en los méritos y en la igualdad de oportunidades, y si se asegura la estabilidad en el cargo, se garantizará su libertad de toda injerencia o presión política”.

¹⁸⁶ Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958

¹⁸⁷ Reiterada en la Sentencia C-503 de 2020.

¹⁸⁸ Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-472 de 1992, C-319 de 2010, C-618 de 2015, C-503 de 2020.

122. La Corte Constitucional ha sostenido que la provisión de cargos en encargo o provisionalidad no atenta contra la preservación del principio constitucional del mérito, por lo que son constitucionales, en tanto su realización logra alcanzar los fines del Estado mediante la preservación de la continuidad del servicio y además, protege los derechos de todas las personas de acceder, en igualdad de condiciones, a funciones y cargos públicos. No obstante, también ha precisado que su empleo es excepcional y que debe ceñirse al cumplimiento de ciertos condicionantes, que pasarán a explicarse a continuación.

123. Esta Corporación, en la **Sentencia C-077 de 2004**, desestimó los cargos por inconstitucionalidad en contra de unas disposiciones del Decreto Ley 262 de 2000 que modificaba la organización de la Procuraduría General de la Nación, las cuales le otorgaban facultades al Procurador General de la Nación para que hiciera nombramientos en provisionalidad de vacantes temporales o permanentes de cargos del sistema de carrera administrativa. En criterio de esta Corte, la realización del concurso público de méritos para proveer una vacante definitiva requiere un tiempo mínimo para que se lleven a cabo todas sus etapas (convocatoria, pruebas de selección y conformación de las listas). En cambio, la función pública requiere continuidad, en aras de preservar los principios del artículo 209 de la Constitución, mismos que condicionan la materialización de los fines esenciales del Estado. Es por ello, que como criterio racional y práctico, surgió la necesidad de proveer los cargos de forma *temporal y transitoria* y mientras se hace la provisión definitiva, esto es, mientras duren las situaciones administrativas o los movimientos de personal que generaron la vacancia temporal del empleo, lo cual se suple con las instituciones del nombramiento provisional de cualquier persona o mediante el encargo de empleados de carrera.¹⁸⁹

124. La Corte señaló que, con el propósito de evitar que el nombramiento provisional pierda su carácter temporal y se convierta en permanente, el Legislador debe establecer límites y condiciones para su utilización. Ello, a fin de preservar la aplicación de la carrera administrativa en la provisión de cargos públicos, lo mismo que el derecho de acceso a ellos, en igualdad de condiciones. Respecto al carácter eminentemente temporal del nombramiento provisional, la Corte dijo:

“[se] privilegia su temporalidad, a fin de impedir que los nombramientos provisionales en los cargos de carrera administrativa se prolonguen de manera indefinida y se conviertan en institución permanente, tal como lo fue en pasado cercano. En este sentido se rechazan las prórrogas injustificadas de los

¹⁸⁹ Concretamente, la Corte Constitucional dijo que “[e]n ese entendido, la hipótesis de nombramiento en provisionalidad contenida en el artículo 218 del Decreto Ley 262 de 2000 se encuentra acorde con la Constitución, debido a que es una de las formas previstas por el Legislador acorde con su amplio margen de configuración en la materia, que exceptúa la provisión de empleos mediante un concurso de méritos, a efectos de permitir la continuidad en la prestación del servicio y realizar, de esta manera, el principio de eficiencia de la función pública y garantizar el correcto funcionamiento del servicio durante el período que dura vacante el cargo, esto es, mientras se evalúa el período de prueba del funcionario ascendido.”

*nombramientos provisionales, por cuanto “la prórroga debe ser la estrictamente necesaria para que se superen las circunstancias que dieron lugar a la suspensión del concurso y, se debe proceder a reanudarlo en forma inmediata, de manera tal, que el concurso de méritos, sea el instrumento previo, idóneo y esencial, para la provisión de los cargos públicos; porque, de no ser así, se daría lugar a la aplicación de la responsabilidad disciplinaria y patrimonial, tanto de la autoridad nominadora que omita la aplicación de las normas de carrera, como de la Comisión Nacional del Servicio Civil, en el evento de que omita las funciones que la Constitución Política le ha otorgado. Por tanto, se debe garantizar ante todo, la continuidad del servicio público (...).”*¹⁹⁰

125. Seguidamente, en la **Sentencia C-753 de 2008**, la Corte declaró la exequibilidad condicionada de una disposición del Decreto Ley 091 de 2007 que autorizaba la provisión de empleos vacantes de carrera por encargo o provisionalidad en el sistema de carrera del sector defensa. En ese caso, se reiteró que en aras de preservar los principios de la función administrativa y la continuidad del servicio, se justifica la provisión temporal del empleo mediante el encargo y la provisionalidad. No obstante, reiteró que se trata de una situación temporal y la sujetó a las siguientes reglas de aplicación: “(i) en desarrollo del principio de transparencia, precisó que la estricta necesidad para proveer el cargo debe encontrarse identificada y explicada en un acto administrativo motivado y (ii) su duración no puede prologarse indefinidamente, lo que sería inconstitucional al desconocer la carrera, como regla de provisión de empleos y el derecho a la igualdad en el acceso a los empleos y funciones públicas.”¹⁹¹

126. Por último, en la **Sentencia C-503 de 2020**, el Pleno de esta Corporación estudio nuevamente la constitucionalidad de algunas disposiciones del Decreto Ley 262 de 2000, las cuales no habían sido objeto de pronunciamiento en la Sentencia C-077 de 2004. Además de reiterar la jurisprudencia constitucional sobre el carácter *excepcional y temporal* de los nombramientos provisionales, elaboró un juicio intermedio de igualdad en su intensidad *intermedia* que lo llevó a concluir que las normas acusadas no comportan un tratamiento discriminatorio injustificado en la provisión transitoria de cargos de carrera mediante encargos o nombramientos en provisionalidad por parte del Procurador General de la Nación. En ese caso, la Sala concluyó que se superó el test de razonabilidad y proporcionalidad, en razón a que; (i) se persiguió una finalidad constitucionalmente importante referida a garantizar la continuidad de las funciones que cumple la Procuraduría General de la Nación

¹⁹⁰ Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-077 de 2004, que reiteró las sentencias C-368 de 1999, C-109 de 2000 y C-793 de 2002.

¹⁹¹ En esa oportunidad -en la Sentencia C-753 de 2008- la Corte declaró la exequibilidad condicionada del inciso primero del artículo 74 del Decreto 091 de 2007 en el entendido que la provisión de cargos en provisionalidad o en encargo en la administración del sector defensa se realizará hasta cuando se provea el cargo respectivo mediante concurso público o hasta cuando se reintegre el titular del cargo, según sea el caso; así mismo deberá ser justificada mediante acto administrativo motivado, en donde se deberán exponer las razones por las cuales se considera que es estrictamente necesario dicha provisión excepcional.

durante el tiempo en que dure vacante el cargo; (ii) es conducente para la consecución de dicho objetivo, en la medida en que permite al nominador suplir la vacancia de manera expedita; y (iii) es proporcional.

127. Como fundamento de este tercer elemento, concluyó varias cosas. **Primero**, puntualizó en que el hecho de estar inscrito en el régimen de carrera de una entidad no genera como tal un *mejor derecho* que sitúe al servidor en una situación de privilegio frente al particular, cuando se está ante una necesidad de proveer transitoriamente una vacante. **Segundo**, que la posibilidad de efectuar nombramientos en cargos de carrera sin la realización previa de un concurso es constitucional, siempre que se acuda a esa figura de forma excepcional y “*no como mecanismo para eludir la obligación de proveer los cargos mediante procesos de selección objetivos e igualitarios, sino como medida para asegurar la continuidad de la función pública.*” **Tercero y último**, el decreto ley en cuestión limita *temporalmente* la facultad concedida al Procurador y reivindica la prevalencia del principio del mérito. Pues bien, tratándose de vacantes definitivas, dispone que se deberá convocar a concurso dentro de los 3 meses siguientes al nombramiento por encargo o provisionalidad y además, que el nombramiento tendrá una duración de 6 meses, prorrogables por un periodo igual y/o hasta tanto culmine el respectivo proceso de selección. Ello, ante la inminente necesidad de preservar la continuidad del servicio.

128. Por último, la jurisprudencia constitucional también ha sabido diferenciar los cargos por encargo y en provisionalidad. Al respecto, ha sostenido que si bien se trata -en ambos casos- de personas que desean ocupar transitoriamente un empleo público, los *encargos* son ocupados por empleados públicos inscritos en la carrera administrativa de la entidad, mientras que los *provisionales* son provistos por particulares que adquieren la calidad de empleados públicos en provisionalidad. La Corte Constitucional ha dicho que se trata de sujetos distintos; los empleados públicos de carrera son servidores públicos que demuestran los méritos requeridos para el ejercicio del cargo, en cambio, el nombramiento de empleados en provisionalidad es una figura excepcional en la que personas que no detentan previamente la calidad de servidores públicos y que no son seleccionados mediante concurso de méritos, aspiran a ser seleccionadas para el ejercicio transitorio de empleos de carrera y cuya estabilidad relativa depende de la provisión del cargo mediante el correspondiente concurso de méritos. En este último supuesto, no se otorgan derechos propios de carrera ni se generan expectativas indefinidas en el cargo.¹⁹²

129. En conclusión, la jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en señalar que los cargos en provisionalidad y encargo son constitucionales, porque permiten darle continuidad al servicio de la administración, y con ello, alcanzar los fines del Estado Social de Derecho y, además, preserva el derecho de acceder a cargos públicos en igualdad de condiciones. Sin embargo, el Legislador debe limitar su

¹⁹² Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-503 de 2020.

aplicación, a fin de preservar la naturaleza *excepcional* y *temporal* del nombramiento en provisionalidad y encargo, al cumplimiento de las siguientes reglas: (i) la estricta necesidad de proveer el cargo debe encontrarse identificada y explicada en un acto administrativo motivado, en procura del principio de transparencia; (ii) su duración no puede prolongarse indefinidamente, pues ello va en desmedro de la carrera administrativa y del derecho a la igualdad en el acceso a empleos y funciones públicas y (iii) su utilización se justifica siempre que no se emplee como un mecanismo para eludir la obligación de proveer cargos mediante procesos de selección objetivos e igualitarios, sino como una medida para asegurar la continuidad del servicio. Además, los cargos provistos en *encargo* o *provisionalidad* también revisten de ciertas diferencias.

(ii) Los sistemas de carrera administrativa y la carrera administrativa específica en la DIAN. Reiteración de jurisprudencia

Sistemas de carrera administrativa

130. En el ordenamiento jurídico colombiano existen tres tipos de sistemas de carrera administrativa. El primero, el sistema general, al que pertenecen la mayoría de empleos públicos, que tiene origen en el artículo 125 de la Constitución, se encuentra regulado en la Ley 909 de 2004¹⁹³ y comprende una gran parte de los empleos de la administración pública.¹⁹⁴ El segundo, que corresponde a los sistemas especiales de carrera de origen constitucional, que tiene fundamento en disposiciones de la constitución, y se ocupa de la provisión de empleos de las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional;¹⁹⁵ de la Fiscalía General de la Nación;¹⁹⁶ de la Rama Judicial;¹⁹⁷ de la Registraduría Nacional del Estado Civil;¹⁹⁸ de la Contraloría General de la República;¹⁹⁹ de la Procuraduría General de la Nación;²⁰⁰ y de los entes universitarios autónomos²⁰¹ y, finalmente, el tercero, corresponde a los sistemas específicos de carrera administrativa, que tienen origen en la facultad del legislador de someter el ejercicio de ciertas funciones institucionales a un régimen propio, cuando las particularidades de una entidad justifican la adopción de un estatuto singular²⁰² y que están sometidos a la vigilancia de la CNSC.²⁰³

¹⁹³ “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa y se dictan otras disposiciones.”

¹⁹⁴ Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-285 de 2015.

¹⁹⁵ Constitución Política, artículos 217 y 218.

¹⁹⁶ Constitución Política, artículo 253.

¹⁹⁷ Constitución Política, artículo 256.1.

¹⁹⁸ Constitución Política, artículo 266.

¹⁹⁹ Constitución Política, artículo 268.10.

²⁰⁰ Constitución Política, artículo 279.

²⁰¹ Constitución Política, artículo 69.

²⁰² Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-285 de 2015.

²⁰³ Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-285 de 2025, T-405 de 2022 y SU-452 de 2024.

131. Sobre los sistemas específicos en particular, la Corte Constitucional ha reconocido que su creación responde a las singularidades y especificidades de cada régimen, por lo que su comprensión no es la de un sistema autónomo sino derivado.²⁰⁴ Ello se debe a la necesidad de incluir un componente de flexibilidad que garantice que la carrera administrativa se ajuste a los disímiles y cambiantes circunstancias de la función pública. Máxime, teniendo en cuenta la realidad apremiante del Estado de que su aparato institucional esté conformado por personas de las más altas calidades y competencias profesionales que garantice un alto nivel de competitividad y que responda a las exigencias de capital humano propias del desarrollo del mundo científico y tecnológico.²⁰⁵

132. Ahora, la jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en sostener que estos sistemas específicos se ajustan a la Constitución y se enmarcan en las competencias del Legislador,²⁰⁶ en la medida en que respeten el interés general. Esto es, que garanticen los procesos de selección y contribuyan a la realización de los principios de la Constitución y los derechos fundamentales, entre ellos, el del mérito.²⁰⁷ En palabras de esta Corporación:

*“el establecimiento de regímenes de carreras especiales debe obedecer a criterios objetivos, razonables y racionales, en el sentido de que las particulares condiciones fácticas o materiales que los justifiquen deben ser proporcionales a las finalidades especiales de interés público social que se pretendan satisfacer, de modo tal que, con el fin de preservar el derecho a la igualdad, no se otorguen tratos diferenciados para ciertos sectores de empleados que no se encuentran plenamente justificados.”*²⁰⁸

Sistema específico de carrera administrativa de orden legal de la DIAN

133. Entre los sistemas específicos de carrera administrativa se encuentra el de la DIAN.²⁰⁹ Ello, según la determinación inicialmente prevista en el artículo 2 del Decreto 2117 de 1992,²¹⁰ normativa que fue sustituida por el Decreto ley 1072 de

²⁰⁴ Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-172 de 2021.

²⁰⁵ Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-563 de 2000, C-1262 de 2005 y C-285 de 2015.

²⁰⁶ Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-507 de 1995, C-563 de 2000, C-517 de 2002, C-963 de 2003, C-1230 de 2005 y C-753 de 2008, C-285 de 2015, entre otras.

²⁰⁷ Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-517 de 2002, C-963 de 2003, C-1230 de 2005, C-753 de 2008, C-471 de 2013 y C-285 de 2015,

²⁰⁸ Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-563 de 2000, C-567 de 2002 y C-1262 de 2005.

²⁰⁹ Ver el artículo 4 de la Ley 909 de 2004 que desarrolla los sistemas específicos de carrera administrativa y lista, entre ellos, el que regula al personal de la Unidad Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

²¹⁰ “Por el cual se fusiona la dirección de impuestos nacionales y la dirección de aduanas nacionales en la unidad administrativa especial dirección de impuestos y aduanas nacionales y se dictan disposiciones complementarias.” En su artículo 2, se establece que la DIAN es “una Unidad Administrativa Especial, constituida como una entidad de carácter técnico, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cual cuenta con regímenes especiales en materia de administración de personal, nomenclatura, clasificación, carrera administrativa especial, (...).”

1999,²¹¹ posteriormente por el Decreto ley 765 de 2005,²¹² luego por el Decreto ley 71 de 2020,²¹³ y finalmente, el Decreto Ley 937 de 2023,²¹⁴ vigente en la actualidad.

134. La jurisprudencia constitucional se ha pronunciado en reiteradas oportunidades sobre el régimen especial de carrera administrativa de la DIAN.²¹⁵ En la **Sentencia C-1262 de 2005**, esta Corporación se pronunció sobre algunas disposiciones del Decreto 765 de 2005 declarándolas inconstitucionales. Concretamente, se preguntó si la distinción entre los concursos de ascenso y concursos abiertos sugiere una regulación más restrictiva para el ingreso a la carrera administrativa, respecto al ascenso en la misma. En esa oportunidad, la Sala hizo énfasis en los principios constitucionales de los sistemas general y específicos de carrera. Concretamente, precisó que si bien los sistemas específicos de carrera se gobiernan por reglas particulares en materia de ingreso en razón a la singularidad y especificidad en las funciones que cumple la entidad donde se aplica, *“esto no puede ser interpretado en el sentido que la carrera tiene que estar regulada de tal manera que se de prioridad en la provisión de cargos a los concursantes que se encuentran vinculados a la entidad que realiza el concurso, en detrimento de los concursantes que no lo están.”*

135. A juicio de esta Corporación, con la regulación de los sistemas específicos de carrera no se autorizan procesos de selección ni acceso a la carrera con fundamento en tratamientos desiguales. Primero, porque conforme lo establece el artículo 4 de la Ley 909 de 2004, dicha regulación debe estar consagrada en leyes diferentes a las que regulan la función pública y no debe encaminarse a modificar las condiciones de igualdad de los sistemas de concursos. Segundo, porque las particularidades sobre la que reposa el sistema específico de carrera se deben reflejar, en cambio, en las pruebas o en el sistema de evaluación. En palabras de la Corte, los sistemas específicos de carrera no pueden:

“privilegiar a quienes están inscritos en la carrera, pues esto supondría que los únicos que pueden manejar con solvencia las actividades propias de las

²¹¹ “Por el cual se establece el Sistema Específico de Carrera de los servidores públicos de la contribución y se crea el Programa de Promoción e Incentivos al Desempeño de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.” Según de citó en la Sentencia C-172 de 2021, *“a esta regulación la acompañó el Decreto ley 1071 de 1999, que organizó la DIAN como una entidad con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal. Tanto éste como el Decreto ley 1072 de 1999 se expidieron por el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 79 de la Ley 488 de 1998.”*

²¹² Adoptado por el Gobierno nacional en ejercicio de las facultades conferidas por el Congreso de la República en el artículo 53.5 de la Ley 909 de 2004.

²¹³ En ejercicio del artículo 122 de la Ley 1010 de 2019. Como se aclaró en la Sentencia C-172 de 2021, *“[c]omo antecedente del Decreto ley 71 de 2020 está el Decreto ley 1144 de 2019, proferido por el Ejecutivo en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 104 de la Ley 1943 de 2018 -Ley de financiamiento. No obstante, dado que esta última se declaró inexecutable por la Corte Constitucional en la Sentencia C-481 de 2019, la validez de aquél se afectó por la figura de la inexecutable por consecuencia.”*

²¹⁴ Conforme a las facultades extraordinarias dadas al Presidente de la República en virtud del artículo 66 de la Ley 2277 de 2022.

²¹⁵ En la Sentencia C-725 de 2000, la Corte Constitucional, entre otros asuntos, declaró constitucionales las facultades extraordinarias concedidas al Presidente de la República en virtud del numeral 2 del artículo 79 de la Ley 488 de 1998 para crear la carrera administrativa de los funcionarios de la DIAN.

entidades en las que se aplica el sistema específico de carrera, son quienes están vinculadas a éstas. Lo cual es irrazonable al menos por dos razones. La primera porque resulta un juicio a priori sobre las capacidades de las personas externas a la entidad, cuyo fundamento único es ese precisamente: que son externas a la entidad. Lo que no justifica en definitiva un trato distinto ni para discriminar ni para dar una prerrogativa previa. Y la segunda porque la razón de ser del concurso es justamente determinar la solvencia de los distintos aspirantes frente a unas actividades y unos temas y establecer cuál es el mejor. Luego carece de sentido pretender determinar, antes de la realización del concurso, que unos u otros aspirantes son más aptos para desempeñar las funciones requeridas que otros, por específicas o técnicas que éstas resulten.”

136. La Corte señaló los criterios jurisprudenciales que caracterizan a los sistemas específicos de carrera, que son: (i) tanto los sistemas generales como los específicos de carrera, por mandato constitucional del artículo 130, deben ser administrativos y vigilados por la CNSC, lo que implica la unificación de criterios para la estructura de los concursos y la competencia en la operatividad de los mismos en cabeza de esa entidad; (ii) los sistemas específicos de carrera están sometidos a los principios que gobiernan los sistemas generales de carrera, por lo que no pueden rebasarlos y (iii) las regulaciones específicas en materia de ingreso, capacitación, permanencia, ascenso y retiro del personal de la entidad no pueden interpretarse en desmedro de los principios generales del sistema general de carrera, como lo son la igualdad, la imparcialidad, el mérito, entre otros. Sobre este último criterio, la Corte sostuvo que “[l]as regulaciones específicas que lo diferencian del sistema general sólo pueden ser establecidas en razón a las particularidades de la naturaleza y función de las actividades de la entidad, pero no pueden establecer una carrera diferente, ni en su estructura, ni en sus etapas, ni en los principios que inspiran su implementación.”

137. En síntesis, la Corte trajo a colación un test con elementos mínimos para determinar la conformidad o inconvincencia de las regulaciones legales de los sistemas de concursos con la Constitución -con independencia de que se trate de un sistema general o específico de carrera-. Así, los presupuestos normativos de los sistemas de carrera administrativa estarán acordes con la Constitución, sí; (i) no se establece una distinción que disponga una regulación para el ascenso en la carrera y otra más restrictiva para el ingreso a la misma; (ii) no se derivan de las normas que regulan la carrera, condiciones de desigualdad que impidan la determinación objetiva del mérito de cada concursante; (iii) no se incluyen ítems de evaluación cuya aplicación proceda sólo para algunos concursantes y no para todos; (iv) no se disponen criterios de selección que evalúen la idoneidad frente a ciertas actividades específicas o técnicas, en condiciones desiguales entre los aspirantes vinculados a la entidad y los no vinculados; y (v) si no se remite la regulación de cuestiones propias de la administración de la carrera al Ejecutivo, salvo lo correspondiente a la potestad reglamentaria general. En consecuencia, cualquier regulación normativa que contradiga alguno de los supuestos anteriores es sin duda inconstitucional.

138. En la **Sentencia T-090 de 2013**, la Corte se pronunció sobre una acción de tutela interpuesta por empleados de la DIAN en contra de la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Universidad de San Buenaventura, a quienes se les concedió una comisión de servicios en el exterior en las mismas fechas en que fueron citados para presentar las entrevistas de una convocatoria para la carrera administrativa de la DIAN. En criterio de los accionantes, se les debía dar un tratamiento especial y exceptivo con miras a obtener la reprogramación de tales pruebas. Allí, si bien la Corte declaró improcedente la acción de tutela, se pronunció sobre el criterio de igualdad de los concursantes en las convocatorias públicas de acceso a los cargos de carrera administrativa en la DIAN.

139. La Sala sostuvo que las normas de los concursos que son conocidas con suficiente antelación por todos los participantes deben aplicarse sin distinción alguna y privilegiando el principio de igualdad que conforme lo dictamina la Ley 909 de 2004, debe regir los diferentes procesos de selección, incluyendo a las convocatorias para proveer cargos de carrera administrativa en la DIAN. Por consiguiente, adujo que *"no es posible avalar una diferenciación en la aplicación de las normas del concurso por el sólo hecho de tener la condición de servidor público de una entidad estatal, pues con ello se genera un trato diferenciado que pone en plano de desigualdad injustificada a los demás participantes del concurso de méritos que no detentan dicha condición."*

140. La Corte, en la **Sentencia C-285 de 2015** se volvió a pronunciar sobre algunas de las disposiciones del Decreto 765 de 2005. Además de hacer un recuento histórico sobre la carrera administrativa en la Constitución de 1991, puntualizó en la facultad del Legislador para adoptar el sistema específico de carrera de la DIAN y sus límites constitucionales. A su turno, hizo énfasis en la función de administración y vigilancia de la CNSC, la cual le es extensiva a los sistemas específicos de carrera administrativa, en virtud de la interpretación sistemática de los artículos 125 y 130 de la Constitución y del carácter no independiente de los sistemas específicos de carrera de origen legal respecto al régimen general.

141. Por último, en la **Sentencia C-172 de 2021** la Corte declaró inexecutable algunas de las disposiciones del Decreto Ley 071 de 2022. Entre otras cuestiones, la Corte -a partir de un recuento jurisprudencial minucioso- sintetizó algunas conclusiones sobre el sistema específico de carrera administrativa de la DIAN, así: (i) la decisión del Legislador de adoptar una carrera específica en la DIAN se debe a las particularidades de la labor técnica y especializada de la entidad, lo que no es óbice para que se desconozcan preceptos constitucionales como los principios de carrera administrativa; (ii) el cuestionamiento de la idoneidad ética de los funcionarios públicos no puede desconocer el debido proceso y el principio del mérito y (iii) la competencia de administración del sistema recae sobre la CNSC, en virtud del artículo 130 de la Constitución, entre otras.

142. En suma, el sistema específico de carrera administrativa de la DIAN: (i) está sujeto a la administración y vigilancia de la CNSC; (ii) las regulaciones específicas para el ingreso, capacitación, permanencia, ascenso y retiro del sistema responden a las necesidades técnicas y especializadas de la entidad; no obstante, deben interpretarse a la luz de los principios que gobiernan los sistemas generales de carrera administrativa, entre los que se encuentran la igualdad, la imparcialidad y el mérito, entre otros; y, (iii) existen unos elementos mínimos para determinar la conformidad de las regulaciones especiales de los sistemas de concursos de carrera con la Constitución, por lo que si alguno se desvirtúa, la regulación es inconstitucional.

Contenido y alcance del Decreto Ley 927 de 2023; normativa vigente que regula la carrera administrativa de la DIAN

143. El Decreto Ley 927 de 2023 modificó el sistema específico de carrera de los empleados públicos de la Unidad Administrativa de la DIAN y reguló la administración y gestión de su talento humano, por lo que derogó en su totalidad el Decreto Ley 071 de 2020.²¹⁶ En las consideraciones del decreto, el Gobierno explicó que se le concedieron facultades extraordinarias para fortalecer institucionalmente la entidad, y que así, cuente con los medios idóneos para la recaudación, fiscalización, liquidación y la gestión de obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias.

144. En ese marco regulatorio, se trazaron los principios que orientan el sistema específico de carrera de la DIAN, entre los que se encuentran, el mérito, la igualdad, la especialidad, la libre concurrencia en el ingreso, ascenso y movilidad en los cargos de carrera y la eficacia y eficiencia en la manera de organizar los empleos públicos, de tal manera que los perfiles profesionales se adecúen a las funciones y competencias de la entidad.²¹⁷ Sobre la oferta de empleos públicos, dentro de los cuales están los cargos en vacancia definitiva que están provistos temporalmente en encargo o provisionalidad, el decreto estableció que deben ser provistos mediante concurso de méritos.²¹⁸

145. El Decreto Ley 927 de 2023 también estableció la prioridad y formas de proveer las vacantes definitivas y temporales para los empleos de carrera administrativa. De una parte, dispuso que la provisión definitiva de empleos de carrera se efectuará en el siguiente orden:

“24.1 Con la persona que al momento de su retiro acreditaba derechos de carrera y cuyo reintegro haya sido ordenado por autoridad judicial.

²¹⁶ En ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere el artículo 66 de la Ley 2277 del 13 de diciembre de 2022.

²¹⁷ Artículo 2. “Principios que orientan el Sistema Específico de Carrera Administrativa de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN.”

²¹⁸ Artículo 21. “Oferta de empleo público.”

24. 2 Por traslado del empleado con derechos de carrera que demuestre su condición de desplazado por razones de violencia, una vez impartida la orden por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

24. 3 Con la persona de carrera administrativa a la cual se le haya suprimido el cargo y que hubiera optado por el derecho preferencial a ser reincorporado a empleos iguales o equivalentes.

24.4 Con la persona que haya renunciado con posibilidad de reingreso.

24.5 Con la persona que al momento en que deba producirse el nombramiento ocupe el primer puesto en la lista de elegibles vigente para el empleo respectivo.

24. 6 En estricto orden de mérito, con la utilización de la lista de elegibles si la vacancia se generó después de publicada la convocatoria del correspondiente concurso, siempre y cuando el empleo exija los mismos requisitos de ingreso y tenga funciones iguales o equivalentes.”²¹⁹ (Subrayado fuera del texto original).

146. De otra, sostuvo que las vacancias definitivas y temporales de los empleos de carrera administrativa se proveerán así: (i) las vacancias definitivas se proveerán mediante concurso de méritos y mientras sean provistas, serán ocupadas en encargo y cuando ello no sea posible, de nombramiento provisional y (ii) las vacancias temporales -que se presentan cuando el titular del empleo público se encuentra en una situación administrativa que implique la separación temporal del mismo- se proveerán por medio de encargo, y cuando ello no sea posible, en nombramiento provisional.

147. El decreto especificó las reglas aplicables a los cargos ocupados en encargo y/o en nombramiento provisional. Frente al **encargo**, precisó que serán encargados por el término de la vacancia temporal o hasta que se provea de forma definitiva el empleo, los empleados públicos de carrera administrativa que acrediten los requisitos de desempeño y que no hayan sido sancionados disciplinariamente en el último año.²²⁰ La terminación anticipada del encargo se hará cuando;

“26.1 El empleo público cuya vacancia definitiva justificó el encargo, es provisto mediante concurso de méritos.

26.2 Finaliza la situación administrativa que dio lugar a la vacancia temporal.

²¹⁹ Artículo 24. “Prioridad para la provisión definitiva de los empleos de carrera administrativa.” (...) “PARÁGRAFO. Si agotadas las anteriores opciones no fuere posible la provisión del empleo deberá realizarse proceso de selección.”

²²⁰ Artículo 25. “Formas de proveer los empleos de carrera administrativa.”

26.3 El resultado del proceso de evaluación del desempeño denota un insuficiente desempeño de las funciones asignadas.

26.4 Cuando se presente alguna de las causales de desvinculación previstas en el presente Decreto -Ley.”²²¹ (Subrayado fuera del texto original).

148. En lo que se refiere al **nombramiento en provisionalidad**,²²² éste busca que una persona cubra de forma transitoria un empleo de carrera en vacancia temporal -o de manera excepcional vacantes definitivas- con personal que no fue seleccionado mediante el sistema del mérito. La duración del nombramiento será por el término de la vacancia y éste procederá únicamente ante la inexistencia de empleados públicos de carrera que puedan proveer el encargo, cumplidos una serie de supuestos. Asimismo, se dijo que para el nombramiento en provisionalidad se realizará un proceso de selección que valore objetivamente las capacidades y competencias y que se podrá hacer uso de las listas de elegibles vigentes del sistema específico de carrera administrativa de la DIAN, siempre y cuando el empleo exija los mismos requisitos de ingreso y tenga funciones iguales o equivalentes y sin afectar la posición de la lista para la provisión de las vacantes definitivas.²²³ Por último, el nombramiento en provisionalidad se dará por finalizado si se constata alguno de los siguientes supuestos:

“27.1 El empleo público cuya vacancia definitiva justificó la provisionalidad, es provisto mediante concurso de méritos.

27.2 Finaliza la situación administrativa que dio lugar a la vacancia temporal.

27.3 El resultado del proceso de seguimiento laboral denota un inadecuado desempeño de las funciones asignadas. (...)

27.4 Cuando se presente alguna de las causales de desvinculación previstas en el presente decreto.”²²⁴

149. Por último, el Decreto Ley 927 de 2023 dispuso las reglas de ingreso y ascenso a los cargos del sistema específico de carrera.²²⁵ Entre ellas, se encuentra el artículo 36 que regula el uso de las listas de elegibles. Esta disposición incluye varios

²²¹ Artículo 26 “Terminación anticipada del encargo.”

²²² De acuerdo con el artículo 23.3 del Decreto Ley 927 de 2023, el nombramiento en provisionalidad “[e]s aquel que se hace a una persona para proveer de manera transitoria, un empleo de carrera con personal no seleccionado mediante el sistema de mérito y siempre que no hubiese sido posible el encargo.”

²²³ Ídem. El nombramiento en provisionalidad procederá ante la inexistencia del encargo, cumplidas cualquiera de las siguientes circunstancias: “i) No se cumplen los requisitos para el desempeño de los empleos a proveer. ii) Se ha renunciado o no se ha aceptado un encargo en el último año de manera injustificada. iii) Se está desempeñando un empleo en calidad de encargo sin que se haya superado el año en esta situación administrativa. iv) Habiéndose ofertado internamente los empleos a proveer, los empleados públicos de carrera que cumplan los requisitos para el cargo, en el plazo concedido, no manifiestan interés en ser encargados.”

²²⁴ Artículo 27.

²²⁵ Capítulo V. “Ingreso y ascenso a los cargos, y movilidad en el sistema específico de carrera administrativa.”

elementos que se explicarán a continuación; (i) la vigencia de las listas de elegibles tendrá una duración de un año, contado a partir de su firmeza; (ii) la lista de elegibles deberá utilizarse en estricto orden descendiente para vacantes generadas con posterioridad a la convocatoria, siempre que los requisitos del empleo sean los mismos y sus funciones iguales o equivalentes; (iii) los supuestos de exclusión de la lista de elegibles; (iv) el deber de permanencia de los empleados públicos que superen el periodo de prueba y (v) una medida transitoria, a fin de darle uso a las listas de elegibles resultantes de los concursos realizados en virtud del párrafo transitorio del artículo 32 del Decreto Ley 071 de 2020.²²⁶

150. Esta medida transitoria, que está contenida en el párrafo transitorio del artículo 36, quiso revivir la utilización de las listas de elegibles que resultaron de los concursos de méritos realizados en virtud del Decreto Ley 071 de 2020, los cuales correspondían a los años 2020, 2021 y 2022. Al respecto, precisó que luego de proveer los cargos en estricto orden de méritos, las listas deberán utilizarse en el término de su vigencia para ocupar vacantes generadas con posterioridad a la convocatoria o como ampliación de la planta de personal, siempre que los requisitos del empleo sean los mismos y sus funciones iguales o equivalentes. Lo anterior tenía como fin, preservar los principios de economía, sostenibilidad fiscal y austeridad del gasto. Concretamente, se refirió al proceso de selección cuyas reglas se encuentran contenidas en el Acuerdo No. CNT2022AC000008 del 29 de diciembre de 2022, el cual deberá seguir su curso con independencia de la etapa en que se encuentre. Ahora, al final del párrafo, dispuso una excepción a esa medida transitoria -que es el fragmento que se demanda en esta oportunidad- consistente en una restricción en el uso de esas listas de elegibles cuando el cargo se encuentre ocupado mediante encargo o provisionalidad. En ese caso, dijo la norma, se deberá realizar una nueva convocatoria aplicando las reglas previstas en este decreto.

(iii) El inciso tercero del párrafo transitorio del artículo 36 del Decreto Ley 927 de 2023 es contrario al principio constitucional del mérito y a los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a cargos públicos

151. La Corte Constitucional concluye que el inciso tercero del párrafo transitorio del artículo 36 del Decreto Ley 927 de 2023 es inconstitucional. Lo anterior, porque el fragmento cuestionado no superó los juicios de igualdad y proporcionalidad en su dimensión *estricta*; si bien la norma cumple una finalidad imperiosa y constitucionalmente importante, como lo es la de garantizar una continuidad y eficiencia del servicio que presta la DIAN y el medio empleado de restringir que se utilicen las listas de elegibles cuando el cargo está siendo provisto en encargo o provisionalidad es efectivamente conducente para la consecución del fin.,

²²⁶ Párrafo transitorio. “Para los años 2020, 2021 y 2022, se convocará a concurso para la provisión definitiva de los empleos de la planta de personal de la Entidad de forma anual.”

la medida no es necesaria, en tanto existen otras alternativas que no comprometen el principio constitucional del mérito y los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a cargos públicos. Además, es evidentemente desproporcionada porque el beneficio que otorga la medida a propósito de alcanzar la finalidad no es proporcional al impacto que ocasiona a las prerrogativas constitucionales mencionadas.

152. Para resolver el caso concreto, la Corte comenzará por hacer un breve recuento de los argumentos planteados en las demandas, del contenido del artículo 36 del Decreto Ley 927 de 2023 y de las pruebas recaudadas. Posteriormente, traerá a colación la jurisprudencia constitucional sobre el juicio de razonabilidad y proporcionalidad, así como de sus diferentes intensidades y sus supuestos de aplicación. Por último, con fundamento en ese parámetro, resolverá sobre la constitucionalidad del acápite de la norma demandada.

Recuento de las demandas, del contenido del artículo 36 del Decreto Ley 927 de 2023 y de las pruebas recaudadas en sede de constitucionalidad

153. En síntesis, las demandas que se estudian en esta oportunidad argumentan que el acápite de la norma cuestionada desconoce los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a cargos públicos en igualdad de oportunidades, así como el principio constitucional al mérito. En opinión de los actores, la restricción de utilizar las listas de elegibles cuando los cargos están provistos en encargo o provisionalidad constituye una nueva condición que no era previsible para los aspirantes, les confiere a quienes ostentan esos cargos un mayor derecho respecto al que tienen los integrantes de las listas y desnaturaliza las figuras de la provisionalidad y el encargo. Además, refirieron que la realización de un nuevo concurso de méritos va en desmedro de la correcta gestión de los recursos públicos del Estado.

154. El apartado demandado hace parte del párrafo transitorio del artículo 36 del Decreto Ley 927 de 2023, por medio del cual se modifica el Sistema Específico de Carrera de los empleados públicos de la Unidad Administrativa Especial -DIAN y la regulación de la administración y gestión de su talento humano. El artículo 36 establece los parámetros bajo los cuales se utilizará la lista de elegibles. Así, dispone que; (i) la vigencia se extiende por un año a partir del momento en que se proveen los cargos ofertados en el concurso; (ii) puede ser usada para proveer cargos generados con posterioridad a la convocatoria; (iii) se excluye al aspirante que no acepta el nombramiento o no toma posesión del cargo y, (iv) superado el periodo de prueba, el funcionario debe permanecer por lo menos dos años en el lugar donde se encuentra provisto el empleo.

155. A su turno, el párrafo transitorio se compone de las siguientes prerrogativas normativas; (i) las listas elaboradas como resultado de los concursos realizados con ocasión del artículo 23 del Decreto Ley 071 de 2020 deben ser usadas para proveer

las vacantes generadas con posterioridad a la convocatoria y para ampliar la planta de personal; (ii) el proceso derivado del Acuerdo No. CNT2022AC000008 del 29 de diciembre de 2022 continuará su curso y la lista que se produzca como resultado debe ser usada para proveer los cargos que se generen por la ampliación de personal; (iii) las listas a las que se refiere el párrafo transitorio “*no podrán utilizarse si el empleo público se encuentra provisto mediante encargo o provisionalidad*” y por último, (iv) esos cargos frente a los que no se pueden usar las listas, deben ser ofertados en un nuevo concurso, siendo las últimas dos prerrogativas las demandadas en esta oportunidad.

156. Ahora bien, en los documentos allegados al expediente, la Corte constató que para la DIAN, la restricción sobre el uso de las listas de elegibles para proveer cargos que así estén en vacancia *definitiva*, los ocupan funcionarios en encargo o en nombramiento provisional, se justifica porque: (i) es una medida que permite un tránsito legislativo entre el Decreto Ley 071 de 2020 y el Decreto Ley 927 de 2023; (ii) tiene por objetivo ampliar la vigencia de la listas de elegibles, evitar que pierdan fuerza ejecutoria y puedan ser utilizadas para proveer empleos no convocados; (iii) la especialidad de su régimen, además de que obedece a su misionalidad, “*implica la adquisición de competencias y conocimientos en el desarrollo mismo de la función, por lo que la medida transitoria favorece que se gestione el conocimiento al interior de la entidad y que no se afecten los servicios esenciales prestados por la DIAN*” y (iv) es una medida transitoria, pues la disposición establece que frente a los cargos en los que no se puede hacer uso de la lista de elegibles se debe convocar a un nuevo concurso.²²⁷

157. Del recaudo probatorio se evidencia que la DIAN cuenta con **21.709** empleos de carrera administrativa, de los cuales **10.166** (46.81%) fueron creados en marzo de 2023. Además, corroboró que un alto número de esos cargos se encuentran en vacancia definitiva.²²⁸ De ellos, 7.220 fueron provistos en carrera administrativa mediante concurso de méritos; 298 están en proceso de provisión, 737 están pendientes de tomar posesión y 3.134 están pendientes de ser provistos en periodo de prueba.

158. Del número de cargos en *vacancia definitiva* sin proveer, la Sala identificó tres datos diferentes. El primero es de 10.320, el cual fue suministrado por la DIAN el 9 de septiembre de 2024, sin indicar la fecha de corte,²²⁹ el segundo es de 15.350 vacantes, obtenido del Plan Estratégico de Talento Humano 2024, con corte a 31 de

²²⁷ Expediente digital D-15.948 AC contenido en *Siicor*, documento del 9 de septiembre de 2024 que contiene la respuesta a las pruebas solicitadas por parte de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), p. 3 y 4.

²²⁸ Expediente digital D-15.948 AC contenido en *Siicor*, documento del 9 de septiembre de 2024 que contiene la respuesta a las pruebas solicitadas por parte de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), p. 4 y 5.

²²⁹ Expediente digital D-15.948 AC contenido en *Siicor*, documento del 9 de septiembre de 2024 que contiene la respuesta a las pruebas solicitadas por parte de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), p. 16.

diciembre de 2023²³⁰ y un tercero de 14.354 cargos, reportados en el documento “concurso 2024” presentado a la Mesa de Revisión Sindical por la Subdirección de Gestión de Empleo Público, el 5 y 6 de agosto de 2024.²³¹ La Sala observa que la variación en los datos allegados pudo deberse al momento en que fueron consolidados. No obstante, en tanto las tres cifras provienen de información suministrada por la DIAN, para efectos de esta providencia, se utilizarán los datos contenidos en el último documento referido que fue presentado a la Mesa de Revisión Sindical, en tanto por su fecha de elaboración, es el que de acuerdo con la fecha de corte contiene la información más actualizada. Ello implica que para agosto de 2024, el 65,43% de los cargos de la DIAN se encontraban en *vacancia definitiva*.

159. En el mismo documento entregado a la Mesa de Revisión Sindical, se informó que de los cargos en *vacancia definitiva*, 8.595 cargos no habían sido provistos, 4.320 habían sido ocupados en provisionalidad y 1.439 mediante encargo.²³² Ello implica que 5.759 empleos -que resultan de la sumatoria de las dos cifras anteriores- equivalentes al 26,52% de los cargos de carrera administrativa de la DIAN, son ocupados de forma transitoria, entre tanto se producen los nombramientos como resultado del concurso de méritos.

160. En cuanto a los procesos de provisión adelantados en el marco del Decreto Ley 071 de 2022, se conoció que a septiembre de 2024, se habían adelantado 3 procesos. Entre ellos, el Proceso de selección DIAN 2497 de 2022²³³ -que dio como resultado la lista de elegibles que aún no se ha agotado-²³⁴ ofertó 1.410 vacantes en la modalidad de ascenso y 3.290 en la modalidad de ingreso.²³⁵ La DIAN indicó que como resultado de ese proceso, 737 cargos estaban a la espera de la posesión y 3.134 estaban pendientes de ser provistos en periodo de prueba²³⁶. Además, agregó que estimaba usar esas listas para la provisión de 1.600 cargos.²³⁷ En suma, la Sala concluye que si del total de cargos ofertados en la modalidad de ingreso (3.290), se restan aquellos en los que ya se efectuó el nombramiento y se está a la espera de la

²³⁰ Expediente digital D-15.948 AC contenido en *Siicor*, documento del 17 de septiembre de 2024 que contiene la intervención de Luis Fernando Lozada Elizalde, p. 12.

²³¹ Expediente digital D-15.948 AC contenido en *Siicor*, documento del 17 de septiembre de 2024 que contiene la intervención de Luis Fernando Lozada Elizalde, p. 44.

²³² Expediente digital D-15.948 AC contenido en *Siicor*, documento del 17 de septiembre de 2024 que contiene la intervención de Luis Fernando Lozada Elizalde, p. 44.

²³³ *Ídem*.

²³⁴ Expediente digital D-15.948 AC contenido en *Siicor*, documento del 9 de septiembre de 2024 que contiene la respuesta a las pruebas solicitadas por parte de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), p. 9.

²³⁵ Expediente digital D-15.948 AC contenido en *Siicor*, documento del 17 de septiembre de 2024 que contiene la intervención de Luis Fernando Lozada Elizalde, p. 13.

²³⁶ Expediente digital D-15.948 AC contenido en *Siicor*, documento del 9 de septiembre de 2024 que contiene la respuesta a las pruebas solicitadas por parte de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), p. 8.

²³⁷ Expediente digital D-15.948 AC contenido en *Siicor*, documento del 9 de septiembre de 2024 que contiene la respuesta a las pruebas solicitadas por parte de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), p. 8.

posesión (737) se obtiene que 2.553 podrían no ser provistos con las listas de elegibles constituidas con ocasión del proceso de selección DIAN 2497 de 2022.

161. Finalmente, se recaudó información sobre el costo de los procesos de selección adelantados con ocasión del Decreto Ley 071 de 2020. Respecto del proceso 2497 de 2022, la DIAN indicó que contó con un certificado de disponibilidad presupuestal de \$18.871.063.500.²³⁸ Por su parte, la CNSC reportó que aún no se había realizado cierre financiero, en tanto el proceso estaba en la etapa de elaboración de las listas de elegibles, sin embargo, señaló que la estructura de costos aprobada era del orden de los \$29.320.356.418.²³⁹ Además, uno de los intervinientes puso de presente que para este concurso se incorporó un examen médico y psicofísico que debía ser sufragado por los aspirantes para continuar en el proceso que tenía un costo por persona de \$265.000.²⁴⁰

Juicio de proporcionalidad; intensidades y supuestos de aplicación. Reiteración de jurisprudencia

162. Como quedó expuesto en párrafos anteriores, en esta oportunidad la Corte efectúa el control constitucional respecto a un apartado del parágrafo transitorio del artículo 36 del Decreto Ley 927 de 2023 que es acusado de transgredir los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al acceso a la función pública y al principio constitucional del mérito. Para realizar el análisis constitucional requerido, la Corte desarrollará un juicio de proporcionalidad en el que tendrá en cuenta todas las prerrogativas constitucionales involucradas, incluyendo el precepto contentivo de igualdad. Por ello, de forma previa, la Corte agotará el primer paso del juicio de igualdad²⁴¹ que consiste en identificar los sujetos entre los cuales se predica el tratamiento presuntamente desigual y el parámetro (*tertium comparationis*) que los hace comparables entre sí. Posteriormente, continuará con los siguientes pasos del juicio de proporcionalidad, predicables de forma transversal respecto de todas las disposiciones vulneradas.

163. En este caso, los grupos de sujetos comparables son; (i) los funcionarios provisionales y en encargo vinculados a la DIAN que se encuentran ocupando un

²³⁸ *Ídem.*

²³⁹ Expediente digital D-15.948 AC contenido en Siicor, documento del 9 de septiembre de 2024 que contiene la respuesta a las pruebas solicitadas por parte de la Comisión Nacional del Servicio civil (CNSC).

²⁴⁰ Expediente digital D-15.948 AC contenido en Siicor, documento del 17 de septiembre de 2024 que contiene la intervención de Luis Fernando Lozada Elizalde.

²⁴¹ Sobre la necesidad de realizar este juicio, en la Sentencia C-220 de 2017, la Corte indicó que “*Al ser necesario que el principio de igualdad tenga que ser concretado la jurisprudencia constitucional se ha aproximado al mandato de igualdad en la casuística, de manera que ha advertido que no existen, en la práctica, situaciones idénticas, ni supuestos absolutamente diferentes. Lo que se presenta, en cambio, son supuestos (situaciones, personas, grupos) con igualdades y desigualdades parciales, así que la tarea del juez consiste en determinar cuáles poseen mayor relevancia desde criterios normativos contenidos en el ordenamiento jurídico, para concluir si deben o no recibir el mismo tratamiento por parte del derecho. Lo anterior, ha llevado a concluir a la Corte que no todo trato diferente es reprochable desde el punto de vista constitucional, pues un trato diferente basado en razones constitucionalmente legítimas es también legítimo, y un trato diferente que no se apoye en esas razones debe considerarse discriminatorio y, por lo tanto, prohibido*”.

cargo de carrera transitoriamente, pero sobre el cual no ostentan derechos de carrera *per se* y (ii) el resto de los aspirantes externos con expectativa de poder acceder a dichos cargos por haber sido incluidos en las listas de elegibles constituidas como resultado del concurso de méritos. El parámetro de comparación radica en que ambos grupos están compuestos por personas que aspiran a acceder a empleos públicos en vacancia definitiva.

164. La Corte Constitucional reitera que el juicio de proporcionalidad es una herramienta metodológica que fundamenta la razonabilidad, predictibilidad y legitimidad de la decisión adoptada por el juez constitucional. Ello, a partir de una estructura compuesta de tres subelementos: la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto.²⁴² Esta Corporación ha denominado la estructura anterior *juicio de razonabilidad*, el cual se clasifica en tres intensidades específicas; *leve*, *intermedio* y *estricto*, cada una de ellas compuesta de unos elementos particulares.²⁴³

165. A su turno, la Corte ha referido una serie de criterios indicadores para establecer el nivel de intensidad del juicio, así: (i) el juicio *leve* se aplica cuando se analiza la razonabilidad del ejercicio legislativo en materias económicas, tributarias o de política internacional;²⁴⁴ (ii) el juicio *intermedio* opera cuando la medida interfiere con un derecho constitucional no fundamental -en su faceta prestacional progresiva- o que involucra categorías que en algunos supuestos han sido consideradas como semi sospechosas²⁴⁵ y (iii) el juicio *estricto* es aplicable cuando la cuestión impacta un derecho constitucional fundamental que sea exigible de forma inmediata en virtud de la Constitución, cuando está de por medio una categoría sospechosa en los términos del artículo 13 de la Constitución o cuando recae sobre personas en condición de debilidad manifiesta o grupos marginados o discriminados.²⁴⁶

166. A propósito del tema que convoca a la Corte en esta ocasión -una medida legislativa dirigida a garantizar la continuidad y eficiencia del servicio de la DIAN, y con ello, a preservar los principios de la función administrativa y los fines del Estado- amerita aplicar un juicio de razonabilidad y proporcionalidad en sentido ***estricto***. El juicio no es *leve*, porque si bien el Legislador cuenta con un amplio margen de

²⁴² Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-022 de 2020.

²⁴³ En la Sentencia C-673 de 2001, reiterada en las sentencias C-234 de 2019 y C-220 de 2022, se establecieron los siguientes criterios: “(i) en el test de intensidad leve -que es el ordinario- el juicio de constitucionalidad debe establecer que la finalidad y el medio sean legítimos, esto es, constitucionalmente no prohibidos; y, que el medio sea potencialmente adecuado para alcanzar el fin. (ii) En el juicio de intensidad intermedio, por su parte, el fin debe ser legítimo e importante, por promover “intereses públicos valorados por la Carta o en razón a la magnitud del problema que el legislador busca resolver”; y el medio, además de no estar prohibido, debe ser adecuado y efectivamente conducente para la consecución del fin. Y, finalmente, (iii) el test de intensidad estricta exige establecer que el fin es legítimo, importante e imperioso; y el medio, además de legítimo, debe ser adecuado, efectivamente conducente y necesario para la consecución del fin, esto es, que no puede ser reemplazado por uno menos lesivo. Adicionalmente, en estos casos, se exige adelantar un juicio de proporcionalidad en sentido estricto.”

²⁴⁴ Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-220 de 2017.

²⁴⁵ Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-673 de 2001, C-520 de 2016, C-220 de 2017, C-115 de 2017 y C-022 de 2020.

²⁴⁶ Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-520 de 2016 y C-022 de 2020.

configuración legislativa al tratarse de regímenes específicos de carrera administrativa de origen legal, lo cierto es que el mismo ordenamiento constitucional le ha impuesto unos límites que encuentran justificación en la necesidad de garantizar el derecho a acceder a cargos públicos en igualdad de oportunidades y el principio constitucional del mérito. Tampoco es *intermedio*, porque la medida no está siendo acusada de transgredir derechos no fundamentales, por el contrario, los demandantes señalan que la disposición demandada transgrede derechos constitucionales fundamentales -como lo son la igualdad, el debido proceso y el acceso igualitario a cargos y funciones públicas-, e incluso un principio constitucional axial como lo es el mérito.

167. Así las cosas, esta Corporación procederá a evaluar la constitucionalidad del inciso tercero del parágrafo transitorio del artículo 36 del Decreto Ley 927 de 2023 a partir del juicio de proporcionalidad en su intensidad *estricta*. En consecuencia, evaluará los siguientes elementos, tal como los ha clasificado y explicado la jurisprudencia constitucional; (i) que el fin de la norma acusada sea imperioso; (ii) que el medio utilizado sea efectivamente conducente (iii) que sea necesario para alcanzar dicho propósito y (iv) que la medida sea proporcional en sentido estricto.

La finalidad de garantizar la continuidad y eficiencia del servicio que presta la DIAN es imperiosa

168. La Corte Constitucional ha dispuesto unos supuestos para identificar la finalidad de la medida, y con ello, determinar si aquella persigue o no un objetivo apremiante a la luz de la Constitución. En el primero, el Legislador hace expresa la finalidad o el objetivo de la norma en el curso del proceso legislativo, bien sea en la exposición de motivos o en el curso del debate. En el segundo, en caso de que el trámite legislativo no permita establecer con certeza la finalidad que persigue la medida, ésta habrá que definirla de acuerdo con las manifestaciones generales que haya hecho el Legislador sobre los objetivos de la ley o del cuerpo normativo. En el tercero y último, si no existiere manera de identificar la disposición a partir de lo debatido en el curso legislativo o en las pruebas aportadas al expediente, el juez constitucional podrá suplir la carencia a partir de una valoración razonable del contexto de la disposición y de la finalidad que podría inspirarla.²⁴⁷

169. Aplicando las reglas referidas, la Corte encuentra que la finalidad de la medida no está contenida ni en el curso del proceso legislativo ni en las manifestaciones generales del Legislador, que para el caso del Decreto Ley 927 de 2023, era el Ejecutivo como legislador extraordinario. No obstante, la DIAN en su intervención señaló que la medida responde a las necesidades de eficiencia, estabilidad y continuidad en la prestación del servicio y a la preservación del conocimiento teórico, técnico y práctico de los funcionarios. Además, que garantiza el principio constitucional del mérito, en tanto y cuanto permite la ampliación del personal

²⁴⁷ Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-388 de 2022.

mediante la extensión de la vigencia de las listas de elegibles de los concursos llevados a cabo bajo la órbita del Decreto Ley 071 de 2020, y con ello, una estabilidad transitoria del conocimiento y de la experiencia y el cumplimiento de las metas de recaudo y sostenibilidad fiscal.

170. De esas manifestaciones, la Corte Constitucional encuentra que el párrafo transitorio del Decreto Ley 927 de 2023 trae consigo dos finalidades distintas. Una, -primera parte del párrafo transitorio-, consistente en garantizar el principio del mérito -incluyendo las reglas de obligatoriedad de las listas de elegibles- y los principios de economía, sostenibilidad fiscal y austeridad del gasto, mediante el establecimiento de una medida transitoria dirigida a darle uso a las listas de elegibles resultantes de los concursos realizados en virtud del Decreto Ley 071 de 2020, y con ello, ampliar la planta de personal de la DIAN de forma escalonada y ordenada. La otra, -inciso final del párrafo transitorio- que corresponde al fragmento demandado en esta oportunidad, buscó preservar la eficiencia, estabilidad y continuidad del servicio mediante la restricción en el uso de esas listas de elegibles cuando el cargo se encuentre ocupado mediante encargo o provisionalidad.

171. Avizorado lo anterior, la Sala encuentra que la finalidad de la medida acusada que debe analizarse en este primer elemento es la segunda, pues corresponde a la del acápite cuya constitucionalidad se analiza en este caso. Así, concluye que la finalidad es imperiosa, puesto que el propósito de garantizar la eficiencia, estabilidad y continuidad del servicio, así como la preservación del conocimiento técnico y especializado de la entidad mediante la provisión de cargos en provisionalidad o encargo, puede contribuir a dar continuidad en la prestación de los servicios por parte de la DIAN.

172. Así lo ha manifestado previamente esta Corporación. De un lado, constató que la función administrativa requiere continuidad en aras de cumplir los principios de celeridad y eficacia, así como los fines esenciales del Estado, lo que conlleva la necesidad de proveer los cargos mediante las instituciones del nombramiento en provisionalidad o encargo.²⁴⁸ A su vez, ha dicho que la finalidad de garantizar la continuidad del servicio es imperiosa, en la medida en que asegura que no existan interrupciones o alteraciones mientras se realiza la selección ordenada por la Constitución o se supera la situación administrativa que dio lugar a la vacancia.²⁴⁹

Restringir el uso de las listas de elegibles cuando el cargo está provisto en encargo o provisionalidad, es una medida efectivamente conducente

²⁴⁸ Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-077 de 2004.

²⁴⁹ Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-502 de 2020. Así mismo, en la Sentencia C-387 de 2023, la Corte Constitucional indicó que “[e]n efecto, los procesos de selección sujetos a un desarrollo gradual y en distintos tiempos, evita que se presenten cambios masivos de servidores que puedan derivar en traumatismo en la gestión de las causas jurisdiccionales a cargo de la citada entidad, lo que resulta acorde con la Constitución.” Ver también la Sentencia C-102 de 2022, misma que clasifica la finalidad de darle continuidad al servicio como constitucionalmente importante.

173. La Corte observa que la restricción en la utilización de las listas de elegibles para la provisión de cargos de carrera administrativa en vacancia *definitiva* es una medida conducente para garantizar la continuidad en la prestación del servicio de la DIAN. Así, puede afirmarse razonablemente que permitir que los trabajadores en provisionalidad o encargo continúen prestando servicios en la DIAN contribuye a garantizar la eficiencia, la estabilidad y la continuidad del servicio, así como la preservación del conocimiento técnico y especializado de la entidad, especialmente si se considera que la permanencia de los trabajadores temporales solo se mantiene hasta tanto se realice el concurso de méritos. También es plausible sostener que cualquier proceso de empalme o reemplazo para la provisión de esos cargos implica dedicar parte de las tareas asignadas a su ejecución, lo cual afecta en algún grado la continuidad y la estabilidad del servicio. Por otro lado, es claro que los funcionarios en encargo o provisionalidad han recorrido una curva de aprendizaje que permitiría, *prima facie*, garantizar que la prestación del servicio continúe de forma óptima, adecuada y diligente.

174. En consecuencia, la Sala estima que la medida analizada es efectivamente conducente para alcanzar la finalidad propuesta.

Restringir el uso de las listas de elegibles cuando el cargo está provisto en encargo o provisionalidad, no es una medida necesaria para garantizar la continuidad y eficiencia del servicio que presta la DIAN

175. La Corte concluye que la restricción en la utilización de las listas de elegibles para la provisión de cargos de carrera administrativa en vacancia *definitiva* no es una medida necesaria para garantizar que la prestación del servicio de la DIAN se dé de forma eficiente y continua. Esto, con fundamento en las razones que pasan a exponerse a continuación.

176. Si bien la Corte Constitucional comprende que la entidad quiera conservar el capital humano y la debida prestación del servicio de una forma eficiente y continua, considera que la restricción en el nombramiento de personas integrantes de las listas de elegibles en periodo de prueba y la extensión del nombramiento temporal en provisionalidad o encargo, no es la medida necesaria para alcanzar dicho fin. Como lo señaló la Universidad de Antioquia, la administración puede: (i) acudir a la realización de empalmes que eviten contratiempos en la prestación regular y eficiente de los servicios, hasta tanto se realice la adaptación definitiva y el cumplimiento de los periodos de prueba; (ii) conceder comisiones de servicio, traslados entre dependencias y utilizar la figura del supernumerario y la contratación de prestación de servicios y (iii) diferenciar entre los cargos que conllevan mayores riesgos para la continuidad y eficiencia del servicio y aquellos que no. Por último, en el caso de la DIAN, el nombramiento de quienes son retirados de los cargos, en los empleos creados por la ampliación de la planta de personal, que no han sido ofertados en concursos anteriores.

177. En suma, la Sala constata que la medida es innecesaria, en tanto y cuanto la administración cuenta con otros mecanismos que permiten dar continuidad en la prestación de los servicios de la entidad, mismos que no implican restringir los derechos fundamentales de quienes ocuparon los primeros puestos en el concurso de méritos.

La restricción de utilizar las listas de elegibles contenida en el acápite demandado es desproporcionada en sentido estricto

178. En conclusión, la restricción de utilizar las listas de elegibles cuando los cargos estén provistos en encargo o en provisionalidad es desproporcionada en sentido estricto, puesto que el beneficio que otorga la medida a propósito de alcanzar la finalidad no es proporcional al impacto que ocasiona en el principio del mérito -eje axial de la Constitución-, ni en los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a cargos públicos de los aspirantes que conforman esas listas.

179. En síntesis, la Sala Plena encontró que la norma privilegia los nombramientos en encargo o en provisionalidad, al punto de desconocer el principio del mérito, el debido proceso, el acceso a cargos públicos, y además, propiciar un tratamiento discriminatorio que beneficia a los ocupantes de cargos de forma temporal en detrimento de los derechos de quienes ocuparon los primeros puestos en las listas de elegibles originadas como resultado de un concurso de méritos. En consecuencia, la consecución de la continuidad y la eficiencia en la prestación del servicio no amerita que se desconozcan las mencionadas prerrogativas constitucionales, las cuales además de que gozan de una connotación *iusfundamental per se*, son el cimiento del principio constitucional del mérito como eje axial de la Constitución.

180. En criterio de esta Corporación, la norma es desproporcionada por las razones que pasan a exponerse a continuación.

181. Primero, la medida desestimó el eje axial del mérito como forma de proveer los cargos públicos de carrera administrativa de la DIAN, al permitir la permanencia indefinida en el empleo de quienes ejercen los cargos en provisionalidad o encargo. La Corte Constitucional observa que la medida transitoria propuesta en el acápite demandado impide la provisión de cargos en vacancia definitiva vía mérito, lo que desconoce no solamente la calidad de los aspirantes, sino también el mecanismo definido constitucional y legalmente como la regla general para proveer los cargos públicos.

182. Permitir que quienes ocupen los cargos ofertados en provisionalidad o encargo permanezcan en ellos por un tiempo indefinido, desconoce el mérito como eje axial de la Constitución, y con ello, la debida ejecución de la carrera administrativa, la realización de los fines del Estado y el ejercicio de la función pública. Hay una razón por la que la normativa que rige los sistemas generales de carrera administrativa, así como los específicos de origen legal -entre los que se encuentra el regulado por el

Decreto Ley 927 de 2023- dispone que los empleos de carrera administrativa deben ser provistos a partir de las listas de elegibles constituidas como resultado de un concurso de mérito: la de racionalizar la administración mediante la provisión de cargos públicos ocupados por funcionarios con las capacidades necesarias para ejercer las funciones que les encarga la administración. Así, al extender el empleo de de dos figuras que son de por sí excepcionales -la provisionalidad y el encargo- desconoce la Constitución, al punto de sustituirla, así como la jurisprudencia constitucional decantada en la materia.

183. La DIAN adujo que las medidas de transición como la contenida en el apartado acusado favorecen la gestión del conocimiento en la entidad y evitan que se afecten los servicios esenciales prestados. Sin embargo, lo cierto es que esta Corporación no encontró una razón objetiva que permitiera concluir que los aspirantes que ocuparon los primeros puestos en las listas de elegibles no puedan desempeñar las funciones en condiciones de continuidad y eficiencia. Máxime, cuando el propósito principal de propender por el mérito en la provisión de cargos públicos es precisamente esa; la de proveer los cargos con funcionarios capacitados para garantizar la debida prestación del servicio de la entidad en condiciones de debida diligencia, continuidad y eficiencia.

184. Como fundamento de su afirmación, la DIAN trajo a colación la Sentencia C-387 de 2023 que declaró exequible una disposición del régimen de carrera administrativa de la Fiscalía General de la Nación. Al respecto, la Corte debe señalar que esa decisión no es un precedente jurisprudencial aplicable en este caso, por varias razones. Por una parte, porque en ella se reconoció un amplio margen de configuración legislativa en la definición del alcance de las listas de elegibles, y con ello, en la gradualidad en el ingreso a la carrera. Por eso, en el caso de la carrera administrativa de la Fiscalía General de la Nación era admisible que las listas de elegibles resultantes de un proceso de selección solo fueran utilizadas para proveer vacantes definitivas inicialmente provistas en las convocatorias y no para suplir vacantes preexistentes que no fueran convocadas. En cambio, lo que hace la disposición acusada en esta oportunidad, lejos de delimitar el alcance de las listas, es restringirlo a tal punto que no permite que se utilicen para proveer los cargos que fueron ofertados en un concurso anterior; desconociendo el propósito mismo de su convocatoria.

185. Por la otra, en esa providencia se reconoció que los nombramientos en encargo y provisionalidad exigen el deber de motivar los actos administrativos de vinculación, y en virtud de las justificaciones que allí se plasmen, valorar el mérito de las personas para estar en los cargos que ocupan. Como se explicará más adelante, en el caso *sub examine* la norma general no suple la obligación de motivar, mediante un acto administrativo particular, la necesidad de proveer esos cargos mediante formas *temporales* de provisión del cargo. Tercero y último, porque se refiere a un régimen especial de carrera administrativa de otra entidad, cuyo contexto evidencia una serie

de dificultades que han impedido que su implementación sea efectiva e integral, lo que no necesariamente sucede en este caso.

186. Segundo, desconoció la jurisprudencia constitucional sobre el carácter vinculante de las listas de elegibles, así como los derechos adquiridos de quienes ocupan los primeros puestos en ellas. Tal como se expuso previamente (*supra* FJ 103 y ss), le corresponde a la administración definir las reglas que deben regir cada uno de los concursos convocados y así establecer los requisitos que deben cumplir los aspirantes que busquen ser nombrados en los cargos ofertados. De esa forma, el proceso de selección determina si quienes aspiran al cargo acreditan las condiciones y calidades específicas, así como las competencias necesarias para desempeñar el cargo. Es así como al finalizar el proceso, las listas de elegibles están integradas por las personas que demostraron durante el concurso ser las más idóneas y mejor calificadas para el ejercicio de cada uno de los cargos. Dichas reglas, ha sostenido la jurisprudencia de esta Corporación, deben respetarse de principio a fin, sin que sea aceptable modificar o cambiar las bases o los efectos del concurso.²⁵⁰

187. El principio del mérito se concreta en el momento en que los cargos se provisionan con las personas que integran la lista, en estricto orden meritocrático. Es por lo que la Corte Constitucional ha sido tan enfática en sostener que el uso de las listas de elegibles es vinculante y obligatorio para la administración, tanto para los cargos ofertados como para los iguales o equivalentes. Pues de ahí es de donde se deriva la preservación del principio del mérito en la provisión de cargos públicos. Además, el desarrollo adecuado del concurso de méritos -desde la etapa de convocatoria, hasta su finalización con el nombramiento en periodo de prueba de quienes ocupan los primeros lugares y el posterior registro en la carrera administrativa- permite materializar distintos derechos fundamentales como el debido proceso y la igualdad, específicamente respecto de las condiciones para el acceso a los cargos públicos.

188. La Sala Plena observa que contrario a lo argumentado por la DIAN, con la inclusión del apartado cuestionado se entorpeció la continuidad y la eficiencia del servicio, que se alcanzaba mediante la selección de trabajadores que, por su mérito y capacidad profesional, pudieran desempeñar sus funciones de forma diligente y eficiente. Asimismo, se desconoció el carácter vinculante y obligatorio de las listas de elegibles, pues con la restricción impuesta por el inciso demandado, se optó por no utilizarlas, y con ello, se desconoció el derecho subjetivo de quienes ocuparon el primer puesto en la lista de elegibles, así como la mera expectativa de quienes ocuparon los siguientes puestos.

189. Tercero, violó los presupuestos excepcionales y temporales exigidos por la jurisprudencia constitucional para la provisión de cargos en provisionalidad y encargo. El Legislador desconoció los parámetros que la jurisprudencia

²⁵⁰ Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-084 de 2018.

constitucional ha considerado y que constituyen un antecedente aplicable al empleo de las figuras de nombramiento en provisionalidad y encargo. Recuérdese que la Corte ha señalado que para que se garantice la continuidad en el servicio sin transgredir la Constitución, esas formas de provisión de empleo, deben: (i) estar debidamente identificados y explicados en un acto administrativo motivado; (ii) su duración no puede prolongarse indefinidamente y (iii) su empleo está justificado siempre que no se utilice como un mecanismo para eludir la obligación de no proveer los cargos mediante un proceso de selección objetivo e igualitario, sino como una medida para asegurar la continuidad del servicio.

190. La Corte no observa que el fragmento demandado provea una motivación que justifique la provisión del empleo público mediante un nombramiento en encargo o provisionalidad. Avizora todo lo contrario; que la instrucción de extender el término de provisión de los cargos proviene de una norma general y abstracta, más no de un acto administrativo concreto que determine, con suficiente fundamento, por qué cada cargo debe ser provisto bajo esa modalidad. Así, la orden legal que instruya esa restricción en el uso de las listas de elegibles no permite desarrollar el principio de transparencia, pues no evidencia con objetividad cuál es el motivo por el cual se necesitan esos nombramientos, cual es la actividad de la entidad que no puede ser interrumpida y por qué ese cargo es esencial para garantizar la continuidad y eficiencia del servicio.

191. A su turno, se evidencia que la provisión de los empleos mediante provisionalidad y encargo se extiende indefinidamente. Si bien el inciso tercero establece que esos cargos públicos serán ofertados mediante una nueva convocatoria, lo cierto es que ese suceso es incierto, futuro e indeterminado. Al respecto, la DIAN sostuvo que no es cierto que los empleos en encargo o provisionalidad se perpetuarán o que con el acápite en cuestión se les está otorgando derechos de carrera, pues el régimen de transición finalizará cuando la entidad oferte esos cargos en un nuevo concurso de méritos.

192. Al respecto, la Corte evidencia que los cargos se vienen prolongando indefinidamente y sin justificación; los empleos ya venían ocupándose en provisionalidad o encargo, no obstante, para el momento de realizarse la provisión definitiva -que daba lugar a su finalización- su provisión se extendió de forma indeterminada, pues se sujetó a un hecho que si bien normativamente se debe realizar en un año, el nombramiento en periodo de prueba de quienes ocupen los primeros lugares en la lista de elegibles tomaría más tiempo. Máxime, teniendo en cuenta que la realización de un proceso de selección suele tomar bastante tiempo.

193. Por último, la Corte concluye que el acápite demandado permite eludir la obligación de la entidad de proveer los cargos mediante las listas de elegibles originadas en un proceso de selección. Por las razones que ya se explicaron, la Sala Plena evidencia que el fragmento acusado desconoció el carácter vinculante de las listas de elegibles, a fin de darle prioridad a la efectiva y continua prestación del

servicio. Ello, ignorando que tal como se explicó arriba (*supra* FJ 176), existen otros medios más eficaces para alcanzar esa finalidad, mismos que no soslayan el deber constitucional y legal de proveer los cargos mediante un proceso de selección objetivo e igualitario, como lo es el concurso de méritos.

194. Cuarto, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso al desempeño de cargos y funciones públicas, pues además de que cambió intempestivamente las condiciones del concurso, privó a los aspirantes de la posibilidad de ocupar las vacantes. La Sala advierte que el Legislador extraordinario cambió las condiciones de los concursos de méritos que se encontraban en desarrollo al determinar que quienes ocuparan los primeros lugares de las listas de elegibles no podrían acceder a los cargos para los que concursaron, si estos estaban siendo ejercidos en provisionalidad o encargo, y en consecuencia, que solo podrían ser nombrados en los cargos equivalentes que no estuvieran provistos.

195. Lo anterior, en términos prácticos, no significa nada distinto a que durante la realización del concurso de méritos, se modificaron las reglas definidas por la administración para su desarrollo, y con ello, se vulneraron los derechos fundamentales de las personas que, en atención al concurso de méritos, ocuparon los primeros lugares de las listas de elegibles. Al privilegiar la ocupación indefinida de un cargo mediante provisionalidad o encargo hasta tanto se realice una nueva convocatoria, se vulneró el derecho fundamental al debido proceso y al acceso, en igualdad de oportunidades, al desempeño de cargos y funciones públicas, pues además de que se cambiaron intempestivamente las condiciones del concurso, se privó a los concursantes de la posibilidad de ocupar esas vacantes.

196. Quinto, se transgredió el derecho a la igualdad, en tanto y cuanto resulta irrazonable, desproporcionado y discriminatorio privilegiar la permanencia en el cargo de servidores que los ocupan de forma transitoria, en perjuicio de los aspirantes que superaron el concurso de méritos respectivo. Como se indicó anteriormente, los sistemas específicos de carrera administrativa de origen legal, como el de la DIAN, gozan de una amplia configuración legislativa; sin embargo, están sujetos a los mismos principios constitucionales y legales del sistema general de carrera administrativa, así como a la jurisprudencia constitucional. Ello implica que las normas relativas al ingreso, permanencia, ascenso y retiro del personal de la entidad no puedan interpretarse en contravía de los principios generales del sistema general de carrera, como lo son la igualdad, la imparcialidad y el mérito.²⁵¹

197. Por lo anterior, no es constitucional que en los procesos de selección de los sistemas específicos de carrera administrativa se establezcan reglas que desatiendan esas prerrogativas constitucionales. En particular, el mérito de quienes participaron en los concursos y acreditaron tener las condiciones de idoneidad para el ejercicio del

²⁵¹ Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C- 1262 de 2015. En esa oportunidad al hablar sobre la regulación de las carreras especiales, la Corte indicó que “no pueden establecer una carrera diferente, ni en su estructura, ni en sus etapas, ni en los principios que inspiran su implementación.”

cargo ofertado, a fin de privilegiar de forma injustificada la permanencia en los cargos de quienes se vincularon por virtud de un nombramiento discrecional del nominador. Este tratamiento daría lugar a pensar que quienes ocupan los cargos mediante provisionalidad o encargo son los únicos que pueden desempeñar adecuadamente las actividades de la entidad, lo cual no solamente constituye un juicio *a priori* sobre las capacidades de las personas externas a la entidad, sino también un trato discriminatorio e inconstitucional.

198. Adicionalmente, no puede perderse de vista que el proceso de selección DIAN 2022 ofertó 4.700 cargos, de los cuales 1.410 hicieron parte del concurso en la modalidad de ascenso.²⁵² Ello implica que quienes ocuparan los lugares más meritorios en el concurso cuentan con experiencia en la entidad, y por ello, con los conocimientos específicos que la DIAN pretendía conservar a partir de la restricción en el uso de las listas de elegibles contenida en el apartado acusado.

199. Sexto y último, ocasionó la destinación de recursos públicos para la realización de un concurso de méritos para ofertar vacantes, desconociendo que sobre ellas ya existen listas de elegibles vigentes. Al respecto, la Corte precisa que realizar un concurso posterior para proveer las plazas que no fueron provistas con el uso de las listas de elegibles advierte un uso ineficiente de los recursos públicos y desatiende la disciplina con la que estos deben ser manejados e invertidos. Además, un uso indebido de los recursos públicos y humanos contravía la garantía de transparencia que caracteriza la gestión pública, en tanto despliega un esfuerzo económico y humano adicional con la finalidad aparente de garantizar la continuidad y eficiencia del servicio.

200. De acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, en el proceso de selección DIAN 2022, la DIAN informó que se emitió un certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) por \$18.871.063.500 y la CNSC corroboró que su estructura de gastos correspondió a \$29.320.365.410. Teniendo en cuenta que estos recursos estaban destinados a financiar los concursos de méritos para proveer 4.700 vacantes, la Corte estima que el costo del concurso en la modalidad de ingreso por vacante ofertada puede alcanzar los \$4.015.970, si se tiene como referencia el valor del CDP o \$6.238.375 en atención a la cifra reportada por la CNSC.

201. Además, la información remitida por la CNSC da cuenta de que, para los concursos convocados en los años 2020, 2021 y 2022, se destinaron más de **\$50.000** millones de pesos. Sin embargo, de una planta de 21.937 cargos, solo 7.853, el 35% aproximadamente, se encuentran provistos por carrera administrativa o por libre nombramiento y remoción²⁵³. Es decir que, luego del esfuerzo económico para la

²⁵² Expediente digital D-15.948 AC contenido en *Siicor*, documento del 17 de septiembre de 2024 que contiene la intervención de Luis Fernando Lozada Elizalde, p.13.

²⁵³ Expediente digital D-15.948 AC contenido en *Siicor*, documento del 17 de septiembre de 2024 que contiene la intervención de Luis Fernando Lozada Elizalde, p. 44.

realización de los concursos de méritos, 14.354 empleos²⁵⁴, aproximadamente el 65% de los cargos de la planta de la DIAN, aún se encuentran en vacancia definitiva y de estos, alrededor de **5.600** cargos son ocupados por encargo o provisionalidad. Ahora, a pesar de que no se conoce el número de cargos en los cuales, en aplicación del apartado demandado, no se realizó la provisión en periodo de prueba, lo cierto es que en la modalidad de ingreso se ofertaron 3.290 vacantes, lo que da lugar a inferir que la repetición del proceso de selección genera un nuevo gasto; lo que a juicio de la Sala advierte un uso ineficiente de los recursos y desatiende la disciplina con la que deben ser manejados en invertidos los recursos públicos.

202. En suma, es palmario que el esfuerzo institucional y presupuestal que demandó la realización de los concursos, sumado al impacto real de mantener los cargos vacantes o en interinidad, muestra que la medida no es razonable y genera un retroceso injustificado, sobre todo en términos de mérito.

203. Por todo lo anterior, para la Corte resulta evidente que el impacto que la medida genera en la preservación del principio constitucional del mérito y los derechos fundamentales a la igualdad, el debido proceso y el acceso al empleo público, es desproporcionado en sentido *estricto*.

Conclusión

204. Sentado lo anterior, la Corte Constitucional declarará la inexequibilidad parcial del párrafo transitorio del artículo 36 del Decreto Ley 927 de 2023 que dice: “[e]n todo caso, las listas de elegibles a que hace referencia el presente párrafo transitorio no podrán utilizarse si el empleo público se encuentra provisto mediante encargo o provisionalidad. Estos cargos públicos deberán ser ofertados en una nueva convocatoria aplicando las reglas previstas en este Decreto-Ley.” Ello, al concluir que es contrario al principio constitucional del mérito y a los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a cargos públicos. Así, esta Corporación advierte que, como consecuencia de la declaratoria de inexequibilidad, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), a partir de la fecha, debe proveer los cargos ofertados utilizando, en estricto orden meritocrático, las listas de elegibles, que además están próximas a vencer, constituidas como resultado del concurso de méritos.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

²⁵⁴ *Ibidem*.

RESUELVE

PRIMERO. Declarar la **INEXEQUIBILIDAD** del tercer inciso del párrafo transitorio del artículo 36 del Decreto Ley 927 de 2023.

Notifíquese, comuníquese, publíquese y archívese el expediente.

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR
Presidente

NATALIA ÁNGEL CABO
Magistrada

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ
Magistrado

DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE
Magistrado
Con impedimento aceptado

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA
Magistrada

CAROLINA RAMÍREZ PÉREZ
Magistrada (e)

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado
Salvamento de voto

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ
Secretaria General

**SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
MIGUEL POLO ROSERO
A LA SENTENCIA C-197/25**

Referencia: Expediente D-15.948 y D-15.971AC

Asunto: demandas de inconstitucionalidad promovidas en contra del artículo 36 (parcial) del Decreto-Ley 927 de 2023, “[p]or el cual se modifica el Sistema Específico de Carrera de los empleados públicos de la Unidad Administrativa Especial -DIAN y la regulación de la administración y gestión de su talento humano”.

Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte Constitucional, me permito salvar mi voto en la presente decisión, por las siguientes razones. *Primero*, el análisis del asunto debió realizarse mediante un juicio de proporcionalidad intermedio, y no mediante uno estricto. De haberse optado por este enfoque, la disposición cuestionada habría sido declarada exequible. *Segundo*, incluso si se aplicara el juicio estricto, la exigencia de necesidad se acreditaba en este caso y también la proporcionalidad en sentido estricto, lo que, en cualquier circunstancia, habría hecho la norma compatible con la Constitución.

1. En cuanto a lo *primero*, en casos semejantes, como los resueltos en las sentencias C-503 de 2020, C-102 de 2022 y C-387 de 2023, la Corte aplicó un juicio de proporcionalidad de *intensidad intermedia*, para valorar los cargos propuestos en las demandas. En todos estos casos fue fundamental la consideración de que la Constitución le otorga un amplio margen de configuración al Legislador para fijar el alcance de las listas de elegibles, entre otros aspectos, referidos a la regulación de la

carrera administrativa, lo que habría dado lugar a declarar exequible la disposición demandada. A pesar de esto, la mayoría de la Sala no cumplió con la carga de exteriorizar una especial argumentación para revelar por qué los motivos por los cuales decidió no seguir el precedente e implementar un juicio de proporcionalidad estricto eran más poderosos, respecto de la obligación primigenia que tienen los jueces, incluidos los constitucionales, de preservar una misma lectura del derecho.

2. En cuanto a lo *segundo*, la disposición demandada resulta compatible con la Constitución, incluso si se le aplica un juicio de proporcionalidad de intensidad estricta. Esto es así, en tanto, como lo sostuvo la mayoría de la Sala, persigue un fin constitucional imperioso y es idónea o efectivamente conducente para lograr su satisfacción. No obstante, contrario a lo resultó en la sentencia objeto de este salvamento de voto, la medida adoptada es necesaria y proporcional en sentido estricto. Las razones que fundamentan mi postura son las siguientes.

3. La disposición demandada restringía, de manera transitoria y excepcional, el uso de las listas de elegibles derivadas de dos tipos de procesos públicos de méritos que se han adelantado en la DIAN, para cierto tipo de cargos y únicamente respecto de aquellos empleos públicos que, para la fecha de expedición del Decreto Ley 927 de 2023, se encontraban temporalmente ocupados, ya fuese por encargo o en provisionalidad.

4. La **finalidad** de esa medida, que se podía interpretar a partir del propio contenido normativo de la disposición, consistía en evitar que se usen ciertas listas (unas ya concluidas, como las derivadas del párrafo transitorio del artículo 32 del Decreto Ley 071 de 2020, y otras en proceso de consolidación, que corresponden a las que se sigan del concurso de que trata el Acuerdo CNT2022AC000008 del 29 de diciembre de 2022) para llenar plazas cuya provisión ya había sido resuelta temporalmente (aunque no en propiedad), y garantizar que se adelantara un nuevo concurso abierto y actualizado, regido por las nuevas reglas introducidas en el Decreto Ley 927 de 2023. De esta forma, en atención a ese mandato, se aseguraba una mayor transparencia y competitividad en los concursos, conforme con los nuevos criterios del sistema específico, ajustado a los fines misionales y técnicos de la DIAN, que buscan privilegiar la profesionalización, la equidad en el ingreso y la evaluación periódica de competencias, en los términos de los artículos 2, 3, 4 (en especial, su inciso segundo), 21, 24, 25, 29, 34 y 36 del decreto en mención.

5. La medida resultaba **idónea**, en tanto contribuía directamente a la finalidad de implementar de manera técnica, gradual y funcional el nuevo sistema específico de carrera de la DIAN, de tal forma que se asegurara la correspondencia entre los empleos provistos y las nuevas reglas. En efecto, la disposición acusada: (i) evitaba que los cargos ocupados temporalmente fueran provistos en propiedad mediante reglas anteriores a la reforma normativa; (ii) permitía que la provisión definitiva de dichos empleos se realizara mediante nuevos concursos, conforme con el nuevo régimen (artículos 29 y 34), lo que privilegiaba el mérito, pero bajo parámetros

actualizados y más exigentes en términos de competencias y evaluación, y (iii) impulsaba una transición institucional ordenada, en la que, como se infería de lo indicado en la intervención de la DIAN, se preservaba la planeación y la capacidad operativa de la entidad, mientras se surtían los nuevos concursos anuales, según el artículo 34 del citado decreto.

6. En este sentido, el medio elegido por el Legislador extraordinario —esto es, la restricción parcial y transitoria en el uso de las listas de elegibles— no era arbitrario o irrazonable, sino que correspondía una modulación adecuada de un instrumento de la carrera, en aras de asegurar una implementación gradual y técnica del nuevo sistema.

7. En atención al contenido normativo de la disposición acusada, se trataba de una medida **necesaria** para alcanzar el fin constitucionalmente imperioso que buscó el Legislador extraordinario. En *primer lugar*, la disposición no suprimía el uso de las listas de elegibles en general, sino que las restringía únicamente respecto de cargos que venían siendo ocupados por encargo o provisionalidad al momento de la entrada en vigor del Decreto Ley 927 de 2023, y que exigían una transición regulada hacia el nuevo régimen funcional y misional de carrera de la DIAN²⁵⁵.

8. En efecto, la disposición no restringía, *in genere*, el uso de las listas de elegibles. El párrafo transitorio permitía que las listas de elegibles producto de los concursos anteriores (las derivadas del párrafo transitorio del artículo 32 del Decreto Ley 071 de 2020, y las del concurso de que trata el Acuerdo CNT2022AC000008 del 29 de diciembre de 2022) fueran usadas para llenar vacantes posteriores a las respectivas convocatorias (durante el término de su vigencia temporal). La expresión acusada (el último inciso del párrafo transitorio del artículo 36), por su parte, restringía esta posibilidad exclusivamente respecto de empleos que estén ocupados por encargo o provisionalidad, lógicamente, al momento de la entrada en vigencia del Decreto Ley 927 de 2023. De esta forma, la disposición garantizaba que la provisión de estos empleos temporalmente cubiertos se realizara, de manera definitiva, mediante las nuevas reglas del sistema específico de carrera de la DIAN, adoptadas en el Decreto Ley 927 de 2023. Así, se garantizaba la temporalidad y subsidiariedad de esta forma de empleo, en tanto se surte el proceso definitivo por concurso de méritos, en los términos del artículo 29 de ese decreto; de allí que no consolidaran derechos de carrera.

9. En *segundo lugar*, no existía una medida menos gravosa con igual grado de idoneidad que permitiera asegurar, al mismo tiempo: (i) la continuidad del servicio, (ii) la coherencia técnica entre el ingreso definitivo y las nuevas reglas y (iii) la salvaguarda de una transición sin rupturas organizacionales. Por lo tanto, en el marco

²⁵⁵ Según indicó la DIAN en su intervención, “el régimen de transición no ha afectado la garantía de la provisión de los empleos por mérito. De una parte, en el año 2023 se proveyeron cerca de 1.900 vacantes mediante el uso de las listas de elegibles de las convocatorias 1461 de 2020 y 2238 de 2021, hasta el término de su vigencia y/o agotamiento. Por otra parte, en la presente vigencia, se está adelantando la provisión de 1.623 vacantes con el uso de las listas de elegibles de la Convocatoria 2497 de 2022, adicionales a las 4.700 vacantes ofertadas en dicha convocatoria”.

del juicio estricto propuesto por la mayoría de la Sala, se acreditaba el carácter necesario de la medida, al no existir alternativas normativas de igual idoneidad y menor impacto sobre los derechos en tensión.

10. Finalmente, la medida superaba el juicio de **proporcionalidad en sentido estricto**, ya que (i) su alcance era limitado y transitorio, (ii) no suprimía el principio del mérito ni el acceso mediante concurso y (iii) aseguraba mayores beneficios institucionales –como la continuidad del servicio, la profesionalización y la planeación organizacional, finalidades adscritas a la estructura del sistema específico de carrera de la DIAN, en los términos del Decreto Ley 927 de 2023– frente a una menor afectación respecto de las expectativas individuales de las personas que participaron de los concursos de que trata el párrafo transitorio del artículo 32 del Decreto Ley 071 de 2020, y quienes participan de la convocatoria del Acuerdo CNT2022AC000008 del 29 de diciembre de 2022.

11. En concreto, es claro que el eventual sacrificio de las expectativas (que no derechos adquiridos) de los elegibles era menor frente a las ventajas institucionales de la medida. Si bien algunas personas que integran las listas anteriores podrían verse afectadas en su expectativa de ser nombradas en ciertos cargos (al hacer parte de una lista de elegibles), la medida preservaba la integridad funcional de la entidad, evitaba rupturas en la prestación del servicio tributario y aduanero, y garantizaba la coherencia entre el nuevo modelo de carrera y el ingreso definitivo. Además, no cabía duda de que los elegibles mantenían su derecho de ser nombrados en otros cargos vacantes posteriores a la convocatoria, durante el tiempo de vigencia de la lista, conforme se dispone en el resto del párrafo transitorio del artículo 36 del Decreto Ley 927 de 2023.

12. Esta valoración era especialmente compatible con el precedente de la sentencia C-387 de 2023, en la que la Corte juzgó una medida semejante a la que se estudió en esta oportunidad, relacionada con la restricción temporal del uso de la lista de elegibles en el sistema especial de carrera de la Fiscalía General de la Nación. En la citada providencia, a la Corte le correspondió valorar “*si el inciso 3° del artículo 35 del Decreto Ley 20 de 2014, al establecer que las listas de elegibles resultantes de los procesos de selección adelantados por la Fiscalía General de la Nación solo podrán ser usadas para proveer las vacantes definitivas que se generen en los empleos inicialmente provistos por los concursos, y no para suplir vacantes preexistentes de los empleos ofertados pero que no fueron convocados, resulta contrario al derecho de acceso al desempeño de cargos y funciones públicas y al principio fundamental del mérito para el ingreso a empleos de carrera*”. La Corte declaró la exequibilidad simple de la disposición, al superar las exigencias del juicio intermedio. De manera puntual, al enjuiciar la proporcionalidad en sentido estricto de la medida, hizo referencia a los siguientes supuestos que, *mutatis mutandis*, son aplicables al caso que se analizó en la sentencia objeto de este salvamento de voto:

“... aunque los aspirantes que están en una lista de elegibles, por razón del desarrollo de los concursos, en principio, han acreditado el mérito suficiente para ocupar un cargo vacante en la entidad, no por ello se impone la obligación constitucional de que necesariamente deba asignárseles un cargo que esté en dicha condición, por fuera de los que fueron sometidos a concurso, como lo propone el accionante. Ello es así, por una parte, porque el Legislador puede determinar cuál es el alcance que tendrían las listas de elegibles en cada entidad en particular, a partir de los objetivos que se buscan con ella; y, por la otra, porque esos propósitos deben tener respaldo en fines constitucionales válidos, como ocurre, en este caso, con los mandatos de gradualidad, adaptación y continuidad (...) // Por otra parte, en las sentencias C-135 de 2018 y C-084 de ese mismo año, la Corte se pronunció sobre las listas de elegibles, y determinó que no existe un derecho adquirido a un ocupar un cargo público, por la sola circunstancia de estar incluido dentro de una de ellas, pues necesariamente se requiere de la existencia de una vacante y de que la misma sea susceptible de ser cubierta por su incorporación dentro un concurso de méritos, salvo que el Legislador disponga de una regla distinta respecto de la aplicación de la lista, como ya se ha mencionado en esta providencia. // (...) al no tratarse de un derecho absoluto, la posibilidad de ingreso a un cargo depende no solo de las exigencias que se impongan para el mismo, sino también de las reglas que se hayan fijado en la convocatoria y del alcance que tenga la lista de elegibles, aspectos que se sujetan al ámbito de configuración del Legislador y que excluyen decisiones arbitrarias que carezcan de un fin válido, lo que no ocurre en el presente caso. // (...) Por último, también cabe puntualizar que el sistema de carrera y la superación del concurso público son las formas que, por excelencia, permiten acreditar el mérito para el ejercicio de un cargo. Sin embargo, ello no conduce a que se entienda que el mérito es exclusivo de dichos mecanismos y que otras de formas de vinculación a la función pública son ajenas a la carga de acreditar las calidades y capacidades necesarias para el desarrollo de las atribuciones propias de un empleo. Por ello, aun cuando es deber del Estado y de todas sus entidades adoptar las medidas necesarias para llevar a cabo los concursos que permitan ocupar todos los cargos de carrera administrativa, a fin de cristalizar de forma plena el principio del mérito, mientras ello ocurre, no puede entenderse que existe un privilegio hacia la provisionalidad o el encargo, y que esas figuras pueden utilizarse sin ningún control, ya que, como lo advirtió este tribunal en la sentencia C-102 de 2022, dichas formas extraordinarias de proveer vacantes exigen el deber de motivar los actos de vinculación, y en virtud de las justificaciones que allí se plasmen, valorar el mérito de las personas para estar en los cargos que ocupan”.

13. En suma, aun aplicando un juicio estricto de proporcionalidad, y en concordancia con los precedentes jurisprudenciales sobre la materia, así como con una lectura integral del precepto demandado, la Corte debió haber declarado la constitucionalidad de la disposición acusada. No me cabe duda de que esta decisión seguramente generará un escenario de conflictividad en sede administrativa, contenciosa administrativa y de tutela, a partir de quienes reclaman un mejor derecho, y de un sinnúmero de empleados públicos que, al no ver su cargo en la convocatoria, no tomaron la decisión de participar en los concursos, respecto de los cuales, ahora, se extiende la aplicación de las listas. De ahí que en el fondo queda un importante interrogante, y es si estos efectos no debieron ser examinados por la Corte, por ejemplo, en línea con el mandato de la igualdad de oportunidades, la confianza legítima y la buena fe.

Fecha ut supra,

MIGUEL POLO ROSERO
Magistrado